

القضاء الإداري والدستوري

إعداد

دكتور

محمد عبد الله مغازي
أستاذ القانون العام
كلية الشريعة والقانون
بدمنهور - جامعة الأزهر

دكتور

فؤاد محمد النادى
أستاذ القانون العام
كلية الشريعة والقانون
بالقاهرة جامعة الأزهر

دكتور

أحمد عبد الحسيب السنتريسي
أستاذ ورئيس قسم القانون العام
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
جامعة الأزهر

الجزء الأول
مبدأ المشروعية
وتنظيم مجلس الدولة

أ.د/ فؤاد محمد النادى
أستاذ القانون العام
بكلية الشريعة والقانون
بالقاهرة - جامعة الأزهر

الباب الأول مبدأ المشروعية

تمهيد: يعد مبدأ المشروعية من أهم الضمانات الأساسية لحقوق وحرريات الأفراد إن لم يكن أهمها جميعاً.

وتبدو أهمية هذا المبدأ في اعتباره أساس فرض الرقابة على أعمال الإدارة لضمان التزامها بأحكام القانون. وهذا ما حرصت السلطة التأسيسية التي قامت على إعداد الدستور الحالي على تأكيده في وثيقة إعلان الدستور فقررت: "أن سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت".

كما أكد الدستور في المادة (٦٤) منه على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتتزايد أهمية مبدأ المشروعية نظراً لتزايد دور الدولة في الوقت الحاضر وزيادة تدخلها في حياة الأفراد.

ورغم حالات الخصخصة التي نفذتها الدولة إلا أنها لا تزال لها السيطرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية بما يؤثر على حقوق الأفراد وحررياتهم وحاجتهم المستمرة للحماية في مواجهة السلطات الحاكمة في الدولة. كما تبدو أهمية المبدأ في أنه يقوم بنوع من الموازنة بين مطلبين متعارضين وهما حرية الأفراد وفاعلية الإدارة.

ذلك أن القاعدة القانونية وهي تضع حداً لنشاط الإدارة فإنها تعمل كمحرك لنشاطها لأنها تجعل كل عامل مختص بعمل معين في الإدارة ذا صفة في القيام بهذا العمل وتمنحه السلطة اللازمة لتحقيق الهدف المبتغى من وظيفته.

ولقد استقر الرأي في معظم الدول الديمقراطية أن تنظيم الحريات لا يكون إلا بقانون ومن المتصور أن يتم المساس بأي من هذه الحريات ولذا كان تقرير مبدأ المشروعية بمعنى الخضوع للقانون - أكبر ضماناً لحماية هذه الحريات.

ونتناول مبدأ المشروعية في الشرائع الوضعية في فصول أربعة:

الفصل الأول: مضمون مبدأ المشروعية. الفصل الثاني: مصادر المشروعية.

الفصل الثالث: حدود مبدأ المشروعية. الفصل الرابع: أعمال مبدأ المشروعية

وصور الرقابة على مشروعية أعمال الإدارة.

الفصل الأول مضمون مبدأ المشروعية Le principe de la légalité

فى هذا الفصل نتناول فى مبحثين:

- تحديد مضمون مبدأ المشروعية.
- نطاق مبدأ المشروعية.

المبحث الأول مضمون مبدأ المشروعية

لم تعرف النظم السياسية مبدأ المشروعية خلال الفترات التي اختلطت فيها الدولة بشخصية الحاكم.

ففي العصور القديمة والوسطى حيث سادت النظريات الثيوقراطية (الحق الإلهي المباشر والحق الإلهي غير المباشر) لم يكن يتصور الحديث عن مبدأ المشروعية. فالحكم المطلق لا يعترف للمحكومين بأي حقوق قبل الحكام، ولا يقبل الحكام الخضوع لأي قانون، ولا يقبلون المساءلة أمام أي من البشر.

أما في الدولة القانونية فإن جميع تصرفات السلطات العامة والأفراد داخل الدولة تخضع للقانون وهو ما أطلق عليه مبدأ المشروعية سواء كان التصرف إيجابياً يقتضي القيام بإجراء معين أو مزاولة نشاط معين أو كان التصرف سلبياً يتمثل في الامتناع عن القيام بعمل معين. ويقصد بالقانون هنا القانون بالمعنى الواسع، أي كافة القواعد القانونية الملزمة مكتوبة (كالدستور والقانون واللائحة) أو غير مكتوبة (كالعرف والمبادئ العامة للقانون).

ومبدأ المشروعية على هذا النحو لا يقتصر على الدول الديمقراطية وإنما يطبق أيما كان شكل الدولة ولو كانت الدولة دكتاتورية طالما كان هناك التزام بأحكام القانون، أما إذا أهدر مبدأ المشروعية كانت الدولة بوليسية.^(١)

^١ - أستاذنا الدكتور/ سليمان الطماوي، الوجيز في القضاء الإداري، ١٩٧٠، ص ١٤.

فالخضوع لأحكام القانون هو أهم ما يميز الدولة القانونية عن الدولة البوليسية^(١). وقد بدأت الدولة القانونية في الظهور مع بداية اعتناق النظريات التي ترجع السيادة للأمة أو الشعب واعترف فيها للمحكومين بدور في اختيار الحكام، وألزم الحكام أنفسهم باحترام حقوق وحرريات المحكومين إلا أن الجدير بالذكر أن وصف الدولة بالقانونية ليس شعاراً يردد ولا لافتة ترفع ليتستر وراءها الاستبداد والطغيان، إنما هو التزام وتقيد بحكم القانون المطبق، فالقانون متى وضع بشروطه يجب أن يلتزم به حتى يلغي أو يتم تعديله.

وإذا كان المقصود بمبدأ المشروعية هو خضوع الجميع حكماً ومحكومين لأحكام القانون، إلا أن هذا المعنى أطلقت عليه عدة مصطلحات أبرزها مبدأ المشروعية، مبدأ الشرعية، مبدأ الخضوع للقانون، إلا أن الفقه يكاد يجمع على تعريفه بأنه "سيادة حكم القانون"^(٢).

ورغم شيوع اصطلاح سيادة القانون كتفسير لمبدأ المشروعية، إلا أن بعض الفقه قد اعترض على استخدام هذا الاصطلاح لما له من مدلول خاص في وصف الدولة كاملة الاستقلال بأنها "ذات سيادة"^(٣).

كما انتقد بعض الفقه اصطلاح مبدأ المشروعية بأنه "اصطلاح غير موفق ولا يدل مبناه على معناه" ويقترح بدلاً عنه اصطلاح سيطرة أحكام القانون^(٤). بينما اختار بعض الفقه اصطلاح مبدأ الشرعية وبين أن المقصود به مبدأ الخضوع للقانون^(٥).

^١ - الأستاذة الدكتورة سعاد الشرقاوي، المنازعات الإدارية، ١٩٧٦، ص ٧٠-٧١، وتشير سيادتها إلى أن التحول من الدولة البوليسية إلى الدولة القانونية يعتبر دليلاً على تقدم الدولة وحضارتها ووعيتها

- G. vedel: La soumission de l'administration à la loi. Le Carie 1952.

- مشار إليه في هامش المرجع السابق، ص ٧٠.

^٢ - على سبيل المثال: الأستاذ الدكتور / محسن خليل، مبدأ المشروعية وتنظيم القضاء الإداري، ١٩٩٣، ص ٧ الأستاذ الدكتور محمود حلمي، المرجع السابق، استاذنا الدكتور / سامي جمال الدين، الرقابة على أعمال الإدارة، ١٩٩٢، ص ١٠. استاذنا الدكتور العميد سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص ١٣.

^٣ - الأستاذ الدكتور / أنور رسلان، وسيط القضاء الإداري، الكتاب الأول، المشروعية والرقابة القضائية، ١٩٩٧، ص ١٥.

^٤ - الأستاذ الدكتور / عبد الحميد متولى، الحريات العامة، ١٩٧٥، ص ٨٩-٨٨،

^٥ - الأستاذ الدكتور / محمود حافظ، القضاء الإداري (دراسة مقارنة)، ط ٣، ١٩٦٦، ص ١٩.

ولقد نبه الدكتور ماجد الحلو الى ضرورة التفرقة بين اصطلاح المشروعية (Legalité) ويعنى احترام قواعد القانون القائمة فعلا في المجتمع، واصطلاح الشرعية (Ligitimité) وهي فكرة مثالية تحمل في طياتها معنى العدالة وما يجب أن يكون عليه القانون (١).

وعلى العكس من ذلك تماماً يرى بعض الفقه أن التعبيرين مترادفان ولا مجال للتفرقة بينهما حيث أن مبدأ المشروعية "يعنى احترام الأفكار المثالية التي تحمل في طياتها معنى العدالة، ويعني احترام قواعد المشروعية الوضعية" (٢).

ونحن نرى بضرورة التفرقة التي ذهب اليها الدكتور/ ماجد الحلو حيث يلاحظ أن السلطة في كثير من البلدان تسيطر على الأداة التشريعية في غياب الديمقراطية الحقيقية وتتمرر من القوانين ما تشاء بما يخدم أغراضها ولو تعارض مع مصالح المحكومين، كما أن البرلمانات توافق على القوانين التي تخدم مصالح أغلبية أعضائها (٣).

ولكن تلك التفرقة لا تتعارض مع تفسير عبارة "مبدأ المشروعية" بأنها "سيادة حكم القانون" بل ومع إمكانية القول باندماجها معاً.

وقد أكدت وثيقة إعلان الدستور الحالي الصادر ٢٠١٤ على مبدأ سيادة القانون باعتباره ضماناً مطلوباً لحرية الفرد وباعتباره كذلك الأساس الوحيد لمشروعية السلطة.

الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع: وهذا ما نصت عليه المادة (٢)

من دستور ١٩٧١ بعد تعديلها عام ١٩٨٠، والدساتير المصرية التالية له والجدير بالذكر هنا أنه في ظل المشروعية الإسلامية فإن الدستور يتقيد بمبادئ الشريعة الإسلامية فهي التي تشكل المشروعية العليا التي يتقيد بها واضعوا الدستور.

١ - الدكتور / ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، ١٩٨٥، ص ١٩.

٢ - الأستاذ الدكتور محمد أنس قاسم جعفر، المرجع السابق، هامش ص ٩.

٣ - ولقد ذهب الدكتور/ أنور رسلان الى عدم التمييز بين اصطلاحي الشرعية والمشروعية إذا التزمت الدولة بكل من المبادئ القانونية العامة والمبادئ القانونية الوضعية على حد سواء، أما إذا انحرفت السلطة التشريعية ولم تلتزم بالمساواة التامة بين جميع الأفراد فمن الأفضل في رأى سيادته - الأخذ بالتفرقة بين الشرعية والمشروعية (المرجع السابق، ص ١٨-١٧).

ومن ثم فلا يمكن التسليم بما ذهب اليه بعض الفقه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مجموعة من المبادئ العامة للقانون تتمتع بقوة الزامية تعلق التشريع في تدرج القواعد القانونية وإن لم تصل الى مرتبة الدستور...^(١) ولا يمكن الاستناد في هذا الصدد الى نص المادة (٢) المعدل من الدستور والذي اعتبر مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع^(٢). ذلك أن نصوص الدستور إن هي إلا نوع من أنواع التشريع التي يجب أن يكون مصدرها الرئيسي مبادئ الشريعة الإسلامية.

ومن جانب آخر فإننا نتفق مع الرأي السابق في سريان التعديل الدستوري للمادة الثانية من الدستور في ١٩٨٠/٥/٢٢ سواء بالنسبة للتشريعات اللاحقة على التعديل أو تلك السابقة عليه وذلك بضرورة مطابقتها لمبادئ الشريعة الإسلامية وإلا كانت باطلة لمخالفتها نصوص الدستور، مخالفين في ذلك ما انتهت اليه المحكمة الدستورية العليا في ١٩٨٥/٥/٤^(٣). ونضيف الى الحجج التي ساقها هذا الرأي في اعتراضه على حكم المحكمة الدستورية العليا ما تعتقد أنه يستفاد من نص الدستور ان دين الدولة الإسلام، فلا يمكن الاعتراف لدولة ما أنها دولة إسلامية وهي لا تطبق مبادئ الشريعة الإسلامية ولا تضعها في المكان اللائق بها في تدرج القواعد القانونية^(٤).

^١ - الدكتور/ سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص ١٠٨.
^٢ - كان النص قبل التعديل أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع، وقد تمت الموافقة على التعديل وسريانه اعتباراً من ١٩٨٠/٥/٢٢.
^٣ - حكم المحكمة الدستورية العليا في ١٩٨٥/٥/٤ في الدعوة رقم ٢٠ لسنة (١) ق دستورية و (٧) لسنة (٩) ق عليا دستورية، الجريدة الرسمية، العدد (٢٠) بتاريخ ١٩٨٥/٥/١٦. ص ٩٧٧-٩٨٨.
- حيث ورد بالحكم أن "إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع على ما سلف بيانه لا ينصرف سوى الى التشريعات التي تصدر التاريخ الذي فرض فيه الإلزام ... أما التشريعات السابقة على ذلك فلا يتأتى إبعاد حكم الإلزام المشار اليه بالنسبة لها لصدورها فعلاً من قبله، أي في وقت لم يكن القيد المتضمن هذا الإلزام قائماً واجب الأعمال، ومن ثم فإن هذه التشريعات تكون بمنأى عن أعمال هذا القيد، وهو مناط الرقابة الدستورية..."
وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها (في ١٩٨٢/٤/٣) إلى رأي مماثل فقضت بأنه "إلى أن ينبثق النظام التشريعي الكامل (المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية) ويستكمل قوته الملزمة فإن التشريعات السابقة في الوقت الحاضر تظل نافذة، بحيث يتعين على المحاكم تطبيقها توصلاً للفصل في المنازعات التي ترفع إليها."
^٤ - راجع أيضاً الأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي الذي لا يرى الاكتفاء بالقول بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وإنما يجب أن تعلن قيام المجتمع الإسلامي فوراً مجتمع تظله الشريعة الإسلامية من الله إلى بانه (الدستور المصري ورقابة دستورية القوانين، منه).

والحقيقة أن الرأي الذي قال بعدم سريان تعديل المادة (٢) من الدستور على التشريعات السارية وقت التعديل قد استند على عدة حجج واهية لا يمكن قبولها ويمكن تلخيصها والرد عليها فيما يلي (١).

أولاً: أدلة الرأي القائل بعدم نفاذ مبادئ الشريعة الإسلامية على التشريعات السابقة على التعديل:

أ- أن المشرع الدستوري لو كان قد أراد أن يرتب البطلان أو الإلغاء بالنسبة للتشريعات القائمة وقت سريان التعديل في حالة مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية لكان قد نص على ذلك، فلعله لم يشأ ذلك لأن القول بالإلغاء سيحدث هزة عنيفة في البنيان القانوني في البلاد.

ب- أن القول ببطلان التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية والمطبقة وقت سريان التعديل يتعارض مع روح التشريع الإسلامي والتي تتسم بالاعتدال وسنة التدرج وتراعى الضرورة ورفع الحرج.

ج- أن نفاذ مبادئ الشريعة الإسلامية على التشريعات السابقة من شأنه المساس بمبدأ الفصل بين السلطات.

ثانياً: الرد على هذه الأدلة:

أ- أن من خواص النصوص الدستورية أن ترد مجملة في عبارات مقتضبة ولا تتناول بيان حالات التطبيق أو عدم التطبيق وإنما هذا محله تفسير النصوص والذي يتولاه الفقه والقضاء وفقاً لقواعد معمول بها. كما أنه ليس هناك أي دليل على أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على التشريعات السارية وقت التعديل سيتربط عليه هزة في البنيان القانوني بل ثبت عكس ذلك.

ب- أن هذه الحجة فيها تناقض واضح، فإذا كانت روح التشريع الإسلامي تتسم بالاعتدال ومراعاة التدرج والضرورة ورفع الحرج فلماذا الخوف إذا من تطبيقه بأثر فوري.

١ - راجع في عرض هذه الأدلة بالتفصيل والرد عليها، الدكتور سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص ١٠٤-١٠٨.

ج- لا يجوز إقحام مبدأ الفصل بين السلطات هنا، رقابة دستورية القوانين معترف بها قانوناً منذ زمن بعيد ولم يقل أحد أن في ممارسة هذه الرقابة مساس بمبدأ الفصل بين السلطات.

المبحث الثاني

نطاق مبدأ المشروعية ومدى خضوع الإدارة لهذا المبدأ

المطلب الأول

نطاق مبدأ المشروعية

نطاق المبدأ: ذكرنا أن المشروعية تعنى سيادة حكم القانون بمعنى خضوع الجميع حكماً ومحكومين لأحكام القانون. فما هو المدى الذي تصل إليه سيادة حكم القانون أو الخضوع للقانون (١).

بداية فالمقصود بالقانون هذا القانون بمعناه الواسع أي كافة القواعد القانونية السارية أي كان مصدرها مكتوبة أو غير مكتوبة على النحو الذي سنتناوله تفصيلاً في مصادر المشروعية.

والمقصود بالمحكومين هنا جميع الأفراد دون تفرقة بينهم بسبب جنس أو لون أو عقيدة أو وضع إجتماعي أو اقتصادي. ومن جهة أخرى يقتضي المبدأ خضوع السلطات المختلفة التشريعية والتنفيذية والقضائية لأحكام القانون.

فتلتزم السلطة التشريعية بأحكام الدستور والمبادئ العامة للقانون، كما أنها تلتزم بقيود أهمها أن يكون رائدها الأول هو المصلحة العامة باعتبار أنها الهدف الذي يجب أن يحكم تصرفات كافة السلطات العامة في الدولة (٢).

١ - في بيان مدى سيادة القانون أوضح الدكتور/ سامي جمال الدين عدة حقائق نذكر منها:
- يستبعد أن تعنى سيادة القانون مجرد فرض النظام واستتباب الأمن لأنه يحصر سيادة القانون في نطاق السلطة البوليسية بالإضافة الى تبرير وجودها".

- لا يكفي لتحقيق سيادة القانون خضوع الإدارة فعلاً للقانون، حيث ستصبح الحقوق الفردية "مرهونة بإرادة ومشينة المشرع... لأن القانون إذا توافرت شروطه الشكلية سيكون واجب الاحترام بغض النظر عن مضمونه، وبالتالي تكون الحماية (المقررة) للفرد في مواجهة الإدارة بالزام الأخيرة للخضوع للقانون هي حماية مشروطة بما يتضمنه القانون نفسه من قواعد"، المرجع السابق، ص ١١ وما بعدها.

٢ - والجدير بالذكر أن السلطة التشريعية تلتزم بالقوانين التي تضعها طالما أنها قائمة لم يصيها التعديل أو الإلغاء، راجع في ذلك: الأستاذ الدكتور / محمود حافظ، المرجع السابق، ص ١٢٠

أما السلطة القضائية فإنها مطالبة بتطبيق أحكام القانون على المنازعات التي تفصل فيها وذلك بحكم عملها. أما السلطة التنفيذية فهي مطالبة أكثر من غيرها باحترام أحكام القانون وذلك للأسباب الآتية:

١- أن الإدارة تكون اعمالها عرضة للتحيز والتعسف لصدورها غالبا من موظف فرد على عكس السلطة التشريعية فإنها تقوم على سن القوانين والتي تتضمن قواعد قانونية تتسم بالعموم والتجريد وبالتالي لا تكون عرضة للتحيز أو الانحراف. كما أن السلطة القضائية قد وضع القانون من الضمانات ما يكفل استقلالها.

٢- أن الإدارة هي التي تتولى تنفيذ الإجراءات الماسة بحقوق الأفراد وحياتهم، ويكون اتصالها المباشر بالأفراد ذوي الشأن فتكون فرصة رجال الإدارة أكبر للتأثر بالاعتبارات الشخصية وبالتالي تكون الحاجة أكثر لضمانات المشروعية.

٣- يحتاج الأفراد الى حماية جدية في مواجهة تصرفات الإدارة التي تتمتع بصدها بسلطة تقديرية واسعة.

المطلب الثاني **مدى خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية**

مقتضى مبدأ المشروعية كما رأينا أن تلتزم الإدارة بمجموعة من القواعد القانونية التي تتحقق معها أفضل حماية لحقوق الأفراد وحياتهم.

ولقد اختلف الفقهاء في مدى خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية، فوجدت ثلاثة آراء فقهية متباينة يمكن إجمالها فيما يلي (١):

الرأي الأول: ألا تقوم الإدارة بأي عمل مخالف للقانون:

ومقتضى هذا الرأي أنه لا يجوز للإدارة أن تأتي عملاً (قانونياً أو مادياً) مخالفاً للقانون. فالممنوع على الإدارة وفقاً لهذا الرأي أن تأتي عملاً مخالفاً للقواعد القانونية السارية، ولذا فإنه يعد أكثر الآراء تساهلاً حيث يمنح الإدارة فيمنحها حرية واسعة

^١ - الأستاذ الدكتور أنور رسلان، المرجع السابق، ص ٢١-١٩. الأستاذ الدكتور/ محمود حافظ، المرجع السابق، ص ٢٢-٢١

في التصرف فتكون كل أعمالها مشروعة طالما أنها لم تخالف حكماً من أحكام القانون.

الرأي الثاني: أن يستند عمل الإدارة الى القانون:

ومقتضى هذا الرأي أن تستند الإدارة في كل عمل تأتيه الى أساس من القانون، فلا يكفيها عدم مخالفة القانون - كما هو في الرأي الأول وإنما يجب فوق ذلك حتى يكون عملها مشروعاً أن يستند الى قاعدة قانونية تجيزه (سواء كانت قاعدة مكتوبة أو غير مكتوبة) وهذا الرأي يضيق حرية الإدارة في التصرف ببعض الشئ عن الرأي الأول، وبالتالي يفسر مبدأ المشروعية تفسيراً واسعاً.

الرأي الثالث: أن يكون عمل الإدارة مجرد تطبيق لقاعدة قانونية قائمة:

يضيق هذا الرأي الى حد كبير سلطة الإدارة في التصرف ويوسع الى أقصى حد مبدأ المشروعية، بحيث يجعل الإدارة مجرد أداة لتنفيذ القانون. فلا يعتبر تصرف الإدارة مشروعاً - وفقاً لهذا الرأي - إلا إذا كان تنفيذاً لقاعدة قانونية سارية.

ويلاحظ أنه لا يمكن إعمال الرأي الثالث بأي حال من الأحوال ذلك أنه يلغي السلطة التقديرية للإدارة تماماً ويجعل تصرفها منوط بوجود قاعدة قانونية تسمح لها بالتدخل، وهذا يكبل الإدارة ويعوقها عن أداء واجباتها الأساسية في اشباع حاجات المواطنين فوق أنه يتعارض مع نصوص القانون في كل من فرنسا ومصر والتي تسمح للإدارة بإصدار اللوائح بمختلف أنواعها (ومنها اللوائح المستقلة).

ونرى أنه يمكن إعمال الرأيين الأول والثاني معا في آن واحد فهما ليسا متعارضان وإنما متكاملان ومقتضى اعمالهما معا أن يكون لمدلول خضوع الإدارة للقانون جانبين:

الأول: ألا تقوم بعمل مخالف للقانون: وهذا قيد سلبي يرد على تصرفات الإدارة.

الثاني: أن يكون عمل الادارة دوما مستندا الى القانون.

وغنى عن البيان ان المقصود بالقانون هنا كافة القواعد القانونية أياً كان مصدرها سواء كان نصا مكتوباً (تشريعاً أساسياً أو عادياً أو فرعياً) أو قاعدة عرفية أو مبدأ قانونياً عاماً.

الفصل الثاني

مصادر المشروعية

إذا كان مبدأ المشروعية يعني خضوع الجميع حكماً ومحكومين لأحكام القانون، والقانون كما ذكرنا يؤخذ بمعناه العام أي كافة القواعد القانونية التي يتكون منها النظام القانوني أيّاً كان مصدرها وأياً كان شكلها سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة وأياً كان تدرجها على سلم تدرج القواعد القانونية.

والقواعد القانونية قد تكون مكتوبة، وهذه القواعد المكتوبة تتعدد بحسب مصدرها:

- فقد تصدر عن السلطة التأسيسية التي من حقها وضع الدستور.

- وقد تصدر عن السلطة التشريعية "البرلمان" وهي القوانين.

- وقد تصدر عن الإدارة نفسها وهي اللوائح بأنواعها المختلفة.

كما قد توجد قواعد قانونية في بعض الدول تجد مصدرها في المواثيق وإعلانات الحقوق ومقومات الدساتير. أما القواعد غير المكتوبة فتجد مصدرها في العرف أو المبادئ العامة للقانون كما أنه نظراً لاختلاف السلطات أو الهيئات التي قامت بوضع القواعد القانونية المختلفة فإنه يحتمل حدوث تعارض فيما بينها لذا لزم الحديث عن تدرج القواعد القانونية.

وعلى ذلك فإن تناولنا لهذا الفصل سيكون في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: المصادر المكتوبة.

المبحث الثاني: المصادر غير المكتوبة.

المبحث الثالث: تدرج القواعد القانونية.

المبحث الأول

المصادر المكتوبة

تتميز القواعد المكتوبة بأنها تعد تعبيراً صريحاً عن الإرادة العامة للأمة بينما تعد القواعد غير المكتوبة تعبيراً ضمناً عن هذه الإرادة. وتتمثل هذه القواعد في المواثيق وإعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير والتشريعات الدستورية، وفي التشريعات العادية التي تقرها السلطة التشريعية ثم التشريعات الفرعية (أي اللوائح) ونتناول كل منها في مطلب مستقل، ثم نتناول الرقابة على دستورية القوانين.

المطلب الأول

المواثيق وإعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير

يحدث في بعض الدول وعقب التحولات الكبرى لديها أن تضع وثيقة تضمنها المبادئ العامة والتوجيهات الأساسية للمجتمع وأيديولوجية المرحلة القادمة. وهذا بالفعل ما حدث في مصر بإصدار ميثاق العمل الوطني في عام ١٩٦٢ وبيان ٣٠ مارس ١٩٦٨.

ومثال ذلك أيضاً ميثاق الجزائر عام ١٩٧٦ والعهد الاعظم في إنجلترا عام ١٢١٥ ووثيقة الحقوق عام ١٦٨٩ وإعلان حقوق الإنسان والمواطنين في فرنسا عام ١٧٨٩ والتي صاغ منها رجال الثورة الفرنسية الفلسفة السياسية للثورة ومبادئها واعتمدت مقدمة للدستور الفرنسي الصادر عام ١٧٩١ وتمسكت بها كذلك مقدمة دستور ١٩٤٦ كما أعلنت مقدمة الدستور الفرنسي الحالي الصادر عام ١٩٥٨ تمسكها بكل من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر من الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩ ومقدمة دستور ١٩٤٦.

كما تضمن دستور ٢٠١٤ في مقدمته نصاً يقضى بأن يشكل الدستور بديباخته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً وكلاً لا يتجزأ وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة" مما يعنى أن مقدمة الدستور شأنها شأن كافة نصوصه.

ولقد ثار خلاف في الفقه حول التكييف القانوني لهذه المواثيق وإعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير، وما إذا كانت تدخل ضمن القواعد القانونية الملزمة وبالتالي ضمن مصادر المشروعية من عدمه كما أن الفقهاء الذين اعترفوا لها بقيمة قانونية اختلفوا في مكانتها في سلم التدرج القانوني.

وقد برزت عدة اتجاهات فقهية في هذا الصدد:

الاتجاه الأول: أن المبادئ الواردة في هذه المواثيق وإعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير ليس لها أي قيمة قانونية وتخلو من أي قوة الزامية وإنما هي مجرد مبادئ فلسفية وسياسية تعبر عن آمال وطموحات واضعيها، وبالتالي ليس لها الا قيمة أدبية فقط ولا يترتب على إغفالها أي مخالفة لمبدأ المشروعية.

وقد استند هذا الرأي على أن السلطة التأسيسية التي تضع الدستور لو أرادت منح هذه المبادئ قوة قانونية لأدرجتها ضمن مواد الدستور ذاته^(١) ومن ذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٠/١٢/١٩٤٨ ووقعته مصر فإنه كما أكدت المحكمة العليا في مصر من أنه "لا يعدو أن يكون توصية غير ملزمة وليست له قيمة المعاهدات الدولية المصدق عليها"^(٢)

ومن ذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٠/١٢/١٩٤٨ ووقعته مصر فإنه كما أكدت المحكمة العليا في مصر من أنه "لا يعدو أن يكون توصية غير ملزمة وليست له قيمة المعاهدات الدولية المصدق عليها".

الاتجاه الثاني: وهو الرأي الغالب في فرنسا ويذهب الى الاعتراء لهذه المبادئ بالطبيعة القانونية وبالتالي لها قوة ملزمة.

إلا أن هذا الفقه قد انقسم على نفسه بشأن تحديد القوة القانونية لهذه المبادئ وذلك الى عدة آراء:^(٣)

الأول: أن هذه المبادئ تعتبر القانون الأسمى للدولة وتعلو قيمتها القانونية على

قيمة الدستور ذاته: *Valeur super constitutionnelle*

فهي على قمة الهرم القانوني ويجب أن يلتزم بها كل من المشرع الدستوري والمشرع العادي والمشرع اللانحي فهي تعد ملزمة للسلطة التأسيسية التي تتولى وضع الدساتير علاوة على إلزامها للسلطات العامة في الدولة، ويستند هذا الرأي الى أن هذه المبادئ تعد تعبيراً عن الإرادة العليا للجماعة وتتضمن التوجيهات والأسس التي قام عليها الدستور.

^١ - الدكتور ماجد راهد الحلو، القضاء الإداري، ١٩٧٧، ص ١٨.
^٢ - حكم المحكمة العليا في مصر في ١/٣/١٩٧٥، دعوى ٧ لسنة ٢٠٢٠ دستورية، المجموعة - القسم الأول، ١٩٧٧، ص ٢٢٨.

^٣ - الاستاذة الدكتورة/ سعاد الشرفاوي، المنازعات الإدارية، ١٩٧٦، ص ٩٠. الاستاذ الدكتور/ محمود حافظ، المرجع السابق، ص ٢٥. الاستاذ الدكتور/ سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص ٢٣-٢٤. الاستاذ الدكتور/ أنور رسلان، المرجع السابق، ص ٧٨. الاستاذ الدكتور/ محمد أنس قاسم جعفر، المرجع السابق، ص ٣٩.

الثاني: أن هذه المبادئ لها قيمة قانونية تعادل قيمة الدستور فهي تعبر عن ارادة السلطة التأسيسية شأنها شأن القواعد الدستورية الا انها صيغت في شكل اهداف عامة ومثل عليها، وما نصوص الدساتير الا ترجمة لهذه المبادئ والاهداف والمثل في شكل قواعد قانونية، فلذا يلزم أن يتمتع بنفس القيمة القانونية. ويرى أنصار هذا الرأي أن بعض هذه المبادئ غير المحددة يتعذر تطبيقها عملاً، ومع ذلك فهي تعتبر توجيهات وارشادات على المشرع والسلطة التنفيذية تنفيذاً.

وقد استند اصحاب هذا الرأي الى ما نصت عليه دساتير فرنسا ١٧٩١، ١٩٤٦، ١٩٥٨ من اعتبار اعلان حقوق الانسان والمواطن الصادر عام ١٧٨٩ جزءاً لا يتجزأ من القوانين الدستورية، وإلى أن القضاء في الولايات المتحدة الأمريكية في رقابته على دستورية القوانين يبحث مدى موافقتها من عدمه لأحكام الدستور واعلانات الحقوق معاً (١).

الثالث: أن هذه المبادئ لها قيمة القوانين العادية، فهي تتكفل بتنظيم بعض الحقوق ولو أراد واضعوا الدستور منحها القوة القانونية للقواعد الدستورية لنصوا على ذلك.

ومقتضى ذلك أنه يجوز للسلطة التشريعية تعديلها أو الغائها بتشريع عادي بينما السلطة التنفيذية تلتزم بتنفيذها طالما بقيت سارية.

الرابع: ويفرق هذا الرأي -بحق- بين نوعين من المبادئ التي تتضمنها هذه المواثيق ومقدمات الدساتير.

النوع الأول: ما ورد النص عليه في شكل قواعد قانونية قابلة للتطبيق وتكون متضمنة إنشاء مراكز قانونية معينة وتضمنت نصوصاً صريحة بالزاميتها. وهذا النوع من المبادئ تكون له القيمة القانونية لنصوص الدستور في رأى البعض (١) بينما يرى البعض الآخران له قيمة قانونية أعلى من قيمة الدستور (٢). ومثل هذا النوع المادتان ١٠، ١٧ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواطن الصادر عن الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩ حيث تؤكد المادة (١٠) على

١ - الأستاذ الدكتور/ أنور رسلان، المرجع السابق، ص ٧٩.

٢ - الأستاذ الدكتور/ محمود حافظ، المرجع السابق، ص ٢٩.

حرية الرأي والعقيدة بشرط عدم المساس بالنظام العام، بينما تقرر المادة (١٧) أن الملكية الفردية حق مصون مقدس ولا يجوز نزعها الا لضرورة عامة مقرر قانوناً وبشرط تعويض عادل يدفع مقدماً.

النوع الثاني: وهي مبادئ لم يتم صياغتها في شكل قواعد قانونية بل تشكل مجرد قواعد فلسفية أو توجيهات تعبر عن أهداف الدولة ومثلها فلا تشكل قواعد ملزمة بذاتها للسلطات العامة وانما تنتظر من المشرع التدخل لوضع مبادئها موضع التطبيق فيما تصدره من تشريعات، ومن أمثلة ذلك اعلان حق كل مواطن في العمل.

وقد قرر البعض أنه ليس لهذا النوع إلا قوة إلزام أدبية فقط (١) بينما يرى البعض الآخر أن هذه القواعد تحدد معالم التشريع مستقبلاً وعلى المشرع ألا يصدر تشريعاً مخالفاً لأحكامها وإلا عُذ غير دستوري (٢).

أما بالنسبة لميثاق العمل الوطني الذي أقر من قبل المؤتمر العام للقوى الشعبية في مصر وأعلن في ١٩٦٢/٦/٣٠ وقرر المؤتمر والذي يعد بمثابة السلطة التأسيسية له- أن الميثاق يستمد قوته من إرادة الشعب وينزل من الدستور منزلة الأبوة وأن له صفة الإلزام بالنسبة للمواطنين وبالنسبة لأجهزة الدولة.

وبناء على ذلك فقد اعتبر معظم الفقه ان الميثاق يكون ملزماً لواضعي الدستور وأن للميثاق قيمة قانونية أكبر من قيمة الدستور (٣).

بينما فرق البعض بين الناحية الموضوعية حيث اعتبر الميثاق أعلى مرتبة من الدستور، أما من الناحية الشكلية فيتوقف على الجهة التي تتولى وضع الدستور وعرضه على الأمة في استفتاء شعبي فليس هناك ما يمنع من تعديل الميثاق من قبل سلطة مشابهة أو سلطة أعلى من السلطة التي قامت بوضعه (٤).

^١ - الأستاذ الدكتور محمد أنس قاسم جعفر، المرجع السابق، ص ٤١.

^٢ - الأستاذ الدكتور/ محسن خليل، المرجع السابق، ص ١٥.

^٣ - الأستاذ الدكتور/ أنور رسلان، المرجع السابق، ص ٨٠، الأستاذ الدكتور/ محمد أنس قاسم جعفر، المرجع السابق، ص ٤٢.

^٤ - الأستاذ الدكتور/ محمود حافظ، المرجع السابق، ص ٣٠-٣١.

وبالفعل فقد قرر البعض أن نتيجة الاستفتاء الذي أجرى في مصر في ١٩٧٩/٤/١٩ أكدت وجود إرادة شبه الجماعية على اعتبار الدستور الوثيقة القانونية الوحيدة الملزمة فلم يعد هناك مجال للشك في انتفاء الطابع الالزامي عن ميثاق العمل الوطني.^(١)

بل وقد سبق للبعض أن اعتبر أن نتيجة الاستفتاء الذي أجرى على بيان ٣٠ مارس ١٩٦٨ وموافقة الشعب عليه في ١٩٦٨/٥/٢ جعلت للبيان نفس القوة القانونية للميثاق وأنه عند التعارض تكون الأولوية لمبادي بيان ٣٠ مارس لكونه صدر تاليا للميثاق.^(٢)

بل لقد غالي بعض الفقه في تقرير أهمية بيان ٣٠ مارس واعتبر أن له قيمة قانونية أعلى من الميثاق حيث أنه وافق عليه الشعب في استفتاء عام بينما وافق على الميثاق ممثلوا الشعب^(٣)

والذي نرجحه بشأن المواثيق عموماً ومقدمات الدساتير وإعلانات حقوق الإنسان هو ما ذهب إليه الرأي الرابع السابق الإشارة إليه، مع ملاحظة أن دستور ١٩٧١ قد وافقت عليه أغلبية الشعب في استفتاء ١٩٧١/٩/١١ وكذلك دستور مصر الصادر ٢٠١٤ ولذا فإنهما ألغيا ما يتعارض معهما من مبادئ وردت في الميثاق أو بيان ٣٠ مارس وأصبح دستور ٢٠١٤ يمثل الهرم القانوني في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن المبادئ والأهداف والمثل التي تتضمنها المواثيق ومقدمات الدساتير وإعلانات الحقوق لا تشكل قواعد قانونية ملزمة من الممكن أن تحتوى على كثير من المبادئ العامة للقانون التي يتولى القضاء الكشف عنها وتطبيقها باعتبارها مصراً من مصادر المشروعية ويلغى كل تصرفات الإدارة المخالفة لها^(٤).

^١ - الأستاذ الدكتور/ وهيب عياد سلامة، القضاء الإداري، المجلد الأول، ١٩٨٦، ص ٢٦ وما بعدها.

^٢ - الأستاذ الدكتور/ فؤاد العطار، القضاء الإداري، ١٩٦٨، ص ٢٩-٣٠.

^٣ - الأستاذ الدكتور/ أنور رسلان، المرجع والموضع السابقين.

^٤ - ويذكر الفقه مثلاً لذلك حكم (Brel) الذي قضى فيه مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء قرار الوزير المختص باستبعاد خمسة أشخاص من التقدم المسابقة الإنتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة استناداً على ما ورد بمقدمة دستور ١٩٤٦ من مبدأ قانوني عام مقتضاه أن لكل فرد الحق في تلك الوظيفة العامة ولا يجوز حرمان شخص من

المطلب الثاني **التشريعات الدستورية**

يقصد بالدستور مجموعة القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وتقرر الأسس والأهداف السياسية والإقتصادية والاجتماعية للدولة وتحدد الحقوق والحريات العامة للأفراد وتنظم السلطات العامة في الدولة. والدستور هو التشريع الأساسي أو النظام الأساسي في أي دولة قانونية بحيث لا يتصور قيام دولة قانونية دون أن يكون لها دستور وتعتبر القواعد الدستورية في قمة القواعد القانونية الوضعية بحيث تسمو على غيرها من القواعد، فكل القواعد القانونية الوضعية الأخرى يجب ألا تخرج على الدستور وإلا كانت غير مشروعة وطبق عليها جزاء عدم المشروعية.

وقد قررت محكمة القضاء الإداري منذ البداية بأنه لا يجوز لأى سلطة أن تجاوز النشاط الذي حدده لها الدستور والا كان عملها مخالفا لمبدأ المشروعية. وقضت بناء على ذلك بالغاء القرار الإداري الصادر بإبعاد أحد المواطنين المصريين خلافاً لما نص عليه الدستور.

بل وقررت صراحة بأن الدولة اذا كان لها دستور مكتوب وجب عليها التزامه في تشريعها وقضائها وفيما تمارسه من سلطات إدارية" كما تقرر بأن الدستور حين حدد لكل سلطة من السلطات الثلاث المجال الذي تعمل فيه فقد قرنته بمبدأ آخر أكده ضمناً وجعله ملازماً معه حين قرر أن استعمال السلطات يكون على الوجه المدين بالدستور.

ويلاحظ بالنسبة لإعمال مبدأ سمو الدستور ما يلي:

أولاً: بالنسبة للسلطة التشريعية :

يجب أن تتوافق كافة الأعمال الصادرة عنها مع أحكام الدستور سواء كانت تشريعات أو أعمالاً برلمانية، إلا أن البرلمان له أن يجري بشأنها ما يراه من تعديلات بالحذف أو الاضافة أو الالغاء بنفس الاجراءات المتبعة في سن القوانين. وبالتالي فإن مخالفة

ذلك سبب آرائه ومعتقداته حيث تبين أن قرار الوزير المختص بالاستبعاد قد اتخذ بسبب ما يدين به الأشخاص الخمسة من معتقدات سياسية، راجع في ذلك الاستاذ الدكتور/ محسن خليل، المرجع السابق، ص ١٦.

هذا النوع من الدساتير لا يعد مخالفة لمبدأ المشروعية طالما اتبعت الإجراءات المفروضة التي حددها الدستور. أما بالنسبة للدساتير الجامدة (وهي تلك التي تتطلب اجراءات معينة في تعديلها أو إلغائها) فإن السلطة التشريعية تلتزم باحكامها ومن هذه الدساتير الدستور المصري الصادر سنة ٢٠١٤ .

ثانيا: بالنسبة للسلطة التنفيذية:

لا شك أن السلطة التنفيذية ملزمة بإحترام القواعد الدستورية والقواعد التشريعية في ادائها لعملها تطبيقاً لمبدأ المشروعية.

لكن بعض الفقه لاحظ أن مخالفة السلطة التنفيذية للقواعد الدستورية (وهو ما أطلق عليه عيب عدم الدستورية) هو العيب الأهم والأكثر خطورة ويتمثل في المخالفة المباشرة لقواعد الدستور مثل تلك التي تنظم كيفية ممارسة الإدارة لإختصاصاتها الدستورية وفقاً للشروط والقيود الواردة في الدستور كما هو الحال في اللوائح المستقلة ولوائح الضرورة. ففي هذه الحالات يكون العيب عدم دستورية وليس عدم مشروعية حيث لا يظهر هذا الأخير إلا في حالة مخالفة الإدارة للقانون بصدد اللوائح التنفيذية أو مخالفة الإدارة للمبادئ العامة للقانون (١).

وقد ذهب رأى آخر في الفقه إلى أن مخالفة الإدارة تشكل في الغالب الأعم عيب مشروعية وليس عيب عدم دستورية حيث تخالف الإدارة القانون الذي يكون دائماً بين القاعدة الدستورية والعمل الإداري (٢).

ولاشك لدينا ولا شك لدينا في أن الرأى الأول يصدق بالنسبة لمخالفات الإدارة المباشرة لنصوص الدستور وهي رغم خطورتها حالات قليلة إذا ما قورنت بمخالفات الإدارة للقوانين التي تنظم معظم عمل الإدارة فالرأى الثاني في رأينا يكمل كل منهما الآخر ولا يتعارضان.

(١) الدكتور سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص ٢٧-٢٩

(٢) الدكتور السيد محمد إبراهيم، دستورية القوانين ومشروعية اللوائح، مجلة العلوم الإدارية، ٣٤، ص ١٦٢

المطلب الثالث التشريعات العادية (البرلمانية)

يقصد بالتشريعات العادية القوانين التي تسنها السلطة التشريعية، ووفقاً لمبدأ المشروعية فإن القوانين تأتي في مرتبة تالية للقواعد الدستورية فهي المصدر الثاني للمشروعية نظراً لصدورها عن ممثلي الشعب وتلتزم باحترامها كافة الهيئات العامة في الدولة الى جانب الافراد.

ولا جدال أن الادارة تلتزم عند ممارسة وظيفتها الادارية بمراعاة القوانين التي تتفق وطبيعة هذه الوظيفة وإلا كانت أعمالها غير مشروعة.

ولكن يجوز للإدارة أن تستبعد كل القوانين التي لا تتلاءم وطبيعة عملها الإداري مثل تلك المتعلقة بالقانون الخاص التي لا تتلاءم مع حاجات المرافق العامة^(١) لكن ليس هناك ما يمنع الإدارة من اللجوء باختيارها الى تطبيق بعض وسائل القانون الخاص متخلفة عن وسائل القانون العام، ومن جهة أخرى فإن القوانين يجب الا تخالف موضوعياً أحكام الدستور والا كان القانون غير دستوري.

واستناداً إلى نص المادة ١٦ من الدستور ومفادها أن يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ... وذلك على الوجه المبين بالدستور" فإن مجلس الشعب هو الذي يتولى أصلاً السلطة التشريعية. وأنه يتدخل بتنظيم كافة المسائل التي يقدر هو أهمية تدخله لتنظيمها، فله في هذا الصدد سلطة تقديرية لكن يبدو أن هناك عدة قيود دستورية على سلطة مجلس الشعب في اصدار القوانين منها:

١- أن هناك مسائل منع الدستور التعرض لها مثل:

- تسليم اللاجئين السياسيين.
- ابعاد المواطنين المصريين عن البلاد أو منعهم من العودة اليها.
- تحصين أي أعمال أو قرارات إدارية من رقابة القضاء.

^١ - الدكتور ماجد راهد الحلو، المرجع السابق، ص ١٩.

٢- أن هناك مسائل اشترط الدستور بعض شروط يلزم الأخذ بها عند تنظيمها

مثل:

- المصادرة العامة للأموال.

- الا يكون نزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل مادة (٣٤).

٣- أن هناك مسائل أوجب الدستور تدخل السلطة التشريعية لتنظيمها:

ويستفاد ذلك مثلاً من نص المادة (٩٨) من دستور ٢٠١٤ على أن حق

الدفاع مكفول. ونص المادة (١٥١) من نفس الدستور على أن إنشاء النقابات

والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون (١).

٤ - ينبغي أن يستهدف التشريع المصلحة العامة والا كان باطلاً: كان يكون

استهدف مجلس الشعب من التشريع القضاء على معارضة احزاب الاقلية أو الحد من

فعاليتها، أو قصد تحقيق رغبات الحكومة أو حزب الاغلبية، وخروج السلطة

التشريعية على هدف تحقيق المصلحة العامة يعت بر خروجاً عن وظيفتها المقررة

دستوريا مما يعرض القوانين المخالفة للحكم بعدم الدستورية اعمالاً لمبدأ

المشروعية (٢).

فإذا كان الأصل أن سلطة التشريع عند تنظيم الحقوق سلطة تقديرية وأن الرقابة

القضائية على دستورية التشريعات لا تمتد الى ملاءمة اصدارها، الا أن هذا لا يعني

إطلاق هذه السلطة في سن القوانين دون التقيد بالحدود والضوابط التي نص عليها

الدستور (٣).

^١ - لذا قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية القانون رقم ١٢٥ لسنة ١٩٨١ استناداً الى ان المادة ١٥٦ من الدستور قد قيدت المشرع العادي بألا يتعارض ما يسنه من نصوص تشريعية في شأن النقابات مع مبدأ الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطي (المحكمة الدستورية العليا في ١١/٦/١٩٨٣، قضية رقم ٤٧ لسنة ٣٣ دستورية، المحاماة، س٦٣، العددان ٥-٦، ص ١٧٩)، حكم محكمة القضاء الإداري في ١٩٨٣/٧/٥ قضية رقم ٣٩٤٩ لسنة ٣٧ق، المحاماة، س٦٣، العددان ٥-٦، ص ٢٢٣. حيث استندت الى حكم المحكمة الدستورية العليا السابق لبيان رأيها بشأن عدم دستورية القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة.

^٢ - راجع في تفصيل هذه القيود وموقف المحكمة العليا والمحكمة الدستورية العليا استاذنا الدكتور/ سامي جمال الدين في عرضه القيم للحدود الدستورية للسلطة التشريعية والمراجع والأحكام التي أشار إليها، المرجع السابق، ص ٣١-٣٧.

^٣ - حكم المحكمة الدستورية العليا في ١٩٨٥/٢/٢ في القضية رقم ٦٧ لسنة ٤ق، ج٣، ص ١٢٥. نفس المعنى حكم المحكمة العليا في ١٩٧٦/٧/٣ دعوى رقم ٥ لسنة ٥ق عليا دستورية، المجموعة، القسم الأول، ص ٤١٤.

فالذي تمنعه على نفسها المحكمة الدستورية العليا ومن قبلها المحكمة العليا- مناقشة ملاءمة التشريع أو البواعت التي حملت السلطة التشريعية على اقراره، باعتبار أن ذلك يدخل في صميم السلطة التقديرية للسلطة التشريعية (١) فإذا كانت الملاءمات السياسية متروك تقديرها للسلطة التشريعية الا أن ذلك لا يمنع من اخضاع القوانين التي تقرها للرقابة الدستورية إذا تعرضت لأمر نظمها الدستور ووضع لها ضوابط محدودة. (٢)

وإذا كان لا يمكن الجزم بأن قضاءنا الدستوري يبحث مدى توافر عيب الانحراف في أعمال السلطة التشريعية، إلا أن ذلك لا يمنعه من مناقشة مثل هذه الادعاءات بالانحراف في بعض الأحكام وإن كان توصل الي عدم قيام الدليل على أن القانون المطعون فيه لم يستهدف الصالح العام وإنما صدر بقصد الانتقام والكيد. (٣)

المطلب الرابع

المعاهدات

هذا ويلحق بالتشريعات العادية **المعاهدات** (٤). وهي تعد مصدراً من مصادر المشروعية في الدولة وذلك بعد اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها حيث تصبح جزءاً من القانون الداخلي للدولة وتأخذ نفس القوة القانونية للتشريعات العادية (القوانين). وهذا ما نصت عليه المادة ١٥١ من دستور ٢٠١٤ التي خولت لرئيس الدولة بأن يبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون. ويترتب على ذلك أن الادارة تكون ملزمة في كل تصرفاتها باحترام المعاهدات التي أبرمتها الدولة وتم التصديق عليها ونشرها وإلا كان عملها غير مشروع.

١ - حكم المحكمة العليا في ١٩٧٢/٤/١ دعوى رقم ١١ لسنة اق العليا دستورية وحكمها في ١٩٧٥/٦/٧ دعوى رقم

٢ لسنة ٣ اق العليا دستورية، المجموعة، القسم الأول، رقم ٢٩، ص: ٣١٤

٢ - حكم المحكمة الدستورية العليا في ١٩٨١/٥/١٦ في القضية رقم ٧ لسنة اق، الجزء الأول، ص ١٩٨

٣ - حكم المحكمة العليا في ١٩٧٥/٦/٧ السابق الإشارة اليه.

٤ - وتنص المادة ١٥١ من الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ على أن يدرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويبلغها لمجلس الشعب ويكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية ويجب أن يوافق مجلس الشعب على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والمعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل نفقات الخزنة الدولة.

كما يلتزم الأفراد وكافة السلطات العامة باحترام المعاهدات والنزول على أحكامها، ويترتب على الاعتراف للمعاهدات بنفس قوة التشريعات العادية في تدرج القواعد القانونية ما يلي:

١- إذا أبرمت مصر معاهدة وكانت تخالف أحكامها بعض أحكام القوانين العادية المطبقة، فإن المعاهدة تلغي أحكام القانون المتعارض معها وتصبح أحكام المعاهدة هي النافذة.

٢- إذا صدر تشريع داخلي به بعض الأحكام التي تخالف معاهدة صدقت عليها مصر فإن هذا التشريع يعد ناسخاً للحكم الوارد في المعاهدة بالنسبة لتشريعنا الداخلي. وعلى عكس الحال في مصر، فإن دستور فرنسا ١٩٥٨ قد أعطى المعاهدات قيمة قانونية تعلو على القوانين العادية، ولذا فإنه في حالة تعارض تشريع داخلي في فرنسا مع أحكام معاهدة دولية تكون أحكام المعاهدة هي الواجبة الاتباع، وهذا أمر منطقي إذ لا يمكن للمشرع الداخلي أن يعدل نصوص معاهدة دون الرجوع إلى أطراف المعاهدة الأخرى.

المطلب الخامس

الرقابة على دستورية القوانين

كانت المحاكم العادية ومحاكم مجلس الدولة بعد إنشائه تتصدى للرقابة على دستورية القوانين في مصر ورغم عدم وجود نص في الدساتير السابقة على دستور ١٩٧١ أو القوانين المختلفة قبل سنة (١) ١٩٧٩ إلا أنها كانت تتوقف عند الرقابة السلبية بامتناعها من تطبيق نص القانون في النزاع المعروض عليها إذا تبين لها أنه غير دستوري. (٢)

^١ - اعترفت المحاكم العادية لنفسها في ظل دستور ١٩٢٣ وقبل إنشاء مجلس الدولة بالحق في التصدي لبحث مدى دستورية القوانين مؤكدة أن هذا هو التفسير السليم لمبدأ الفصل بين السلطات.

^٢ - فكانت محكمة القضاء الإداري عندما يتبين لها وجود تعارض بين الدستور والقانون لا تلغى القانون المعارض للدستور طالما لم ينص على ذلك الدستور صراحة، كما أنها لا تطبق القانون المخالف للدستور إعمالاً لمبدأ الشرعية، وإنما كانت كل ما تستطيعه أن تمتنع عن تطبيق القانون غير الدستوري في القضية المعروضة أمامها.

كما قرر مجلس الدولة في هذه الفترة مبدأ إلغاء القرار الإداري إذا أصدرته الإدارة مستندة إلى قانون غير دستوري (١). وبموجب القانون ٨١ لسنة ١٩٦٩ أنشئت المحكمة العليا كأول محكمة في مصر تختص بالفصل في دستورية القوانين إذا ما دفع أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية قانون من القوانين.

وعندما صدر دستور ١٩٧١ أفرد فصلاً خاصاً للمحكمة الدستورية العليا ثم صدر القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ والذي حددت المادة (٢٩) منه حالات الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وحصرتها في إحالة إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا إذا تراءى لها عدم دستورية نص في قانون أو لائحة أو إذا دفع أحد الخصوم أمامها بذلك ووجدت أن الدفع جدي.

ومعنى ذلك أن القانون لا يجيز في مصر رفع دعوى أصلية مبتدأه أمام المحكمة الدستورية العليا بطلب فحص عدم دستورية أحد القوانين.

المطلب السادس **التشريعات الفرعية (اللوائح)**

هي قرارات إدارية تتضمن قواعد عامة مجردة تطبق على عدد غير محدود من الأفراد، ولذا يطلق عليها القرارات الإدارية التنظيمية. وتعتبر اللوائح أعمالاً إدارية وفقاً للمعيار الشكلي أو العضوي (الذي يستند في تكييف طبيعة العمل إلى جهة إصداره).

بينما تعتبر اللوائح أعمالاً تشريعية بالنظر إلى المعيار الموضوعي أو المادي (الذي يعتبر في تكييف طبيعة العمل بالموضوع دون الشكل) فهي تنشئ قواعد عامة مجردة لا تطبق على أشخاص معينين بالذات شأنها في ذلك شأن التشريعات العادية (القوانين).

ومن الناحية العضوية أو الشكلية تتفق اللائحة مع القرار الإداري الفردي في صدورهما من جهة الإدارة، إلا أن اللائحة تعلو القرار الإداري الفردي حته لو كان القرار صادر من سلطة أعلى لأن هذا الأخير يحدث أثراً قانونياً تجاه فرد معين أو

١ - حكمها بتاريخ ١٩٧٥/١٢/٤.

أفراد معينين، ومن ثم وجب على الإدارة أن تصدر قراراتها الفردية موافقة للوائح، والتي هي قرارات عامة مجردة، والا كانت غير مشروعة. أما من الناحية الموضوعية فإن اللوائح تتفق مع القوانين في أن كلاهما يتضمن قواعد عامة مجردة، ولكن نجد القانون أعلى في القوة القانونية من اللائحة وذلك تطبيقاً لمبدأ المشروعية يجب أن تتوافق اللائحة مع القانون والدستور والا كانت غير مشروعة وأمكن الطعن عليها أمام القضاء ما لم تبادر الإدارة بإلغاء اللائحة أو سحبها أو تعديلها لتصحيح العيب الذي شابها. ووفقاً للدستور فإن اللوائح تختص بإصدارها السلطة التنفيذية بينما القانون تختص بإصداره السلطة التشريعية. وفي حديثنا عن التشريعات الفرعية نبين نطاق التشريع لكل من القانون واللائحة في فرنسا ثم نتناول الوضع في مصر كل في فرع مستقل.

الفرع الأول

نطاق التشريع لكل من القانون واللائحة في فرنسا

القاعدة التقليدية هي أن التشريع يكون عن طريق السلطة التشريعية، وأن يكون استثناء وبضوابط معينة بواسطة اللائحة عن طريق السلطة التنفيذية. ومرجع ذلك إلى مبدأ الفصل بين السلطات، والذي دعت الحاجة إليه لمواجهة نظام تركيز السلطات حيث كانت سلطة التشريع سواء بقوانين أو بقرارات بيد الحاكم وكان في ذلك استبداد وتحكم واعتداء على حرمات المواطنين فكانت المناداة بمبدأ الفصل بين السلطات على أنه وسيلة لكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم العامة. وقام فكر مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التمييز بين وظائف ثلاث للدولة: الأولى: التشريع وتسند لبرلمان منتخب يعبر عن ارادة الشعب. الثانية: تنفيذ القوانين واشباع الحاجات العامة للمواطنين وتسند للسلطة التنفيذية.

الثالثة: الفصل في المنازعات بتطبيق حكم القانون عليها وتسند للسلطة القضائية.

واتفق الفكر السياسي على مسألة أساسية وهي أن القانون الذي هو تعبير عن الإرادة العامة تختص به السلطة التشريعية وضعاً وتعديلاً والغاءً.

إلا أنه لما تعذر تطبيق الفصل المطلق بين السلطات فقد لجأ إلى الفصل النسبي بين السلطات وعلى أثره اعترف للسلطة التنفيذية بدور في التشريع في مجالات معينة وبضوابط معينة (١).

وأصبحت القاعدة المتفق عليها في النظم السياسية المعاصرة هي اعطاء سلطة التشريع للبرلمان واعتبار القانون هو الأصل العام في التشريع، وأن يكون التشريع استثناء للسلطة التنفيذية.

وظلت هذه القاعدة إلى أن خرج عليها الدستور الفرنسي الصادر عام ١٩٥٨ (دستور الجمهورية الخامسة) فأثى بقاعدة جديدة مخالفة تقوم على اعتبار اللائحة هي الأصل العام للتشريع وأن مجال القانون هو الاستثناء (٢).

الفرع الثاني

السلطة اللائحية في مصر

النظام التقليدي في العلاقة بين القانون واللائحة هو السائد في معظم النظم الدستورية، فلا يوجد نطاق معين للتشريع حيث يخول البرلمان في هذه النظم سلطة واسعة في سن التشريع في أي مجال من المجالات.

أما بالنسبة لللائحة فلا يوجد نطاق محتجز لها وإنما يمكن أن تصدر بعض اللوائح المستقلة في موضوعات محددة لاعتبارات معينة.

وعلى العكس هناك مجالاً محجوزاً للقانون لا يجوز التشريع فيه باللائحة. ويجوز للبرلمان أن يشرع في أي مجال غير المجالات المحجوزة للقانون باعتباره صاحب الولاية العامة على التشريع حتى في مجالات اللوائح.

١ - راجع في تفصيل ذلك الأستاذ الدكتور/ محسن خليل، المرجع السابق، ص ٢٣. الأستاذ الدكتور/ أنور رسلان، المرجع السابق، ص ٨٥ وما بعدها.

٢ - ولقد تابع الدستور الفرنسي في ذلك الدساتير المغربية الصادرة أعوام ١٩٦٢، ١٩٧٠، ١٩٧٢، والدستور المغربي الحالي سنة ١٩٩٢، كما أخذ بها الدستور الجزائري الصادر ١٩٧٦. راجع الأستاذ الدكتور/ أنور رسلان، المرجع السابق، ص ٨٦.

هذا النظام التقليدي في العلاقة بين القانون واللائحة هو الذي أخذ به الدستور المصري الحالي والدساتير المصرية المتعاقبة وتتلخص فيما يلي:

- أن للبرلمان أن ينظم كافة المسائل التي يرى ضرورة التدخل لتنظيمها حتى في مجال اللائحة.

- حدد الدستور مجالاً محتجزاً للقانون وموضوعات يمكن أن تتدخل فيها السلطة اللائحية.

- يقتصر النطاق المحدد لللائحة وفقاً للدستور على اللوائح التنفيذية (١٧٠) لوائح الضبط (م ١٧٢) لوائح المرافق العامة (م ١٧١) من دستور ٢٠١٤م وبعض هذه المجالات يمكن أن تنظم بقانون .

أنواع اللوائح في النظم التقليدية ومنها مصر:

أولاً - اللوائح التنفيذية: Les rélements d'exécution :

هي التي تصدر عن السلطة التنفيذية بقصد وضع المبادئ التي تضمنها القانون موضع التنفيذ. فهي تبين الخطوات والإجراءات والقواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.

وهي لا يجوز لها إلغاء أو تعديل أو وقف تنفيذ أو تعطيل حكم من أحكام القانون وإن كان يجوز لها أن تتضمن حكماً جديداً له علاقة مباشرة بتنفيذ نصوصه بشرط أن يكون متفقاً مع الأغراض التي من أجلها صدر القانون. وقد نصت عليها المادة ١٤٤ من دستور ١٩٧١م وجعلت الاختصاص بإصدارها إلى رئيس الجمهورية أو من يفوضه في ذلك كما أجازت أن يحدد القانون من يصدر لائحته التنفيذية.

أما بالنسبة لدستور ٢٠١٤م فقد عهد بإصدار اللوائح التنفيذية إلى رئيس مجلس الوزراء، حيث تنص المادة (١٧٠) على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.

ثانياً- اللوائح المستقلة:

وهي اللوائح التي تصدر عن السلطة التنفيذية لتنظيم مسائل معينة لم ينظمها القانون، فهي تصدر في مجال مستقل لم يصدر فيه قانون معين، ولذا فهي لوائح

مستقلة لا ترتبط بقانون. فهي على عكس النوع السابق من اللوائح الذي يصدر تنفيذاً لحكم قانون ما، ومثالها:

أ- لوائح الضبط الإداري وهي تصدر بهدف حماية النظام العام بمدلولاته الثلاثة: الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة، وقد نصت المادة ١٤٥ من الدستور على أن يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط. وقد اشتمل دستور ٢٠١٤م على تعديل هذا الاختصاص حيث عهد به إلى رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء؛ وفي ذلك تنص المادة (١٧٢) على أن: "يصدر رئيس مجلس الوزراء، لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء.

ب- اللوائح التنظيمية: وتتعلق بإنشاء وتنظيم المرافق العامة وقد نصت المادة ١٤٦ من الدستور على أن «يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المصالح العامة». وقد اشتمل دستور ٢٠١٤م على تعديل هذا الاختصاص حيث عهد به إلى رئيس الوزراء؛ وفي ذلك تنص المادة (١٧١) على أن: "يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء.

ثالثاً- اللوائح التفويضية:

وقد خلا دستور ٢٠١٤ من النص عليها ويحمد للمشرع ذلك ومن ثم فلا مجال للإفاضة في هذا الشأن

رابعاً- لوائح الضرورة:

وهي قرارات تصدر من رئيس الجمهورية تكون لها قوة القانون في حالة وجود ضرورة تستدعي إصدارها، وذلك بالشروط الواردة بالدستور وقد نص عليها الدستور في المادة ١٥٦

حيث تنص المادة (١٥٦) من دستور ٢٠١٤ على أنه: "إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها

ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

الحالة الأولى: نصت عليها المادة ١٥٦ من الدستور، وتجيز لرئيس الجمهورية في حالة الضرورة اتخاذ تدابير عاجلة وذلك بالشروط الآتية:

أ- أن يحدث ذلك في حالة غيبة البرلمان سواء لوجوده في العطلة البرلمانية أو لحله أو وقف جلساته طبقا للمادة ١٣٧ من الدستور (ويحدث ذلك في الفترة السابقة على حل المجلس، حيث يصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس ويستفتي الشعب على الحل خلال ٢٠ يوما).

ب- أن توجد حالة ضرورة تتطلب الإسراع في اتخاذ إجراءات عاجلة، وتقدير ذلك موكول لرئيس الجمهورية تحت رقابة مجلس الشعب يمارسها عند عرض القرارات عليه (١).

ج- أن يتم عرض القرارات على مجلس الشعب خلال ١٥ يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما وفي أول اجتماع له إذا كان المجلس متحلا أو أوقفت جلساته.

- وفي حالة عدم العرض فإن القرارات تزول آثارها القانونية بأثر رجعي من تاريخ صدورها.

- أما إذا عرضت على المجلس ووافق عليها فتظل سارية ولها قوة القانون، ولكن تختلف في طبيعتها

- أما إذا عرضت ولم يوافق عليها المجلس زالت آثارها القانونية بأثر رجعي إلا إذا رأى المجلس نفاذ أثرها خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ العرض أو إذا رأى تسوية الآثار التي تترتب عليها منذ صدورها حتى تاريخ عدم الموافقة عليها.

^١ - حدثت حالات كثيرة لإصدار قرارات بقوانين هامة ربما لم تتوافر بشأنها حالة الضرورة الملحة التي اشترطها الدستور ومن ذلك القرار بقانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢م بشأن السلطة القضائية، والقرار بقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢م بشأن مجلس الدولة، والقرار بقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٢م بشأن تنظيم الجامعات.

خامساً - لوائح الخطر أو الأزمات الخاصة:

والتي نصت عليها المادة ٧٤ من دستور ١٩٧١م حيث أجازت لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها للدستور أن يتدخل فوراً ويتخذ الإجراءات السريعة الضرورية لمواجهة هذا الخطر.

وتتميز هذه الحالة عن الحالة الأولى بما يلي:

- ١- أن اللجوء للحالة الأولى مرهون بغيبة البرلمان، أما في هذه الحالة فلا يشترط ذلك فيمكن اتخاذ الإجراءات الواردة فيها والمجلس في حالة انعقاد.
- ٢- أن التدابير التي يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة الأولى تأخذ شكل قرارات بقانون تعرض على مجلس الشعب فيما بعد، أما في الحالة التي نحن بصددتها فإن النص يعطى رئيس الجمهورية سلطة اتخاذ أي إجراءات لازمة لمواجهة الخطر سواء كانت في شكل قرارات أو في أي شكل آخر.
- ٣- على خلاف الحالة الأولى فإن المادة ٧٤ قد حددت مفهوم الضرورة هنا بحالات معينة على درجة من الخطورة، فحصرتها في أمر من الأمور الثلاثة الآتية:
 - أ - تهديد الوحدة الوطنية في البلاد.
 - ب - تهديد سلامة الوطن.
 - ج - إعاقة مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري.وهي حالات من الاتساع بحيث يمكن أن يندرج تحتها كل الاحتمالات التي يرى رئيس الجمهورية التدخل فيها بإجراءات استثنائية.
- ٤ - لم تشر المادة (٧٤) إلى أي دور لمجلس الشعب من قريب أو بعيد وبالتالي فليس له أي سلطة في إقرار هذه الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية كما هو الحال بالنسبة للحالة الأولى وإنما اكتفت المادة (٧٤) بأن يقوم رئيس الجمهورية بتوجيه بيان إلى الشعب، يعقبه استفتاء شعبي على ما اتخذته من إجراءات خلال ٦٠ يوماً من اتخاذها.

وينتقد الفقه نص المادة (٧٤) من الدستور بأنها يمكن أن تغني عنها اللوائح

التفويضية المنصوص عليها في المادة (١٠٨) من الدستور (١) فوق أنها تسمح بإقامة دكتاتورية مؤقتة (٢).

أثر الاستفتاء على الإجراءات التي يتخذها رئيس الجمهورية تطبيقاً للمادة (٧٤) من دستور ١٩٧١:

بداية نقرر بأن الاستفتاء المشار إليه في المادة (٧٤) وإن كان يبدو من الاستفتاءات الموضوعية التي تتعلق بأخذ رأى الشعب في موضوع معين وهو الإجراءات التي يتخذها رئيس الجمهورية في مواجهة الخطر الذي حل بالبلاد، إلا أن لهذا الاستفتاء الموضوعي جانب شخصي يتعلق بشخص رئيس الجمهورية ومدى رضا الشعب عنه ومدى ثقتهم فيه.

وبالنظر لهذا الجانب الشخصي في الاستفتاء فإنه يصبح استفتاءً سياسياً يقصد منه بالدرجة الأولى تأكيد الثقة في شخص رئيس الجمهورية بمناسبة الإجراءات التي اتخذها، ومما يؤكد الطبيعة السياسية لهذا الاستفتاء أن نتيجته ليست ملزمة، فالمادة (٧٤) وإن كانت جعلت إجراء الاستفتاء إلزامياً خلال ٣٠ يوماً من القيام بالإجراءات إلا أنها لم تجعل نتيجته وجوبية.

ويترتب على الاعتراف بالصفة السياسية للاستفتاء أنه لا أثر له على الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية فلا يعتبر تصديقاً على النحو السابق بيانه بالنسبة للوائح التفويضية ولا يترتب عليه تغييراً في طبيعته ولا حالته من المشروعية أو عدم المشروعية (٣).

فدور الشعب في الاستفتاء دور سىاسى محض فلا يغير من الطبيعة اللائحية لهذه القرارات ولا يطيرونها من العيوب، كما أن هذا الدور السياسى للشعب في الاستفتاء

١ - استاذنا الدكتور العميد/ سليمان الطماوى، النظرية العامة للقرارات الإدارية، ١٩٦٧م، ص ٣٧.

٢ - الأستاذ الدكتور/ مصطفى أبو زيد فهمي، الدستور المصرى ورقاية دستورية القوانين، ١٩٨٥م، ص ٤٠٩.

٣ - حكم محكمة القضاء الإداري في ١٢/٤/١٩٨٣م في الدعوى ٩٣٤، ص ٣٦، وعلى العكس يرى أستاذنا الدكتور/ سليمان الطماوي أنه يتوقف على نتيجة الاستفتاء مدى شرعية هذه الإجراءات فإذا وافق عليها تحولت إجراءات شرعية بحسب طبيعتها ... باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات ولا معقب على رأيه .. النظرية العامة للقرارات الإدارية ١٩٧٦م، ص ٦٣ ومابعدها. (

لا ينقلب إلى دور تشريعي لأن الشعب في مصر لا يمارس حقه في التشريع مباشرة، وإنما بواسطة السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية في بعض الأحوال^(١)

من حيث القوة القانونية للوائح الضرورة:

في الأحوال العادية: تحتفظ اللوائح التفويضية بقوة اللائحة وهي تلى مرتبة القانون في تدرج القواعد القانونية.

في الظروف الاستثنائية: تكون للوائح ذات مرتبة القوانين.

أما من حيث الطبيعة القانونية:

فإن اللوائح أيا كان نوعها (تفويضية أو ضرورية) فإنها تظل في جميع الأحوال ذات طبيعة لائحة ولا تنقلب إلى قانون حتى ولو تدخلت السلطة التأسيسية فوافقت عليها من خلال استفتاء شعبي أو تدخل السلطة التشريعية وأقرتها بالتصديق عليها وإقرارها، ففي جميع هذه الأحوال تبقى أعمالاً إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري. ويلاحظ أن دستور ٢٠١٤ أسقط من نصوصه اللوائح التفويضية المنصوص عليها في المادة ١٠٨ من دستور ١٩٧١ وكذلك لوائح الخطر المنصوص عليها في المادة ٧٤ من ذات الدستور.

مدى خضوع اللوائح لمبدأ المشروعية

تخضع اللوائح بكافة أنواعها وأيا كان مصدرها لمبدأ المشروعية، فلا يجوز للوائح أن تخالف نصوص القانون أو الدستور.

ويمارس مجلس الدولة على اللوائح رقابة قضائية عندما يثار في منازعة مطروحة مدى مخالفة اللائحة لنص من النصوص القانونية.

بينما تراقب المحكمة الدستورية العليا مدى دستورية اللوائح شأنها شأن القوانين وذلك إعمالاً للنص الصريح للمادة (٢٥) من قانون إنشائها رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩م^(٢).

^١ - حكم محكمة القضاء الإداري في ١٢/١٢/١٩٨١م في الدعوى رقم ٢١٢٣ لمسلة ٣٥ق.
^٢ - وقبل إنشاء المحكمة الدستورية العليا سبق للمحكمة العليا مدت اختصاصها رقابة مدى دستورية اللوائح دون نص وقد كان ذلك محل الفقه. (راجع الأستاذ الدكتور محمود عاطف البناء الرقابة القضائية على بمجلة القانون والاقتصاد العدد ١، ٢ بتاريخ ١٩٧٨م، ص الأستاذ الدكتور المرجع السابق، ص ٦٠).

وتتدرج القرارات الإدارية فيما بينها بحسب المعيار الشكلي فتخضع القرارات الصادرة من عضو السلطة الإدارية للقرارات الصادرة من العضو الأعلى في درجة السلم الإداري، كما تخضع القرارات الإدارية الفردية للوائح، وتعد اللوائح ملزمة للجهات التي أصدرتها والجهات الأدنى منها.

وفوق ذلك تعد ملزمة للجهات الأعلى منها درجة في السلم الإداري فرئيس الدولة يلتزم باللوائح التي أصدرها مرفق معين إذا أراد إصدار قرار بتعيين موظف في هذا المرفق.

ولم يشر دستور ٢٠١٤م إلى نص مقابل للمادة ٧٤ سالفه الذكر مما يعني بالضرورة عدم جواز قيام رئيس الجمهورية باتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة ٧٤، وحسناً فعل المشرع الدستوري بإلغاء هذه المادة، التي أخذها واضعوا دستور ١٩٧١ من المادة (١٦) من دستور فرنسا الصادر عام ١٩٥٨م، ويؤخذ على واضعوا هذا النص أنه خلا من الضمانات الشكلية والموضوعية التي حددتها المادة (١٦) حتى يتمكن رئيس الجمهورية الفرنسية من استخدام هذه التدابير.

المبحث الثاني

المصادر غير المكتوبة

وتشمل العرف والمبادئ العامة للقانون، ونتناول كل منهما في مطلب مستقل:

المطلب الأول

العرف

المسلم به في مصر وفي فرنسا الاعتراف بالقواعد العرفية كأحد مصادر المشروعية، والعرف بصفة عامة هو القواعد القانونية الناشئة عن اضطراد سلوك الأفراد أو السلطات العامة على نحو معين لمدة زمنية ويستقر بعدها وجدان هذه السلطات على أن هذا السلوك ملزم واعتبار هذه القاعدة هي الواجبة التطبيق.

أنواع العرف بصفة عامة:

والعرف بصفة عامة قد يكون إدارياً أو دستورياً وقد يكون عرفاً بين الأفراد والطوائف، أما العرف الإداري فهو ما درجت الإدارة على اتباعه من قواعد في

مباشرة وظيفتها. وبالطبع المقصود هو القواعد التي لم تنص عليها القوانين أو اللوائح.

فهذه القواعد تصبح ملزمة للإدارة فتضاف لعنصر من عناصر المشروعية.^(١) وأما العرف بين الأفراد والطوائف فمجاله القانون الخاص. أما العرف الدستوري فيتعلق بسلوك السلطات العامة بشأن مسألة تتصل بنظام الحكم في الدولة.

ويختلف العرف الإداري عن مجرد التسامح الإداري، فالعرف الإداري قاعدة قانونية ملزمة يترتب على مخالفتها عدم المشروعية، أما التسامح الإداري فمقتضاه أن تتسامح الإدارة على نحو معين مخالف للقانون فذلك لا يكسب الأفراد حقا في مواجهتها كتكرار وضع سيارة في مكان ممنوع الوقوف فيه أو سماح الإدارة للأفراد فترة من الزمن بالسفر للعمل بالخارج دون إذن عمل لدى هيئة اجنبية دون تطبيق نصوص القانون في هذا الشأن. والعرف الإداري -شأنه شأن العرف في بقية فروع القانون الأخرى- يتكون من عنصرين هما:

- ١ - عنصر مادي: ويتمثل في الاعتياد على الأخذ بالقاعدة المتبعة.
- ٢ - عنصر معنوي: ويتحقق في شعور الجماعة بضرورة احترام القاعدة العرفية والزاميتها وتوقيع جزاء على من يخالفها. ويشترط في الاعتياد العمومية بأن يكون:

- أ- متبعا من غالبية من يعينهم الأمر.
- ب- القدم: بأن تمضي على اتباع العرف فترة من الزمن تتناسب مع طبيعة الوضع وتقدير ذلك مرجعه للقضاء.

^١ - فقد قضت محكمة القضاء الإداري بأن "المخالفة القانونية ليست مقصورة على مخالفة نص في قانون أو لائحة، بل تشمل مخالفة كل قاعدة جرت عليها الإدارة والتزمته واتخذتها منهجا لها" (حكمها في ١٩٥٠/٥/٤، المجموعة، س ٤، ص ٦٩٧).

ج - الثبات: أن يطرد الأمر على اتباع العرف بلا انقطاع في جميع الحالات التي تتوافر فيها شروط انطباقه.

د - المشروعية بألا يخالف العرف نصاً قائماً^(١).

والجدير بالذكر أن القاضي الإداري هو الذي يقدر قيام قاعدة عرفية إدارية ويحدد مضمونها ومحتواها وأن احترام القاعدة العرفية لا يمنع من تعديلها أو الغائها إذا توافرت شروط نشأة قاعدة عرفية جديدة تحل محلها.

فالثابت أن الإدارة -إذا دعتها دواعي التطور والمصلحة العامة يجوز لها العدول عن قاعدة عرفية مطبقة وذلك لتتبنى قاعدة أخرى جديدة أفضل، ولتعديل عن العرف السائد.

أما إذا خالفت الإدارة العرف المطبق في حالة بعينها. مع احتفاظها بالقاعدة العرفية في تطبيقات أخرى فإن تصرف الإدارة المناقض للعرف يُعد باطلاً عرضة للإلغاء إذا طعن فيه أمام القضاء الإداري لمخالفته مبدأ المشروعية^(٢).

وقد ثار خلاف في الفقه حول تحديد أساس القوة الملزمة للقواعد العرفية. فذهب رأى إلى أن إلزامية العرف ترجع إلى الإرادة الضمنية للمشرع. فالمشرع -وفقاً لهذا الرأي- يوافق ضمناً على العرف ولا يخالفه. ولا يخفى ما في هذا الرأي من خلط بين العرف وبين التشريع، فوق أنه يتجاوز حقيقة أن البشرية قد عرفت العرف قبل التشريع.

بينما ذهب رأى ثان إلى أن إلزامية العرف ترجع إلى الإحالة الصريحة للمشرع، كما هو الحال في المادة الأولى من التقنين المدني المصري التي نصت على أنه "إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف". ويتعارض هذا الرأي مع الحقيقة التاريخية التي مضمونها أن العرف أسبق من التشريع.

^١ - حكم محكمة القضاء الإداري في ١٩٥٧/٦/٢٢، القضية ٣٤٨٠ لسنة ٩٩، المجموعة، من ١١، رقم ٣١٦، ص ٤٩٦. وحكم المحكمة الإدارية العليا في ١٩٦٤/٢/٢٤ السابق الإشارة إليه.

^٢ - راجع حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ ١٩٥٧/٦/٢٢، السابق الإشارة إليه، الأستاذ الدكتور/ محسن خليل، المرجع السابق، ص ٤٨. أ.د محمود حافظ، المرجع السابق، ص ٣٧.

ووجد رأى ثالث يسند الزامية العرف الى القضاء بتطبيقه القواعد العرفية على المنازعات. ولا شك أن في ذلك خلط بين العرف والمبادئ العامة للقانون. ووجد رأى رابع يسند إلزامية العرف إلى ضمير الجماعة أو روح الأمة. وفي ذلك خلط بين المصادر المادية للقانون والمصادر الرسمية له التي منها العرف. وقد ذهب الرأي **الراجح** في الفقه الى أن العرف مصدر رسمي مستقل للقانون وأنه ليس معنى أن وظيفة التشريع قد أسندت الى البرلمان والسلطة التنفيذية أحياناً فكل ذلك لا يعنى أن الشعب قد تولى تماماً عن المشاركة في التعبير عن إرادة الأمة ومن ذلك وجود صور للديمقراطية شبه المباشرة جنباً إلى جنب مع النظام النيابي .

أنواع العرف الإداري:

يميز الفقهاء عادة بين ثلاثة أنواع من العرف الإداري وهي العرف المفسر والعرف المكمل والعرف المعدل.

العرف المفسر: هو عرف ينشأ لتفسير قاعدة قانونية مكتوبة وتوضيح معناها. وهو لا يوجد ولا يضيف بذاته قاعدة قانونية جديدة، ولذلك اعترض على القول بوجود هذا العرف لأنه لو أوجد قاعدة قانونية جديدة -أي أحدث أثراً قانونية بذاته- لخرج عن معنى التفسير، ولذا فعملية التفسير تقتصر على تطبيق القاعدة التطبيق السليم دون أن يترتب عليه وجود عرف جديد.

والعرف المعدل: هو الذي يكون من شأنه إنشاء أو إلغاء قيد أو شرط أو اختصاص بسبب مسألة سبق أن نظمها النص المكتوب لذا فهو غير مشروع لمخالفة هذا السلوك لشروط العرف ومنها ألا يخالف نصاً.

وقد أكد القضاء الإداري على أن "اطراد العمل على مخالفة القانون وبفرض حدوثه - لا يسبغ الشرعية على هذه المخالفة بل تظل برغم ذلك انحرافاً ينبغي تقويمه ... والقول بغير ذلك يجعل اطراد الإهمال في مجال الوظيفة العامة عرفاً يحول دون مجازاة من ارتكبه وهذه نتيجة ظاهرة الفساد (١)".

١ - حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ ١٩٦٥/٥/٨، المجموعة، س ١٠، ص ١٢١٩.

أما النوع الوحيد الذي لا خلاف على القول بمشروعيته هو العرف المكمل. وهو الذي يكمل نقصاً في النصوص القانونية بشرط ألا يتعارض مع أي نص قانوني قائم. والعرف الإداري المكمل له تطبيقات عديدة نظراً لعدم تقنين معظم قواعد القانون الإداري، كما أن الاعتماد على القواعد العرفية يضمن لها تطورها الدائم وتتاسبها مع طبيعة العمل الإداري الذي تنتشعب مجالاته وتتسع بما يجعلها تستعصى على التقنين. والإعتراف بالعرف المكمل يجعل قواعده عنصراً من عناصر المشروعية، إلا أن الرأي الذي نرجحه يجعلها في مرتبة أدنى من مرتبة التشريع استناداً إلى أن شرط الإعتراف بها عدم وجود نص في موضوعها وألا تكون مخالفة كذلك لأي نص قانوني قائم^(١).

المطلب الثاني **المبادئ العامة للقانون** **Principes généraux du droit**

هي القواعد القانونية غير المكتوبة التي يستنبطها القضاء ويقرها في أحكامه^(٢). ويتحتم على السلطات العامة احترامها وإلا عد تصرفها المخالف لها باطلاً لخروجه على مبدأ المشروعية والمبادئ العامة للقانون يستوحيها القضاء من ضمير الجماعة وقواعد العدالة والروح العامة للتشريع ومن تفسيره لإرادة المشرع.

^١ - راجع الدكتور/ سامي جمال الدين، الذي يقرر الإعتراف للعرف المكمل بمرتبة أقل من التشريع العادي حتى ولو كان عرفاً دستورياً اعتماداً على أنه ولو تعلق بقاعدة دستورية من حيث الموضوع إلا أنها ليست كذلك من حيث الشكل لأنها لم ترد في الوثيقة الدستورية، فعنده أن "المسائل التي لم تنظم في هذه الوثيقة (أي الوثيقة الدستورية) لا تتمتع بصفة القواعد الدستورية ولا مرتبتها ولا حصانتها ولو كانت من الموضوعات الدستورية بطبيعتها".

أنظر عكس ذلك: الاستاذ الدكتور/ محسن خليل، الذي يعترف للعرف المكمل بنفس قوة الدستور ويعترف كذلك بنفس قيمة الدستور لكل من العرف المفسر والمعرف المعدل الذي يرى أنه لا يمكن إنكار وجوده عملياً مهما قيل من حجج نظرية إنكاره، المرجع السابق، ص ١٣ وما بعدها.

^٢ - عرفت المحكمة الإدارية العليا بأنها قواعد غير مدونة مستقرة في ذهن وضمير الجماعة، يعمل القاضي على كشفها بتفسير هذا الضمير الجماعي العام، وتلك القواعد المستقرة في الضمير تملئها العدالة المثلى ولا تحتاج إلى نص يقرها (حكمها المنشور مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، س ١، ص ٦١٣).

ويرجع الفضل في الأخذ بهذه المبادئ الى مجلس الدولة الفرنسي الذي أعلن صراحة عن اعتبارها مصدراً للشرعية إبان فترة الإحتلال الألماني لفرنسا في بداية الحرب العالمية الثانية وسقوط الجمهورية الثالثة وما ترتب عليه من انهيار النظام القانوني، فلجأ مجلس الدولة الفرنسي إلى فكرة المبادئ العامة للقانون ليتمكن من الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية.

ومن أمثلة المبادئ العامة للقانون التي أقرها مجلس الدولة في فرنسا وفي مصر - مساواة المواطنين أمام القانون، والمساواة في كافة المجالات (الوظيفة العامة، أمام الضرائب والتكاليف العامة، مساواة المنفيعين بخدمات المرافق العامة...).

- حرية التجارة والصناعة. - عدم الجمع بين العقوبات.

- عدم رجعية القرارات الإدارية. - كفالة حق التقاضي.

- حرية العقيدة. - حجية الشيء المقضى به.

- كفالة حقوق الدفاع.

ويلاحظ أن اتجاه القضاء إلى إبراز المبادئ العامة للقانون يزداد في فترات الأزمات وحدثت التغيرات العميقة في المجتمعات وما يصحبها من اضطرابات وديناميات مؤقتة وعدم استقرار قانوني بصفة عامة، فيلجأ القضاء الى المبادئ العامة للقانون كحصن حصين لحماية حقوق وحريات الأفراد ولتحقق من خلالها الاستقرار التشريعي الذي تنتشه الأمة في هذه الأوقات (١).

أساس المبادئ العامة للقانون:

لا يمكن القول بأن القاضي يبتدع القاعدة القانونية حينما يجتهد ليستلهم المبادئ العامة في القانون وإلا كان ذلك تعدياً على حق المشرع ومخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات.

ولذا فالقاضي يقف دوره عند الكشف عن هذه المبادئ و إعلان وجودها ثم صياغتها وتقرير إلزاميتها.

١ - راجع : الاستاذ الدكتور/ أنور رسلان، المرجع السابق، ص ١٢٥ وما بعدها، استاذنا الدكتور/ سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص ٧٠ وما بعدها.

فهذه المبادئ العامة هي في الواقع مستقرة وكامنة في ضمير الجماعة إلا أنها لم تجد طريقها الى القانون المكتوب، فهي في وجودها تسبق القواعد القانونية مما يمكن تسميته بالمصادر المادية للقانون فإذا نقلها المشرع الى عالم النصوص التشريعية كانت قانوناً مكتوباً وإلا بقيت مكانها حتى يجئ دور القاضي الذي يأخذ بيدها الى عالم القواعد القانونية الملزمة بعد أن يتولى صياغتها وتطبيقها في أحكامه. ومن الميادين الخصبة لهذه المبادئ والتي يذهب القاضي للكشف عنها فيها مقدمات الدساتير وإعلانات الحقوق والمواثيق.

ولا شك أن ما يدفع القاضي للبحث عن هذه المبادئ والتعلق بها عند اكتشافها هو غياب النصوص التشريعية التي تنطبق على الواقعة المعروضة على القاضي ولذا كانت الحاجة اليها أشد أمام القاضي الإداري.

مصدر القوة القانونية للمبادئ العامة للقانون:

أ- ذهب رأى الى أن المبادئ العامة للقانون تستمد قوتها من ورودها في مقدمة الدستور أو في اعلان حقوق الإنسان. لكن يعاب على هذا الرأى أن هناك مبادئ عامة للقانون لم ترد في مقدمة الدستور أو إعلان حقوق الإنسان مثل كفالة حق الدفاع في المحاكمات التأديبية، علاوة على أن من المبادئ العامة للقانون ما يسبق في وجوده مقدمات الدساتير أو إعلانات الحقوق.

ب- وذهب رأى آخر الى فكرة القانون الطبيعي كأساس للقوة القانونية للمبادئ العامة للقانون، إلا أن ذلك يتعارض مع موقف القضاء الفرنسي الراض لفكرة القانون الطبيعي.

ج- والرأى الراجح^(١) هو أن القوة القانونية للمبادئ العامة للقانون ترجع إلى الدور الإنشائي للقاضي الإداري في حالات عدم وجود نص تشريعي يفصل بموجبه في النزاع المعروض عليه.

^١ - الأستاذ الدكتور/ محمود حافظ، المرجع السابق، ص ٤١ وما بعدها.

وقد عبرت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ بشأن تنظيم مجلس الدولة بقولها "أن القانون الإداري يفترق عن القوانين الأخرى كالقانون المدني أو التجاري في أنه غير مقنن .. لذلك يتميز القضاء الإداري بأنه ليس مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء المدني، بل هو في الغالب قضاء إنشائي يبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ بين الإدارة في تسييرها للمرافق العامة وبين الأفراد."

القوة القانونية للمبادئ العامة للقانون:

اختلفت الآراء حول المرتبة القانونية للمبادئ العامة للقانون^(١).

الرأي الأول : للمبادئ العامة للقانون نفس مرتبة الدستور :

وقد وجد هذا الرأي تبريراً له بظهور اللوائح المستقلة في الدستور الفرنسي الصادر عام ١٩٥٨ حيث أباحت المادة (٣٧) منه السلطة التنفيذية أن تصدر هذه اللوائح المستقلة والتي لها قوة القانون، وتنظم بها مسائل من اختصاص السلطة التشريعية أصلاً، فإذا اعترف للمبادئ العامة للقانون بنفس مرتبة القوانين فإن هذه اللوائح سيكون بإمكانها مخالفة هذه المبادئ وستفقد من الرقابة^(٢). بينما على العكس فإن اعطاء المبادئ القانونية العامة قوة دستورية تعلو القوانين العادية سيوفر حماية أكبر لحقوق الأفراد وحياتهم^(٣).

الرأي الثاني: المبادئ العامة للقانون لها نفس مرتبة القانون .

ويرجع هذا الرأي الى عدة اعتبارات:

الأول : أن القاضي ينقب عن المبادئ العامة للقانون في التنظيم القانوني للدولة

فمن الطبيعي الاعتراف لها بقوة القانون.

الثاني : أن القضاء الفرنسي لازال لا يعترف لنفسه بالحق في رقابة دستورية

القوانين وبالتالي فلا معقب على القوانين العادية ولو من قبل النصوص

الدستورية، ومن المنطقي أن المبادئ العامة للقانون لا تستطيع من باب أولى - أن

^١ - راجع في عرض هذه الآراء الدكتور/ سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص ٧٩ وما بعدها. الاستاذ الدكتور/ أنور رسلان، المرجع السابق، ص ١٢٩-١٣٠. الاستاذ الدكتور محمد أنس قاسم جعفر، المرجع السابق، ص ٦٨-٧٤. الاستاذ الدكتور/ محسن خليل، المرجع السابق، ص ٥٩ وما بعدها.

^٢ - ولكن الذي حدث أن مجلس الدولة الفرنسي أخضع اللوائح المستقلة لرقابته باعتبارها قرارات إدارية وبالتالي لم يعد هذا الرأي في حاجة للقول بالاعتراف للمبادئ العامة للقانون بمرتبة تعلو القوانين.

^٣ - الاستاذ الدكتور/ محسن خليل، المرجع السابق، ص ٦٤.

تقوم بما عجزت عنه النصوص الدستورية. فليس من المستساغ أن يمثل القاضي للقانون المخالف للدستور ولا يمثل للقانون المخالف للمبادئ العامة للقانون.

الثالث : أن القانون العادي يعبر عن الإرادة العامة للمجتمع، فلا يجوز أن يكون للمبادئ العامة للقانون قوة أعلى من قوة الإرادة العامة للمجتمع.

الرأي الثالث: ويفرق بين المبادئ العامة للقانون المستمدة من الدستور، وهذه تكون لها القيمة القانونية للدستور، وبين تلك المستمدة من مجموعة القوانين المعمول بها داخل الدولة وهذه تكون لها القيمة القانونية والقوة الملزمة للقانون ويكون للبرلمان أن يعدلها بتشريع عادي.

وترجع التفرقة التي اقامها هذا الرأي في عدة مبررات يمكن ايجازها فيما يلي:
١- أن المبادئ المستمدة من الدستور تعد مفسرة أو مكملة للنصوص الدستورية ولذا قيل بمنحها نفس القوة القانونية للدستور.

٢- أن العادة جرت بالنسبة للحريات والحقوق العامة أن تذكر بالدستور أمثلة لها فقط، لذا كان من المنطقي أن الجانب الذي لم ينص عليه ويكشف عنه القضاء أن يمنح نفس القيمة القانونية للدستور.

٣- إذا كان الرأي الغالب في فرنسا لم يذهب الى هذه التفرقة بين المبادئ العامة للقانون، وإنما اعترف لكل المبادئ العامة للقانون بمرتبة القوانين العادية، فإن ذلك يرجع لظروف خاصة بفرنسا وهي عدم الاعتراف بالرقابة القضائية على دستورية القوانين.

الرأي الرابع: يرى أن هذه المبادئ وإن كانت ملزمة للإدارة إلزامها بالقوانين العادية إلا أنها لا تستطيع مخالفة أحكام القوانين العادية المكتوبة، بينما على العكس يمكن للقوانين العادية الخروج على هذه المبادئ العامة للقانون بالتعديل أو الإلغاء، لذا يجب الاعتراف لها بقيمة أدنى من القوانين العادية.

ولكن لما كانت الإدارة لا تستطيع مخالفة هذه المبادئ العامة للقانون فتكون قيمتها القانونية أعلى من قيمة اللائحة.^(١)

^١ - الأستاذ الدكتور/ محمود حافظ، المرجع السابق، ص ٣٩-٤٠.

الرأي الخامس: أن للمبادئ العامة للقانون قوة الزامية تعلو القوانين العادية وأقل من الدساتير:

فالمركز القانوني للمبادئ العامة يعلو القوانين العادية لأنها تشكل الأسس التي يلجأ إليها المشرع عند وضع النصوص القانونية، ولكنها لا تصل لمرتبة الدستور لأنه لا يجوز للدستور بنص صريح أن يخالف إحداها وإن كانت السلطة التشريعية تلتزم بها التزاماً بالدساتير.^(١)

وفي تقديرنا أن الرأي الثالث فوق أنه منطقي يؤيده أن دور القاضي يقف عند حد الكشف عن هذه المبادئ العامة للقانون، فهي موجودة قبل تدخله، فالقاضي لا ينشئها فكان من اللازم مراعاة مصدرها عند تحديد قوتها.

وكون هذا الرأي منطقي يرجع الى أنه إذا وجد مبدئان كشف عنهما القضاء وطبقهما في أحكامه، فكلاهما متحدان في الدرجة وفقاً للمعيار الشكلي لأنهما مرجعتهما القضاء وكلاهما غير مدون، ولكن من الناحية الموضوعية يجب التمييز بينهما، فالمبدأ الذي موضوعه شأن دستوري لا بد من الاعتراف له بمرتبة تفوق المبدأ الذي موضوعه شأن تنظمه القوانين العادية.

المبحث الثالث

تدرج القواعد القانونية

معنى التدرج: أن هناك قواعد قانونية تتمتع بقوة قانونية أو مرتبة الزامية أكثر من القواعد الأخرى التي تليها في المرتبة.

ويترتب على ذلك نتيجة هامة أنه على كل سلطة معنية بإنشاء قواعد قانونية أن تراعي احكام القواعد القانونية الأعلى مرتبة.

صور التدرج:

١- التدرج الشكلي: المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن ترتيب القواعد القانونية

المدونة يبدأ بالقواعد الدستورية - على قمة الهرم القانوني - تليها القواعد

^١ - الدكتور/ سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص ٨٢ وما بعدها.

التشريعية (القوانين بالمعنى الضيق) واخيراً التشريعات الفرعية أو اللوائح.^(١) والمرجع في ذلك هو المعيار الشكلي أو العضوي أي بحسب مرتبة السلطة التي أصدرت القاعدة القانونية، فالقاعدة القانونية الصادرة من سلطة أعلى تعتبر أعلى مرتبة من تلك التي صدرت من سلطة أدنى، ولذا كانت القواعد الدستورية هي أعلى القواعد القانونية وذلك لصدورها عن السلطة التأسيسية التي تلو كل السلطات داخل الدولة لأنها هي التي أوجدتها.

ولما كانت السلطة التشريعية أعلى من السلطة التنفيذية (لكونها هي المختصة أساساً بالتشريع أما السلطة التنفيذية فتختص به استثناءً). لذا قلنا أن القوانين أعلى مرتبة من اللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية.

والسلطة التنفيذية تتكون من عدة هيئات وجهات إدارية متدرجة فيما بينها وتصدر عنها أعمال متنوعة، لذا فإن هذه الأعمال تتدرج فيما بينها حسب درجة كل هيئة أو جهة من الجهات الإدارية.

٢ - التدرج من حيث الإجراءات:

تتم التفرقة بين بعض التشريعات التي تصدرها نفس الجهة وذلك إذا كانت الإجراءات اللازمة لإستصدار بعضها تختلف عن الإجراءات التي تستخدم لاستصدار البعض الآخر.

ومن أمثلة ذلك القوانين الأساسية في فرنسا حيث اشترط الدستور لإقرارها أغلبية خاصة وإجراءات أشد من القوانين العادية، ولذا اعتبرت القوانين الأساسية أعلى مرتبة من القوانين العادية.

٣ - التدرج من حيث الموضوع:

في حالة اصدار نفس الجهة لأعمالها بإجراءات مماثلة فالمعيار الشكلي لا يمكن تطبيقه في هذه الحالة ويكون ذلك مثلاً بالنسبة للأعمال الإدارية حيث تصدر عن الإدارة اللوائح والقرارات الإدارية الفردية كذلك، فلا يمكن التمييز بينها وتحديد

^١ - حكم المحكمة الإدارية العليا في ١٢/٧/١٩٥٨، قضية ٩٢٩ لسنة ٣، المجموعة، س ٣، رقم ١٧٣، ص ١٩٩١.

درجة الزامية كل منها بالرجوع للمعيار الشكلي أو العضوي، وإنما يلزم اللجوء إلى معيار موضوعي أساسه موضوع كل من اللائحة والقرار الفردي.

فاللائحة تتضمن قواعد عامة مجردة ولذا تعد أعلى درجة من القرارات الإدارية الفردية التي يجب أن تصدر تطبيقاً لها^(١). فإذا قيدت جهة معينة نفسها بقواعد عامة معينة في تعيين الموظفين وجب عليها الإلتزام بها في تطبيقاتها الفردية^(٢)، ومن باب أولى الجهات الأدنى منها بل إن السلطات الأعلى تلتزم بالقواعد التنظيمية التي تضعها سلطات أدنى منها فيلتزم رئيس الجمهورية بالقواعد التي تضعها الجهة المعنية عند إصداره قرار تعيين أحد التابعين لها من يتطلب تعيينه إصدار قرار جمهوري.

٤ - تدرج استثنائي: استثناء من الأصل الذي ذكرناه بخصوص التدرج الشكلي فإن المشرع الدستوري قد يتدخل ويغير من القوة الإلزامية للعمل القانوني.

ومثال ذلك ما حدث بالنسبة للوائح الضرورة في مصر فهي وفقاً للمعيار الشكلي لوائح تصدر عن السلطة التنفيذية، ولكن يتدخل المشرع الدستوري وينص في المادتين ١٠٨، ١٤٧ على أن لها قوة القانون.

ومثال ذلك في فرنسا اللوائح المستقلة فهي تتعلق بموضوعات كان يتم تنظيمها بقانون ولكن دستور ١٩٥٨ نص في المادة ٣٧ على تخصيص هذا المجال للوائح^(٣).

على أنه يجب مراعاة أن تغيير القوة الإلزامية للعمل القانوني على هذا النحو لا يترتب عليه كما سبق أن ذكرنا تغيير في الطبيعة القانونية إذ تظل الأعمال القانونية

^١ - اعتبر بعض الفقه أن التدرج الموضوعي يتمثل في اعتبار القواعد الأدنى درجة محددة للقواعد الأعلى درجة بحيث تعتبر تنفيذاً لها، بينما تعتبر القواعد الأعلى درجة هي الإطار الخارجي للقواعد الأدنى درجة، (د. محمود حلمي، المرجع السابق، ص ١٥).

^٢ - حكم محكمة القضاء الإداري في ١٩٥٣/٢/١١، المجموعة، ص ٨، ص ١٢.

^٣ - ومثال ذلك أيضاً بعض نصوص قانون الإصلاح الزراعي في مصر وما أضافه عليها دستور ١٩٥٦ من قوة دستورية، ومثال ذلك في الكويت نظام توارث الامارة ورفع القانون الذي ينظمها إلى مرتبة الإلزامية للدستور. راجع استاذنا الدكتور/ سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص ١١٦.

الصادرة عن جهة الادارة أعمالا ادارية تخضع للرقابة القضائية من جانب القضاء الادارى للتأكد من مشروعيتها وذلك مهما كانت قوتها الالزامية. والمستقر فقهاً وقضاءً الإعتماد في تحديد هوية العمل القانوني (ببيان ما إذا كان عملاً إدارياً أو تشريعياً أو قضائياً) إلى المعيار الشكلي -كما أوضحنا وذلك بسبب وضوحه وانضباطه وتحديد عناصره حيث يكفي فيه الرجوع الى الجهة التي أصدرت العمل على عكس المعيار الموضوعي الذي يتطرق الى مضمون العمل ومكوناته.

مقتضى أعمال قواعد التدرج:

يترتب على التدرج أنه إذا خرجت سلطة ما عند انشائها لقاعدة قانونية على أحكام القواعد القانونية التي تعلوها أن يكون عملها مخالفاً لمبدأ المشروعية. فالقوانين التي تقرها السلطة التشريعية يجب أن تكون موافقة لأحكام الدستور وإلا كانت غير دستورية، وكذلك اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية يجب أن تكون موافقة لأحكام القانون والدستور وإلا كانت غير مشروعة أو غير دستورية حسب الأحوال. ولا شك أن مبدأ المشروعية يظل فكرة فلسفية مالم توجد الوسائل الكفيلة بوضعه موضع التطبيق، فمبدأ المشروعية لن ينتج أثره إلا بقيام مبدأ آخر يكمله ويعتبر ضرورياً مثله، لأن الإخلال به يؤدي بمبدأ المشروعية ويسلمه إلى العدم، ذلك هو مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين من جهة وعلى مشروعية القرارات الإدارية من جهة أخرى، لأن . هذه الرقابة القضائية هي المظهر العملي الفعال لحماية المشروعية فهي التي تكفل تقييد السلطات العامة لقواعد القانون، كما تكفل رد هذه السلطات الى حدود المشروعية إن هي تجاوزت تلك الحدود...^(١)."

^١ - حكم المحكمة العليا في ١٩٧٦/٤/٣، دعوى رقم ١١ لسنة ١٩٧٦، المجموعة، القسم الأول، ص ٤٤٢.

الفصل الثالث

موازنات مبدأ المشروعية^(١)

أوضحنا أن مبدأ المشروعية يعني سيادة حكم القانون بمعنى التزام الجميع حكماً ومحكومين بأحكام القانون أي كان مصدرها، ويستوى في ذلك الأفراد أو السلطات العامة.

غير أن التزام الإدارة بمبدأ الشرعية لا يعني تكبيلها بقيود صارمة تحد من قدرتها على التصرف وتقتل فيها روح المبادأة والابتكار مما يجعلها عملاً روتينياً، وإنما يقتضى الصالح العام منح الإدارة قدراً من الحرية في مباشرة نشاطها. وهكذا ترد على مبدأ المشروعية عدة تيسيرات في شكل مزايا تحقق قدراً من المرونة في عمل الإدارة بما يمكنها من تحقيق التوازن بين المصالح الخاصة المتمثلة في حماية حقوق الأفراد وحياتهم وبين المصلحة العامة المتمثلة في حسن سير الإدارة.

وتتمثل هذه الموازنات أو التيسيرات أو المزايا في الأمور الثلاثة الآتية:

١ - اعتبار بعض أعمال الإدارة لا تخضع للرقابة القضائية وذلك لاعتبارات معينة تتصل بسيادة الدولة في الداخل والخارج أو علاقة الدولة بالبرلمان وغيرها من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء سواء قضاء الإلغاء أو التعويض إلا أنها أمور استثنائية لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي المتعلقة بأعمال السيادة.

٢ - قد تلم ظروف استثنائية بالدولة يكون من شأن تطبيق قواعد المشروعية العادية بصددها الحاق الضرر بالمصلحة العامة وتعريض سلامة الدولة للخطر، ولذا يتم التخفيف من قواعد المشروعية العادية وتطبيق قواعد المشروعية الاستثنائية المتعلقة بحالة الضرورة وهو ما عرف بنظرية الظروف الاستثنائية.

^١ يرى كثير من الفقهاء أن هذه الموازنات تعتبر قيداً أو استثناءً على مبدأ المشروعية وفيما نرى أن هذه الموازنات ليست قيداً أو استثناءً على هذا المبدأ لأن جميعها جزء لا يتجزأ من المشروعية عدا أعمال السيادة كما سنوضح

٣ - أخيراً وفي ظل الظروف العادية يلزم الإعتراف للإدارة بقدر من الحرية والمرونة في ممارسة اختصاصها وذلك بالإعتراف لها بحرية التقدير في جانب أو أكثر من جوانب العمل الإداري وهو ما يعرف بالسلطة التقديرية.

وستتناول الموضوعات الثلاثة كل في مبحث مستقل:

المبحث الأول : أعمال السيادة.

المبحث الثاني : الظروف الاستثنائية.

المبحث الثالث : السلطة التقديرية للإدارة.

المبحث الأول

أعمال السيادة

المطلب الأول

تعريف أعمال السيادة ونشأتها وتطورها

أعمال السيادة هي طائفة من أعمال السلطة التنفيذية تخرج عن اختصاص المحاكم أيما كان نوعها فلا تخضع لأى رقابة قضائية سواء في مجال الالغاء أو التعويض وسواء في ظل الظروف العادية أو الاستثنائية.^(١) نظرية أعمال السيادة نظرية قضائية المولد والنشأة، بل وترتبط نشأتها وتطورها بنشأة وتطور مجلس الدولة الفرنسي.

ففى بداية نشأة مجلس الدولة الفرنسي وحتى نهاية الإمبراطورية الأولى لم تظهر فكرة أعمال السيادة لأن المجلس كان يقدم مجرد اقتراحات تخضع للتصديق من جانب الحكومة كما أن المجلس كان يحظى بثقة نابليون الذي أنشأه.

بعد سقوط نابليون وعودة الملكية في عام ١٨١٤ كان ينظر بعين الشك والريبة لمجلس الدولة لكونه من مخلفات نابليون، فأراد مجلس الدولة أن يكسب ثقة الحكومة بإبتداع نظرية أعمال السيادة.^(١)

^١ - راجع لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع:

دكتور/ - محمد حافظ هريدي، أعمال السيادة في القانون المصري والمقارن، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة ١٩٥٢. دكتور/ عبد الفتاح ساير داير، نظرية أعمال السيادة، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، القاهرة ١٩٥٥.

في ظل الامبراطورية الثانية أكتسب المجلس ثقة الحكومة وأرسي قواعد مبدأ المشروعات ووسع من شروط قبول دعوى الالغاء، وحفاظاً على هذا التطور أرسى المجلس قواعد نظرية أعمال السيادة بترك قدر كبير من أعمال الحكومة بعيداً عن رقابته.

وفي ظل الإمبراطورية الثالثة اعترف لمجلس الدولة بسلطة البت النهائي في المنازعات بحيث أصبحت أحكامه لا تخضع للتصديق من أحد، وذلك بموجب القانون الصادر في ١٨٧٢/٥/٢٤، واستمر المجلس في تقرير أعمال السيادة.

المطلب الثاني **معيار تحديد أعمال السيادة**

اختلف الفقهاء في المعيار الذي يتم به تمييز أعمال السيادة ووجدت عدة معايير نذكر منها:

١ - معيار الباعث السياسي:

في البداية ارتبطت فكرة أعمال السيادة بمعيار الباعث السياسي، فاعتبر أن الأعمال التي تصدر عن باعث سياسي (لكون الغرض منها حماية الجماعة في ذاتها)، لا يمكن المطالبة بالغائها أو مجرد التعويض عن الأضرار المترتبة عليها^(٢). ورغم بساطة معيار الباعث السياسي إلا أنه انتقد بشدة لخطورته على الحقوق والحريات العامة، ذلك أن السلطة التنفيذية يمكنها وفقاً لهذا المعيار أن تنهرب من المسؤولية عن أي عمل غير مشروع بادعائها بأن الدافع وراءه كان سياسياً.

^١ - كان أول حكم طبق هذه الفكرة حكم مجلس الدولة الفرنسي عام ١٨٢٢ (٣٧١). C.E. 1-5-1822, Lafitte leb. p حيث كان قد صدر قانون في فرنسا في ١٨١٦/١/١٦ وكانت تنص المادة (٤) منه على إيمان أسرة نابليون بوناپرت من فرنسا وحرمانهم من التمتع بالحقوق المدنية على أرضها وحرمانهم من مستحقات تقررت لهم والزامهم ببيع الأموال التي تملكوها، ولما ثار نزاع بسبب مستحقات أحد أفراد الأسرة تدخلت الحكومة الفرنسية وقررت عدم صرف المستحقات، فلما طعن في قرار الحكومة أمام مجلس الدولة رفض نظر الدعوى لتعلقها بمسألة سياسية.

^٢ - C.E. 1-5-1822 Lafitte lab. P. 371.

C.E. 9-5-1867 Dve d'Aumale, S. 1867 II 124.

وبالفعل فقد هجر مجلس الدولة الفرنسي هذا المعيار تماماً، وورد في احكامه اعتباراً من عام ١٨٧٥ بأن الباعث السياسي لا يكفي لاعتبار العمل من أعمال السيادة^(١).

٢ - معيار طبيعة العمل:

ويعتمد هذا المعيار على النظر لطبيعة العمل بحسب كونه عملاً إدارياً أو حكومياً بصرف النظر عن الباعث عليه فظهرت في أحكام مجلس الدولة الفرنسي عبارات مثل:

أن هذه الاعمال "تقلت من كل رقابة قضائية بسبب طبيعتها"، أو أن هذه الأعمال "من طبيعة تجعلها غير قابلة للطعن فيها قضائياً"

وحاول الفقهاء تفسير هذا القضاء بالتفرقة في أعمال السلطة التنفيذية بين العمل الحكومي (وهو الذي يعد من أعمال السيادة) وبين العمل الإداري (وهو الذي يمكن الطعن فيه أمام القضاء) ووضعوا عدة معايير للتمييز بين العمل الحكومي والعمل الإداري منها):

أن العمل الإداري يتمثل في التطبيق اليومي للقوانين، بينما العمل الحكومي ما يقصد به تحقيق مصلحة الجماعة السياسية والسهر على احترام الدستور وسير الهيئات العامة والإشراف على علاقة الدولة مع الدول والهيئات الأجنبية والإشراف على الأمن الداخلي.

في حين أن البعض الآخر يرى أن العمل الإداري يتركز في تسيير المصالح الجارية للجمهور بينما العمل الحكومي ينحصر في السهر على تحقيق مصالح الدولة الرئيسية ووضع الحلول للأمور الاستثنائية.

بينما ذهب البعض الآخر إلى أن العمل الحكومي هو ما يكون تنفيذاً لنص في الدستور، والعمل الإداري ما يكون تنفيذاً لقانون عادي ويرى معظم الفقه أنه يصعب التفرقة بين الأعمال الإدارية والأعمال الحكومية مما من شأنه عدم التسليم بهذا المعيار .

¹ - CE 192-1875 Prince Napoleon, S. 1875 11 95, G. A No. 3. IC
١٨٨٠-١١-٥ Marquigny D. 1880 III 121

٣- معيار قائمة أعمال السيادة:

لم يكن أي من المعايير التي قيل بها ضمن معيار طبيعة العمل مانعاً جامعاً لكل حالات أعمال السيادة، ولذا لجأ مجلس الدولة الى تحديد أعمال السيادة في كل حالة على حدة. وظهر بناء على ذلك ما سمي "بقائمة أعمال السيادة" والتي اعتمد الفقه في الوقوف عليها على أحكام مجلس الدولة الفرنسي واحكام محكمة التنازع وتشمل هذه القائمة عدة مسائل منها:

- الأعمال المتعلقة بعلاقة الحكومة بالبرلمان (مثل دعوة الناخبين للانتخاب، دعوة البرلمان للإنعقاد...).

- استعمال السلطة التنفيذية لحقوقها المتعلقة بالتشريع (كإقترح القوانين أو الاعتراض عليها...)

- الأعمال المتعلقة بسير مرفق التمثيل الدبلوماسي كحماية المواطنين المقيمين في الخارج^(١)، والأعمال المتعلقة بإبرام المعاهدات (كالمفاوضات والتوقيع، والتصديق وتفسير المعاهدات...^(٢)).

- الأعمال المتعلقة بالحرب (كقرار إعلان الحرب وسير العمليات الحربية والتدابير المتخذة قبل رعايا الدول المعادية كابعادهم أو اعتقالهم وإعلان حالة الطوارئ).

الأعمال المتعلقة بالمحافظة على سلامة الدولة وأمنها الداخلي وبعض المسائل المتعلقة بسيادة الدولة في المجال الداخلي كالمسائل التي تتخذها الدولة لحماية اقتصادها أو عملتها العالية أو قرارات العفو عن بعض المسجونين.

وقد اتسمت هذه القائمة بالمرونة فكان مجلس الدولة يوسع من نطاقها في حالات الأزمات، أما في الظروف العادية فإنه يحرص باستمرار على التضييق منها فتجده

^١ - يمارس الممثلون السياسيون في الخارج أعمالاً لا تدخل في وظائفهم السياسية مثل القضاء أو التحكيم أو التوثيق وهي تعد أعمالاً إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري.

^٢ - من أمثله ذلك في القضاء المصري:

- حكم محكمة مصر الابتدائية المختلطة في ١٩١٠/٤/١١ الذي اعتبر اتفاقية ١٨٩٩/١/١٩ المبرمة بين مصر وإنجلترا بخصوص السودان من أعمال السيادة.

- حكم محكمة القضاء الإداري في ١٩٤٩/٥/٢٦ والذي ورد به أن "النزاع في تفسير المعاهدات وتطبيقها على الدولة أو الأفراد هو من الأمور السياسية، ويعد من قبيل أعمال السيادة التي لا تسأل عنها الحكومة".

في أحكامه الحديثة يخضع أعمالها لرقابته بينما كان في السابق يعتبرها من أعمال السيادة.

ونظراً للنقد الشديد والهجوم العنيف الذي شنه الفقهاء على نظرية أعمال السيادة باعتبارها ثغرة حقيقية في بناء المشروعية وبقية من بقايا الدولة غير القانونية فقد أثمرت هذه الحملة ما يلي:

١ - تضيق القضاء من نطاق أعمال السيادة، فأصبح يبسط رقابته القضائية إلغاءً وتعويضاً على أعمال كان يعتبرها من قبل من أعمال السيادة.

كما أن هناك أعمالاً أخرى خرجت من أعمال السيادة لإرتباطها بأفكار أخرى، فمثلاً قرارات العفو التي يصدرها رئيس الدولة أو رئيس السلطة التنفيذية فقد أصبحت من الأعمال القضائية التي تتبع السلطة القضائية.

٢ - الحد من الآثار الخطيرة للنظرية وذلك بقصر تطبيقها على تحصين أعمال السيادة ضد قضاء الإلغاء فقط والسماح بإمكانية التعويض عنها، وذلك استناداً لنظرية تحمل التبعية وفكرة المخاطر في فرنسا (١).

المطلب الثالث

أساس نظرية أعمال السيادة

قيل بعدة آراء في بيان أساس حصانة أعمال السيادة ضد الرقابة القضائية نذكر منها:

١ - **الأساس التاريخي:** أن النظرية تعد نوعاً من السياسة القضائية التي لجأ إليها مجلس الدولة الفرنسي للتعاشي مع الحكومة حيث تنازل عن حقه في رقابة بعض أعمال الحكومة مقابل الحفاظ على كيانه وبقائه رقيباً على بقية أعمال الإدارة.

٢ - **الطبيعة السياسية لأعمال السيادة:** فالسلطة التنفيذية وهي تمارس نشاطها تقوم بنوعين من الأعمال:

١ - وقد حكمت محكمة الاستئناف المختلط في مصر بالتعويض في محاولة للتخفيف من آثار أعمال السيادة وذلك في حكمين مادريين في ١٩٠١/١/٣١ (قضية جيد وليفي)، ١٩٢٧/٥/١١ (قضية شركة الملاحه البريطانية) وذلك استناداً إلى فكرة العدالة.

مشار إليهما في مؤلف دكتور / وحيد رافت، رقابة القضاء لأعمال الإدارة، ١٩٤٢، ص ٢٤٩ وما بعدها. راجع في ذلك الأستاذ الدكتور / أنور رسلان، ص ١٤٥ وما بعدها.

النوع الأول: تقوم به باعتبارها حكومة أو هيئة سياسية، ولذا يغلب عليه الطابع السياسي (وهو ما يعد من أعمال السيادة) ويخرج هذا النوع عن رقابة القضاء ويخضع فقط لرقابة الهيئة السياسية.

النوع الثاني: وهي أعمال الإدارة وهي التي تخضع للرقابة القضائية وكما أشرنا يصعب التوصل إلى معيار دقيق يميز بين العاملين.

٣ - **الأساس التشريعي:** حاول البعض البحث عن أساس تشريعي لقيام نظرية أعمال السيادة، فأشار بعض الفقه في فرنسا إلى المادة (٢٦) من القانون الفرنسي الصادر في ١٨٧٢/٥/٢٤ والتي تنص على "حق الوزراء في أن يحيلوا الأمر إلى محكمة التنازع بشأن القضايا المرفوعة أمام القسم القضائي (بمجلس الدولة) والتي تخرج من اختصاصه".

ولكن اعترض على تفسير النص بهذا الشكل، وقيل بأنه قصد به فقط تحقيق التوازن في توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري عن طريق منح الوزراء الحق في أن يحولوا إلى محكمة التنازع المنازعات التي تخرج من اختصاص القضاء الإداري.

وعلى أية حال فإن هذا النص لم يجد سبيله إلى التطبيق فلم يقرم الوزراء باستخدام هذا الحق لا في مجال أعمال السيادة ولا في مجال توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والإداري.

وفي مصر وجد بعض الفقه في نصوص التشريعات المصرية المتعاقبة أساساً قانونياً لنظرية أعمال السيادة ذلك أن قوانين تنظيم القضاء في مصر وقوانين مجلس الدولة قد تعاقبت على النص صراحة على منع المحاكم العادية والإدارية من نظر المنازعات المتعلقة بأعمال السيادة.^(١)

^١ - مثال ذلك المادة (١١) من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة الصادرة عام ١٩٠٠.

المادة (١٥) من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية بعد تعديلها عام ١٩٣٧.

المادة (١٦) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥.

المادة (١٨) من قانون نظام القضاء رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩.

المادة (١٥) من قانون السلطة القضائية رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٩.

المادة (٦) من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦.

ولكن بعد صدور دستور ١٩٧١ والنص في م ٢/٦٨ على حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، فقد أصبح النص على أعمال السيادة أمر محل نظر ويمس الدستورية. فالقول بنظرية أعمال السيادة في حقيقته ليس إلا تحصين لهذه الأعمال ضد رقابة القضاء وهذا ما يخالف صريح نص الدستور وفيما نرى أن حظر النص على تحصين أي عمل أو قرار إداري الذي جاء به دستور ١٩٧١ أصبح من القواعد الدستورية بطبيعتها سواء وردت أم لم ترد في الدساتير التالية .

ورغم ذلك فقد نص قانون السلطة القضائية رقم ٤١ لسنة ١٩٧٢ في المادة (١٧) وقانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ في المادة (١١) على عدم اختصاص القضاء بالنظر في أعمال السيادة مما اعتبره الفقه أساساً لنظرية أعمال السيادة في القانون المصري.

المادة (٧) من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم ١ لسنة ١٩٤٩ .
المادة (١٢) من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ .
المادة (١٢) من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ (المعدل بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٦٣).
وقد كانت السادة (٦) من قانون مجلس الدولة ١١٢ لسنة ١٩٤٦ تتضمن بعض الأمثلة على أعمال السيادة فذكرت أنه لا تقبل الطلبات المقدمة عن القرارات المتعلقة بالأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بمجلس البرلمان وعن التدابير الخاصة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة وعن العلاقات السياسية أو المسائل الخاصة بالأعمال الحربية. وبعد ذكر هذه الأمثلة ورد نص عام "وعلى العموم سائر الطلبات المتعلقة بعمل من أعمال السيادة". ونظراً للانتقاد الشديد للفقه لهذا النص لأن ضرب الأمثلة ليس عمل المشرع وإنما الفقه أو القضاء، فقد صدر قانون مجلس الدولة رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ مكتفياً بالمبدأ العام ولم يشر إلى أي من الأمثلة. وتابعه في ذلك قانون مجلس الدولة رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ تاركاً تحديد متى بعد العمل من أعمال السيادة للقضاء.
ولكن المشرع عاد بموجب القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٦٣ ليعدل المادة (١٢) من قانون مجلس الدولة برقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ ليصبح نصها "لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في المنازعات المتعلقة بأعمال السيادة، ويعتبر من قبيل أعمال السيادة قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي .." وعاد القانون العالي رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بالنص على المبدأ دون ذكر الأمثلة.
علماً بأنه بعد صدور دستور ١٩٧١ والنص على عدم جواز تحصين عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء فقد قضت المحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٦٣ لأنه ينطوي على مصادرة لحق الموظفين في الطعن في تلك القرارات أو التقاضي بشأنها فضلاً عن إهداره مبدأ المساواة بين المواطنين والحقوق.
ويلاحظ أن أسلوب النص على المبدأ وعدم ضرب الأمثلة هو ما درج عليه المشرع بالنسبة للمحاكم العادية منذ البداية وحتى القانون الحالي للسلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ حيث ينص في ١٧ على أنه ليس للمحاكم أن تنتظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة" تاركاً أمر تحديدها للقضاء.

إلا أن هذا الرأي انتقد -بحق- من زاوية أن هذه النصوص غير دستورية لمخالفتها صريح نص المادة ٢/٦٨ من الدستور، ولذا لا تصلح أساساً للقول بنظرية أعمال السيادة في مصر.

٤ -لجأ البعض إلى المبدأ القائل بأن سلامة الدولة فوق القانون لتبرير أعمال السيادة، فقرر أن القانون ما هو إلا وسيلة لحماية الدولة، فإذا كان التمسك به سيكون على حساب سلامة الدولة فإنه يضحى بالقانون ويسمح للحكام بالخروج عليه في سبيل بقاء الدولة والمحافظة عليها.

كما قيل أن اخضاع أعمال السلطة التنفيذية جميعها للرقابة القضائية يجعل رجالها يترددون في تصرفاتهم باستمرار خشية المساءلة مما قد يضر سلامة الدولة وأمنها في بعض الظروف الهامة ولذا قيل بنظرية أعمال السيادة لتشجيع الحكام على التصرف دون خشية المسؤولية.

والواقع أن هذه المبررات قيل بها في تبرير نظرية الظروف الاستثنائية ولا داعي للخلط بين النظريتين، فمجال النظريتين مختلف تماماً، حيث تظل نظرية الظروف الإستثنائية في نطاق المشروعية وإن ترتب عليها توسيع نطاق المشروعية أما نظرية أعمال السيادة فتخرج تماماً عن دائرة المشروعية وتعد استثناءً عليها.

٥ -إعتبر البعض أن أعمال السيادة تتعلق بمسائل تحول المصلحة العليا و اعتبارات أمن الدولة من أن تلوّكها المخاصمات القضائية ويجب أن تظل بعيداً عن أروقة المحاكم، وهذا القول يعيدنا الى الأساس السياسي التقليدي النظرية والذي سبق ذكره.

ونحن نرى أنه لا يجب البحث عن أساس قانوني لنظرية أعمال السيادة فهي فكرة غير قانونية أصلاً وتعد خروجاً واستثناءً على مبدأ المشروعية فلا يمكن البحث لها عن أساس قانوني، وإنما هي نوع من السياسة القضائية دفعت إليه اعتبارات تاريخية خاصة بمجلس الدولة الفرنسي.

أما عدم رقابة القضاء على أعمال السلطة التنفيذية في الحالات المتبقية من نظرية أعمال السيادة فتجد تبريرها -كما سنرى- في القواعد العامة في الاختصاص.

المطلب الخامس موقف الفقه الحديث من النظرية

الرأى الأول: يذهب جانب من الفقه الحديث بحق - الى القول بأن نظرية أعمال السيادة لم يعد لها ضرورة وأن عدم خضوع الأعمال المتبقية التي يقال عنها أعمال سيادة للرقابة القضائية يرجع إلى القواعد العامة.

فالقواعد العامة تقضي بأن القاضي الاداري هو قاضي السلطة التنفيذية يخرج عن اختصاصه ما يمس السلطتين التشريعية والقضائية، كما أنه قاضي وطني يخرج عن اختصاصه أعمال السلطة التنفيذية في علاقتها بالسلطات الأجنبية. أما باقى تطبيقات النظرية فمشكوك فيها ومختلف عليها.^(١)

الرأى الثاني: بالمقابل فقد اكتفى جانب آخر من الفقه بالإنقاد الشديد للنظرية واعتبرها استثناءً بغيضاً على مبدأ المشروعية ونقطة سوداء في جبين المشروعية.^(٢)

بينما اكتفى البعض الآخر مع صراحة النصوص في مصر بالدعوة بأن يعمل القضاء على تضيق نطاق تطبيقها بالقدر الذي يقف بها عند الحدود الضرورية.^(٣) ونحن من جانبنا نؤيد ما انتهى اليه الرأى الأول وذلك لعدة اعتبارات يمكن إجمالها فيما يلي:

- ١- أن مجلس الدولة الفرنسي الذي أنشأ نظرية أعمال السيادة منذ البداية يلجأ الى صيغ عامة لا يمكن الإستناد إليها للقول بالابقاء على تطبيق هذه النظرية.
- ٢- أن أعمال السيادة بعد تضيق مجلس الدولة لها- لم تعد تشمل سوى الأعمال التي يمكن اخراجها عن نطاق اختصاص القضاء وفقاً لقواعد الاختصاص العادية وهي الأعمال المتعلقة بعلاقة الإدارة بالسلطات الأخرى التشريعية والقضائية والأعمال المتعلقة بالعلاقات الدولية والمنظمات الدولية.

^١ - الدكتور سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص ٢٦١ وما بعدها، راجع كذلك الاستاذ الدكتور/ محمد أنس قاسم جعفر، المرجع السابق، ص ٨٤.

^٢ - استاذنا الدكتور العميد سليمان الطماوى، الوجيز في القضاء الاداري، ١٩٧٠، ص ٢٨٠. الاستاذ الدكتور/ أنور رسلان، المرجع السابق، ص ١٤٦.

^٣ - الاستاذ الدكتور/ محسن خليل، المرجع السابق، ص ١٣٥.

أما القسم الثالث من أعمال السيادة المتعلق أغلبه بتدابير الأمن الداخلي فلا حاجة للإدارة بشأنه في التذرع بنظرية أعمال السيادة وإنما يكفيها الإستناد الى نظريات معترف بها كنظرية الضرورة والسلطة التقديرية ولعل في ذلك غنى عن التمسك بنظرية أعمال السيادة كاستثناء غير مرغوب فيه على مبدأ المشروعية.

٣- أن إخراج هذه الأعمال من نطاق الرقابة القضائية على أساس القواعد العامة في الإختصاص لا يمنع من خضوعها لصور أخرى من الرقابة كرقابة البرلمان وهذه تمتد الى مجال الملاءمة إضافة إلى مجال المشروعية.

٤- إذا كان التوجه الآن لدى الفقه المؤيد للنظرية هو الى الحد من آثار أعمال السيادة، عن طريق امكانية التعويض عن هذه الأعمال^(١)، فإن القول برد هذه الأعمال الى القواعد العامة في الاختصاص يحقق نتيجة أفضل لحقوق وحرريات الأفراد حيث تتجه الإتجاهات القضائية الحديثة لإخضاع سائر أعمال الدولة تشريعية أو قضائية أو إدارية لرقابة التعويض^(٢).

٥- أن هذا الرأي يعتبر أكثر اتفاقاً مع النصوص الدستورية في مصر حيث نصت المادة ٢/٦٨ من دستور ١٩٧١ على أنه "يحظر النص في القوانين على استبعاد أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء."

ولا يمكن الاحتجاج في هذا الصدد بنص المادة (١٧) من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم السلطة القضائية والمادة (١١) من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم مجلس الدولة لأن هاتين المادتين تعتبران غير دستوريتين لمخالفتهما صريح نص المادة ٢/٦٨ من الدستور السابق ذكرها^(٣).

٦- وإذا كان الدستور المصري يمنع على المشرع في المادة ٢/٦٨ أن ينص في القوانين على استبعاد أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء فإن هذا الالتزام ينصرف الى القاضي كذلك فلا يجوز له أن يخالف الدستور^(٤) لذلك أشرنا قبل ذلك

^١ - الأستاذ الدكتور/ أنور رسلان، المرجع السابق، ص ١٤٥ - ١٤٧.

^٢ - استاذنا الدكتور/ سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص ٢٤٩.

^٣ - من هذا الرأي الدكتور/ ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، ص ٨٣ وما بعدها.

^٤ - ولكن الواقع لم يتفق مع هذه الاعتبارات القانونية فنجد أن المحكمة العليا (حلت ملحقاً الآن المحكمة الدستورية العليا) والتي من اختصاصها كفالة احترام احكام الدستور، تجدها تعترف بأعمال السيادة في حكمها الصادر في

إلى أن عدم جواز تحصين أي عمل أو قرار إداري يعد من القواعد الدستورية بطبيعتها سواء نص عليه في الدساتير التالية له أو لم ينص .

المبحث الثاني

الظروف الاستثنائية

المطلب الأول

ماهية الظروف الاستثنائية

نشير ابتداءً أن فقهاء القانون يزعمون أن هذه النظرية من إبتداع القضاء الإداري الفرنسي، وهو غير صحيح ففقهاء الإسلام أول من أسس هذه النظرية وحدد ضوابطها وشروطها وجعلها الوجه الآخر للمشروعية.

وتقتضي نظرية الظروف الاستثنائية أن بعض الإجراءات الإدارية التي تعتبر غير مشروعة في الأوقات العادية يمكن اعتبارها اجراءات مشروعة في الظروف الاستثنائية، إذ تكون ضرورية لحماية النظام العام أو لاستمرار سير المرافق العامة. وتختلف نظرية الظروف الاستثنائية عن نظرية أعمال السيادة، فبينما تخضع قرارات السلطة التنفيذية الصادرة في ظل الظروف الاستثنائية إلى قواعد المشروعية بعد توسيعها، فإن القرارات المسندة إلى نظرية أعمال السيادة تستثنى تماماً من الرقابة القضائية إلغاءً تعويضاً.

فالإدارة لا تخرج على مبدأ المشروعية في حالة الظروف الاستثنائية، فمبدأ المشروعية قائم بصفة دائمة سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية كما يتم تطبيقه بقدر كبير من المرونة.

ويرجع اللجوء الى نظرية الظروف الاستثنائية الى أن مناط الزام الإدارة باحترام مجموعة القواعد القانونية المطبقة في المجتمع هو الظروف العادية، لكن اذا طرأت ظروف استثنائية كحدوث حرب أو اشتعال فتنة أو ظهور كارثة أو انتشار وباء، فإن القواعد القانونية العادية تعجز عن مواجهة هذه الظروف، ولذا تمنح الإدارة سلطات واسعة فتتخذ من التدابير والإجراءات السريعة والحاسمة ما يدفع

الخطر عن البلاد، فمن غير المقصود مثلاً أن تتبع الإجراءات المعقدة للإستيلاء على مال للمصلحة العامة إذا كانت البلاد معرضة لخطر محقق.

فلا شك أن التقيد بصرامة مبدأ المشروعية خلال الظروف الإستثنائية سيؤدي إلى نتائج ضارة بالدولة بأسرها، وهنا تتم المفاضلة بين المصلحة الخاصة لصاحب الشأن والتي يحققها الإلتزام بمبدأ المشروعية، وبين المصلحة العامة في دفع الضرر عن الدولة بأسرها، فيتم تغليب المصلحة العامة.

ولذا نجد القضاء في ظل الظروف الاستثنائية يعترف للإدارة بمشروعية بعض الأعمال كان يعتبرها غير مشروعة في الظروف العادية ومن أمثله ذلك:

- اعترف مجلس الدولة الفرنسي بمشروعية إجراءات ماسة بالحرية الفردية كالقبض والطرء والحجز صدرت بالمخالفة للوائح البوليس العادية.

- اعترف مجلس الدولة الفرنسي بمشروعية فرض بعض الرسوم التي فرضت فوق الحدود المنصوص عليها لمواجهة الأعباء المالية الناجمة عن غزو الألمان عام ١٩٤٠. اعترف بمشروعية قرارات إدارية بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضى به إذا كان سيقرب على تنفيذها إخلال خطير بالأمن.

ومثاله في فرنسا ما قضى به مجلس الدولة في قضية كوبيتاس^(١) بمشروعية امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم بملكية أراضي زراعية في تونس بعدم تمكين المالك من وضع يده عليها حيث سيقرب على ذلك إخراج وطرء الأهالي التونسيين المقيمين بهذه الأراضي مما قد ينتج عنه فتنة وهياج يخل بالأمن.

ومن جانبها قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه لئن كان لا يجوز للقرار الإداري في الأصل أن يعطل تنفيذ حكم قضائي وإلا كان مخالفاً للقانون، إلا أنه إذا كان سيقرب على تنفيذه فوراً إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه كحدوث فتنة أو تعطيل سير مرفق عام فيرجح عندئذ الصالح العام على الصالح الفردي الخاص ولكن بمراعاة أن تقدر الضرورة بقدرها^(٢).

^١ - C.E. 30-11-1923 Coultess S. 1923 III 57.

^٢ - حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم ٧٢٤ لسنة ٣، المجموعة، م ٤، ص ٥٢٣.

المطلب الثاني

مصدر نظرية الظروف الاستثنائية

تتم مواجهة الظروف الإستثنائية إما بنصوص تشريعية خاصة، وأما بنظريات قضائية تكمل هذه النصوص من أجل تمكين السلطات العامة من مواجهة الخطر.

أولاً : النصوص التشريعية:

يواجه المشرع المصري الظروف الإستثنائية بعدة تشريعات مثل قانون التعبئة العامة وقانون الأحكام العرفية وقانون الدفاع المدني، كما ينص المشرع الدستوري على بعض الصلاحيات لرئيس الدولة الذي هو رئيس السلطة التنفيذية للتدخل بإجراءات معينة في الظروف الإستثنائية ويتضح ذلك في الحالات الآتية:

١ - حالة الطوارئ:

نصت المادة ١٥٤ من دستور ٢٠١٤ على أن "يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه ، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادة وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض الأمر على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له "وهو ما نصت عليه المادة ١٥٦ من دستور ٢٠١٤ .

٢ - حالة الاستعجال:

نصت المادة ١٤٧ من دستور ١٩٧١ على سلطة رئيس الجمهورية اذا طرأت ظروف استثنائية في حالة غيبة البرلمان أن يتخذ إجراءات عاجلة بموجب قرارات يكون لها قوة القانون وهو ما نصت عليه المادة ١٥٦ من دستور ٢٠١٤ .

٣ - حالة الأزمة:

أجازت المادة ٧٤ من دستور ١٩٧١ في حالة حدوث خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ

الإجراءات العاجلة اللازمة لمواجهة الخطر، وعلى رئيس الجمهورية أن يوجه بياناً للشعب ويجري استفتاءً شعبياً على ما اتخذته من إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها. ولم ترد هذه الحالة في دستور ٢٠١٤.

ثانياً : النظريات القضائية:

يبدو دور القضاء في مجال مواجهة الظروف الإستثنائية أعمق من دور المشرع، فالتشريعات مهما توسعت فإنها لا تواجه كل الحالات التي تظهر في الواقع العملي ويتصدى لها القاضي.

أن القضاء يتولى تغطية العجز وتكملة النقص الذي يتكشف له عند تطبيق النصوص التشريعية المعدة لمواجهة الظروف الإستثنائية.

حيث يقوم القاضي خلال عمله بالموازنة بين ضرورة مواجهة الخطر الناشئ عن الظرف الإستثنائي، وبين الحفاظ على حقوق وحريات الأفراد.

المطلب الثالث

أساس نظرية الظروف الإستثنائية ونطاقها

أولاً: أساس النظرية

رد القضاء نظرية الظروف الاستثنائية إلى أساسين:

الأول: أن المشرع وضع القوانين لتطبيق في الظروف العادية أما إذا طرأت ظروف استثنائية ثم أجبرت الإدارة على تطبيق النصوص العادية، فإن ذلك يؤدي حتماً إلى نتائج غير مستساغة تتعارض حتى ونية واضعي تلك النصوص العادية....." (١)

فالقواعد العادية وضعت لتطبق في الظروف العادية، أما إذا تغيرت الظروف وحلت ظروف استثنائية فإنه يجب أن تحكمها قواعد غير عادية بما يمكن من السيطرة عليها.

الثاني: أن وظيفة القانون هي حماية الدولة فإذا أدى تطبيق القانون الى فناء الدولة فانه يضحى بالقانون وذلك بالتخفيف من بعض القيود التي يفرضها في سبيل

^١ - حكم المحكمة الادارية العليا في ١٤/٢/١٩٦٢، المجموعة، س٧، ص ٦٠١.

المحافظة على الدولة، فغاية مبدأ المشروعية يتطلب أولاً وقبل كل شئ العمل على بقاء الدولة، الأمر الذي يستتبع تخويل الحكومة استثناء، وفي حالة الضرورة، من السلطات ما يسمح لها باتخاذ الاجراءات التي يتطلبها الموقف ولو خالفت في ذلك القانون في مدلوله اللفظي، ما دامت تبغى الصالح العام^(١).

وقد رد بعض الفقهاء نظرية الظروف الاستثنائية الى وجود مبدأ عام في القانون يفرض على السلطات العامة عدم تطبيق القوانين العادية في هذه الظروف وإنما يتم مواجهة هذه الظروف بما تقتضيه من إجراءات^(٢).

والحقيقة أن نظرية الظروف الاستثنائية تجد أساسها في فكرة الضرورة والتي هي الوجه الثاني للمشروعية والذي أقرته الشريعة الإسلامية، حيث عرفت وجهين من المشروعية:

١- **العزائم:** وهي المشروعية العادية وتطبق في الظروف العادية ويلتزم بها الجميع حكماً ومحكومين.

٢- **الرخص:** وتمثل المشروعية الاستثنائية، وهي ما شرع لعذر مع قيام السبب المحرم وهو ما يبرر للسلطة العامة إصدار القرارات التي توجبها الضرورة^(٣).

وقد جمع وجهي المشروعية الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتي رخصه كما يجب أن تؤتي عزائمه فلا يؤتى المسلم - حاكماً كان أو محكوماً عملاً إلا إذا كان مشروعاً مما استوجب أن يكون للضرورة حكمها الشرعي الخاص بها^(٤).

ثانياً : نطاق نظرية الظروف الاستثنائية:

يتسع نطاق نظرية الظروف الإستثنائية ليشمل كافة الواجبات المفروضة على السلطة التنفيذية في مجال سير المرافق العامة والمحافظة على النظام العام.

^١ - حكم المحكمة الإدارية العليا السابق الاشارة اليه.

^٢ - الأستاذ الدكتور/ محمود حلمي، المرجع السابق، ص ٢٥.

المطلب الرابع **: شروط قيام حالة الظروف الاستثنائية**

يتعين أن تتوفر الشروط الآتية :

١ - قيام حالة واقعية غير مألوفة: يكون من شأن تطبيق القواعد القانونية العادية عليها تهديد خطير للأمن أو لسير المرافق العامة (ومن أمثلة هذه الحالات: حالة الحرب - الفتنة الداخلية- الزلازل أو البراكين أو الكوارث الطبيعية عموماً...) وغيرها لذلك يتعين أن تكون الضرورة حالة وقائمة بالفعل أو الشواهد كلها تؤدي إلى وقوعها لا محالة .

ولا يشترط أن تكون هذه الحوادث مؤكدة الوقوع بل يكفي احتمال وقوعها، مما يبرر الاستعداد لتلافي آثارها أو الوقاية منها، كما لا يشترط أن تكون الحادثة شاملة لكل إقليم الدولة، بل يكفي وقوعها في جزء منها وفي هذه الحالة يقتصر تطبيق النظرية على هذا الجزء من إقليم الدولة.

٢ - **تعريض المصالح العامة للخطر:** يجب أن يكون من شأن تطبيق الاجراءات العادية على الحالة الاستثنائية تعريض المصالح العامة للخطر. وللقاضي أن يتحقق من وجود هذا الخطر.

وقد قضت المحكمة الادارية العليا بأن الحاجة الملحة الى مبان تعليمية تستوعب طلاب المرحلة الأولى كانت وراء قرار الحاكم العسكري بالاستيلاء على العقار موضوع المنازعة ولولا هذا الاجراء لتعطل الطلبة عن الاستمرار في دراستهم، مما كان سيؤدي الى اضطراب سير مرفق التعليم الذي يعد من المرافق الهامة التي يجب العمل على سيرها بانتظام واضطراك حتى يستتب الأمن العام ويتوفر الشعور بالطمأنينة لدى الجمهور.^(١)

٢- أن تعجز الإدارة بوسائلها العادية عن مواجهة الظروف غير العادية، وأن يتعذر على الإدارة اتباع القواعد المألوفة في الظروف العادية، بحيث تعتبر الوسائل غير العادية هي الوسائل الوحيدة للتغلب على الظروف الاستثنائية ولا تستطيع الإدارة

٢- للمؤلف نظرية الضرورة في القانون العام الإسلامي الزهراء للإعلام العربي ١٩٨٦ م

تأجيل التصرف الى أن يتم زوال الظروف غير العادية دون أن تتعرض المصالح العامة للخطر، وباختصار يشترط أن يكون تصرف الادارة ضرورياً ولازماً لمواجهة الحالة الإستثنائية بوصفه الوسيلة الوحيدة.^(١) أن تقدر الضرورة بقدرها بمعنى أن الخروج على المشروعية العادية يكون بالقدر اللازم لمواجهة الظرف الإستثنائي .

المطلب الخامس

ضوابط تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية لا يعني قيام حالة الظرف الإستثنائي وتوسيع قواعد المشروعية بناءً عليه أن تطلق يد الإدارة تفعل ما تشاء لما في ذلك من خطورة على حريات وحقوق الافراد، ولذا وضعت عدة ضوابط أهمها:

- ١- أن يتناسب الإجراء الإستثنائي الذي تلجأ اليه الإدارة من حيث شدته مع خطورة الظرف الإستثنائي، بمعنى أن تقدر الضرورة بقدرها فلا تمارس الإدارة السلطات الإستثنائية إلا بالقدر وفي الحدود التي تتطلبها المصلحة العامة.
- ٢- ملائمة الإجراء الإستثنائي، وهي مسألة موضوعية تختلف باختلاف الظروف.
- ٣- أن تكون ممارسة الإدارة للوسائل غير العادية موقوتة بمدة وجود الظرف الإستثنائي.

النتائج المترتبة على الظروف الاستثنائية:

إذا توفرت شروط الظرف الإستثنائي يترتب على ذلك ما يلي:

١- إمكانية اصدار قرارات إدارية تفنقذ إلى ركن أو أكثر من أركان القرار الإداري (الإختصاص الشكل المحل) دون أن يؤدي ذلك إلى بطلان القرار أو انعدامه **ومن الأمثلة على ذلك:**

- اعتراف مجلس الدولة الفرنسي بمشروعية قرار إداري مشوب بعيب عدم الإختصاص أصدرته السلطة الإدارية بينما هو من اختصاص المشرع نظراً لصدوره إثر غزو الحلفاء سواحل فرنسا عام ١٩٤٤.

^١ - قضت محكمة القضاء الاداري بإلغاء قرار محافظ سيناء باعتقال أحد الاشخاص لإتهامه في بيع أجهزة الراديو للمواطنين بطريقة فيها استغلال لهم واحتيال عليهم مستندة في ذلك الى أنه كان يمكن للجهة الادارية حماية المواطنين من اعمال هذا الشخص باتباع الوسائل التي تنص عليها القوانين المعدة للظروف العادية. فاللجوء الى الاعتقال وهو من السلطات الاستثنائية يجب عدم اللجوء اليه الا اذا أملت الظروف الاستثنائية التي لا تحدى معها وسائل البوليس المعروفة.

- اعتراف مجلس الدولة الفرنسي بمشروعية قرار أصدره أحد المديرين عام ١٩٤٠ بإيقاف أحد العمد دون مراعاة الإجراءات القانونية أي بالمخالفة للقواعد الشكل لكن يجب على الإدارة في كل حالة حتى في ظل الظروف الإستثنائية - أن تكون الغاية من قراراتها تحقيق الصالح العام، كما يجب أن تقوم قراراتها على سبب صحيح وإلا كانت باطلة.

٢ - الاعتراف بتصرفات الموظف الفعلي:

قد يحدث أثناء الظروف الإستثنائية (كحرب أو أزمة) أن يضطر بعض الموظفين إلى ترك أعمالهم أو يحال بينهم وبين القيام بها، ولدوام سير المرفق العام فإن بعض الأفراد العاديين قد يتدخلون للقيام بهذه الأعمال وهؤلاء يسمون الموظفون الفعليون. ورغم أن هؤلاء الموظفين الفعليين ليس لهم صفة قانونية حيث لم يتم تعيينهم كموظفين بصفة رسمية إلا أن القضاء اعترف بصحة الأعمال التي قاموا بها فيما عرف بنظرية الموظف الفعلي.

٣ - تعطيل تنفيذ بعض القوانين لبعض الوقت: فقد تضطر السلطة العامة لتعطيل تنفيذ بعض القوانين مؤقتاً تحت تأثير الظروف الإستثنائية، وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة ومن ذلك:

- وقف بعض الضمانات المقررة للموظفين العموميين بشأن المساءلة التأديبية^(١)
- الإستيلاء مؤقتاً على العقارات بالمخالفة للتشريعات السائدة^(٢).
- وقف إصدار بعض الصحف.

المطلب السادس

الرقابة على أعمال الإدارة في الظروف الاستثنائية

أولاً شروط الرقابة الفعالة على الأعمال الاستثنائية:

- ١ - أن تكون الرقابة في وقت معاصر تقريباً لاستخدام السلطة الإستثنائية وذلك لضمان فعاليتها.

^١ - حكم مجلس الدولة الفرنسي في ١٩١٨/٦/٢٨، المجموعة، ص ٦٥١.
^٢ - حكم مجلس الدولة الفرنسي في ١٩٦٨/٥/٢٤، المجموعة، ص ٣٢٩. حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ ١٩٦١/٥/١٣، المجموعة، ص ٦، ٣٤، ص ٢١٠.

- ٢ - أن يكون هناك جهاز رقابي فعال حتى لا تستغل الإدارة هذه الظروف في تجاوز سلطاتها والاعتداء على الحقوق والحريات العامة .
- ٣ - إمام الجهاز الرقابي بالحقائق السياسية التي دفعت السلطة التنفيذية لاتخاذ الاجراءات الاستثنائية.

ثانياً أنواع الرقابة على الأعمال الاستثنائية:

١-رقابه سياسية (برلمانية):

- من المتصور وجود رقابة سياسية من قبل البرلمان على أهم الاعمال الاستثنائية وهي لوائح الضرورة، ورقابة البرلمان هنا منطقية لأن لوائح الضرورة تصدر في النطاق الذي يتم تنظيمه أصلا بقانون والرقابة البرلمانية إما أن تكون سابقة أو لاحقة.
- وتتمثل الرقابة السابقة للبرلمان في اشتراط الحصول على إذن من البرلمان للسلطة التنفيذية في اصدار اللائحة وهو ما يسمى باللوائح التفويضية.
- لكن هذا الإذن غير كاف لأنه يتم قبل الإجراء وإن كان يشكل أول مراحل الرقابة أما الرقابة اللاحقة فتتم بإحدى صورتين:
- أ- إقرار البرلمان للقوانين التي تصدر في غيبة البرلمان -لوائح الضرورة-، وهذا الإقرار يصبح روتينياً وخالياً من كل مظاهر الرقابة لأنه يأتي بعد زوال الظروف الإستثنائية فلا مجال لإلغاء التدابير المتخذة أو تعديلها.
- ب- تصديق البرلمان على لوائح الضرورة، وهذا التصديق إما أن يكون بالموافقة، وإما أن يكون بالتعديل كتخفيض المدة التي تسرى فيها اللائحة. ورفض التصديق لا يمنع من بقاء بعض الآثار في الماضي وهي تلك التي يستحيل محوها.
- عيوب الرقابة البرلمانية في الحالات الاستثنائية:** يمكن القول بأنها رقابة قليلة الجدوى من الناحية العملية حيث انتقدت من عدة أوجه:
- ١- أن جدية الرقابة البرلمانية تتوقف على قدرة أعضاء البرلمان وإمكانيتهم مواجهة الحكومة من عدمه.
- ٣- لا يسعى البرلمان الا لتحقيق مصالحه البرلمانية ولا يلتزم بجدية الرقابة خاصة مع عدم اشتراط ضرورة التصديق.

٤- تلجأ الحكومة الى اصدار عدد كبير من هذه اللوائح في حالة الضرورة ويصعب ممارسة هذه الرقابة خاصة إذا أحالت الحكومة هذا العدد الكبير من اللوائح في وقت واحد ما يصعب معه مراجعتها جيداً والإضطرار إلى موافقه عليها.

٥- إن رفض تصديق البرلمان على اللوائح لا يؤتي ثماره عملاً إلا بالنسبة للمستقبل، ومع ذلك فإن هذا يكون قليل الجدوى لأن معظم هذه اللوائح يكون مؤقتاً ينتهي العمل به عند انتهاء الظروف الإستثنائية التي تحدث غالباً قبل التصديق.

٦- إن فكرة الأثر الرجعي للتصديق لا تصلح إلا بالنسبة للوائح التفويضية كما أن التصديق لا يتحقق إلا بعد تنفيذ اللائحة في مواجهة المواطنين. وقد يعطى الدستور لوائح الضرورة القيمة القانونية منذ اصدارها فلا يكون هناك أي أثر عملي للتصديق.

٢ - الرقابة القضائية على الأعمال الاستثنائية:

يجمع الفقه على أن الرقابة الفعالة على الاعمال الاستثنائية هي الرقابة القضائية. والرقابة القضائية المتصورة هنا هي الرقابة بنوعيتها (الإلغاء والتعويض) ففي حالة مخالفة العمل الإستثنائي للضوابط المشار إليها فإنه يكون عرضة لإلغائه والتعويض عنه.^(١)

إلا أنه لا يمنع الاعتراف بمشروعية عمل من أعمال الإدارة في الظروف الاستثنائية من إمكانية التعويض عنه.^(٢)

ولتفهم مدى الرقابة القضائية على لوائح الضرورة -والتي هي أهم وسائل الإدارة لمواجهة الظروف الإستثنائية- يجب التمييز بين القوة القانونية لللائحة وطبيعتها القانونية كعمل إداري صادر عن جهة الإدارة.

وبناءً على المعيار الشكلي (الراجح فقهاً وقضاءً) تخضع لوائح الضرورة لرقابة القضاء الإداري بإعتبارها عملاً إدارياً، ويفحص القاضي جوانب اللائحة المختلفة لتبين مشروعيتها من عدمه، فإذا شابها عيب من العيوب تصبح غير مشروعة ويحكم القضاء بإلغائها.

^١ - للحاكم العسكري سلطة تقديرية في ظل الأحكام العرفية، لكن يجب الإلتزام بحدودها الدستورية وألا تتغول خاصة على الحريات الفردية بدون مبرر، وإلا شاب تصرفاته عدم المشروعية وانبسطت عليه رقابة القضاء الإداري الغاء وتعويضاً" (حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم ١٥١٧ لسنة ٢٠٠٢ق).

ويأتي دور الظروف الإستثنائية في تقرير مدى امكانية مخالفة اللائحة لنص قانوني قائم، وهنا تبدو أهمية القوة القانونية التي تتمتع بها هذه اللوائح، فهي لها قوة القانون وبالتالي يمكن أن تخالف أي قانون قائم دون أن يؤثر ذلك على مشروعيتها. فهذه اللوائح التي تصدر عن الإدارة في الظروف الإستثنائية وتطبيقاً لنصوص الدستور هي أعمال إدارية لذا فإنها تخضع لرقابة القضاء، وهي في ذات الوقت لها قوة القانون فيمكن أن تعدل نص قانوني أو تلغيه دون أن يؤثر ذلك على مشروعيتها.

عيوب الرقابة القضائية:

- تنصب هذه الإنتقادات على السياسة القضائية التي يتبعها القضاء، ذلك أن القضاء نفسه يساهم في إضعاف رقابته عن طريق:
- أ- اعتباره بعض هذه التدابير الإستثنائية من أعمال السيادة فيخرجها تماماً من رقابته.
 - ب- يفسر بعض النصوص التي تسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل تفسيراً واسعاً.
 - ج - يرفض القضاء أحياناً الرقابة على توافر صفة الضرورة بدعوى أنها من الأمور التقديرية للإدارة.
 - د- يرفض القضاء الطعن في اللوائح التي تم التصديق عليها من البرلمان، رغم ماسبق ذكره من أن هذا التصديق لا يغير من طبيعتها كعمل إداري.
- وعلى أية حال فإن من الأنسب لتحقيق أكبر قدر من فعالية الرقابة على الأعمال الإستثنائية أن يتم الجمع نوعي الرقابة (السياسية والقضائية) وعلى قدم المساواة فيما بينها، بحيث تراقب الأولى مدى الملائمة السياسية للعمل الإستثنائي بينما تراقب الثانية مدى مشروعيته.

المبحث الثالث

السلطة التقديرية

Le pouvoir discrétionnaire

المطلب الأول

ماهية السلطة التقديرية

إذا كان مقتضى مبدأ المشروعية احترام القانون من الجميع حكماً ومحكومين، فتخضع كافة سلطات الدولة للقواعد القانونية المطبقة وتمارس الإدارة عملها في

اشباع الحاجات العامة للمواطنين في اطار من أحكام القانون بالمعنى الواسع، ولكن القانون لا ينظم عمل الإدارة على وتيرة واحدة في جميع الحالات.

فأحياناً يلزم القانون الادارة بالتصرف على نحو محدد دون أن يترك لها حرية الاختيار وإنما يضع لها أهم الشروط اللازمة لتصرفها ويلزمها بالتدخل عند توافر الشروط فهنا تكون سلطة الإدارة مقيدة. (Pouvoir lié)

ومثال السلطة المقيدة حالة الترقية بالأقدمية المطلقة لقدامى العاملين ممن قضوا مدداً معيناً في درجاتهم فتتم الترقية تلقائياً إذا توافرت شروطها دون تدخل من الإدارة لتقدير ملائمة أو عدم ملائمة الترقية، كما أن من امتثلتها حالة منح الرخص التي يضع القانون لها شروطاً معينة لمنحها فتلتزم الادارة بمنح الرخصة بمجرد توافر هذه الشروط.

ولكن في حالات أخرى يراعى المشرع أن يمنح الإدارة قدراً من حرية التصرف، سواء بالنسبة للتدخل أو عدم التدخل أو أسباب التدخل أو وقت التدخل أو مضمون القرار أو شكله.

وتكون الإدارة في كل هذه الحالات ذات سلطة تقديرية (Pouvoir discretionnaire) ومثالها حالات الترقية بالاختيار التي لا يقيد بها القانون بضوابط معينة.

ولا شك أن لجوء المشرع الي أي من الأسلوبين تحكمه اعتبارات معينة تملئها المصلحة العامة فتدفع المشرع إلى منح السلطة المقيدة اعتبارات الرغبة في حماية الأفراد من تعسف الإدارة، بينما يمنح المشرع الإدارة السلطة التقديرية في الحالات التي تحتاج خبرة الإدارة وظروف تطورها المستمر.

فالسلطة التقديرية تتحقق في كل حالة يتخلل فيها المشرع عن تنظيم جانب من جوانب الموضوع أو عنصر من عناصره تاركاً إياه للإدارة، فالمشرع هو الذي يقدر ما إذا كان من الأنسب للمصلحة العامة ان يقيد سلطة الإدارة أو أن يترك لها قدراً من حرية التصرف.

فالسطة التقديرية وسيلة لتطبيق القانون شأنها شأن السلطة المقيدة تماماً فهي ليست استثناءً على مبدأ المشروعية أو لموازنته كما يذكر الفقه عادة. والملاحظ أننا نجد السلطة التقديرية تضيق وتتسع وفقاً لما تضعه القواعد القانونية من حدود السلطة الإدارية تباشر اختصاصها في نطاقها.

ولتوضح مجال السلطة المقيدة والتقديرية في الأمثلة التقليدية الخاصة بمنح الرخص ونظام الترقية ونظام التأديب.

ففي مثال منح الرخص: نجد أنه إذا حدد القانون شروطاً معينة لمنح الرخصة وألزم الإدارة بمنحها عند توافر هذه الشروط فإن سلطة الإدارة تكون مقيدة، أما إذا حدد شروط منح الترخيص فقط لكنه لم يلزمها بمنح الترخيص عند توافر الشروط فإن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في منح الرخصة أو عدم منحها إلا أنها إذا اختارت منحها فإن عليها الإلتزام بالشروط التي حددها المشرع. وهنا تكون سلطة الإدارة تقديرية من حيث المنح وعدم المنح ومقيدة من حيث وجوب مراعاة الشروط التي فرضها القانون في حالة المنح.

وفي مجال الترقية:

فإنه في الحالات التي تتم فيها الترقية بالأقدمية المطلقة يحدد القانون لها شروط الترقية فتكون الإدارة مقيدة بحيث يجب عليها ترقية كل موظف يتوافر في حقه شروط الترقية التي حددها القانون (كمدة الخدمة - درجة تقارير الكفاية - وجود درجة مالية خالية....).

أما الحالات التي تتم منها الترقية بالإختيار فتكون الإدارة مقيدة فقط بالقيود التي قد يوردها القانون كاختيار وقت الترقية ولكن تكون لها السلطة التقديرية في العناصر الأخرى كاختيار أكفأ الموظفين وأفضلهم أداء.

وفي مجال التأديب:

نجد مثلاً أن قانون الخدمة المدنية في الدولة أورد نصاً على سبيل الحصر بالعقوبات التي يمكن توقيعها على الموظف (الإنذار - الخصم من الراتب...) وبناءً

على ذلك فإن السلطة التأديبية مقيدة بألا توقع عقوبة غير العقوبات المنصوص عليها في القانون.

ولكن القانون لم يحدد العقوبة التي توقع في حالة ارتكاب كل جريمة تأديبية وإنما ترك للسلطة التأديبية اختيار العقوبة المناسبة لجريمة التأديبية.

فالسلطة التأديبية تتمتع بسلطة مقيدة فيما يتعلق بالتزامها بعدم توقيع أي عقوبة غير العقوبات التي نص عليها القانون ولكنها من جهة أخرى تتمتع بسلطة تقديرية في اختيارها للعقوبة المناسبة للجرم من بين العقوبات المنصوص عليها قانوناً.^(١)

المطلب الثاني **حدود السلطة التقديرية**

يحتوى كل عمل من الأعمال الإدارية على قدر من السلطة التقديرية وقدر من السلطة المقيدة فلا يوجد عمل يحتوى على سلطة تقديرية مطلقة ولا سلطة مقيدة خالصة.

وإنما كل ما في الأمر أنه يختلف مدى كل من هاتين السلطتين المقيدة أو التقديرية داخل العمل الواحد ويطلق على العمل أن الإدارة تتمتع بصده بسلطة تقديرية أو سلطة مقيدة بحسب القدر الغالب الأعم من التقييد أو التقدير .
ولتحديد مجال السلطة التقديرية في القرار الإداري فإنه يتم تحليله الى عناصره الأساسية الخمسة (الاختصاص - الشكل - الغاية - السبب - المحل) البحث عناصر التقييد والتقدير في كل منها:

بالنسبة لعنصر الاختصاص: فإنه لا مجال للسلطة التقديرية في تحديد اختصاص الإدارة، وإنما يتم تحديد هذا الاختصاص قانوناً وعلى وجه الدقة، بل أن

^١ - وإن كان القضاء الإداري في مصر قد تدخل بفرض قيد على سلطة الجهة التأديبية التقديرية في اختيارها العقوبة، وذلك باشتراط عدم الغلو في تقدير العقوبة (حكم المحكمة الإدارية العليا الشهير في ١١/١١/١٩٦١ في القضية رقم ٥٦٣ لسنة ٧ق، المجموعة، س٧، ص٢٦)، ويعد ذلك مثلاً على تدخل القضاء لتصديق السلطة التقديرية للإدارة وتوسيع السلطة المقيدة، فنتقيد سلطة الإدارة بفرض بعض القيود على تصرف مصدره القانون بصفة عامة، وليس فقط النصوص التشريعية (القوانين واللوائح) وإنما يتدخل القضاء الإداري ويضع قيداً أو أكثر على سلطة الإدارة تطبيقاً لأحد المبادئ العامة في القانون فيساهم بذلك في نقل إجراء ما من الاختصاص التقديري الى الاختصاص المقيد للإدارة.

قواعد الإختصاص من النظام العام لا يجوز الإتفاق على ما يخالف نفس القانون بشأنها.

بالنسبة لعنصر الشكل : فإن الأمر يتوقف على تحديد القانون لشكل أو لإجراءات معينة يلزم اتباعها، فهنا تكون سلطة الإدارة بالنسبة لها مقيدة. أما اذا لم يحدد القانون شكلاً معيناً أو اجراءات معينة يلزم اتخاذها فإن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية حيالها وبالتالي تكون حرة في اختيار الشكل أو الإجراءات التي ترى اتباعها .

بالنسبة لعنصر الغاية (الهدف) : لا خلاف على أن هدف الادارة من تصرفها يجب أن يكون المصلحة العامة دائماً، وقد يلزمها المشرع بهدف محدد في حالة تخصيص الأهداف وفي هذه الحالة تكون سلطة الادارة مقيدة بتحقيق ذلك الهدف ولا يغنيها تحقيق هدف آخر ولو كان هذا الهدف يتعلق بالمصلحة العامة. أما في الحالات التي لا يتولى فيها المشرع تخصيص هدف معين لكل قرار على حده فإنه يجب أن يكون رائد الإدارة في تصرفها المصلحة العامة وإلا كان قرارها مشوباً بالإنحراف بالسلطة أو إساءة استعمال السلطة.

بالنسبة لعنصر السبب : تلتزم الإدارة بأن تكون قراراتها مبنية على أسباب صحيحة واقعاً وقانوناً، فلا مجال للسلطة التقديرية فيما يتعلق بصحة وجود السبب الذي تدعيه الإدارة، فيراقب القضاء مدى صحة الوقائع التي كانت سبباً في اصدار القرار الإداري^(١) ويلغى القرار إذا استند لسبب أو واقعة غير صحيحة ومثاله توقيع عقوبة على موظف دون أن يرتكب أى ذنب إداري^(٢).

كما يراقب القضاء الإداري مدى صحة التكييف القانوني للوقائع التي استندت اليها الإدارة في اصدارها للقرار الإداري، وذلك للوقوف على ما إذا كانت هذه الوقائع توصل الى القرار الذي تم اصداره أم لا.

^١ - حكم المحكمة الإدارية العليا في ١٩٦٧/٢/٢٥، المجموعة، س١٢، ص٦٧٩.
^٢ - حكم المحكمة الإدارية العليا في ١٩٥٨/١/٢٥، المجموعة، س٣، ص٦٣٥. وفيه تقول المحكمة " ... وإذا انعدم المأخذ على السلوك الإداري للموظف فلا يكون ثمة ذنب إداري، وبالتالي فلا محل لجزاء تأديبي لفقدان القرار في هذه الحالة لركن من أركانه".

فالقضاء الإداري يبحث هل الوقائع التي استندت إليها الإدارة -على فرض وجودها مادياً - توصل الى النتيجة التي يتطلبها القانون أم لا.

فحين ترفض الادارة منح ترخيص بفتح محل عام لقربه من مكان للعبادة فإن القضاء الدارى يراقب مسألة القرب أو البعد من مكان العبادة، ويقف القضاء عند هذا الحد بالنسبة لركن السبب فلا يتدخل في تقدير مدى خطورة السبب وما يمكن أن يترتب عليه من آثار.^(١)

بالنسبة لركن المحل

ومحل القرار الإدارى هو الأثر القانوني الذي يترتب على القرار الإداري حالاً ومباشرة.

وتبدو السلطة التقديرية واضحة فيما يتعلق بمحل القرار فتملك الإدارة سلطة تقديرية بشأن:

- التدخل أو عدم التدخل (كحالة ارتكاب الموظف لخطأ تأديبي لكن ترى الإدارة عدم مجازاته لسبب أو لآخر).
- اختيار وقت التدخل (كحاجة الإدارة لتعيين عدد من الموظفين ولكنها ترى إرجاء ذلك لوقت لاحق).
- تحديد مضمون القرار (كتحديد عدد الموظفين الذين تشملهم حركة الترقيات أو التنقلات).

المطلب الثالث

رقابة القضاء على السلطة التقديرية

لا شك أن الهدف من تقرير السلطة التقديرية هو منح الإدارة قدرً من المرونة وحرية التصرف حتى تواجه متطلبات الحياة الإدارية وتطورها المستمر، ولقد فهم من ذلك في البداية أن مقتضى تمتع الإدارة بالسلطة التقديرية أن تكون بمنأى عن الرقابة القضائية والتي تقتصر على السلطة المقيدة فوجدت نظرية الأعمال التقديرية (Les ctes discretionnaires) وكان مقتضاها وجود عدد من الأعمال الإدارية لا تخضع لأي نوع من الرقابة القضائية.

^١ - حكم المحكمة الإدارية العليا في ١٢/٢٦/١٩٦٧، المجموعة، من ١٣، ص ٢٨٣

ولكن هذه النظرية اختلفت تماماً منذ فترة طويلة ولعل المرجع في اختفائها هو ما ذكرناه منذ قليل من أنه لا يوجد عمل تقديري بحت وإنما يحمل كل قرار إداري في كيانه عناصر تقييد و عناصر تقدير على النحو الذي رأيناه عند تحليل عناصر القرار الإداري .

فعنصر الإختصاص كما رأينا في كل قرار اداري هو من عناصر التقييد التي يحددها المشرع بدقة وبالتالي يخضع للرقابة القضائية.

أما عنصر الهدف فيخضع لرقابة القضاء باعتبار أن كل قرار إداري يجب أن يكون هدفه الصالح العام، كما رأينا أن القضاء يراقب الوجود المادي للوقائع في عنصر السبب فيتأكد من أن الأسباب قائمة وأنها مطابقة للحقيقة والواقع ويراقب كذلك التكيف القانوني للوقائع. كما يراقب القضاء قواعد الشكل والإجراءات التي يفرضها القانون.

فالعناصر السابقة تخضع جميعها لرقابة القضاء في كل قرار إداري^(١) أما عناصر السلطة التقديرية فلا تخضع لرقابة القضاء الإداري وذلك لعدم خبرة القاضي الإداري في هذا المجال، إضافة الى أن رقابته للسلطة التقديرية تجعله بمثابة رئيس أعلى لرجل الإدارة مما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.

المشروعية - الملاءمة:

مشروعية القرار الإداري (أو تصرف الإدارة عموماً هي مدى مطابقته للقانون، وبالتالي يتم بحثها بالنظر إلى القواعد القانونية المطبقة. أما ملاءمة التصرف فتعني أنه مناسب أو ملائم لكل الإعتبارات المحيطة به، فينظر إليها بحسب الظروف الواقعية المحيطة، فلا تقف المشروعية والملاءمة على طرفي نقيض وإنما يكمل كل منهما الآخر.

أما السلطة التقديرية فهي تقابل السلطة المقيدة، فمعنى وجود أحدهما عدم وجود الأخرى، والقاضي الإداري عندما يراقب مشروعية العمل الإداري فهو يراقب

^١ - وهذه تعتبر رقابة الحد الأدنى وقد أضاف إليها مجلس الدولة الفرنسي رقابة المطا الطاهر في التقدير في بعض الحالات. راجع في ذلك :

عناصر التقيد به ليتأكد من مدى مطابقتها للقانون، لكنه لا يتعرض لعناصر التقدير، فالقاضي الإداري قاضي مشروعية لكنه لا يراقب السلطة التقديرية، بينما يمكن أن يراقب القاضي الملاءمة إذا رأى أنها ضرورية للقول بمشروعية العمل الإداري.^(١) وفي هذه الحالة فإن القاضي يوجد قاعدة قانونية جديدة - غالباً يستند فيها إلى المبادئ العامة للقانون - يوسع بها من نطاق السلطة المقيدة ويضيق من نطاق السلطة التقديرية، ولكن على أية حال تظل حالات رقابة الملاءمة على سبيل الإستثناء ولا اعتبارات معينة.

^١ - وقد طبق ذلك القاضي الإداري في مجال الرقابة على إجراءات الضبط الإداري لمساسها بالحريات العامة حيث اعتبر الملائمة في هذه الحالات عنصراً من عناصر المشروعية. كما راقب الملائمة مجلس الدولة الفرنسي وتابعه في ذلك مجلس الدولة المصري في تقدير المنفعة العامة في مجال نزاع الملكية. راجع في ذلك رسالتنا للدكتوراه في "المنفعة العامة في نزاع الملكية الخاصة دراسة مقارنة- نظرية الموازنة، جامعة الاسكندرية، ١٩٩٢.

الفصل الثالث

آليات أو وسائل أعمال مبدأ المشروعية

صور الرقابة على مشروعية أعمال الإدارة

لا يكفي النص على مبدأ المشروعية لقيام الدولة القانونية وحماية حقوق الأفراد وحيرياتهم العامة وإنما يلزم فوق ذلك ضمان أعمال وكفالة تحقيق مبدأ المشروعية وهو لا يتحقق إلا بالرقابة على أعمال الإدارة بوجه خاص والتأكد من التزامها بمبدأ المشروعية وسيادة حكم القانون

وتتخذ الرقابة على مشروعية أعمال الإدارة عدة صور:

- الرقابة السياسية.
- الرقابة الإدارية.
- الرقابة القضائية.

ونتناول كل منها في مبحث مستقل.

المبحث الأول

الرقابة السياسية

تعتبر الرقابة سياسية إذا قامت بها إحدى الجهات السياسية كالرقابة البرلمانية ورقابة الرأى العام والأحزاب السياسية .

وتعد الرقابة البرلمانية من أهم صور الرقابة السياسية وهى تتولد من العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على النحو الذى ينظمه الدستور من حيث آلياتها والنتائج المترتبة عليها ونشير فى عجالة إلى بعض صور الرقابة السياسية.

وتتميز الرقابة السياسية بأنها شاملة تمارس على الأشخاص وعلى الأعمال كما تمتد إلى ملاءمة العمل الإداري إلى جانب مشروعيته.

أولاً : الرقابة البرلمانية

وتعتبر أهم صور الرقابة السياسية، وتمارس عن طريق البرلمان بالوسائل

الآتية:

- حق توجيه الأسئلة أو الإستجواب إلى الوزراء.

- حق طلب المناقشة والتحقيقات البرلمانية.
- حق سحب الثقة من الحكومة في حالتى المسئولية الفردية والتضامنية
- إقرار الموازنة العامة للدولة.
- الموافقة على المشروعات التي يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة.

ثانياً : رقابة الأحزاب السياسية

على الرغم من أن الحركة الحزبية في مصر ضعيفة لعدم إقبال المواطنين على الانخراط فى الأحزاب السياسية وضعف مشاركتهم في النشاط الحزبي وتدني دور الأحزاب في الشارع السياسي، إلا أن بعض صحف المعارضة تشكل وسيلة رقابية فعالة بتسليطها الضوء على بعض أوجه الفساد والانحراف في الإدارة.

ثالثاً : رقابة المجالس الشعبية المحلية

كفل قانون الإدارة المحلية رقم ٩ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته سلطات رقابية واسعة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية وخاصة بالنسبة للمرافق المحلية تتمثل في جوانب كثيرة منها:

تقديم الأسئلة وطلبات الإحاطة والمناقشة وتقديم الإقتراحات، ولكن لا تزال هذه الرقابة غير فعالة من الناحية العملية.

رابعاً : رقابة رأى العام

ويعني رقابة المواطنين والجمعيات والنقابات ووسائل الإعلام وجماعات الضغط وذلك بابرار آرائهم بشأن الموضوعات التي تهمل أغلب أفراد المجتمع وتوصيلها للسلطات العامة في الدولة.

تقدير الرقابة السياسية

تعد الرقابة الساسية وسيلة من وسائل إلتزام الإدارة بمبدأ المشروعية إلا أنها لا تكفي الرقابة السياسية وحدها لتحقيق ضمانات للأفراد في مواجهة الإدارة لعدة أسباب منها:

- ١- سيطرة المصالح الحزبية وتغليبها على المصلحة العامة.
- ٢- يتوفر دور الرقابة السياسية على مدى النضج الثقافي والسياسي لأفراد المجتمع ومدى الشوط الذي قطعته الدولة في طريق الديمقراطية.

- ٣- إقتصار الرقابة على بحث الملاءمة السياسية فقط دون التطرق لبحث مشروعية العمل أو التعويض عنهما ومن ثم فإنها رقابة غير كافية .
- ٤- يلزم لإجراء الرقابة على أعمال الإدارة إحاطة العامة بالقواعد القانونية وهذا لا يتوافر فى الرقابة السياسية.

المبحث الثاني

الرقابة الإدارية

تحرص الإدارة على أن تراقب أعمالها بنفسها سواء من ناحية مشروعية هذه الأعمال ومطابقتها للقانون أو من ناحية ملاءمتها ومناسبتها للظروف المحيطة ، ويقوم بهذه الرقابة الذاتية الرؤساء الإداريون أو أجهزة متخصصة داخل الجهاز الإدارى.

طرق الرقابة الإدارية: إلى جانب أجهزه خاصة بالرقابة كالرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات توجد الرقابة الذاتية داخل الأجهزة الإدارية ويتم تحريك الرقابة الإدارية إما تلقائياً بمعرفة الإدارة نفسها أو بناءً على تظلم من صاحب الشأن.

أولاً - الرقابة التلقائية قد يقوم الموظف نفسه الذي قام بالتصرف بمراجعة ما سبق أن قام به فيكتشف عدم مشروعيته أو عدم ملاءمته فيقوم بتعديل تصرفه، وقد يقوم بذلك الرئيس الإداري للموظف أثناء قيامه بواجب الإشراف والرقابة على أعمال هذا الموظف. فالرئيس الإداري له الغاء التصرف أو تعديله أو إتخاذ قرار جديد.

ثانياً - الرقابة بناء على تظلم وهذه تتحقق بناء على طلب يرفع من ذوي الشأن الذين أصابهم ضرر من جراء تصرف الإدارة. ويقدم إما إلى رجل الإدارة الذي صدر عنه هذا التصرف (ويسمى تظلم ولائى) وإما إلى الرئيس الإدارى لمن صدر عنه التصرف (ويسمى تظلم رئاسى).

كما قد يرفع التظلم من صاحب الشأن إلى لجنة تشكل خصيصاً لنظر تظلمات الأفراد من تصرفات الإدارة. وتقوم الجهات التي يرفع إليها التظلم بفحصه وتصحيح العيب الذي يشوبه إذا ثبتت جدية التظلم.

والأصل أن اللجوء إلى التظلم إختياري لصاحب الشأن ولكن يحدث إستثناء من ذلك أن يشترط المشرع أحياناً عدم قبول الدعوى أمام القضاء قبل التظلم من القرار أمام الجهة الإدارية وذلك بغية الحد من رفع الدعاوى أمام القضاء.

الأساس القانوني للرقابة الإدارية: تستند الإدارة في رقابتها على أعمالها إلى مبدأ المشروعية ذاته، ذلك أنها ملزمة شأنها شأن الأفراد باحترام القانون، فإذا وجدت أن خطأ معيناً قد ارتكبه فإن عليها أن تقوم بإصلاحه ذاتياً، فتقوم بالغاء أو سحب أو تعديل القرار غير المشروع.

وإذا كان القرار صادراً من سلطة أدنى فإن للجهة الأعلى منها بما لها من سلطة رئاسية أن ترده إلى حظيرة المشروعية.

وبالنسبة لقرارات الإدارة غير الملائمة فإن للإدارة أن تصدر قرارات جديدة تلائم الظروف التي تستجد، وإن كان هذا لا يدخل في الرقابة الإدارية التي هي أصلاً رقابة مشروعية.

تقدير الرقابة الإدارية: تؤدي الرقابة الإدارية إلى إحترام مبدأ المشروعية وهذا يحقق حماية حقوق الأفراد وحررياتهم إضافة إلى تحقيق مصلحة الأفراد ذاتها في إنتظام سير المرفق العام وحسن أداء العمل به.

مزايا الرقابة الإدارية: ١- التيسير على الأفراد: فهي لا تتطلب إجراءات معقدة، ولا تحمل الأفراد أعباء مالية مثل تلك التي تتطلبها الرقابة القضائية.

٢- الإتساع والشمول: حيث قد تؤدي إلى سحب القرار الإداري أو تعديله أو إلغائه، كما أنها قد تمتد إلى ملاءمة القرار ولا تقف عند بحث مشروعيته فقط.

عيوب الرقابة الإدارية: لا تظهر للرقابة الإدارية آثار جليلة في النظام الإداري اللامركزي الذي تأخذ به معظم دول العالم حالياً، حيث تقتصر رقابة الإدارة المركزية على التصديق على أعمال الهيئات اللامركزية بكاملها أو الإعتراض عليها بكاملها فلا تملك إلغائها أو تعديلها أو سحبها أو الحل محلها في إصدارها. كما لا تملك الإدارة المركزية إصدار الأوامر والتعليمات الملزمة للهيئات اللامركزية.

١- تكون الإدارة في هذا النوع من الرقابة هي الخصم والحكم في نفس الوقت، فهي التي أصدرت القرار وهي التي يتظلم منه أمامها، وهذا يتنافى مع أبسط قواعد العدالة التي تفترض أن يفصل في النزاع هيئة محايدة وخاصة أن الإدارة لا تعترف بسهولة بخطئها وربما دافعت عنه وأصرت عليه.

٢- أن الإدارة غير ملزمة بالرد على تظلمات الأفراد.

٣- أن البت في شرعية تصرف الإدارة من عدمه مسألة قانونية تحتاج إلى من له خبرة في هذا الخصوص وقد لا يتوافر ذلك في جهة الإدارة.

٤- قد يكون هناك عائق نفسى يمنع من اللجوء إلى التظلم وخاصة الرئاسي منه" وهو علم صاحب الشأن بأن التظلم سيحول غالباً إلى الموظف المختص نفسه الذي سبق أن أصدر القرار.

لهذه الأسباب ولغيرها فإن الرقابة على أعمال الإدارة يجب ألا تقتصر على هذا النوع من الرقابة وإنما يجب أن يتوافر إلى جوارها رقابة جهة فنية متخصصة ومحايدة توازن بين إحترام حقوق الأفراد وبين متطلبات الإدارة وحسن سير المرافق العامة في إطار من الشرعية ويتوافر ذلك في الرقابة القضائية.

المبحث الثالث

الرقابة القضائية

وتقوم بها المحاكم المختلفة على اختلاف أنواعها وعلى الأخص القضاء الإدارى بغرض حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وذلك عن طريق إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة لو الحكم بالتعويض عن الضرر الذي يصب الأفراد من جرائها.

المطلب الأول

خصائص الرقابة القضائية وتقديرها

أولاً : خصائص الرقابة القضائية

١- أن رقابة القضاء ليست تلقائية كالرقابة الإدارية وإنما لا بد من رفع دعوى من صاحب المصلحة، وبالمقابل فإن القاضي ملزم بالفصل في الدعوى وإلا كان مرتكباً لجريمة إنكار العدالة على عكس رجل الإدارة الذي لا يلزم بالرد على تظلم صاحب الشأن.

٢- أن دور القاضي يقتصر في الأصل على مشروعية القرار الإداري من حيث مدى مطابقته للقواعد القانونية المطبقة ولا يبحث في سلامة القرار أو مدى مناسبته لظروف إصداره.

٣- تقتصر سلطة القاضي بالنسبة لقرارات الإدارة على الحكم بمشروعيتها أو بالغائها أو التعويض عنها فليس له أن يصدر للإدارة أوامر معينة أو أن يحل محلها في إصدار القرار.

ثانياً : تقدير الرقابة القضائية

يفضل الأفراد الرقابة القضائية على غيرها من طرق الرقابة لأنها أجدى لضمان حقوقهم وحرياتهم للأسباب الآتية:

١- يتحقق في الرقابة القضائية الحيدة والاستقلال سواء في مواجهة الحكومة أو المتقاضين.

٢- دقة الإجراءات المتبعة أمام القضاء تضمن حقوق المتقاضين.

٣- تعتبر الرقابة القضائية على أعمال الإدارة أقل تأثراً بالإعتبارات السياسية من أنواع الرقابة الأخرى (السياسية أو الإدارية).

٤- فور صيرورة حكم القضاء نهائياً فإنه يتمتع بحجية الشئ المقضى فيه ويجوز تنفيذه بالقوة الجبرية إذا لزم الأمر، على عكس القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها خلال مدة معينة.^(١)

٥- حيدة القاضي واستقلاله فضلاً عن إلمامه بأحكام القانون.

^١ - هناك عدة حالات أيضاً تثار فيها عدم شرعية القرارات الإدارية على الرغم من انتهاء مدة الطعن فيها منها:

١- يمكن أن يثار البحث في مشروعية قرار إداري رغم إنتهاء مدة الطعن فيه وذلك بمناسبة قرار إداري صدر تنفيذاً له.

٢- يجوز بحث مشروعية قرار إداري انتهى ميعاد الطعن فيه بالإلغاء وذلك إذا ترتب عليه حدوث ضرر ورفع بشأنه دعوى تعويض، ذلك أن دعوى التعويض لا تسقط بالمدة القصيرة المقررة في القانون.

٣- يمكن لصاحب الشأن طلب تعديل لائحة أو إلغائها وذلك بعد مضي مدة الطعن وذلك إذا تغيرت الظروف الواقعية التي دفعت إلى إصدارها أو عدل التشريع الذي استندت إليه اللائحة.

٤- يمكن بصفة عامة طلب فحص شرعية أي قرار لائحي رغم مرور مدة الطعن فيه بالإلغاء وذلك عن طريق الدفع بعدم مشروعيته كما لو قدم الشخص للمحاكمة بتهمة مخالفة لائحة فيدفع بعدم مشروعية هذه اللائحة، راجع تفصيل ذلك الأستاذ الدكتور/ محمود حافظ، المرجع السابق، ص ٧٩.

المطلب الثاني **صور الرقابة القضائية**

تختلف الدول في تنظيم الرقابة القضائية بين نظام القضاء الموحد ونظام القضاء
المزدوج.

ففي نظام القضاء الموحد يقوم قضاء واحد بنظر جميع المنازعات سواء في ذلك
المنازعات التي تتم بين الأفراد أو تلك التي تتم بينهم وبين الدولة وتطبق نفس
القواعد القانونية على كافة المنازعات.

أما في نظام القضاء المزدوج فإنه يوجد قضاء إداري إلى جانب القضاء العادي
يختص بنظر المنازعات الإدارية التي تخضع لقواعد قانونية تراعي متطلبات
وإحتياجات الإدارة . وسوف نتناول كل منها في فرع خاص

الفرع الأول **نظام القضاء الموحد**

ومهد هذا النظام انجلترا وتأثرت به عدد من الدول مثل العراق والأردن
والسودان، ويتميز التطبيق الإنجليزي له بالخصائص الآتية:

١- **القانون الإنجليزي قانون قضائي:** فالقاضي لا تقتصر مهمته على تطبيق
القانون وإنما يقوم بدور كبير في نشأة القاعدة القانونية وتحديد مضمونها وذلك عن
طريق الأخذ بنظام السوابق القضائية فيلزم القاضي نفسه بالمبادئ التي تقررت
في أحكام سابقة، وتأتي أحكام القضاء في المرتبة الأولى والتشريع في المرتبة
الثانية، ويأتي العرف في المرتبة الثالثة بعد أن كان يحتل المرتبة الأولى، حيث
أدى تطبيق قواعد العرف في أحكام القضاء لمدة طويلة أن غيرت هذه القواعد
القانونية من مجال العرف إلى مجال السوابق القضائية.

٢- **تقسيم القانون إلى عام وخاص:** لا يعرف القانون الإنجليزي تقسيم القانون
إلى عام وخاص كما هو في فرنسا والدول التي أخذت عنها وإنما يقسم القانون
إلى: المشترك أو العام (commun law) وهو الذي مصدره أحكام القضاء
والعرف وطبق فترة طويلة من الزمن كما أن القاضي يلتزم بعد ذلك بتطبيق :-

- قواعد العدالة وهي التي توضع لتكمل القانون العام أو المشترك.
- القانون المكتوب وهو مجموعة القواعد التي يضعها البرلمان.
- ٣ - فكرة القواعد الآمرة والقواعد المكملّة: لا يعرف النظام الانجليزي فكرة القواعد الآمرة (التي لا يجوز الإتفاق على خلافها) والقواعد المكملّة (التي تكمل إرادات الأفراد وتطبق عند عدم الإتفاق على خلافها) وذلك لأن هذه التفرقة بين النوعين من القواعد لا تكون إلا إذا كان مصدر القواعد القانونية التشريع وهذا ليس هو الحال في القانون الانجليزي.
- ٤ - قاعدة عدم مسئولية الدولة عن أعمال موظفيها: إن القاعدة في القانون الانجليزي كانت عدم مسئولية الدولة عن أعمال موظفيها إلا بنص خاص، فكان الموظف العام في حصانة من إجراءات التقاضي إلا بموافقة التاج وذلك استناداً لقاعدة دستورية قديمة مؤداها أن الملك لا يخطئ وأنه لا يجوز محاكمة الملك أو موظفيه أمام المحاكم التي هي من إنشائه، كما أن العلاقة بين الموظف والدولة علاقة تعاقدية فتخرج أعمال الموظف التي تضر بالغير عن حدود الوكالة التي تربط الموظف بالدولة.
- ونظراً لخطورة ذلك على حريات الأفراد وحقوقهم فقد تم في مرحلة لاحقة تقرير مسئولية الإدارة عن أعمال الإدارة المحلية وقصر حالات عدم المسئولية على الإدارات المركزية، كما تلاحظ زيادة تدخل المشرع والقضاء للحد من قاعدة عدم المسئولية الإدارية وظهرت الإستثناءات من هذه القاعدة مثل حالة مسئولية الإدارة عن العقود التي تبرمها وانتهى الأمر بقاعدة مسئولية الدولة عن أعمالها بقانون ١٩٤٧ عرف بقانون مقاضاة التاج.
- هـ - قاعدة مسئولية الموظف شخصياً عن أخطائه: ولقد سادت في القانون الانجليزي أيضاً قاعدة مقتضاها التزام الموظف شخصياً عن أخطائه دون التفرقة بين الخطأ الشخصي أو الخطأ المرفقي.
- ولكن العرف جرى على أن تدفع الدولة التعويض المستحق على موظفيها في هذه الحالات ولكن ليس على أساس التزام الدولة قانوناً بذلك وإنما من باب العطف

والرعاية من الدولة لموظفيها ومساعدتهم، وتطبيقاً لقواعد العدالة، كما أورد القانون الانجليزي بعض القيود على رفع الدعاوى على الموظفين للتقليل من الدعاوى الكيدية

٦ - سلطة القاضي الانجليزي في الرقابة على أعمال الإدارة: يملك القاضي الانجليزي سلطات واسعة في مواجهة الإدارة ومن ذلك:

- إن رقابة القاضي تشمل مشروعية العمل الإدارى إضافة إلى ملاءمته.
- إن القاضي الانجليزي يستطيع أن يلزم الإدارة بعمل معين أو الإمتناع عن عمل، كما يملك هو تعديل القرار الإدارى على نحو معين أو إلغائه، فهو يمارس على أعمال الإدارة سلطة الرئيس الإدارى.

لكن يلاحظ أنه تحت تأثير توسع نشاط الدولة وازدياد المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها فقد تم اسناد بعض المنازعات الإدارية لجهات ادارية ذات اختصاص قضائي للفصل فيها مثل لجان الصحة - التعليم - الضرائب وتشكل من موظفين من الجهة المعنية إضافة إلى عصر قضائي، كما عهدت تشريعات معينة لبعض الوزراء بسلطة الفصل في منازعات إدارية أو تستأنف أمامه قرارات اللجنة الإدارية ذات الاختصاص القضائي.^(١)

تقدير نظام القضاء الموحد:

نسب أنصار هذا النظام إليه عدة مزايا:

- ١- أنه أكثر اتفاقاً مع مبدأ المشروعية: حيث تخضع الإدارة والأفراد لقانون واحد وقضاء واحد دون منح الإدارة أي امتيازات، فنتحقق المساواة أمام القانون في أجلي صورها.
- ٢- يمتاز هذا النظام بالبساطة وعدم التعقيد ويجنبنا إشكالات توزيع الاختصاص التي تنور في حالة القضاء المزدوج.

^١ - من ذلك قانون الصحة العامة الصادر عام ١٨٧٥، وقانون التعليم الصادر عام ١٩٢١، وقانون المنازل الصادر ١٩٢٥ والذي حل محله قانون عام ١٩٥٧، وقانون تخطيط وتجميل المدن الصادر عام ١٩٤٦ ونظراً لتزايد هذه الإستثناءات فقد اعتبر ذلك اعترافاً من المشرع بعدم قدرة نظام القضاء الموحد على حل مشكلات الإدارة الحديثة، كما اعتبر ذلك خطوة في إتجاه إنشاء محاكم إدارية على النحو الموجود بنظام القضاء المزدوج.

٣- يعد تطبيقاً حرفياً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقضي بانفراد السلطة القضائية بالفصل في المنازعات.

عيوب نظام القضاء الموحد:

١- لا يراعي حاجات الإدارة وكونها تسعى لتحقيق الصالح العام مما يستلزم منحها عدداً من الإمتيازات، بعكس الأفراد الذين يسعون في المقام الأول لتحقيق مصالحهم الخاصة.

٢- إن تقرير مبدأ المسؤولية الشخصية للموظفين عن أخطائهم يؤدي إلى تخوفهم باستمرار وخشيتهم من وقوعهم في حبال المسؤولية مما يؤثر سلباً على مستوى الأداء.

٣- في اسناد منازعات إدارية لجهات غير إدارية للفصل فيها تعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.

الفرع الثاني نظام القضاء المزدوج

يقوم على أساس وجود جهتين قضائيتين منفصلتين، تختص إحداها (جهة القضاء العادى) بنظر المنازعات التي تثور بين الأفراد وبين الإدارة حين لا تتدخل الإدارة وهي صاحبة سلطة، بينما تنتظر الثانية المنازعات التي تثور بين الأفراد والإدارة التي تتدخل الإدارة فيها باعتبارها صاحبة سلطة مما يستوجب تطبيق قواعد القانون العام بموجب قضاء متخصص (القضاء الإدارى).

وتعتبر فرنسا مهد نظام القضاء المزدوج وقد تابعها في ذلك عديد من البلدان منها مصر، ولذا يلزم قبل دراسة نظام القضاء الإدارى في مصر إعطاء لمحة سريعة عن نشأ القضاء الإدارى في فرنسا من حيث ظروف إنشائه وتطوره.

المطلب الثالث

النظام المزدوج في فرنسا وتطوراته

ترجع نشأة نظام القضاء المزدوج إلى العام الثامن للثورة (١٧٨٩ ١٨٠٠) ويحيط بنظام القضاء المزدوج في فرنسا اسباب تاريخية واعتبارات فلسفية تتصل بالعلاقة بين الادارة والسلطة القضائية، كما تتصل بفهم رجال الثورة

الفرنسية لمبدأ الفصل بين السلطات، كما أنه مر بعد ميلاده بتطورات عديدة، وأهم ملامح تطور نظام القضاء المزدوج في فرنسا ما يلي:

١- فيما يتعلق بالسبب التاريخي، فإن المحاكم الفرنسية عمدت على التدخل في أعمال السلطة التنفيذية وتعطيلها بشتى الطرق، وقد قام برلمان فرنسا - وهو محكمة وليس برلماناً كما توحى التسمية بالدور الأكبر في التدخل في أعمال السلطة التنفيذية وذلك بانتحال صفة سياسية إلى جانب صفته القضائية، فقد انتحل صفة أنه خلف لمجلس الملك القديم في سلطاته واختصاصاته، وكان مجلس الملك القديم يشارك الملك في كثير من السلطات، ومنها الإعتراض على بعض القرارات بحجة كونها مخالفة للقوانين الأساسية في البلاد، واستناداً على هذه الصفة اعتبر برلمان فرنسا نفسه حامياً لقوانين المملكة، واستناداً على هذه الصفة عطل الكثير من الأوامر الملكية التي تصدرها السلطة التنفيذية بإعتبار أنه يختص بتسجيل هذه الأوامر وذلك في الحالة التي يرى فيها برلمان فرنسا أن هذه الأوامر مخالفة للقوانين الأساسية، وقد دعم هذا المسلك المعادى للسلطة التنفيذية أن القضاة كانوا يتحصلون على رواتبهم من الرسوم القضائية، لذلك كانوا يحاربون أي إصلاح قضائي يتناول اختصاصاتهم، وحينما قامت الثورة الفرنسية فإن السلطة القضائية في مجموعها كانت معادية لها، الأمر الذي أدى برجال الثورة الفرنسية أن يعمدوا إلى تقليص أظافر السلطة القضائية باعتبارها خصماً ونداً لها، لذلك أصدرت الثورة الفرنسية القانون رقم ١٦ في ١٤/٨/١٧٩٠، ويخول هذا القانون للرئيس الإداري الحق في الفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها، وترتب على ذلك إمتناع القضاء أن يعقب على نشاط الإدارة أو تصرفاتها، وأصبح الإختصاص بنظر المنازعات الإدارية موكولاً إلى الإدارة نفسها، وكذلك نص هذا القانون على أن الوظائف القضائية مستقلة ومنفصلة عن الوظائف الإدارية، وأن القضاة لا يجوز لهم التدخل في أعمال الإدارة، أو تعطيل نشاطها وإلا تعرضوا لعقوبات رادعة، فليس للقضاة أن يعرقلوا بأي صورة كانت أعمال الهيئات الإدارية أو يستدعوا رجال الإدارة للمثول أمامهم لمقاضاتهم بسبب قيامهم بأداء وظائفهم، كذلك صدر قانون يحرم على المحاكم النظر في أعمال الإدارة على اختلاف أنواعها.

٢- وكان من المنطقي أن يرتب رجال الثورة على إبعاد القضاء عن النظر في أعمال السلطة الإدارية النتيجة المنطقية وهي إيجاد قضاء خاص يراقب الإدارة، ولكنهم عهدوا بهذه المهمة الدقيقة إلى الإدارة ذاتها وهو ما يعرف بنظام "الإدارة القضائية" أو "الوزير القاضي".

٣- وفي عهد نابليون بونابرت وبناءً على نصيحة السياسي الشهير "إيمانويل سيبير" بأن يقيم هيئات استشارية إلى جانب الإدارة العاملة، استجاب نابليون إلى ذلك وكان من ضمن الهيئات الاستشارية التي أنشأها "مجلس الدولة" و "مجلس الأقاليم"، وقد عهد إلى هذه الهيئات النظر في المنازعات الإدارية، وكانت هذه الهيئات خطوة لها وزنها وقيمتها في تطور النظام الفرنسي نحو نزع المهمة القضائية من الإدارة، وهذه الهيئات لم يكن لها اختصاص قضائي بالمعنى الفني، وإنما كانت تبدى الرأي القانوني وتقدمه لرئيس الدولة للتصديق عليه كما كانت تقترح حلولاً يتوقف الأخذ بها على رأى الرؤساء الإداريين وهو ما عرف بنظام القضاء المحجوز" أو "العدالة المحجوزة" باعتبار أن رأي هذه الهيئات كان مرهوناً بما تراه الإدارة.

٤- وفي سنة ١٨٧٢ أكد مجلس الدولة صفته القضائية حيث أصبحت أحكامه تنفذ دون حاجة إلى تصديق، وهو ما عرف بنظام "القضاء البات" أو "المفوض".

٥- وحتى هذه المرحلة السابقة فإن اختصاص مجلس الدولة الفرنسي كان مقيداً بنظرية الوزير القاضي أو الإدارة القضائية حيث كان مجلس الدولة لا يملك النظر في المنازعات الإدارية اللهم إلا ما تصرح به السلطة التنفيذية له، حيث كان يلزم على الأفراد قبل رفع الدعوى أمام مجلس الدولة أن يعرضوا الأمر على جهة الإدارة للنظر فيها مالم ينص القانون على غير ذلك، وفيما عدا هذه المسائل المحدودة كان يتعين على الأفراد اللجوء إلى الإدارة أولاً، فإذا لم ينصفوا لجئوا إلى مجلس الدولة كجهة استئنافية، وقد ظل هذا الوضع حتى سنة ١٨٨٩ حيث أكد المجلس صفته كصاحب الاختصاص الأصيل في المنازعات الإدارية في القضية الشهيرة بقضية كادو ، فقد قرر مجلس الدولة بالنسبة لهذه الدعوى قبولها ابتداءً دون لجوء صاحب الشأن إلى الإدارة، ومنذها أصبح مجلس الدولة الفرنسي صاحب الاختصاص العام في المنازعات الإدارية.

٦ - وفي سنة ١٩٥٤ أصبحت المحاكم الإدارية الفرنسية صاحبة الاختصاص العام في المنازعات الإدارية بدلاً من مجلس الدولة، وذلك بمقتضى القانون العام الصادر في ١٩٥٣/٩/٣٠، وهذا التعديل خاص بالعلاقة بين هيئات القضاء الإداري ذاتها، ولا صلة له بتوزيع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي.

٧ - كما أصدر المشرع الفرنسي في ٣١ ديسمبر سنة ١٩٨٧ القانون رقم ١١٢٧ لسنة ١٩٨٧ على أن يعمل به اعتباراً من أول يناير سنة ١٩٨٩، وقد تضمن هذا القانون إنشاء محاكم الاستئناف الإدارية COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL للتخفيف عن كاهل مجلس الدولة الفرنسي بصفته قاضي استئناف، وذلك عن طريق إسناد هذا الاختصاص بصورة أساسية إلى محاكم الاستئناف الإدارية. وتم ذلك من أول يناير ١٩٨٩ عن طريق إحالة الطعون الاستئنافية الصادرة من المحاكم الإدارية في منازعات القضاء الكامل المنظورة أمام مجلس الدولة بحالتها إلى تلك المحاكم المستحدثة.

أما فيما يتعلق بطعون الاستئناف عن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في طعون مجاوزة السلطة (الإلغاء) المتداولة أمام مجلس الدولة، فقد تم نقلها إلى المحاكم الاستئنافية آنفة البيان على مراحل انتهت في ٣١ ديسمبر ١٩٩٤.

واستهدف المشرع الفرنسي من إنشاء المحاكم الاستئنافية، سرعة الفصل في المنازعات الإدارية المطروحة على القضاء الإداري وحسمها بأحكام نهائية، سواء بالنسبة لطعون القضاء الكامل أو بالنسبة لطعون مجاوزة السلطة على حد سواء، وتعد المحاكم المذكورة درجة ثانية من درجات التقاضي بين المحاكم الإدارية ومجلس الدولة.

وقد تحقق باصلاح عام ١٩٨٨ لا مركزية القضاء الإداري وتقريب العدالة الإدارية إلى المتقاضين.

والنتيجة التي نستخلصها من هذا التطور أن نظام القضاء المزدوج في فرنسا لم يوجد نتيجة مقارنة واعية بينه وبين نظام القضاء الموحد، وإنما نشأ استجابة للتطورات التاريخية التي استعرضناها، والتي ترجع في مجموعها إلى حماية الإدارة من تدخل القضاء.

وفيما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات، فقد استندوا إلى مبدأ الفصل بين السلطات في تبريرهم الأخذ بالقضاء المزدوج باعتبار أن إعطاء القضاء العادي النظر في منازعات الإدارة يعتبر اعتداءً على السلطة التنفيذية وماساً بمبدأ الفصل بين السلطات، وقد سبق أن أشرنا إلى أن أنصار نظام القضاء الموحد استندوا أيضاً إلى المبدأ ذاته في عدم وجود القضاء المزدوج باعتبار أن المبدأ يقضي بأن تستقل السلطة القضائية بنظر كافة المنازعات بكافة أنواعها، إذ أن حرمان السلطة القضائية من بعض اختصاصاتها فإن ذلك يشكل اعتداءً خطيراً على مبدأ الفصل بين السلطات. والحقيقة أن مبدأ الفصل لا يسعف أي من الفريقين في هذا الصدد، كما أنه أقحم في المفاضلة بين الأسلوبين وذلك للمبررات الآتية التي ساقها أستاذنا الدكتور/ أحمد كمال أبو المجد يرحمه الله وهي:

- ١- لا نفهم كيف تعتبر رقابة المحاكم العادية خروجاً على مبدأ الفصل بين السلطات، ولا تعتبر رقابة المحاكم الإدارية خروجاً على نفس المبدأ، فالمحاكم الإدارية إما أن تكون محاكم بالمعنى الصحيح أو هيئات إدارية، فإذا كانت محاكم فإن رقابتها على أعمال الإدارة لا تختلف عن رقابة المحاكم العادية بالنسبة لأثر هذه الرقابة على مبدأ الفصل بين السلطات، أما إذا كانت هيئات إدارية - وهو ما لم يقل به أحد - فإن ذلك وحده الذي ينطوي على اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات وما يحتمه من ضرورة إسناد وظائف الدولة لهيئات متخصصة.
 - ٢ - كذلك فإن الفقه الإنجليزى والأمريكى لا يستطيع أحد أن يسايره في اعتبار القضاء المزدوج خروجاً على مبدأ الفصل بين السلطات، إذ مؤدى هذا المنطق تجميع الوظيفة القضائية في يد جهة واحدة، وهو أمر لا ضرورة له مطلقاً، وليس من شأن مبدأ الفصل بين السلطات أن تقوم جهة واحدة بالفصل في الخصومات، كل ما يباه هذا المبدأ أن تتولى هيئة ليست قضائية التصدي للمنازعات القضائية.
- والخلاصة التي انتهى إليها أستاذنا الدكتور أحمد كمال أبو المجد أن مبدأ الفصل بين السلطات لا يسعف أي من الفريقين في هذا الخصوص.

والملاحظة الجديرة بالاعتبار أن الوسيلة التي كشفت التجربة عن صلاحيتها وكفايتها لوضع الحلول القانونية المناسبة لمشاكل القانون العام وقضاياها المتميزة عن قضايا الأفراد هي وجود قضاء إدارى مزدوج تتحقق فيه سمات ثلاث:

١- تمتعه بالاستقلال الكافى عن الإدارة.

٢- إلا أنه لا يؤدى هذا الإستقلال إلى عزلة القضاء الإدارى عن الوقوف عن مشاكل الإدارة، وهو ما يحتم وجود قدر من الإتصال بينه وبين الإدارة العاملة تتيح له الإحاطة بالعملية الإدارية وذاتية المشاكل التي تتعرض لها الإدارة، وهو ما يؤدى إلى أن يقف القاضي الإدارى على حسن الإدارة ومقتضياتها دون أن ينال ذلك من استقلاله وحيدته.

٣- تحرره من نصوص القانون المدني والقانون الخاص بصفة عامة والتي لم توضع أصلاً لتنظيم العلاقات التي تنتمى إلى القانون العام.

لذلك كان منطقياً أن تأخذ مصر بالرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة، وأن تفرد لها قضاءً خاصاً هو القضاء الإدارى عملاً بما أثمرت عنه التجربة الفرنسية من مزايا وهي :

١- ثبت في الدول التي أخذت بالقضاء المزدوج أن القضاء الإدارى وقف مدافعاً عن حقوق الأفراد وملاًذاً لحماية حرياتهم رغم أنه في بداية الأخذ به في فرنسا كان امتيازاً للإدارة يمنع منازعاتها من نظرها أمام المحاكم العادية، ولذا لا يمكن التسليم بما قاله البعض من إمكانية محابة القضاء الإدارى لجهة الإدارة.

٢- إن العلاقات التي تنور بين الإدارة باعتبارها سلطة عامة وبين الأفراد تختلف عن تلك التي تنور بين الأفراد بعضهم البعض فهي علاقة بين طرفين غير متكافلين فالإدارة حتى تتمكن من أدائها لواجباتها لابد من الإعراف لها بعدد من الإمتيازات، ولذا فإن وجود قضاء متخصص لأقضية الإدارة يتفهم مشكلاتها ضروري لتحقيق المصلحة العامة، وبالإضافة الى ذلك فإن مبدأ التخصص هو سمة عالم اليوم الذي يتجه إلى المزيد من التخصص في كافة المجالات.

- ٣- أن المشكلة التي يمكن أن يثيرها القضاء المزدوج هي مشكلة حل تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء العادى والادارى وقد تم التغلب عليها بإنشاء محكمة خاصة للتنازع أو إسناد المنازعات المتعلقة بالاختصاص للمحكمة العليا في البلاد.
- ٤- لا يمكن قبول الإدعاء بأن ازدواج القضاء يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، فكل ما يأباه هذا المبدأ هو أن تتولى جهة غير قضائية الفصل في منازعة قضائية، أما أن تقوم على الفصل في المنازعة جهة واحدة أو جهتان فليس في ذلك مساس بمبدأ الفصل بين السلطات.

الباب الثاني **نشأة مجلس الدولة المصري وتبعيته وأقسامه.**

تمهيد وتقسيم:

وفي تعرضنا للقواعد العامة التي تنظم مجلس الدولة المصري نتناول المسائل الآتية:

الفصل الأول : في تاريخ نشأة مجلس الدولة في مصر.

الفصل الثاني : تبعية المجلس.

الفصل الثالث : نظام موظفي المجلس.

الفصل الرابع : هيئات المجلس وأقسامه.

الفصل الخامس : الاختصاص القضائي لمحاكم مجلس الدولة المصري.

الفصل السادس : تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري.

الفصل الأول

تاريخ الأخذ بنظام القضاء الإداري في مصر

أشرنا إلى أن مصر أخذت بنظام "القضاء الإداري" لأول مرة بمقتضى القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ الصادر في ٧ أغسطس سنة ١٩٤٦ والذي بدأ العمل به ابتداءً من ١٥ من الشهر التالي، وقد حل محله القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ ثم القانون ١٦٥ لسنة ١٩٥٥، والقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ وأخيراً القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ المعمول به الآن.

وقد نما مجلس الدولة المصري من خلال هذه القوانين المتعاقبة وتطور على يد قضاته ومفوضيه بما بذلوه من جهد أثرى القانون الإداري المصري إثراءً كبيراً.

ولقد اعتبر الأخذ بنظام مجلس الدولة في مصر في رأى أستاذنا العميد الدكتور عثمان خليل عثمان يرحمه الله "إصلاح قضائي جليل" وفتاحة إصلاحات

قانونية وإدارية أجل وأسمى، وفاتحة عهد جديد للإصلاحات القانونية الإدارية التي لا يقدر مداها إلا مع الزمن.

غير أنه يجب أن نشير إلى أن المسلمين منذ العهد الأول كانوا أول من أخذ بنظام القضاء الإداري، فحينما فتح المسلمون مصر طبقوا الشريعة الإسلامية وأدخل عمرو بن العاص نظام القضاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وكان من بين المحاكم التي أنشأها "قضاء المظالم" وهو قضاء كان يلجأ إليه المتقاضون من ظلم الحكام وذوي النفوذ، ومن ثم فإن هذا القضاء كان يتصدى للمنازعات التي يرفعها الأفراد ضد الحكام والولاة وكل من يمارس سلطة عامة.

ويعد قضاء المظالم من الناحية التاريخية أول قضاء إداري متخصص في التاريخ، وليس كما هو معروف لدى فقهاء القانون العام في مصر أن أول نظام للقضاء الإداري هو الذي نشأ في فرنسا.

وقضاء المظالم ترتيباً على ذلك يعد الظاهرة الواضحة لنظام مجلس الدولة في العصر الحديث، وأول من جلس للمظالم من خلفاء الدولة الأموية عبد الملك بن مروان حيث أفرد للتظلمات يوماً معيناً ثم جلس بعده الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وسوف نتناول هذا المبحث في مطلبين.

المبحث الأول

محاولات إنشاء مجلس الدولة

غير أن مجلس الدولة المصري لم يولد فجأة في عام ١٩٤٦، وإنما اختمرت فكرته منذ مطلع القرن التاسع عشر، منذ أوجد محمد علي مؤسس مصر الحديثة بعض المجالس وخولها بعض الاختصاصات القضائية والإدارية والاستشارية والتشريعية، وكان من بين هذه المجالس "ديوان الوالي الذي أنشئ عام ١٨٠٥م، وقد قام بأمر هذا الديوان عالم من كل مذهب من المذاهب الأربعة الإسلامية. ثم تغير اسم هذا الديوان إلى "المجلس العالي الملكي" بمقتضى الأمر الصادر في ١٨٢٤/٢/٢٧، كذلك أنشأ محمد علي دواوين سبعة كان أهمها في نطاق هذه الدراسة المجلس العالي الملكي الذي اختص بقانون السياسة الصادر في سنة ١٨٢٧.

وفي ١٨٤٢/٢/١٤ أنشئت جمعية الحقانية حيث جمعت بين سلطة سن القوانين واللوائح وبين الاختصاص القضائي الشامل لجميع القضايا المتعلقة بالعسكرية

والأهالي التي تقدم إليها من الدواوين المختصة، كما كانت هذه الجمعية تتولى الفصل في التهم الموجهة ضد القوانين وأطلق عليها اسم "مجلس الأحكام واعتبر هذا المجلس أعلى هيئة قضائية وإفتاءية في البلاد.

غير أن المحاولات الجادة لإنشاء مجلس الدولة بدأت في عهد الخديوي اسماعيل باشا وبعد صدور مجموعة القوانين المختلطة ١٨٧٥.

فقد كان من الطبيعي وبعد أن تم اقتباس القوانين المصرية من القانون الفرنسي أن يفكر في الأخذ بنظام مجلس الدولة كنظام شبيه لنظيره في فرنسا، وعلى ذلك صدر الأمر العالي المؤرخ في ١٨٧٩/٤/٢٣ بإنشاء مجلس الدولة على نسق مجلس الدولة في فرنسا، وقد أختص مجلس الدولة بمقتضى المواد ١٠،٩٠٨ باختصاصات صياغة مشروعات القوانين والإفتاء والفصل في المنازعات الإدارية. فالمادة (٨) من هذا الأمر العالي نصت على أن يؤخذ رأى مجلس الدولة في جميع مشروعات القوانين الواجب تقديمها من نظارنا إلى مجلس شورى النواب والتصديق عليها منا، ويعد مشروعات القوانين التي تطلب إليه الحكومة إعدادها وكذلك بعد لوائح الإدارة العمومية، ويبدى رأيه في المسائل القانونية والمسائل المتصلة بالمصلحة العامة التي يحيلها إليه مجلس نظارنا لبحثها.

وهذه الاختصاصات لا تخرج عن الاختصاصات التي نيّطت بقسمي الفتوى والتشريع عند إنشاء مجلس الدولة بمقتضى القانون ١١٢ لسنة 1946 على النحو الذي سنوضحه تفصيلاً في حينه.

أما المادة التاسعة من هذا الأمر العالي فقد أسندت إلى المجلس بعض الاختصاصات القضائية حيث نصت على أن يفصل مجلس الدولة بناءً على طلبنا أو طلب نظارنا في جميع المنازعات التي تنشأ بينهم:

أولاً: فيما يتعلق باختصاصات كل منهم بمقتضى القوانين واللوائح.

ثانياً: فيما يتعلق بتطبيق القوانين ويبدى رأيه في جميع المسائل التي يحيلها

إليه نظارنا كما ينظر في تصرفات الموظفين التي يطلب إليه فحصها.

أما المادة العاشرة من هذا الأمر فقد أفصحت بجلاء عن اختصاص مجلس الدولة بالبت في المنازعات الإدارية حيث قررت يفصل مجلس الدولة بصفة انتهائية في المنازعات الإدارية والواضح أن هذه أول محاولة جادة لإيجاد مجلس الدولة كجهة قضاء في المنازعات الإدارية وصياغة مشروعات القوانين واللوائح الإدارية والإفتاء غير أن الضائقة المالية التي كانت تمر بها البلاد آنذاك أدت إلى تعطيل تنفيذ هذا القانون.

وفي سنة ١٨٨٣ أعيد التفكير في إنشاء مجلس الدولة، غير أن الأمر العالي الصادر في ١٨٨٣/٩/٢٢ اقتصر على إنشاء قسمين أحدهما للتشريع والثاني للإفتاء، ولم يخلو المجلس أي اختصاص قضائي وذلك بسبب صعوبات أدى إليها الاحتلال الإنجليزي من ناحية، والامتيازات الأجنبية والقضاء المختلط من ناحية أخرى، ولم يدم هذا المجلس طويلاً حيث توقف لاعتبارات سياسية في ١٣/٢/١٨٨٤، وعهد إلى لجنة قضايا الحكومة وهي الآن هيئة قضايا الدولة بإعداد مشروعات القوانين واللوائح، ومن ذلك يتضح بأن قسمي الفتوى والتشريع وهما من الأقسام الرئيسية لمجلس الدولة قد تحقق وجودهما منذ مدة طويلة، على النقيض من ذلك القسم القضائي حيث تعثر وجوده في هذه الفترة بسبب ما كان يعترض ذلك من أسباب منها وجود المستعمر الأجنبي والامتيازات الأجنبية، وما ترتب على ذلك من وجود المحاكم المختلطة والقنصلية مما يبعد الأجانب ذوى الامتيازات من الخضوع لسلطان القضاء الوطني. وبالرغم من ذلك لم يستبعد إنشاء مجلس الدولة من أذهان المصلحين والمشرعين في مصر فقد ظلت فكرة وجوده تراود أحلام الفقهاء، والكتاب والمؤلفات القانونية ونادي بها رجال البرلمان مما أدى إلى أن يتردد اسم مجلس الدولة في خطاب العرش في ١٩٣٨/٦/٢١ حيث ورد فيه "ومما تعترزم حكومتي - حكومة جلالة الملك فؤاد - اتخاذه من التدابير في هذا الصدد تأمين الموظفين بوجه عام على الأخذ بالعدل والمصلحة، ورفع أسباب القلق والإبهام فيما يتعلق بشئونهم من تعيين وترقية وتأديب."

وتنفيذاً لما ورد في خطاب العرش المشار إليه وقع مشروع قانون إنشاء مجلس الدولة في عام ١٩٣٩ غير أنه لم يقدم إلى المجلس، وفي سنة ١٩٤١ ثم وضع مشروع آخر غير المشروع السابق ذكره إلا أنه تعطل.

المبحث الثاني

نشأة مجلس الدولة المصري

وفي عام ١٩٤٥ قدم النائب محمود محمد محمود باشا مشروعاً في سنة ١٩٤٥ في صورة اقتراح بقانون، غير أن الحكومة أعدت مشروعاً مقارباً تقدمت به إلى البرلمان في إبريل عام ١٩٤٦ هو الذي صدر على أساسه القانون ١١٢ لسنة ١٩٤٦. وكان ذلك فاتحة خير للإصلاح القضائي في مصر والأخذ بنظام القضاء المزدوج .

ونرى أن الدافع الرئيسي الذي ساعد على إصدار هذا القانون وخروجه إلى النور وحيز الوجود إنما يعود في المقام الأول إلى معاهدة "موننترو" الخاصة بإلغاء الامتيازات الأجنبية حيث أصبح من الممكن التفكير في إنشاء مجلس الدولة بعد أن قضت هذه المعاهدة على جواز تقاضى الأجنبي أمام المحاكم المصرية غير المختلطة متى قبل ذلك مختاراً عرض النزاع على تلك المحاكم. أما قبل هذا فلم يكن يتيسر ذلك حيث لم يكن من الممكن خضوع الأجانب الممتازون للقضاء الوطني مما كان يحول دون إنشاء مجلس الدولة، لذلك فإن معاهدة موننترو جعلت أمنية إنشاء مجلس الدولة حقيقة واقعة بصدر القانون ١١٢ لسنة ١٩٤٦ المشار إليه.

على أنه وإن كان النظام القضائي في مصر لم يعرف نظام القضاء الإداري إلا بصدر هذا القانون إلا أنه يحمد للقضاء العادي قبل هذا التاريخ أمران:

الأول : أنه في بعض المنازعات الإدارية التي شاب العمل الإداري فيها عيب من العيوب الجسيمة توصل إلى تجريد هذه الأعمال من الصفة الإدارية لها وهبط بها إلى مستوى العمل المادي ليتوصل الى انعدام هذه القرارات، وكان ذلك بغية أن يتوصل من وراء ذلك إلى بسط ولايته على هذه المنازعات العادية التي تدخل في ولايته، وقد استفاد القضاء العادي في هذه المرحلة بما توصل إليه القضاء الإداري الفرنسي في أوجه مشروعية القرار الإداري.

الثاني: كما يحمد للقضاء العادي المحاولات المشكورة التي بذلها في بعض النواحي القانونية والإدارية فتوسع في تفسير النصوص تارة وأرهمها في التفسير وتجاوزها تارة أخرى، وذلك لكي يفتح ثغرات تقتضيها بعض المبادئ الإدارية الحديثة العادلة التي لم تكن سائدة عندما وضع القانون المدني وأصبحت تقتضيها طبيعة العلاقات الإدارية وإن لم تتفق وطبيعة العلاقات المدنية أو الأسس التي تحكم روابط القانون الخاص.

ولا ننسى مطلقاً أن الرعيل الأول من قضاة مجلس الدولة كانوا جميعاً من قضاة القضاء العادي وهذا الجيل ساهم بحق في إنشاء وتطوير مجلس الدولة المصري ليكون حصناً حصيناً للحقوق والحريات العامة.

المبحث الثاني

تبعية المجلس

المقصود بالتبعية:

لا يقصد بتحديد الجهة التي يتبعها المجلس أن يكون تابعاً لهذه الجهة تبعية رئاسية على النحو المعروف في تدرج إدارات الحكومة ومصالحها المختلفة، وإنما المقصود هو تحديد الجهة التي يتصل المجلس عن طريقها بالهيئات الحكومية الأخرى دون أن يكون لهذه الجهة التي يتبعها المجلس التدخل في أعماله، كما لا تملك هذه الجهة توجيه نشاطه وهو ما أكدته القوانين المختلفة التي صدرت بتنظيم مجلس الدولة وما سوف نشير إليه.

الجهة التي يتبعها المجلس:

نصت المادة الأولى من القانون (١١٢) لسنة ١٩٤٦ أول قانون منظم لمجلس الدولة وكذلك القانون رقم (٩) لسنة ١٩٤٩ الذي حل محل القانون الأول في مادته الأولى أيضاً على ما يلي (يكون مجلس الدولة هيئة قائمة ويلحق بوزارة العدل). غير أنه صدر في عهد آخر وزارة لحكومة الوفد القانون رقم ٦ لسنة ١٩٥٢ حيث نص بمقتضى المادة ٣٨ مكررة التي أضيفت إلى القانون ٩ لسنة ١٩٤٩ على: "لوزير العدل حق الإشراف على المجلس وأعضائه وموظفيه"، فهذا التعديل استهدف الرقابة الكاملة والإشراف على المجلس وأعضائه من قبل وزارة العدل.

وقد اعتبر هذا القانون اعتداءً صارخاً على استقلال المجلس وإهداراً لكيانه وأكدت الجمعية العمومية لمجلس الدولة اعتراضها على هذا القانون، ولم يلبث هذا الحكم الشاذ أن ألغى بعد أن توالى الاعتراضات عليه بمقتضى القانون رقم (١١٥ لسنة ١٩٥٢) الذي نص في مادته الأولى على أن: "يكون مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء".

وهذا القانون الأخير لم يخلص مجلس الدولة من الوضع الشاذ الذي أتت به المادة ٣٨ مكرر من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٥٢ فحسب، وإنما خلصه من التبعية التي كانت القوانين السابقة على هذا القانون تفرضها على هذا المجلس وهو تبعيته لوزارة العدل، وبذلك فإن القانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٥٢ خلص مجلس الدولة من تبعيته لوزارة العدل، وهذا في حد ذاته ضمانه جوهرية تحقق للمجلس الحرية والنزاهة في ممارسته لوظائفه المختلفة (القضاء في المنازعات الإدارية - الإفتاء والصياغة) وذلك للاعتبارات الآتية:

١- تبعية المجلس لرئاسة الوزارة تؤكد استقلاله، ذلك أن تبعيته للجهة التي يتبعها القضاء العادي من شأنها أن تفقده الطابع المميز الذي يجب أن يحتفظ به.

٢- لما كان مجلس الدولة جهة الافتاء والصياغة لجميع الوزارات فإنه من المنطق السليم أن لا يلحق بأي وزارة من الوزارات، وإنما يجب أن يلحق برئاسة الوزارة وليس باحداها.

٣- كما أن إلحاق مجلس الدولة برئاسة الوزراء من شأنه أن يدعم استقلال المجلس لأن فرصة تدخل رئيس الوزراء في أعماله قليلة وذلك لكثرة أعبائه وتعدد مشاغله كما أنها تتيح لوزير العدل الفرصة في التخصص وتركيز عمله في نطاق القضاء العادي.

وقد أخذ القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ بنفس الحكم فقررت المادة الأولى من هذا القانون على أن: "يكون مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء".

ثم جاء القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ الخاص بتنظيم مجلس الدولة فأكد هذا المعنى وزاد عليه بأن نص في مادته الأولى بأن يكون مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة الجمهورية.

ونظراً لما طرأ على البنين الدستوري من تغير في أواخر الخمسينات وذلك لدخول مصر في وحدة إندماجية مع سوريا تحت اسم "الجمهورية العربية المتحدة" فقد صدر القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٥٩ حيث نص على أن يكون مجلس الدولة هيئة مستقلة وتلحق برئاسة المجلس التنفيذي. رغم الانفصال بين مصر وسوريا عام ١٩٦١.

وبإعلان الدستور المؤقت في ٢٥ مارس سنة ١٩٦٤ وانتهاء العمل بدستور سنة ١٩٥٨ -دستور الوحدة- ألغى المجلس التنفيذي وحل مجلس الوزراء محل ما كان يسمى بالمجلس التنفيذي ومن ثم فإن تبعية المجلس عادت إلى مجلس الوزراء.

إلا أن القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨ عاد وعدل الجهة التي يلحق بها المجلس غير التي كان تابعاً لها أمداً طويلاً من سنة ٥٢ حتى ١٩٦٨ فألحق مجلس الدولة بوزارة العدل وكان ذلك في حد ذاته وعلى حد تعبير المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ القانون الأخير المنظم لمجلس الدولة يعد "انتقاصاً لضمانة أساسية لهذا الصرح، بغيرها لا تستكمل العدالة الإدارية مقوماتها ولا مبدأ سيادة القانون سلطاته.

وحيثما صدر دستور ١١ سبتمبر سنة ١٩٧١ حظي مجلس الدولة من بين مواد

هذا الدستور بالمادة ١٧٢ التي نصت على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة."

وكان من المنطق أن تكون تبعية المجلس في أي قانون جديد بعد هذا الدستور لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية إلا أن القانون الأخير رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ نص في مادته الأولى على أن "مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق بوزارة العدل" ومن ثم فإن المشرع عاد إلى إلحاق تبعية المجلس بوزارة العدل على ما وجه إلى ذلك من نقد.

على أن الذي يتفحص المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وما انتهى إليه القانون في مادته الأولى المشار إليها يجد تناقضاً صارخاً بين المذكرة الإيضاحية وبين نص

المادة الأولى حيث أن المذكرة الإيضاحية أخذت تعدد المساوئ التي تترتب على تبعية المجلس لوزارة العدل، فكان من المنطق تبعاً لذلك أن يأتي القانون مخلصاً مجلس الدولة من هذه التبعية، تقول المذكرة الإيضاحية " وإذا كان مجلس الدولة يقضي في خصومات الوزارات والهيئات جميعاً والأفراد وكان يصوغ التشريعات للوزارات كلها ويمد الدولة بمختلف مرافقها وعلى كافة مستوياتها بالمشورة والرأي، فهو أحق الأجهزة بأن يكون هيئة مستقلة إذ لا يتفق مع طبائع الأشياء أن يكون المجلس تابعاً لوزارة العدل أو خاضعاً لإشرافها.

إن ذلك إذن يكون مدعاة لزعة الثقة بحيدة القاضي الإداري، إذ كيف يستقر في وجدان المتقاضين أن هذا القاضي يطمأن إليه وهو يعلم أن خصمه يتولى الإشراف عليه، إن هذا حاسم في الدلالة على أن تبعية المجلس لأحد الوزراء أو إشرافه عليه يتعارض مع طبيعة وظيفته.

كذلك فإن الحكم في مصائر الحقوق العامة والحريات والأموال إذا مستها قرارات إدارية لا يكون إلا لمجلس الدولة فهو إذن خليف بأن تحشد كل الضمانات لدعم استقلاله وتعزيز كيانه.

وليس بخاف أن الفرق بين القضاة الإداريين والعاديين هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان، إذ القضاء الأول يفصل في علاقات الدولة بالأفراد، والثاني يحكم في الخصومات الشاجرة بين الأفراد فيما يتصل بروابط القانون الخاص.

وإذا وضح أن القضاء الإداري بحكم اختصاصه له طبيعة رقابية على الجهاز الإداري للدولة تعين بحكم اللزوم ألا يكون تابعاً لأحد الوزراء خاصة وقد أتيح لمصر أن يترعرع في رحاب نظمها القضائية قضاء الإلغاء الذي قيل عنه بحق أنه ليس أداة قضائية لرقابة أعمال الإدارة فحسب، بل هو أداة شعبية لهذه الرقابة، واستقلال مجلس الدولة هو دعم للضمانة الأصلية التي يحققها قضاء الإلغاء، ولا كفالة لهذا الاستقلال حتى تنحى عنه وصاية السلطة التنفيذية، لأنه بدلاً من أن تكون قرارات السلطة التنفيذية داخلية في ولاية مجلس الدولة بما يملكه عليها من قضاء الإلغاء يصبح المجلس على النقيض من ذلك داخلاً في وصاية السلطة التنفيذية، بل وصاية أحد أعضائها.

ولهذا كان أحد المكاسب التي حققها الشعب في دستور ١٩٧١ لجمهورية مصر العربية ما نص عليه في المادة ١٩٠ من الدستور أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ومؤدى هذا أن إلحاق مجلس الدولة بالسلطة التنفيذية يقضى على استقلال المجلس الذي نص عليه الدستور وينطوي على مخالفة دستورية لأن استقلال المجلس أصبح ضماناً دستورية ينافيها الإلحاق لأنه صورة من صور التبعية ولو كان شكلاً بغير مضمون."

وواضح مدى التناقض بين ما تضمنته المذكرة الإيضاحية ونص المادة الأولى من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢.

وقد تدخل المشرع لإزالة هذا التناقض بين ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ وما أكدته نصوص الدستور من استقلال مجلس الدولة وبين ما ورد في المادة الأولى من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ من تبعية مجلس الدولة لوزارة العدل، فصدر القانون رقم ١٣٦/١٩٨٤ باستبدال المادة الأولى من قانون مجلس الدولة لتتص على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة" وهو نص مغاير لما ورد في قوانين مجلس الدولة المختلفة منذ نشأته بمقتضى القانون ١١٢ لسنة ١٩٤٦ حتى صدور هذا التعديل حيث خلصه تماماً من تبعية السلطة التنفيذية وليضع حداً لتبعية المجلس لوزير العدل وهو ما يؤكد استقلال المجلس في مواجهة السلطة التنفيذية ويدعم ما نصت عليه المادة ١٧٢ من دستور جمهورية مصر العربية لعام ١٩٧١ من استقلال المجلس.

وهذا المسلك الأخير يتفق مع المنطق وما تقضى به طبيعة الأمور بالنسبة لهيئة قضائية تقوم بالفصل في منازعات الإدارة وقيامها بالرقابة على مشروعية أعمالها.

وهو ما قضت به المادة ١٩٠ من دستور ٢٠١٤ التى نصت على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها ويحدد القانون

اختصاصاته الأخرى" ونحن نرى أن هذا النص كفل الإستقلال الكامل لمجلس الدولة عن السلطة التنفيذية.

المبحث الثالث

نظام موظفي المجلس

ينقسم أعضاء المجلس وموظفوه إلى قسمين:

القسم الأول: وهم الموظفون الفنيون الذين يشغلون الوظائف الفنية بالمجلس.

القسم الثاني: وهم الموظفون الإداريون والكتابيون وهؤلاء اكتفى المشرع بمقتضى المادة ١٢٦ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتقرير أن رئيس مجلس الدولة له سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى العاملين من شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية، كما قررت نفس المادة أن يكون لأمين عام المجلس بالنسبة لهؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال، وقد اشترطت المادة ١٢٨ من نفس القانون أن يكون تعيين هؤلاء بعد امتحان مسابقة يجريه المجلس للمرشحين طبقاً للنظام الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، كما أجازت المادة ١٢٧ تعيين الحاصلين منهم على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق في الوظائف الإدارية، ويوزع هؤلاء على أقسام المجلس المختلفة كما أجازت نفس المادة أن يعين من هؤلاء في وظيفة مندوب من يظهر كفاية ممتازة في عمله ويحصل على المؤهلات اللازمة للتعيين في هذه الوظيفة.

وعلى ما بعد ذلك أن نتعرض بإيجاز للموظفين الفنيين - قضاة مجلس الدولة

- من حيث فئاتهم والأحكام الخاصة بتعيينهم وترقيتهم وإعارتهم وتأديبهم.

أولاً فئات الأعضاء الفنيين لمجلس الدولة:

يتكون مجلس الدولة من رئيس المجلس، وعدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين، ومن المستشارين المساعدين، والنواب، والمندوبين، أما المندوبون المساعدون فهؤلاء لا يعدون أعضاء في المجلس وإنما اعتبرهم القانون ملحقين به (م ٢ من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢) وتسري على هؤلاء الأحكام الخاصة بالمندوبين بصفة عامة عدا شرط الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا (م ٧٥ من

القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢). وعلى ضوء هذا الإجمال يمكن الحديث بإيجاز عن كل فئة من فئات أعضاء مجلس الدولة.

١ - رئيس مجلس الدولة:

منذ أن نشأ مجلس الدولة بالقانون ١١٢ لسنة ١٩٤٦ وله رئيس من أعضائه خلافاً لمجلس الدولة الفرنسي الذي يتولى رئاسته من الناحية القانونية رئيس مجلس الوزراء وحيث إن تعيين رئيس مجلس الدولة قد جاء بالمادة ١٨٥ من الدستور الجديد والذي نص على أنه يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله وذلك على النحو الذي ينظمه القانون ويشغل رئيس مجلس الدولة رئاسة المحكمة الإدارية العليا.

ويتولى رئيس المجلس رئاسة الجمعية العمومية للمجلس كما له حضور جلسات الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع ولجان المجلس وجلسات قسم التشريع وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة.

ويشرف رئيس المجلس على أعمال الأقسام المختلفة للمجلس وتوزيع العمل بينها فضلاً عن الإشراف على الأعمال الإدارية وعلى الأمانة العامة، كما أن رئيس مجلس الدولة هو الذي ينوب عن المجلس في صلاته بالغير، وقد خولت المادة ٦٩ من قانون مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة تقديم تقرير سنوي لرئيس مجلس الوزراء كلما رأى ضرورة لذلك متضمناً ما أظهرته الأحكام والبحوث من نقص أو غموض في التشريع القائم أو حالات إساءة استعمال السلطة.

كما أن المادة ١٠٦ من قانون مجلس الدولة خولت لرئيس المجلس سلطات الوزير المختص المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين من شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية.

ويرأس رئيس مجلس الدولة المجلس الخاص للشئون الإدارية الذي استحدث بالقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨٤ الذي أضاف المادة ٦٨ مكرر لقانون مجلس الدولة حيث نصت هذه المادة على أن ينشأ بمجلس الدولة مجلس خاص للشئون الإدارية برئاسة رئيس مجلس الدولة وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس المجلس وعند غياب أحدهم

أو وجود مانع لدية يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس المجلس، ويختص هذا المجلس بالنظر في تعيين أعضاء مجلس الدولة وتحديد أقدمياتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم خارج المجلس وإعارتهم والتظلمات المتصلة بذلك وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا القانون، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتصلة بمجلس الدولة، ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه.

والملاحظ أن المجلس الخاص للشئون الادارية أسند اليه كافة الاختصاصات التي كان يتولاها المجلس الأعلى للهيئات القضائية على أعضاء مجلس الدولة، بحيث يستقل المجلس بكل الاختصاصات والولاية الكاملة على أعضائه.

٢ - نواب رئيس مجلس الدولة:

أشرنا إلى أن المادة الثانية من قانون مجلس الدولة نصت على وجود عدد كاف من نواب الرئيس، وهؤلاء يعينون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس، والملاحظة الجديرة بالاعتبار أن قانون مجلس الدولة لم يحدد عدد نواب الرئيس وهو مسلك درج عليه المشرع منذ استحداث وظيفة نائب رئيس المجلس.

ويحل أقدم النواب محل رئيس المجلس في اختصاصاته عند غيابه، هذا وإذا كان قانون مجلس الدولة لم يحدد عدد النواب إلا أن مواد قانون مجلس الدولة نصت على عدد منهم وهم:

- النائب الأول لرئيس مجلس الدولة للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
- نائب رئيس المجلس لهيئة المفوضين.
- نائب رئيس المجلس للمحاكم التأديبية.
- نائب رئيس المجلس القسم الفتوى.
- نائب رئيس المجلس لقسم التشريع.
- نائب رئيس المجلس للمحاكم الإدارية.
- نائب رئيس المجلس لإدارة للتفتيش الفني.

٣- وكلاء مجلس الدولة:

استحدثت وظائف وكلاء المجلس في القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ القانون الثالث لمجلس الدولة، غير أن القرار رقم ٦٩ لسنة ١٩٦٩ ألغى وظائف وكلاء المجلس وأدمجها في وظائف نواب رئيس المجلس، كما أن القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ القانون الحالي لمجلس الدولة لم ينص عند صدوره على وظائف الوكلاء ثم صدر القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ حيث عدل المادة الأولى من قانون مجلس الدولة وأعاد نظام الوكلاء من جديد.

ونرى مع غيرنا من الشراح أن هذا المسلك يدل على ما اعتاد عليه المشرع من تخطيط تشريعي حيث كان بإمكان المشرع أن يتدارك ذلك لو أنه بذل قدراً من الدراسة المتأنية البعيدة عن العجلة والتسرع.

٤- أمين عام مجلس الدولة والمكتب الفني:

رئيس مجلس الدولة يختص بحكم منصبه بالإشراف على سائر نواحي الحياة الإدارية بالمجلس، وهي متشعبة ومتنوعة ولا يستطيع أن يمارسها بنفسه إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي أسندها قانون مجلس الدولة لرئيسه، لذلك جعل القانون له فرداً يعاونه في هذه النواحي المختلفة وهو الأمين العام لمجلس الدولة، وهو أحد الأعضاء الفنيين للمجلس، يندب لهذه الوظيفة بقرار من رئيس المجلس، ويشترط فيه أن يكون في درجة مستشار مساعد على الأقل يعاون رئيس المجلس في تنفيذ اختصاصاته الإدارية، كما يشرف على الجهاز الإداري بما فيه من الموظفين الكتابيين والإداريين وله عليهم سلطة رئيس المصلحة خاصة في التأديب والعقاب، كما يرأس المكتب الفني الذي يتولى إعداد البحوث الفنية التي يطلبها أمين المجلس، كما يشرف الأمين العام على إعداد مطبوعات المجلس كالمجلة ومطبوعات الأحكام والفتاوى فضلاً عن الاهتمام بالمكتبة وأعمال الترجمة.

وعلى ذلك نصت المادة ٧١ من قانون مجلس الدولة على أن يعاون رئيس المجلس في تنفيذ اختصاصاته خاصة فيما يتعلق بالأعمال الإدارية بالمجلس أمين عام من درجة مستشار مساعد على الأقل، ويندب لهذا العمل بقرار من رئيس مجلس الدولة، كما أن المادة ٧٢ من ذات القانون قضت بأن يشكل بالأمانة العامة لمجلس

الدولة مكتب فنى برئاسة الأمين العام، ويندب أعضاؤه بقرار من رئيس المجلس من بين المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين، ويلحق به عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين، ويختص هذا المكتب بإعداد البحوث التي يطلبها رئيس المجلس، كما يشرف على أعمال الترجمة والمكتبة وإصدار المجلة ومجموعات الأحكام والفتاوى وتبويبها وتنسيقها.

٥-المستشارون والمستشارون المساعدون والنواب والمندوبون:

وهؤلاء هم بقية أعضاء مجلس الدولة الفنيين، ويعينون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية، وهؤلاء يزاولون أعمالهم القضائية والقانونية من خلال أقسام مجلس الدولة المختلفة التي سنتولى بيانها. ويلاحظ أن القانون وزع عليهم الاختصاصات بما يخلق نوعاً من التناسب والمواءمة بين أهمية الاختصاص والدرجة التي يشغلها من يسند إليه هذا الاختصاص.

ويلاحظ أن أعضاء مجلس الدولة يتولون وظائفه المختلفة عن طريق الترقية أساساً من الوظائف الدنيا إلى الوظائف العليا (مندوب مساعد، مندوب، نائب، مستشار مساعد، مستشار، وكيل مجلس الدولة، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس مجلس الدولة) إلا أن قانون مجلس الدولة أجاز التعيين في وظائفه الفنية بغير طريق الترقية وإنما من خارج المجلس في حدود معينة، غير أنه اشترط أن يكون هؤلاء من الحقوقيين الذين عملوا بالقضاء أو المحاماة أو التدريس بالجامعات وذلك في حدود ربع عدد الدرجات الخالية في كل وظيفة خلال سنة مالية، ولا يدخل في هذه النسبة وظائف المندوبين والوظائف التي تملأ بالتبادل بين شاغلها ومن يحل محلهم من خارج المجلس وكذلك الوظائف المنشأة.

٦-المندوبون المساعدون:

وهؤلاء لا يعتبرون من الأعضاء الفنيين بالمجلس وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى كما سبق الإشارة الى ذلك، وهؤلاء يلحقون بالمجلس وتسرى عليهم القواعد المقررة بالنسبة للمندوبين فيما عدا شرط الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا ويعتبر المندوب المساعد معيناً في وظيفة مندوب من أول يناير التالي لحصوله على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما في العلوم الادارية أو القانون العام.

ثانياً الشروط الخاصة فيمن يعين عضواً في مجلس الدولة:

نصت المادة ٣٧ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ على الشروط التي يتحتم توافرها في أعضاء مجلس الدولة هي:

- ١- أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
- ٢- أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
- ٣- ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مغل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.
- ٤- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- ٥- أن يكون حاصلاً على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام إذا كان التعيين في وظيفة مندوب.
- ٦- ألا يكون متزوجاً بأجنبية، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجاً بمن تنتمي جنسيتها إلى إحدى البلاد العربية.
- ٧- ألا يقل سن من يعين مستشاراً بالمحاكم عن ثمان وثلاثين سنة، وألا يقل سن من يعين عضواً بالمحاكم الإدارية عن ثلاثين سنة، وألا يقل سن من يعين مندوباً مساعداً عن تسع عشرة سنة.

ثالثاً الأحكام الخاصة بترقية أعضاء مجلس الدولة:

تستخدم وسيلتين لترقية أعضاء مجلس الدولة هما الأقدمية والاختيار:

- ١- الأقدمية: فتنبع في ترقية من هم أعضاء بمجلس الدولة حتى درجة نائب، وذلك متى حصل على درجة كفاية لا تقل عن (فوق متوسط) في تقرير التفتيش الفني الذي يجري على أعمال أعضاء مجلس الدولة.

أما الاختيار : فتنبع هذه الوسيلة في ترقية أعضاء مجلس الدولة الى وظيفة مستشار مساعد وما يعلوها، وهي تتم أيضاً على أساس الكفاية، وفي حالة تساوي

أكثر من عضو ممن يرقون بهذه الوسيلة في درجة الكفاية، فالمعاملة تتم في هذه الحالة على أساس الأقدمية (مادة ٨٤ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢).

رابعاً الأحكام الخاصة بإعارة أعضاء مجلس الدولة:

أجازت المادة ٨٨ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ إعارة أعضاء المجلس للعمل بالوزارات والمصالح والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة، وذلك بقرار من رئيس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية، على أن يتولى المجلس وحده تحديد المكافأة التي يستحقها العضو المعار عن هذه الأعمال، أما إذا كانت الإعارة لبلد أجنبي أو هيئة دولية فتتم بقرار جمهوري بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية.

ولا يجوز أن يترتب على الإعارة الإخلال بحسن سير العمل في مجلس الدولة، وإذا كانت لبلد أجنبي فيشترط ألا تزيد مدة الإعارة عن أربع سنوات، وعلى ذلك فإن قانون مجلس الدولة الأخير أغفل القيود الخاصة بالإعارة التي كانت واردة في القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ وهي أن يكون المرشح للإعارة قد قضى في وظيفته في مجلس الدولة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وألا تقل وظيفته عن نائب، وألا تقل الدرجة المالية للوظيفة المعار إليها عن درجة الوظيفة التي يشغلها، وأن يكون نوع العمل في الوظيفة المعار إليها مما يكسب العضو المعار خبرة في عمله بمجلس الدولة.

كما أن القانون الجديد غير من الأداة التي تختص بإصدار القرار الخاص بالإعارة، ففي ظل القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ قررت المادة ٦٢ منه أن يجوز إعارة العضو بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية.

في حين أن القانون الجديد خول هذا الاختصاص لرئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية (م ٨٨).

ويحقق نظام الإعارة وعلى وجه التحديد إعارة أعضاء مجلس الدولة للوزارات والمؤسسات وغيرها من مصالح الحكومة فوائد كثيرة ومتعددة، لأنه يحقق قدراً من

الحوار المثمر والبناء بين المجلس من ناحية وبين الإدارة العامة من ناحية أخرى، كما أنه من ناحية ثانية من شأنه أن يزود أعضاء المجلس بخبرة عملية تمنحهم الفرصة للوقوف على طبيعة سير العمل في الجهاز الإداري للدولة، وما يصادفه من مشاكل على ضوء القوانين واللوائح المعمول بها ومن ثم يعطى لهم ذلك الفرصة الكافية للوقوف على قصور القوانين واللوائح مما يمكن أن يتلافاه المجلس بعد ذلك عن طريق قسم التشريع عندما يقوم بصياغة مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية، وهو ما يؤدي الى القول بأن نظام الإعارة الداخلية يساعد أعضاء مجلس الدولة على حسن أداء وظائفهم بأقسام المجلس المختلفة ويتفق مع الطبيعة الخاصة لمجلس الدولة.

كما أن المادة (٦٩) من القانون الجديد أعطت لرئيس مجلس الدولة كلما وجد ضرورة لذلك أن يقدم تقريراً إلى رئيس مجلس الوزراء متضمناً ما أظهرته الأحكام أو البحوث من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه أو حالات إساءة استخدام السلطة من أي جهة من جهات الإدارة أو مجاوزة تلك الجهات لسلطاتها. ومن الطبيعي أن الوقوف على كثير من هذه الأمور لا يتسنى لرئيس مجلس الدولة إلا عن طريق أعضاء مجلس الدولة المعارين إلى الجهات الحكومية المختلفة.

خامساً الاحكام الخاصة بتأديب أعضاء مجلس الدولة:

إذا ارتكب عضو مجلس الدولة ما يخل بواجبات وظيفته فإنه يحاكم أمام مجلس تأديب خاص نصت عليه المادة ١١٢ من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ وعلمنا الآن أن نبين تشكيل هذا المجلس ثم الإجراءات التي يجب اتباعها أمامه والعقوبات التي يملك مجلس التأديب توقيعها على العضو. ١٩٧٢

١ - تشكيل مجلس التأديب:

يشكل مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة من رئيس المجلس وستة من نواب رئيس المجلس بحسب أقدميتهم، وعند خلو وظيفة رئيس المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم النواب وكذلك الأمر بالنسبة لباقي أعضاء مجلس التأديب فيحل محل كل منهم من يليه في الأقدمية من نواب الرئيس ثم من المستشارين.

٢ - إجراءات رفع الدعوى التأديبية والمحاكمة:

يتولى اختصاص رفع الدعوى التأديبية نائب رئيس المجلس لإدارة التفتيش الفني وذلك بناءً على تحقيق جنائي أو إداري يتولاه أحد نواب رئيس المجلس إذا كان العضو المتهم يشغل وظيفة مستشار، أما من باقي أعضاء المجلس فإن الذي يتولى التحقيق أحد المستشارين ويصدر قرار من رئيس المجلس بتحديد من يتولى التحقيق، ويجب أن تتضمن عريضة الدعوى التهمة الموجهة الى العضو، والأدلة المؤيدة لها، وتودع العريضة سكرتارية مجلس التأديب، ليصدر المجلس قراره بإعلان العضو للحضور أمامه كما يحق للمجلس أن يندب أحد أعضائه ليجري ما يراه لازماً من تحقيقات. وللمجلس أو من يندبه لهذا الغرض السلطة الخاصة بقاضي الجناح بالنسبة للشهود الذين يرى وجهاً لسماع أقوالهم.

وللمجلس أن يكلف العضو بالحضور بميعاد اسبوع بناءً على أمر من رئيس المجلس إذا رأى وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها، ويجب أن يتضمن تكليف العضو بالحضور بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.

كما يجوز لمجلس التأديب عندما يقرر السير في إجراءات المحاكمة أن يوقف العضو عن مباشرة مهام وظيفته أو يقرر منحه أجازة إجبارية وفي كل الحالات له الحق أن يعيد النظر في أمر الإيقاف أو الأجازة، ويستحق العضو مرتبه في خلال الوقف أو الإجازة ما لم يتضمن قرار المجلس خلاف ذلك.

ويجب أن تكون جلسات المحاكمة سرية ويصدر المجلس حكمه بعد أخذ رأى إدارة التفتيش الفني وسماع دفاع العضو الذي يجب أن يكون آخر من يتكلم.

ويحضر العضو إجراءات المحاكمة بنفسه، ويحق له أن يدافع عن نفسه كتابة، كما يجوز له أن ينيب عنه أحد أعضاء المجلس للقيام بهذه المهمة، كما يجوز له أن يوكل محام وفي حالة غيابه أو عدم الإنابة فإن الحكم يصدر في غيبته بعد التأكد من صحة إعلانه بعريضة الدعوى.

ويصدر المجلس قراره مسبباً، ويجب أن تستلئ هذه الأسباب عند النطق بالحكم الذي يجب أن يكون في جلسة سرية، وهذا الحكم غير قابل للطعن بأي طريقة من طرق الطعن في الأحكام.

ومما لا ريب فيه أن تأديب أعضاء مجلس الدولة أمام مجلس تأديب خاص من أعضاء المجلس وعلى أعلى مستوى لأعضائه كما سبق البيان يعتبر ضماناً كبرى بالنسبة للأعضاء تحميهم من تدخل السلطة التنفيذية في شئونهم وتقيهم من أي تأثير في النزاهة والحيمة التي يجب أن يتصفوا بها.

وقد اعتبرت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في ١٦/٥/١٩٨٢ في القضية رقم ١٠ لسنة ١ قضائية مجلس التأديب المشار إليه هيئة قضائية عهد إليها المشرع باختصاص قضائي محدد الأمر الذي يترتب عليه أن القرارات الصادرة من هذا المجلس تعتبر أحكاماً قضائية من درجة واحدة من غير الجائز الطعن فيها بأي طريقة من الطرق، ولا يعتبر بالتالي قرارات إدارية.

٣ - الجزاءات التي يملك المجلس توقيعها

العقوبات التي يملك مجلس التأديب أن يوقعها على العضو اللوم أو العزل.

أ- عقوبة العزل: وهي تعنى عزل عضو المجلس من وظيفته، وتعتبر الفترة من تاريخ صدور الحكم حتى نشره في الجريدة الرسمية أجازة حتمية، والتاريخ الذي يعتد به في العزل هو تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.

ب - اللوم: وهو يعني لوم العضو وتأنيبه عما صدر منه مخالفاً لما تقضى به واجبات وظيفته، ويصدر قرار بتنفيذ هذه العقوبة من رئيس المجلس ولا ينشر منطوق هذا الحكم أو قرار اللوم في الجريدة الرسمية.

وفي نطاق الجرائم الأخرى التي تنسب إلى العضو إذا اقتضى ذلك حبس العضو، فإنه يجب أن يوقف عن مباشرة مهام وظيفته طوال مدة الحبس، ولمجلس التأديب أن يوقف العضو عن مباشرة مهام وظيفته طوال مدة الحبس، ولمجلس التأديب أن يوقف العضو أثناء التحقيق أو المحاكمة من جريمة وقعت منه، ويحق

لمجلس التأديب أن يصدر هذا القرار من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من رئيس المجلس ويحق للعضو أن يتقاضى مرتبه مدة الوقف ما لم يقرر المجلس صرف نصف المرتب، ويحق لمجلس التأديب أن يعيد النظر في أي وقت في أمر الوقف أو المرتب.

سادساً ضمانات أعضاء مجلس الدولة:

أحاط القانون أعضاء مجلس الدولة بمجموعة من الضمانات توفر لهم الحيدة والاستقلال في مباشرة وظائفهم، وأهم هذه الضمانات هي ضمانات عدم القابلية للعزل، والتأديب بواسطة مجلس خاص، وحيث أنه سبق الحديث عن نظام التأديب بواسطة مجلس خاص، ومن ثم فإن الحديث هنا يقتصر على ضمانات عدم القابلية للعزل.

نصت المادة ١١ من قانون مجلس الدولة على أن: "أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها غير قابلين للعزل، ويسرى بالنسبة لهؤلاء جميع الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن.

ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة أو فقد أسباب الصلاحية لأدائها لغير الأسباب الصحية أحيل الي المعاش أو نقل الى وظيفة معادلة غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس التأديب.

وينتقد بعض الفقه نظام عدم القابلية للعزل الذي قرره المادة ٩١ المشار إليها، ويرى أنه يجب ألا يسمح بالعزل بقرار جمهوري بسبب فقد الثقة والاعتبار وذلك لأن العضو الذي يفقد الثقة أو الاعتبار يعد مَخْلًا بواجبات وظيفته ويمكن لمجلس التأديب أن يقرر عزله في هذه الحالة بدلاً من ترك الأمر لاعتبارات سياسية غير مضمونة، ووفقاً لذلك فإن أعضاء مجلس الدولة يتمتعون بكافة الضمانات المقررة للقضاة في عدم جواز قابليتهم للعزل.

الفصل الرابع

هيئات المجلس وأقسامه

المبحث الأول

هيئات المجلس

يتكون المجلس من مجموعة من الهيئات تتولى الإشراف على مهامه القضائية ودوره في الإفتاء وصياغة مشروعات القوانين واللوائح، كما تتولى إدارة شئون أعضاء مجلس الدولة الإدارة اليومية لأعماله، وهذه الهيئات هي:

١- الجمعية العمومية لمجلس الدولة.

٢- الأمانة العامة والمكتب الفني.

٣- المجلس الخاص للشئون الإدارية.

المبحث الأول

الجمعية العمومية لمجلس الدولة

تتشكل الجمعية العمومية من جميع المستشارين بمجلس الدولة، ويتولى رئاستها رئيس مجلس الدولة وعند غيابه يتولى رئاستها أقدم الحاضرين من نواب رئيس المجلس، وعند غياب النواب يتولى رئاستها أقدم الحاضرين من المستشارين. وتدعى للانعقاد بناءً على طلب من رئيس المجلس أو خمسة من أعضاء الجمعية العمومية ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتمارس الجمعية العمومية العديد من الاختصاصات هي:

١- إنشاء لجنة أو أكثر من رؤساء إدارات قسم الفتوى يعهد إليها بمسائل معينة.

٢- الموافقة على تعيين نواب رئيس المجلس ووكلائه الذين يعينون بعد ذلك

بقرار من رئيس الجمهورية.

٣- إصدار اللائحة الداخلية للمجلس.

٤- إبداء الرأي في تعيين رئيس المجلس من بين نواب رئيس المجلس، غير أن

هذا الاختصاص ليس موكولاً لجميع أعضاء الجمعية العمومية، وإنما هو قاصر فحسب على جمعية خاصة من بين الجمعية العمومية تتكون من

رئيس المجلس ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين وحيث أنه بعد صدور القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٧ بتعديل طريق إختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية لم تعد الجمعية العمومية هي من تقوم بتعين رئيس مجلس الدولة بل تقوم باختيار ثلاثة مرشحين من بين أقدم سبعة نواب تقتص المادة الرابعة من القانون ١٣ لسنة ٢٠١٧ على أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة والمشكلة من رئيس المجلس ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله . ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوماً على الأقل . وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل إنتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس

المبحث الثاني

الأمانة العامة وإدارة التفتيش الفني

والأمانة العامة يرأسها الأمين العام لمجلس الدولة، وقد سبق الحديث عنها عند التعرض لموظفي المجلس.

أما إدارة التفتيش الفني فيتولى رئاستها أحد نواب رئيس المجلس وتتولى التفتيش الفني على أعمال المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين المساعدين. وتتكون هذه الإدارة من عدد كاف من المستشارين، والمستشارين المساعدين، وتتولى تقدير الكفاية لأعضاء المجلس السابق ذكرهم والتي تتحصل من التفتيش الفني على أعمالهم، ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: (كفء-فوق المتوسط-متوسط-أقل من المتوسط).

المبحث الثالث

المجلس الخاص للشئون الإدارية

كان القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٦٩ الخاص بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية يخول لهذا المجلس الإشراف على مجلس الدولة وسائر الهيئات القضائية. وبصدور القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨٤ استرد المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة اختصاصاته حيث أضاف - القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨٤ للقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم مجلس الدولة - المادة ٦٨ مكرر والتي نصت على "ينشأ بمجلس الدولة مجلس خاص للشئون الإدارية برئاسة رئيس مجلس الدولة وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس المجلس وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس المجلس، ويختص هذا المجلس بالنظر في تعيين أعضاء مجلس الدولة وتحديد أقدمياتهم ونقلهم وندبهم خارج المجلس وإعارتهم والتظلمات المتصلة بذلك، وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في القانون، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتصلة بمجلس الدولة، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه. وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه. كما يلزم موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية على تعيين أعضاء المجلس من درجة مستشار فأقل والمندوبين المساعدين.

المبحث الرابع

تكوين مجلس الدولة

مقدمة :

نصت المادة الثانية من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ على ما يلي:

يتكون مجلس الدولة من:

- ١- القسم القضائي. ٢- قسم الفتوى. ٣- قسم التشريع.
- وتقسيم المجلس إلى أقسام ثلاثة يتفق مع المسلك الذى انتهجه المشرع في قانون مجلس الدولة رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ والقانون الثانى لمجلس الدولة رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ حيث كان مجلس الدولة في ظل هذين القانونين يتكون من أقسام ثلاثة

على خلاف ما انتهجه المشرع في ظل القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ الثالث لمجلس الدولة، كذلك الأمر في ظل قانون مجلس الدولة رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ حيث كان كل منهما يقسم مجلس الدولة إلى قسمين:

الأول : القسم الإستشاري للفتوى والتشريع.

الثاني : القسم القضائي.

وقبل أن نوضح اختصاص كل من أقسام مجلس الدولة فإننا سنورد بعض الملاحظات التي وجهها الفقه على فكرة دمج قسم التشريع مع قسم الفتوى، أو جعل كل منهما قسماً قائماً بذاته، ومسلك المشرع في ظل القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ومدى ما تلافاه من عيوب وجهت إلى ما انتهجه المشرع في ظل القانونين رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ ورقم (٩) لسنة ١٩٤٩ الذي يقوم على فصل قسم الفتوى عن قسم التشريع

أولاً استقلال قسم الفتوى عن قسم التشريع في ظل القانون

١١٢ لسنة ١٩٤٦ والقانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩:

أشرنا إلى أن القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ والقانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ كان كل منهما يجعل كلاً من قسم الرأي وقسم التشريع مستقلاً ، وقد وجه الفقه بعض النقد الى منهج المشرع في ظل هذين القانونين، وذلك استناداً على عدم جواز فصل المهمة التي كان يقوم بها قسم التشريع عن المهمة التي يقوم بها قسم الفتوى (الرأي) وذلك لأن المهمة الأولى (الصياغة) ليست في حقيقتها الا نوعاً من الإفتاء، فقسم التشريع يبدى رأيه في صياغة التشريع كما يبدى قسم الرأي رأيه في الموضوع ولكن هذا النقد لم يكن له محل، ذلك أن المشرع في ظل القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦- لم يغفل هذه الملاحظة فنص في المادة ١٩ من هذا القانون على أنه يجوز أن يشترك في جلسات قسم التشريع مستشار من قسم الرأي عند النظر في مشروعات القوانين أو المراسيم أو اللوائح أو القرارات التي تتصل بإداراتهم. كما خطى القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ خطوة موفقة في خلق نوع من الحوار والترابط بين القسمين، فقرر هذا القانون إنشاء جمعية عمومية تجمع قسماً الرأي والتشريع يرأسها وكيل

واحد من وكلاء المجلس، وعلى ذلك فلا محل للنقد الذي وجه الى هذا التقسيم في ظل القانونين سالفى الذكر وذلك لما وفره المشرع من إيجاد صلات بين القسمين. **ثانياً منهج المشرع في ظل القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ والقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩:**

دمج القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ بين قسم الرأي وقسم التشريع وجعلهما قسماً واحداً هو القسم الاستشاري للفتوى والتشريع، وقد عللت المذكرة الإيضاحية هذا الدمج بقولها: أن الفتوى هي تطبيق القوانين واللوائح القائمة، فمن يمارسها هم أقدر الناس على تعرف عيوب التشريعات القائمة وأوجه إصلاحها ولن يكون التشريع الجديد كاملاً إلا إذا اجتمعت خبرة الرأي الى فن الصياغة، كما أن من يتولون إعداد التشريع وصياغته هم يكونون الناس بقصد الشارع عند تطبيق التشريع الجديد وتفسيره لدى الإفتاء.

وعلى هذا النهج سار المشرع في ظل القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ على أنه كما أسلفنا لم يكن الفصل الذي تحقق في ظل القانون الأول والقانون المعدل له يحول دون وجود صلات القربى بينهما التي من شأنها ان تحقق الهدف الذي ابتغى المشرع تحقيقه من تقرير هذا الدمج، لهذا فإن البعض نادى بضرورة فصل القسمين عن بعضهما في ظل هذين القانونين.

ثالثاً منهج المشرع في ظل القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢:

عاد القانون الأخير لمجلس الدولة إلى النهج الذي اتبعه القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦، والقانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ بجعل كل من قسمي الرأي والتشريع قسماً قائماً بذاته، ونرى أن منهج المشرع في ظل القانون الأخير قد تلافي كل ما يمكن أن يوجه إلى فصل القسمين من نقد وذلك لما يلى:

أولاً : أنه أوجب عند اجتماع قسم التشريع لممارسة اختصاصه، فعلى رئيسه أن يدعو رئيس إدارة الفتوى المختصة عند نظر التشريعات الخاصة بإدارته للاشتراك في المداولات وجعل له صوتاً معدوداً مع أصوات قسم التشريع، ومن ثم

فإن اشتراك إدارات الرأي مع قسم التشريع وجوبياً بنص القانون خلافاً لما كان منصوص عليه في قانون مجلس الدولة الأول على ما أسلفنا حيث كان يوجب اشتراك مستشار من قسم الرأي في جلسات قسم التشريع عند النظر في مشروعات القوانين أو المراسيم أو اللوائح أو القرارات التي تتصل بإدارتهم.

ثانياً : أنه جمع بين القسمين (قسم الرأي وقسم التشريع) تحت لواء جمعية عمومية خاصة بهما، ومن ثم فإنه حقق مزايا كل من الفصل لما يترتب عليه من التخصص والاستقلال ومزايا الدمج بما رتبته من إيجاد وسائل مختلفة للحوار والترابط بينهما، وهو أمر محمود للمشرع في ظل القانون الأخير.

غير أن أخذ المشرع تارة بالفصل وتارة بالدمج يدل على تخطيط المشرع وعدم الأخذ بسياسة واحدة في هذا الشأن.

وبعد هذه الملاحظة فإننا سنبين أقسام مجلس الدولة كل قسم على حدة من حيث تشكيله واختصاصه كل في مطلب خاص وسوف نفرد للهيئات الأخرى الملحقة بالمجلس المطلب الأخير.

المطلب الأول **قسم الرأي (الفتوى)**

١ - تكوين قسم الرأي: يتشكل قسم الفتوى من إدارات تخصصية لمختلف جهات الإدارة كما يتكون أيضاً من لجان للفتوى تتكون من رؤساء إدارات الفتوى ذات الاختصاصات المتجانسة، وعلى ذلك فهو يضم إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، والهيئات العامة، ويرأس كل إدارة من هذه الإدارات مستشار، أو مستشار مساعد ويعين عدد الإدارات في الجهاز الإداري للدولة كما تحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية لمجلس الدولة، كما يضم إلى جوار ذلك لجان الفتوى ذات الاختصاصات المتجانسة كما أشرنا.

٢ - المفوضون لدى جهات الإدارة: أجاز قانون مجلس الدولة أن يندب برئاسة الجمهورية وبرئاسة مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والهيئات العامة وذلك بناء على طلب ذوي الشأن مستشارون مساعدون أو نواب للعمل

كمفوضين لمجلس الدولة، وذلك للاستعانة بهم في دراسة الشئون القانونية والتظلمات الإدارية ومتابعة ما يهم هذه الجهات لدى المجلس، أو ما للمجلس لديها من مسائل تدخل في اختصاصه طبقاً للقوانين واللوائح.

ويعتبر مفوض مجلس الدولة ملحقاً بإدارة الفتوى المختصة بشئون الجهة التي يعمل فيها، وقد استحدث نظام مفوضي الدولة بالقانون رقم ٢٦٥ لسنة ١٩٥٥ وقد سبقت عدة مزايا لهذا النظام منها أنه يخلق صلة بين جهة الإدارة ومجلس الدولة مما ييسر التفاهم بينهما، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى سرعة انجاز الأعمال الإدارية واكتساب مفوض الدولة الخبرة الإدارية بجانب الخبرة القانونية مما يجعلهم أقدر في الوصول إلى الحلول القانونية وتفهم مجريات العمل الإداري.

٣ - اختصاص قسم الرأي: اختصاص قسم الرأي بصفة عامة يتمثل في إبداء الرأي في المسائل القانونية التي تهم جهات الادارة المختلفة إلا أن هذا الاختصاص يختلف باختلاف أهمية المسألة المعروضة، وهل تختص بإبداء الرأي فيها إدارة الفتوى الملحقة بكل وزارة أو هيئة عامة أم كانت مختصة بإبداء الرأي فيها اللجان المتخصصة في نوع معين من المسائل التي نص القانون على جواز انشائها.

أ- اختصاص إدارات الرأي الملحقة بالوزارات والهيئات العامة:

تختص إدارات الرأي الملحقة بالوزارات والمؤسسات العامة بما يلي:

١- إبداء الرأي في المسائل التي يطلب الرأي فيها من رئاسة الجمهورية والوزارات والمصالح العامة.

٢- فحص التظلمات الإدارية التي ترفع إليها من ذوي الشأن في القرارات الإدارية التي تصدرها الهيئات الملحقة بها هذه الادارات.

٣- إبداء الرأي في الصلح أو التحكيم أو العقود الإدارية التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف جنيه حيث حتم القانون (م٥٨) على الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ألا تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها عن خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء إدارات الرأي الملحقة بهذه الجهات.

٤- كما أجازت المادة ٥٩ من القانون الأخير إلحاق مستشارين مساعدين أو نواب للعمل كمفوضين لمجلس الدولة برئاسة الجمهورية، وبرئاسة مجلس الوزراء، وبالوزارات، والمحافظات، والهيئات العامة، وذلك بناء على طلب من رؤساء هذه الجهات للاستعانة بهم في دراسة الشئون القانونية والتظلمات الإدارية، ومتابعة ما يهم هذه الجهات لدى مجلس الدولة أو ما يهم مجلس الدولة لدى هذه الجهات من مسائل تدخل في اختصاص مجلس الدولة طبقاً للقوانين واللوائح.

ب- أما اللجان التي تختص بنوع معين من الاختصاصات:

فقد أجاز قانون مجلس الدولة الأخير بقرار من الجمعية العمومية لمجلس الدولة إنشاء لجنة أو أكثر تتخصص في نوع معين من المسائل بحيث يمتد اختصاص هذه اللجان إلى جميع إدارات الفتوى، ويبين قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة طريقة تشكيل هذه اللجان، وتختص هذه اللجان بإبداء الرأي في الأمور الآتية:

١- إبداء الرأي في المسائل التي يحيلها رئيس إدارة الفتوى لأهميتها، غير أن هذه الاحالة تعد وجوبية في المسائل الآتية.

٢- كل التزام موضوعه استغلال مورد من مواد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة.

٣- عقود التوريد والأشغال العامة، وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقاً والتزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عليها إذا زادت قيمته على خمسين ألف جنيه.

٤- المسائل التي يرى أحد المستشارين رأياً يخالف فتوى صدرت من إحدى إدارات قسم الفتوى أو لجانه.

٥- الترخيص في تأسيس الشركات التي ينص القانون على أن يكون إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية.

على أنه بالنسبة لإدارة الفتوى الملحقة بالمصالح والهيئات العامة خارج مدينة القاهرة، فإنه يجوز لرئيس الدولة أن يمنحها اختصاص اللجنة المتخصصة وفي هذه الحالة تملك اختصاصات هذه اللجان.

على أن يلاحظ أن التجاء جهات الإدارة إلى إدارات الرأي ، جوازي فيما عدا الحالات التي أوجب القانون أخذ رأيها فيها، كما أن التزام جهات الإدارة بمضمون الفتوى جوازي كذلك، وذلك يرجع إلى أنه في النهاية يجب أن يتحقق لهذه الجهات حرية التقدير في الأخذ بما انتهت إليه إدارات الرأي من عدمه، والقول بغير ذلك من شأنه المساس باستقلال السلطة التنفيذية، كما أن من شأنه أن يضع الجهات الإدارية تحت وصاية المجلس، وذلك فيما عدا فتاوى الجمعية العمومية لمجلس الدولة التي تصدر في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو الهيئات المختلفة أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، طبقاً لنص المادة (٦٦) بند (٨ د) من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ يكون رأي الجمعية العمومية ملزماً للجانبين، ولا تعتبر فتاوى هذا القسم قرارات إدارية كما لا تعد أحكاماً قضائية ملزمة أو قابلة للطعن وإنما هي مجرد آراء استشارية لجهة الإدارة تأخذ بها أو تخالفها حتى في تلك المجالات التي تلزم فيها الإدارة بالرجوع إلى قسم الفتوى، ففي مثل هذه الحالات يتعين على جهة الإدارة أخذ الرأي والا كان القرار معيباً بعيب الشكل الجوهرى إلا أنها لا تلتزم بالأخذ به.

المطلب الثاني

قسم التشريع

أولاً تشكيل قسم التشريع: يرأس قسم التشريع أحد نواب رئيس المجلس وعضو المجلس الخاص ويشكل من عدد كاف من نواب رئيس المجلس ممن اشتغلوا بالقسم القضائي وبقسم الفتوى مدة عشر سنوات على الأقل ويتولى رئاسة المجلس نائب رئيس المجلس أو أقدم المستشارين في القسم عند غياب نائب رئيس المجلس، وقد سبق أن أشرنا إلى أن القانون الجديد أوجب على رئيس قسم التشريع أن يدعو رئيس إدارة الفتوى المختصة عند نظر التشريعات الخاصة بإدارته للاشتراك في المداولات

ثانياً: اختصاصات قسم التشريع: قبل الحديث عن اختصاصات قسم التشريع فإن هناك ملاحظة جديرة بالاعتبار مؤداها أن اختصاصات قسم التشريع لا تتعلق بأي

حال من الأحوال بسن التشريع، لأن هذه السلطة تتولاها السلطة التشريعية أي البرلمان بمجلسيه، لذلك فإنه من التجاوز أن تسمى اختصاصات هذا القسم تشريعاً ذلك أن العملية التشريعية تختص بها سلطة مختصة كما أشرنا فلا يملك قسم التشريع أن يبيت في تشريع ما، ودور القسم هنا لا يخرج عن صياغة مشروعات القوانين واللوائح التي تختص بها السلطة التنفيذية وتدور اختصاصات هذا القسم حول أمور ثلاثة

١- التأكد من مشروعية القانون أو القرار المعروض عليه وذلك بمراجعته على نصوص القانون التي تليه في درجات السلم القانوني.

٢- مدى التوافق والتناسق بين النص والنصوص الأخرى التي تتساوى معه في سلم التدرج القانوني، وعلى ذلك فإن الأمر هذا لا يتعلق بالتأكد من مشروعية مشروع القانون أو القرار للقواعد الأعلى منه درجة، وإنما المقصود تحقيق التناسق والحيولة بين تضارب القواعد القانونية وتعارضها بخلق نوع من وحدة الاتجاه بين النصوص التشريعية التي تعالج موضوعاً واحداً.

٣- الوقوف على مدى ما ينطوي عليه المشروع المعروض من فن الصياغة ووضوحها وسلامة التعبير.

واختصاصات قسم التشريع حسبما حددتها المادة ٦٢ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ تتحدد فيما يلي:

أولاً : ما حتمته المادة ٦٣ من هذا القانون بوجوب أن تعرض كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أي قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية أو لائحية المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته ، كما يجوز للوزارات والمصالح أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات.

ثانياً: ما نصت عليه المادة ٦٤ من هذا القانون من مراجعة صياغة التشريعات التي يرى مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة نظرها على وجه الاستعجال، على أن هذا الاختصاص ليس موكولاً لقسم التشريع جميعه، وإنما إلى لجنة خاصة مشكلة من رئيس قسم التشريع أو من يقوم مقامه وأحد مستشاري القسم يندبه رئيس القسم ورئيس إدارة الفتوى المختصة.

والسؤال الآن عن الجزاء الذي يترتب على إغفال عرض مشروعات القوانين

والقرارات الجمهورية ذات الصلة التشريعية واللوائح التي يصدرها الوزراء وهي المسائل التي نص قانون مجلس الدولة على ضرورة عرضها على قسم التشريع. يميز الفقه في هذا النطاق بين مشروعات القوانين ومشروعات القرارات التنظيمية التي تصدر من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء.

بالنسبة لمشروعات القوانين:

فلا يترتب على عدم عرضها على قسم التشريع بطلانها ومرد ذلك أن مناقشة المجلس النيابي - السلطة التشريعية - لهذه المشروعات تعتبر تغطية لاحقة لما يكون قد شابها من عيوب في الصياغة، ومن شأن إقرار المجلس النيابي لهذه المشروعات أن يكفل تصحيح هذا العيب، فعدم عرض مشروعات القوانين على قسم التشريع لا يعتبر مخالفة دستورية توجب بطلان القانون، وذلك لأن قانون مجلس الدولة لم يكن يبغي من وراء ذلك جعل المجلس رقيباً على السلطة التشريعية حتى يمكن القول ببطلان هذه التشريعات، وإنما ابتغى من وراء ذلك جعل المجلس رقيباً على السلطة التنفيذية عندما تقترح مشروع قانون فضلاً عن إسناد هذا الأمر لجهة قانونية مختصة توفر لرجالها الإحاطة بالقانون بالإضافة إلى فن الصياغة. لذلك فإن عدم الرجوع إلى قسم التشريع ليس عيباً جوهرياً يلحق بالتشريع ويؤدي إلى بطلانه.

أما بالنسبة للقرارات التنظيمية الصادرة من السلطة التنفيذية:

فقد استقر الرأي فقهاً وقضاً على أن عرض القرارات التنظيمية الصادرة من السلطة التنفيذية على قسم التشريع قبل إصدارها ليس واجباً حتماً فقط، بل هو إجراء جوهري يترتب على مخالفته البطلان، وفي هذه الحالة يعتبر القرار أو اللائحة معيباً بعيب الشكل.

ومن الحجج الهامة التي استندت إليها محكمة القضاء الإداري (في حكمها الصادر في ١٩٥٢/٢/٢٦) قولها: "أنه لم يرد نص صريح على الجزاء الذي يترتب على الإخلال بهذا الإجراء الواجب، وفيما إذا كان الجزاء "البطلان". ومن حيث القول بأن البطلان لا يكون إلا بنص صريح قد أصبح قولاً مهجوراً ولم يعد هو الرأي المعمول به، وبخاصة في دائرة القانون العام.

ومن حيث أنه عند السكوت عن الجزاء الذي يترتب على مخالفة اجراء واجب يتعين استخلاص هذا الجزاء من ذلك التشريع، ومن الحكمة التي توخاها الشارع في جعله الاجراء وجوبياً، فإذا تبين أن هذه المحكمة من شأنها أن تجعل الاجراء جوهرياً، وجب أن يكون الجزاء على الاخلال بهذا الاجراء الجوهري هو "البطلان" وقد أكدت محكمة القضاء الإداري ذلك في حكم آخر (١٩٥٢/٦/٢١) وهي بصدد التعرض لمشروعية المرسوم بقانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٥٢ فقررت أن تمسك الحكومة بهذا المرسوم لمنع سماع الدعوى غير جائز ذلك أن هذا المرسوم لم يعرض على قسم التشريع فيكون باطلاً من حيث الشكل.

المطلب الثالث

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع:

سبق أن أشرنا إلى أن القانون الجديد للمجلس جعل من قسم الرأي وقسم التشريع قسماً مستقلاً، إلا أنه جمع بين القسمين في جمعية عمومية لقسمي الفتوى والتشريع، ويرجع هذا المسلك إلى ما سنه القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩، ثم عاد إليه المشرع في ظل القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ وهو مسلك حميد من المشرع للاعتبارات التي سبق أن أشرنا إليها. وفيما يلي نبين تشكيل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ثم اختصاصها:

أ- تشكيل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع:

تشكل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وعضوية نواب رئيس المجلس لقسمي الفتوى والتشريع ومستشاري قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى. (653)

ب- اختصاصات الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع:

تختص الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسبباً في المسائل الآتية:

١- المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة، ويجوز

لمن طلب الرأي أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية العمومية عند النظر في هذه المسائل، كما يجوز له أن يندب من يراه من ذوي الخبرة كمستشارين غير عاديين ويكون لهم وان تعددوا صوت واحد في المداولات.

٢- المسائل التي ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأياً يخالف رأى لجنة أخرى أو رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

٣- المسائل التي ترى إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها لأهميتها.

٤- المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض، وفي هذه الحالة يكون القرار الذي تنتهي إليه الجمعية العمومية ملزماً لطرفي النزاع.

٥- وتختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصلة التشريعية واللوائح التي يرى قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها.

ج - اختصاص المكتب الفني للجمعية العمومية بالمسائل الآتية:

١- إعداد مشروعات الفتاوى واستخلاص المبادئ القانونية التي تتضمنها تلك

الفتاوى والعمل على نشرها وتوزيعها على أعضاء مجلس الدولة أولاً بأول.

٢- إعداد بيان بالموضوعات التي طرحت على الجمعية والمتضمنة تشريعات

يشوبها القصور أو الغموض.

وتحال الموضوعات التي تختص بها الجمعية العمومية مشفوعة بتقرير العضو

الذي أعده ، وتعقيب من رئيس الإداري على ما ورد بالتقرير مبيناً رأيه وأسانيده

.ويكون حضور رؤساء إدارات الفتوى جلسات الجمعية العمومية شخصياً ولا يجوز

أن ينوب عنهم أحد من أعضاء إدارات الفتوى في حضور هذه الجلسات ، وفي حالة

قيام مانع لدى رئيس الإداري يحول بينه وبين حضور الجلسة يخطر رئيس الجمعية

العمومية بذلك قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف ، وفي هذه الحالة لرئيس الجمعية

العمومية التصريح بحضور أقدم أعضاء الإدارة جلسة الجمعية العمومية ولا يكون له

صوت معدود فى المداولات . كما يجوز أن يحضر مع رئيس الإدارة العضو الذي أعد التقرير عند مناقشة الموضوع دون أن يكون له صوت معدود.

المطلب الرابع

هيئات القسم القضائي لمجلس الدولة المصري

نصت المادة الثالثة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة على أن

يؤلف القسم القضائي من:

أ- المحكمة الإدارية العليا.

ب- محكمة القضاء الإداري.

ج- المحاكم الإدارية.

د- المحاكم التأديبية.

هـ- هيئة مفوضي الدولة.

وبناءً على نص هذه المادة يتبين أن القسم القضائي يتكون من هيئات خمس حيث أدخل هذا القانون المحاكم التأديبية ضمن القسم القضائي لمجلس الدولة، وهذه الخطوة من الخطوات العظيمة التي سيكون لها الأثر الكبير في تطور مجلس الدولة وفي إرساء الضمانات التي تحول دون اعتداء الإدارة العامة على عمالها، وتحول بين أي تعسف أو انحراف يمكن أن يقع عليهم وهو ما سنبينه بالتفصيل حينما نتعرض للهيئات المختلفة التي يتألف منها القسم القضائي. وسوف نخصص فرعاً لكل هيئة من الهيئات التي يتألف منها القسم القضائي بمجلس الدولة.

الفرع الأول

المحكمة الإدارية العليا

استحدثت المحكمة الإدارية العليا لأول مرة في القانون الثالث لمجلس الدولة

رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ فلم تكن موجودة في القانون الأول ١١٢ لسنة ١٩٤٦، ولا في القانون الثاني رقم ٩ لسنة ١٩٤٩.

وقد نصت عليها المادة ٣ من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩، كما نص عليها

في القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ في المادتين (٣، ٤) من هذا القانون وهو القانون الأخير المنظم لمجلس الدولة. ومقرها مدينة القاهرة وتعد هذه المحكمة المعقب النهائي لجميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية.

تشكيل المحكمة الإدارية العليا:

يرأس هذه المحكمة رئيس مجلس الدولة كما يرأس الهيئة المشكلة طبقاً للمادة ٥٤ مكرر من قانون مجلس الدولة ويحل محله في رئاستهما أقدم رؤساء الدوائر بالمحكمة، وتتشكل هذه المحكمة من إحدى عشر دائرة وتتكون كل دائرة من عدد يتراوح بين ثمانية وتسعة مستشارين. وتخصص دائرة أو أكثر لفحص الطعون المقدمة إليها. ومقر هذه المحكمة مدينة القاهرة

وهذه المحكمة بحسب وضعها بين التنظيم القضائي لمحاكم مجلس الدولة تعتبر أعلى هذه المحاكم بنص المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة، وهي المعقب النهائي على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية، فضلاً عن دورها المثمر والخلق في توحيد اتجاه القضاء الإداري ومنع التناقض بين الأحكام وتثبيت وتعميق مبادئ القانون الإداري وتكريس دور القضاء في مواجهة مستحدثات الحياة الإدارية.

دوائر المحكمة الإدارية العليا :

وفيما يلي نلقى بعض الضوء على دوائر المحكمة الإدارية العليا.

الدائرة الأولى: أفراد وحقوق وحریات واستثمار:

وهذه الدائرة يرؤسها رئيس مجلس الدولة وتختص بنظر المسائل الآتية:

1- الطعون المتعلقة بالحقوق والحریات العامة، والمنازعات الخاصة بالأحزاب السياسية.

2- الطعون المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار، وسوق رأس المال، والبنك المركزي، والجهاز المصرفي والنقد، والتأجير التمويلي،

وقانون التمويل العقاري، وحماية الإقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية المستهلك، وتنظيم الاتصالات، والتي لا تدخل في اختصاص الدائرة الثالثة.

٣- الطعون الخاصة بالجنسية والإقامة والإبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها.

٤- الطعون المتعلقة بالأفراد والهيئات التي لا تدخل في اختصاص أي من دوائر المحكمة الإدارية العليا الأخرى.

٥- طلبات التعويض المرتبطة بأي من هذه الطعون.

الدائرة الثانية: الطعون في منازعات أعضاء الهيئات القضائية:

وتختص هذه الدائرة بالمسائل الآتية:

١- المنازعات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، وطلبات التعويض المرتبطة بها.

٢- الطعون الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة التي لا تدخل في نطاق أي من الدوائر الأخرى للمحكمة، وطلبات التعويض المرتبطة.

الدائرة الثالثة: عقود إدارية وإصلاح زراعي:

وتختص هذه الدائرة بنظر المسائل الآتية:

١- الطعون الخاصة بتطبيق قوانين الإصلاح الزراعي.

٢- الطعون الخاصة بالعقود الإدارية بجميع أنواعها.

٣- طلبات التعويض المرتبطة بأي من هذه الطعون.

الدائرة الرابعة: تأديب:

وتختص هذه الدائرة بنظر المسائل الآتية:

١- الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بشأن العاملين المدنيين

بالدولة الخاضعين لأحكام قانون الخدمي المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٧

٢- الطعون على الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية في شأن العاملين

بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام (الشركات القابضة) وبنوك القطاع العام والجمعيات وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية، نقلاً من الدائرة السابعة.

3- الطعون على القرارات الصادرة عن مجالس التأديب.

4- طلبات التعويض المرتبطة بأي من هذه الطعون.

الدائرة الخامسة: تراخيص:

وتختص هذه الدائرة بنظر المسائل الآتية:

1- الطعون على الأحكام الصادرة بشأن التراخيص الإدارية بمختلف أنواعها.

2- الطعون الخاصة بالضرائب والرسوم والموارد والطعون في الأحكام الصادرة بشأن المنازعات الجمركية.

3- الطعون الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية والشهر العقاري والسجل التجاري.

4- طلبات التعويض المرتبطة بأي من هذه الطعون.

5- الطعون على الأحكام الصادرة في شأن المقابل النقدي لرصيد الأجازات للعاملين المدنيين بالدولة.

الدائرة السادسة: تعليم ولوائح خاصة

وتختص هذه الدائرة بنظر المسائل الآتية:

1- الطعون على الأحكام الصادرة بشأن الطلبة في كافة مراحل التعليم.

2- الطعون على الأحكام الصادرة في شأن المقابل النقدي لرصيد الإجازات للعاملين المدنيين بالدولة.

3- طلبات التعويض المرتبطة بأي من هذه الطعون.

الدائرة السابعة: كادرات خاصة والتي تنظم شؤون توظيفهم لوائح خاصة

وطلبات التعويض المرتبطة بها

وتختص هذه الدائرة بالمسائل الآتية:

1- الطعون في الأحكام الصادرة في شأن من شؤون العاملين

الخاضعين لكادرات خاصة، وكذا الذين تنظم شؤون توظيفهم لوائح خاصة، بما في

ذلك القرارات الصادرة بالجزاءات الإدارية (التأديبية) الموقعة عليهم من غير مجالس التأديب، ومنازعات المعاشات الخاصة بهم.

٢- طلبات التعويض المرتبطة بأى من هذه الطعون.

الدائرة الثامنة: بدلات ورصيد أجازات :

وتختص هذه الدائرة بالمسائل الآتية:

- ١- الطعون على الأحكام الصادرة في شأن منازعات البدلات بكافة أنواعها.
- ٢- الطعون على الأحكام الصادرة في شأن قرارات التحميل للعاملين المدنيين بالدولة.

٣- الطعون الخاصة بإخلاء السكن الإدارى.

٤- طلبات التعويض المرتبطة بأى من هذه الطعون.

الدائرة التاسعة: تسويات:

وتختص هذه الدائرة بالمسائل الآتية:

- ١- الطعون على الأحكام الصادرة في شأن التسويات وضم مدد الخدمة ومنازعات الرواتب والعلاوات بأنواعها والمعاشات وما يرتبط بها من منازعات طبقاً لقوانين التأمين الإجتماعى للعاملين المدنيين بالدولة وطلبات التعويض المرتبطة بها.
- ٢- الطعون على الأحكام الصادرة في شأن المقابل النقدى لرصيد الأجازات للعاملين المدنيين بالدولة.

الدائرة العاشرة: تأمين - مرور - مخالفات البناء - تعويض عن قرارات

الاعتقال

وتختص هذه الدائرة بالمسائل الآتية:

- ١- الطعون الخاصة بالأحكام الصادرة في شأن وقف وإزالة الأعمال المخالفة لقوانين البناء، وإزالة التعدى على أملاك الدولة وعلى الأراضي الزراعية.
- ٢- الطعون الخاصة بالأحكام الصادرة في شأن تنفيذ قوانين التأمين الصحي وقانون المرور.

3- الطعون على الأحكام الصادرة في شأن مقابل رصيد الإجازات.

٤- التعويض عن قرارات الإعتقال.

٥- نظر طلبات التعويض المرتبطة باختصاصها الوارد في البنود ١، ٢، ٣.

الدائرة الحادية عشر: ضرائب

وتختص هذه الدائرة بالطعون على أحكام الضرائب والرسوم وكافة أنواعها والموارد والمنازعات الجمركية .

- طلبات التعويض المرتبطة بأى من الطعون النصوص عليها في البند السابق وهناك دائرة أخرى وهي الدائرة المنصوص عليها في المادة ٥٤ مكرراً من قانون مجلس الدولة وهي التي تتعلق بتوحيد المبادئ بين دوائر المحكمة الإدارية العليا وسوف نشير إليها بعد ذلك وهذه الدائرة يرأسها رئيس مجلس الدولة وهو رئيس المحكمة الإدارية العليا وعضوية أقدم عشرة مستشارين بالمحكمة الإدارية العليا ويحل محل أي منهم حال غيابه أو وجود مانع لديه الأقدم فالأقدم من أعضاء المحكمة، وتتكون كل دائرة - من الدوائر المشار إليها - عدا دائرة المادة ٥٤ مكرراً من خمسة مستشارين على الأقل وتخصص دائرة أو أكثر لفحص الطعون المقدمة إليها، وبالنسبة لدوائر فحص الطعون فأنها تتشكل من ثلاثة مستشارين. ومقر المحكمة الإدارية العليا مدينة القاهرة، وهي المعقب النهائي على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ولهما دور بارز في توحيد اتجاهات القضاء الإداري والحيلولة دون تناقض الأحكام وتعميق مبادئ القانون الإداري وابتداع الحلول القانونية للإدارة كما سبق الإشارة.

اختصاص المحكمة الإدارية العليا:

إن مهمة المحكمة الإدارية العليا بجميع دوائرها السابق بيانها تتجسد في التعقيب النهائي على جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية، ومن ثم فإن هذه المهمة تؤدي بها إلى أن تكون عاملاً من عوامل تحقيق التجانس في الأحكام واستقرار مبادئ القانون الإداري وترسيخ وإرساء قواعده (١)

^١ - أستاذنا العميد الدكتور سليمان الطماوى، قضاء الإلقاء ١٩٨٦م، ص ١٣٧.

وقد حددت المادة ٢٣ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ اختصاص المحكمة الإدارية العليا في نظر الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية:

١- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

٢- إذا وقع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

٣- إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المقضي به سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع.

وفي الأحوال الثلاثة السابقة يكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ٦٠ يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه - على رئيس هيئة المفوضين - القانون الطعن في الحكم.

٤- الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والتي صدرت منها متعلقة بطعون في أحكام المحاكم الإدارية، وذلك إذا كانت الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في هذه الطعون قد صدرت على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره من قبل وذلك في خلال ٦٠ يوماً من تاريخ صدور الحكم، ولا يجوز الطعن في هذه الأحكام إلا من رئيس هيئة المفوضين حيث لم يجر القانون لذوي الشأن الطعن في هذه الأحكام. وذلك لاستنفاد سلطتهم في الطعن أمام محكمة القضاء الإداري من ناحية، ومن ناحية أخرى للأمر يتعلق بدور المحكمة الإدارية العليا في توحيد المبادئ.

ولعل العلة من قصر هذا الحق على رئيس هيئة المفوضين أن الطعن في هذه الحالات السابقة لا يتعلق بوقائع النزاع وإنما يتعلق بكون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يخالف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو كون الفصل في الطعن يتطلب تقرير مبدأ قانوني لم يسبق تقريره من قبل، وفي كلتا

الحالتين فإن الأمر يتعلق بدور المحكمة الإدارية العليا بصفة عامة باعتباره يساهم في إرساء قواعد القانون الإداري، وذلك باعتبار أن هذا القانون يعتمد إلى حد كبير على المبادئ والقواعد التي يستقر عليها القضاء الإداري، وعلى وجه الخصوص المحكمة الإدارية العليا.^(١)

٥- كما تختص بالفصل في الطعون التي يرفعها أعضاء مجلس الدولة في القرارات المتعلقة بشئونهم الوظيفية.

٦- كما أن من اختصاص المحكمة الإدارية العليا النظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية، وتوزيع الأعمال بين أعضائها أو بين دوائرها، وهذا الاختصاص ليس موكولاً إلى دائرة من الدوائر، وإنما حتمت المادة ٥٥ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أن تجتمع المحكمة الإدارية العليا بهيئة جمعية عمومية للنظر في هذه المسائل.

وتتألف الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا من جميع مستشاريها العاملين بها وتدعى إليها هيئة المفوضين، ويكون لممثليها صوت محدود في المداولة، وتدعى الجمعية العمومية للمحكمة العليا بناءً على طلب رئيس المجلس، وهو بطبيعة الحال رئيس المحكمة أو ثلاثة من المستشارين أو رئيس هيئة المفوضين، ولا يكون هذا الاجتماع صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وتكون الرئاسة لأقدم الحاضرين، ويجوز لرئيس المجلس أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية، وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه صوت الرئيس. وواضح أن اختصاص الجمعية العمومية في هذا النطاق لا يتعلق بالاختصاص القضائي لهذه المحكمة وإنما يتعلق بتنظيم العمل فيها.

^١ - وذهبت المحكمة الإدارية فعليا إلى أن توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإداري مسألة تنظيمية لا تصلح سببا للطعن في السلم المحكمة الإدارية العليا. (أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٧٢٣ لسنة ١٩٨٢/١١/٢٨ ص ١٢٨ ص ١٩٠).

دائرة توحيد المبادئ

المادة ٥٤ مكرراً من قانون مجلس الدولة هي التي أوجدتها والعلة في إنشاء هذه الدائرة ترجع لكون المحكمة الإدارية العليا تضم عدداً من الدوائر الأمر الذي يمكن أن يتصور معه صدور أحكام من هذه الدوائر يخالف بعضها البعض. كما قد يرى العدول عن مبدأ قانوني سبق أن قرره المحكمة من قبل، ورغبة من المشرع في تكريس وتدعيم دور هذه المحكمة في إرساء مبادئ القانون الإداري وتوحيد اتجاه المحاكم الإدارية وعدم التضارب بين الأحكام الصادرة منها، لذلك قضت المادة ٥٤ مكرراً من قانون مجلس الدولة المضافة بالقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨٤ بأنه إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قرره أحكام سابقة من المحكمة الإدارية العليا، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكّلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام قضائي من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه.

ويجب على سكرتارية المحكمة أن تعرض ملف الدعوى خلال ثلاثة أيام من صدور قرار الإحالة إلى رئيس المحكمة ليعين تاريخ الجلسة التي ستعقد فيها الدعوى، ويعلن الخصوم بهذا التاريخ قبل حلوله بأربعة عشر يوماً على الأقل، وتصدر الهيئة المذكورة أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.

ومن ثم تكون هيئة المحكمة في الحالة السابقة مكونة من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة وعشرة مستشارين على النحو السابق بيانه وتصدر قراراته بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل لا بالأغلبية العادية وذلك ضماناً لاستقرار وعدم تضارب المبادئ التي تقررها المحكمة الإدارية العليا لكي تهتدى بها محاكم القسم القضائي لمجلس الدولة.

دائرة فحص الطعون :

إعمالاً للمادة الرابعة من قانون مجلس الدولة التي نصت على أن يكون مقر المحكمة الإدارية العليا مدينة القاهرة ويرأسها رئيس مجلس الدولة وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون

وتشكل من ثلاثة مستشارين ودائرة فحص الطعون تصدر أحكاماً باتة لا يجوز الطعن عليها.

الفرع الثاني

محكمة القضاء الإداري

كانت محكمة القضاء الإداري هي الجهة القضائية الوحيدة التي أنشأها قانون مجلس الدولة رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦، وقد كان ذلك مثار النقد الشديد من جانب الفقه لعدة أمور أهمها:

الأول: بعد المحكمة عن المتقاضين حيث إن مقرها القاهرة، ومن ثم فإن اللجوء إليها يكون متعذراً على معظم المتقاضين في المناطق البعيدة.

الثاني: حرمان المتقاضين من الميزة التي تترتب على تعدد درجات التقاضي وذلك لأن قصر التقاضي على درجة واحدة من المسائل المنتقدة وكأن المشرع يفترض عصمة هذه المحكمة من الوقوع في الزلل وهو غير متصور.

الثالث: بطء التقاضي وذلك لكثرة القضايا وتراكمها حتى أنها بلغت في عام ١٩٥٤ نحو خمسة عشر ألف قضية تمثل ثمانية أضعاف ما كان معروضاً أمامها في سنة ١٩٥٢، إلى جانب أن هذا الرقم لا يمكن أن يقارن بعدد القضايا التي رفعت أمام هذه المحكمة في عامها الأول (٣٦٨ قضية) وقد بذلت محاولات عديدة لتخفيف هذه العيوب والحد منها أهمها:

أ - زيادة دوائرها حتى بلغت ١٥ دائرة في عام ١٩٥٢ وذلك بقصد سرعة البت في القضايا.

ب - كما أن المرسوم رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٢ قرر إنشاء لجان قضائية في الوزارات والمصالح للنظر في منازعات الخاصة بموظفي الدولة وذلك لتخفيف العبء على المحكمة .

وجعل هذا المرسوم اللجوء إلى هذه اللجان شرطاً حتمياً قبل اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري عن طريق الطعن في قرارات هذه اللجان، وكان الهدف من إنشاء هذه اللجان هو تخفيف العبء على محكمة

القضاء الإداري وذلك بمحاولة تصفية المنازعات الخاصة بالموظفين عند المنبع إلا أن الغريب أن إنشاء اللجان أتى بنتائج عكسية وذلك لأن سهولة الإجراءات أمام هذه اللجان أغرى الكثير في اللجوء إليها بحيث كان من المحتمل أن لا يلجأوا في شأنها إلى محكمة القضاء الإداري، كما أن الكثير ممن لجأ إلى هذه اللجان كثيراً ما كان يواصل الطريق في الخصومة وذلك بالطعن في أحكام هذه اللجان إذا لم تجبهم إلى مطالبهم، وهو ما جسم العبء أمام هذه المحكمة، لذلك سرعان ما ألغيت هذه اللجان بمقتضى القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٤، واستعوض عنها بالمحاكم الإدارية وقد ساهمت هذه المحاكم إلى حد كبير في تخفيف التركيز الكبير أمام محكمة القضاء الإداري وقد وضع القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ والقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ بعض الحلول الجزئية لتلافى العيوب السابقة منها العدول عما كان متبعاً في تشكيل دوائر هذه المحكمة بشأن التفرقة بين دوائر قضاء الإلغاء التي كانت تتشكل من خمسة مستشارين وبين دوائر قضاء التعويض التي كانت تتشكل من ثلاثة لذلك جعل المشرع في ظل القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ هذه الدوائر تتشكل من ثلاثة مستشارين أيضاً كانت المنازعة، وذلك بهدف زيادة عدد الدوائر وقد احتفظ القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ بهذا التشكيل.

أما القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ فقد حاول منذ صدوره حتى الآن أن يضع حلاً حاسماً لتقريب القضاء من المتقاضين تكريساً لما كفلته الدساتير المصرية من حرية التقاضي وضرورة أن يكون اللجوء إلى القضاء في متناول المتقاضين، وأهم ما نراه من حلول أتى بها القانون الجديد ذلك أن هذا القانون وإن احتفظ بأن يكون مقر محكمة القضاء الإداري مدينة القاهرة، إلا أنه وبمقتضى المادة الرابعة من هذا القانون أجاز لرئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر لمحكمة القضاء الإداري في المحافظات، فلاحظ أنه ومنذ صدور هذا القانون دأب مجلس الدولة على زيادة عدد الدوائر التي تتشكل منهما محكمة القضاء الإداري حيث بلغت في العام

القضائي ٢٠١٤/٢٠١٥ سبعون دائرة، منها سبعة عشر دائرة في القاهرة وحدها والباقي موزع على سائر المحافظات منها دائرتين في محافظة بني سويف، ودائرتين في محافظة الفيوم، ودائرتين في محافظة المنيا وثلاثة دوائر في محافظة أسيوط، ومثلها في محافظة سوهاج، ومثلها في قنا، ودائرة في محافظة الأقصر وهي أحدث دائرة من بين دوائر محكمة القضاء الإداري، ودائرة في محافظة أسوان، وثلاثة دوائر في محافظة القليوبية، ومثلها في المنوفية، ومثلها في الغربية، ودائرتين في محافظة كفر الشيخ، وثلاثة دوائر في محافظة الإسكندرية، ودائرتين في محافظة البحيرة، وخمس دوائر في المنصورة، ودائرتين في محافظة الشرقية ودائرة في محافظة بورسعيد. ودائرتين في محافظة الإسماعيلية، أما محافظة البحر الأحمر فتتبع دوائر قنا، والوادي الجديد فتتبع دوائر أسيوط، ومرسى مطروح تتبع دوائر الإسكندرية، وشمال سيناء وجنوبه، ومحافظة السويس فتتبع دوائر محافظة الإسماعيلية، ولا زال مجلس الدولة يزيد من هذه الدوائر تخفيفاً لأعباء محكمة القضاء الإداري وتيسيراً على المتقاضين.

ويحمد لمجلس الدولة هذا الاتجاه فهو في صالح حق النقاضي وضرورة أن يكون القضاء في متناول المتقاضين كما سبق أن أشرنا.

هذا وقد احتفظ القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتشكيل الدوائر من ثلاثة مستشارين أيّاً كان نوع المنازعة غير أن العمل يجرى أن تكون كل دائرة من خمسة أعضاء على الأقل وذلك لسرعة إنجاز القضايا وعدم تراكمها غير أن الحكم يصدر من ثلاثة أعضاء.

ويرأس محكمة القضاء الإداري نائب رئيس مجلس الدولة للمحكمة وعضو المجلس الخاص وكما سبق تتكون من مجموعة من الدوائر ويحدد وهي اختصاص كل دائرة من دوائرها بقرار من رئيس مجلس الدولة، وإذا شمل اختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز لها بقرار من رئيس المجلس عقد جلساتها في عاصمة أي من المحافظات الداخلة في دائرة اختصاصها، وهو ما يذلل إلى حد كبير أعباء كثيرة على المتقاضين، وقد بلغ عدد

دوائر محكمة القضاء الإداري طبقاً لآخر تشكيل لها (١٢٢) دائرة وتوزيع الاختصاصات بين هذه الدوائر مسألة تنظيمية محضة لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا وتعتبر محكمة القضاء الإداري صاحبة الاختصاص العام في المنازعات على النحو الذي سنوضحه في السطور الآتية:

اختصاص محكمة القضاء الإداري (١):

تختص محكمة القضاء الإداري بنظر النزاع لأول مرة، وقد تكون جهة استئنافية تنتظر الطعون في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، وسوف نتحدث أولاً عن اختصاص محكمة القضاء الإداري بالنزاع لأول مرة، ثم نتكلم ثانياً عن اختصاص محكمة القضاء الإداري كجهة استئنافية.

أولاً: اختصاص محكمة القضاء الإداري بالنزاع لأول مرة:

قضت المادة ١٣ من قانون مجلس الدولة بأن تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة العاشرة من ذات القانون عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، وقد عدت المادة ١٠ المشار إليها ثلاثة عشر مسألة بالإضافة إلى ما نص عليه في الفقرة الرابعة عشرة من اختصاص المحاكم بسائر المنازعات الإدارية، وعلى ضوء ما نصت عليه المادتان سالفتا الذكر نتبين أن محكمة القضاء الإداري تعتبر صاحبة الولاية العامة على سائر المنازعات الإدارية، إذ أنها تختص بسائر المنازعات التي تدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة عدا ما يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية والتأديبية، وباستبعاد المسائل الأخيرة نتبين أن محكمة القضاء الإداري تختص بالفصل في المسائل الآتية:

١- الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.

٢- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين

العموميين من مستوى الإدارة العليا أو المستوى الأول، أو لورثتهم (٢).

١ - الدكتور خميس السيد إسماعيل، قضاة مجلس الدولة، دار الطباعة الحديثة ١٩٨٧م، ص ٣٤. الدكتور عبد الرحمن حشيش، مبادئ القضاء الإداري، دار النهضة العربية، المجلد الأول، ١٩٨٨م، ص ٢٠٥.

٢ - يكفي لاختصاص محكمة القضاء الإداري أن يتعلق موضوع القضية بمركز قانوني لأحد العاملين من المستوى الأول أو من مستوى الإدارة العليا، ولو كان المدعى من المستوى الثاني ممن تختص بقضاياهم إحدى المحاكم

٣-الطلبات المتعلقة بإلغاء القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات أو بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو بالفصل بغير الطريق التأديبي، وذلك بالنسبة للموظفين من المستويين سالف الذكر.

٤-الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الادارية النهائية.

٥-الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الادارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.

٦-دعوى الجنسية.

٧-الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل، وذلك متى كان مرجع الطعن هو عدم الاختصاص أو عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.

٨-طلبات التعويض عن القرارات الإدارية سواء رفعت بصفة أصلية أو بصفة تبعية لدعوى الإلغاء، وذلك عدا ما يتعلق بالتعيين أو الترقية أو بمنح العلاوات أو بالإحالة إلى المعاش أو بالإستيداع أو بالفصل بغير الطريق التأديبي بالنسبة للموظفين من المستويين الثاني والثالث.

٩-المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر متى كانت قيمة المنازعات تجاوز خمسمائة جنيه.

١٠- سائر المنازعات الادارية.

ثانياً: اختصاص محكمة القضاء الادارة كجهة استئنافية:

تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون التي ترفع إليها في الاحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، وبالنسبة لهذه الطعون فإنه يكون لذوي الشأن أو

لرئيس هيئة مفوضي الدولة الطعن في هذه الأحكام، والعمل موزع بين دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيث تختص كل دائرة بنوع من المنازعات (١) على أن هذا لا يعني عدم اختصاص أي دائرة بما تختص به دائرة أخرى، وذلك لأن الدوائر جميعاً تعتبر محكمة واحدة، ولا يعتبر الحكم الصادر من إحدى الدوائر في مسألة موزعة على دائرة أخرى أنه صادر من محكمة غير مختصة. (٢)

هذا وقد منحت المادة ٥٥ من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة للجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري بعض الاختصاصات على النحو الذي بيناه بالنسبة للجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا.

وتجتمع محكمة القضاء الإداري بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل الخاصة بنظامها الداخلي وتوزيع الأعمال بين أعضائها ودوائرها تتألف المستشارين العاملين بها، وتدعى إليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت محدود في المداولة وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس المحكمة أو ثلاثة من المستشارين من أعضائها أو بناء على طلب رئيس هيئة المفوضين ويصح الانعقاد بأغلبية أعضائها وتكون الرئاسة لأقدم الحاضرين أو رئيس المجلس في حالة حضوره.

الفرع الثالث

المحاكم الإدارية

سبق أن أشرنا إلى أن المشرع حاول أن يخفف العبء على محكمة القضاء الإداري فأنشأ لجاناً قضائية للنظر في المنازعات الخاصة بموظفي الدولة وذلك بمقتضى القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٢، وقررنا أن هذه اللجان زادت الأمر سوء مما حدا بالمشرع أن يلغى هذه اللجان بمقتضى القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٤، ويستعيز عنها بالمحاكم الإدارية لتختص بالنظر في المنازعات الخاصة

١ - تتكون محكمة القضاء الإداري بالقاهرة من ست دوائر على أساس التخصص وهي: الدائرة الأولى (أفراد)، الدائرة الثانية (جزاءات)، الدائرة الثالثة (ترقيات)، الدائرة الرابعة (تسويات)، الدائرة الخامسة (عقود)، الدائرة السادسة على أساس استثنائي، وهناك دائرة بالإسكندرية ودائرة أخرى بالمنصورة ودائرة بكل من أسيوط وقنا والإسماعيلية، وكل دائرة تقوم بكافة الاختصاصات المماثلة لدوائر القاهرة بما فيها الاختصاص الاستثنائي.

٢ - حكم محكمة القضاء الإداري في ١٩٦٨/١٢/٥ (المجموعة س ٢٣، ص ٤٢٧).

بالموظفين العموميين، وقد تألفت هذه المحاكم من عناصر قضائية خالصة قوامها رئيس وعضوان من أعضاء مجلس الدولة بالنسبة لكل محكمة.

تشكيل المحاكم الإدارية ومقارها:

مقار المحاكم الإدارية في القاهرة والاسكندرية، ويجوز إنشاء محاكم إدارية أخرى في المحافظات بقرار من رئيس المجلس.

وقد أصدر مجلس الدولة القرار رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٣ بإنشاء محكمة إدارية بمدينة المنصورة، كما صدر القرار رقم ١٢٦ لسنة ١٩٧٣ بإنشاء محكمة إدارية بمدينة طنطا، والقرار رقم ١٤٩ لسنة ١٩٧٣ بإنشاء محكمة إدارية بمدينة أسيوط، والقرار رقم ٢٧٧ لسنة ١٩٩٣ بإنشاء محكمة إدارية بمدينة قنا، والقرار رقم ٢٨٧ لسنة ١٩٩٣ بإنشاء محكمة إدارية بالإسماعيلية.

ويشمل اختصاص المحكمة الإدارية بالمنصورة المنازعات الخاصة بمصالح الحكومة والهيئات العامة من محافظات الدقهلية ودمياط.

أما المحكمة الإدارية بمدينة طنطا فيشمل اختصاصها المنازعات الخاصة بمصالح الحكومة والهيئات العامة من محافظات الغربية وكفر الشيخ والقليوبية والمنوفية

ويشمل اختصاص المحكمة الإدارية بأسيوط المنازعات الخاصة بمصالح الحكومة والهيئات العامة من محافظات أسيوط وسوهاج والوادي الجديد.

ويشمل اختصاص المحكمة الإدارية في قنا بالمنازعات الخاصة بمصالح الحكومة والهيئات العامة في محافظات أسوان وقنا ومدينة الأقصر، والبحر الأحمر.

ويشمل اختصاص المحكمة الإدارية بالإسماعيلية المنازعات الخاصة بمصالح الحكومة والهيئات العامة من محافظات الإسماعيلية والشرقية وسيناء والسويس وبورسعيد.

كما أن المحكمة الإدارية بمدينة الإسكندرية تختص بنظر المنازعات الخاصة بوزارة النقل البحري والهيئات التابعة لها ومصالح الحكومة في محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

أما في القاهرة فتتعدد المحاكم الإدارية وتختص كل منها بعدد من الوزارات والمصالح والهيئات العامة.

والمحاكم الادارية بالقاهرة هي:

١ - محكمة إدارية لنظر المنازعات الخاصة برئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارات (التخطيط، والداخلية، والخارجية، والعدل، والطيران، والجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة الشباب والرياضة، والهيئات العامة التابعة لهذه الوزارات)، كما تختص بمنازعات المحافظات المتعلقة بمهام الوزارات المذكورة.

٢ - محكمة إدارية لنظر المنازعات الخاصة بوزارات (التعليم العالي، والتربية والتعليم، والثقافة والإعلام، والقوى العاملة، والسياحة، والهيئات العامة التابعة لهذه الوزارات)، كما تختص بمنازعات المحافظات المتعلقة بمهام الوزارات المذكورة.

٣ - محكمة إدارية لنظر المنازعات الخاصة بوزارات (الصحة، والاسكان والمرافق، والأوقاف وشئون الأزهر، والشئون الاجتماعية، والهيئات العامة التابعة لهذه الوزارات)، كما تختص بمنازعات المحافظات المتعلقة بمهام الوزارات المذكورة.

٤ - محكمة إدارية لنظر المنازعات الخاصة بوزارات (المالية، والاقتصاد، والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة، واستصلاح الأراضي، والكهرباء، والصناعة والبتترول، والثروة المعدنية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئات العامة التابعة لهذه الوزارات)، كما تختص بمنازعات المحافظات المتعلقة بمهام الوزارات المذكورة.

٥ - محكمة إدارية لنظر المنازعات الخاصة بوزارة الري، كما تختص بمنازعات المحافظات المتعلقة بمهام الوزارة المذكورة.

٦ - محكمة إدارية لنظر المنازعات الخاصة بوزارات (المواصلات، والنقل، والهيئات العامة التابعة لهذه الوزارات)، كما تختص بمنازعات المحافظات المتعلقة بمهام الوزارات المذكورة.

وتتشكل كل محكمة من المحاكم الإدارية من دوائر تشكل كل منها برئاسة

مستشار مساعد وعضوية اثنين من النواب على الأقل، وتحدد دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة، وإذا شمل اختصاص المحكمة أكثر من محافظة جاز لها أن تتعقد في عاصمة أي محافظة من المحافظات الداخلة في اختصاصها، وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة ويشرف على هذه المحاكم نائب من نواب رئيس المجلس يعاون الأخير في تنظيمها وحسن سير العمل فيها، ومقار هذه المحاكم في القاهرة والإسكندرية كما يجوز انشاء محاكم إدارية في المحافظات الأخرى بقرار من رئيس المجلس.

وهذا التشكيل لا يختلف بصفة عامة عما نصت عليه القوانين السابقة على القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ إلا أن المشرع في ظل القانون الأخير أغفل ما كان منصوصاً عليه في المادة السادسة في كل من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥، والقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ التي كانت تنص على أن:

يكون لكل وزارة أو مصلحة عامة أو أكثر محكمة إدارية أو أكثر يعين عددها وتحدد دائرة اختصاص كل منها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح رئيس مجلس الدولة."

وبإنشاء المحاكم الإدارية على هذا النحو يكون المشرع قد عالج المساوئ التي تترتب على بعد القضاء عن المتقاضين علاجاً جزئياً، وذلك لأن المشرع وإن كان قد أجاز في ظل القوانين المتتالية التي تنظم مجلس الدولة اعتباراً من سنة ١٩٥٥ إنشاء محاكم إدارية في المحافظات غير القاهرة، والإسكندرية وبذلك فإنه يكون متجهاً لجعل اختصاص هذه المحاكم إقليمياً على النحو المطبق في فرنسا حيث توجد المحاكم الإقليمية الإدارية، غير أن اختصاص المحاكم الإدارية في مسائل محدودة كما سنبين لا يعطينا الحق في القول بأن المشرع قضى على مساوئ بعد القضاء على المتقاضين بصفة كلية، وللمحاكم الإدارية نائب لرئيس مجلس الدولة يعاون رئيس المجلس في القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بها^(١).

^١ - الدكتور/ فؤاد العطار، القضاء الإداري، دار النهضة العربية، ١٩٦٨، ص ٢٨١.

اختصاص المحاكم الإدارية:

لم يكن اختصاص المحاكم الإدارية اختصاصاً عاماً وإنما اقتصر على بعض قضايا الموظفين الخاصة بالترقيات والمكافآت والمعاشات المستحقة للموظفين الداخلين في الهيئة وطوائف العمال والمستخدمين خارج الهيئة أو لورثة كل منهم على أن تكون أحكامها انتهازية إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى ٢٥٠ جنيهاً، أما إذا تجاوزت هذه القيمة أو كانت القيمة مجهولة جاز استئناف أحكامها أمام محكمة القضاء الإداري على أنه في ظل القانونين رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥، ٥٥ لسنة ١٩٥٩ وزع المشرع الاختصاص بين المحاكم الإدارية وبين محكمة القضاء الإداري لا على أساس أن الأخيرة تعتبر محكمة استئنافية بالنسبة للأولى، وإنما وزعه توزيعاً نوعياً على أساس وأهمية النزاع.

أما القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ فإنه نظم اختصاص المحاكم الإدارية على نحو لم تعد هذه الاختصاصات تقتصر على المنازعات الخاصة بالموظفين العموميين وإنما وسع اختصاصاتها بحيث أصبحت تختص بنظر المنازعات المتعلقة بعقود الالتزام، أو الأشغال العامة، أو التوريد، أو بأي عقد إداري آخر متى كانت قيمة المنازعات لا تتجاوز خمسمائة جنيه إلى جانب اختصاص هذه المحاكم بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة ببعض فئات الموظفين العموميين وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات كما تختص بنظر المنازعات^(١) المتعلقة بعقود الالتزام، أو الأشغال العامة، أو التوريد، أو بأي عقد إداري آخر متى كانت قيمة المنازعات لا تتجاوز خمسمائة جنيه إلى جانب اختصاص هذه المحاكم بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة ببعض فئات الموظفين العموميين وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات كما تختص بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لفئات هؤلاء الموظفين وتوسيع اختصاص هذه المحاكم على هذا النحو يعتبر اتجاهاً نحو جعل اختصاص هذه المحاكم يشمل المنازعات الخاصة بقضايا الأفراد.

^١ - الدكتور/ يحيى الجمل، القضاء الإداري، دار النهضة العربية، ١٩٨٦، ص ٢٧١.

ويجب أن نلاحظ أن القانون الجديد جعل من محكمة القضاء الإداري محكمة درجة ثانية بالنسبة لقضاء المحاكم الإدارية وهو ما أشرنا إليه في موضعه. وقد حددت المادة ١٤ من قانون مجلس الدولة هذه الاختصاصات فيما يلي:

١- الفصل في طلبات القرارات المنصوص عليها في البند ثالثاً ورابعاً وهي الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات والطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.

٢- الفصل في المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في الفقرة السابقة أو لورثتهم.

٣- الفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة العاشرة وهي المتعلقة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر فيما كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه.

وتجتمع المحاكم الإدارية بهيئة جمعية عمومية تتألف من جميع أعضائها وذلك للنظر في المسائل الخاصة بنظامها وشؤونها الداخلية وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس، أو نائب رئيس المجلس المختص لهذه المحاكم، أو رئيس هيئة المفوضين أو ثلاثة من أعضائها على الأقل وتدعى هيئة المفوضين ويكون لها صوت محدود في المداولة ولا يكون الانعقاد صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتبلغ القرارات لرئيس المجلس ولا تنفذ إلا بعد تصديقه عليها وذلك بعد أخذ رأى نائب رئيس المجلس لهذه المحاكم وتكون الرئاسة لرئيس مجلس الدولة في حالة حضوره وإلا فلنائب الرئيس لهذه المحاكم وفي حالة غيابه لأقدم الحاضرين.

والجدير بالذكر أن القانون الحالي لسنة ١٩٧٢ جعل من محكمة القضاء الإداري محكمة درجة ثانية بالنسبة لقضاء المحاكم الإدارية وهو ما أشرنا إليه في حينه.

توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية:

المحاكم الإدارية متعددة، تختص كل واحدة منها بقضايا العاملين في وزارة أو عدد من الوزارات والمصالح، كما تختص واحدة منها بالمنازعات الخاصة بمصالح الحكومة في محافظات الإسكندرية والصحراء الغربية والبحيرة وهناك محاكم إدارية في محافظات أخرى.

والمناطق في تحديد دائرة اختصاص كل محكمة إدارية هو اتصال الجهة الإدارية بموضوع المنازعة، لا مجرد تبعية العامل لهذه الجهة عند رفع الدعوى^(١)، وتعتبر الجهة الإدارية متصلة بموضوع المنازعة متى كانت هي التي أصدرت القرار المطعون فيه، أو كانت تتحمل الآثار المالية المحكوم بها من مآليتها، باعتبارها الجهة القادرة على تنفيذ الحكم، وإذا تحملت عدة جهات إدارية أعباء التنفيذ، فإن الاختصاص يوزع بين المحاكم الإدارية، ويقتصر اختصاص كل محكمة إدارية في الحكم على الجهة التي تختص بنظر دعواها، فيرفع المدعى دعوى مستقلة أمام كل محكمة إدارية لإلزام الجهة التي تدخل في اختصاص هذه المحكمة بما يخصها من طلبات^(٢).

فإذا نقل العامل كانت المحكمة المختصة بالنزاع هي محكمة الجهة المنقول منها، طالما كانت هي الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه أو المطلوب التعويض عنه، أو هي الجهة المتصلة بالنزاع، أما إذا اتصل النزاع بالجهة المنقول إليها، كأن تكون المنازعة في قرار النقل، فإن المحكمة المختصة في هذه الحالة تكون محكمة الجهة المنقول إليها^(٣).

وفي حالة ندب العامل تكون الجهة التي يتصل بها النزاع هي الجهة المنتدب إليها، إذا كانت المنازعة متعلقة بالآثار المترتبة على هذا الندب^(٤).

^١ - حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ ١٩٦٣/٣/٢٤ (المجموعة م، ص ٩٤٢).

^٢ - الدكتور/خمس اسماعيل، قضاء مجلس الدولة، المرجع السابق، ص ٤٤.

^٣ - حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ ١٩٥٨/٢/١٥ (المجموعة س٣، ص ٨٣).

^٤ - حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ ١٩٥٨/٢/١٥ (المجموعة س٣، ص ٧٢).

أما إذا كانت المنازعة متعلقة بالمركز الوظيفي للعامل، فتختص بالمنازعة محكمة الجهة التي يتبعها الموظف وإذا حلت جهة إدارية محل الجهة المختصة بالنزاع، فتختص بالمنازعة محكمة الجهة التي يتبعها. وإذا حلت جهة إدارية محل الجهة المختصة بالنزاع في إدارة المرفق كانت الجديدة هي المتصلة بموضوع النزاع ومحكمتها هي المحكمة المختصة.^(١)

أما عن توزيع الاختصاص المحلي^(٢) بين المحاكم الإدارية بالقاهرة والمحكمة الإدارية بالإسكندرية أو بإحدى المحافظات، فالمناطق في توزيع الاختصاص هو اتصال المنازعات موضوعياً بمصلحة من المصالح التي مقرها في الإسكندرية أو الصحراء الغربية أو البحيرة أو بالنطاق الإقليمي للمحافظة، ولو لم يكن لهذه المصلحة شخصية اعتبارية مستقلة^(٣).

الطعن في أحكام المحاكم الإدارية

منذ إنشاء المحاكم الإدارية سنة ١٩٥٤ حتى سنة ١٩٦٩ كان الطعن في أحكامها أمام المحكمة الإدارية العليا، على أن هذا الوضع تغير منذ صدور القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٩، إذ جعل الطعن في أحكام المحاكم الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري. وقد تأيد هذا الوضع بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢.

الفرع الرابع المحاكم التأديبية

يمكن أن نميز فيما يتعلق بالمحاكم التأديبية بين مرحلتين أساسيتين كل منها تعتبر مرحلة مغايرة تماماً للآخرى^(٤)، وتتحدد المرحلة الأولى في الفترة ما بين إنشاء هذه المحاكم حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، كما تتحدد الفترة الثانية بما أتى

^١ - فإذا كان المدعى تابعاً لمجلس مديرية الشرقية، وحلت وزارة التربية والتعليم محل هذا المجلس في القيام على مرفق التعليم الذي كانت تتولاه، فإن الدعوى تكون من اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم لا المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية، حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ ١٩٥٧/٦/٢٢ (المجموعة م ٢، ص ١٢٠٢).

^٢ - لا يعتبر الاختصاص المحلي في فرنسا من النظام العام، أما في مصر فهو من النظام العام، حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ ١٩٦٠/١/٢ (المجموعة س ٥، ص ١٢٢).

^٣ - حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ ١٩٦٠/١/٢ (المجموعة منه، ص ١٢٢).

^٤ - الدكتور فؤاد المطار، القضاء الإداري، المرجع السابق، من ١٨٤، الدكتور يحيى الجمل، القضاء الإداري، المرجع السابق، من ١٣٥.

به القانون المشار إليه من تطور خلاق بالنسبة لتشكيل هذه المحاكم وفيما يلي توضيح ذلك:

أولاً: المحاكم التأديبية في ظل قوانين مجلس الدولة السابقة على القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢^(١).

أنشأت المحاكم التأديبية بمقتضى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨، بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية لتحل محل مجالس التأديب التي كانت موجودة قبل هذا القانون، وذلك بقصد إيجاد المزيد من الضمانات التي لم تكن تتوفر في هذه المجالس حيث تتشكل من عناصر بعضها غير قضائية بل من الموظفين الإداريين، وكانت هذه المجالس تعتبر مجالس إدارية لا محاكم، وكانت تتعدد بتعدد درجات الموظفين. ولتلافي الآثار السيئة على الموظفين التي وجدت في ظل مجالس التأديب الناتجة من تعدد اللجان وتنوعها وتشكيلها من عناصر إدارية أنشأت المحاكم التأديبية بمقتضى القانون المشار إليه، وقد حرص المشرع في تشكيلها على تغليب العنصر القضائي مما وفر كثيراً من الضمانات بسبب ما يتمتع به القضاة من ضمانات يظهر أثرها في المحاكمات، وذلك بتيسير الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات وهو ما يحقق الاستقرار في الجهاز الحكومي، لذلك قررت المادة ١٨ من القانون المذكور إنشاء محاكم تأديبية تختص بمحاكمة المثبتين على وظائف دائمة وذلك في المخالفات المالية والإدارية.

كما قررت المادة ١٩ منه على أن تشكل هذه المحاكم بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد أخذ رأى مدير عام النيابة الإدارية ويختار كل من رئيس ديوان المحاسبة (الجهاز المركزي للمحاسبات الآن) ورئيس ديوان الموظفين (الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الآن) عضواً أصلياً وآخر احتياطياً لكل محكمة أو أكثر بحيث إذا غاب العضو الأصلي حل محله العضو الاحتياطي، ويجوز دائماً إعادة انتداب الأعضاء، وقد نص القانون المشار إليه إلى نوعين من المحاكم، وأضاف القانون رقم

^١ - أنظر شرحاً مسهباً للتطبيقات التشريعية للمحاكم التأديبية في مؤلف أستاذنا الدكتور سليمان الطماري، قضاء التأديب، طبعة ١٩٨٧، ص ٥١٣ وما بعدها.

١٩ لسنة ١٩٥٩ محاكم لموظفي الشركات والجمعيات والهيئات الخاصة، وسوف نشير إليها تباعاً.

١. المحاكم التأديبية العليا:

وتختص بمحاكمة الموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها وتتشكل من وكيل مجلس الدولة رئيساً ومن مستشار أو مستشار مساعد وموظف من الدرجة الأولى من ديوان المحاسبة أو ديوان الموظفين بحسب نوع المخالفة بحسب ما إذا كانت مالية أو إدارية.

٢ - المحاكم التأديبية:

وتختص بمحاكمة الموظفين الشاغلين الدرجة الثانية فما دونها، وتلحق هذه المحاكم بمختلف الوزارات والمصالح وتتشكل من مستشار أو مستشار مساعد من مجلس الدولة، ومن نائب من المجلس وموظف من الدرجة الثانية على الأقل من ديوان عام المحاسبة أو من ديوان الموظفين تبعاً لنوع المخالفة كما أشرنا.

٣. المحاكم التأديبية الخاصة بموظفي الشركات والجمعيات والهيئات الخاصة

وهي التي تختص بمحاكمة موظفي الشركات والجمعيات الخاصة التي يصدر بتحديد قرار من رئيس الجمهورية أو تلك التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الهيئات الخاصة بنسبة لا تقل عن ١٥% وتتشكل هذه المحاكم على النحو المشار إليه بالنسبة للموظفين العموميين.

وقد تعرض الفقه لتكييف الطبيعة القانونية لهذه المحاكم، وهل تعتبر إحدى هيئات القسم القضائي بمجلس الدولة وما يترتب عليه من اعتبار قراراتها أحكاماً قضائية من عدمه؟

أما عن طبيعة هذه المحاكم فمما لا شك فيه أنها لا تعتبر محاكم قضائية بالمعنى الفني كما لا تعتبر تبعاً لذلك من ضمن الهيئات القضائية التي يتشكل منها القسم القضائي لمجلس الدولة وذلك لعدة اعتبارات منها أن هذه المحاكم ورغم التسمية التي أطلقت عليها لا تتشكل عناصرها من قضاة بل يوجد موظفون إداريون لا تتوفر فيهم الضمانات والشروط التي يوفرها القانون في القاضي، كما لا يشترط فيهم أن يكونوا

مؤهلين من الناحية القانونية بأن يكونوا حاصلين على إجازة الحقوق، كما أنه من ناحية أخرى لم تذكر المادة الثالثة من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ القانون الثالث لمجلس الدولة هذه المحاكم من ضمن الهيئات القضائية، لذلك فإننا نرى مع غيرنا عدم اعتبار هذه المحاكم محاكم قضائية وإنما هي هيئات إدارية، كما أننا نرى أن ما يصدر من هذه المحاكم من قرارات لا يعتبر أحكاماً قضائية، وإنما يعتبر قرارات إدارية يكون للمحكمة الإدارية العليا عليها من الرقابة ما يجاوز في نطاقه مالها من رقابة على أحكام محكمة القضاء الإداري وهو ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا حيث قررت كل منها أن قرارات المحاكم التأديبية تعتبر قرارات إدارية في جوهرها ومضمونها رغم ما تحمله من اسم أو ما تسير عليه من إجراءات في إصدار أحكامها.^(١)

ثانياً : المحاكم التأديبية بعد القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ :

حسم القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ هذا الموقف بأن جعل هذه المحاكم إحدى الهيئات التي يتضمنها القسم القضائي لمجلس الدولة، وهذه الخطوة من الخطوات الموفقة كما سبق أن أشرنا، بما يترتب عليه من اعتبارها محاكم قضائية تتشكل من قضاة مجلس الدولة مع استبعاد العناصر الإدارية، كما حرص المشرع على كفالة السرعة في الفصل في الدعاوى التأديبية كما نظم الإجراءات بما يهيئ أفضل السبل لتحقيق هذا الهدف وسنبين فيما يلي أنواع هذه المحاكم وتشكيلها واختصاصها:^(٢)

أولاً : أنواع المحاكم التأديبية في ظل القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢

واختصاصاتها:

احتفظ القانون الجديد بما كان متبعاً في قانون مجلس الدولة رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ من تقسيم المحاكم التأديبية بحسب فئات الموظفين ودرجاتهم وليس حسب أهمية

^١ - حكم المحكمة الإدارية العليا في دمشق ١٩٦٠/٤/٢٦. حيث كان القانون ١٩٥٦/٥٥ بشأن مجلس الدولة يطبق في مصر وسوريا (الجمهورية العربية المتحدة) وقت الوحدة.

^٢ - أستاذنا العميد الدكتور/ سليمان الطماوى، قضاء التأديب، المرجع السابق، ص ٥٢٦.

المخالفة وخطورتها، لذلك قررت المادة (٧) من هذا القانون على أن تتكون المحاكم التأديبية من:

- أ- المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم.
- ب- المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأولى والثاني والثالث ومن يعادلهم ويكون لهذه المحاكم نائب لرئيس المجلس يعاونه في القيام على شئونها. ويتخذ الربط المالي أساساً لتحديد المعادلة لهذه الدرجات، فمن كان راتبه يعادل راتب المدير العام أو يزيد فإنه يخضع للمحاكم التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أما من هم أقل من ذلك فيخضعون للمحاكم التأديبية للمستوى الأول والثاني والثالث. ويلاحظ أن التوزيع السابق فيما بين النوعين من المحاكم، لا يسرى في شأن الدعاوى التأديبية، وإنما يسرى أيضاً في شأن الطعون في القرارات والجزاءات التأديبية، وكذلك فيما يتعلق بالوقف عن العمل أو مده، وما يرتبط به من صرف نصف المرتب. ويتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعاً للمستوى الوظيفي وقت إقامة الدعوى وإذا تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم في المستوى الوظيفي هي المحكمة المختصة بمحاكمتهم جميعاً (م ١٧ من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢). وفي حالة تعدد المتهمين بتهم لا تقبل التجزئة، فإن المحكمة التأديبية تختص بمحاكمتهم جميعاً ولو كان أحدهم من الذين تستقل السلطات الرئاسية بتأديبهم.^(١)

وتختص المحاكم التأديبية كل في دائرة اختصاص بالفصل في الأمور الآتية:

أولاً: الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من:

- ١- العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وكذلك العاملين بالهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات التي تلتزم لها الحكومة بحد أدنى من الأرباح.

^١ - المستشار/هاني الدريدي، الدليل العملي للإجراءات والصيغ القانونية أمام مجلس الدولة، ج١، ص ٤٥٢. وقد أشار سيادته لحكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ ١٩/٢/١٩٧٢ في القضية رقم ١٠٤٦ لسنة ١٣ قضائية.

٢- أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين وفقاً لأحكام القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٦٣ في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها.

٣- العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديد لها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً مصرياً شهرياً^(١).
ويلاحظ أنه يخرج من اختصاص المحاكم التأديبية الفئات التي تنظم القوانين التي يخضعون لها نظاماً خاصاً للتأديب وذلك كرجال القضاء وأعضاء مجلس الدولة وهيئات التدريس بالجامعات^(٢).

ثانياً: وبالإضافة إلى نظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات الإدارية والمالية للفئات السابقة، فإن المحاكم التأديبية تختص بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين التاسع والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة وهي:

١- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية للسلطات التأديبية.

٢- الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين في القطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.

٣- الفصل في طلبات الوقف الاحتياطي عن العمل لأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٦٣ في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها.

٤- كما أنه وفقاً للتفسير الذي انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا في ٤ نوفمبر عام ١٩٧٢ فإن المحاكم التأديبية تختص بطلبات التعويض المتعلقة بالطعون التأديبية بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام، وقد قضى الحكم المشار إليه باختصاص

^١ - يجب إعادة النظر في تعديل هذه الفئة من العاملين حيث أن النص وضع منذ ١٩٥٨.

^٢ - أستاذنا العميد الدكتور/ سليمان الطماوى، قضاء التأديب، المرجع السابق، ص ٥٢١.

هذه المحاكم في كل ما يتعلق بالجزاءات التأديبية سواء من حيث الإلغاء أو التعويض.

٥- كما يصدر رئيس المحكمة التأديبية قراراً يتعلق بالفصل في طلب وقف أو مد وقف المقدمين للمحاكمة التأديبية عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف عن العمل في الحدود المقررة قانوناً.^(١) ولا يجوز إقامة الدعوى التأديبية بالنسبة للعاملين الذين انتهت مدة خدمتهم إلا في حالتين:

الأولى: إذا كان قد بدأ في التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة.

الثانية: إذا كانت المخالفة مالية يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها وذلك لخمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدأ في التحقيق قبل ذلك.

وتنظر الدعوى التأديبية في جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع الأوراق قلم كتاب المحكمة، وعلى المحكمة أن تفصل في القضايا التي تحال إليها على وجه السرعة، كما لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لذات السبب ولا يجوز أن تتجاوز فترة التأجيل أكثر من أسبوعين، وتصدر المحكمة الحكم في الدعوى، كما لا يجوز تأجيل النطق بالحكم أكثر من مرة، وتصدر الأحكام مسببة ويوقعها الرئيس والأعضاء.

ويلاحظ أن المشرع قد استهدف من وراء ذلك كله عدم إطالة إجراءات المحاكم التأديبية، ذلك أن طول الوقت الذي تستغرقه إجراءات المحاكمة من شأنه أن يضر بالجهاز الإداري في الدولة ^(٢) من ناحيتين:

الأولى: أن ثبوت إدانة الموظف بعد مرور وقت طويل يفقد الجزاء الذي يوقع عليه كل قيمة من حيث ردع الموظف ذاته، كما أنه يفقده مضمونه باعتباره ردعاً

^١ - المادة ١٦ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ / ١٩٧٢ المعدل بالقانون ١٣٦ / ١٩٨٤.

^٢ - استاذنا العميد الدكتور/ سليمان الطماوى، قضاء التأديب، ١٩٨٧، ص ٥٤٢. ويعبر سيادته عن هذا المعنى بقوله: "لقد أجمعت حكمة الأجيال على أن العدالة البطيئة هي أشد أنواع الظلم" لهذا فإننا نرى ضرورة إعادة النظر في جميع إجراءات التأديب بما يكفل السرعة والفاعلية.

لغيره من العاملين، وذلك لأن العقاب وقع في وقت محيت فيه آثار الجريمة التي تمت من الأذهان.

الثانية: ومن الناحية المقابلة فإنه من الأفضل ألا يظل سيف العقاب مسلطاً على الموظف البرئ، وأن يظل أمره معلقاً بما يؤدي إليه ذلك من أثر سيئ على نفسية هذا الموظف مما من شأنه أن يصرفه عن أداء عمله والاهتمام بالبحث عن أسباب براءته.

لكل ذلك أوجبت المادة ٣٥ من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بأن: "تفصل المحكمة التأديبية في القضايا التي تحال إليها على وجه السرعة" وحتى لا تتلأأ الجهات الإدارية في إطالة أمد الدعوى التأديبية أوجبت نفس المادة "على الوزراء والرؤساء المختصين موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل في الدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب"، كما منعت المادة ذاتها "تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين".

كما حددت ذات المادة أمداً نهائياً للفصل في الدعوى حيث أوجبت على المحكمة بأن: تصدر حكمها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها". وزيادة في ضمانات المحاكمة فقد نصت المادة ٩ من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ على أن تتولى النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية.^(١)

وتبت المحكمة في الوقائع الواردة بقرار الإحالة، ويجوز لها سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة الإدارية التصدي لوقائع أخرى لم ترد في قرار الإحالة والحكم فيها إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة في الأوراق ويشترط منح العامل أجلاً مناسباً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك.

ويجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على عاملين لم يردوا في قرار الإحالة إذا توافرت لديها أسباب جدية بوقوع مخالفة منهم، وفي هذه الحالة يجب منحهم

^١ - المستشار/ مصطفى كامل اسماعيل، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة، المرجع السابق الإشارة إليه، ص ٢٢.

أجلاً مناسباً لتحضير دفاعهم إذا طلبوا ذلك، وتحال الدعوى برمتها إلى دائرة أخرى بقرار من رئيس المجلس بناءً على طلب رئيس المحكمة. وإذا رأت المحكمة أن الوقائع الواردة في قرار الإحالة أو غيرها ممن تناولها التحقيق تشكل جريمة جنائية فيتعين إحالتها إلى النيابة العامة للتصرف، وتفصل المحكمة التأديبية في الدعوى التأديبية إلا إذا كان الفصل في الدعوى الأخيرة يتوقف على تصرف النيابة في الدعوى الجنائية، ففي هذه الحالة يتعين وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الدعوى الجنائية.

ولا يجوز للمحاكم التأديبية أن تتجاوز مهمتها التي حددها المشرع وهي توقيع العقوبات التأديبية إلى الحكم على الموظفين المحالين إليها بتعويض عن الأضرار التي ألحقوها بالإدارة نتيجة أخطائهم وعلى الإدارة إذا أرادت الحصول على التعويض عن هذه الأضرار أن تلجأ إلى الطرق القانونية المقررة.^(١)

وأحكام المحاكم التأديبية نهائية، ويطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال التي بينها القانون ويجوز لذوي الشأن والوزير المختص، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومدير النيابة الإدارية، والعامل الذي صدر ضده الحكم، الطعن فيها، وإذا كان الحكم الصادر من المحكمة التأديبية هو الفصل من الخدمة فإنه يتعين على رئيس هيئة المفوضين بناءً على طلب العامل المفصول أن يقيم الطعن في الفصل.

وتجتمع المحكمة التأديبية العليا في صورة جمعية عمومية تتألف من جميع أعضائها للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها الداخلي، وتوزيع الاختصاص بين دوائرها. وتتخذ بناءً على طلب رئيس مجلس الدولة أو نائب رئيس المجلس للمحاكم التأديبية أو ثلاثة من أعضائها على الأقل، وتدعى إليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت محدود في المداولة، وفي حالة حضور رئيس المجلس تكون له رئاسة الجلسة وفي غير هذه الحالة تكون الرئاسة لنائب رئيس المجلس لهذه المحاكم وعند غيابه لأقدم الحاضرين.

^١ - أستاذنا العميد الدكتور/ سليمان الطماوى، قضاء التأديب، المرجع السابق، ص ٥٣٣. حيث يشرح سيادته باستفاضة كبيرة أنه لا اختصاص للمحاكم التأديبية في مجال التعويضات المدنية.

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتبلغ القرارات لرئيس المجلس ولا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من رئيس المجلس بعد أخذ رأى نائب رئيس المجلس لهذه المحاكم.

ثانيا : تشكيل المحاكم التأديبية :

يختلف تشكيل المحاكم التأديبية بحسب درجة الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، فإذا كان الموظف من مستوى الإدارة العليا فإن المحكمة التي تختص بمحاكمته تتشكل من ثلاثة مستشارين، أما إذا كان الموظف ممن يشغلون درجات في المستوى الأول أو الثاني أو الثالث فإنه يحاكم أمام محكمة تتشكل برئاسة مستشار على الأقل وعضوية اثنين من النواب (١).

وبصفة عامة فإن المحاكم التأديبية تتشكل كل واحدة منها من دائرة أو أكثر. وتكون مقام المحاكم التأديبية بالنسبة لمستوى الإدارة العليا في القاهرة والاسكندرية. وتتألف كل واحدة منها من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء محاكم تأديبية بالمحافظات، واستعمالاً لهذا الحق أصدر القرار رقم ١٢٥ لسنة ١٩٧٣ بإنشاء محكمة تأديبية بمدينة المنصورة، ويشمل اختصاصها الدعاوى والطعون الخاصة بالعاملين في محافظات الدقهلية ودمياط والشرقية والاسماعيلية وبورسعيد وسيناء ووحدات الحكم المحلي بهذه المحافظات.

كذلك أصدر القرار رقم ١٢٧ لسنة ١٩٧٣ بإنشاء محكمة تأديبية بمدينة طنطا تختص بالنظر في الدعاوى التأديبية والطعون الخاصة بالعاملين بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والقليوبية والمنوفية ووحدات الحكم المحلي في هذه المحافظات. كذلك أصدر القرار رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٣ بإنشاء محكمة تأديبية بمدينة أسيوط تختص بنظر الدعاوى التأديبية والطعون الخاصة بالعاملين في محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ووحدات الحكم المحلي في هذه المحافظات.

^١ - أستاذنا العميد الدكتور/ سليمان الطماوى، قضاء التأديب، المرجع السابق، ص ٥١٨.

أما المحكمة التأديبية بالإسكندرية فتختص بنظر الدعاوى التأديبية والطعون الخاصة بالعاملين بمحافظات الإسكندرية والبحيرة والصحراء الغربية، وكذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم التي مقرها مدينة الاسكندرية بالدعاوى والطعون الخاصة بالعاملين (من مستوى الادارة العليا) من محافظات الاسكندرية والبحيرة والصحراء الغربية. وتتعدد المحاكم التأديبية (للعاملين من المستوى الأول والثاني والثالث) بالقاهرة وتختص كل منها بعدد من الوزارات والمصالح.

وقد صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٣ بشأن تعيين المحاكم التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثاني والثالث وما يعادلها وتحديد دائرة اختصاص كل منها على الوجه الآتي:

١- محكمة تأديبية بالنسبة للعاملين برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارات الخارجية والعدل، والداخلية، وأمانة الإدارة المحلية، والمنظمات الشعبية، ووحدات الإدارة المحلية، وشئون مجلس النواب، والتخطيط، والقوى العاملة، والسياحة والجهات التابعة والملحقة بالوزير.

٢- محكمة تأديبية بالنسبة إلى العاملين بوزارات (الصناعة، والبتترول والثروة المعدنية، والكهرباء، والحربية، والانتاج الحربي، والطيران المدني، والشئون الاجتماعية، والري)، والجهات التابعة والملحقة بالوزير.

٣- محكمة تأديبية بالنسبة إلى العاملين بوزارات (التربية والتعليم، والتعليم العالي والثقافة، والإعلام، والشباب، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والاقتصاد والتجارة الخارجية، والتأمينات، والأوقاف وشئون الأزهر)، والجهات التابعة والملحقة بالوزير.

٤- محكمة تأديبية بالنسبة إلى العاملين بوزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي، والجهات التابعة والملحقة بالوزير.

٥- محكمة تأديبية بالنسبة إلى العاملين بوزارتي الإسكان والمرافق، والصحة، والجهات التابعة والملحقة بالوزير.

٦- محكمة تأديبية بالنسبة إلى العاملين بوزارتي النقل، والمواصلات، وهيئة النقل العام لمدينة القاهرة، والجهات التابعة والملحقة بالوزير.

وتختص كل محكمة تأديبية بالعاملين بفروع الوزارات والموجودة بالمحافظات ولو كانت تحت إشراف المحافظ.

وهكذا يتحدد اختصاص المحكمة من بين المحاكم التأديبية طبقاً لأساسين:

أولهما: المستوى الوظيفي للعامل المقدم للمحاكمة وقت إقامة الدعوى. فإذا تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلامهم في المستوى هي المختصة بمحاكمتهم جميعاً.

ثانيهما: أن تكون محاكمة العاملين المنسوب إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها، ومجازاتهم، أمام المحكمة التي وقعت في دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة. فإذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه. هذا وإذا كانت الجهة التي يتبعها العامل وقت توقيع الجزاء قد حلت محل جهة كانت قائمة على شئون المرفق الذي وقعت المخالفة في شأنه فإن الاختصاص بتوقيع الجزاء عن هذه المخالفة. يصبح للجهة التي صار العامل تابعاً لها أخيراً، وذلك نتيجة حلولها محل الجهة الأولى في اختصاصها (١). ومن ثم ينعقد الاختصاص أيضاً للمحكمة التأديبية التي تتبعها هذه الجهة.

وأما العاملون المعارون أو المنتدبون أو المكفون فالأصل فيهم وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة ٨٢ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ أنهم يخضعون للمحكمة التأديبية التي تتبعها الجهة المنتدب أو المعار إليها العامل أو المكلف، باعتبار أن هذه الجهة هي المختصة بالتحقيق معهم وتأديبهم عن المخالفات التي يرتكبونها أثناء إعارتهم أو نديبهم، إلا أنه يشترط لذلك أن تكون السلطة التأديبية في الجهة التي يعار إليها العامل، أو يندب للقيام بالعمل فيها، تملك قانوناً توقيع جزاءات تأديبية على العاملين المعارين أو المنتدبين إليها من جنس الجزاءات التي يخضع لها هؤلاء العاملون في الجهات الأصلية التي يتبعونها (٢). وأما إذا كانت هذه الجهة من

١ - حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ ١٩٧٦/٥/٢٢ في القضية رقم ٦٥٨ لسنة ١٤٠٤ ق. مشار إليه في كتاب الدليل العملي للإجراءات أمام مجلس الدولة للأستاذ هاتي الدريدي، دار النهضة العربية ١٩٨٠، ج ١، ص ٤٥٥.

٢ - حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ ١٩٧٩/١/٦ (المجموعة س ١٩، ص ٢٢١).

الجهات الخاصة التي لا يخضع العاملون فيها للمحاكم التأديبية مثلاً، فإن العامل المعار أو المنتدب يسأل عن طريق جهته الأصلية (١)، وبالتالي فإنه يخضع للمحكمة التأديبية التي تتبعها جهته الأصلية.

والقواعد المتعلقة باختصاص المحاكم التأديبية تعتبر من النظام العام، وعليه يجوز للموظف المحال للمحاكمة، كما يجوز للنيابة الإدارية التي أقامت الدعوى التأديبية، الدفع بعدم اختصاص المحكمة وذلك في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، فضلاً عن أن للمحكمة التأديبية أن تتصدى للقضاء بعدم اختصاصها وذلك إذا ما تبين لها ذلك من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك ذوو الشأن بهذا الدفع.

وسبب ذلك أن اختصاص المحاكم التأديبية سواء تعلق بشخص العامل، أو بمكان وقوع المخالفة التأديبية، إنما يتحدد على أساس اعتبارات المصلحة العامة وحدها، والتي لا يجوز تجاهلها (٢). وإذا صدر الحكم رغم سلامة تشكيلها جاز الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا (٣).

الفرع الخامس **هيئة مفوضي الدولة**

لم يكن نظام المفوضين معروفاً في ظل القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ القانون الأول لمجلس الدولة، كما لم يعرف هذا النظام في نصوص القانون رقم (٩) لسنة ١٩٤٩ الذي حل محل القانون الأول، إنما عرف في تاريخ تال في ظل القانون رقم (٩) لسنة ١٩٤٩ وذلك بمقتضى المرسوم بقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٥٢ الذي أضاف فقرة جديدة للمادة (٤٠) من القانون رقم (٩) لسنة ١٩٤٩ تنص على أن "يكلف الموظفون الملحقون بالمحكمة باعتبارهم موظفين بالمجلس - بتقديم تقرير في كل قضية يرى رئيس المحكمة تقديمه وتبين اللائحة الداخلية النظام الذي يسير عليه مفوضو المجلس في أعمالهم."

١ - هاني الدريدي الدليل العملي للإجراءات أمام مجلس الدولة، المرجع السابق، ص ٤٥٥.
٢ - دكتور/ عبد الفتاح حسن، التأديب في الوظيفة العامة، دار النهضة العربية، ١٩٦٣ ص ٢٠٨-٢٠٩.
٣ - دكتور/ عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص ٢٠١. المستشار/ مصطفى بكر، تأديب العاملين في الدولة، ص ٢٤٢.

وقد اقتبس هذا النظام من نظام مجلس الدولة الفرنسي حيث يقوم بدور هام وفعال في توجيه القضاء الإداري، وتطوير قواعد القانون الإداري، وذلك وهم بصدد دراسة ملف الدعوى وتهيئة القضية للحكم، والمفوض وهو يمارس هذه الوظيفة كثيراً ما يهتدى إلى حكم يرشد المحكمة إلى ما انتهى إليه المفوض بألفاظه، لذلك فإن بعض الشراح يقرر أن هؤلاء المفوضين يحركون القانون الإداري الفرنسي من وراء ستار.^(١)

ومهمة هؤلاء المفوضين في مجلس الدولة الفرنسي تتلخص في دراسة ملف الدعوى وإعداد تقرير يبدأ بتلخيص الدعوى ذاتها وينتهي ببيان الرأي النهائي الذي يقترح المفوض على المجلس اعتناقه في حكمه وبطبيعة الحال فإن هذا الرأي يجب أن يكون محايداً، ف شأن المفوض واتجاهاته في دراسة القضية يماثل تماماً ما يجب أن يتحلى به القاضي الذي يفصل في الخصومة، وقد نجح نظام المفوضين في مجلس الدولة الفرنسي نجاحاً فائقاً، وهذا النجاح يعود في المقام الأول إلى عظمة الرجال القائمين عليه إلى حد أن كثيراً من المبادئ والنظريات الهامة التي توصل إليها مجلس الدولة في فرنسا كان الفضل في إعدادها يرجع إلى اجتهادات مفوضي الدولة ومذكراتهم القانونية.

ومن هنا كانت أهمية نظام مفوضي الدولة في القضاء الإداري المصري، لذلك نجد أن هذا النظام أخذ مكانه بين هيئات القسم القضائي لمجلس الدولة في القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥، وكان ذلك من أهم ما جاء به هذا القانون من أحكام، والقانون ٥٥ لسنة ١٩٥٩ ثم في القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢.

تشكيل هيئة المفوضين

تتكون هيئة المفوضين (م ٦) من أحد نواب رئيس المجلس رئيساً، ومن عدد كاف من المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين وقد حتمت المادة ٦ من

^١ - الدكتور عبد الحميد كمال حشيش، مبادئ القضاء الإداري، المجلد الأول، المرجع السابق، ص ٢١٠ وما بعدها.

القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بأن يكون مفوضو الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري من درجة مستشار مساعد على الأقل.^(١)

ولما كانت هيئة مفوضي الدولة هي الأمانة على المنازعات الإدارية والعامل الأساسي في تحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة، وفي ابداء الرأي القانوني المحايد فيها سواء في المذكرات التي تقدمها أو في الإيضاحات التي تطلب إليها في الجلسة العلنية، فإنه يتقرر عن ذلك كله أنه لا بد من حضور من يمثلها بالجلسة وإلا وقع بطلان في الحكم، كما أنه إذا قام بالمفوض سبب من أسباب عدم الصلاحية أو الرد المنصوص عليها في المادتين ٧٦، ١٤٨ من قانون المرافعات، فإن المفوض يكون غير صالح في الحالة الأولى ممنوعاً من مباشرة مهمته في الدعوى وجاز رده إن لم ينتحى عنها في الحالة الثانية، وذلك تحقيقاً للحيدة التامة بحكم وظيفته في الدعوى، فإذا كان المفوض غير صالح لمباشرة مهمته في الدعوى، و مع ذلك استمر في مباشرتها، حيث يجب عليه التتحى عنها وندب غيره لأداء مهمته فيها، لما كان كذلك منطقياً على بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم فيعييه ويبطله^(٢).

اختصاص هيئة مفوضي الدولة:

بينت المادتان ٢٧-٢٨ من قانون مجلس الدولة الجديد اختصاص هيئة المفوضين حيث نصت المادة الأولى على أن:

"تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازماً من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية، وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدده لذلك..." ويودع المفوض بعد إتمام الدعوى - تقريراً يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبيدي رأيه مسبباً، ويفصل المفوض في طلبات الإعفاء من الرسوم.

^١ - الدكتور/ يحيى الجمل، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص ١٤٠.
^٢ حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم (١٥٠) لسنة ١ق، جلسة ١٧/١٢/١٩٥٥.

كما نصت المادة ٢٨ على أن: "المفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا خلال أجل يحدده."

وعلى ذلك فإننا نخلص الى أن اختصاص هيئة المفوضين يتحدد في الأمور التالية:

أولاً: تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة:

تتحدد المهمة الأساسية لهيئة المفوضين في تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وذلك باستكمال الناقص من البيانات والأوراق بإجراء تحقيق وتمحيص الوقائع الضرورية في الدعوى وتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية إذا رأى المفوض محلاً لذلك، وهيئة المفوضين حين تقوم بهذا الدور فإنها تجرد المنازعات الإدارية من مجاهل الخصومات الفردية ولدها وتنتظر إليها نظرة موضوعية إذ أن الإدارة يجب أن تكون خصماً شريفاً لا يبغي سوى معاملة الناس جميعاً طبقاً للقانون على حد سواء، ولكي يتكفل المفوض بهذا الدور فإنه يبحث القضية من كافة جوانبها والقاء الضوء على ما أظلم منها وإبراز النقاط القانونية فيها، وفضلاً عن ذلك فإنه يقوم بتحضير الدعوى واعدائها للمرافعة مما يخفف عن كاهل القضاة ويسمح لهم بالتفرغ للفصل فيها، وهو في سبيله لتحقيق هذه المهمة فإن له الاتصال بالجهات الإدارية ذات الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية، كما له إجراء التحقيق في الأجل الذي يحدده إلى غير ذلك مما نصت عليه المادة ٢٧ من قانون مجلس الدولة ويدخل في هذه المهمة ما يتكفل به مفوض الدولة من كتابة تقرير يتضمن عرض وتحديد لوقائع الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع، ويمحص القضية تمحيصاً دقيقاً ثم يضع في النهاية رأياً مسبباً تتمثل فيه الحيدة لصالح القانون وحده.

وللمفوض في سبيل إتمام مهمته (١):

١ - طبقاً للمواد من ٢٧ الى ٣٢ من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة.

١- أن يحدد للطالب أجلاً يودع فيه رده على ملاحظات الجهة الإدارية مشفوعاً بما يكون لديه من مستندات، وفي هذه الحالة يجوز للجهة الإدارية أن تودع مذكرة بملاحظاتها على الرد مع المستندات في أجل مماثل.

٢- إجراء جلسات مناقشة وتحضير: إذا رأى المفوض بعد قراءته ملف الدعوى عقد جلسات للمناقشة، قام بإعلان الموجه اليه بكتاب يرسل إليه إدارياً يحدد فيه موعد الجلسة ورقم القضية وأسماء أطرافها والبيان المطلوب ويذكر فيه مكان الجلسة.

ومن الجائز أن تكون المناقشة أو طلب الاستيفاء في مواجهة جهة من جهات الإدارة، دون أن تكون طرفاً في الدعوى ودون حاجة لإدخالها فيها، لأن ذلك فرع من وظيفتها الإدارية العامة، أما الأفراد فلا يجوز طلب مناقشتهم أو تقديم مستندات من جانبهم إلا إذا كانوا أطرافاً في الدعوى أو أدخلوا فيها.

ولا يشترط لصحة جلسات المناقشة أو التحضير أن تكون في مواجهة الطرفين، على أنه من واجب المفوض، ومن واجب المحكمة بعد ذلك، أن تتيح للطرف الآخر فرصة الاطلاع على ما قدمه خصمه من أوراق أو بيانات.

٣- للمفوض الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازماً لتهيئة الدعوى من بيانات وأوراق.

وقد جرى العمل على أن يكون تعامل المفوض مع الجهات الحكومية عن طريق هيئة قضايا الدولة، بالنسبة للدعوى التي تكون الإدارة نائبة نيابة قانونية فيها عن أطرافها، ويتولى العضو المختص في هذه الإدارة الاتصال بدوره في الجهة التي يمثلها لتوافيه بالمطلوب.

وقد يقوم المفوض بطلب الإستيفاءات اللازمة تليفونياً أو بكتاب عادي يوجهه إلى ذوي الشأن، ولا يشترط في هذا الكتاب شكلاً خاصاً.

٤- للمفوض أن يأمر باستدعاء ذوي الشأن، لسؤالهم عن وقائع الدعوى التي يكون تحقيقها لازماً وضرورياً عن طريقهم، ويلجأ المفوض الى هذه الطريقة، إذا أعوزه الدليل الكتابي أو القرائن المستخلصة من الأوراق والملفات.

٥- وللمفوض أن ينتقل الى الجهات المختلفة لإجراء التحقيق أو إجراء المعاينة أو للاطلاع على المستندات لدى الجهات الإدارية المختلفة، إذا تعذر نقل هذه المستندات اليه أو كان من المتعين للمحافظة على سريتها أن يطلع عليها بنفسه.

٦- وللمفوض أن يكلف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية مما يتطلبه استجلاء الحقيقة في النزاع المعروض قبل جلسات التحضير أو في أثنائها، كما أن له ذلك بعد حيز الدعوى للتقرير إذا اتضح له أن التقرير يحتاج الى ذلك.

٧- وللمفوض أن يحدد للخصوم أجلاً لذلك بحيث إذا خولف كان له أن يوقع الغرامة على الطرف المخالف، فقد نصت المادة ٢٧ من قانون، مجلس الدولة على أنه: "لا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد، إلا إذا رأى المفوض ضرورة منح أجل جديد وفي هذه الحالة يجوز أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهاً يجوز منحها للطرف الآخر."

ويجوز للمفوض أن يصدر القرار بالغرامة موقوفاً على شرط، كان يقرر توقيعها إذا لم يقدم المطلوب خلال المدة المحددة، ويجوز سحب القرار الصادر بتوقيع الغرامة في أي وقت، ويجوز ذلك للمفوض الذي أصدر القرار أو لرئيسه.

٨- للمفوض أن يدخل ولو من تلقاء نفسه شخصاً آخر في الدعوى، وله أن يأذن بهذا الإدخال لذوي الشأن متى رأى أن ذلك لازم لحسن سير الدعوى وتحضيرها، كأن تكون الدعوى قد رفعت على الجهة التابع لها الموظف دون الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه، فيكون من صالح العدالة إدخال هذه الجهة حتى تستطيع الرد عليها مما لديها من أوراق أو مستندات.

وللمفوض أن يكتفى بتكليف السكرتارية إعلان ملخص واف من طلبات ذوي الشأن في الدعوى إلى أي شخص يرى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، أن يكون على علم بها.

٩- للمفوض في سبيل إنجاز مهمته الإستيفائية، أن يتخذ من إجراءات التحقيق ما يراه محققاً للهدف الذي يرمي اليه، فله فضلاً عن سماع الشهود أن يستكتب ذوي

الشأن ممن ينكرون توقيعهم على محرر معين ثم يجرى المضاهاة، أما انتداب الخبير لذلك فمن سلطة المحكمة.

١٠- للمفوض في سبيل إنهاء المنازعة الإدارية بأقصر الطرق وأيسر السبل، أن يعرض على الطرفين في المنازعات التي ترفع إلى محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التي تثبت عليها المحكمة الإدارية العليا خلال أجل يحدده، فإن تمت التسوية استبعدت القضية من الجدول لانتهاء النزاع، وإن لم تتم جاز للمحكمة عند الفصل في الدعوى أن تحكم على المعارض على التسوية بغرامة عشرين جنيهاً يجوز منحها للطرف الآخر.

بعد استيفاء الدعوى وتحقيقها يصدر المفوض قراراً بحجز الدعوى للتقرير، والتقرير الذي يقدمه المفوض في الدعوى يتضمن ملخصاً وافياً لوقائع النزاع وعرضاً لطلبات المدعى، ثم شرحاً وافياً للأسانيد القانونية التي يستند إليها في دعواه، كما يتناول التقرير رد المدعى عليه على الدعوى وأسانيده القانونية.

وبعد عرض وجهات النظر المختلفة للنزاع، يبدي المفوض الرأي القانوني الذي يراه مع تأسيس هذا الرأي على الأسس القانونية والواقعية التي يراها سبباً لهذا الرأي، ولا يتقيد المفوض في رأيه بما أبداه الخصوم من دفوع أو من أسانيد، بل عليه أن يثير من نفسه جميع الدفوع التي تتعلق بالمنازعة، سواء كانت دفوفاً في الاختصاص أو الشكل أو كانت دفوفاً في الموضوع، وكل ما يتقيد به في هذا الشأن هو طلبات الخصوم.

وبعد كتابة التقرير يقوم المفوض بإيداع مسودته ملف الدعوى وتتولى السكرتارية نسخه من أصل وعدد من الصور، ويجوز لأصحاب الشأن الاطلاع عليه تمهيداً للرد عليه ومناقشته أمام المحكمة.^(١)

ثانياً: محاولة إنهاء النزاع ودياً:

لمفوض الدولة كما نصت على ذلك المادة ٢٨ من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أن يعرض على أطراف الخصومة تسوية النزاع ودياً على أساس الثابت من المبادئ القانونية التي استقر عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا، وذلك خلال أجل محدد، فإن قبل الخصوم ذلك أثبتت التسوية في محضر

^١ - استاذنا الدكتور/ محمود حلمي، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص ٤٢٤.

يوقع من الخصوم أو من يوكلونهم ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي. كما تعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام وتستبعد القضية في هذه الحالة من الجدول لانتهااء النزاع فيها، وإذا لم تتم التسوية حسبما أشار مفوض الدولة فالمحكمة عند الفصل فيها أن تحكم على المعارض بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً ويجوز منحها للطرف الآخر.

ثالثاً: الطعن في الأحكام الإدارية:

نصت المادة ٢٣ من قانون مجلس الدولة على أن يكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة المفوضين أن يطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم، وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم بوجوب الطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بناءً على طلب العامل المفصول من حالات الفصل من الخدمة (م ٢٢ من قانون مجلس الدولة)^(١)، كما أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ولا من رئيس هيئة المفوضين وحده خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم، إلا إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن بمقتضى تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره.^(٢)

رابعاً: الفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم:

وقد خولت المادة ٢٧ من قانون مجلس الدولة لهيئة المفوضين الفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم وذلك بالنسبة لمن لا تتوفر لديهم القدرة على دفعها، وبشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب، ويصدر قرار من المفوض دون تسبيب.

^١ - والأصل أن يوقع رئيس هيئة المفوضين على تقرير الطعن الذي يرفع منه أمام المحكمة الإدارية العليا، فإذا قام مانع أو عذر حال دون توقيعه، أل هذا الاختصاص إلى من يليه في الأقدمية، كما أن لرئيس هيئة المفوضين أن يندب أحد معاونيه لاتخاذ سبيل الطعن سواء وقع هذا الندب كتابة أم شفاهة، وللمزيد من التفصيل: راجع: دكتور/ فؤاد العطار، رقابة القضاء على أعمال الإدارة العامة، ص ٢٩٥، ط ١٩٦٨.

^٢ - استاذنا العميد الدكتور/ سليمان الطماوي، قضاء التعويض ١٩٨٦. حيث يشرح سيادته باستفاضة طرق الطعن في الأحكام الإدارية في الصفحات من ٥٣١ إلى ٧١٤. المستشار/ عبد الوهاب البنداري، طرق الطعن في العقوبات التأديبية إدارياً والمائياً، دار الفكر العربي، بدون تاريخ نشر أو رقم إيداع، ولكن لوحظ أنه صدر بعد القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢م.

الفصل الخامس الاختصاص القضائي لمحاكم مجلس الدولة المصري

المبحث الأول مجلس الدولة القاضي العام للمنازعات الادارية

لجأ المشرع منذ إنشاء مجلس الدولة المصري بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ إلى تحديد اختصاص القضاء الإداري بتحديد ما يختص به من مسائل على سبيل الحصر، تاركاً ما لم ينص عليه من مسائل للقضاء العادي، وذلك عدا ما يخرج من ولاية القضاء عامة.

فلم يجعل المشرع اختصاص مجلس الدولة اختصاصاً عاماً بكافة المنازعات الادارية، وإنما اتبع طريقة الحصر والتحديد للاختصاصات بالنص التشريعي. وإذا كان المشرع قد توسع شيئاً فشيئاً في القوانين المتعاقبة لتنظيم مجلس الدولة المصري، حتى شمل الاختصاص القضائي لمجلس الدولة معظم المنازعات الإدارية، فإن هذا الاختصاص ظل محدداً على سبيل الحصر إلى أن صدر دستور ١٩٧١ حيث نصت المادة ١٧٢ من هذا الدستور على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الأخرى" وقد رأى معظم الفقه أن دستور ١٩٧١ حسم مسألة شغلت الفقه كثيراً، وهي تقرير اختصاص مجلس الدولة بنظر كافة المنازعات الإدارية، مما يعني أنه قد أصبح قاضي القانون العام في هذا الشأن.^(١) وكان نصراً كبيراً لهذا الاتجاه الذي نحا إليه الدستور وقانون السلطة القضائية الذي نص في المادة ١٥ منه على تقرير اختصاص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات فيما عدا المنازعات التي يختص بها مجلس الدولة، وقد تأكد ما اتجه إليه

^١ - دكتور/ مصطفى كمال وصفي، مقال بعنوان: "مجلس الدولة القاضي العام للمنازعات الادارية، مجلة العلوم الادارية، السنة ١٤، العدد الثالث ديسمبر ١٩٧١، ص ٨٣ وما بعدها. أستاذنا الدكتور/ سليمان الطماوي، القضاء الاداري، الكتاب الثاني، ص ١٠٨ وما بعدها. دكتور/ ماجد الحلو، القضاء الاداري، طبعة ١٩٨٥ ص ١٨٢.

أستاذنا الدكتور/ محمود حافظ، القضاء الاداري، دار النهضة العربية، طبعة ١٩٧٩، ص ٣٠٦.
الدكتور/ أنور رسلان، مسؤولية الدولة غير التعاقدية، دار النهضة العربية، ص ١٨٠-١٧٩.

المشرع في دستور ١٩٧١ بصدر القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم مجلس الدولة حيث قرر في البند الرابع عشر من المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في "سائر المنازعات الإدارية"، وذلك بعد أن أشار في البنود الثلاثة عشر السابقة الى بعض الأمثلة التي تعتبر : من اختصاص محاكم المجلس بوصفها منازعات إدارية، وهكذا أكد المشرع الدستوري والعادي اختصاص مجلس الدولة وحدة بنظر كافة المنازعات الإدارية الا ما استثنى منها بنص تشريعي صريح على النحو الذي سنوضحه.

وهكذا أصبح مجلس الدولة المصري ولأول مرة صاحب الاختصاص العام بالمنازعات الإدارية مقتضياً أثر مجلس الدولة في فرنسا.

وبالرغم من النصوص الصريحة التي وردت في قانون مجلس الدولة الذي نص في مادته العاشرة على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بسائر المنازعات الإدارية، فقد ذهب رأى في الفقه إلى غير ذلك بالنسبة لاختصاص القضاء الإداري بدعوى المسؤولية عن أعمال الإدارة المادية مخالفاً بذلك ما ارتآه غالبية الشراح، وذلك لأن الأمر عنده يستلزم شيئاً من استطلاع الواقع حسبما يتجه إليه القضاء عملياً، ذلك أن مثل هذه المسائل لا تقرر دائماً بطريقة نظرية محضة، كما يرى أن بعض الاعتبارات القانونية والعملية قد تؤيد الإبقاء على اختصاص القضاء العادي بهذه المنازعات برغم التعديلات الجديدة مثل الرغبة في توحيد قواعد المسؤولية المطبقة في الدولة ... فقد يكون من الأفضل والأرجح القول ببقائه -أي التعويض عن أعمال الإدارة المادية- في اختصاص القضاء العادي.

ومن ناحيتنا فإننا نؤيد ما ذهب إليه غيرنا من عدم الموافقة على ما انتهى إليه هذا الرأي، كما لا نسلم مع غيرنا بالأسباب التي ساقها تبريراً للرأي السابق، وذلك لوضوح النص سواء الدستوري أو التشريعي، ومن ثم لا محل لاستطلاع الواقع مع صراحة النصوص التي لا تحتل أي تأويل والتي لا يجوز أن تحول دون تطبيقها أي اعتبارات قانونية أو عملية، ولم يكن الأمر محل جدل بالنسبة لأحكام القضاء الإداري^(١).

^١ - للمزيد من التفصيل في نقد هذا الرأي: راجع: دكتور/ أنور رسلان، المرجع السابق، ص ١٨٢-١٨١.

وقد عرض الموضوع على المحكمة العليا في الدعوى رقم ٥ لسنة ٣ عليا (دستورية). فقررت بتاريخ ٢٩ يونيو سنة ١٩٧٤ ما يأتي (١):
يستفاد من الأعمال التحضيرية للدستور التي أسفرت عن إقرار نص المادة ١٧٢ منه أن مناقشات فقهية عميقة ثارت بين أعضاء لجنة نظام الحكم بشأن هذا النص حول مسألتين:

الأولى: ضرورة النص في الدستور على قيام مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة باعتباره صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية، وذلك على خلاف ما جرت الدساتير السالفة من إغفال هذا النص فكانت تصدر دون ذكر لمجلس الدولة أو مجرد الإشارة إليه.

الثانية: هي تحديد مدى اختصاصه بالفصل في المنازعات الإدارية والدعوى التأديبية "وبالنسبة إلى **المسألة الأولى** استقر الرأي في لجنة نظام الحكم على ضرورة النص في الدستور على مجلس الدولة واختصاصاته كهيئة قضائية تختص برقابة شرعية أعمال الإدارة، وذلك صوناً له من العدوان عن طريق التشريع العادي كلما ثار الخلاف بينه وبين السلطة التنفيذية.

إذا كان انشاء المجلس وتحديد اختصاصاته يتم بقوانين عادية يجوز إلغاؤها وتعديلها بقوانين عادية في مرتبتها فأصبح بنص المادة ١٧٢ من الدستور دائماً ومستقراً محصناً بقوة النص الدستوري ضد أي عدوان على كيانه أو اختصاصه المقرر في الدستور عن طريق التشريع العادي، ولم يقف المشرع الدستوري في دعم مجلس الدولة عند هذا الحد، بل جاوزه إلى حماية اختصاصه وذلك بإلغاء القيود التي كانت تقف حائلاً بينه وبين ممارسته فاستحدثت في المادة ٨٦ نصاً يقضى بأن: "النقاضي حق مكفول للناس كافة وأن لكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء"، وهكذا سقطت النصوص القانونية التي كانت تحظر الطعن في

١ - مجموعة الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية من المحكمة العليا، القسم الأول، الجزء الأول (الأحكام الصادرة في الفترة من انشاء المحكمة سنة ١٩٧٠ حتى لو امير ١٩٧٦)، من ١٧٨ وما بعدها.

القرارات الإدارية وسقطت بذلك جميع الحوائل التي كانت تحول بين المواطنين وبين الالتجاء إلى مجلس الدولة يطلبون العدل والنصفة."

"وفي أكتوبر من عام ١٩٧٢ صدر القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة معدلاً اختصاصاته وفقاً لأحكام المادة ١٧٢ من الدستور، وقد تضمنت المادة العاشرة هذا التعديل إذ نصت في ثلاث عشرة فقرة على المسائل التي كان يختص بها المجلس على سبيل الحصر طبقاً لقوانينه السابقة، ثم عقت عليها في الفقرة الرابعة عشرة بالنص على اختصاص المجلس بسائر المنازعات الإدارية باعتباره صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية."

وبالنسبة إلى **المسألة الثانية** التي تناولها أعضاء لجنة نظام الحكم في مناقشاتهم، وهي تحديد مدى اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، فقد كان الهدف السائد من هذه المناقشات هو الانتقال بمجلس الدولة من مرحلة الاختصاصات المقيدة على سبيل الحصر إلى مجال الاختصاص العام على النحو المتقدم باعتباره صاحب الولاية العامة على المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، وذلك استيفاء لاختصاصه الطبيعي.

وقد اقترح بعض الأعضاء نصاً بهذه الصيغة "يكون لمجلس الدولة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية والتأديبية" وأقر الأعضاء ثم استبدل به النص الحالي للمادة ١٧٢ من الدستور، وكلا النصين يفيدان تقرير الولاية العامة لمجلس الدولة على المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، فلم يعد اختصاصه مقيداً بمسائل محددة على سبيل الحصر كما كان منذ إنشائه، وهذا لا يعنى غل يد المشرع عن إسناد الفصل في بعض المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية إلى جهات قضائية أخرى على أن يكون ذلك على سبيل الاستثناء من الأصل العام المقرر بالسادة ١٧٢ من الدستور وبالقدر وفي الحدود التي يقتضيها الصالح العام، وعلى هذا النحو يهمل المشرع التفويض المخول له بالعادة ١٦٧ من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها مع مراعاة الأصل العام المقرر بالمادة ١٧٢ من الدستور في شأن اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات

الإدارية والدعاوى التأديبية باعتباره صاحب الولاية العامة على هذه الدعاوى وتلك المنازعات".

وهكذا حسمت المحكمة العليا الخلاف الذي أثير بمناسبة صدور قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ وتضمنين المادة العاشرة منه أمثلة للمسائل التي تختص بها محاكم مجلس الدولة، ثم التعميم بعد ذلك والنص على اختصاص محاكم مجلس الدولة بسائر المنازعات الإدارية، الأمر الذي يؤدي بنا إلى القول بأن القضاء الإداري قد أصبح بما لا يدعو للجدل قاضي القانون العام بالنسبة لسائر المنازعات الإدارية سواء ما ورد منها في المادة ١٠ من قانون مجلس الدولة أو غيرها من المنازعات ذلك أن التعداد الوارد في هذه المادة لا يعدو أن يكون مجرد أمثلة لأغلب المنازعات التي تطرح على المحاكم الإدارية وليس حصراً لها.^(١)

المبحث الثاني

المسائل المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بناء على نص المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ - بالفصل في المسائل الآتية:

أولاً : الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.

ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.

ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.

رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.

خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.

^١ - وعلى ذلك لا نوافق على ما ذهب إليه بعض الفقه من أن القضاء الإداري "جهة قضاء محددة الولاية وقد حددت المادة ١٠ من قانون مجلس الدولة ما تختص به محاكم مجلس الدولة وهو تحديد وارد على سبيل الحصر" للمزيد من التفصيل:

راجع: دكتور أحمد الصاوي، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، ج ١، ص ١٧٣، وللمزيد من التفصيل في الرد على هذا الاتجاه: راجع: دكتور أنور أحمد رسلان، المرجع السابق، ص ١٨١ (الهامش).

سادسا: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.

على أنه بالنسبة لهذه المنازعات نصت المادة الثانية من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ على أن يصدر قانون خاص ينظم كيفية نظرها أمام مجلس الدولة، فتظل الجهات القضائية مختصة بنظرها حتى يصدر هذا القانون.

سابعا: دعاوى الجنسية.

ثامنا: الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل، وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.

تاسعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطة التأديبية.

عاشرا: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.

حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر.

ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.

ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.

رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.

ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.

وقد سبق أن أشرنا الى أن دستور ١٩٧١ قد خول مجلس الدولة المصري الولاية العامة على المنازعات الإدارية والدعوى التأديبية بما يمكنه من أن يكون القاضي العام في المنازعات الإدارية، ووفقاً لنص المادة ١٧٢ من الدستور فإن مجلس الدولة يختص بالفصل في المنازعات الآتية:

١- المنازعات الإدارية.

٢- الدعوى التأديبية.

٣- الدعوى الأخرى التي يحددها القانون.

وفيما يتعلق بالأمر الأول وهو اختصاص مجلس الدولة بسائر المنازعات الإدارية فإن ذلك يخول المحاكم الإدارية بأن تتصدى لكافة المنازعات الإدارية، لذلك جاء نص المادة ١٠ من قانون مجلس الدولة منطقياً مع ما أشار به دستور ١٩٧١ وتوكيداً له حيث حددت المادة المذكورة ثلاثة عشر نوعاً من المنازعات الإدارية تمثل في الحقيقة معظم المنازعات الإدارية التي تختص بها هذه المحاكم ثم عكبت المادة المذكور بان قررت اختصاص مجلس الدولة بسائر المنازعات الإدارية وذلك بخلاف الوضع السابق في قوانين مجلس الدولة قبل القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ حيث كان اختصاص مجلس الدولة محدداً على سبيل الحصر ولم يكن بالتالي يختص بدعوى مسئولية الإدارة عن أعمالها المادية، كما ان بعض القرارات المتعلقة بالموظفين العموميين كانت تخرج من ولاية المجلس، ولا يعني النص على اختصاص مجلس الدولة بكافة المنازعات الإدارية أنه قد أصبح محيطاً بكل منازعات الإدارة التي تكون الإدارة أحد أطرافها، وإنما المقصود بالمنازعات الإدارية التي تدخل في ولاية المجلس تلك المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها، وتختلف في طبيعتها وظروفها عن المنازعات التي تكون بين الأفراد أو أشخاص القانون الخاص بصفة عامة، وفيما عدا ذلك فإن مجلس الدولة يختص بسائر منازعات المسئولية سواء تعلقت بمسئولية الإدارة عن أعمالها القانونية أو المادية، وكذلك المنازعات بأعمال التعدي^(١)، والمنازعات المتعلقة باستيلاء الإدارة بصفة دائمة أو

^١ - وقد أكدت محكمة القضاء الإداري منذ مدة طويلة ولايتها بنظر أعمال التعدي، فني حكم لهذه المحكمة في ٨ مارس ١٩٥١ أكدت للمحكمة اختصاصها في موضوع هذه القضية بتعلق بدعوى رفعها شرطي كان له شارب

مؤقتة على عقارات مملوكة لأحد الأفراد بالمخالفة لأحكام القانون وهي التي يطلق عليها غصب العقارات، فضلاً عن اختصاص مجلس الدولة بأعمال السيادة التي أخرجتها المادة ١١ من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ من اختصاص المجلس وذلك لمخالفة ذلك لأحكام المواد ٦٤، ٦٥، ٦٨ من الدستور (١).

أما فيما يتعلق بالأمر الثاني الذي أشارت إليه المادة ١٧٢ من دستور ١٩٧١ وهو اختصاص مجلس الدولة بالدعاوى التأديبية فإن محاكم مجلس الدولة تختص وحدها دون غيرها بالفصل في الدعاوى التأديبية، وقد أكد قانون مجلس الدولة هذا الاختصاص الذي ورد في الدستور في البند الثاني عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، ومن ثم يدخل في اختصاص المحاكم القضائية لمجلس الدولة كافة الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين في الحكومة أو القطاع العام على النحو الذي حدده قانون مجلس الدولة (٢). أما فيما يتعلق بالأمر الثالث فقد أشارت المادة ١٧٢ من الدستور على أن يحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وقد درج المشرع على تخويل مجلس الدولة النظر في بعض المنازعات التي يصعب أن تعد في نطاق المنازعات الإدارية والتأديبية، ومن ذلك اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وفقاً لما ينص عليه القانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٤٨ والمعدل بالقانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٥٥.

وترتيباً على ذلك فإن مجلس الدولة المصري يختص بكافة المنازعات الإدارية بالمعنى الذي أشرنا إليه والدعاوى التأديبية، والدعاوى الأخرى التي ينص القانون على تخويل مجلس الدولة اختصاص نظرها.

طويل يشبه شارب الملك ونشرت إحدى الصحف صورته مع تعليقات ساخرة فأمرت الإدارة بحلق شاربه ونفذت الأمر بالقوة، فحكم القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وتعويض المدعى.

^١ - للمزيد من التفصيل:

راجع: دكتور/ ماجد الحلو، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص ١٨٢-١٩٦.

راجع: دكتور/ أنور رسلان، مسؤولية الدولة غير التعاقدية، ص ١٧٩-١٨٤.

^٢ - المواد من ١٥ إلى ٢٢ من قانون مجلس الدولة الحالي رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ والمعدل بالقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨٨.

ونصت المادة ١١ على عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة .

كما نصت المادة ١٢ على عدم قبول الطلبات الآتية:

- أ- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية.
 - ب- الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود (ثالثاً ورابعاً وتاسعاً) من المادة ١٠، وذلك قبل التظلم منها الى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم.
 - وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة ويمكن رد هذا التعداد الى المسائل الآتية:
 - ١- الطعون الانتخابية.
 - ٢- طعون الموظفين.
 - ٣- طعون الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية أو بالتعويض عنها ومن هذه القرارات الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي.
 - ٤- المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية.
 - ٥- المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم.
 - ٦- دعاوى الجنسية.
 - ٧- الدعاوى التأديبية.
 - ٨- الطعون على الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام.
 - ٩- سائر المنازعات الإدارية.
- وستتولى فيما يلي شرح هذه المفردات التي يتحدد على ضوئها اختصاص المحاكم الإدارية في مصر وسنبين كل منها في مطلب خاص.

المطلب الأول

الطعون الانتخابية

نصت المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم مجلس الدولة على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون الخاصة

بانتخابات الهيئات المحلية، وإعمالاً لما تقضى به المادة رقم ١٣ من ذات القانون فإن محكمة القضاء الإداري هي المختصة وحدها بنظر هذه الطعون. والطعون الانتخابية التي يختص بها القضاء الإداري هي الطعون المتعلقة بانتخاب المجالس المحلية وفقاً لما تقضى به المادة الأولى من قانون الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ١٩٨٨، وهي مجالس المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى.

وقد كانت المجالس المحلية قبل القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٥ في ظل القانون رقم ١٢٤ سنة ١٩٦٠، والقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٧١ تتشكل من عناصر منتخبة وأخرى معينة مع ترجيح كفة العناصر المنتخبة في جميع تشكيلات المجالس المحلية، وكان الواقع العملي يخالف ما تقضى به هذه القوانين حيث كانت تتشكل المجالس المحلية من عناصر معينة، لذلك كان البند الأول من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة معطلاً لعدم وجود عناصر منتخبة، وقد أصبح تشكيل المجالس الشعبية المحلية في ظل القانون ٥٢ لسنة ١٩٧٥ من عناصر جميعها عن طريق الانتخاب لذلك نصت المادة ٨٦ من هذا القانون في فقرتها الأخيرة على أن: تفصل المحكمة الإدارية المختصة في الطعون الخاصة بصحة العضوية ويجب أن ترفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب."

ويقصد بالطعون الخاصة بصحة العضوية الطعون المتعلقة بعملية الانتخاب سواء كان ذلك يتعلق بشروط الانتخاب أو إجراءاته، كما تشمل الطعون الخاصة بإسقاط العضوية، وعلى ذلك يتعين التفرقة بين حالتين من الطعون الانتخابية وهما:

١- الطعون في العملية الانتخابية.

٢- الطعون في إسقاط العضوية.

وقبل الحديث عن هذين النوعين من الطعون نشير الى أن الطعون الانتخابية لا تتعلق بطعن في قرار إداري، ومن ثم فلا يكون الطعن متعلقاً بدعوى إلغاء حيث أن الطعن بالإلغاء لا يكون إلا في قرار إداري، وإنما يتعلق الطعن بانتخاب تفصح الإدارة بمقتضاه عن إرادة الناخبين، لذلك فإن المشرع أفرد له بنداً خاصاً يستقل عن الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية.

وفيما يلي نتحدث عن نوعي الطعون الانتخابية:

أولاً: الطعون في العملية الانتخابية:

وهي طعون توجه إلى العملية الانتخابية بذاتها وذلك قبل أن تثبت للشخص صفة العضوية، وهذه الطعون ينعقد الاختصاص بالنسبة لها لمحكمة القضاء الإداري حيث يكون لها ولاية القضاء الكامل، ومن ثم فإن محكمة القضاء الإداري تتصدى لمنازعات العملية الانتخابية، واختصاصها يشمل:

- ١- التأكد من مراعاة الإجراءات التي نص عليها المشرع بالنسبة للانتخابات.
- ٢- مراقبة مواعيد وتشكيل لجان الانتخاب وطريقة التصويت وفرز الأصوات، ومراقبة الشروط الواجب توافرها في الناخب، ومدة الطعن الانتخابي ثلاثون يوماً على النحو الذي نص عليه القانون.

ثانياً: إسقاط العضوية:

نصت المادة ٩٦ من قانون الإدارة المحلية على أن تسقط عضوية المجلس المحلي عنمن تزول عنه صفة العامل أو الفلاح التي قام عليها انتخابه في المجلس أو بفقد شرط من الشروط اللازمة للترشيح ويجب إسقاط العضوية عنمن تثبت مخالفته لأحكام المادة ٩٢ الخاصة بتعاقد العضو مع المجلس الشعبي أو من يفقد الثقة والاعتبار، كما يجوز إسقاط العضوية في حالة إخلال العضو بواجبات العضوية الأخرى أو بمقتضياتها، ويجب في جميع الأحوال السابقة صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية أو بإسقاطها، وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله في المواعيد وطبقاً للقواعد وبالأغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة".

وقد جرت أحكام القضاء الإداري على تأكيد اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعون الخاصة بإسقاط العضوية في المجالس المحلية على أساس أنها تدخل ضمن الطعون الانتخابية، وهذا غير صحيح، لأن إسقاط العضوية لا يتحقق إلا بعد ثبوت العضوية ومع ذلك كان المشرع يفسر ما جرت عليه أحكام المحكمة في قوانين الإدارة المحلية السابقة، كما أقر أن ميعد الطعن في قرارات إسقاط العضوية هو ذات ميعد الطعون الانتخابية وهي ١٥ يوماً، ويجب الفصل فيها على وجه

الاستعجال وبدون رسوم، ويرى بعض الفقه ان هذه القوانين كانت أكثر توفيقاً من القانون الحالي الذي لم ينظم الطعن في إسقاط العضوية حيث أن تنظيم الطعن في هذه القرارات يحقق مصلحة مؤكدة، لذلك فليس هناك ما يمنع من اختصاص محكمة القضاء الإداري بالنظر في هذه الطعون على أساس أنها تعتبر من قبيل الطعون التي يقدمها الأفراد والهيئات لإلغاء القرارات الإدارية طبقاً لنص البند خامساً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة.

المطلب الثاني

طعون الموظفين

منذ أنشئ مجلس الدولة سنة ١٩٤٦ وطعون الموظفين تشكل الجانب الأكبر من القضايا المنظورة أمامه مما يكشف عن مدى حاجة الموظفين لحماية القضاء الإداري، وهو ما رددته الأعمال التحضيرية لقانون إنشاء مجلس الدولة.

ولم يتول المشرع في قوانين مجلس الدولة المتعاقبة تحديد معنى الموظف ولكن محكمة القضاء الإداري ثم المحكمة الإدارية العليا فيما بعد قد قامت بهذه المهمة حيث حددت فكرة الموظف العام التي هي مناط اختصاص القضاء الإداري، ومن ذلك على سبيل المثال حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ ١٩٦٢/٥/٥ إذ تقول:

"ليس في التشريعات أو اللوائح في مصر نص يعرف الموظف العام، وإن كان الكثير من القوانين المصرية استعملت عبارة: "الموظفين العموميين أو المستخدمين العموميين" دون تفرقة بين العبارتين ودون تحديد فئة الموظفين العموميين بالذات وقد تلاقى القضاء والفقه الإداري على عناصر أساسية للوظيفة العامة ولاعتبار الشخص موظفاً عمومياً مراعاة قيام العناصر الآتية:

١- أن يساهم في العمل في مرفق عام تديره الدولة عن طريق الاستغلال المباشر، وفي مصر يعتبر الموظفين العموميين عمال المرافق العامة سواء كانت إدارية أم اقتصادية ما دامت هذه المرافق تدار بأسلوب الاستغلال المباشر.

٢- أن تكون المساهمة في إدارة المرافق العامة عن طريق التعيين أساساً وقرار إسناد الوظيفة يكون عن طريق عمل فردي أو جماعي يصدر من جانب السلطة العامة.

٣- أن يشغل وظيفة دائمة، وأن يكون شغله لهذه الوظيفة بطريقة مستمرة لا عرضية وغنى عن القول أن هذه العناصر لا يمكن اعتبارها عناصر قاطعة نهائية للحكم على عامل من عمال الإدارة بأنه موظف أو غير موظف إلا أنها عناصر أساسية يجب مراعاتها.

وهناك عناصر أخرى يتعين استبعادها ولم يعول عليها القضاء، من ذلك المعيار في اعتبار الموظفين ليس نوع العمل الذي يسند اليهم أو أهمية العمل أو كونهم مثبتيين أو غير مثبتيين، يستقطع منهم معاش أم لا يستقطع، أو في منحهم مرتبات نقدية أو عينية، أو في عدم منحهم مرتبات، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على اعتبار أن العمد والمشايخ من الموظفين العموميين، إذ أن الراتب الذي يجرى عليه حكم الاستقطاع ليس شرطاً أساسياً لاعتبار الشخص موظفاً عمومياً، كذلك الحال فيما يتعلق بالمأذون وهو الذي يوثق عقود الزواج في مصر، فلا يؤثر في هذا النظر عدم تقاضيه راتباً من خزانة الدولة، لأن الراتب ليس من الخصائص اللازمة للوظيفة العامة أو شرطاً من الشروط الواجبة في اعتبارها

ولا يقتصر الموظفون العموميون على موظفي الحكومة المركزية، بل يدخل فيهم موظفو السلطات اللامركزية الإقليمية والسلطات اللامركزية المصلحية لو كانوا لا يخضعون لجميع أحكام قانون موظفي الدولة أي لو صدرت في شأنهم قوانين خاصة. والمبادئ التي أوردها هذا الحكم لا زالت سليمة جملة وتفصيلاً اللهم إلا بخصوص شرط دائمية الوظيفة فلقد خرج قانون العاملين المدنيين رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ وتعديلاته على هذا الشرط وأخضع لأحكامه من يعينون طبقاً له سواء كانت وظائفهم دائمة أو مؤقتة، وقد توسع قضاء مجلس الدولة في تعريف الموظف العام ففتح أبوابه لكل من يشغل مركزاً عاماً ويمارس قدراً من السلطة العامة، بقصد تحقيق مصلحة عامة للمواطنين، وفي حدود ما يسمح به تفسير النصوص في هذه المجالس.

مدى ولاية القضاء الإداري فيما يتعلق بهذه الطعون:

كان من المنطقي وقد وحد الاختصاص بطعون الموظفين ومنح للقضاء الإداري دون مشاركة من جانب المحاكم القضائية أن يختص هذا القضاء بجميع

شئون الموظفين، ولكن المشرع لم يتبع هذا المسلك وجعل الاختصاص محددًا على سبيل الحصر، إلا أننا نعتقد أن هذا الحصر قد أصبح شاملاً لجميع هذه الطعون بعد أن أضاف المشرع في القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ الاختصاص الرابع عشر وهو "سائر المنازعات الإدارية" إذ بهذا الاختصاص المستحدث، وفي نطاقه ستدرج جميع طعون الموظفين باعتبارها من المنازعات الإدارية، والأمر أولاً وأخيراً مرجعه تفسير القضاء الإداري لعبارة المنازعات الإدارية ومدى شمولها لهذه الطعون، وتدل السوابق القضائية للمجلس على توسعه في تفسير النصوص ليظل بحمايته أغلب هذه الحالات.

وسنعرض فيما يلي التفسير الواسع الذي ذهب إليه القضاء الإداري في الفقرات ثانياً، ثالثاً، رابعاً، تاسعاً، من المادة ١٠ السالف الإشارة إليها وهي تطابق حرفياً نصوص القوانين السابقة المنظمة لمجلس الدولة.

أ- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.

وقد فسرت محكمة القضاء الإداري المرتب بحيث جعلته يشمل جميع المزايا المقررة للوظيفة فقالت: "إن المرتب في عموم معناه لا يقتصر على المبلغ المحدد أساساً بصفة أصلية للموظف بحسب درجة وظيفته، بل يشمل كذلك جميع المزايا المتعلقة بالوظيفة مادية كانت أو أدبية عينية كانت أو نقدية إذ يعتبر من ملحقات المرتب الأصلي وتأخذ حكمه كالمرتبات الإضافية وبديل السفر وعلاوة الغلاء وبديل الغذاء وبديل السكن والملابس والاغتراب وبديل الإقامة في الجهات النائية وبديل العيادة.

كما توسعت أيضاً في تفسير اصطلاح المكافآت المستحقة للموظفين العموميين فجعلته شاملاً للمكافآت المقررة بمقتضى قوانين المعاشات والمكافآت التي يستحقها الموظف بناءً على أعمال إضافية من الجهة الحكومية التابع لها أو إحدى الجهات الحكومية الأخرى.

ولم يقف اجتهاد المحكمة عند حد التوسع في تفسير مدلول الألفاظ بل شمل النزاع في ذاته وطبيعته أو كما نقول: "واختصاص هذه المحكمة بالمنازعات المتعلقة بالرواتب هو اختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات ولجميع ما يتفرع

منها، وبهذه المناسبة تنتظر المحكمة ما يكون قد صدر بشأنها من إجراءات أو قرارات وذلك باعتبارها من العناصر المتفرعة عن المنازعات الأصلية في حدود اختصاصها الكامل بنظرها."

واستناداً لهذا المبدأ قضت المحكمة باختصاصها بنظر النزاع الخاص بتقدير السن بواسطة القومسيون الطبي لأنه من المنازعات المتعلقة بالمعاشات، وقد كانت المحكمة حريصة في كل هذه المجالات أن توضح أن هذا التوسع في التفسير يجب أن يحتمله النص، ولقد أيدت المحكمة الإدارية العليا هذا الاجتهاد.

ب- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.

وهذه أيضاً قد توسعت المحكمة فيها فلم تقصر التعيين على بدء صلة الموظف بالحكومة لأول مرة، بل فسرتة على أنه تقليد للوظيفة الحكومية بالمعنى الواسع، ويستوي في ذلك أن يكون التعيين قد أدى إلى التحاق الموظف بالعمل لأول مرة أو إلى تولى الموظف وظيفة جديدة تغاير في طبيعتها أو من حيث شروط التعيين في الوظيفة السابقة التي كان يشغلها، وكان من شأن هذا التوسع أن امتد اختصاص المجلس ليشمل طائفة من القرارات لم ترد في النصوص، منها على سبيل المثال النقل النوعي أي نقل الموظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى مغايرة.

وقد تبنت أيضاً المحكمة الإدارية العليا هذا الاجتهاد في مجال الترقية فقررت المحكمة أن مدلولها لا يقتصر على تعيين الموظف في درجة مالية أعلى من درجته بل يشمل تعيين الموظف في وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفة التي يشغلها في مدارج السلم الإداري، إذ أن الترقية بمعناها الأعم هي ما يطرأ على الموظف من تغيير في مركز قانوني ويكون من شأنه تقديمه على غيره وتدرجه في مدارج السلم الوظيفي والإداري، ويتحقق ذلك أيضاً بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته الحالية في مجال الاختصاص وإن لم يصاحب هذا التقليد نفع مادي.

كما أن محكمة القضاء الإداري لم تقصر اختصاصها على المنازعات التي تتعلق مباشرة بقرارات التعيين أو الترقية أو منح العلاوات، وإنما سحبت هذا الاختصاص ليشمل جميع القرارات التي تمت بصلة وثيقة إلى المنازعات المبينة

بالفقرتين ثانياً وثالثاً والتي تؤثر في الحاضر أو المستقبل في مرتبات الموظفين أو معاشاتهم أو مكافاتهم أو في ترقيةهم أو منحهم العلاوات، مثال ذلك القرارات الصادرة في شأن الأقدمية في الدرجة، التقرير السنوي بكفاية الموظف، قرار مجلس الجامعة باستبعاد عضو هيئة التدريس من الترشيح لكرسي الأستاذية.

ج- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية

الصادرة بإحالتهم إلى المعاش.

وهنا أيضاً لم تقتصر المحكمة على قرارات الإحالة إلى المعاش أو الفصل الصريحة، بل أدخلت فيها الاستقالات التي يكره الموظفون على تقديمها إذ تقول: "وإذا استبان للمحكمة من استعراض الوقائع أن طلب الاستقالة الذي قدم من المدعى لم يصدر منه عن إرادة حرة وإنما حصل تحت تأثير الإكراه الأدبي الذي وقع عليه من ممانعة الوزارة له في الاستمرار في عمله الحر إلى أن يحصل على ترخيص جديد من مجلس الوزراء أولاً... ومن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على هذا القرار ثانياً، ثم تصميمها على هذا المنع مع مخالفة ذلك للقانون مما يجعل رضاه معدوماً، ومن ثم كان قرار قبول الاستقالة والحالة هذه بمثابة الفصل غير المشروع." وحيث أن محكمة النقض المصرية قد منحها القانون دون غيرها الفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، فقد قررت هذه المحكمة في حكم حديث لها بأن الاستقالة التي أكره على تقديمها أحد المستشارين في مجلس الدولة من أفراد جماعة الإخوان المسلمين تحت الضغط المادي والتعذيب البدني في السجن الحربي بمثابة الفصل المخالف للقانون ومن ثم وجب إلغاؤه واعتباره كأن لم يكن.

وكذلك الشأن فيما يتعلق بطلب الإحالة إلى المعاش إذ يجب أن يكون صادراً عن رغبة صحيحة ورضاء طليق فإذا شابه عيب مما يهدم الرضا أو يفسده كان قرار الإحالة إلى المعاش باطلاً، وبمثابة الفصل المخالف للقانون وجاز الطعن فيه والغاؤه.

د- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية

للسلطات التأديبية.

وتتمثل عبارة "القرارات النهائية للسلطات التأديبية" وفقاً لقضاء مجلس الدولة

المصري في كل قرار يكون تأديبياً في موضوعه سواء صدر من السلطة الرئاسية أم من مجلس التأديب.

وقد أقرت المحكمة الإدارية العليا هذا المبدأ بقولها أنه إذا كان القضاء الإداري غير مختص كقاعدة عامة بالنظر في المنازعات المتعلقة بقرارات النقل فإن من بين القرارات الموضوعية بأنها قرارات نقل مما يتعين على محكمة القضاء الإداري أن تقول كلمتها حيالها، منها القرار الذي يقضى بنقل موظف إلى وظيفة تقل درجته عن درجته أو كادر تقل مزاياه عن مزايا الكادر الذي ينتمي إليه، وذلك الذي يتسبب عنه تفويت دور الموظف المنقول في الترقية بالأقدمية في الجهة المنقول منها، والآخر الذي ينطوي على جزاء مقنع ومرد الاختصاص في شأن هذه القرارات يرجع إلى ما لحقها من عيب سواء لمخالفتها للقانون أو لصدورها مشوبة بالانحراف بالسلطة وتتكب وجه المصلحة العامة بإعطاء أسباب ظاهرية للنقل حالة أنها تخفي في الواقع هدفاً غير مشروع، ولقد امتد قضاء مجلس الدولة -بعد تردد- ليشمل قرارات النقل أو النذب المكنى أو القرارات التي احتوت على عقوبة تأديبية مقنعة.

نوع ولاية القضاء الإداري فيما يتعلق بطعون الموظفين:

واضح من استعراض الفقرات السابقة والفقرة العاشرة أن اختصاص مجلس الدولة يشمل نوعي القضاء الإداري وهما: القضاء الكامل (الإلغاء والتعويض) وقضاء الإلغاء.

ووفقاً لولاية القضاء الكامل للمحكمة تستطيع المحكمة أن تحدد بنفسها للموظف حقوقه التي يستمدّها من القانون كالمرتّب أو المعاش أو المكافأة مما يطلق عليه (تسوية حالة) وفقاً للتفسير الواسع الذي التزمه القضاء الإداري في هذا الصدد، كما تستطيع المحكمة إلغاء القرارات المنصوص عليها في الفقرات السابق بيانها بناءً على طلب الموظف ذي المصلحة بشرط أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة وليس من الضروري أن يكون ثمة قرار إيجابي معيب صادر من الإدارة وإنما يكفي أن يكون هناك قرار حكمي على نحو ما ورد في الفقرة

الأخيرة من المادة ١٠ وهو ما سنشير إليه .

وليس من السهل دائماً التفرقة بين ما يندرج في نطاق قضاء الإلغاء ودعاوى التسوية من منازعات الموظفين، ولما كان الفارق بين الدعويين كبير وتختلف أحكام كل منهما عن الأخرى فإن القضاء في حاجة إلى وضع معيار للتمييز بين النوعين، وإلى هذا المعيار أشارت المحكمة الإدارية العليا حيث تقول: "من المسلمات أن تكيف الدعوى وبيان حقيقة وضعها إنما يخضع لرقابة القضاء.. والتمييز بين دعاوى الإلغاء وطلبات التسوية في مجال قضية من أبرز المشاكل التي يثيرها تكيف الدعاوى الإدارية وما يترتب على مثل هذا التكيف من آثار، وقد تصعب التفرقة في كثير من الأحوال بين هذين النوعين من الطلبات.. والقضاء الفرنسي تجنب هذه الصعوبات بأن سار على اعتبار الأعم الأغلب من منازعات الموظفين في روايتهم من قبيل طلبات الإلغاء وقيدها بهذا النوع من الدعاوى واعتبر أن الطعن موجه لقرار الإدارة بتحديد حالة الموظف أو استحقاقه، فإذا كان الموظف يطالب بما لم تتخذه الإدارة في مواجهته ألزمه القضاء بالتظلم إليها أولاً حتى يحصل على قرار ولو سلبي بالرفض يجيز له رفع طلب الإلغاء، أما في مصر فقد جهد القضاء الإداري منذ نشأته في إيجاد فيصل للتفرقة بين النوعين ولم ينجح في هذا الشأن منهج القضاء الفرنسي بل فصل من جهة بين جميع منازعات الموظفين في مراتبهم وجعلها من قبيل دعاوى الاستحقاق فتستطيع المحكمة بولاية قضائها الكامل أن تحدد بنفسها للموظف حقوقه التي يستمدّها من القانون كالمرتّب أو المعاش أو المكافأة مما يطلق عليه تسوية الحالة وبين طلبات الإلغاء بمعناها الحقيقي من جهة أخرى، وقد اعتمد هذا القضاء في هذه التفرقة على النظر إلى مصدر الحق الذاتي الذي يطالب به المدعى في دعواه، فإن كان يطالب بحق ذاتي مقرر له مباشرة في قاعدة تنظيمية عامة كقانون أو لائحة، فإن الدعوى تكون في هذه الحالة من دعاوى الاستحقاق (التسوية) ويكون ما أصدرته الإدارة من أوامر وتصرفات في هذه المناسبة هو مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى مجرد تطبيق القانون على حالة الموظف وتوصيل ما نص عليه القانون إليه، ولا يكون هذا التصرف الإجرائي قراراً إدارياً بالمعنى المفهوم بل يكون مجرد إجراء تنفيذي أو عمل مادي لا يسمو إلى مرتبة

القرار الإداري، ومن ثم لا يمكن أن تكون الدعاوى في هذا الشأن من دعاوى الإلغاء، وعلى عكس ذلك إذا لم يكن مركز الموظف قد نشأ عن القاعدة التنظيمية ذاتها بل استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص يخوله هذا المركز القانوني فإن الدعوى تكون من دعاوى الإلغاء.

المطلب الثالث

طعون الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية

يتعين على الإدارة وهي تمارس اختصاصاتها المختلفة أن تلتزم بأحكام القانون، فإن خالفت أحكامه كان قرارها باطلاً ويتعين الغاؤه، وذلك حماية للأفراد مما قد يلحقهم من ضرر نتيجة ما اتخذته الإدارة من قرارات مخالفة للقانون.

وقد نصت المادة العاشرة في فقرتها الخامسة على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، ومن ثم فإنه وفقاً لهذا النص فإن طعون الأفراد تشمل فئتين: الأولى: أشخاص لا يتقلدون أي وظيفة عامة وذلك باعتبار أن طعون الموظفين لها فقرات خاصة سبق الإشارة إليها.

الثانية: موظفون عموميون وذلك في حالة طعنهم باعتبارهم أفراد عاديين وليسوا موظفين.

أما طعون الهيئات فالمقصود بها الأشخاص الاعتبارية الخاصة كالشركات والنقابات العمالية والجمعيات والأشخاص الاعتبارية العامة.

ويتعين أن تكون القرارات نهائية بمعنى أن يكون صادراً من السلطة الإدارية بعد استنفاد حق التعقيب على القرار الإداري من الجهات الإدارية التي تم التعقيب عليها فضلاً عن ضرورة أن يكون القرار قد شاب عيب من عيوب القرار الإداري .

المطلب الرابع

القرارات الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي

أما بالنسبة لطلبات الإلغاء الموجهة إلى القرارات الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي (فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل) فلم يكن لهذه المادة مقابل في أول قانون لمجلس الدولة (١١٢ لسنة

(١٩٤٦)، واستحدثت لأول مرة في القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ ذلك أن دعوى الإلغاء لا توجه إلا إلى القرارات الإدارية بالمعنى الفني، وفي ظل القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ ثار جدل حول اختصاص محكمة القضاء الإداري بطلبات الإلغاء الموجهة إلى القرارات الصادرة من الهيئات الإدارية التي تمارس اختصاصات قضائية أو شبه قضائية مثل مجالس التأديب ولجان الترع والجسور.. الخ، وكان مرجع الخلاف حول طبيعة هذه القرارات هل هي أحكام قضائية فلا تتدرج في مدلول القرارات الإدارية وبالتالي لا يشملها اختصاص المحكمة بالإلغاء، أم هي قرارات إدارية فيكون العكس.

ولم تتردد محكمة القضاء الإداري كثيراً وحسمت الأمر في ظل القانون ١١٢ لسنة ١٩٤٦ آخذة بالمعيار الشكلي ومن ثم أدرجت في اختصاصها الغاء القرارات الصادرة من هذه اللجان ولو كانت تمارس اختصاصاً قضائياً باعتبار أن هذه القرارات تعد قرارات إدارية من ثم يمكن الطعن فيها بالإلغاء.

غير أن المشرع -استمراراً لما اتبعه في القوانين السابقة- فقد أخرج من اختصاص القضاء الإداري الطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل باعتبار أنه يدخل في تشكيل تلك الهيئة قضاة وأن لقراراتها قوة الأحكام النهائية ومن ثم لا يجوز الطعن فيها بالإلغاء.

ويقصد بالجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي اللجان المتنوعة التي نص عليها القانون وخولها اختصاصاً قضائياً، ومن أمثلتها لجان مخالفات قوانين الترع والجسور، لجان الجمارك، لجان التحكيم الطبي المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية، لجنة تسوية الديون العقارية، لجان الفصل في المنازعات الزراعية وغيرها.

ويختص مجلس الدولة في الفصل في الطعون التي ترفع ضد القرارات النهائية من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي، وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، ووفقاً للرأي الراجح في الفقه فإن مجلس الدولة يختص أيضاً بالطعون في هذه القرارات إذا كانت معيبة بعيب إساءة استعمال السلطة، وإن كان هذا العيب يندر

من الناحية العملية أن يتحقق في القرارات الصادرة من هيئات ذات اختصاص قضائي، وذلك لأن سلطة هذه اللجان سلطة مقيدة وليست تقديرية، وبطبيعة الحال فإن عيب إساءة استخدام السلطة لا يظهر إلا حينما تكون سلطة الإدارة تقديرية، إلا أن هذا الاعتبار لا يحول دون تصور وجود هذا العيب، حيث يوجد ولو بقدر بسيط من السلطة التقديرية لهذه اللجان، وفي حالة تحقق ذلك فإن عيب إساءة استخدام السلطة أمر متصور من الناحية الواقعية.

المطلب الخامس

المنازعات المتعلقة بالعقود الادارية

لم يكن مجلس الدولة يختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالعقود الادارية بمقتضى القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ وورد النص على هذا الاختصاص في القانون ٩ لسنة ١٩٤٩ إلا أنه كان محدوداً من ناحيتين.

الأولى: إذا كان هذا الاختصاص مشتركاً بين القضاء العادي والقضاء الاداري بحيث إذا رفع إلى أيهما فلا يجوز رفعه أمام الأخرى.

الثانية: لم يكن يتناول جميع العقود الإدارية بل اقتصر على عقود ثلاثة منها فقط هي عقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد وما عداها كان من اختصاص المحاكم العادية.

وبالنسبة لهذه العقود الثلاثة كان اختصاص القضاء الإداري مقصوراً على المنازعات التي تنشأ بين الحكومة والطرف الآخر في العقد.

وقد عدل المشرع ابتداء من القانون ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ عن ذلك فجعل هذا الاختصاص للقضاء الإداري دون غيره، كما جعله يشمل كافة منازعات جميع العقود الادارية، ويقتضي ذلك ان يقتصر اختصاص القضاء الإداري على المنازعات المتعلقة بالعقود الادارية بمعناها الفني.

وعلىنا أن نتحدث في هذا المطلب عن المسألتين الآتيتين:

أولاً: تعريف العقد الإداري.

ثانياً: مدى اختصاص مجلس الدولة في هذا الشأن.

الفرع الأول

تعريف العقد الإداري ومعياري تمييزه

يعد عقداً إدارياً كل اتفاق بين طرفين أحدهما شخصاً من أشخاص القانون العام بهدف إدارة أو تنظيم أو استغلال مرفق عام من مرافق الدولة بحيث يظهر في العقد نية تطبيق أحكام القانون العام باحتوائه على شروط غير مألوفة في نطاق العقود الخاصة، ويتحقق ذلك بتمتع الإدارة بامتيازات وسلطات لا يتمتع بها الأفراد في نطاق العقود المدنية، أو بمنح المتعاقد مع الإدارة سلطات استثنائية في مواجهة الغير لا يتمتع بها في حالة ما لو تعاقد مع غيره من الأفراد كتحويله حق نزع الملكية العامة.

وعلى ذلك ووفقاً للرأي الراجح في القضاءين الفرنسي والمصري لا يكون العقد إدارياً إلا إذا توافرت فيه ثلاث خصائص:

- ١- أن تكون الإدارة طرفاً في العقد.
 - ٢- أن يتصل العقد بمرفق عام.
 - ٣- أن تظهر فيه الإدارة المتعاقدة الأخذ بوسائل القانون العام.
- فإذا توافرت في العقد الخصائص الثلاث أصبح العقد إدارياً وأضحى القضاء الإداري هو المختص دون غيره بكافة المنازعات المتعلقة به سواء في تكوينه أو تنفيذه أو إنهائه وكل ما يتفرع عن ذلك.

الفرع الثاني

اختصاص مجلس الدولة في مجال العقود الإدارية

اختص مجلس الدولة بكافة المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، وذلك من جميع نواحيها ابتداء من المراحل الأولى لميلاد العقد حتى آخر مرحلة من مراحلها وما يتفرع منه وما يتصل به، ومن ثم فإن اختصاص مجلس الدولة في مجال العقود اختصاص مطلق وشامل لكل المنازعات التي تثار في شأن العقد الإداري، فلمجلس الدولة ولاية القضاء الكامل في هذا الشأن حيث يستطيع أن يحكم ببطالان العقد إذا ما شابه عيب يتعلق بركن من أركانه، والقاضي الإداري خول هذه السلطة من ولاية القضاء الكامل لا من دعاوى الإلغاء وذلك لكون دعوى الإلغاء لا يجوز أن

يكون محلها عقداً إدارياً، كما يجوز للقاضي أن يحكم بالتعويض لصالح الطرف الذي لحقه ضرر من جراء إبرام العقد وتنفيذه، كما أن القاضي يملك أيضاً سلطة الفسخ بناء على طلب المتعاقد.

ولا شك أن جعل الاختصاص المطلق لكافة المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية على اختلاف أنواعها للقضاء الإداري قد فتح مجالاً لإبراز معالم العقود الإدارية وخلق القواعد التي تحكمها بخلاف ترك هذه المنازعات للمحاكم القضائية العادية فقد أضفى عليها صبغة مدنية لا تتفق وطبيعتها.

واختصاص القضاء الإداري في مجال هذه المنازعات يثير بعض المشاكل التي تتعلق بطبيعة هذا الاختصاص وسنتناوله بإيجاز، والمسلم به من ناحية أخرى أن قضاء العقود الإدارية ينتمي أساساً إلى القضاء الكامل (قضاء التعويض) ولكنه يثير بعض المشاكل التي تتعلق بقضاء الإلغاء على النحو الآتي:

أولاً : القضاء الكامل في مجال العقود الإدارية:

وهذا هو القضاء الأصيل فيما يتعلق بالمنازعات التي تترتب على العقود الإدارية وقد ورد اختصاص القضاء الإداري في هذا المجال مطلقاً، ومن ثم فقد جرت محكمة القضاء الإداري على تفسير هذا النص في ظل القوانين المطبقة - تفسيراً واسعاً وتتخذ الدعوى في هذه الحالات صوراً شتى:

أ- فقد تستهدف الدعوى بطلان العقد وذلك لعب في تكوينه.

ب- وقد تستهدف الدعوى الحصول على مبالغ مالية إما في صورة ثمن أو أجر متفق عليه أو تعويض عن الأضرار أو لأي سبب من الأسباب التي ترد في مجال العقود الإدارية.

ج- وقد تستهدف الدعوى إبطال بعض التصرفات الصادرة عن الإدارة خلافاً للالتزاماتها التعاقدية.

د- وأخيراً قد تستهدف الدعوى فسخ العقد.

ثانياً: قضاء الإلغاء في مجال العقود الإدارية:

إن مجال قضاء الإلغاء في العقود الإدارية محدود باعتبار أن مجالها الطبيعي هو القضاء الكامل ويقوم هذا القضاء (قضاء الإلغاء) على مبدئين أساسيين:

الأول: أن دعوى الإلغاء لا توجه الى العقود الادارية إذ أن من شروط قبول دعوى الإلغاء أن توجه الدعوى الى قرار اداري وهو تعبير عن إرادة الادارة بمفردها، بينما العقد هو توافق إرادتين وهو ما سنوضحه بالتفصيل عند الحديث عن دعوى الإلغاء.

الثاني: أنه في مجال قضاء الإلغاء لا يمكن الاستناد الى مخالفة الادارة لالتزاماتها التعاقدية كسبب من الأسباب التي تجيز طلب الغاء العقد الاداري، فدعوى الإلغاء هي جزاء لمبدأ المشروعية والالتزامات المترتبة على العقود الادارية هي التزامات شخصية، وبالرغم من ذلك الاطلاق فقد افسح مجلس الدولة مكاناً محدوداً للاستثناء من هاتين القاعدتين في حالتين تتميزان بخصائص ذاتية هما:

١- القرارات الادارية المنفصلة عن عمليات التعاقد.

٢- طعون المستفيدين في حالة عقود الامتياز.

أولاً: القرارات الادارية المنفصلة:

لا تتميز الادارة بذات الحرية التي يتمتع بها الأفراد في إبرام عقودهم، إذ تلتزم في أغلب الأحوال بأن تتبع أسلوباً محدداً لاختيار التعاقد معها سواء كان العقد من عقود القانون الخاص أو من العقود الادارية، ويحدث أن يصدر من الادارة وهي بسبيل التعاقد قرارات إدارية تستهدف التمهيد لإبرام العقد أو السماح بإبرامه أو تحول دون إبرامه، وهذه القرارات ليست غاية في ذاتها بل تندرج في عملية التعاقد فهل تعتبر جزءاً من التعاقد وبالتالي تدخل في قضاء العقود أي القضاء الكامل؟ ثم إنه قد يصدر من الادارة قرارات إدارية أخرى يكون لها أثر على العقد بعد إبرامه وحينئذ يكون للمتعاقد أن يطعن على هذه القرارات بالإلغاء.

ونعرض فيما يلي بإيجاز لهاتين الحالتين

أ- طلب الغاء القرارات الادارية المنفصلة المقدم من غير المتعاقد:

تستهدف هذه القرارات كما سبق القول العمل على إتمام العقد أو الحيلولة دون إتمامه ويكون الطعن فيها لغير المتعاقد لأن سبيل التعاقد هو القضاء الكامل أمام قاضي العقد، أما غير المتعاقد فلا يمكن أن يلجأ إلى قاضي العقد ومن ثم فقد فتح له المجلس باب قضاء الإلغاء.

وفكرة القرار الإداري المنفصل ليست مقصورة على العقود بل هي أوسع من ذلك مدى، فيمكن أن تدخل في كل عملية مركبة سواء انتهت بالتعاقد أو بغيره مثل اجراءات نزع الملكية أو التعيين في الوظائف العامة عن طريق المسابقات العامة أو اجراءات الانتخابات. والطعن في القرار الإداري المنفصل في حالة العقود الادارية يتميز بنتيجة بالغة الأهمية هي أثر الإلغاء على وجود العقد الإداري.

فمن المسلم به أن إلغاء القرارات الادارية المنفصلة يؤدي إلى بطلان ما يترتب عليها من نتائج لأن ما يبنى على الباطل فهو باطل، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي منذ أمد بعيد وتابعه في ذلك مجلس الدولة المصري جرى على أن إلغاء القرارات المنفصلة في حالة العقود الادارية وحدها لا يؤدي بذاته إلى إلغاء العقد بل يبقى العقد سليماً وناظراً حتى يتمسك أحد أطرافه بالحكم الصادر بالإلغاء، وبناء على الأثر المطلق لحكم إلغاء أمام قاضي العقد وحينئذ يجوز لقاضي العقد أن يحكم بإلغائه استناداً إلى سببه إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة التي ساهمت في عملية التعاقد.

وقد كانت هذه النتيجة مثار نقد الفقهاء لما تنطوي عليه من تناقض بحكم أن القرار المنفصل هو مرحلة من مراحل العملية المركبة فإن كان صحيحاً صحت العملية وإن كان باطلاً بطلت العملية.

ب- طلب إلغاء القرارات الادارية المنفصلة المقدم من المتعاقد:

هذه الصورة تفترض أن عملية التعاقد قد تمت وأبرم العقد ثم يتبين المتعاقد أن بعض القرارات التي ساهمت في تكوين العقد كانت غير مشروعة، فهل له طلب إلغاء هذه القرارات الادارية المنفصلة؟

يذهب أغلب الفقهاء إلى عدم جواز ذلك باعتبار أنه لا سبيل أمام المتعاقد إلا قاضي العقد ليتولى بمقتضى سلطة القضاء الكامل الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالعقد وبالتالي فإن وجود طريق الدعوى الموازية يمنع من اللجوء إلى دعوى الإلغاء. إلا أن المتعاقد قد يسترد حقه في الالتجاء الى قضاء الإلغاء إذا ما صدرت عن الادارة قرارات غير مشروعة بصفة أخرى أي لم تستند الى صفتها كمتعاقدة، عندئذ يكون للمتعاقد - شأنه شأن المواطنين - أن يختصم هذه القرارات.

ثانياً: طعون المستفيدين في حالة عقود الامتياز:

ويرجع هذا الاستثناء الى الطبيعة اللاتحجية لبعض الشروط الواردة في عقد الامتياز التي تنظم كيفية أداء الخدمة للمنتفعين، ذلك لأن تلك الشروط لها طبيعة اللاتحجة الإدارية فإذا ما خرج الملتزم على القواعد الواردة بعقد امتيازها والتي تنظم كيفية أداء الخدمة للمنتفعين، فإن لكل ذي مصلحة أن يرده إلى نطاق المشروعية بأن يتقدم إلى الجهة الادارية المختصة طالباً منها أن تتدخل بناء على سلطتها الادارية لتجبر الملتزم على احترام شروط العقد فإذا رفضت الادارة التدخل صراحة أو ضمناً حق للمنتفع أن يطعن في هذا القرار أمام قاضى الإلغاء.

المطلب السادس

الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الادارية في منازعات الضرائب والرسوم

وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة نص على هذه الطعون لأول مرة القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ إلا أن المشرع قد عطل من اختصاص مجلس الدولة به إذ جعل ممارسته له رهيناً بصدور قانون الاجراءات الادارية ولم يصدر هذا القانون حتى صدر قانون مجلس الدولة رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ الذي أعاد النص على هذا الاختصاص وجعل ممارسته منوطة بصدور قانون ينظم ذلك.

وقد جاء القانون الأخير أيضاً رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ فنص على هذا الاختصاص وجعل ممارسته وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة، ولذلك سيظل هذا الاختصاص معطلا حتى يصدر قانون الاجراءات الادارية.

وقد عرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا بشأن اختصاص مجلس الدولة بالضرائب والرسوم فقررت "أن الأصل أن المنازعات المتعلقة بتحديد الرسوم والضرائب وعناصرها ومقوماتها والملتزمين بسدادها والقرارات الصادرة بتحديداتها إنما يتصل في اختصاص محاكم مجلس الدولة بحسبان المشرع -على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا- قد أقر بالطبيعي الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم بدءاً بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة الذى أسند بنص المادة سابعاً من

المادة ٨ منه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات وأوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الاختصاص بهذه الطعون تقرر لمجلس الدولة باعتبار أنه ذو طبيعة إدارية بحتة وقد جرى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٥ بشأن تنظيم مجلس الدولة على هذا النهج ونص في البند سابعاً من المادة ٨ منه على الحكم ذاته وأكد هذا الاختصاص نص المادة ١٠ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ الذي عقد في البند ٦ منه الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهاز الإداري في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم نظر هذه المنازعات أمام محاكم مجلس الدولة صاحب الاختصاص الولائي لنظر المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم باعتباره القاضي الطبيعي لنظر تلك المنازعات .

ومنذ صدور هذا الحكم تتولى محاكم مجلس الدولة نظر الطعون في منازعات الضرائب والرسوم.

(المحكمة الإدارية العليا الدائرة الحادية عشر طعن رقم ١١٤٣٩٨ لسنة ٦٥ ق

ع جلسة ٢٣-٥-٢٠٢١) الهامش

المطلب السابع

دعاوى الجنسية

تتخذ المنازعات الخاصة بالجنسية عدة صور:

- أ- صورة دعاوى أصلية محررة بالجنسية ترفع ابتداء مستقلة عن أي نزاع، يكون الطلب الأصلي فيها هو الاعتراف بتمتع شخص بجنسية معينة.
- ب- أو صورة طعن في قرار إداري نهائي صادر في شأن الجنسية يطلب الغاؤه لسبب من الأسباب التي نص عليها القانون.
- ج- أو في صورة مسألة أولية أثناء نظر دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل في مسألة الجنسية.
- د- أو طلب التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة والتي تصدر في موضوع الجنسية.

ولقد أصبح الاختصاص بمسائل الجنسية منذ صدور القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ لمجلس الدولة دون غيره، وقصر هذا الاختصاص على القضاء الإداري له مزايا أهمها:

١ - تعتبر رابطة الجنسية من روابط القانون العام وبالتالي تخضع للضوابط التي تحكم هذا القانون، والقضاء الإداري بحكم تخصصه وباعتراف المشرع أقدر من المحاكم العادية على تطبيق مبادئ ذلك القانون.

٢ - أن محكمة القضاء الإداري هي المختصة دون غيرها بإلغاء القرارات الإدارية ووقف تنفيذها وبالتعويض عنها، وهذا الاختصاص يستنفذ معظم قضايا الجنسية.

٣ - أن توزيع الاختصاص لقضايا الجنسية بين القضاء العادي والقضاء الإداري على النحو الذي كان سائداً قبل سنة ١٩٥٩ كان يؤدي إلى احتمال التضارب بين جهتي القضاء، وإلى اختلاف الحلول في موضوع حيوي وهو موضوع الجنسية.

المطلب الثامن

الدعاوى التأديبية المنصوص عليها

وهذه الدعاوى طبقاً لأحكام المادتين ١٥، ١٦ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ هي:

الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من:

١- العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات والشركات التي تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الأرباح.

٢ - أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٦٣.

٣ - العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديد قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً.

٤ - الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

المطلب التاسع

الطعون على الجزاءات الموقعة على العاملين

بقطاع الأعمال العام في الحدود المقررة قانونا

صدر بنظام العاملين بالقطاع العام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ وتعديلاته، وفي ١٩ يونية سنة ١٩٩١ صدر القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، ونص في المادة الثانية على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام.

ونصت المادة الرابعة والأربعون على أن تسري في شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام المواد ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٩١، ٩٢، ٩٣ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ وأحكام القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بشأن النيابة الادارية وأحكام قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨٤.

وتختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون غيرها بالنسبة للعاملين في الشركات المشار إليها في الفقرة السابعة بما يلي:

أ- توقيع جزاء الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الشركة بعد العرض على اللجنة الثلاثية.

ب- الفصل في التظلمات من القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية أو المجالس التأديبية المختصة بالشركات.

ويكون الطعن في أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بتوقيع الجزاء أو في الطعون في القرارات التأديبية أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة.

المطلب العاشر

سائر المنازعات الإدارية

وقد سبق أن أشرنا الى اتجاه المشرع المصري بنصه على اختصاص المحاكم الادارية بسائر المنازعات الادارية من حيث كونه يتجه الى جعلها صاحبة الولاية العامة على كافة المنازعات الادارية وذلك عند حديثنا عن معيار تحديد

اختصاص المحاكم الادارية في فرنسا وفي مصر. وعلينا الآن أن نتحدث عن ماهية المنازعة الإدارية باعتبار أن مجلس الدولة أصبح هو صاحب الولاية العامة على المنازعات الإدارية، كما نبين أهم المسائل التي أصبحت تدخل في نطاق اختصاص مجلس الدولة بعد أن صار صاحب الاختصاص العام على المنازعات الإدارية.

الفرع الأول

ماهية المنازعة الإدارية

توجد معايير عديدة للوقوف على ماهية المنازعة الإدارية، ومن أهم هذه المعايير الآتي:

١ - معيار التمييز بين أعمال السلطة العامة وأعمال الإدارة العادية، ووفقاً لهذا المعيار تعتبر المنازعة إدارية إذا كان محلها موضوعاً يدخل في نطاق أعمال السلطة العامة، أما إذا كانت تتعلق بأعمال الإدارة العادية التي تجردت الإدارة أثناء قيامها بها من اعتبارها سلطة فلا تعتبر منازعة إدارية.

٢ - معيار المرفق العام، وبمقتضاه تعتبر منازعة إدارية إذا تعلقت بأحد المرافق العامة في الدولة وهي التي تنشئها الإدارة وتتولى إدارتها وتنظيمها وتشرف عليها تحقيقاً للنفع العام.

٣ - معيار المنفعة العامة، وبمقتضى ذلك تكون المنازعة إدارية إذا كان نشاط الإدارة تستهدف من ورائه تحقيق المنفعة العامة أو المصلحة العامة، وهذا ما يميز المرفق عن المشروع الخاص حيث يستهدف الأخير تحقيق الربح لا النفع العام ولا المصلحة العامة.

٤ - معيار السلطة وإمتهاداتها، ووفقاً لهذا المعيار تعتبر المنازعة إدارية إذا استخدمت الإدارة وسائل القانون العام وإمتهاداته فهي أساس اختصاص القضاء الإداري

٥ - المعيار المختلط، وهذا المعيار يمزج بين فكرة المرفق العام وفكرة السلطة، ومن ثم فإن المنازعة تعتبر منازعة إدارية إذا تعلقت بمرفق عام واستخدم المرفق امتيازات السلطة العامة ووسائلها، وهذا المعيار هو المعيار الذي يرى معظم الفقه أنه المعيار السليم للوقوف على ماهية المنازعة الإدارية.

الفرع الثاني

المسائل التي أصبحت تدخل في نطاق اختصاص القضاء الإداري بعد أن صار القاضي العام في سائر المنازعات الإدارية

من أهم المسائل التي أصبحت تدخل في اختصاص القضاء الإداري بعد ورود النص باختصاص مجلس الدولة بسائر المنازعات الإدارية هي اختصاص مجلس الدولة بأعمال الإدارة المادية والمنازعات المتعلقة بالاعتداء المادي الذي يقع من جهة الإدارة وكذلك المنازعات المتعلقة بالحجز الإداري.

أولاً: المنازعات المتعلقة بأعمال الإدارة المادية: ويقصد بأعمال الإدارة المادية تلك الأعمال التي تنجرّد من صفاتها الإدارية وتصدر من الإدارة دون أن تبغى من ورائها تحقيق أثر قانوني معين، ومن أمثلتها: أعمال التعذيب، إصابة أحد المواطنين نتيجة طلق نارى أطلق من أحد رجال الشرطة، وكذلك الأفعال التي تقع من أحد الموظفين أثناء قيامه بأداء واجبات وظيفته، ويرى غالبية الشراح في مصر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة والاختصاص المطلق على المنازعات المتعلقة بأعمال الإدارة المادية، ولم يشذ عن هذا الإجماع سوى أحد الشراح الذي رأى أنه من الأولى أن يترك هذا الاختصاص للقضاء العادي باعتبار أن أحكام المسؤولية عن أعمال الإدارة المادية قد بلغ فيها القضاء العادي شأناً عظيماً وبلورها وحدد معالمها في حين أن القضاء الإداري لم يشدد عوده بعد في بلورة أحكام هذه المسؤولية، وقد اعترض أغلب الشراح على هذا الرأي لأنه يتعارض مع نص الدستور باختصاص مجلس الدولة بسائر المنازعات الإدارية.

أما فيما يتعلق باتجاه القضاء الإداري في هذا الشأن، فقد انتهت المحكمة الإدارية العليا على أن أعمال الإدارة المادية تدخل في عموم المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة شريطة أن تستخدم الإدارة بصدد هذه الأعمال المادية وسائل وامتيازات السلطة العامة.

ثانياً: المنازعات المتعلقة بالاعتداء المادي: ويتحقق ذلك حال قيام الإدارة بعمل يتضمن اعتداء على إحدى الحريات أو اعتداء على حق الملكية الخاصة بحيث لا ينطبق على تصرف الإدارة نص في قانون أو لائحة، كحالة القبض على أحد المواطنين بدون وجه حق، أو مصادرة مال دون حكم قضائي، فأعمال

الإدارة في هذا الشأن تعتبر أعمال مادية وقعت على جسم شخص أو ماله، وقد كان اختصاص القضاء على هذه المنازعات اختصاصاً مشتركاً بين القضائيين العادي والإداري، إلا أنه بعد صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ فقد أصبح هذا الاختصاص لمجلس الدولة دون غيره باعتباره القاضي العام للمنازعات الإدارية.

ثالثاً : منازعات الحجز الإداري:

وفيما يتعلق بهذه المنازعات فقد استقر قضاء النقض على اختصاص المحاكم العادية بهذه المنازعات، إذ أن توقيع الحجز الإداري لا يعد قراراً إدارياً يمكن الطعن فيه بالإلغاء، وقد أيدت المحكمة الإدارية العليا ما انتهى إليه قرار النقض إلا أنه بعد صدور القرار رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أصبح مجلس الدولة هو القاضي العام في سائر المنازعات الإدارية مما يؤدي بنا مع غيرنا إلى القول بأن هذه المنازعات تدخل في اختصاص مجلس الدولة.

المبحث الثالث

توزيع الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة

وازن المشرع في القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بين وجوب تقرير اختصاص مجلس الدولة بكافة المنازعات الإدارية والدعوى التأديبية إعمالاً لنص المادة ١٧٢ من الدستور وبين الحاجة إلى تفصيل عناصر هذا الاختصاص وتحديد حالاته تحديداً منضبطاً، فاختار في هذا الصدد سبيلاً وسطاً حرص فيه على ذكر أبرز التطبيقات التي تدخل في مفهوم النزاعات الإدارية ثم نص أيضاً على اختصاص المجلس بنظر سائر المنازعات الإدارية الأخرى على النحو السابق تفصيله وهو ما يجعلنا نعتقد معه بأن اختصاص المحاكم الإدارية في مصر أصبح على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر.

وفي توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية أبقى القانون على اعتبار محكمة القضاء الإداري هي المحكمة ذات الاختصاص العام، مع تعديل في بعض اختصاصاتها عهد به إلى المحاكم الإدارية تخفيفاً على محكمة القضاء الإداري وسنوجز فيما يلي اختصاص كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري، المحاكم الإدارية، المحاكم التأديبية.

أولاً المحكمة الإدارية العليا:

استحدث المشرع هذه المحكمة في القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ لأول مرة واحتفظ بها القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ ثم القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ومهمة هذه المحكمة طبقاً لما استقرت عليه أحكامها: "التعقيب النهائي على الأحكام.. حتى تكون كلمتها هي القول الفصل في تأصيل أحكام القانون الإداري تأصيلاً يربط بين شتاتها ربطاً محكماً وتنسيق مبادئه ومنع التناقض في الأحكام".. وتختص هذه المحكمة بالطعون في أحكام محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية في الأحوال المبينة في القانون والتي سبق بيانها.

ثانياً محكمة القضاء الإداري: حددت المادة ١٤ اختصاصات المحاكم الإدارية

على النحو الآتي:

١- الفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة ١٠ متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث وما يعادلهم، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات وقد سبق بيان هذين البندين، وموظفي المستويين الثاني والثالث طبقاً لأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بشأن نظام العاملين المدنيين.

٢- الفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.

٣- الفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة ١٠ (منازعات العقود الإدارية) متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه.

ثالثاً المحاكم التأديبية: إعمالاً لنص المادة ١٧٢ من الدستور أورد المشرع المحاكم التأديبية كجزء من القسم القضائي بمجلس الدولة ونظم انشاء وترتيب وتشكيل هذه المحاكم والاجراءات التي تتبع أمامها.

وتختص هذه المحاكم بالفصل في الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية كما تختص بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعاً وثالثاً عشر من المادة ١٠ والسابق بيانها وتنقسم هذه المحاكم إلى نوعين:

أ- محكمة تأديبية من مستوى الإدارة العليا (١٢٠٠-١٨٠٠) جنيهاً سنوياً وهم موظفو الفئة الأولى والعالية والممتازة.

ب- محاكم تأديبية للمستوى الأول، والمستوى الثاني، والمستوى الثالث.
وقد جعل القانون تشكيل هذه المحاكم جميعاً من قضاة من مجلس الدولة مستبعداً تماماً العنصر الإداري تنفيذاً لأحكام الدستور.
وقد عهد القانون إلى رؤساء المحاكم التأديبية الفصل في طلبات الوقف عن العمل أو من الوقف أو صرف المرتب كله أو بعضه تخفيفاً على المحكمة بهدف الحفاظ على الانجاز المطلوب للقضايا.

وبالنسبة للدعوى التأديبية التي تتطوي على جرائم جنائية فقد وازن المشرع عدم ضياع معالم الجريمة إذا طال اتصال النيابة العامة بوقائعها وبين تأخير الفصل في الدعوى التأديبية فنص على أن تحيل الواقعة إلى النيابة العامة على أن تفصل المحكمة في الدعوى التأديبية بغير توقف على تصرف النيابة العامة في الجريمة الجنائية وذلك ما لم يكن الحكم في الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجنائية فيجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.

كما اشترط القانون لمحاكمة من انتهت خدمته عن المخالفات التي تم محاكمته بمقتضاها أن تكون وقعت منه أثناء الخدمة أو أن يكون قد بدء في التحقيق أو المحاكمة قبل ذلك عدا المخالفات المالية التي يترتب عليها ضرر مالي فإنه يجوز محاكمة العامل عنها ولو لم يكن قد بدء في التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء خدمته وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة.

المبحث الرابع

عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة

بما تختص به جهات قضائية أخرى

صدر دستور ١١ سبتمبر ١٩٧١ ونص في المادة ١٧٢ منه على أن: "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى." وقد اتجه دستور ٢٠١٤ إلى نفس الاتجاه حيث أكدت المادة ١٩٠ منه أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص

دون غيره بالفصل في سائر المنازعات الإدارية .

فإن هذا النص كان توجيهاً للمشرع بأن مجلس الدولة أصبح صاحب الاختصاص العام في المنازعات الادارية والدعاوى التأديبية والإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه كما يختص بالفصل في الدعاوى التي يحددها القانون ، ومراجعة وصياغة القوانين والقرارات ذات الصلة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وتنفيذاً للدستور صدر قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ونص في المادة العاشرة منه على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:

أولاً:

ثاني:

رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.

وتدل الفقرة ١٤ على أن اختصاص مجلس الدولة لم يرد على سبيل الحصر بل أصبح اختصاصه يمتد ليشمل جميع المنازعات الإدارية وأصبحت محاكم لها الولاية العامة في المنازعات الادارية.

وكان قد سبق أن قررت المحكمة العليا (في حكمها المشار اليه) أن محاكم مجلس الدولة أصبحت صاحبة الولاية العامة على كافة المنازعات الادارية والدعاوى التأديبية، وبعد أن قررت أن مجلس الدولة أصبح قاضي القانون العام بالنسبة إلى كافة هذه الدعاوى والمنازعات، ولم يعد اختصاصه مقيداً بمسائل محددة على سبيل الحصر كما كان منذ إنشائه، قالت: "هذا لا يعني غل يد المشرع عن إسناد الفصل في بعض المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية إلى جهات قضائية أخرى على أن يكون ذلك على سبيل الاستثناء من الأصل العام المقرر بالمادة ١٧٢ من الدستور وبالقدر وفي الحدود التي يقتضيها الصالح العام وهذا ما يتفق مع المادة ١٩٠ من دستور ٢٠١٤ المشار إليه سابقاً .

وهكذا لا تختص محاكم مجلس الدولة بشئون رجال القضاء (١)، والنيابة (٢)، وأعضاء هيئة قضايا الدولة (٣)، والمحامين (٤)، ورجال القوات المسلحة (٥). كما لا يختص القضاء الإداري كذلك بالنظر في الأعمال التشريعية، أو الأعمال القضائية (٦)، أو أعمال النيابة العامة (٧)، أو أعمال رجال الضبطية القضائية التي يؤدونها لحساب النيابة العامة (٨). كذلك لا تختص محاكم مجلس الدولة المصري بالطعن في قرارات النيابة الادارية (٩)،

١ - حكم المحكمة الادارية العليا بتاريخ ١٩٧٦/٦/٢٦ (المجموعة س ٢١، ص ٢٣١).
٢ - حكم محكمة القضاء الاداري بتاريخ ١٩٦٨/٥/٣٠ (المجموعة س ٢٢، ص ٣٣٣).
٣ - حكم المحكمة الادارية العليا بتاريخ ١٩٦٨/٤/٧ (المجموعة س ١٣، ص ٧٧٦).
٤ - حكم المحكمة الادارية العليا بتاريخ ١٩٥٨/٢/١٥ (المجموعة س ٣، ص ٧٥٢).
٥ - حكم المحكمة الادارية العليا بتاريخ ١٩٧٩/١/١٤ في القضية رقم ٤٤٥ لسنة ٢١ ق.
٦ - حكم المحكمة الادارية العليا بتاريخ ١٩٦٠/٤/٢٦ (المجموعة م ٤، ص ٨٢٤).
٧ - حكم محكمة القضاء الاداري بتاريخ ١٩٦٣/٥/١٢ (المجموعة س ١٧، ص ٢٠٠).
٨ - حكم محكمة القضاء الاداري بتاريخ ١٩٦٤/١٢/٢٩ (المجموعة س ١٩، ص ٤٥٢).
٩ - حكم محكمة القضاء الاداري بتاريخ ١٩٦٣/٤/١٧ (المجموعة س ١٧، ص ١٨٧).

الفصل السادس

تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء

وبين محاكم مجلس الدولة المصري

الاختصاص يعني قدرة جهة القضاء أو المحاكم على الفصل في نزاع معين، وعدم الاختصاص انتفاء ولاية جهة القضاء أو المحاكم عن نظر نزاع معين^(١)، وسوف نقسم هذا الفصل الى مبحثين: الأول نتناول فيه تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والاداري- وفي الثاني تنازع الاختصاص بين المحاكم الإدارية- .

المبحث الأول

تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري

إن أخذ الدولة بنظام القضاء المزدوج من شأنه أن يؤدي في التطبيق العملي إلى منازعات بين جهتي القضاء بسبب الاختصاص إذ قد تدعى كل جهة الاختصاص لنفسها في مسألة معينة وحينئذ نكون أمام قاضيين مختلفين كل منهما يدخل النزاع في ولايته، وهذا وضع غير سليم إذ لا يصح أن يختص بالنزاع الواحد إلا جهة قضائية واحدة، وثبوت الاختصاص لها يمنع اختصاص غيرها. والصورة الأولى للتنازع هنا تعرف بالتنازع الإيجابي على الاختصاص إذ تحاول كل جهة نظر النزاع على أساس أنها المختصة بالفصل فيه.

الصورة الثانية التنازع السلبي :

ويتحد في أن التنازع على الاختصاص صورة عكسية حينما تتخلى كل من جهتي القضاء عن نظر نزاع معين بحجة أنها غير مختصة به، ففي هذه الحالة نكون أمام إنكار للعدالة إذ لا يوجد للنزاع قاض يفصل فيه، وهذا الموقف السلبي من جهتي القضاء يسفر عنه وضع يسمى بالتنازع السلبي في الاختصاص.

وعلة تنازع الاختصاص بنوعيه الايجابي والسلبي ترجع إلى ازدواج القضاء وإلى معايير تحديد الاختصاص بين جهتيه، فهذه المعايير مهما بلغت من الدقة

^١ - الدكتور/ فؤاد العطار، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص ٣٥٤.

والوضوح فإنها لا تستطيع منع النزاع حول الاختصاص في التطبيق العملي نتيجة اختلاف وجهات النظر في التفسير واستنباط الحلول.

ولا يقف الأمر عند حد التنازع على الاختصاص بين القضائين (العادي والاداري) وإنما قد تصدر عنهما أحكام متعارضة ولا بد من العمل على إزالة هذا التعارض حتى يستطيع الفرد الوصول إلى حقه، ومن هنا تظهر الصورة الثالثة للتنازع وهي حالة تعارض الأحكام.

وعلى ذلك فمن الضروري إيجاد وسيلة لحل هذه المشاكل التي تثور في العمل ويقع على المشرع أساساً عبء تقرير الحل المناسب لهذه المسألة المتشعبة المتعلقة بالتنازع على الاختصاص وتعارض الأحكام.

ولما كانت هذه المسألة تثير نزاعاً قانونياً بين جهتي القضاء، فإن الوضع الطبيعي يقضي بأن يوكل أمر حل هذا النزاع إلى هيئة قضائية تكون حكماً بين الجهتين المتنازعتين على الاختصاص أو المتعارضتين أحياناً في أحكامهما.

وقد أخذ المشرع الفرنسي بهذا الحل إذ قرر إنشاء محكمة عليا فوق جهتي القضاء تسمى بمحكمة التنازع، وعهد إليها بمهمة الفصل في حالات تنازع الاختصاص وتعارض الأحكام.^(١)

وفي مصر إذا قضت جهتا القضاء العادي والإداري باختصاصهما المطلق بنزاع معين كنا أمام صورة التنازع الإيجابي، وإذا قضت كل منهما بعدم اختصاصهما، كنا أمام التنازع السلبي، وفي الحالتين يتعرض المواطن لحالة إنكار العدالة إذا لم تكن ثمة وسيلة لتحديد الجهة المختصة^(٢). وعلينا بعد هذه المقدمة أن نتناول في مبحث محكمة التنازع ومبحث آخر صوره.

^١ - انشئت محكمة التنازع في فرنسا وفقاً للقانون الصادر في ٢٤ مايو ١٨٧٢ ولم تكن المحكمة تختص إلا بنوعين من التنازع هما: التنازع الإيجابي والتنازع السلبي. وقد ظل هذا الوضع قائماً إلى أن صدر قانون بتاريخ ٢٠ أبريل سنة ١٩٣٢ فاستحدث نوعاً ثالثاً من التنازع هو التنازع نتيجة تناقض الأحكام، وتقتصر وظيفة المحكمة في صورتها الشارعية الإيجابية والسلمية على تعيين الجهة القضائية المختصة، بينما في حالة تعارض الأحكام، تتصدى المحكمة لموضوع الدعوى للفصل فيها. وفي ٢٥ يوليو سنة ١٩٦٠ صدر مرسوم استحدث نظاماً بمقتضاه تتولى المحاكم ذاتها إحالة الأمر إلى محكمة تنازع الاختصاص.

^٢ - أستاذنا الدكتور سليمان الطماوي، قضاء إلغاء، المرجع السابق، ص ١٩٧.

المبحث الأول محكمة تنازع الاختصاص

كان من الضروري في حالة تعدد جهات القضاء أن توجد جهة قضائية تتولى فض المنازعات التي تثار بين هذه الجهات بشأن الاختصاص، وقد نظم المشرع الفرنسي هذا الموضوع بأن أسند الى هيئة محايدة حل مشاكل التنازع حتى لا يكون في تشكيلها ما يجعل الكفة تميل الى أي من الجهتين -جهة القضاء العادي وجهة القضاء الإداري- فأنشأ محكمة خاصة هي محكمة التنازع تشكل من ٩ أعضاء التنازع تشكل من ٩ أعضاء منهم أربعة يمثلون القضاء العادي وأربعة يمثلون القضاء الإداري ويرأسها وزير العدل.

أما في مصر فقد أسند في البداية لمحكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية حسم مشاكل التنازع بين القضاء العادي والقضاء الإداري، وهو وضع معيب، حيث يرجح جهة القضاء العادي على حساب مجلس الدولة وذلك بحكم كون محكمة النقض هي أعلى محكمة للقضاء العادي، وبحكم تكوين أعضائها كانوا يغلبون القضاء المدني والحلول المدنية على القانون الإداري، وقد ظل هذا الوضع قائماً حتى سنة ١٩٥٩ حيث صدر القانون رقم ٥٦ المنظم للسلطة القضائية وعدد من الوضع السابق حيث جعل حل مسائل التنازع موكولاً إلى محكمة خاصة سماها محكمة تنازع الاختصاص وجعلها برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعضوية ثلاثة مستشارين من مستشاري محكمة النقض تختارهم جمعيتها العمومية سنوياً وثلاثة من مستشاري المحكمة الإدارية العليا يختارهم المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة سنوياً، وهذا التشكيل بلا شك أخف وطأة مما كان سائداً قبل عام ١٩٥٩، وإن أخذ عليه أنه رجح كفة القضاء العادي حيث جعل رئاسة محكمة التنازع لرئيس محكمة النقض أو أحد نوابه مما يؤدي الى عدم مراعاة الحيادة التامة في تشكيل المحكمة، حيث يرجح هذا التشكيل كفة القضاء العادي على القضاء الإداري.

وأخيراً تحقق ما يرنوا اليه الفقهاء من وجود هيئة قضائية محايدة تتولى حسم مشاكل التنازع بين جهتي القضاء العادي والإداري حيث أسند هذا الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا وفقاً لما نص عليه القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإنشاء

المحكمة الدستورية العليا.

ولهذا نصت المادة ٣١ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بشأن المحكمة الدستورية العليا على أن: "لكل ذي شأن أن يطلب الى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في حالة التنازع الإيجابي والتنازع السلبي.^(١) ويجب على رافع الدعوى في الحالتين أن يبين في الطلب موضوع النزاع، وجهة القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منهما في شأنه، ويترتب على تقديم الطلب، وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه."

وتختص المحكمة الدستورية العليا طبقاً للمادة ٢/٢٥ بحل التنازع بين جهتي القضاء بتعيين جهة القضاء المختصة إذا ما رفعت الدعوى عن موضوع أمام جهتين معاً ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها وتختص المحكمة الدستورية العليا وفقاً للمادة ٣/٢٥ بالفصل في النزاع في حالة صدور حكمين متضاربين نهائيين صدر أحدهما من جهة قضائية أخرى. وهنا يحق لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكمين النهائيين المتناقضين^(٢).

هذا ولقد حرص المشرع الفرنسي عند إنشائه لمحكمة التنازع والمشرع المصري عند إنشائه للمحكمة الدستورية العليا على كفاءة حيدتها حتى تستطيع أداء مهمتها دون محاباة جهة على حساب الأخرى لهذا نص المشرع في المادة الأولى من القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ على أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها."

المبحث الثاني

صور التنازع

وفي ضوء نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا وتطبيقاتها العملية في أحكام المحاكم سنقسم دراستنا لتنازع الاختصاص بين جهتي القضاء الإداري والعادي إلى المطالب الآتية:

^١ - نشر القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ في الجريدة الرسمية في العدد ٣٦ الصادر في ٦ سبتمبر ١٩٧٩، ونصت المادة العاشرة من قانون إصداره على أن يعمل به بعد أسبوعين من تاريخ نشره، فكان قانون المحكمة الدستورية العليا أصبح معمولاً به منذ ١٩٧٩/٩/٢١.

^٢ - أستاذنا العميد الدكتور/ سليمان الطماوى، قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص ١٩٨.

المطلب الأول: التنازع الإيجابي. **المطلب الثاني:** التنازع السلبي.
المطلب الثالث: تناقض الأحكام. **المطلب الرابع:** الاحالة وفقا للمادة ١١٠ من قانون المرافعات.

وسوف نوالي الحديث عن كل مطلب على حدة:

المطلب الأول

التنازع الإيجابي على الاختصاص

تبدو صورة التنازع الإيجابي في حالة وجود دعوى مرفوعة أمام إحدى جهتي القضاء، ويدفع أمام هذه الجهة بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى لاختصاص الجهة القضائية الأخرى بها ، إلا أن كل محكمة من هذه المحاكم تتمسك بولايتها على النزاع وتتمسك بولايتها على الدعوى وبذلك يهدف التنازع الإيجابي إلى حماية قواعد الاختصاص بين جهتي القضاء الإداري والعادي، وهو أمر يتعلق بالنظام العام.^(١) وهذا النوع من التنازع يعد إيجابياً لتمسك كل جهة من الجهات بولايتها على المنازعة .

غير أننا إذا استعرضنا تنظيم إجراءات التنازع على صورة واحدة، هي حالة رفع الدعوى أمام المحاكم العادية، كما جعل الدفع بعدم الاختصاص في هذه الحالة قاصراً على الإدارة وحدها دون الأفراد وهذا المظهر الشاذ في النظام الفرنسي يبرره أسباب تاريخية تتحصل في أن مجلس الدولة الفرنسي حين أنشئ بداية الأمر إنما قصد به حماية الإدارة لا حماية قواعد الاختصاص بصفة مجردة.

وفي مصر يكون التنازع الإيجابي إذا قضت جهتا القضاء العادي والإداري باختصاصهما المطلق وتدعى كل منهما أنها صاحبة الاختصاص بمفردها، ففي هذه الحالة يحق لكل ذي مصلحة رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا طبقاً للمادة ٣١ من قانونها رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ لكي تعين له جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى. وقد نظم حل هذا التنازع بعد صدور القانون ٨١ لسنة ١٩٦١ بشأن إنشاء المحكمة العليا حيث خولت بفض التنازع الإيجابي بين جهتي القضاء ثم أسند هذا

^١ - للمؤلف النظرية العامة للسلطات - دراسة تحليلية لسلطات مصر - الكتاب الثاني طبعة ٢٠١٨ ص ١٣٢ وما بعدها. د فؤاد العطار المرجع السابق ص ٢١١ وما بعدها.

الإختصاص إلى المحكمة الدستورية العليا إعمالاً للمادة ١٧٤ من دستور ١٩٧١ حيث حددت المادة ١٧٥ منه اختصاصاتها وقد نظمت المادتان ٢٥، ٢٦ من قانون المحكمة إختصاصاتها ومنها حل التنازع .

هذا ويشترط لقيام حالة التنازع الإيجابي: (١)

أولاً: أن تكون هناك دعوى قائمة فعلاً أمام المحاكم القضائية لجهتي القضاء العادي والإداري وتتمسك كل منهما باختصاصها بالتصدي لموضوع الدعوى، وعلى ذلك لا يعتبر تنازعا مجرد التهديد برفع الدعوى أمام جهة القضاء الأخرى.

ثانياً: وحدة موضوع الدعوى المرفوعة أمام جهتي القضاء بغض النظر عن وحدة الخصوم في الدعويين.

ثالثاً: يشترط أن لا يكون قد صدر حكم نهائي في موضوع الدعوى ومن ثم لا نكون بصدد تنازع إيجابي في حالة صدور حكم من المحكمة العادية طعن فيه بالنقض، لكن إذا قبل الطعن وأعيدت القضية أمام دائرة أخرى، جاز للإدارة في هذه الحالة أن تدفع بعدم الاختصاص (٢).

رابعاً: يجب أن تكون المحكمة العادية قد تمسكت باختصاصها بنظر الموضوع رغم تقديم طلب الدفع بعدم الاختصاص.

هذا ويترتب على تقديم طلب التنازع الى المحكمة الدستورية العليا وقف الدعاوى القائمة المتعلقة بهذا التنازع الى حين أن تصدر المحكمة حكماً بتعيين الجهة القضائية المختصة. (٣)

المطلب الثاني

التنازع السلبي

يثور التنازع السلبي عندما يطرح نزاع أمام جهتي القضاء الإداري والعادي على التعاقب فتتخذ الجهتان منه موقفاً سلبياً بمعنى أن تحكم كل جهة بعدم اختصاصها بنظر النزاع والفصل فيه.

١ - الدكتور/ فؤاد العطار، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص ٢٠٨.

٢ - أستاذنا الدكتور/ سليمان الطماوى، قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص ٦٧.

٣ - الدكتور/ فؤاد محمد النادي، المبادئ العامة للإجراءات القضائية والاختصاص القضائي لمحكمة مجلس الدولة المصري، ص ١٣٤.

فالشخص هنا يواجه إنكاراً للعدالة لأنه لا يجد جهة قضائية تفصل له في دعواه وتقضى له بحقه الذي يدعيه. ولا شك في أن موقف القضاء فيه مخالفة أكيدة لقواعد الاختصاص إذ لا يعقل أن تكون الجهتان غير مختصة وإنما لابد أن تكون إحداها مختصة بنظر النزاع.

ولتفادي هذا الوضع نظم المشرع إجراءات التنازع السلبي ليصل الى احترام قواعد الاختصاص، وبالتالي حماية الحقوق الفردية عن طريق تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى بعد الموقف السلبي لرفع النزاع الى المحكمة الدستورية العليا في مصر طبقاً للمادة ٣١ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ لتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى لتحديد جهة القضاء المختصة، إزاء هذا الوضع بملاساته المذكورة تقرر الحق.

ويجب على رافع الدعوى أن يبين في الطلب موضوع النزاع، وجهات القضاء التي نظرت، وما اتخذته كل منها في شأنه، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، وتحدد وظيفة المحكمة الدستورية العليا في حالة التنازع السلبي بالقضاء ببطلان الحكم الذي صدر خطأ بعدم اختصاص إحدى الجهتين القضائيتين. ومؤدى ذلك أن تعود الدعوى إلى هذه الجهة القضائية باعتبارها المختصة بنظر الدعوى (١).

ويجب لقيام صورة التنازع السلبي أن تتوافر الشروط الآتية:

١- شرط وحدة الموضوع، أي أن يكون النزاع المثار أمام جهتي القضاء بين ذات الخصوم بذات الصفة واستناداً إلى عين السبب وأن تكون الطلبات المطروحة على الجهتين واحدة.

٢- يقتصر الحكم الصادر من جهتي القضاء على نفى الاختصاص وعلى ذلك اذا امتنع كل من القضاء العادي والاداري عن الحكم في مسألة تتعلق بأعمال السيادة مثلاً فلا يعتبر ذلك من قبيل التنازع السلبي (٢).

^١ - الدكتور/ فؤاد العطار، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص ٢١٤،
^٢ - استاذنا الدكتور/ سليمان الطماوى، قضاء الألقاء، المرجع السابق، ص ١٩٨.

وعلى ذلك إذا رفضت الدعوى لسبب آخر غير سبب الدفع بعدم الاختصاص، فلا يترتب على هذا الرفض إيجاد حالة تنازع سلبي، كذلك إذا حكمت إحدى جهتي القضاء باختصاص الجهة الأخرى (مع الاحالة طبقاً للمادة ١١٠ من قانون المرافعات كما سنوضحه في المطلب الرابع وكذلك إذا قضت جهة بجزء من طلبات المدعى فليس له أن يرفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا لأن هذه الحالة لا تعتبر من قبيل التنازع السلبي، إذ أن المحكمة قضت في موضوع الدعوى.

المطلب الثالث

التنازع نتيجة تعارض الأحكام

يثار تعارض الأحكام إذا كنا بصدد تعارض تنفيذ حكمين نهائيين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى.

والتنازع نتيجة تعارض الأحكام اتفقت شروطه في كل من مصر وفرنسا، ففي فرنسا نصت عليه المادة الأولى من القانون الصادر في إبريل سنة ١٩٣٢ بقولها: "الأحكام النهائية الصادرة من القضاة الإداريين والعاديين في موضوع واحد يجوز عرضها على محكمة تنازع الاختصاص إذا اشتملت على تناقض من شأنه أن يؤدي إلى حالة الامتناع عن الحكم."

وفي مصر تقضى الفقرة الثالثة من المادة ٢٥ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بشأن المحكمة الدستورية العليا بأنه يحق للشخص أن يطلب من المحكمة الدستورية الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكمين النهائيين المتناقضين.

وواضح مما سبق: أنه يوجد اتفاق بين القانون الفرنسي والمصري في

اشتراط خمسة شروط هي:

أولاً: أن يكون الحكمان صادران من القضاة الإداريين والعاديين.

ثانياً: أن يكون الحكمان نهائيان.

ثالثاً: أن يكون الحكمان صادران في موضوع واحد.

رابعاً: أن يكون الحكمان متناقضان.

خامساً: أن يكون التناقض مؤدياً إلى حالة الامتناع عن تنفيذ الحكم.

وتشترط المادة ٣٧ من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ١٩١٩ أنه يجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين، ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع.

المطلب الرابع

إحالة الدعوى طبقاً للمادة ١١٠ من قانون المرافعات المدنية

استحدث قانون المرافعات المدنية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ المادة ١١٠ التي تقضى بأنه على المحكمة عندما تحكم بعدم اختصاصها أن تحدد المحكمة المختصة بالدعوى، وتحيل الدعوى إليها، وتلتزم هذه المحكمة الأخيرة باختصاصها الذي حددته المحكمة الأولى، ويقوم هذا الالتزام ولو كان تحديد الاختصاص قد بنى على قاعدة قانونية غير سليمة.^(١)

ويستوي في هذا أن يكون عدم اختصاص المحكمة بالدعوى التي رفعت إليها متعلقاً بالنظام العام أو غير متعلق به، وينطبق النص ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية، فتحكم المحكمة بإحالة الدعوى إلى الجهة الأخرى المختصة بها، وهكذا تضمن قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ قاعدة مخالفة تماماً للقاعدة الأصولية التي تقضى بأن لا تحدد محكمة اختصاص محكمة أخرى.

ويعود النظام الذي يأخذ به المشرع المصري في قانون المرافعات إلى حرصه على ألا يتحمل المدعى بعد الحكم بعدم الاختصاص أو انتفاء الولاية مشقة إعادة رفع الدعوى من جديد أمام المحكمة المختصة بها أو الجهة ذات الولاية به، ومشقة إعادة الإجراءات التي تمت في الخصومة من جديد وقد تكون مسألة الولاية أو الاختصاص من الصعوبة بحيث يكون المدعى معذوراً في خطئه بشأنها^(٢).

هذا وينطبق نص المادة ١١٠ على الإحالة من جهة المحاكمة العادية إلى جهة القضاء الإداري.

^١ - مجموعة أحكام محكمة النقض بتاريخ ١٩٧٧/١١/٢٩ في الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٤٤٤ ق.
^٢ - أستاذنا الدكتور فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية ١٩٨٠، ص ٣٣٣

وفي هذا الصدد يرى أستاذنا الدكتور/ فتحي والى أن على جهة المحاكم أن تقتصر على الإحالة الى جهة القضاء الإداري دون أن تحدد المحكمة المختصة التي تختص بالدعوى داخل هذه الجهة، فإن هي تجاوزت تحديد الجهة الى تحديد المحكمة فإنها تكون قد تجاوزت سلطاتها المخولة لها وفقا للمادة ١١٠، ومن ناحية أخرى فإن جهة القضاء الاداري تلتزم بولايتها بالدعوى المحالة إليها^(١).

حقيقة أن المادة ١١٠ غير موجهة إلى جهة القضاء الإداري إلا أن القول بعدم التزامها يعني عدم إعمال ما أراده المشرع من حجية لحكم الإحالة ومن جهة المحاكم "ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية"، على أن جهة القضاء الإداري لا تلتزم إلا بهذه المسألة، فإذا حددت جهة فلا تلتزم هذه الجهة، إذ ما تبين لهذه الجهة أن هذه المسألة لا تدخل في ولاية جهة المحاكم المحال إليها الدعوى.

غير أن هناك اتجاه كان يتردد في أحكام المحاكم الادارية يتجه الى عدم التزام جهة القضاء الإداري بالحكم بالإحالة الذي يصدر من جهة المحاكم العادية^(٢)، ولقد توج هذا الاتجاه بحكم المحكمة الادارية العليا في الطعون ارقام ١٨٤٥ لسنة ٢٧ق و ١٦ لسنة ٢٩ق و ٧١١، ٧١٧، ٢٨٢٧، ٢٣٧١ لسنة ٣٠ قضائية عليا المحالة من المحكمة الادارية العليا "دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات والعقود الادارية" الى الهيئة المشكلة وفقاً لحكم المادة ٥٤ مكرر من قانون مجلس الدولة المعدل بالقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨٤ للنظر في مدى تطبيق حكم المادة ١١٠ من قانون المرافعات المدنية وحدود هذا التطبيق، فقضت المحكمة الادارية العليا بتاريخ ١٨ شعبان سنة ١٤٠٦ الموافق ٢٧ من إبريل سنة ١٩٨٦ "بعدم التزام محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقاً للمادة ١١٠ من قانون المرافعات إذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانوناً لمحاكم مجلس الدولة، أما في الدعاوى المرفوعة ابتداء أمامها فلها أن تحيلها الى المحكمة المختصة إذا تبين لها عدم اختصاصها بنظرها، وأمرت بإحالة كل من الطعون الى الدائرة المختصة به لتفصل فيه في ضوء ذلك.

^١ - استاذنا الدكتور فتحي والى الوسيط في قانون القضاء المدني المرجع السابق، ص ٣٣٤.
^٢ - انظر: تقرير مفوض الدولة لدائرة العقود والتعويضات بمجلس الدولة في الدعوى رقم ٦٥ لسنة ٢٥ قضائية.

ولقد جاء في أسباب هذا الحكم:

أن المادة ١٧٢ من الدستور تنص على أن: "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الادارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى"، وتنص المادة ١٦٧ من الدستور على أن: "يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها".

وتطبيقاً لهذين النصين الدستوريين حددت المادة ١٠ من قانون مجلس الدولة في بنودها المسائل التي تختص بها محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فيها وختمتها بالبند: "رابع عشر: على اختصاص هذه المحاكم بسائر المنازعات الإدارية." ومن ثم لا يجوز الخروج عن الاختصاص الذي حدده الدستور ثم القانون الا بذات الأداة من نص دستوري أو قانون، ولا يجوز أن يتمخض تطبيق أي نص من نصوص أي قانون بمعرفة جهة ليس لها سلطة التشريع الدستوري أو إصدار القانون إلى الخروج عن تحديد الدستور أو القانون لاختصاص المجلس سواء بالإضافة أو بالانتقاص على أي وجه من الوجوه، فلا يجوز إلزام محاكم مجلس الدولة بالنظر في دعاوى ومنازعات تخرج بطبيعتها عن حدود الأصل الدستوري المحدد لاختصاص مجلس الدولة، ولا تتدرج في عداد المسائل التي تختص بها قانوناً المحاكم التابعة له، استناداً إلى ظاهر نص المادة ١١٠ من قانون المرافعات لمجرد إحالتها إليها من محكمة تابعة لجهة قضائية أخرى مما يؤدي الى خروج سافر على ما حدده الدستور في شأن اختصاص مجلس الدولة، وكذلك على القواعد التي حددها القانون في توزيع الاختصاص بين جهات القضاء والتي تقوم على تطبيق القانون الخاص في المنازعات المدنية والتجارية والأحوال الشخصية التي يحكم اجراءاتها قانون المرافعات، وعلى تطبيق القانون الجنائي في المسائل الجنائية التي يحكم اجراءاتها قانون الاجراءات الجنائية، وبين المنازعات الادارية والدعاوى التأديبية التي يحكمها بصفة أصلية قانون مجلس الدولة. كما يؤدي ذلك إلى أن يكون اختصاص كل جهة متروكاً لقضاء الجهة الأخرى - حسبما تراه في تكييف الدعوى المطروحة أمامها حتى ولو ترتب على ذلك مخالفة لما حدده الدستور والقانون من اختصاص لمحاكم مجلس الدولة- لذلك حكمت المحكمة

الادارية العليا بعدم التزام محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقاً لنص المادة ١١٠ من قانون المرافعات المدنية إذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانوناً لمحاكم مجلس الدولة." وقد يتفق مع المادة ١٩٠ من دستور ٢٠١٤ التي تقضى بأن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه كما يختص بالفصل في الدعاوى التي يحددها القانون ، ومراجعة وصياغة القوانين والقرارات ذات الصلة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى

وهكذا: يمكننا القول (١) بأنه في حالة الاحالة وفقاً للمادة ١١٠ من قانون المرافعات من جهة القضاء العادي الى جهة القضاء الاداري فإن محاكم مجلس الدولة إذا تبين لها أن النزاع يخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانوناً لمحاكم مجلس الدولة فإنها تحكم من جديد بعدم اختصاصها.

المبحث الثالث

تنازع الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة

حينما تأخذ الدولة بنظام القضاء الإداري فإنها تسلك أحد سبيلين لتحديد اختصاص محاكم مجلس الدولة:

الطريقة الأولى: تحدد الاختصاص وفقاً لمعيار عام يطبقه القضاء على كل حالة على حدة.

الطريقة الثانية: أن يحدد المشرع على سبيل الحصر المسائل الداخلة في اختصاص المحاكم الادارية فيكون الاختصاص بما عداها للمحاكم القضائية.

ولقد لجأ المشرع المصري عند إنشاء مجلس الدولة سنة ١٩٤٦ إلى الطريقة الثانية، حتى إذا نجحت التجربة ورسخت أصول هذا النظام أخذ بالطريقة الأولى في تحديد اختصاص المحاكم الادارية المصرية وذلك في القانون الحالي

^١ - الدكتور/ فؤاد محمد النادي، المبادئ العامة للإجراءات القضائية والاختصاص القضائي لمحاكم مجلس الدولة المصري، ص ١٤١.

لمجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨٤ إلا أن المشرع قد مزج بين الطريقتين، فنص صراحة على أهم المسائل التي تتدرج في اختصاص القضاء الإداري ثم عقب على ذلك بإيراد المعيار العام.

المطلب الأول

تحديد اختصاص المحاكم الادارية في مصر

سلك المشرع المصري في القوانين المتعاقبة لتنظيم مجلس الدولة المصري مسلكاً مغايراً لمسلك القضاء الفرنسي، فقد سلك المشرع المصري في القوانين المختلفة لمجلس الدولة كالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦، والقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ في تحديده لاختصاص المحاكم الادارية وهو تحديد هذا الاختصاص على سبيل الحصر ومن ثم فإن الخلاف الذي حدث في الفقه الفرنسي لا محل له في الفقه المصري، لأن اختصاص المحاكم الادارية في مصر لا خلاف حوله لأنه محدد على سبيل الحصر فما لم ينص عليه يدخل في ولاية المحاكم العادية وذلك لأن اختصاص القسم القضائي بمجلس الدولة المحدد بالقانون من النظام العام لا يقبل الاتفاق على ما يخالفه ومن ثم لا يجوز لهذه المحاكم أن تتصدى لمنازعة غير واردة في التعداد المصري الذي درجت على بيانه قوانين مجلس الدولة المختلفة.

ويلاحظ أن القضاء الإداري أخذ في بعض أحكامه بمعيار المرفق العام، وتارة اتجه الى معيار السلطة العامة غير أنه بصدر دستور جمهورية مصر العربية في ١١ سبتمبر سنة ١٩٧١ متضمناً النص في المادة ٦٨ منه على أن: "التقاضي حق مصون ومخول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ويحظر النص في القوانين العادية على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء"، كذلك استحدث الدستور ولأول مرة- النص على مجلس الدولة في الباب الخاص بالسلطة القضائية فتضمنت المادة ١٧٢ الإشارة إلى أن: "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الادارية" وبذلك أصبح مجلس الدولة صاحب الاختصاص العام في جميع المنازعات الادارية.

وعلى ضوء هذا الاستقلال الذي كفله دستور ١٩٧١ لمجلس الدولة وردت المادة العاشرة من قانون المجلس رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ لتقضي في الفقرة ١٤، بأن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل في سائر المنازعات الادارية، وذلك بعد أن عدت المادة سالفه الذكر ثلاثة عشر نوعاً من أنواع المنازعات الإدارية التي تختص بها هذه المحاكم.

ووفقاً لهذا النص فإن اختصاص مجلس الدولة بالمنازعات الادارية لم يعد اختصاصاً حصرياً كما كان الشأن قبل صدور القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ وإنما أصبحت المحاكم الادارية صاحبة الولاية الكاملة على سائر المنازعات الادارية، بحيث تشمل كافة المنازعات التي تكون الادارة طرفاً فيها سواء كان مجالها القضاء الكامل أو قضاء الالغاء، وهذا التطور الذي ترتب على دستور ١٩٧١، والقانون الأخير المنظم لمجلس الدولة يعطينا الحق في القول -كما سبق أن أشرنا الى ذلك بالتفصيل- بأن اتجاه المشرع هو جعل اختصاص مجلس الدولة اختصاصاً عاماً يجعله صاحب الولاية العامة على كافة المنازعات الادارية كما سبق الإشارة الى ذلك، ومن ثم فإننا نتشكك في القول بأن اختصاص مجلس الدولة لا زال اختصاصاً حصرياً، وإلا كان النص على اختصاص مجلس الدولة بسائر المنازعات الادارية تزيد من المشرع لا قيمة له، وهو أمر لا نسلم به، ومن ثم يتجه المشرع المصري الى جعل اختصاص المحاكم الادارية اختصاصاً عاماً بالمنازعات الادارية على النحو الذي استقر عليه الأمر في فرنسا، واذ أخذ بهذا الاتجاه ووضع في موضعه الصحيح فإن أمر البحث عن معيار يتحدد على ضوءه اختصاص المحاكم الادارية في مصر سي طرح نفسه في الفقه والقضاء المصري.

هذا وإذا كان ما آل إليه قانون مجلس الدولة هو جعل المحاكم الادارية صاحبة الولاية العامة على جميع المنازعات الإدارية، فإن ذلك لا يعني أن اختصاص ان ماء أصبح يغطي كافة المنازعات التي تكون الادارة طرفاً فيها، ذلك أن المنازعة الادارية التي يختص بها هذا القضاء الإداري يتعين أن تختلف طبيعتها وظروفها عن المنازعات التي تحدث بين الأفراد، ومن ثم إذا كانت المنازعة مع الادارة لا باعتبارها سلطة فإن مثل هذه المنازعة لا تعتبر منازعة ادارية تدخل في

ولاية القضاء الإداري، ومن ثم يشترط حتى تكون المنازعة إدارية أن تكون الإدارة طرفاً فيها باعتبارها سلطة عامة، فضلاً عن أن هناك منازعات تكون فيها الإدارة "سلطة عامة" ومع ذلك لا يختص بها القضاء الإداري لوجود نص يقضي بذلك، إلى جانب وجود اعتبارات قانونية أخرى تخرج بعض المنازعات الإدارية من اختصاص القضاء، وعلى ضوء ذلك يمكن أن نوضح المنازعات التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري رغم وجود الإدارة طرفاً في العلاقة القانونية:

١- المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها غير أنها تلجأ فيها إلى استخدام أساليب القانون الخاص وغالباً ما تكون في نطاق المرافق الصناعية والتجارية لما تستلزمه طبيعة هذه المرافق من استخدام أساليب ووسائل القانون الخاص.

٢- المنازعات التي تختص بها جهات قضائية أخرى سواء كانت هذه الجهة هي القضاء العادي أو غيرها، ومن أمثلة المنازعات الإدارية التي تدخل في ولاية القضاء العادي بنص القانون ما ورد في القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم السلطة القضائية حيث نصت المادة ١٧ على أن للمحاكم أن تفصل:

أ- في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي نص فيها القانون على غير ذلك.

ب- في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها.

ومن أمثلة المنازعات التي أخرجها المشرع من اختصاص المحاكم الإدارية وأدخلها في ولاية جهة أخرى غير جهة القضاء الإداري، اللجان القضائية الخاصة بالإصلاح الزراعي، لجنة التأديب والتظلمات الخاصة بإدارة قضايا الدولة، واللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وكذلك الطعن في القرارات الخاصة بالمجلس الأعلى للصحافة.

ويرى بعض الفقه أن التشريعات التي تقتطع من مجلس الدولة بعض الاختصاصات الإدارية وتحرمه من ولاية هذه المنازعات غير دستورية لمخالفتها لنص المادة ١٧٢ من دستور ١٩٧١ التي تجعل مجلس الدولة صاحب الولاية التامة على المنازعات الإدارية وهو ما نميل إليه.

٣- المنازعات المتعلقة بالحالة المدنية للأفراد إلا إذا تعلقت هذه المنازعات بقرار إداري، وتضم هذه المنازعات المسائل المتعلقة بالاسم والموطن والأهلية، ويستثنى من هذه المسائل الأمور المتعلقة بالجنسية، لأنها وفقاً للمادة ١٠ الفقرة السابعة من قانون مجلس الدولة تدخل في ولاية القضاء الإداري.

٤- بعض المسائل الأولية الخاصة بتفسير وفحص مشروعية القرارات الإدارية، فمن سلطة المحاكم على اختلاف درجاتها أن تقوم بتفسير القرارات التنظيمية عند قيامها بتطبيقها، ولها أن تمتنع عن تطبيق هذه اللوائح إذا تبين لها عدم مشروعيتها إعمالاً لما يقضى به تدرج القواعد القانونية وسمو القاعدة القانونية على اللوائح بكافة أنواعها، بل إن للمحاكم الجنائية الحق في فحص مشروعية القرارات الإدارية، وإذا اتضح لها عدم مشروعيتها فإن لها الحق في أن تمتنع عن تطبيقها. وفيما عدا هذه الأمور الأربعة فإن المحاكم الإدارية هي صاحبة الولاية العامة على سائر المنازعات الإدارية.

المطلب الثاني

توزيع الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة

وازن المشرع في القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بين وجوب تقرير اختصاص مجلس الدولة بكافة المنازعات الإدارية والدعوى التأديبية إعمالاً لنص المادة ١٧٢ من الدستور وبين الحاجة إلى تفصيل عناصر هذا الاختصاص وتحديد حالاته تحديداً منضبطاً، فاختار في هذا الصدد سبيلاً وسطاً حرص فيه على ذكر أبرز التطبيقات التي تدخل في مفهوم المنازعات الإدارية، ثم نص أيضاً على اختصاص المجلس بنظر سائر المنازعات الإدارية الأخرى على النحو السابق تفصيله وهو ما يجعلنا نعتقد معه بأن اختصاص المحاكم الإدارية في مصر أصبح على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر.

وفي توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية أبقى القانون على اعتبار محكمة القضاء الإداري هي المحكمة ذات الاختصاص العام مع تعديل في بعض اختصاصاتها عهد به إلى المحاكم الإدارية تخفيفاً على محكمة القضاء الإداري، وذلك على التفصيل الذي أوردناه آنفاً.

الجزء الثاني
(قضاء التعويض – قضاء التأديب)

دكتور
محمد عبد الله مغازي
أستاذ القانون العام

مقدمة

يعد قضاء القانون العام الإداري والدستوري إحدى اللبّات الأساسية في تحقيق أسانيد الدولة القانونية^(١) ، حيث يأتي من بين فروعها التي ندرسها في هذا الكتاب ما يلي :

- قضاء التعويض.

- قضاء التأديب.

ودراسة هذه الموضوعات سوف تكون في ضوء أحدث التشريعات ، وما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري والدستوري في ضوء ما يختص به القانون العام من خصائص ، ومنها :

أولاً - هناك مفاهيم عامة ومبادئ مشتركة وقواعد أساسية ، تجمع بين القضاء الإداري والدستوري تتمثل في أن السلطة العامة طرف فيهما سواء تدخلت بوصفها الحكومي ، أم بوصفها سلطة إدارية ، وفي الحالتين تظل السلطة الحكومية أو الإدارية خاضعة لقواعد القانون العام تحقيقاً لهدف سام تسعى إليه التشريعات القانونية ، والأحكام القضائية وهو التطبيق السليم لقواعد القانون علي اختلاف مدارجها وتنوع مصادرها ومساقها ، تلك التي يعتمد عليها المشرع عند سن التشريع ، وتلتزم السلطة التنفيذية بذات الغاية ، وهي تسعى دوماً لتحقيق المصلحة العامة بمفاهيمها المنظمة دستورياً وقانونياً علي المستويين الحكومي والإداري ، كما يستند إليها القاضي في مرحلة حسم النزاع المطروح عليه ، وهو ما يجعل قاضي القانون العام يسير وفق قواعد وإجراءات تختلف عن ذلك الذي يتبعه قاضي القانون الخاص بفروعه المتعددة .

ثانياً - إننا دائماً نقرر حقيقة قانونية ثابتة وراسخة في شتى النظم القانونية المقارنة ألا وهي : إن الإجراءات والشكل لا يقل أهمية عن الموضوع ، لما يمثلته من ضمانة جوهرية وأساسية في مرحلة نقل القاعدة من الجانب النظري الأكاديمي

^(١) انظر حكم المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ، ٣ يونيو سنة ٢٠٠٠ م ، في القضية المقيدة بجدول المحكمة برقم ١٥٣ لسنة ٢١ قضائية دستورية ، المصدر مجلة المحاماة ، العدد الأول ، ٢٠٠١ ، ص ٣٥٢ .

إلى مستوى التنفيذ الفعلي والتطبيق العملي لفكرة الحق العام الذي ينظمه القانون الدستوري والإداري ، وبدون ذلك يظل هذا الحق نظرياً ، ما لم يضمن قضائياً وتنفيذياً ، وهذه مرحلة ، تدخل دراستها في هذا الجزء الثاني في إطار الموضوعات المحددة له .

ثالثاً - هناك تطورات قانونية وقضائية سريعة ومتلاحقة في ميدان القانون العام ، وهو ما ينعكس على نظرياته الإدارية والدستورية ، بالنسبة لانتهااء بعض النظريات من التطبيق أم لتعديلات أدخلت على بعضها ، وتلك أمور يجب أن تكون تحت نظر الباحث في ميدان هذا القانون ، من حيث خضوع بعض المسائل القانونية فيه لأمر كلية ، واستعصاء البعض الآخر على القياس القانوني ، وهو الأمر الذي يقتضي اجتهاداً ، ق لا يتوافق مع المسلك الإجرائي في القواعد العامة للإجراءات .

خطة الدراسة :

توزع الدراسة في هذا الجزء في بابين :

الباب الأول - قضاء التعويض .

الباب الثاني - قضاء التأديب .

الباب الأول قضاء التعويض

تقديم وتقسيم :

يُنْتَظَم علم القانون في صورة مبادئ عامة وفلسفة كلية تمثل الإطار الشامل لما ينبغي أن يحكم عمل المشرع والقاضي علي سواء ، وعلى الأخص ما ارتبط منها بالعدالة والمساواة ؛ حيث تعد ضمن أسس القانون الطبيعي للإنسان ؛ بغض النظر عن ترجمته في صورة قواعد منضبطة ؛ كانت ترجمة لمصالح ضغطت علي المشرع حتى يتدخل بالتنظيم ؛ ومن بين ما يعد تطبيقاً لهذه الفكرة ، قواعد المسؤولية تلك التي تلزم من ارتكب ضرراً أن يعرض فاعله، طالما أن هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر، ومن حيث الأصل ، فلا فرق في قواعد المسؤولية بين المسئوليتين المدنية والإدارية ، إلا أن الأمر لم يكن كذلك من ناحية التطور التاريخي في مجال مسؤولية الدولة عن أعمالها بصفة عامة ، وفيما يتعلق بتخصيص هذه المسؤولية بأحكام مستقلة .

وفي دراسة تاريخ مسؤولية الدولة عن أعمالها ؛ يتضح لنا أن مبادئها وقواعدها لم تتضح عملاً ، إلا مع نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ؛ حيث كان المبدأ أن الملك لا يخطئ ، ومن ثم فهو غير مسئول عن أعماله المدنية والجنائية ، وانعكس ذلك بالتالي علي المسؤولية الإدارية عن أعمال الدولة الصادرة عن سلطاتها والتي تسبب ضرراً للأفراد ، ولم يكن هناك من مناص للفرد في هذه الحالة سوى الاعتصام بقواعد المسؤولية الشخصية، والتي لا تسعفه في غالب الأحوال فيما يتصل بالعدالة وسرعة جبر الضرر ، ولصعوبات متعددة تتصل بالإثبات ، أو أن يكون مرتكب الضرر مليوناً ، وفكرة التوازن في مراكز الخصوم ، وعصمة الدولة ؛ وهذا كله كان مرجعه عدم تطور وانتشار الأفكار الديمقراطية ، حتى مع قيام الثورات التاريخية كالثورة الفرنسية ، والثورة الأمريكية ، فعلى الرغم من كونها قد جاءت وزرعت المبادئ الديمقراطية ، بيد أنها لم تترك أثراً بينة علي فكرة مسؤولية الدولة ، وانتظر الأمر ما يقرب من المائة عام أخرى ، حتى بدأت تتضح معالم مسؤولية الدولة عن أعمالها ، وإن لم تكن بالشكل الذي وصلت إليه الآن .

وفي دراستنا لقضاء التعويض ينبغي أن نضع في اعتبارنا ما يلي :

أولاً - تعدد سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية واختلاف وظيفة كل منها وطبيعة أعمالها ، والقائمين عليها ، إذ تظل الدولة شخصاً معنوياً تدار بواسطة مسؤوليها وموظفيها وعمالها ، وهنا يتضح الفارق الجوهرى بين المسؤولية المدنية بنوعيتها العقدية والتقصيرية ، ومسئوليتها محل البحث ، فالأولى ينسب الخطأ فيها إلي شخص مرتكب الفعل ومن ثم تطاله المسؤولية شخصياً من حيث الأصل ، مع وجود تفصيلات وضوابط ليس هنا محل دراستها ، فلتراجع في مواضعها في القانون المدني في باب المسؤولية ، بينما في مجال مسؤولية الدولة هنا نحن أمام شخص يتصرف باسم الدولة ولمصلحتها ، فتدق قواعد المسؤولية عن نوعية الخطأ وطبيعته ومداه .

ثانياً - تنوع واختلاف طبيعة المعايير التي يمكن من خلالها قياس الخطأ وهل هو حقيقي أو مفترض ، وتباين طبيعة الضرر ومدى جسامته ومساهمة الضرر فيه ، وهذا كله من شأنه أن يجعل المسؤولية الإدارية تحتاج إلي قواعد خاصة في تنظيمها وتطبيقها ، تباين في بعض الأحيان ذلك المستقر عليه في مبادئ المسؤولية المدنية .

ثالثاً - الأحكام المتواترة في قضاء مجلس الدولة المصري والقضاء الإداري الفرنسي ، كان لها دورها البارز في استخلاص قواعد هذه المسؤولية وتطويرها علي النحو الذي يتفق مع طبيعة المنازعة الإدارية ، واختلافه عن المنازعة العادية ، سواء من حيث إجراءاتها أم القواعد القانونية التي سوف تنطبق عليها ، الأمر الذي يتطلب منا ، أن نقف على أحدث ما وصل إليه هذا القضاء في ميدان المسؤولية الإدارية .

وبالبناء علي ما تقدم نقسم هذه الدراسة إلي فصول هي :

الفصل الأول - عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطتين التشريعية والقضائية

وحدود هذا المبدأ .

الفصل الثاني - قواعد المسؤولية العقدية للإدارة عن التعويض .

الفصل الثالث - قواعد المسؤولية التقصيرية للإدارة عن التعويض .

الفصل الرابع - المسؤولية التقصيرية للإدارة علي أساس الخطأ .

الفصل الخامس - مناهج المسؤولية التقصيرية .

الفصل السادس - ركنا الضرر وعلاقة السببية في المسؤولية التقصيرية .

الفصل السابع - التعويض .

الفصل الأول

عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطين التشريعية والقضائية وحدود هذا المبدأ

توطئة :

علي الرغم من تبعية السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية للدولة ، إلا أنه يظل من الناحية المنطقية ضرورة التفريق في طبيعة المسؤولية ومداها ، بين أعمال السلطين لتشريعية والقضائية من جانب ، وعمل السلطة التنفيذية من جانب آخر ، ولعل هذا مرده إلي أن وظيفة كل منهما تلقي بظلالها علي علاقتها بالأشخاص ، ومن حيث إمكانية حدوث الضرر ومداها ؛ فالأخيرة هي الأكثر احتكاكاً بالجماهير بحكم مسؤوليتها عن إشباع حاجاتهم اليومية من خلال مرافقها العامة أو من خلال قيامها بمراقبة سلوكهم عن طريق قواعد الضبط الإداري ومبادئه ، ومن خلال الوسائل التي تعتمد عليها أو الأساليب التي تلجأ إليها ، يكون الخطأ أكثر حدوثاً ، ومن ثم فكم الضرر ، واتساع نطاقه يختلف بالتالي نتيجة لهذا التبرير ، ولعل هذا هو الذي يقدم لنا كيف أن مسؤولية الدولة عن تصرفات سلطاتها الإدارية كانت هي الأسبق في الظهور ، وهي الأساس الذي قامت في نطاقه ، واتسعت مسؤولية الدولة عن أعمالها ، مقارنة بعمل السلطين الآخرين ، وهما السلطة التشريعية ، والسلطة القضائية ، ومن ثم نقسم هذا الفصل إلي مبحثين هما :

المبحث الأول: مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية وحدوده

المبحث الثاني - مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية

وحده .

المبحث الأول

مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية وحدوده

تمهيد وتقسيم : وظيفة السلطة التشريعية الرئيسية هي التشريع أو سن القوانين ،

ويتم اختيار أعضائها عن طريق الانتخاب من قبل الشعب ، ومن ثم فهؤلاء هم

ممثله الحقيقيون ، الذي يعبرون عن إرادته ويعكسون مصالحه في صورة قواعد قانونية ، يطبقها القضاء ، وتنفذها الإدارة ، بيد إنه يظل الضرر الحاصل من جراء ممارسة هذه الوظيفة متصوراً ، ويظل البحث قائماً حول مدة مسئولية الدولة عن هذه الوظيفة .

ويضاف إلي ذلك عمل آخر ، وإن لم يكن ضمن الوظيفة الأساسية لهذه السلطة ، ونعني به العمل البرلماني ، وهي طائفة من الأعمال تختلف في طبيعتها ومقصودها عن العمل التشريعي ، وإن كانت تتصل به من حيث كونها سلطة واحدة ، يصدر عنها كلا العاملين ، ومن ثم فإن الدراسة هذه تتطلب أن نقسم هذا المبحث إلي مطلبين :

المطلب الأول - مبدأ عدم مسئولية الدولة عن الأعمال التشريعية .

المطلب الثاني - عدم مسئولية الدولة عن الأعمال البرلمانية .

المطلب الأول

مبدأ عدم مسئولية الدولة عن الأعمال التشريعية

نبذة : نتناول في هذا المطلب النقاط التالية : مفهوم الأعمال التشريعية والمبدأ فيها ومبرراته ، والتطورات المستحدثة التي لحقت به ، وعلاقة الانحراف التشريعي بمبدأ عدم المسئولية ، وتغير مفهوم دور الدولة وأثره علي مبدأ عدم المسئولية ، وذلك علي الوجه التالي :

مفهوم الأعمال التشريعية : يقصد بالأعمال التشريعية تلك الصادرة عن البرلمان في أداته لوظيفته الأصلية ، وهي سن القوانين التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع ^(١) ، وينبغي أن يفهم التشريع هنا بالمعنى الضيق ، وهو القانون الصادر عن البرلمان ، ومن ثم يستبعد من نطاقه ما يلي :

(١) دكتور ، رمزي الشاعر ، قضاء التعويض ، ط ١٩٨٧ ، ن ٦٥ ، حيث يقرر سيادته أن : " القانون - كما هو معروف - هو ذلك الذي يصدر عن السلطة التشريعية ، ويحتوي علي قواعد قانونية عامة مجردة .. " راجع :

- د / سليمان الطماوي ، دروس في القضاء ، دراسة مقارنة ، ملتزم الطبع والنشر : دار الفكر العربي ، ط ١٩٧٦ ، ص ٢٦٨ .

- د / محمد رفعت عبد الوهاب ، أصول القضاء الإداري - قضاء الإلغاء - قضاء التعويض - الإجراءات للقضاء الإداري ، ط ١٩٩٣ ، ص ٢١١ .

١- **الدستور** : حيث تعد النصوص الدستورية هي المبادئ العليا والقانون الأسمى في الدولة ، والتي ترسم تنظيم وحدود عمل سلطات الدولة ، وتحدد حقوق الأفراد وحررياتهم ، ومن ثم فهو تعبير عن إرادة السلطة التأسيسية الأصلية ، التي لا تعلوها سلطة أخرى ، فمضامين هذه النصوص تتعارض وتقرير قواعد للمسئولية عنها .

٢- **التشريعات اللاحقة** : يقصد بها تلك التي تتضمن قواعد عامة مجردة مثلها في ذلك مثل التشريع العادي ، ولكنها صادرة عن السلطة التنفيذية ، سواء وضعت تفصيلات تنفيذ القانون ، وهي اللوائح التنفيذية ، أو تضبط سلوك الأشخاص بطريقة وقائية وهي لوائح الضبط ، أو كانت من قبيل القرارات بقوانين حسبما يمنحه المشرع الدستور للسلطة التنفيذية الاختصاص بإصدارها في حالات التفويض أو الضرورة وفقاً للنظم الدستورية المختلفة ، وذلك قبل اعتمادها من قبل البرلمان ، لأنها بعد هذا تصبح من قبيل القانون الصادر عن البرلمان .

ولا محل هنا للحديث عن مسئولية الدولة عنها ؛ لأنها تدخل ضمن المسئولية الإدارية للدولة عن أعمال السلطة التنفيذية وفقاً لما سوف نتناوله لاحقاً .

٣- **القرارات الفردية** ^(١) : وهي تصدر عن السلطة التنفيذية ، ولا تضع قواعد عامة مجردة ، بل تخاطب مراكز فردية ، ولا تعد بالتالي من قبيل العمل التشريعي ، محل بحثنا هنا ، بل تدخل ضمن أعمال السلطة الإدارية ، وقواعد المسئولية عنها . ويستوي بعد ذلك في تحديد مضمون العمل التشريعي ، أن يكون صادراً عن المجلسين وفقاً للنظم التي تتبعه ، أم عن مجلس واحد ، وسواء صدر عن اقتراح حكومي أم عن اقتراح أعضاء البرلمان .

- **المبدأ عدم المسئولية** : هناك مبدأ تقليدي يحكم هذه المسألة سواء في ذلك النظام القانوني الفرنسي أو المصري ، وهو عدم مسئولية الدولة عن التعويض عن أعمال السلطة التشريعية ، علي الرغم من أنها قد تنتج عنها أضرار قد تكون جسيمة في بعض الأحيان ، مثال ذلك عمليات التأمين التي تمت في الماضي فهي بدايات الاستقلال في الدول ، أو ما تقوم به بعض الدول المعاصرة ، من تطبيق الفكرة علي

(١) د/ عاطف البناء، الرقابة القضائية علي دستورية اللوائح، مكتبة النصر بجامعة القاهرة، طبعة ١٩٩٢، ص ١، ٢

بعض المنتجات أو الصناعات (١) ، وبناءً على أن هذا المبدأ له أصوله التاريخية والتي مازالت تؤثر في تطبيقاته (٢) ، حتى الآن في شتى النظم والتشريعات المقارنة . وهناك ملاحظة جوهرية وهي أن هذا المبدأ في تبريره التاريخي كانت مرتبطاً بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة في هذه الحقبة والتي كانت تفرضه فرضاً ، ولكن إذا كان هذا مقبولاً ، لمبررات معينة ، إلا أننا نرى أنه من الناحية الموضوعية يظل تحديد المقصود بالعمل التشريعي مسألة جوهرية ، حتى لا تضفي صفة التشريع على عمل من أعمال الإدارة .

- الأساس القانوني لمبدأ عدم المسؤولية عن الأعمال التشريعية :

قيل بعده مبررات لنفي مسؤولية الدولة عن التعويض عن الأضرار المترتبة على الأعمال التشريعية ، ومن أهمها :

- **قرينة افتراض الصحة :** حيث يفترض أن العمل التشريعي الصادر عن البرلمان تقوم لصالحه قرينة أساسية هي صحة هذا العمل ، طالما أنه صادر عن المشرع صاحب السلطة في التشريع ، ومن ثم فإن الأضرار التي تترتب عليه لا يمكن تعويضها (٣)

وفي الحقيقة فإن هذه الحجة غير مقنعة ، لأن البرلمان يتكون من أعضاء لا يمكن عصمتهم عن الخطأ ، ومن المتصور عقلاً وعملاً صدور تصرفات غير مشروعة في صورة قوانين ، تخالف المبادئ والأصول الدستورية التي سنّها المشرع ، ومن هنا فقد اتجهت النظم الدستورية الحديثة إلى تقرير نوع من الرقابة على تصرفات هذه السلطة ، وضمان التأكد من السلامة الدستورية لأعمالها التشريعية ، هذا علاوة على أن القانون قد يخالف الدستور نصاً ، ولكن تترتب عليه أضرار بالأفراد أو بطائفة منهم ، ومن هنا فإن التساؤل حول تعارض منع التعويض وتقرير مسؤولية الدولة عنه مع مبادئ العدالة (٤) .

(١) مثل الحركة التي يقودها " هوجر شافير " رئيس فنزويلا من تأميم صناعة النفط التي كانت تحتكرها الشركات الفردية .

(٢) د / سليمان الطماوي ، دروس في القضاء الإداري ، سابق ، ص ٢٦٩ .

(٣) السابق ، ص ٢٧٠ .

(٤) خاصة مع التطورات الحديثة في المبادئ العامة للقانون .

الإرادة السياسية العليا : فالأعمال التشريعية تدخل ضمن الأعمال المرتبطة بالسيادة، وهي طائفة من الأعمال التي تصدر عن الدولة وترتبط بسيادتها ولا يمكن أن تكون محلاً للمسئولية عن الأضرار المترتبة عليها ، وبالتالي فالمبدأ عدم مسئولية الدولة عن هذه الأعمال أياً كانت السلطة الصادرة عنها (١) .

وهذه الحجة تقليدية ، وغدت منبوذة من حيث الاستناد إليها في تبرير اتصال الدولة من مسئوليتها عن بعض الأعمال ، فلم يعد مبدأ المشروعية ، وانتشار الأفكار الديمقراطية يتحلمان مثل هذا التبرير .

وعلى الرغم من عدم سلامة ما سبق ، فقد يقال أن السبب مرده هو عدم وضع العقوبات في سبيل نهوض المشرع (٢) بأعماله في سن القوانين التي تحتاجها الدولة في تنظيم شئونها ، وتسيير تصرفات مواطنيها - ومع ذلك يظل التمسك بمبدأ المشروعية هو الملاذ الذي لا ينبغي لنا أن نحيد عنه ، ويبقى قيد تعويض المضرور لازماً لمبادئ العدالة ، ويتطلب بالتالي التخفيف من حدة نفي المسئولية .

- التطورات المستحدثة التي لحقت بمبدأ عدم المسئولية : إن مبدأ عدم مسئولية الدولة عن الأعمال التشريعية هو السائد والمطبق حتى الآن في مصر ،

(١) راجع : د / عبد المنعم محفوظ ، قضاء المشروعية ، ط ١ بدون تاريخ ، ص ١١٤ ، ن ١١٥ .
د / محمد أنس قاسم جعفر ، الوسيط في القانون العام ، القضاء الإداري ، ط ١٩٨٧ م دار النهضة العربية ، ص ٩٢ . وفي اتجاه لمحكمة القضاء الإداري ، تقول : " أن المبدأ المسلم به كقاعدة عامة عدم مساءلة الدولة عن أعمالها التشريعية ، لأن التشريع يجب أن تكون له الكلمة العليا في تنظيم المجتمع عن طريق وضع القواعد العامة المجردة ، فإذا ما ترتب على التشريع ضرر لبعض المواطنين ، فإن الصالح العام يقتضي أن يتحملوا عبء ذلك ومبدأ عدم مسئولية الدولة عن النشاط التشريعي ، وعما قد تسببه القوانين من أضرار هو مبدأ تقليدي يقوم على مبدأ سيادة الدولة ، ومن خصائص السيادة أنها تفرض سلطاته على الجميع دون أن يكون لأحد أي حق في التعويض عنها ، إذ أن الضرر الذي تسببه القوانين لا تتوافر فيه الشروط للحكم بالتعويض ، وأهمها الخصوصية ، ولأن القوانين وهي قواعد عامة مرده يقتصر أثرها على تغيير المراكز العامة .

فإذا ما ترتب عليها ضرر عام لا يصيب أشخاصاً بذواتهم فإن مثل هذا الضرر لا يعرض عنه ، ما لم يقر القانون صراحة منح التعويض لمن يضار من صدره ، فإذا سكت المشرع عن تقرير هذا التعويض ، كان ذلك قرينة على أنه لا يترتب على التشريع أي تعويض " .. مصدرنا في هذا الحكم : دكتور / رمزي الشاعر ، قضاء التعويض ، سابق ، ص ٦٨ ، ٦٩ .

(٢) د / رمزي الشاعر ، قضاء ، سابق ، ص ٧ .

حيث لا يوجد نص تشريعي يقر مبدأ المسؤولية عن الأعمال التشريعية مهما بلغت جسامة الأضرار الناتجة عنها ومهما كان هناك من ضيق نطاق الضرر المتحقق بفرد أو بطائفة من الأفراد ، ومن ثم فالمستقر عليه في اتجاهات القضاء هو الالتزام بمبدأ عدم مسؤولية الدولة ، ومن ثم فلا محل لدعوى التعويض عنها ، وذلك ما لم يتدخل المشرع بالنص الصريح علي التعويض عن الأضرار الناجمة عن تطبيق قانون معين^(١)

حيث يجب هنا لتقرير التعويض في حالة النص في بعض التشريعات ، أن يكون الضرر الناتج عن العمل التشريعي نسبياً وليس عاماً مطلقاً ، إذ أن عمومية الضرر من شأنها أن تحول دون تقرير هذا التعويض ، وباعتبار أن العبء قد تحمله الجميع ، ومن شأن ذلك أن يجعل المساهمة تقع علي عاتق الكل دون البعض ، وهذا الأمر يختلف عن الحالة التي يكون فيها الضرر خاصاً وعلي درجة معينة من الجسامة ترتفع به عن محض الضرر الجزئي أو البسيط الذي يمكن تحمله في المعتاد ، إذ يكون ثمة مبرر لتقرير مسؤولية الدولة في هذا الوضع ، وأن يكون هذا الضرر قد لحقه شخصياً ، أما إذا كان هناك ظروف تحول بين ذلك وبين كون الضرر علي هذا النحو ، فلا محل لإعمال موقف مجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن^(٢) .

ونحن نرى أنه من الأوفق أن يساير مجلس الدولة المصري مسلك نظيره الفرنسي من حيث تقرير المسؤولية عن الأعمال التشريعية للبرلمان ، لأن ذلك هو الأكثر توافقاً مع مبدأ المشروعية الذي يقضي بخضوع الكافة للأحكام القانونية حكماً كانوا أم محكومين ، إذ من شأن ذلك التقريب بين الفرد والدولة في تطبيق قواعد المسؤولية ، حتى نصل مستقبلاً إلي تقرير مبدأ المسؤولية عن أعمال الدولة كافة ، وتزداد مطالبتنا بذلك ، حيث تكثر القوانين التي تنتج عنها العديد من الأضرار .

- **علاقة الانحراف التشريعي بمبدأ عدم المسؤولية :** البحث هنا حول مسألة جوهرية تحتاج إلي التعمق في دراستها ، وهي عن حالة وجود انحراف تشريعي في

(١) د / سليمان الطماوي ، دروس ، سابق ، ص ٢٧٢ .

(٢) السابق ، ص ٢٧٤ .

قانون ما ، وما إذا كان الأمر يظل متصلاً بمبدأ عدم المسؤولية عن الأعمال التشريعية ، أم أن الحل يكون مختلفاً .

مفهوم الانحراف التشريعي :

يرتبط بالرقابة علي دستورية القوانين التي يباشرها القضاء الدستوري ، فعندما يتصل الأمر بالمخالفة المباشرة للقاعدة الدستورية البعيدة عن الانحراف ، فإن الأمر يظل خاضعاً لمبدأ عدم المسؤولية بتفصيلاته التي سلف عرضها ، أما في حالة الانحراف التشريعي ، وهو يتصل بالمجافاة وتنكب وجه المصلحة العامة في التشريع ، فإن فكرة الضرر المترتب علي وجود هذا العيب ، من الواجب أن تخضع لحكم يختلف موجهه لجسامة المخالفة المرتبطة بالتشريع ، ومن ثم فمن العدالة في هذه الحالة هي القضاء بالتعويض وترتيب مسؤولية الدولة .

تغير مفهوم دور الدولة وأثره علي مبدأ عدم المسؤولية :

إن التطور اللاحق بدور الدولة في وقتنا الحالي ، ولجوء الدولة إلي فكرة الخصخصة لممتلكاتها ، وإتباع فكر المشروع الخاص في إدارة المشروعات الحكومية ، من شأنه أن يؤثر في نظرة القاضي لمبدأ عدم المسؤولية ، فإذا كان المبرر التاريخي له هو أن التشريع هو الذي يقود عجلة التنمية والنقد بالدولة ، فقد بدأ هذا المبرر يتلاشي أمام الاعتبارات السالفة ، ومن ثم يجب أن يخفف من حدة مبدأ عدم المسؤولية إزاء ذلك ، ويبدأ مجلس الدولة المصري في بلورة صياغة جديدة له تراعي هذه المستجدات، باعتبار أنه قضاء إنشائي يبتدع الحلول ويرسي المبادئ والنظريات الكبرى في مجال المسؤولية الإدارية بخاصة ، والقانون الإداري بعامة .

المطلب الثاني

مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن الأعمال البرلمانية

تتناول دراسة هذا المطلب في عدة نقاط ، تتصل بتحديد مدلول للأعمال البرلمانية ، والقواعد التي تحكم مبدأ المسؤولية عنها ، وإمكانية تطوير موقف القضاء منها .

مدلول الأعمال البرلمانية :

يقصد بالأعمال البرلمانية هي تلك التي تخرج عن نطاق الوظيفة الأصلية للبرلمان وهي التشريع ، ذلك أنه يقوم بوظيفة أخرى هي وظيفة الرقابة علي السلطة

التنفيذية وفي سبيل إنجازها ، منح أعضاؤه دستورياً الوسائل البرلمانية ومنها السؤال والاستجواب وطلبات الإحاطة وتقصي الحقائق وما إليها ، هذا بالإضافة إلي أعمال أخرى وإن كانت لا تدخل في مهامه الأساسية بيد أنها من وسائلها ، كشئون الموظفين والعمال بالبرلمان، والقرارات الصادرة بشأنهم ، والعقود التي يبرمها في تسير شئونه كمرفق حيوي ، وكذا التصرفات المادية التي تنسب إليه ، إلي جانب من التصرفات القانونية السابقة (١) .

من ثم يخرج عن هذا النطاق ، تصرفات الأعضاء الشخصية بعيداً عن الوظيفة البرلمانية في التشريع والرقابة ، سواء صدرت عن العضو باعتباره وظيفته العمومية أم بكونه فرداً عادياً ، إذ تظل قواعد المسؤولية العادية هي السارية .

القواعد التي تحكم مبدأ المسؤولية عن الأعمال البرلمانية :

عدم مسؤولية لدولة عن الأعمال البرلمانية هو المبدأ الذي استقر تاريخياً ، ونستطيع تحليل هذا المبدأ في عدة قواعد هي :

أولاً - الجمود التاريخي : كان هذا المبدأ يعاني من الجمود في التطبيق نظراً للظروف المحيطة بالثورة الفرنسية، وكان يغلب علي الأذهان وضع البرلمان في المرحلة السابقة عليها ، ومن ثم وحتى يحافظ مبدأ القاضي الإداري علي نشأته ، فقد تم الاستناد إلي فصل السلطات باعتبارها حائلة دون نظر المسؤولية عن الأعمال البرلمانية ، خاصة وأنه في هذه الفترة كان مجلس الدولة الفرنسي يخضع لنظام القضاء المقيد ، حيث كان القنصل الأول هو من يملك سلطة التقرير ، وما دور مجلس الدولة في هذا الشأن سوى تهيئة القرار للصدور ، ولقد كان قانون ١٦ - ٢٤ أغسطس ١٧٩٠ هو اللبنة الأولى التي قررت فصل الوظيفة الإدارية عن الوظيفة القضائية (٢) .

(١) د / محمد حسنين عبد العال ، القانون الدستوري ، الناشر : دار النهضة العربية ، ط ١٩٩٢ ، ص ٢٣٩ وما

بعدها . راجع : دكتور / محمد رفعت عبد الوهاب ، القانون الدستوري ، المبادئ الدستورية العامة -

دراسة النظام الدستوري المصري ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، ن ط ١٩٩٠ ، ص ٤١٢

(٢) راجع روبري بيلو ، المواطن والدولة ، ترجمة نهاد رضا ، منشورات عويدات ببيروت - باريس ، الطبعة

الثالثة ١٩٨٣ ، ص ١١٩ ، ن ١٢٠ .

ثانياً - إن مجلس الدولة المصري قد طور هذا المبدأ ، فمع تسليمه بعدم المسؤولية ، فقد قررها في نطاق تصرفات البرلمان في شئون موظفيه وعماله الإداريين ، فالقرارات الصادرة من مكتب المجلس أو من رئيسه في شأن تعيينهم موظفيه أو عماله أو ترقيةهم أو تأديبهم وغيرها يعد من قبيل الأعمال القانونية الخاضعة لقواعد المسؤولية ، وما يبره المجلس من العقود الإدارية مثل عقود الأشغال العامة وعقود التوريد ، وسواها تعد من قبيل الأعمال التي تخضع للمسؤولية في التعويض عن الأضرار المترتبة عليها (١) .

ثالثاً - إن مجلس الدولة الفرنسي قد اختط منذ البداية موقفاً جامداً تجاه هذا المبدأ ، رافضاً فكرة المسؤولية عن الأعمال البرلمانية ، وقد حاول لاحقاً تطوير اتجاهه حيال قواعد المسؤولية هذه من خلال تقديم تبريرات لها ، إما من خلال التفسير المحدد لمفهوم العمل البرلماني وعلاقته بالعمل الإداري المادي أو القانوني ، ومحاولة ربط ذلك بإحدى نظريات القانون الإداري من الناحية الموضوعية (٢) .

وقد تدخل المشرع الفرنسي بمقتضى القانون الصادر عام ١٩٥٨ م ، ليقرر أساسين فيما يتصل بالمسؤولية هنا ، وهما :

الأساس الأول - علاقة البرلمان بموظفيه وعماله ، وفيما يصدر بشأنهم ، حيث يعد ذلك من قبيل القرارات الإدارية التي تخضع لقواعد المسؤولية وفقاً لضوابطها العامة (٣) .

الأساس الثاني - الأعمال المتصلة بممارسات وأنشطة البرلمان ، مثل العقود التي يبرمها والتي تتصل بتنسيقه ، أو الأعمال المادية الناتجة عن قيامه بأعماله ، مثل الحوادث التي تقع من السيارات التابعة له ، أو الأضرار المادية التي تقع بالغير ناتجة عن أنشطته ، حتى ولو لم يكن المضرور من المتعاقدين منها (٤) .

(١) راجع في ذلك د / سليمان الطماوي ، دروس ، سابق ، ص ٢٩٥ .

(٢) د / رمزي الشاعر ، قضاء التعويض ، سابق ، ص ٥٢ ، ٥٣ .

(٣) د / سليمان الطماوي ، دروس ، سابق ، ص ٢٦٨ .

(٤) السابق ، ص ٢٦٨ .

إمكانية تطوير موقف القضاء من المبدأ :

إن فكرة الفصل بين السلطات باعتبارها مبرراً تاريخياً لمبدأ عدم مسئولية الدولة عن الأعمال البرلمانية ، بالإضافة إلى الأسانيد الأخرى التي قيل بها استبعاداً لهذا المسئولية ، لم تعد كافية من وجهة نظر المشروعية والعدالة في ذلك، وهذا لعدة أسباب :

السبب الأول - مبدأ المشروعية أصبح يقضي بالتزام أحكام القانون من الكافة ، ولم يعد من المقبول تبرير عدم مسئولية الدولة عن الأعمال البرلمانية ، لأسباب لا تتصل بماهية المشروعية بقدر اتصالها بأسباب عملية يمكن التغلب عليها ، إذا ما كانت المشروعية هي الهدف.

السبب الثاني - إن العدالة تتطلب المساواة في المراكز القانونية مع مراعاة حاجة الدولة لتنفيذ برامجها عن طريق التشريعات ، واعتماد البرلمان علي وسائله في ممارسة وظائفه ، فإنه تظل العدالة تتعارض معها نفي فكرة جبر الضرر الواقع من هذه الأعمال ، في مقابل نفاذها ، فيجب أن تظل الحقوق محفوظة للمضارين ، والقول بغير ذلك معناه تحول الأمر إلي الاستبداد الذي يعد أشد عداءً للنظام الديمقراطي ، الذي لا يعني فقط وجود سلطات متعددة يباشر كل منها وظيفة محددة ، بل يجب أن يقترن بذلك احترامها لأحكام القانون والتزامها بقواعده ، كما أن عدم المسئولية من شأنه أن يقر فكرة غصب الحقوق ، والإضرار بحقوق الأفراد المادية أو المعنوية والمكفولة لهم .

السبب الثالث - تقرير المسئولية عن الأعمال البرلمانية من شأنه أن يرد البرلمان إلي جادة الصواب ، لأننا هنا نتحدث عن فكرة جبر الضرر الواقع بالأشخاص ، ويجعل البرلمان يستعمل الوسائل الدستورية الممنوحة له في هدفها ، دون الخروج عن الحدود والضوابط الدستورية، ويحمي ويكفل حقوق الآخرين في أموالهم أو سمعتهم ، دون هدف تحقيق منافع ومآرب شخصية لا صلة لها بالقانون .

السبب الرابع - تزداد المطالبة بتقرير المسئولية عن الأعمال البرلمانية خاصة في ظل النظم إلي تهدف إلي أن تكون فيها البرلمانات تعمل في نطاقها المحجوز بطريقة سليمة ، وحتى يمكن التحقق من الالتزام بالضوابط والمبادئ الدستورية

الملزمة والمقررة ، الأمر الذي يكون معه القضاء في ظلها هو الملاذ لحقوق الأفراد وحررياتهم في مواجهة الغصب والاستبداد والعصف بالحقوق تحت ستار غير دستوري ، ومن ثم يجب أن يطور القضاء موقفه ويقرر مبدأ المسؤولية عن الأعمال البرلمانية استناداً لهذه المبررات وغيرها كثير .

ويمكن أن نحقق ذلك من خلال سن تشريع جديد ، يوازن بين طبيعة العمل البرلماني ، وما ينبغي أن توفره العدالة من جبر للضرر اللاحق بالأشخاص في ضوء قواعد المسؤولية .

المبحث الثاني

مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية وحدوده

توطئة :

السلطة القضائية وظيفتها تطبيق القانون الذي سنه المشرع علي الدعاوى والمنازعات المطروحة عليه ، وتعتق كافة النظم القانونية هذه الوظيفة للقضاء مع تعدد جهاته بين القضاء العادي والإداري والدستوري ، والجهات القضائية الأخرى والتي تختلف في تنظيمها باختلاف النظم القانونية ، أو كان النظام يقوم على فكرة القضاء الموحد ، وهكذا فعمل القاضي الأساسي هو إصدار الأحكام في المنازعات المطروحة عليه ، ولكن يظل التساؤل هنا هو مدى مسؤولية الدولة عن جبر الأضرار المترتبة علي أعمال هذه السلطة؟

المبدأ المستقر عليه تاريخياً هو عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية ، ولعل هذا المبدأ يعود إلي عدة مبررات لا تخرج في جوهرها عن الأسانيد العملية وليست القانونية منها .

مفهوم الأعمال القضائية :

الأعمال القضائية هي طائفة الأعمال التي تصدر عن السلطة القضائية في مهمتها الأساسية وهي إصدار الأحكام ، أو كانت مهدة أو تالية لها ، أو معاونة علي إنجازها ، ومن ثم يدخل في اعتبارنا ما يلي (١) :

(١) راجع د / سليمان الطماوي ، دروس ، سابق ، ص ٢٧٨ ، ٢٧٩ ، وينبغي أن نلاحظ أن تحديد مفهوم العمل القضائي محل بحث متعمق ، وقد اقتصرنا هنا علي الأفكار العامة ، حيث يتردد هذا المفهوم بين المعيار

أولاً - الأحكام القضائية ؛ سواء صدرت عن جهات القضاء العادي أم الإداري أم الدستوري وسواها من الجهات الأخرى التي تكتسب وصف الجهة القضائية ، وكذا كافة الأعمال التي لا ينطبق عليها وصف الأحكام بالمعني الفني الدقيق ، رغم صدورها من جهات إدارية منحها المشرع اختصاصاً قضائياً ، وكذا أعمال القضاة الأخرى التي تصدر بصفقتهم الولائية .

ثانياً - أعمال النيابة العامة ؛ باعتبارها مساعدة لجهات القضاء مع ملاحظة اختلاف هذه الأعمال عن الأعمال الأخرى التي تصدر عنها بصفقتها الإدارية .

ثالثاً : أعمال مأمور الضبط القضائي ؛

وهذه أعمال تصدر من حيث الأصل عن هذه السلطة ، باعتبارها معاونة لجهة الحكم علي أداء أعماله ، وقد أثارت خلافاً في التطبيقات القضائية حول مفهومها ، فقد قضي بأن : " محكمة القضاء الإداري غير مختصة بالنظر في طلب إلغاء العمل القضائي ... وإذا أجري موظف ضبط عملاً مما لا يجوز طبقاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٣٩ ... بغير ترخيص من وزير المالية ، ولم يحصل حائزه علي هذا الترخيص ، فهذا العمل يخرج عن دائرة اختصاص محكمة القضاء الإداري ، إذ هو عمل قضائي ، لأن موظف الجمرک وعماله يعتبرون بمقتضي المادة السابعة من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٠٥ الخاص بمنع تهريب البضائع من رجال الضبطية القضائية في أثناء قيامهم وظائفهم" (١) .

قواعد المبدأ :

المستقر عليه هو عدم مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية ، علي أساس القول أن الحكم القضائي إنما يفصل في منازعة ، وهو عندما يصدر يكتسب حجية الأمر المقضي به ، علي أساس أن الحكم هو عنوان الحقيقة فيما قضي به (٢) ، هذا مع

الشكلي الذي يعترف بالجهة التي صدر عنها هذا العمل ، وما إذا كانت إدارية أو قضائية ، وأحياناً يتم اعتماد المعيار الموضوعي الذي يحصر الفكرة في موضوع النزاع ، فالعمل القضائي هو الذي يفصل في خصومة أو منازعة قضائية ، وأحياناً يتم الاستناد إلي المعيارين الشكلي والموضوعي في تحديد طبيعة هذا العمل .

(١) مشار إليه في المصدر السابق ، هامش ، ص ٢٨٠ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٢٧٥ .

إعطاء الخصوم حق الطعن عليه حسبما ينظمه القانون في هذا الشأن ، ومن ثم فلا تسأل الدول عن هذه الأعمال احتراماً لحجية هذه الأحكام وقدسيته ، وقد قيل إذا سمحنا بفتح الجدل حول هذه المسؤولية ، لتهديب القضاة من الحكم ، تهيباً من قواعد المسؤولية ، وبالتالي سوف يتعطل هذا المرفق الهام من مرافق الدولة (١) ، وعلي الرغم من عدم سلامة الاستناد إلي هذه الأسانيد وغيرها في استبعاد المسؤولية ، إلا أنه يظل الوضع الحالي هو ذات المبدأ من حيث الأصل اللهم إلا إذا استثنى المشرع حالة وأخضعها للمسئولية.

وفي تطور قانوني جديد بعد صدور دستور ٢٠١٤ في مصر قررت الفقرة الخامسة حكماً جديداً فيما يتعلق بالتعويض عن بعض حالات المسؤولية محل الدراسة ، وفرقت بين أمرين :

الأمر الأول - الحبس الاحتياطي : وفيه قرر المشرع الدستوري أن القانون ينظم أحكامه، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي .

الأمر الثاني - تنفيذ العقوبة : وقد قرر المشرع الدستوري أن القانون ينظم حالات استحقاق التعويض عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه .

(١) د / رمزي الشاعر ، قضاء التعويض ، سابق ، ص ١٤٢ .

وفي هذا المعنى يقول سيادته : " تقوم هذه الحجة علي أن تحقيق الاستقلال للقاضي وضمان حريته في الفصل في القضايا يتطلب ألا تتدخل محكمة في القضايا المعروضة علي محكمة أخرى .. "

الفصل الثاني قواعد المسؤولية العقدية للإدارة عن التعويض

تمهيد :

مسئولية جهة الإدارة إما مسؤولية عقدية أو مسؤولية تقصيرية .
ونتكلم في هذا الفصل عن المسؤولية العقدية ، حيث ينعقد الاختصاص بها لمجلس الدولة باعتباره قاضي المنازعات الإدارية ، فقد نص البند الحادي عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ الصادر في ١٠/٥/١٩٧٢ (١) علي اختصاصاته : " المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر " ، كما نص البند الرابع عشر من ذات المادة علي أن مجلس الدولة يختص : " سائر المنازعات الإدارية " .
ونظراً للطبيعة الخاصة بالعقود الإدارية ، فإن لها قواعدا مميزة في مجال المسؤولية ، والتي تختلف عن تلك التي تحكم المسؤولية المدنية اختلافاً يتفق وطبيعة الإجراءات والقواعد الموضوعية التي تحسم محل النزاع (٢) .
ونتناول في هذا الفصل أهم القواعد التي تحكم المسؤولية العقدية لجهة الإدارة علي النحو الآتي :

(مفهوم المسؤولية العقدية) : المسؤولية العقدية هي تلك المترتبة علي الإخلال بالالتزامات الناشئة عن عقد من عقود الإدارة أو ما يعد مكملاً له والذي يرتب التعويض للمتعاقد ، ومناط العقد الذي تنطبق عليه المسؤولية هنا هو أن تكون الإدارة أحد أطرافه ، وأن يتصل بنشاط المرفق العام من حيث تنظيمه وتسييره بغية خدمة أغراضه وتحقيق احتياجاته مراعاة لوجه المصلحة العامة ، وما تقتضيه من تغليبها

(١) الجريدة الرسمية العدد رقم (٤٠) صادر في ١٠/٥/١٩٧٢ .

(٢) هذه الطبيعة تقوم وفقاً لما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا من أن العقد الإداري هو : " العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد شرطاً أو شروط غير مألوفة في عقود القانون الخاص " ، انظر : مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، ص ١٨٣١ ، وانظر الطعون الآتية : - الطعن رقمي ٢٨٠١ ، ٢٩٦٥ لسنة ٤٥ قضائية عليا صادر في ٢٠٠٢/١/١٥ ، المصدر : مجلة المحاماة - العدد الثالث ٢٠٠٣ ، ص ٣٥٥ .

علي مصلحة الأفراد ، وأن يأخذ العقد بأسلوب القانون العام وما ينطوي عليه من شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص سواء تضمن العقد هذه الشروط أو كانت مقررّة بمقتضى القوانين واللوائح (١) .

فإذا توافر للعقد محل النزاع هذه الأركان كان محلاً للمسئولية من حيث الاختصاص بها ، والقواعد الموضوعية التي تحكمه ، أما إذا اختل واحد منها كان عقداً مدنياً من عقود القانون الخاص ينعقد الاختصاص بنظر النزاع الناشئ عنه القضاء العادي ، وتنطبق عليه قواعد القانون المدني .

والمسئولية هنا تقوم في مواجهة الفرد أو الإدارة ؛ وكلامنا هنا عني مسئولية جهة الإدارة المدنية الناشئة عن العقد الإداري ، أما مسئولية الفرد فلن نتكلم عنها هنا ؛ لأن جهة الإدارة تملك أن تقتضي حقوقها بنفسها هذا من ناحية ، هذا علاوة أن لها من السلطات والامتيازات الاستثنائية في مجال العقود الإدارية ما لا يتوافر للفرد (٢) .

(مناطق المسئولية عن الإجراءات الممهدة للعقد) :

في نطاق هذه الإجراءات يختلف تكيفها عن تلك التي تحكم المسئولية المدنية ، ذلك أن هذه الإجراءات الممهدة للعقد ، لا تدخل في تكوينه ولا تعد جزء منه بالتالي وبالتالي تخضع لنظام قانوني مختلف عن ذلك الذي يحكم نظرية المسئولية العقدية للإدارة؛ حيث أنه في الإمكان تطبيق نظرية العمل المركب عليها مع إمكانية الفصل (٣) .

(١) مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، سابق ، ص ١٨٣٢ ، المبدأ تحت رقم : ٥٥ - ١١ (١٩٦٨/٣/٢٤) ٥٥٧/٧٥ .

(٢) العقد المدني يختلف اختلافاً جوهرياً في طبيعته وفي أساس المسئولية الناشئة عنه عن العقد الإداري ، انظر : الطعن رقم ٣٧٩٧ لسنة ٤٥ قضائية عليا صادر في ٢٠٠٢/٣/١٦ - القاعدة رقم (٣٤٩) المصدر مجلة المحاماة - العدد الثالث - ٢٠٠٣ ، ص ٣٩٥ ، ٣٩٦ ، وانظر : دكتور / سليمان الطماوي ، دروس في القضاء الإدارية - دراسة مقارنة - ملتزم الطبع والنشر : دار الفكر العربي طبعة ١٩٧٦ ، ص ٢٩٦ ، حيث يذكر في مجال تحليله للفرق بين قواعد المسئولية الإدارية والمسئولية المدنية ما يلي : " ولعل أبرز ما يميز الحلول القضائية التي وضعها مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد عن القواعد المدنية التي تحكم مسئولية الأفراد فيما بينهم ، ما يرجع إلي أساس المسئولية ، ونطاقها ... " .

(٣) قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه : " لجنة البت سواء في المناقصة أو المزايدة إنما تختص باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتعيين أفضل المتنافسين أو المترابدين وفقاً لما رسمه القانون ، وذلك حتى يتسنى للسلطة

- (أركان المسؤولية العقدية للإدارة) :

المسؤولية العقدية للإدارة مثلها في ذلك مثل المسؤولية التقصيرية تقوم علي أركان ثلاثة هي : توافر الخطأ من المسؤول ، والضرر لدى طالب التعويض ، وأن يكون الضرر ناتجاً عن الخطأ (علاقة السببية بين الخطأ والضرر) ، وفي ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٣٧٩٧ لسنة ٤٥ ق . علي . صادر في ١٦/٣/٢٠٠٣ بأن : " المادتان (١/٤٧ ، ١/٤٨) من القانون المدني . اعتبر المشرع العقد قانون المتعاقدين وشريعتها الحاكمة لكل ما يثور بشأن تنفيذه من منازعات ، ولذلك لم يجز المشرع نقضه أو تعديله إلا باتفاق طرفيه ، أو للأسباب التي يقررها القانون ، كما أوجب القانون تنفيذ العقد طبقاً لما اشتملت عليه بنوده ، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، يترتب علي ذلك أنه في حالة قعود أي من طرفي العقد عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه يكون للطرف الآخر إجباره علي ذلك بالوسائل التي جعلها القانون في يد الدائن لحمل مدينه علي الوفاء ، وفقاً للقواعد التي ينظمها القانون للتنفيذ الجبري للالتزامات بصفة عامة سواء كانت ناشئة عن الإرادة أو عن أي مصدر آخر من مصادر الالتزام ، فضلاً عن إلزامه بتعويض أية أضرار ترتبت للدائن عن تأخيره في تنفيذ التزاماته طوعية - ومن ثم فالمسؤولية العقدية عن التعويض شأنها شأن المسؤولية التقصيرية، ... فيلزم توافر الخطأ من المسؤولية، والضرر لدى طالب التعويض، وأن يكون الضرر ناتجاً عن الخطأ (علاقة سببية)

(^١)

الإدارية المنوط بها إبرام العقد مباشرة اختصاصها في هذا الشأن ، وليس من شك في أن قرار لجنة البت بإرساء المناقصة أو المزايدة إنما هو في طبيعته علي ما سلف البيان قرار إداري نهائي إذ يجمع له مقومات القرار الإداري من حيث كونه صادراً من جهة إدارية مختصة بما لها من سلطة عامة بمقتضي القانون واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني تحقيقاً لمصلحة عامة ، وليس أبلغ في الدلالة علي صدق هذا النظر من أن جهة التعاقد إنما تلتزم حال انصراف إرادتها إلي إبرام العقد بالتعاقد مع المناقص أن المتزايد الذي عينته لجنة البت وليس لها أن تستبدل به غيره " انظر في المصدر : مجموعة المبادئ - سابق ، ص ١٨٣٤ ، المبدأ تحت رقم ٤٥٦/٣٢٠ - ١٧ (١٩٧٥/٤/٥) ٣٠٧/٨٩/٢٠ .

(^١) انظر الطعن رقم ٣٧٩٧ لسنة ٤٥ قضائية عليا - صادر في ١٦/٣/٢٠٠٢ قاعدة رقم (٣٤٩) . المصدر مجلة المحاماة : العدد الثالث ٢٠٠٣ ، ص ٣٩٥ ، ٣٩٦ وانظر الطعن رقم ٢٨٠١ ، والطعن رقم ٢٩٦٥ في ١٥/١/٢٠٠٢ ، القاعدة ٣٣٦ مجلة المحاماة - العدد الثالث ص ٣٥٥ .

- (ركن الخطأ في المسؤولية العقدية الإدارية) :

- (مفهومه) : يقصد بالخطأ العقدي هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته والمرتبة أو الناشئة عن العقد أيًا كان السبب في ذلك ، يستوي في ذلك أن يكون عدم التنفيذ ناشئاً عن عمد أو إهماله ، أو فعله ، دون عمد أو إهمال ، وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا : " من الأمور المسلمة في العقود كافة ، سواء كانت عقود إدارية أو مدنية ، أن الخطأ العقدي هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة أيًا كان السبب في ذلك يستوي في ذلك أن يكون عدم التنفيذ ناشئاً عن عمد أو إهماله ، أو فعله دون عمد أو إهمال " (١).

(معيار الخطأ العقدي) : يعد المعيار الموضوعي هو الأساس في دراسة الخطأ المرتب للمسؤولية العقدية ، ويتمثل في الإخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد ، بما يخول المدعي الحق في التعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء عدم قيام المتعاقد معه بالتزامه أو بجزء منه أو بتأخره في القيام به ، سواء تم ذلك عن عمد أو إهمال ، أو فعل لا يعد من قبيل العمد أو الإهمال ، وإنما أصاب المتعاقد مع الإدارة بأضرار وفقاً لما هو مقرر في دراسة النظريات التي تؤثر علي العقود الإدارية ، سواء كانت نظرية الظروف الطارئة والظروف الاقتصادية أم نظرية عمل الأمير أم غيرهما . (٢)

(حالات المسؤولية العقدية دون خطأ) : مفهوم الفعل المرتب للمسؤولية العقدية هنا لا يشترط فيه أن يكون عملاً غير مشروع ، فقد يكون كذلك لمخالفته لالتزام

ونلاحظ هنا أن فكرة الخطأ المرتب للمسؤولية العقدية تقوم في جانب الإدارة ، كما تقوم في جانب المتعاقد معها علي السواء مع ملاحظة اختلاف المركز القانوني لكليهما في العقد الإداري .

(١) مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، سابق ص ١٨٦٢ ، تحت رقم ١٣٢٠ / ١٣٤٠ - ١٢ (١٩٦٩/٢/١٥) ٣٧٤/٤٨/١٤ .

(٢) دكتور / محمد رفعت عبد الوهاب ، أصول القضاء الإداري ، ط ١٩٩٣٦ ، ص ٢١١ . حيث يقول : " ومثل منازعات العقود الإدارية حيث يطالب المتعاقد الفرض جهة الإدارة المتعاقد معه من أجل الحصول علي حقوقه المالية المتولدة عن العقد وطبقاً للقانون والمبادئ التي أرساها القضاء الإداري في أحكامه " .

عقدي ، أو يكون فعلاً مشروعاً الحق ضرراً بالمتعاقد ، أو ظرفاً طارئاً أم صعوبات مادية غير متوقعة . (١)

(أساس المسؤولية العقدية في حالة الظروف الطارئة) : أساس المسؤولية هنا يقوم علي أنه قد تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف اقتصادية أو طبيعية أو من عمل جهة إدارية أخرى غير الجهة المتعاقدة ، أو من عمل أي إنسان آخر مما لم يكن في حساب المتعاقد عند إبرام العقد ، ولا يملك لها دفعاً ، ومن شئها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً . (٢)

- (أساس المسؤولية العقدية في حالة عمل الأمير) :

إن قيام المسؤولية الإدارية استناداً لعمل الأمير يقتضي أن يكون العمل الذي ألحق ضرراً بالمتعاقد قد صدر عن جهة الإدارة المتعاقدة معه ، فإذا ما صدر عن شخص معنوي عام غير الذي أبرم العقد ، انتفي الخطأ في جانب جهة الإدارة ، وألا يكون متوقعاً عند إبرام العقد . (٣)

- (أساس المسؤولية العقدية في حالة الصعوبات المادية غير المتوقعة) :

تقوم مسؤولية جهة الإدارة استناداً لهذه الحالة إذا كانت الصعوبات مادية وغير متوقعة عند إبرام العقد ؛ فقد قضي بأنه : " إذا كان مفاد النصوص الواردة في الشروط العامة أن الما قول مسئول مسؤولية كاملة عن جميع الصعوبات المادية التي تصادفه سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة " . (٤)

(١) هذه المسائل كلها تمثل مسائل خارجة في بعضها عن إرادة جهة الإدارة وقد دخلت في موضوع المسؤولية العقدية للإدارة علي أساس طبيعة وخصائص العقود الإدارية ؛ وحتى لا يتهيب الأشخاص التعاقدات الإدارية .

(٢) أنظر حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٥٩٠ لسنة ٤٥ ق . عليا . صادر بجلسة ٢٠٠٢/١/١٥ . المصدر : مجلة المحاماة - العدد الثالث - ٢٠٠٣ . قاعدة رقم (٢٣٥) ، ص ٣٥٥ . حيث تذكر ما يلي :

" إن تطبيق نظرية الحوادث الطارئة في الفقه والقضاء الإداري رهين بأن تطرأ خلال تنفيذ العقد الإداري حوادث .. "

(٣) مؤلفنا : القانون الإداري ، طبعه ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ، ص ٤٤٢ ، ٤٤٣ .

(٤) المجموعة ، سابق ، ص ١٨٧٩ ، ١٨٨٠ . المبدأ تحت رقم ٣١١ - ١١ (١٩٦٩/٦/١٤) ٧٧٨/١٠٣/١٤ .

إذاً في هذه الحالات السالفة وغيرها تقوم مسئولية جهة الإدارة العقدية علي الرغم من عدم وقوع خطأ من جانبها متمثل في الإخلال بالتزام عقدي ، إلا أن القضاء الإداري قد استقر علي المسئولية ضماناً لتنفيذ العقد الإداري ، واستدامة سير المرفق العام الذي يخدمه . (١)

(أمثلة من الأخطاء العقدية المرتبة لمسئولية الإدارة) :

نضرب هنا بعض الأمثلة لما عده القضاء الإداري خطأً عقدياً مرتباً للمسئولية

- (عدم إخطار المتعاقد بإنهاء التعاقد) :

إذا لم تقم جهة الإدارة بإخطار المتعاقد معها في الميعاد المقرر قانوناً بمقتضي العقد المبرم بينهما بانتهاء هذا التعاقد ، فإن الأثر المترتب علي ذلك اعتبار العقد مجدداً لسنة أخرى ، واقتضاء حقه في التعويض علي هذا الأساس . (٢)

- (عدم تسليم العمل محل التعاقد) :

إن عدم قيام جهة الإدارة بتسليم المتعاقد معها موقع العمل خالياً من العوائق مما يترتب عليه وقف العملية مدة طويلة تجاوز المعقول ، يعد إخلالاً جسيماً من جانب الإدارة مما يقوم سبباً مبرراً لاستحقاق المتعاقد معها تعويضاً عما أصابه من أضرار (٣)

- (التأخير في صرف المستحقات) :

من حق المتعاقد مع الجهة الإدارية التعويض عن التأخير في صرف ما يكون مستحقاً له ، طبقاً لأحكام العقد ؛ وهذا يقتصر علي حقه في الطالبة بالتعويض في المادة ٢٢٦ من القانون المدني ، ولا وجه لإلزام الجهة الإدارية بالتعويض عن

(١) المجموعة ، سابق ١٨٨٠ - المبدأ تحت رقم ٣٣١ - ١١ (١٤ / ٦ / ١٩٦٩) ٧٧٨ / ١٠٣ / ١٤ . وهنا نلاحظ اختلاف المسئولية العقدية عن المسئولية التقصيرية في هذا الأساس من حيث مفهوم الخطأ ، وقيام المسئولية دون خطأ تعاقدي .

(٢) أنظر : حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم - ٢٣٤ لسنة ٣٥ ق . عليا . صادر بجلسة ١٦ / ٥ / ١٩٩٥ . المصدر : مجله المحاماة - عدد مايو - أغسطس ١٩٩٥ - الجزء الثاني ، ص ٩٠ .

(٣) انظر الطعن رقم ٢٨٠١ . والطعن رقم ٢٩٦٥ لسنة ٤٥ ق عليا . صادر بجلسة ١٥ / ١ / ٢٠٠٢ المصدر : مجله المحاماة - العدد الثالث - ٢٠٠٣ قاعدة رقم (٢٣٦) ص ٣٥٥ .

التأخير في صرف تلك المستحقات علي نحو مغاير لما نصت عليه ما لم يتم الاتفاق علي غير ذلك . (١)

- (التحديد الاتفاقي للخطأ المتوقع) :

قد يحدث ويتوقع المتعاقدان خطأ معيناً ، ويتفقان علي الأثر المترتب حال حدوثه فهنا يعد هذا البند في العقد ملزماً لجهة الإدارية لا يجوز لها أن تخالفه ، وتطبق ما ورد بقانون التعاقدات الحكومية ، بحجة أن هذا الاتفاق مخالف للقانون ؛ وفي هذا قضي بأنه : " إن العقد الإداري شأنه في ذلك شأن سائر العقود يتم بتوافق إرادتين تتجهان إلي أحداث أثر قانوني معين وليس عملاً شرطياً تضمن إسناد مراكز قانونية عامة وموضوعية إلي أشخاص بذواتهم ، فإذا ما توقع المتعاقدان في العقد الإداري خطأ معيناً ووضعاً له جزاء بعينه ، فإنه يجب أن تنقيد جهة الإدارة والمتعاقد معها بما جاء في العقد ولا يجوز لأيهما مخالفته ، كما لا يصح في القانون القضاء علي غير مقتضاه " . (٢)

- (الخلاصة في بيان نوعي المسؤولية العقدية) :

نخلص في النهاية في تحديد مفهوم الركن الأول من أركان المسؤولية العقدية ، أن لهذه المسؤولية نوعان حسب الفعل المرتب للضرر :

- (النوع الأول - المسؤولية بدون خطأ) :

وهي التي تقوم في مواجهة جهة الإدارة دون وقوع خطأ من جانبها بناء علي فعل يلحق ضرر بالمتعاقد معها ، ويكون الأساس في نسبة المسؤولية لجهة الإدارة هنا هو ضمان تنفيذ العقد الإداري واستدامة سير المرفق العام الذي تخدمه ، ولكن يجب أن يكون هناك نوعاً من الصلة بين هذا الفعل وبين العقد ، إما لأنه يمثل إجراءً

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٣٣٣ لسنة ٤٥ ق عليا . صادر بجلسة ٢٧ / ١١ / ٢٠٠١ . المصدر : مجلة المحاماة - العدد الثالث - ٢٠٠٣ . القاعدة رقم (٩٣) ص ٣٠٣ . وتقول المحكمة : " من المقرر قضاء أن تنفيذ العقود ومن بينها العقود الإدارية يتعين أن يكون طبقاً لما اشتملت عليه نصوص العقد وهي التي تحدد حقوق والتزامات طرفيه وأن يكون التنفيذ طبقاً لما اشتمل عليه العقد وبطريقة تتفق مع حسن النية " .

(٢) مجموعة المبادئ القانونية ، سابق ، ص ١٨٨٣ . المبدأ تحت رقم ٥٠١ - ١٤ (١٩٧١ / ١١ / ١٣) ٩ / ٢ / ١٧ .

عاماً أثر في العقد ، أو ظرفاً أو حادثاً طارئاً غير متوقع أثر في تنفيذ العقد أو صعوبات جعلت التنفيذ مرهقاً للمتعاقد . (١)

- (النوع الثاني - المسؤولية بالخطأ) :

ويتحقق بوقوع فعل من جهة الإدارة عن عمد أو إهمال أو فعل لا يعد عمداً ولا إهمالاً ، ويكون من شأنه أن يشكل إخلالاً بالتزام من التزامات العقد ، أو ما يعد مكماً لهذا العقد .

- (ركن الضرر في المسؤولية العقدية الإدارية) :

ينبغي أن يلحق بالمتعاقد ضرر حتى تقوم المسؤولية العقدية ؛ حيث إن الضرر لا يفترض بأي حال .

ويقصد بالضرر ما لحق بالمتعاقد من خسارة مادية ، ومن ثم فإن الضرر في مجال المسؤولية العقدية يختص بالآتي :

خصائص الضرر في المسؤولية العقدية :

(أ) الضرر لا بد أن يكون مادياً قد لحق بالمتعاقد ، ومن ثم فلا وجود للضرر الأدبي في مجال المسؤولية العقدية للإدارة عن التعويض ، والضرر هنا هو الكسب الفائت والخسارة اللاحقة .

(ب) إذا كان الضرر الذي أصاب المتعاقد قد نتج عن خطأ مشترك له ولجهة الإدارة ؛ فهنا يتحمل كل منهما نصيبه من المسؤولية ، ولهذا قضى بأنه (٢) : " ومتى كان الضرر الذي أصاب المؤسسة جاء نتيجة خطأ كل من الإدارة والمؤسسة معاً (٣) "

(١) أنظر حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في ١٩٧١/٥/٢٠ ، السنة السادسة - ص ١١٣٣ - مشار إليه لدي دكتور سليمان الطماوي ، الأسس العامة للعقود الإدارية - دراسة مقارنة - طبعة دار الفكر العربي - الطبعة الرابعة ١٩٨٤ ، ص ٥٧٣ .

(٢) المجموعة، سابق ، ص ١٩١٩ ، ١٩٢ . المبدأ تحت رقم ١٣٠٣ - ٨ (٣١ / ١٢ / ١٩٦٦) ٤٨ / ١١ / ٤٩٤ . وكانت المحكمة ذكرت أنه : " متى كان تقرر بطلان العقد بطلاناً مطلقاً علي الوجه المتقدم فإن المؤسسة يصيبها كأثر حتمي لتقرير البطلان ضرر يتمثل في قيمة الأدوات التي قامت بتصنيعها والتي تبين أنها غير قابلة للتعامل وليس من سبيل إلي استردادها لمخالفتها لأحكام مرسوم الأوعية ... " .

(٣) هذا ولا يجوز للمتعاقد مع جهة الإدارة أن يمتنع عن التنفيذ بحجة أن جهة الإدارة قد أخلت بالتزاماتها ؛ بل عليه أن يستمر فيه طالما أن ذلك في إمكانه ، ويطالب بالتعويض إذا كان له مقتضي ؛ ولذا قضى بأنه : " إزاء هذه الاعتبارات أن يستمر في التنفيذ مادام ذلك في استطاعته ، ثم يطالب جهة الإدارة بالتعويض عن

، فالفرض أن المؤسسة عليمه بأحكام مرسوم الأوعية علمها بالقانون الذي لا يعذر أحد بالجهل به . وكان من المتعين عليها والحالة هذه أن تثبت من مطابقة ما تصنعه لأحكامه ، ويتمثل خطأ الإدارة في كونها طرحت المناقصة علي أساس عينة نموذجية مخالفة لأحكام مرسوم الأوعية مع ما توافر لديها من الإمكانيات الفنية التي لها الوقوف علي حقيقة الموارد الداخلة في تركيبها . وإذا كان الخطأ مشتركاً كان للقاضي أن يقدر نصيب كل من المسؤولين عن الخطأ في التعويض وفقاً لأحكام المادتين ١٦٩ ، ٢١٦ من القانون المدني ، فإن المحكمة تقدر التعويض المستحق للمؤسسة في ذمة الإدارة - بمراعاة مدي جسامة الخطأ الذي ارتكبه كل منهما " .

(ج) تختلف الأوصاف المطلوبة في الضرر بحسب الفعل الذي سببه ؛ فإذا كان عبارة عن خطأ تعاقدية لجهة الإدارة ؛ فإن المحكمة تقدر التعويض بمراعاة مدي جسامة الخطأ ؛ وفي هذه الحالة فإن أي ضرر يكفي لقيام مبدأ المسؤولية طالما كان ضرراً مادياً .

وقد يحدث أن يكون الضرر ناتجاً عن فعل لا يعد خطأ لجهة الإدارة ؛ وهنا لا بد أن يتوافر في الضرر أوصاف معينة حتى يكن مبرراً للمسؤولية العقدية لجهة الإدارة .

- (مفهوم وأوصاف الضرر في المسؤولية العقدية دون خطأ) :

١- يجب أن ينزل هذه الحادث في حالة الظروف الطارئة بالمتعاقد مع الإدارة خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً (١) ، أو بعبارة أخرى أن الظروف أو الأحداث قد قلبت اقتصاديات العقد ؛ أو إذا كان من شأن هذه الظروف أو الأحداث أنها لم تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً بل أكثر عبثاً وأكثر كلفة مما قدره

إخلالها بالتزامها ، إذا كان ذلك مقتضي ، وكان له فيه وجه حق فلا يسوغ له الامتناع عن تنفيذ العقد بإرادته المنفردة وإلا حقت مساءلته عن تبعة فعلة السلبي "

أنظر : المجموعة ، سابق ، ص ١٩١٦ . المبدأ تحت رقم ٧٦٧ - ١١ (١٩٦٩ / ٧ / ٥) ١٤ / ١٣٤ / ٩٣٢ .
(١) انظر حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٣٥٦٢ لسنة ٢٩ قضائية - عليا . صادر بجلسة ١٦ / ٥ / ١٩٨٧ . المصدر : مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا - لسنة ٣٢ قضائية - الجزء الثاني أول مارس ١٩٨٧ - ٣٠ سبتمبر ١٩٨٧ . لناشر نقابة المحامين - لجنة المكتبة والفر القانوني . قاعدة ١٨٨ ص ١٢٣٩ .

المتعاقدان التقدير المعقول ، وكانت الخسارة الناتجة عن ذلك تجاوز الخسارة المألوفة العادية التي يحتملها أي متعاقد إلي خسارة فادحة استثنائية وغير عادية . (١)
٢- وتطبيقاً لهذا قضي بأنه : " المبلغ المطالب به والذي يمثل مقدار خسارته (٢٥٠٠٠) هو بالنسبة لقيمة العقد البالغة ١١٣٦٨٤ جنية يقرب من ٢٢ % وتلك لا تمثل الخسارة الواضحة المتميزة ؛ فيختل الشرط الأساسي لتطبيق النظرية ؛ ويقتضي لذلك رفض الدعوي " . (٢)

٣- وفي قضاء آخر قررت المحكمة عدم توافر الخسارة الفادحة التي تقلب اقتصاديات العقد ؛ إذا كانت مدة التعاقد ثلاث سنوات بإيجار قدره ٧٧٢٧ جنيهاً سنوياً تدفع علي أربعة أقساط كل قسط عن ثلاثة أشهر في السنة ، فإذا كانت دودة القطن في صيف ١٩٦١ من الفداحة ؛ بحيث تعد من قبيل الحوادث الاستثنائية العامة غير المتوقعة ، فإن ضرر هذه الآفة لن يتجاوز أثره بالنسبة للطاعن ثلاثة أشهر ، ومن ثم فإن الطاعن هنا لم يصب بخسارة فادحة من شأنها قلب اقتصاديات العقد (٣) .
٤- مناط المسؤولية التي تخول للمتعاقد مع الإدارة طلب التعويض ، يستند في حالة الصعوبات المادية غير المتوقعة إلي حصول صعوبات مادية غير عادية واستثنائية ، لم يكن من الممكن توقعها بحال من الأحوال عند إبرام العقد وتؤدي إلي جعل التنفيذ مرهقاً للمتعاقد . (٤)

(١) مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا - سابق ، ص ١٨٧٧ . تحت رقم ٤٦ - ١٤ (١٩٧٢ / ٦ / ١٧) ٥٧٦ / ٨٢ / ١٧ .

(٢) حكم المحكمة في الطعن رقم ٣٥٦٢ لسنة ٢٩ قضائية - عليا ، سابق الإشارة إليه بذات المصدر .
(٣) مجموعة المبادئ ، سابق ، ص ١٨٧٨ ، المبدأ تحت رقم ٤٦ - ١٤ (١٩٧٢ / ٦ / ١٧) ٥٧٦ / ٨٢ / ١٧ .
- وانظر حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٣٥٦٢ لسنة ٢٩ ق . عليا - صادر في ١٦ / ٥ / ١٩٨٧ .
المصدر : مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا - سالف الإشارة إليه . ص ١٢٣٨ ، وقلب اقتصاديات العقد هنا علي النحو الذي يقتضي مشاركة الإدارة له فيما تحمله من خسائر يعد من المسائل التي يقدرها قاضي التعويض .

(٤) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٨٠٠ لسنة ٣٤ قضائية عليا - جلسة ١٩٩٢ / ٥ / ١٩ ، المصدر : مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا - السنة السابعة والثلاثون - العدد الثاني - من أول مارس سنة ١٩٩٢ إلي آخر سبتمبر سنة ١٩٩٢ ، مجلس الدولة - المكتب الفني - القاعدة (١٥٩) ، ص ١٤٧١ .

٥- إن مفهوم ووصف الضرر في حالة عمل الأمير تقوم علي أساس تحقق الضرر أياً كان نوعه وأياً كان جسامته ؛ فكل ضرر يلحق بالمتعاقد من جراء فعل أو إجراء للجهة الإدارية المتعاقدة يخوله الحق في التعويض (١) .

- (ركن علاقة السببية بين الخطأ والضرر) :

يعني هذا الركن أن يكون الضرر ناتجاً عن الخطأ الذي وقع من جهة الإدارة أو عن الفعل الذي ألحق ضرراً بالمتعاقد ولو كان خطأ لجهة الإدارة ؛ ومن ثم فلا تتعقد المسؤولية في حالة عدم توافر هذه العلاقة السببية ، كما لو كان الفعل الضار صادراً من شخص معنوي عام غير الذي أبرم العقد الإداري ، فهنا تختلف علاقة السببية المبررة لانعقاد المسؤولية علي أساس نظرية عمل الأمير.(٢)

وهكذا فالمسؤولية العقدية شأنها في ذلك شأن المسؤولية التقصيرية في أركانها فيلزم لقيامها توافر الخطأ من المسؤول ، والضرر لدى طالب التعويض ، وأن يكون الضرر ناتجاً عن الخطأ .

- (التعويض - حدوده ومداه) :

- (مفهومه) : تتعقد المسؤولية العقدية بتوافر أركانها ، ومن أثر ذلك استحقاق المتعاقد للتعويض المادي الذي يجبر ما أصابه من أضرار أو جزء منها علي حسب مقتضاه .

- (حدود التعويض ومداه) : التعويض يخضع لمجموعة من القواعد التي

استقر عليها مجلس الدولة في هذا الشأن وهي :

- (التعويض الجزئي) : يقصد به أن تتحمل جهة الإدارة جزءاً فقط من

الأضرار التي لحقت بالمتعاقد ويتحمل هو الجزء الباقي ، وذلك في حالة وقوع حوادث أو ظروف طارئة علي نحو ما حددنا فيما سبق ، فهنا يستحق المتعاقد أن يعرض عنها تعويضاً جزئياً ، وبذلك يضاف إلي التزامات المتعاقد معه التزاماً جديداً لم يكن محل اتفاق بينهما ، ومؤدي ذلك أن يفرض القاضي علي الدائن التزامات ينشأ

(١) مجموعة المبادئ القانونية ، سابق ، ص ١٨٧٥ ، المبدأ تحت رقم ١٠١٥٦٢ / ٦٧ - ١١ (١٩٦٨/٥/١١)

٨٧٤/١١٧/١٣ حيث تبين المحكمة أن مناط إعمال نظرية عمل الأمير هو كون الفعل الضار صادراً من

جهة الإدارة المتعاقدة ومن ثم فوفقاً لهذا لا يشترط درجة معينة من الجسامة في الضرر .

(٢) الحكم السابق ، ذات الموضع والمصدر .

من العقد الإداري ، هذا الالتزام هو أن يدفع الدائن للمدين تعويضاً لكفالة تنفيذ العقد تنفيذاً صحيحاً متى كان من شأن الظروف أو الأحداث غير المتوقعة أن تنقل كاهل هذا المدين بخسارة يمكن اعتبارها قلباً لاقتصاديات العقد (١) .

- (مدى التعويض الجزئي) : التعويض الجزئي لا يشمل الخسارة كلها ولا يغطي إلا جزءاً من الأضرار التي تصيب المتعاقد ، ومن ثم فليس للمضرور أن يطالب بالتعويض بدعوى أن أرباحه قد نقصت أو لفوات كسب ضاع عليه ، كما يجب أن تكون الخسارة واضحة ومميزة (٢)

- (التعويض الكامل) : يقصد به التعويض العادل عن الأضرار التي تلحق بالمركز التعاقدي أو تقلب ظروف العقد المالية بسبب ممارسة جهة الإدارة سلطاتها في تعديل العقد وتحويره بما يتلاءم والصالح العام ، أو بسبب خطأ ناشئ عن إخلال بالالتزام تعاقدية لها ورد بالعقد أو بالقوانين أو اللوائح التي تكمل هذا العقد ، سواء كان ذلك عن عمد أو إهمال أو عن فعل لا يعد عمداً أو إهمالاً .

ولا يشترط في الضرر الموجب للتعويض هنا أي شرط ، طالما كان ضرراً مادياً ؛ ومثل إخلالاً جسيماً من جانب الإدارة بما يقوم سبباً مبرراً لاستحقاق التعويض للمتعاقد جبراً لما أصابه من أضرار . (٣)

(١) انظر : مجموعة لمبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا - سابق - الجزء الثاني ، ص ١٨٧٧ ، المبدأ تحت رقم ٤٦ - ١٤ (١٩٧٢/٦٩/١٧) ٥٧٦/٨٢/١٧ .

وهذا التعويض علي الرغم من عدم وقوع فعل يعد خطأ من جهة الإدارة يستند إلي : " فكرة العدالة المجردة التي هو قوام القانون الإداري ، كما أن هدفها تحقيق المصلحة العامة فرائد الجهة الإدارية هو كفالة حسن سير المواقف العامة باستمرار وانتظام وحسن أداء الأعمال المطلوبة وسرعة انجازها كما أن هدف التعاقد مع الإدارة هو المعاونة في سبيل المصلحة العامة وذلك بأن يؤدي التزامه بأمانة وكفاية لقاء ربح وأجر عادل وهذا يقتضي من الطرفين التساند والمشاركة للتغلب علي ما يعترض تنفيذ العقد من صعوبات وما يصادفه من عقبات " . وهذه العدالة التي اقتضت الأخذ بنظرية الظروف الطارئة في مجال المسئولة التعاقدية للإدارة ، أخذاً عن نظرية القانون المدني .

(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٥٩٠ لسنة ٤٥ قضائية - عليا - صادر بجلسة ٢٠٠٢/١/١٥ ، المصدر : مجلة المحاماة - العدد الثالث ، ٢٠٠٣ ، ص ٣٥٥ .

(٣) راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٢٨٠١ و ٢٩٦٥ لسنة ٥٠ - عليا - صادر بجلسة ٢٠٠٢/١/١٥ ، المصدر : مجلة المحاماة - العدد الثالث ، ٢٠٠٣ ، ص ٣٥٥ .

وينصرف التعويض العادل هنا إلي ما لحق بالمتعاقد من خسارة وما فاتته من كسب ، ويقدر ذلك القاضي في ضوء ظروف وملابسات هذا العقد ، بما يحقق فكرة العدالة في التعويض . (١)

ونلاحظ أن وصف الإخلال الجسيم الوارد بهذا الحكم لا يعني تطلب درجة معينة من الجسامة بالنسبة للضرر ؛ وإنما تعني عبارة المحكمة أن الامتناع عن تسليم محل التعاقد يعد إخلالاً جسيماً بحق المتعاقد .
(١) انظر : حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٢٣٤٠ لسنة ٣٥ ق . عليا . بجلسة ١٦/٥/١٩٩٥ - المصدر : مجلة المحاماة - عدد مايو - أغسطس ١٩٩٥ - الجزء الثاني - ص ٩٠ - قاعدة (٤٠) .

الفصل الثالث

قواعد المسؤولية التقصيرية للإدارة عن التعويض

تمهيد وتقسيم :

النوع الثاني من المسؤولية الإدارية هو المسؤولية التقصيرية ، والتي أصبحت تسود في معظم النظم القانونية تبعاً لقواعد العدالة المجردة التي تتطلب تقرير المسؤولية عن الأضرار حتى ولو كان مصدرها الإدارة ؛ ومن ثم يقوم في وجهها مبدأ المسؤولية في جانبها التقصيري (١).

حيث إنه كان من السائد حتى نهاية القرن التاسع عشر عدم مسؤولية الإدارة ، وقد تخلف عن ذلك الإضرار بمصالح الأفراد وحقوقهم ؛ ومن ثم فقد ظهرت عدة تطورات دفعت بمبدأ تقرير المسؤولية عن أعمال الإدارة ؛ وغدا من المبادئ المستقرة في القانون والقضاء علي السواء هو : مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة الإدارية (٢) ونحن بدلاً من الدخول في تفاصيل تاريخية ليس هنا محلاً لعرضها ، نعقد الكلام في هذا الفصل عن المسؤولية التقصيرية من خلال الموضوعات التالية :

- (مفهوم المسؤولية التقصيرية ومجالها) :

المسؤولية التقصيرية للإدارة تقوم علي مخالفتها لالتزام مصدره القوانين أو اللوائح التي تضبط النشاط الإداري علي أساس نظرية الخطأ كمبدأ أو أساس آخر

(١) دكتور / سليمان الطماوي ، دروس في القضاء الإداري ، سابق ، ص ٢٦١ - ٢٦٢ ، حيث يذكر أن : " مبدأ مسؤولية الإدارة - علي الأقل عن تصرفاتها غير المشروعة - عن طريق قضاء التعويض ، إذا كان مسلماً به في الوقت الحاضر في جميع الدول علي وجه التقريب ، فإن القاعدة كانت عكس ذلك تماماً في القديم . فقد كانت القاعدة حتى أواخر القرن الماضي في معظم دول العالم ، هي عدم مسؤولية الدولة (أو الإدارة) عن أعمالها ، فلما بدأ تدخل الدولة يزداد ، وتعددت الأضرار التي تصيب الأفراد نتيجة لهذا التدخل ، بدأ الرأي العام يشكك في سلامة مبدأ عدم مسؤولية الدولة "

(٢) دكتور / محمد رفعت عبد الوهاب ، أصول القضاء الإداري ، سابق ، ص ٢١٣ ، ٢١٤ ونلاحظ هنا مسألة هامة تتصل بأن مسؤولية - الدولة قد تتأثر أحياناً بالظروف السياسية السائدة في الدولة من حيث تطبيق نظام الحكم الرشيد من عدمه ، ذلك أن نظام الحكم الرشيد تكون فيه مسؤولية الحكومة واضحة ، وبالتالي فمسؤولية الإدارة تكون مضبوطة بسيادة القانون دون استثناءات مرتبطة بتأثيرات خلاف هذا المبدأ ، هذا عكس نظم الحكم غير الرشيدة التي يشيع فيها عدم احترام القانون ، ومن ثم تعاني مسؤولية الإدارة من عدة مشكلات في الواقع العملي .

كاستثناء ، حيث إن الإدارة ليست مطلقة من كل قيد قانوني ؛ بل هناك مجموعة من النصوص التي مصدرها القانون أو اللائحة أو غيرها والتي تحدد للنشاط الإدارية حدوده إما بطريقة مقيدة أو تقديرية ، وذلك تحقيقاً لمبدأ المشروعية التي يقتضي خضوع الجميع لحكم القانون، وهو عبارة عن قواعد مرسومة ومحددة سلفاً لا ينبغي مخالفتها ، فإذا خرجت الإدارة عن هذه الحدود وتلك القيود ، بما أحدث ضرراً بحقوق ومصالح الأفراد أو حرياتهم عدت مسئولة مسئولية تقصيرية مصدرها مخالفة القواعد القانونية بالمعني الواسع ، أو بناء المسئولية علي غير نظرية الخطأ مثل نظرية المخاطر. (١)

- (أوجه الاختلاف بين المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية) :

تقوم أوجه التميز والاختلاف بين هاتين المسئوليتين من عدة جوانب :

(الجانب الأول - مصدر الالتزام) :

تقع المخالفة في المسئولية العقدية لالتزام مصدره قانون العقد ، سواء تم ذلك بالمخالفة لالتزام تعاقدية ، أو لأفعال تعد خطأ عقدياً أو لا تعد خطأ بل مرتبطة بالعقد من ناحية ، ويجب علي الإدارة أن تتدخل لحملها مراعاة لحسن سير المرفق . أما في المسئولية التقصيرية ، فإن مصدر الالتزام هو واقعة تمثل مخالفة للقاعدة القانونية أياً كان مصدرها ، والتي تقيد الإدارة في نشاطها مراعاة لمصالح الأفراد ، فإذا ما خرجت عنها وحدث ضرر بتلك المصالح ، انعقدت المسئولية التقصيرية للإدارة ، دون أن يكون هناك عقد ، بل هناك واقعة .

(الجانب الثاني - طبيعة المسئولية) : تتبع المسئولية العقدية من المخالفة

لقانون العقد ، وهو إرادة مشتركة لجهة الإدارة والمتعاقد معها ، ومن ثم فتوجد بينهما علاقة تعاقدية ، تؤثر بعد ذلك في المسئولية سواء عن عمد أم إهمال أم فعل لا يعد عمداً أو إهمالاً (٢).

(١) دكتور / سليمان الطماوي - دروس في القضاء الإداري ، سابق ، ص ٢٦٢.

(٢) الأصل وطبيعة المسئولية هي التي تبرز الاختلاف بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية في مجال مفهوم الأركان والآثار المترتبة عليها .

أما في المسؤولية التقصيرية فتقع لمخالفة لقانون عام الإدارة كما يقيد غيرها بعدم الإضرار بالآخرين ، ومن ثم فهي التزامات عامة يتعين علي الإدارة مراعاتها ، وعدم مخالفتها عمداً أو إهمالاً ، ومقياس المخالفة هنا هو العمد أو الإهمال ، فإذا لم يتحقق فلا تنعقد المسؤولية.

(الجانب الثالث - معيار التحديد) : إن المعيار الذي يعتمد عليه في تحديد المسؤولية العقدية ينظر فيه إلي تحقق المخالفة للالتزام عقدي أو ما يعد قانوناً مكملاً للعقد ، ومن ثم يبحث فيه عن تحقق الضرر ، استناداً لفعل بالنظر إلي قانون العقد الذي يعد معياراً في تحديد المخالفة (١).

أما في المسؤولية التقصيرية ؛ فإنه يتبع في شأنها ما إذا كان فعلاً ما يعد مسؤولية تقصيرية ، بالنظر إلي قوانين تحدد الالتزامات الملقة علي عاتق الجميع بمن فيهم جهة الإدارة ، أو إلي قواعد تحدد التزامات الإدارة بوجه خاص وغير الناشئة عن عقد (٢).

- (مجال المسؤولية التقصيرية) :

بقصد بمجال المسؤولية التقصيرية الأعمال الصادرة عن جهة الإدارة والتي تنعقد بها مسئوليتها ، وهي إما أعمال قانونية ؛ أو مادية :

فهناك القرارات الإدارية غير المشروعة ؛ فقد يحدث وتصدر جهة الإدارة قراراً لها ؛ ويترتب عليه ضرر لأفراد ؛ ومن ثم فقد يقوم هنا البحث عن توافر المسؤولية التقصيرية لجهة الإدارة في نطاق نظرية القرار الإداري ، من حيث دراسة أركانه

(١) ونلاحظ هنا أن هذا الجانب نابع من طبيعة المبادئ التي تحكم العقود الإدارية ، وفي هذا قضت المحكمة الإدارية العليا بأن : " من المبادئ المقررة أن العقود الإدارية تتميز بطابع خاص ؛ مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة علي مصلحة الأفراد الخاصة ، ولما كان العقد الإداري يتعلق بمرفق عام فلا يسوغ للمتعاقد مع الإدارة أن يتمتع عن الوفاء بالتزاماته حيال المرفق ؛ بحجة أن ثمة إجراءات إدارية قد أدت إلي الإخلال بأحد التزاماتها قبله ، بل يتعين عليه إزاء هذه الاعتبارات أن يستمر في التنفيذ مادام ذلك في استطاعته ثم يطالب جهة الإدارة بالتعويض عن إخلالها بالتزاماتها إن كان لذلك مقتضي وكان له فيه وجه حق فلا يسوغ له الامتناع عن تنفيذ العقد بإرادته المنفردة وإلا حقت مسألته عن تبعه فعله السلبي " .

انظر : مجموعة المبادئ القانونية/ سابق ، ص ١٨٧٦ ، المبدأ تحت رقم ٧٦٧ - ١١ (١٩٦٩/٧/٥) ٩٣٢/١٢٤/١٤

(٢) دكتور / محمد رفعت عبد الوهاب ، أصول القضاء الإداري ، سابق ، ص ٢١٢ .

وشروطه، وما خالفته الإدارة منها ، حتى تتعقد مسئوليتها ، وذلك كالقرار الصادر بمنع شخص من السفر للعلاج ، فيصاب الفرد بأضرار ، ثم يتضح بعد ذلك عدم مشروعية هذا القرار .

كذلك تتعقد المسؤولية التقصيرية لجهة الإدارة عن أعمالها المادية ، وهي الأعمال الصادرة عن جهة الإدارة دون أن تتجه إرادتها إلي أحداثها .
ومن ثم فإن مجال المسؤولية الإدارية التقصيرية ، هو القرارات الإدارية غير المشروعة والأعمال المادية (١) .

(مفهوم المسؤولية التقصيرية وقواعدها بين الجهات الإدارية بعضها البعض) :
قبل أن نبدأ بالحديث عن المسؤولية التقصيرية لجهة الإدارة في مواجهة الغير - يجدر بنا أن نعقد هذه النقطة للكلام عن المسؤولية التقصيرية عن الأضرار التي يحدثها شخص معنوي عام بشخص معنوي عام آخر ، وينعقد الاختصاص بنظر النزاع هنا للجمعية العمومية لقسمي التشريع بمجلس الدولة، فتختص بنظر المسؤولية التقصيرية في النزاعات التي تقوم بن الجهات الإدارية بعضها البعض ، ولا تدخل من ثم في اختصاص القسم القضائي.
ومن الأهمية هنا أن نقف علي ما استقرت عليه الجمعية العمومية من قواعد هذا الشأن:

(القاعدة الأولى- معيار الاختصاص بمسؤولية الجهة الإدارية التي تتعقد أمام الجمعية العمومية) :

استظهرت الجمعية العمومية أن الجهة التي تلجأ إليها لحسم نزاع بينها وبين جهة إدارية أخرى ، يتطلب ذلك أن يكون هذا النزاع قد نشأ بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض وهي جميعاً من أشخاص القانون العام .

(١) دكتور / سليمان الطماوي ، دروس في القضاء الإداري ، سابق ، ص ٣٣١ .

وتتحسر ولاية الجمعية العمومية بنظر المنازعات عن تلك التي يكون أحد أطرافها شخصاً من أشخاص القانون الخاص ، ولو كان الطرف الآخر في المنازعة من أشخاص القانون العام ، وبناءً على ذلك لا يدخل في اختصاص الجمعية ما يلي :

(أ) النزاع الذي تمثل فيه الأوقاف باعتبارها نائبة عن الوزير - ناظر الوقف على أساس أن نشاط وزير الأوقاف ومن بعده هيئة لأوقاف في قيامها على شئون الأموال الموقوفة - إنما هو نشاط ناظر الوقف ، وهو من أشخاص القانون الخاص فلا يتحقق للهيئة بهذه المثابة الوصف القانوني الذي يتطلبه نص المادة (٦٦) من قانون مجلس الدولة في جميع النزاعات لكي ينعقد اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع (١).

(ب) شركات توزيع الكهرباء والتي ضمت إليها محطات توليد الكهرباء وملحقاتها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، وأصبحت بالتالي خاضعة لقانون الشركات المساهمة، وبهذه المثابة فقد أصبحت من أشخاص القانون الخاص (٢)

(ج) إذا كان طرفا النزاع يندمجان في كيان قانوني واحد أي شخص من أشخاص القانون العام واحد ذمته المالية واحدة؛ فإننا لا نكون بصدد نزاع مما يدخل في اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، كما هو الحال في النزاع الذي يقوم بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة بإحدى المحافظات، فالمحافظة هنا كيان قانوني واحد تتبعه كلتا المديريتين. (٣)

- (القاعدة الثانية - بناء المسؤولية بين الجهات الإدارية) :

(١) فتوى الجمعية رقم ٣٠٧ بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٣١ ملف رقم ٣٢/٢/٣٠٩٤ ، المصدر: مجلة المحاماة - العدد لأول - ٢٠٠٣ ، ص ٤٤٨ ، وقد انتهت إلي : " ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل بين هيئة الأوقاف بصفتها نائبة عن الوزير ناظر الوقف والهيئة العامة للأبنية التعليمية في شأن فسخ عقد البذل المتعلق ببعض الأراضي الموقوفة ، ومن ثم فإن الفصل فيه يخرج عن اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ولا يغير من ذلك إحالة النزاع إلي الجمعية العمومية بحكم من محكمة استئناف القاهرة للقول بالالتزام بنظره تطبيقاً لنص المادة ١١٠ من قانون المرافعات ذلك أن هذا النص لا يقيد الجمعية العمومية لأنها لا تعد محكمة بالمعنى الذي عناه المشرع في المادة المذكورة " .

(٢) فتوى الجمعية رقم ٣٠٥ بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٣١ ملف رقم ٣٢/٢/٣١٠٣ ، المصدر السابق ، ص ٤٤٩ .

(٣) فتوى رقم ٢٤٧ بتاريخ ٢٠٠٠/٥/١٠ ملف رقم ٣٢/٢/٣٠٦٩ ، المصدر مجلة المحاماة - العدد الأول ، ٢٠٠١ ، ص ٤٤٩ .

من المتصور هنا بناء المسؤولية بين جهات الإدارة في بعض الحالات استناداً إلى فكرة الخطأ المفترض علي النحو الآتي :

١- استظهرت الجمعية العمومية أن الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له مكنة السيطرة علي الشيء يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير ، فإذا أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ في جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشيء الخاضع لحراسته ولا تنتقل هذه الحراسة إلي تابعه المنوطة به استعمال الشيء لأنه وإن كان التابع له السيطرة المادية علي الشيء وقت استعماله ، إلا أنه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقي تعليماته مما يفقده العنصر المعنوي للحراسة ويجعل المتبوع هو الحارس علي الشيء كما لو كان هو الذي يستعمله . (١)

٢- لا يعفى المتبوع من التزامه السابق إلا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبي رغم ما بذله من عناية في الحراسة، وقد يكون السبب الأجنبي قوة قاهرة أو حادثاً مفاجئاً أو خطأ المضرور أو الغير .

٣- الثابت من الأوراق أن السيارة التابعة لوزارة الداخلية (الإدارة العامة للأمن المركزي بالإسكندرية) رقم ١٧٤٠٥ شرطة اصطدمت بأتوبيس الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية رقم ٢٥٢١ مما أحدث به التلفيات الثابتة بالأوراق وقضي بمسؤولية سائقها بغرامة مقدارها عشرون جنيهاً وتم التصديق علي الحكم ، وكن الثابت أن السيارة المتسببة في وقوع الحادث في حراسة وزارة الداخلية باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها وقت الحادث ولم يثبت من الأوراق أن ثمة سبباً أجنبياً أدى إلي حدوث تلك الأضرار ومن ثم تضحى وزارة الداخلية مسئولة

(١) الفتوى رقم ١٠٠ بتاريخ ٢٩/٢/٢٠٠٠ ملف رقم ٣٢/٢/٣١٠٢ المصدر: مجلة المحاماة- العدد الأول ٢٠٠١، ص ٤٠٩ . وفي ذات التطبيق الفتاوى الآتية :- فتوى رقم ١٠٥ بتاريخ ٢٩/٢/٢٠٠٠ ملف رقم ٣٢/٢/١٩٩٥، مصدرنا في هذه الفتاوى : مجلة المحاماة - العدد الأول - ٢٠٠١ ، ص ٤٢٥ .

عن تعويض الهيئة عن الأضرار التي حاقّت بالأتوبيس التابع لها وأداء قيمة تكاليف الإصلاح لتلك التلفيات والتي قدرت بمبلغ ١١٧.٢١ جنيهاً . (١)

- (القاعدة الثالثة - تعويض عن المصروفات الإدارية) : استقرت الجمعية العمومية علي أنه لا تتحمل الجهات الإدارية فيما بينها سوي التعويض عن الأضرار الفعلية، دون المصاريف الإدارية ، إلا إذا اتصل الأمر بتقديم خدمات فعلية تطبيقاً لحكم المادة ٥١٧ من اللائحة المالية للميزان والحسابات (٢) .

(القاعدة الرابعة - لا تعويض عن الكسب الفائت) : لا تعوض الجهة الإدارية عن الكسب الفائت نتيجة للحادث ؛ حيث أفتى تطبيقاً لهذا بأنه : " عدم أحقية الهيئة فيما تطالب به من تعويض عما فاتها من كسب نتيجة تعطل الأتوبيس بسبب الحادث إذ ينبغي عليها أن تتجرد عن المطالبة به إعمالاً لتصحيح المقتضيات التي من أجلها ضرب الصنف عن المطالبة بالفوائد التأخيرية، فيما يثور من أنزعة بين الجهات الإدارية بعضها البعض علي نحو ما جري عليه إفتاء الجمعية العمومية أيضاً في هذا الصدد " . (٣)

(١) انظر : الفتوى رقم ١٠٠ بتاريخ ٢٠٠٠/٢/٢٩ ملف رقم ٣١٠٢/٢/٣٢ المصدر : مجلة المحاماة - العدد الأول - ٢٠٠١ ، ص ٤٠٩ ، وفي ذات المبدأ الفتوى رقم ١٠٥ بتاريخ ٢٠٠٠/٢/٢٩ ملف رقم ٣١٠٢/٢/٣٢ المصدر السابق - ص ٤٢٤ ، ٤٢٥ .

(٢) انظر : الفتوى رقم ١٠٥ بتاريخ ٢٠٠٠/٢/٢٩ ملف رقم ٣١٠٢/٢/٣٢ ، المصدر السابق ، ص ٤٢٥ ، حيث قررت الجمعية ما يلي : دون ما زاد علي ذلك من المصروفات الإدارية أخذاً بما جري عليه إفتاء الجمعية العمومية كما أنه لا محل للمطالبة بالمصروفات الإدارية بين الجهات بعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولاً علي حكم المادة (٥١٧) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لا يتوافر في الحالة المعروضة " .

(٣) انظر : الفتوى رقم ١٠٠ بتاريخ ٢٠٠٠/٢/٢٩ ملف رقم ٣١٠٢/٢/٣٢ ، المصدر السابق ، ص ٤٠٩ ، والفتوى رقم ٧٦ بتاريخ ٢٠٠٠/٢/١٥ ملف رقم ٣١٠١/٢/٣٢ ، المصدر السابق ذات الموضوع ، والفتوى رقم ٢ بتاريخ ٢٠٠٠/١/١١ ملف رقم ٢٢٩١/٢/٣٢ ، المصدر السابق ، ص ٥٠٧ .

الفصل الرابع المسئولية التقصيرية للإدارة علي أساس الخطأ

مدخل :

تقوم الإدارة بنشاطها لتحقيق الصالح العام ، ويتمثل ذلك في الضبط الإداري وما يقتضيه من التدخل في حريات الأفراد ، أو المرفق العام الذي تقوم به جهة الإدارة لإشباع حاجة عامة ، والإدارة في نشاطه تعتمد علي أسلوبين وهما : القرار الإداري والعقد الإداري ، أما الأخير فقد سبق الحديث عنه في قواعد المسئولية في نطاقه في الفصل الثالث .

وبالتالي تظل مسئولية جهة الإدارة عن الأضرار التي تترتب علي القرار الإداري هي محل المسئولية التقصيرية التي تتعقد في مواجهتها حيال الأشخاص ، وهذه القرارات أعمال إدارية اتجهت إرادة الإدارة إليها .

ويضاف إلي ذلك ؛ مسئولية الإدارة عن الأعمال المادية غير الإدارية التي تحدث الأضرار بالآخرين، وفي الحالتين لابد من توافر أركان المسئولية وهي: "الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما".^(١)

وهذا هو الأساس الأول لقيام مسئولية الإدارة التقصيرية وهي : المسئولية استناداً إلي خطأ الإدارة سواء تمثل في قرار إداري أو عمل مادي .

(ركن الخطأ) : تتطلب المسئولية بوجه عام مدنية أو إدارية ، وسواء أكانت عقدية أم تقصيرية ضرورة توافر ركن الخطأ ، حيث إن ذلك مفترض جوهري لانعقادها فلا مسئولية دون خطأ كمبدأ عام .^(٢)

وندرس هذا الركن في المسئولية التقصيرية للإدارة من خلال تحديدنا لمفهومه ومعايير علي النحو الآتي :

(أولاً - مفهوم الخطأ) : الخطأ في اللغة ضد الصواب ، وقد يمد ، وقرئ بهما قوله تعالى " إلا خطأ وأخطأ وتخطأ : بمعنى ، ولا تقل أخطيت وبعضهم بقوله ،

(١) فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم ٦١٣ بتاريخ ٢٠٠٠/١١/٤ ملف رقم ٣١٥٥/٢/٣٢ ، المصدر ، مجلة المحاماة - العدد الأول ٢٠٠١ ، ص ٤٩٠ ، ٤٩١ ، قاعدة رقم (٤) .

(٢) فتوى الجمعية العمومية رقم ٦١٣ ، المصدر السابق ، ذات لموضع .

والخطأ الذنب وهو مصدر خطئ بالكسر . والاسم الخطيئة ، ويجوز تشديدها ، والجمع الخطايا ، أبو عبيدة : خطئ وأخطأ بمعنى ، ومنه المثل " مع الخواطي سهم صائب " الأموي : المخطئ من أراد الصواب فصار إلي غيره ، والخطئ من تعمد ما لا ينبغي وتخطأ له في المسألة : أخطأ . (١)

أما مفهوم الخطأ اصطلاحاً (٢) ؛ فقد أثار خلافاً حول تحديد المقصود به في الفقه والقضاء علي الوجه الآتي :

١- يذهب رأي في فقه القانون المدني إلي أن مفهوم الخطأ كأحد أركان المسؤولية بوجه عام ، وذلك حسب الاتجاه الغالب في الفقه هو : " الإخلال بواجب سابق ، ويرى أصحاب هذا الاتجاه بأنه ينبغي أن تحدد ماهية هذه الواجبات علي وجه الدقة " (٣)

٢- في رأي محكمة النقض أن الخطأ يتوافر عندما يكون هناك انحراف عن السلوك المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر (٤) .

٣- مفهوم الخطأ في الفقه الإسلامي هو في نظر البعض من المحدثين : " الخطأ أو التعدي الموجب للضمان ، وهو السلوك مسلماً مخالفاً لما ألزم به الشارع ، سواء بترك الواجب أو ارتكاب المحرم ، أو بعدم التحوط والتبصر في أداء المباحات ، ولا إشكال في ضبط الخطأ أو التعدي بترك واجب أو فعل محرم ، لأن مرجعه هو الأحكام الشرعية ، وإنما الإشكال في ضبط مدى التحوط الواجب في ممارسة

(١) مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي - طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر ، ص ١٠ ، باب الهمزة فصل الخاص ، وانظر : المعجم الوجيز - صادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة - طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم ، ١٩٩٥ ، ص ٢٠١ .

(٢) حديثنا هنا عن المفهوم العام بغض النظر عن نوع المسؤولية .

(٣) دكتور / عصام أحمد البهجي ، تعويض الأضرار الناتجة عن تطبيقات الهندسة الوراثية في ضوء قواعد المسؤولية المدنية ، بحث منشور بمجلسة هيئة قضايا الدولة - العدد الثاني - السنة التاسعة والأربعون - أبريل - يونيه ٢٠٠٥ ، ص ٧٠ . ويقول سيادته ما نصه : " ويضيف البعض بأنه لا يمكن قصر الخطأ علي الإخلال بالتزام منصوص عليه صراحة في القانون وإلا ترتب علي ذلك تضيق نطاق المسؤولية مما يهدد تحقيق العدالة وحماية المضرور ، وبهذا فإنه من المستقر أن الخطأ يتوافر عند الإخلال بالتزام قانوني غير منصوص عليه " .

(٤) حكم المحكمة في الطعن رقم ٤٠ لسنة ٤٣ ق. صادر في ١٠/٣٠/١٩٧٨ ، مشار إليه في المصدر السابق ، ص ٧١ .

المباحات ، لاختلافه من موقف إلي آخر باختلاف الظروف والعوامل التي ينبغي اعتبارها للحكم بالتقصير والإهمال ، وقد أحال الفقهاء ضبط ما أوجبه الشارع من تحوط وتبصر إلي أعراف لتتاس وعاداتهم في التعامل والسلوك بناءً علي ما تقضي به قواعد إعمال العرف " . (١)

٤- مفهوم الخطأ في مجال المسؤولية التقصيرية للإدارة يقتضي وضع تعريف محدد له يعد بمثابة إسترشاد في بيان جوهره ، ولذا يذهب البعض إلي تعريفه بأنه : " هو أن تقوم الإدارة بعمل مادي أو قرار إداري ، ويكون هذا العمل أو القرار مخالفاً لنصوص القوانين أو اللوائح التي كان علي الإدارة مراعاتها في نشاطها الإداري ، فالخطأ يتمثل في مخالفة قانونية في عمل مادي أو قرار إداري صدر عن جهة إدارية " . (٢)

وهذا الرأي لم يحدد تعريفاً دقيقاً لمفهوم الخطأ ؛ لأن أي تعريف ينبغي أن يحدد جوهر ومضمون المعرف وليس مجاله ؛ لأن مجال المسؤولية التقصيرية للإدارة هو القرار الإداري أو العمل المادي، وليس هذا أو ذاك بمثابة ضبط لمضمون فكرة الخطأ ذاتها .

٥- لم يرد في القانون المدني أي تعريف للخطأ في المسؤولية التقصيرية ، وكل ما نصت عليه المادة ١٦٣ أنه : " كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض " . (٣) وكذلك لم يرد في أي تشريع في مجال القانون الإداري ضبط دقيق لهذا التعريف ، (٤) جرياً علي عهد المشرع بعدم الاعتناء بوضع التعريفات وترك

(١) دكتور / محمد أحمد سراج ، ضمان العدوان في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة بأحكام المسؤولية التقصيرية في القانون ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ١٩٩٠ ، ص ١٤٤ ، حيث يضيف أنه : " ويستند معيار مخالفة المعتاد إلي ما أوجبه الشارع من تحوط وتبصر ، منعاً للإضرار بما منعه الشارع وحماه من مصالح ؛ وهذا هو معنى تقييد فعل المباح بوصف السلامة في منصوص القاعدة الفقهية ، وتخصيص الوصف المقيد بتلك الأضرار " .

(٢) دكتور / محمد رفعت عبد الوهاب ، أصول القضاء الإداري ، سابق ، ص ٢١٥ .

(٣) دكتور / سليمان محمد الطماوي ، دروس في القضاء الإداري ، سابق ، ص ٣٤٤ - ٣٤٦ .

(٤) وتذهب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني إلي أن لفظ الخطأ في هذا المقام يغني عن سائر النعوت .. كاصطلاح " العمل غير المشروع " أو " العمل المخالف للقانون " أو " الفعل الذي يجرمه القانون " .. الخ . فهو يتناول الفعل السلبي (الامتناع) والفعل الإيجابي ، وتتصرف دلالته إلي مجرد الإهمال والفعل العمد علي حد سواء .

هذه المهمة للقضاء والفقهاء ، حتى لا يقيد بذلك التعريف سنة التطور التي تدخل علي المضامين باستمرار ؛ ومن ثم فوضع تعريف محدد قد يعوق الاجتهاد في فهم النص أو سبر أغواره . (١)

٦- **يذهب رأي إلي تعريف الخطأ :** " بمعيار مجرد وهو تصرف الرجل العادي إذا وجد في نفس الظروف الخارجية التي يوجد فيها مرتكب الفعل الضار ، بغض النظر عن ظروف المخطئ الخاصة ، وعلي هذا إذا كان الخطأ منسوباً إلي موظف معين ، كان المقياس هو تصرف الموظف العادي، إذا وجد في عين الظروف الخارجية التي يوجد فيها الموظف المنسوب إليه الفعل الضار . وإذا كان الخطأ منسوباً إلي الإدارة ذاتها، فالقياس يكون بالنسبة كما ينتظر من إدارة علي قدر متوسط من التنظيم" (٢)

ونحن نرى أن هذا الرأي لم يصل إلي تعريف دقيق لمفهوم الخطأ كأحد أركان المسؤولية التقصيرية ، لأنه يبني هذا المفهوم علي أسس القانون المدني ، ولم يقدم بالتالي معياراً واضحاً لبيان مضمون الخطأ بغض النظر عن نوعه ومجاليه . (٣)

٧- **لذا فنحن نرى أن تحديد المقصود بالخطأ في المسؤولية التقصيرية للإدارة يقتضي بيان الآتي :** (١)

(١) وأحياناً يلجأ المشرع إلي منه في التعريفات وهو التعريف بالمثال ، وذلك بضرب بعض الأمثلة لما يدخل في نطاق ما ينطبق عليه العرف .

ونحن نرى أن هذا لا يصلح في مجال تعريف الخطأ ؛ لأنه لا يمكن حصرها في مجال واحد أو حالات معينة بذاتها ؛ لأن الأخطاء مما لا يقبل حصره ولا تحديده

(٢) دكتور / سليمان الطماوي ، دروس في القضاء الإداري ، سابق ، ص ٤٥ .

(٣) وغني البيان اختلاف معايير وزن التصرف الإداري مقارنة بالتصرف المدني ؛ تقول المحكمة الإدارية العليا : " إن الرقابة القضائية علي تصرفات الإدارة ليست حقيقة علي قدر واحد بالنسبة لجميع التصرفات الإدارية بحسب المجال الذي تتصرف فيه ومدى ما تتمتع من حرية وتقدير في التصرف وهي تضيف حقيقة في مجال السلطة التقديرية حيث لا يلزم القانون الإدارة بنص يحد من سلطتها أو يقيد من حريتها في وسيلة التصرف أو التقدير إلا أن هذا لا يعني بدأ أنها سلطة مطلقة وأن الرقابة القضائية تكون في هذه الحالة منعدمة ، بل أن الرقابة القضائية موجودة دائماً علي جميع التصرفات الإدارية لا تختلف في طبيعتها وإن تفاوتت فقط في مداها وهي تتمثل في هذا المجال التقديري في التحقيق من أن التصرف محل الطعن يستند إلي سبب موجود مادياً وصحيح قانوناً وأنه صدر مستهدفاً الصالح العام"

انظر : مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية في خمسة عشر عاماً. سابق - الجزء الثاني ، ص

١٤٢١ ، المبدأ ٣٧٤-١٣ (١٩٦٨/٥/٢٥) ١٣/١٣٢/٩٨٢ .

(أ) مفهوم الخطأ المدني يختلف عن الخطأ الإداري من حيث أطرافه ؛ فأطراف المسؤولية التقصيرية للإدارة هما : المضرور ، وجهة الإدارة التي يقع الفعل المسبب للضرر من قبل موظفيها وعمالها ، أما المسؤولية التقصيرية في القانون المدني ؛ فهي بين أشخاص القانون الخاص ، ولا تدخل جهة الإدارة طرفاً في الموضوع .

(ب) تنطبق علي المسؤولية في القانون المدني قواعد هذا القانون ؛ بينما تنطبق عليها في القانون الإداري قواعد المسؤولية الإدارية ، كما ينعقد الاختصاص بالأولي للقضاء العادي ، وبالثاني للقضاء الإداري ؛ والأخير قضاء إنشائي ، يقتصر علي تطبيق قواعد القانون ، فقد يعوزه النص ، فيبتدع الحلول المناسبة للمنازعات المطروحة عليه ، وقد يكون تلمس هذا الحل في القانون المدني في ضوء ما يتفق مع طبيعة المنازعة الإدارية .

(ج) إن القضاء الإداري لم يضع تعريفاً للخطأ في جوهره ؛ بل تعرض لهذا للتعريف من خلال التفرقة التي أرساها بين الخطأ الشخص والخطأ المصلحي ؛ ومن ثم فهو يراجع كل حالة علي حدة ، وفي ضوء ظروفها وملابساتها ، ويستنتج الخطأ منها ، ويبني قضائية علي هذا الأساس .

(د) إن الخطأ في المسؤولية التقصيرية للإدارة هو : كل فعل إيجابي أو سلبي يمثل مخالفة لالتزام ملق علي جهة الإدارة بمقتضي الواجب العام أو الواجب الخاص ذي الطبيعة الإدارية ، (٢) ويكون ذلك في غير ما هو مصدر لالتزام تعاقدية . ولما كانت الأشخاص الإدارية أو ما يطلق عليه أشخاص القانون العام تعد أشخاصاً اعتبارية لا إرادة حقيقية لها ولا قدرة طبيعية لها علي إحداث الأضرار بالغير ؛ فإنه يتم التصرف عنها بمقتضي موظفيها أو عمالها الذين يعبرون عن إرادة

(١) دائماً ما يربط الفقهاء المسؤولية الإدارية بأصول القانون المدني في إطار المبادئ العامة للمسؤولية ، لأن مسؤولية الإدارة في الحقيقة هي مسؤولية مدنية عن التعويض ؛ ومن ثم فالاختلاف ليس في جوهر المسؤولية بل في مضمون كل ركن .

(٢) دكتور / محمد أحمد سراج ، ضمان العدوان ، سابق ، ص ١٤٨ ، ١٤٩ .

هذا الشخص المعنوي ؛ ويكون مصدر هذا التصرف المباشر هو هؤلاء الموظفين أو العمال.

(ثانياً) : (الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي) :

ومن ثم فإن السؤال هنا : هل ينسب الخطأ، وبالتالي يقع جزاء المسؤولية علي الإدارة أم علي الموظف أو العامل الذي يتصرف باسمها ؟
قد يقال بتحميل المسؤولية للموظف ، لأن هو السبب المباشر لإحداث الضرر بوقوع المخالفة منه ؛ وبالتالي يتحمل هو هذه المسؤولية المتمثلة في التعويض للمضرور.

ولكن هذا الحل قد يؤدي إلي قعود الموظفين والعمال عن التصرف خوفاً من هذه المسؤولية ؛ ثم إنهم لما تصرفوا كان ذلك في سبيل مصلحة المرفق العام ؛ ومن ثم فإن من العدل تحمل الإدارة ذاتها جزاء المسؤولية وليس الموظف .
وقد يقال إن إعفاء الموظف أو العامل الذي ارتكب الخطأ من جزاء المسؤولية وتحيلها علي جهة الإدارة ؛ من شأنه أن يدفعه إلي ارتكاب أخطاء يستفيد منها لمصلحته الشخصية، أو يستهتر في أداء مهامه مما يؤدي إلي وقوع الإضرار بالغير؛ ومن ثم فإن من المنطقي والعدل في هذه الحالة تحمل الموظف ذاته جزاء هذه المسؤولية ، فما هو المعيار السليم في هذا ؟

لقد ذهب الفقه والقضاء إلي أن قواعد العدالة المجردة التي هي قوام القانون الإداري وتحقيق المصلحة ، يتطلب التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي ،
(١) بحيث ينسب الخطأ الشخصي إلي الموظف ذاته، ويتحمل أثر المسؤولية الناشئة عنه، والمتمثل في التعويض للمضرور في مال هذا الموظف الخاص .

(١) لا محل للترقية بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في المسؤولية التابعة للقانون المدني ؛ لأن الأصل فيه أن كل خطأ يسبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، كما يلاحظ البعض أن : " استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع " .
راجع في ذلك : دكتور / عصام أحمد البهجي ، تعويض الأضرار ، سابق ، ص ٧١ .

أما الخطأ المصلحي فينسب إلي المرفق ذاته، ويتحمل هو جزاء المسؤولية ، وتعويض المضرور من أموال المرفق ، بحيث لا يجوز له الرجوع علي الموظف الذي وقعت منه المخالفة .

وقد استقر قضاء مجلي الدولة الفرنسي ومجلس الدولة المصري علي هذه التفرقة من حيث المبدأ ؛ كما سلم بها الفقه سواء في فرنسا أم في مصر ، غير أن الذي أثار الخلاف هو تعريف كل من الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي ، أو بعبارة أخرى ما هي معايير التمييز بينهما ؟

- (التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي) :

تعددت الآراء التي قيلت في التفرقة بين هذين الخطأين ، وحتى تكون الأمور واضحة ، نجعلها في اتجاهين :

الاتجاه الذاتي ، والاتجاه الموضوعي :

(الاتجاه الأول - الذاتي) : يعني هذا الاتجاه ، أن الآراء التي قيلت في داخله تعبر عن قياس وصف الخطأ بالنظر إلي الشخص الذي وقع منه ، دون النظر إلي المخالفة ذاتها ، ولكن عباراتهم قد اختلفت بعد ذلك في التعبير عن هذا الاتجاه .

ومن أهم الآراء التي ذكرها أنصاره ما يلي :

(أ) فكرة القصد أو النية : يعني هذا الرأي أنه يمكن التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي ، من خلال تحري قصد الموظف أو نيته في ارتكاب الخطأ . (١)

فالخطأ الشخصي كما قيل هو : " الذي يكون مطبوعاً بطابع شخصي ، يكشف عن الإنسان بضعفه وشهوته وعدم تبصره " . (٢)

أما الخطأ المصلحي فهو : " غير مطبوع بطابع شخصي ، وينبئ عن موظف عرضه للخطأ والصواب : " (٣)

(١) هذا الرأي تبناه الفقيه الفرنسي لافيرير ، حيث يفرق بين ses passions et ses impondances وبين l'homme avec ses personnlles ، راجع في عرض هذا الرأي : دكتور / سليمان

الطماوي، دروس في القضاء الإداري ، سابق ، ص ٢٩٨

(٢) (٣) المرجع السابق ذات الموضع .

وبعبارة أخرى يمكن وصف هذا الرأي بأنه يكشف عن الخطأ من خلال حسن نية الموظف فيكون الخطأ مصلحياً ، أو سوء هذه النية فيكون الخطأ شخصياً .

- (تقويم هذا الرأي) :

هذا الرأي لا يمكن التسليم به بمفرده ؛ حيث يقوم علي مجادلة نظرية ، قد لا تصلح لاستيعاب جميع حالات الخطأ التي تتطلب العدالة انعقاد المسؤولية عنها ؛ وما قد ذهب إليه مجلس الدولة في بعض التطبيقات التي لم يصلح معها الأخذ بهذا الرأي، ومع ذلك علي الرغم من البيان النظري الذي انطلق منه.^(١)

(ب) فكرة الغاية : يرتبط التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي في نظر هذا الرأي بحسب الغاية أو الهدف أو المتغيا الذي قصد إليه الموظف من تصرفه الخاطئ^(٢).

فإذا كان يعمل في نطاق وظيفته أو عمله بهدف تحقيق الصالح العام للمرفق وتلبية احتياجات الناس ، انطلاقاً من مبدأ حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد ، وفي قيامه بهذا الواجب وقع الخطأ الذي تسبب في الضرر ؛ فإن ذلك الخطأ يعد مصلحياً تسأل عنه جهة الإدارة .

أما إذا استعمل الموظف سلطات وامتيازات الإدارة المتاحة له باعتباره قيماً علي المصلحة العامة ، وذلك في سبيل تحقيق مصالح وأهداف وأغراض شخصية وذاتية له ؛ فإن الخطأ في هذه الحالة يعد شخصياً يسأل عنه الموظف مدنياً .^(٣)

(١) وفي الفقه الإسلامي لا تقتضي المسؤولية هذا البحث في القصد أو النوايا لمعرفة الخطأ إيجاباً للعدالة وحماية للمضرور ، انظر : دكتور محمد أحمد سراج ، ضمان العدوان ، سابق ، ص ١٣٣ ، حيث يقول : " وبهذا فإن سبب الحكم بالضمان هو وقوع حادثة مادية (من فعل أو ترك) اعتبرها الشارع من قبيل الخطأ دون نظر إلي قصد الفاعل " .

(٢) راجع في عرض هذا الرأي دكتور/ محمد رفعت عبد الوهاب، أصول القضاء الإداري، سابق، ص ٢١٩، ٢٢٠
(٣) راجع المصدر السابق ، ذات الموضوع.

(تقويم هذا الرأي) :

هذا الرأي لا يصلح للأخذ به كمعيار وحيد في الواقع العملي للأسباب الآتية :

- ١- باعتباره معيار ذاتياً لا ينطبق علي حالات كثيرة قد تتخلف في الواقع العملي ، وهو ما قد يجافي العدالة ويتصادم مع المنطق القانوني.
- ٢- تقصي الهدف الذي تغياه الموظف مسألة صعبة ، خاصة وأن الظروف والملابسات التي تحيط بكل حالة علي حدة قد لا تفلح في حسم هذا الموضوع .
- ٣- قد لا ينضبط بهذا الرأي حتى الحالات التي يمكن تطبيقه عليها، بمجرد الاعتماد عليه وحده دون الاستناد إلي معايير أخرى.(١)

(الاتجاه الثاني - الموضوعي) :

مضمون هذا الاتجاه التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي علي أساس النظر إلي الخطأ الذي وقع من الموظف ذاته ، دون تحري قصده أو حسن نيته أو سوءها وذلك لانعقاد المسؤولية في مواجهة أيهما .

وبعد الاتفاق علي هذا المبدأ ، ظهرت آراء في داخل هذا الاتجاه لتحاول إجراء عملية القياس الموضوعي التي تحدثنا عنها ومنها :

(أ) حد الجسامة : هذا الرأي يقيس الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي علي أساس حد الجسامة (٢).

فالخطأ الشخصي ، هو خطأ بلغ حداً من الجسامة بحيث لا يمكن اعتباره ضمن الظروف والملابسات التي قد تحيط بالموظف فتدفعه إلي ارتكاب بعض الأخطاء البسيطة ، وهذه الجسامة قد تظهر بوضوح في صورة ما إذا مثل الفعل انتهاكاً للأفعال التي حرم القانون الجنائي اقترافها ، وذلك مثل جرائم القتل والاعتصاب والنصب والسرقة .

(١) وهذا الرأي وجه تصادمه مع العدالة قد تظهر بوضوح من خلال ما ذهب إليه الفقه الإسلامي من التضمين دون نظر إلي هدف من وقع منه الخطأ ، راجع في هذا : دكتور / محمد أحمد سراج ، ضمان العدوان ، سابق، ص ١٣٤ .

(٢) دكتور / سليمان الطماوي ، دروس ، سابق ، ص ٣٠٠ .

أما الخطأ المصلحي ، فيتحقق في حالة ما إذا لم تصل المخالفة إلي هذا الحد من الجسامة ، فتقع في نطاق الأخطاء البسيطة أو غير الجسيمة أو العادية ، التي يكن توقعها من الموظف أو العامل في مجال أداء واجبات الوظيفة أو العمل ، وذلك دون نظر إلي قصد ونية الموظف . (١)

(تقويم هذا الرأي) : يؤخذ علي هذا الرأي ما يلي :

١- هذا الرأي يتصادم مع العدالة التي تقتضي المساواة في ضوء ظروف وملابسات وظروف شخصية مرتبطة بالخطأ ، وقد يؤدي تحريكها ، إلي استبعاد مسؤولية الموظف في بعض الحالات علي الرغم من درجة الجسامة .

٢- قد يؤدي هذا المعيار إلي نفي مسؤولية الموظف عن أخطاء غير جسيمة ، علي الرغم من سوء نيته الواضح فيها واتجاهه إلي إيقاع المخالفة .

٣- قد يتصادم هذا الرأي مع مقاييس القانون التأديبي في بعض الحالات .

(ب) إمكانية الفصل : مضمون هذا الرأي أنه يمكن التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي ، علي أساس إمكانية فصل الخطأ عن العمل المنوط بالموظف أدائه ؛ ومن ثم فالخطأ يعد شخصياً إذا أمكن فصله عن الوظيفة ، أي لا تكون هناك علاقة بين هذا الخطأ وبين تلك الوظيفة لا من حيث الارتباط ، ولا من حيث كونه أحد وسائلها أو من حيث الأعمال التي تؤدي بمناسبة هذه الوظيفة ، الأمر الذي يصبغه بالطابع الشخصي ، وذلك كما في المثال الذي يسوقه الفقه دائماً لهذه الحالة وهو : " قيام أحد المسؤولين بنشر حكم بشهر إفلاس تاجر في شوارع وطرق إحدى القرى بغرض النكاية فيه ، متجاوزاً بذلك واجباته ومهامه التي تتطلب فقط مجرد استبعاده من ممارسة حقوقه السياسية " . (٢)

هذا في الوقت الذي يعد فيه الخطأ مصلحياً ، إذا كان مرتبطاً بالوظيفة ولم يمكن فصله عنها ؛ نظراً لكونه من الأعمال التي ينبغي علي الموظف أن يقوم بها في سبيل مهامه وأعماله ، ومع ذلك أضرار أحد لأفراد منها .

(١) السابق ، ذات الموضوع.

(٢) دكتور / سليمان الطماوي ، دروس سابق ، ص ٢٩٩ ، دكتور / ٢٩٩ ، دكتور / محمد رفعت عبد الوهاب ، أصول القضاء الإداري ، ص ٣٢٠

- (تقويم هذا الرأي) : هذا الفصل بين الوظيفة والخطأ والذي يبني عليه التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي ؛ قد يؤدي إلي عدم الانضباط في بعض الأحيان علي النحو الآتي :

١- من الذي سوف يحدد المعيار الذي يبين لنا ما هي الأخطاء التي يمكن فصلها عن الوظيفة وتلك التي لا يمكن فصلها عنها؟. فالمعيار في ذاته الذي قيل به في هذا التمييز يحتاج إلي معيار .

٢- قد يجافي هذا المعيار العدالة فيؤدي إلي محاسبة الموظف عن أخطاء مصلحية ، أو تحميل الإدارة لأخطاء شخصية من الواجب أن يتحملها الموظف .

٣- قد يؤدي الأخذ بهذا المعيار إلي إفلات بعض الموظفين من المساءلة ، علي الرغم من سوء نيته الواضح واتجاهه القصدي إلي إيقاع الخطأ ، ومن ثم فمن الواجب البحث عن معيار تكميلي أو معايير تكميلية تساعد علي ضبط ما يعد خطأ شخصياً أو خطأ مصلحياً ، لاسيما في حالات عديدة قد يدق البحث فيها بعض الحالات .

- (الاتجاه المختار) : لم يصل الفقهاء إلي رأي محدد يضع تعريفاً دقيقاً لمعيار يميز بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي ، وإنما كلها آراء بعضها نظري لا يمكن الأخذ به عملياً ، أو يمكن الاعتماد عليه في بعض الحالات دون باقي الحالات الأخرى ؛ ومن ثم يتخلف فيه وصف المعيار المنضبط ، وفقاً لمواصفات التعريفات والمعايير السليمة .

ونحن نرى أن كل حالة في موضوع نزاعها ، يخضع حسمها للقاضي في ضوء ظروفها وملابساتها ، فما قد يصلح في حالة منها قد لا يصلح في حالة أخرى ؛ أو قد يتطلب الأمر استخدام عدة معايير مجتمعة للحكم في نزاع معين ؛ كما يتضح من مراجعة موقف مجلس الدولة .

- (اتجاه مجلس الدولة في التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي) :
ما هو موقف مجلسي الدولة في التمييز بين الخطأين ؟

استقر مجلس الدولة في القسم القضائي ، وقسم الفتوى علي عدم الأخذ بمعيار واحد للتمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلي ؛ وإنما المعايير كلها تصلح للأخذ بها في هذا الصدد .

ونعرض فيما يلي لرأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، وبعض أحكام محاكم مجلس الدولة في هذا المبدأ :

- (رأي الجمعية العمومية في التمييز بين الخطأين الشخصي والمصلي) :

استقرت الجمعية علي عدة قواعد وتطبيقها علي النحو الآتي (١) :

(أ) (القاعدة العامة) : استظهرت الجمعية العمومية أن المستقر عليه قضاء وإفتاء ، أن الموظف لا يسأل إلا عن أخطائه المرفقية ، وإنما يسأل فقط عن أخطائه الشخصية ، وأنه لا توجد ثمة قاعدة عامة مجردة تضع ضوابط مجردة محددة تفصل بوجه قاطع بين الأخطاء المرفقية والأخطاء الشخصية ، وإنما يتحدد الخطأ في كل نوع علي حده تبعاً لما يستخلص من ظروف كل حالة وملابساتها .

(ب) (معايير الخطأ) : يستهدي في تحديد نوع الخطأ بعد من المعايير مثل :

١- نية الموظف. ٢- مبلغ الخطأ من الجسامة. ٣- الدافع لارتكاب هذا الخطأ.

٤- إذا كان الخطأ منبت الصلة عن الوظيفة .

وقد يأخذ بها كلها ، وقد يأخذ ببعضها في حالة تتطلب ذلك وفقاً لتقديره .

(جـ) (مفهوم الخطأ المصلي) : يكون الخطأ كذلك إذا كان العمل الصادر

غير مصطبغ بطابع شخصي بل ينم عن موظف معرض للخطأ والصواب ، فإن خطأه في هذه الحالة يعتبر مرفقياً أو مصلياً .

- (مفهوم الخطأ الشخصي) : يكون الخطأ شخصياً في حالتين :

- (الحالة الأولى - سوء النية أو القصد) : وذلك في الخطأ الذي يثبت في

حق المرفق نفسه ، يكشف عن الإنسان بضعفه وشهوته ونزواته وعدم تبصره وقصد النكاية أو الإضرار أو ابتغاء منفعة ذاتية ، فإن الخطأ في هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً .

(١) انظر : الفتوى رقم ٩٢ بتاريخ ٢٠٠١/٢/١٧ ملف رقم ٩٦٩/٣/٨٦ ، المصدر : مجلة المحاماة - العدد الأول ٢٠٠١ ، ص ٥٠١ ، ٥٠٠ .

- (الحالة الثانية - جسامه الخطأ) : يعتبر الخطأ شخصياً ولو لم تتوافر النية السابقة ، إذا كان الخطأ جسيماً .
- (معيار تحديد جسامه الخطأ) : تحديد جسامه الخطأ مسألة نسبية، تتفاوت تبعاً للظروف المختلفة ويستهدي فيها بقدرة الموظف متوسط الكفاية الذي يوجد في ظروف مماثلة ، لتلك التي كان عليها الموظف المخطئ .
- (هل الجريمة تعد خطأ شخصياً ؟) : الجريمة التي يرتكبها الموظف لا يعتبر من قبيل الخطأ الشخصي إلا في حالات هي :
- (الحالة الأولى) : إذا كانت الجريمة منبئة الصلة بالوظيفة .
- (الحالة الثانية) : إذا كانت جريمة عمدية .
- (الحالة الثالثة) : إذا انطوت علي درجة من جسامه الخطأ .
- (د) (أثر توافر القواعد السابقة) (١) : مقتضي ما تقدم أنه لا يجوز لجهة الإدارة أن ترجع علي أي من تابعيها في ماله الخاص لاقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا كان هذا الخطأ متسماً بالطابع الشخصي علي الوجه المتقدم ، وهو الأمر الذي يتطلب الوقوف في كل حالة علي الخطأ الذي نجم عنه الضرر الذي بجهة الإدارة وعلاقة السببية بينه وبين الضرر ، وثبوت اندراج هذا الخطأ في عداد الأخطاء الشخصية بالمفهوم المتقدم دون الأخطاء المرفقية .
- (هـ) (تطبيق أول للقواعد السالفة البيان) : صدر الحكم بإلزام وزارة التربية والتعليم بالتعويض علي أساس أن الخطأ الموجب للتعويض هو الخطأ المادي الذي وقع من جهة الإدارة في عملية جمع الدرجات بتدوين المجموع ٢٣٢.٥ درجة رغم أن صحة هذا المجموع هو ٣٣٢.٥ درجة وهو الأمر الذي شكاه منه المحكوم لصالحه ، فبحث شكواه وثبت وجود خطأ وكلف عضوان من العاملين بلجنة النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المعلمين والمعلمات لتصويب الخطأ الذي كان يتعين علي جهة الإدارة تداركه دون انتظار لمطالبة المذكور بذلك، وأن ما حدث ينم عن تعسف جهة الإدارة وسيطرة الروتين الحكومي علي قراراتها ، وأن هذا الخطأ الذي لاشك في اندراجه

(١) الفتوى رقم ٩٢ بتاريخ ٢٠١١/٢/١٧ ، سابق ، ذات المصدر .

ضمن الأخطاء المرفقية التي مردها سوء تنظيم وإدارة المرفق منبت الصلة عن حالة الخطأ المعروضة حالته السيد / مدير مساعد الشؤون القانونية بالوزارة علي النحو الذي استظهرته تحقيقات النيابة الإدارية والذي كان محلاً للجزاء الإداري الموقع عليه بخصم ثلاثة أيام من راتبه ، ولم يكن هذا الخطأ هو السبب المنتج في صدور الحكم بالتعويض سالف البيان.(١)

(و) (تطبيق ثان) : الحكم الجنائي الصادر ببراءة المتهمين من تهمة الاختلاس ينفي عن الفعل صفة الخطأ الشخصي ، ويعد من قبيل الأخطاء المرفقية التي تتحمل الإدارة تبعة التعويض المترتب عليه . (٢)

ولا ينفي القاعدة السابقة قضاء المحكمة التأديبية بإدانة العاملين تأديبياً ، لأنها لم تثبت أن خطأهم كان خطأ شخصياً . (٣)

(١) الفتوى رقم ٩٢ في ٢٠٠١/٢/١٧ ، سابق ، ذات المصدر.

ونلاحظ من هذه الفتوى ما يلي إن الخطأ الذي وقع هنا والمتمثل في الرصد الخاطئ للدرجات والذي أضير منه الطالب قد وقع من الموظف ، ولكنه كان خطأ مرفقياً قام علي أساس أنه لم يكن هناك سوء فيه أو قصد ولم يهدف إلي النكاية أو الأضرار أو المنفعة الذاتية

١- إن الخطأ هنا غير مصطبغ بطابع شخصي بل يكشف عن موظف معرض للخطأ والصواب ، ومن ثم فلا يجوز لجهة الإدارة أن ترجع علي أي من تابعيها للحصول علي التعويضات التي تحملتها من أخطائهم .

٢- إن المحكمة قد استندت هنا في إثبات وصف الخطأ المرفقي إلي سوء تنظيم وإدارة مرفق التعليم والذي أنتج هذا الخطأ وما كان الموظف سوى أداة للقيام بمهام هذا المرفق ؛ ومن ثم فإن تكليف الموظف تحمل تبعه هذا العمل فيه تكليف بما لا يطاق.

(٢) الفتوى رقم ٣٧٧ في ٢٠٠٠/٦/٢٩ ملف رقم ٩٨٠/٣/٨٦ ، المصدر:مجلة المحاماة- العدد الأول ٢٠٠١ ، ص ٤٥٢ ، ٤٥٣ ،

ونلاحظ في هذه الفتوى ما يلي :

- ١- إن الفتوى قد أخذت بمعيار الشخص العادي الذي يتواجد في كافة الظروف والأوضاع التي تحيط بالعامل المسنول ، فإذا كشف عن إهمال شديد وعدم اكتراث بعواقب الأمور فهو يعد خطأ منفصلاً عن المرفق ومن هنا يكون مجلس الدولة قد أقام التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي علي معيار الخطأ المنفصل .
 - ٢- إن الخطأ غير الجسيم لا يعد خطأ شخصياً إلا إذا كان عن سوء أو نية تكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته ونزواته وأغراضه ومنافعه الذاتية .
- (٣) الفتوى رقم ٣٧٧ بتاريخ ٢٠٠٠/٦/٢٩ ملف رقم ٩٨٠/٣/٨٦ ، المصدر السابق ، ص ٤٥٣ .
- ونلاحظ في هذه الفتوى ما يلي :

- (رأي محاكم مجلس الدولة في التمييز بين الخطأين الشخصي والمصلحي) :
استقرت أحكام محاكم القسم القضائي بمجلس الدولة علي ذات المبدأ والقواعد السابقة التي ذكرناها في رأي قسم الفتوى والجمعية العمومية السابق العرض له ، من حيث مفهوم كل من الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي ، ومعايير التمييز بينهما .
(أ) ونورد فيما يلي عبارات المحكمة الإدارية العليا التي عبرت عن هذا المفهوم :

ذهبت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٢٥٢ لسنة ٢٧ ق - عليا صادر بجلسة ١٢/٤/١٩٨٦ إلي أنه (١) : " لا توجد قاعدة عامة مجردة تضع ضوابط محددة تفصل بوجه قاطع بين الأخطاء المرفقية والأخطاء الشخصية ، وإنما يتحدد كل نوع من هذه الأخطاء في كل حالة علي حدة تبعاً لما يستخلصه القاضي من ظروفها وملابساتها مستهدياً في ذلك بعدد من المعايير ، منها نية الموظف ومبلغ الخطأ من الجسامة والدافع إلي ارتكابه ، فإذا كان العمل غير مصطبغ بطابع شخصي ، بل ينم عن موظف معرض للخطأ والصواب ، كأن يهدف إلي تحقيق أحد الأغراض المنوط بالإدارة تحقيقها والتي تدخل في وظيفتها الإدارية فإن خطأه في هذه الحالة يعتبر مرفقياً ، ويعتبر الخطأ شخصياً ، إذا كان يكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته ونزواته ، وعدم تبصره ويقصد من ورائه النكاية أو الإضرار أو ابتغاء منفعة ذاتية ، وهو يعتبر كذلك أيضاً ولو لم تتوافر في مرتكبه هذه النية إذا كان الخطأ جسيماً ، وتحديد جسامة الخطأ مسألة نسبية تتفاوت تبعاً للظروف المختلفة -

١- إن انتقاء المسؤولية عن العامل باعتبارها من قبيل الأخطاء الشخصية ، وتحميلها علي جهة الإدارة باعتبارها من قبيل الأخطاء المرفقية كان علي أساس براءة العامل من التهمة الجنائية المسنودة إليه .

٢- إن تحمل جهة الإدارة تبعاً الفعل الخاطئ الذي وقع من الموظف كان استناداً إلي سوء تنظيم وإدارة المرفق العام ، حتى وإن كان الموظف هو الذي ارتكب المخالفة

٣- أنه لا يعني إثبات الحكم التأديبي للمخالفة ثبوت الخطأ الشخصي في مواجهة العامل .
(١) مصدر هذا الحكم لدى دكتور / محمد ماهر أبو العنين ، الضمانات والإجراءات التأديبية ، دار الطباعة الحديثة ، ١٩٩٤ ، صادر عن نقابة المحامين ، ص ٣٤٧ .

ويستهدى فيها بقدرة الموظف المتوسط الكفاية الذي يوجد في ظروف مماثلة لتلك التي كان فيها الموظف المخطئ " . (١)

(ب) **قضت المحكمة بما يلي :** " فيصل التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي يكون بالبحث وراء نية الموظف ، فإذا كان يهدف من القرار الذي أصدره تحقيق الصالح العام ، أو كان قد تصرف لتحقيق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها ، والتي تدخل في وظيفتها الإدارية ، فإن خطأه يندمج في أعمال الوظيفة بحيث لا يمكن فصله عنها ، ويعتبر من الأخطاء المنسوبة إلي المرفق العام ويكون خطأ الموظف هنا خطأ مصلحياً ، أما إذا تبين أن الموظف لا يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية ، أو كان خطؤه جسيماً ، بحيث يصل إلي حد ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات ، فإن الخطأ في هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً يسأل عنه الموظف الذي وقع منه هذا الخطأ في ماله الخاص " . (٢)

(ج) **دعوى المسؤولية تدخل في اختصاص قضاء التعويض أو القضاء الكامل ، إلا أنه قد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا علي ما يلي (٣) :** " المشرع قد خلع

(١) وبلاحظ هنا مسألة هامة ، وهي أن الخطأ الذي ارتكبه الموظف كان يشكل ذنباً إدارياً وتحملت الإدارة التعويض للمضرور ثم رجعت بقرار التحميل علي ذلك الموظف فإنه : " إذا كان الفعل المكون للذنب الإداري يمكن أن يشكل ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية إلا أن ذلك لا يؤدي إلي القول بأن إلزام العامل بجبر الضرر بالدعوى التأديبية أو متفرع عنها - أساس ذلك : استقلال فكرة جبر الضرر الناشئ عن المسؤولية التقصيرية عن نظام التأديب من حيث القواعد القانونية التي تحكمه والغرض الذي يسعى إلي تحقيقه - اختصاص المحاكم التأديبية بنظر طلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ليس من شأنه بسط اختصاص هذه المحاكم علي ما عدا ذلك من موضوعات تختص بها محاكم أخرى إلا إذا كان النزاع قد طرح أمامها مرتبطاً بصفة تبعية بمناسبة مباشرتها لاختصاصها " ، انظر : مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا ٣٢- الجزء الثاني - الناشر : نقابة المحامين - لجنة المكتبة والفكر القانوني ، ط ١٩٩١ ، ص ١٠ ، ١١ من الفهرس

(٢) المصدر في هذا الحكم : دكتور / محمد ماهر أبو العنين ، الضمانات والإجراءات ، سابق ، ص ٣٤٦ ، ٣٤٧ (٣) مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا - السنة السابعة والثلاثون - العدد الثاني - ط ١٩٩٩ - صادر عن مجلس الدولة - المكتب الفني - الحكم صادر في الطعن رقم ٩٨٣ لسنة ٣٥ ق . علي .
بجلسة ١٩٩٢/٣/١٧ قاعدة رقم (١١٦) ، ص ١٠٧٨ ، ١٠٧٩ .

ونلاحظ هنا ، أن المحاكم التأديبية هي التي ستتولى هنا الفصل في مسألة التمييز بين الخطأ المصلحي والخطأ الشخصي جرياً علي قضاء المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن وما أرسته من مبادئ وقواعد في قضاء التعويض .

علي المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل في مسائل تأديب العاملين، وأن ولايتها هذه لا تقتصر علي الطعون المباشرة ، في قرارات الجزاءات ، وإنما تمتد إلي الطلبات الأخرى المرتبطة ، وأنه يكفي لانعقاد الاختصاص للمحكمة التأديبية بنظر الدعوى بطلب الحكم ببطالان الخصم من مرتب العامل، أن يكون هذا الخصم مستنداً إلي المخالفة التي ارتكبها ، ولو لم يصدر ضد العامل قرار بمجازاته عنها ، إذ يعتبر الخصم في هذه الحالة جزاءً تأديبياً غير مباشر ، طالما أنه يستند إلي المخالفة المنسوبة إلي العامل ، وليس إلي قاعدة من القواعد المنظمة العامة المحددة لمستحقته الوظيفية ، وتبعاً لذلك فإن إلزام العامل بقيمة ما تحملته جهة الإدارة من أعباء مالية بسبب تقصيره، وإن لم يكن في ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً، إلا أنه يرتبط بها ارتباط الفرع بالأصل".^(١)

(ثالثاً) : (صور الخطأ المصلي) :

الخطأ المصلي هو غير المصطبغ بطابع شخصي ، بل ينم عن عامل معرض للخطأ والصواب ، ويكون خطؤه في هذا الشأن غير جسيم ^(٢) ، أو كان قد تصرف ليحقق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها ، والتي تدخل في وظيفتها الإدارية ، فإن خطؤه يندمج في أعمال الوظيفة ، بحيث لا يمكن فصله عنها ، ويعتبر من الأخطاء المنسوبة للمرفق العام . ^(٣)

ولقد استقر قضاء مجلس الدولة علي عدة صور أو تطبيقات للخطأ المرفقي ، والتي يؤدي تحقق واحدة منها ، لتحمل المرفق آثاره ومغبته دون العامل ، لأنه خطأ المرفق ، وهذه الصور هي ^(٤) :

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٩٨٣ لسنة ٣٥ ق . علي . المصدر السابق ، ذات الموضوع .
(٢) فتوى رقم ٣٧٧ بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٠٠ ملف رقم ٩٨٠/٣/٨٦ ، المصدر : مجلة المحاماة ، سابق ، ص ٤٥٢
(٣) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٩٢٨ لسنة ٤ ق ، صادر في جلسة ١٩٥٩/٦/٦ ، مشار إليه لدى دكتور / محمد ماهر أبو العنين ، الضمانات ، سابق ، ص ٣٤٦ ، ٣٤٧ .
(٤) انظر : أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي ، مارسون لون . بوسير في . جي بريان ، ببيرد لفرلفيه ، برونو جينفوا ، ترجمة الدكتور / أحمد يسري - توزيع دار الفكر الجامعي - الطبعة العاشرة ، ١٩٩٥ ، ص ٣٨ ، ومن الأمثلة : رفض طبيب الإشراف الذهاب إلي مريض رغم استدعاء الطبيب المقيم إياه مرتين وإخطاره بحالة المريض المقلقة .

١ - (سوء تنظيم المرفق وإدارته) :

وهذه الصورة تعني، أن المرفق يؤدي الخدمة ، ولكن دون إتباع المعايير الإدارية السليمة في تنظيم المرفق، أو في إدارته علي نحو ألحق الضرر بالأفراد سواء من المنتفعين بخدمات المرفق أم من غيرهم (١) ، ومن أمثلة هذه الصورة :

(أ) حالة وجود خطأ في رصد الدرجات لأحد الطلاب بتدوين المجموع ٢٣٢.٥ درجة ، رغم أن صحة المجموع هي ٣٣٢.٥ درجة ، وهو الأمر الذي شكا منه المحكوم لصالحه فبحث شكواه ، وثبت وجود الخطأ وكلف عضوان من العاملين بلجنة النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المعلمين والمعلمات لتصويب الخطأ الذي كان يتعين علي جهة الإدارة تداركه دون انتظار لمطالبة المذكور بذلك ، وأن ما حدث ينم عن تعسف جهة الإدارة وسيطرة الروتين الحكومي علي قراراتها ؛ وأن هذا الخطأ الذي لاشك في اندراجه ضمن الأخطاء المرفقية التي مردها سوء تنظيم وإدارة المرفق (٢).

(ب) حالة شغب ومظاهرة في إحدى المدن ؛ فيطلق أحد الجنود الأعيرة النارية فيصيب طفلاً في شرفة منزله ، خرج علي فطرته ليشاهد ماذا يجري بالشارع .

(ج) أن يكون هناك إهمال في إحدى المستشفيات يترتب عليه وفاة أحد المرضى ، علي الرغم من تواجد الأطباء وهيئة التمريض ، ولكن عدم إمداد المرفق بالأدوات الأولية للإسعاف ، أو عدم وجود رقابة نتيجة للفوضى في الجهاز الصحي ، هي التي أحدثت ذلك (٣) .

٢ - (الضرر مجهول المصدر) :

هذه الصورة مستحدثة في رأي مجلس الدولة المصري ؛ حيث يرى أن الضرر إذا كان مجهولاً مصدره ، يعد خطأ مرفقياً تسأل عنه جهة الإدارة .

(١) الفتوى رقم ٩٢ في ٢٠٠١/٢/١٧ ، ملف رقم ٩٦٩/٣/٨٦ : انظر : مجلة المحاماة ، سابق ، ص ٥٠٠ ، ٥٠١ ، قاعدة رقم (٥) .

(٢) السابق ، ذات المصدر ، ص ٥٠٠ ، قاعدة رقم (٥) .

(٣) انظر : أحكام المبادئ ، سابق ، ص ٣٨ ، حيث قد يجتمع الأمران مثل عد حماية الشرطة شخصاً مهدداً بالقتل احتمى بقسم الشرطة ، أو صدور عبارات مهينة للدين وفاضحة من مدرس أمام التلاميذ .

ومن أمثلة هذه الصورة ، صدور حكم من المحكمة الجنائية ببراءة العاملين المعروضة حالتهم ، مما نسب إليهم من اختلاس المبلغ المذكور ، وأسس حكم البراءة علي أن الأوراق التي قدمتها النيابة العامة قاصرة عن بلوغ حد الكفاية للأدلة ، خاصة وأن التقارير الحسابية التي استندت إليها النيابة العامة - لإسناد الاتهام قبل المتهمين قد جاءت بأرقام حسابية خاوية من دليل علي صحتها، بعد أن افتقرت إلي عدم وجود الدليل المستند الذي يؤيدها سيما ، وقد عجز مكتب خبراء وزارة العدل عن فحص تلك التقارير في غيبة مستنداتها ، ومن ثم فإنه بصدور الحكم الجنائي ببراءة المعروضة حالتهم من تهمة الاختلاس الموجهة إليهم، فإنه يكون قد نفى هذه التهمة عنهم ، ويضحى حائزاً لحجية الشيء المحكوم به ، فيما يتعلق بتحديد مدى مسئوليتهم المدنية عما لحق جهة الإدارة من ضرر من جراء فقد هذا المبلغ ، بما مؤداه انتفاء الخطأ الشخصي الموجب لتلك المسؤولية . (١)

٣ - (ببطء المرفق في أداء الخدمة) : (٢)

هذه الصورة تعني أن المرفق أدى الخدمة لجمهور المنتفعين ولكن ببطء أدى إلي إلحاق الضرر بالأشخاص ، فهنا يتحمل المرفق ذاته جزاء المسؤولية عن جبر هذه لأضرار ، ومن أمثلة هذه الصورة مرفق السكة الحديد الذي يهمل في أداء مهامه من خلال تأخر وصول القطارات إلي محطات الوصول تأخيراً ، ترتب عليه إلحاق الضرر الجسيم بأحد الأفراد الذي كان يريد أن يلحق بامتحان أو يدخل في مسابقة كان هذا هو آخر مواعيدها ، وكذا تأخر جهاز مترو الأنفاق في صيانة المترو ، مما ترتب عليه تعطلها مرات عديدة في الطريق وعدم وصولها في الوقت المناسب .

أو بطء المستشفى في تقديم الخدمة للمريض لحظة وصوله إلي المستشفى ، لعدم تجهيزها بالإسعافات الأولية التي هي من بديهيات العمل الطبي .

٤ - (امتناع المرفق عن الوفاء بالخدمة) (٣) :

(١) فتوى رقم ٣٧٧ بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٠٠ ملف رقم ٩٨٠ . المصدر السابق ، ص ٤٥٣ .

(٢) دكتور / سليمان الطماوي ، دروس ، سابق ، ص ٣٠٨ ، ٣٠٩ .

(٣) السابق ، ص ٣٠٤ ، ٣٠٥ .

هنا تتخذ الإدارة المسؤولة عن المرفق العام موقفاً سلبياً ، يتمثل في امتناع هذا المرفق عن أداء الخدمة لجمهور المنتفعين مما ترتب عليه إصابتهم بالأضرار التي تؤدي إلي قيام المسؤولية المدنية في مواجهة الإدارة ، باعتبار ذلك خطأ مرفقياً أو مصلحياً .

ومن الأمثلة علي هذه الحالة ، أن يكون هناك ميعاداً مضروباً للتقدم بالمسابقة التي أعلن عنها ، ومن ثم ففي آخر يوم عمل رسمي ، والمتاح للتقدم فيه للمسابقة ، ولكن لا يفتح المرفق أبوابه لاستقبال الجمهور نظراً لغياب كل موظفيه ، فهنا ينعقد الخطأ المرفقي لجهة الإدارة عن التعويض .

أو أن يكون هناك مريض يتم التوجه به إلي أقرب مستشفى ، ثم يفاجئ بان أبوابها مغلقة نهائياً وفي يوم عمل رسمي ، فهنا تتعقد المسؤولية عن خطأ مصلحي .

رابعاً : (صور من الخطأ الشخصي) (١) :

الخطأ الشخصي ، هو الذي يسأل عنه العامل مدنياً في ماله الخاص ؛ فهو خطأ منفصل عن المرفق ، يكشف عن الإنسان بضعفه وشهوته ونزواته وعدم تبصره وقصده النكاية أو الإضرار أو ابتغاء منفعة ذاتية له ، والجريمة التي يرتكبها الموظف لا تعد من قبيل الخطأ الشخصي، إلا إذا كانت منبئة الصلة بالوظيفة ، أو إذا ارتكبت عمداً أو انطوت علي درجة جسيمة من الخطأ . (٢)

ومن أمثلة هذا الخطأ :

(أ) الخطأ الجسيم الذي يكشف عن الإهمال الشديد وعدم الاكتراث بعواقب الأمور ، مثل قائد المركبة التابعة لوزارة ما الذي يصدم أحد المواطنين فينتج عن ذلك وفاته ، ويظهر أن ذلك القائد كان مخموراً ، وكان يستخدم السيارة في تحقيق أغراض شخصية له .

(١) فتوى رقم ٣٧٧ بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٠٠ ملف رقم ٩٨٠/٣/٨٦ ، المصدر : مجلة المحاماة ، سابق ، ص ٤٥٣ .
(٢) أحكام المبادئ ، سابق ، ص ٣٧٤ ، حيث ورد أنه : " ولاشك أنه إذا ارتكب الخطأ الجنائي خارج المرفق أو إذا ارتكب داخل المرفق أو بمناسبة متضمناً قصد الإضرار أو كان علي جسامه غير مقبولة بالنسبة للمرفق ، وكون خطأ شخصياً يؤدي إلي مسؤولية مرتكبة الشخصية " .

(ب) موظف بأحد البنوك الزراعية، استغل المزارعين بأن قام بسحب قروض شخصية باسم هؤلاء وصرفها لحسابه الشخصي ، أو قام بالنصب عليهم من أجل إعطائهم القروض والحصول علي نسبة من كل مقترض مستغلاً في ذلك ضعف المزارعين ، أو قام مدير البنك باختلاس أموال المواطنين المودعة لديه ، فكل هذه تعد من قبيل الأخطاء الشخصية التي تكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته.

(ج) رحلة مدرسية قام المشرفون علي الرحلة بنقل التلاميذ علي جرار زراعي أو بواسطة عربة نصف نقل ، مما ترتب عليه حدوث تصادم أودى بحياة بعض هؤلاء التلاميذ .

(د) قيام أحد الموظفين أو العمال بارتكاب جريمة ضد أحد المواطنين في داخل محل العمل كالقتل أو الضرب أو السرقة أو الاغتصاب ، وما سواها من الجرائم الجنائية العمدية .

(هـ) قيام أحد العمال أو الموظفين بإفشاء أسرار بعض المواطنين التي اطلع عليها بحكم وظيفته ، الأمر الذي ألحق بالمواطن ضرراً لا بد من جبره من المال الخاص بالموظف أو العامل.

خامساً : (موقف القضاء الإداري الفرنسي من التمييز بين الخطأين) :

استقر القضاء الإداري الفرنسي منذ زمن طويل علي قواعد التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي ، وفقاً لعدة أمور، لعل من أهمها ، أنه ومنذ صدور حكم محكمة التنازع في ١٨٧٣/٢/٨ في قضية بلانكو ضد مدير إقليم الجيرونند ، فقد استقر الأمر علي أن مسؤولية الدولة المدنية ليست عامة ولا مطلقة ، بل إن لها قواعدها الخاصة، التي يتطلبها ضرورة التوفيق بين الحقوق العامة للدولة والحقوق الخاصة^(١).

وقد أقر مجلس الدولة تحميل المسؤولية علي الإدارة ، أو علي الفرد أو علي كليهما ، طبقاً لما قرره من أن الخطأ الشخصي هو : " الذي يكون من المناسب - في إطار سياسة قضائية حسنة - تركه علي عاتق مرتكبه ، والخطأ المرفقي هو الذي لا

(١) أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي ، ص ٢٢ ، قاعدة (١).

يكون من المناسب أو من العدل أن يتحملة مرتكبه وحده ، وقد تطور القضاء في هذا الشأن منذ سنة ١٨٧٣ ، علي حسب ما أقامه من معايير توضح التعريف السابق المحدد الذي وضعه للخطأ الشخصي والخطأ المرفقي". علاوة علي تقريره للمسئولية علي أساس المخاطر.^(١)

الفصل الخامس **مناط المسؤولية التقصيرية**

ركن الخطأ علي النحو السابق ضروري لانعقاد المسؤولية المدنية للإدارة ، غير أن إعمال هذا الركن يتطلب البحث عن مجاله ذلك أن مجال الخطأ الإداري ، إما أن يكون هو القرار الإداري، وإما أن يكون العمل المادي علي النحو الآتي :

- (مناط مسؤولية جهة الإدارة عن القرار الإداري) : يشترط لانعقاد المسؤولية المدنية لجهة الإدارة عن القرار الإداري توافر أركان ثلاثة وهي :

١- ركن الخطأ : ويتمثل في صدور قرار الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون .

٢- ركن الضرر : وهو الأذى المادي أو المعنوي الذي يلحق صاحب الشأن من صدور القرار .

٣- علاقة السببية بين الخطأ والضرر. (٢)

والواضح من هذا أن اعتبار القرار الإداري مبرراً لمسؤولية الإدارة التقصيرية ، يقتضي أن يكون هذا القرار غير مشروع ؛ فإذا كان مشروعاً فلا مسؤولية علي

(١) دكتور / سليمان الطماوي - روس ، سابق ، ص ٣٢ ، وما بعدها .

(٢) مجموعة المحكمة الإدارية العليا - السنة ٣٢ قضائية - سابق ، الجزء الثاني ، ص ٨٩ من الفهرس حيث ورد ما يلي : " يشترط لقيام مسؤولية الإدارة عن القرارات التي يصدرها بالمخالفة لأحكام القانون توافر أركان ثلاثة وهي : ١- ركن الخطأ : ويتمثل في صدور قرار الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون ، ٢- ركن الضرر : وهو الأذى المادي أو المعنوي الذي يلحق صاحب الشأن من صدور القرار ، ٣- علاقة السببية بين الخطأ والضرر متى ثبت أن صاحب الشأن لم يكن يدركه الدور في الإعارة ضمن النسبة المخصصة للمدرسين فلا مسؤولية علي الإدارة ولا وجه للمطالبة بالتعويض عن الحرمان من الإعارة - أساس ذلك : - انتفاء ركن الخطأ الموجب للمسؤولية مما يؤدي إلي عدم اكتمال المسؤولية " .

ونلاحظ هنا أن بناء المسؤولية علي ركن الخطأ في القرار الإداري يرتبط بأساليب الإدارة التي تلجأ إليها ؛ لأنها تتضمن سلطة الإكراه في بعض الحالات كقرار الإزالة، وقرار المنع من السفر .

الإدارة ، ولا وجه للمطالبة بالتعويض حتى ولو ترتب عليه ضرر ؛ لأن الضرر هنا لا يفترض علي الإطلاق .

وقد جرى القضاء الإداري علي القواعد الآتية فيما يتصل بالمسئولية عن القرارات الإدارية :

(أولاً - تحقق ركن الخطأ) : يتحقق ركن الخطأ في حق جهة الإدارة ، وبالتالي مسئوليتها المؤدية إلي التزامها بالتعويض ، بأن يكون القرار الإداري المترتب عليه الضرر غير مشروع ، وذلك بأن يكون مشوباً بأحد عيوب القرار الإداري حسبما حددها قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، بأن يكون مخالفاً للقانون أو تفسيره أو تأويله أو مشوباً بعيب عدم الاختصاص أو الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها. (١)

(ثانياً - انتفاء ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية) : ركن الخطأ يضحى منتقياً في جانب الجهة الإدارية ، وبالتالي تنتقي المسئولية الموجبة للتعويض ، إذا كان المضرور قد ساهم بخطئه في صدور قرار إداري علي نحو معين . (٢)

فإذا قامت جهة الإدارة بإصدار قرارها بإنهاء خدمة موظف لانقطاعه عن العمل استناداً إلي ما قرره اللجنة الطبية من عدم اعتبار مدة انقطاعه أجازة مرضية، ومن ثم يضحى هذا القرار قائماً علي السبب المبرر له قانوناً ولا وجه للنعي عليه.

(ثالثاً - عيوب القرار كأساس للخطأ) :

يجب في قيام المسئولية التقصيرية علي أساس أن القرار الإداري غير مشروع ، أن يتوافر عيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ، أو التي استقر عليها في قضائه ، وهي : عيب الشكل ، وعدم الاختصاص ، وعيب المحل ، وعيب السبب ، والانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها ، (٣) وفقاً للضوابط التالية :

(١) مجموعة أحكام المحكمة العليا - س ٣٢ ق - الجزء الثاني - سابق ، ص ١٣٦٦ ، ١٣٦٧ ، الطعن رقم ٢٢٢٧ لسنة ٣٣ ق . عليا . صادر بجلسة ١٩٩٢/٥/٩ - قاعدة رقم ١٤٧ .

(٢) حكم المحكمة الإدارية في الطعن رقم ٦٠١٩ لسنة ٤٦ ق . عليا - صادر في ٢٠٠٢/٢/١٦ - الدائرة الثانية - المصدر : مجلة هيئة قضايا الدولة - العدد الثالث - السنة السابعة والأربعون - يوليو - سبتمبر ٢٠٠٣ ، ص ١١٧ - ١٢٠ .

(٣) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٢٢٧ لسنة ٣٢ ق . عليا . سالف الإشارة إليه .

(الضابط الأول - تحمل الناس لمغبة القرار المشروع) :

قضت المحكمة الإدارية العليا بما يلي : " إن المناط في مساءلة الحكومة بالتعويض عن القرارات الإدارية ، هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع ، وذلك إذا شابه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها ، وأن يترتب عليه ضرر ، وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر ، فإذا كان القرار سليماً مطابقاً للقانون ، فلا تسأل عنه الإدارة مهما بلغ الضرر الذي يترتب عليه ، لانقضاء ركن الخطأ فلا مندوحة والحالة هذه - من أن يتحمل الناس نشاط الإدارة المشروع أي المطابق للقانون " . (١)

(الضابط الثاني - بحث عدم المشروعية في الدعوي) :

عيوب القرار الإداري طالما أثبتتها حكم الإلغاء في دعوى منفصلة ، إذا رفعت دعوى التعويض بعدها ، أو رفع طلب التعويض مقترناً بطلب الإلغاء وثبت عدم مشروعية القرار ، فإن حكم الإلغاء يكون أساساً في ذلك ، دون حاجة لبحث أوجه عدم المشروعية في طلب التعويض ، بيد أن الأمر يختلف إذا رفعت دعوى التعويض قبل دعوى الإلغاء أو غير مقترنة بها أو لم ترفع أصلاً ، فهنا لابد أن يبحث قاضي التعويض الطلب ، ويتحري عدم مشروعية القرار الإداري ، استناداً لسبب من أسباب بطلان القرار ، أو بعبارة أخرى وجه من أوجه عدم المشروعية . ويعود الأساس في ذلك إلي أن دعوى الإلغاء هي الدعوى الأصلية في فحص مشروعية القرار الإداري ؛ ومن ثم فينبغي أن يبني علي الحكم فيها الآثار التي ينبغي إعمالها في دعوي التعويض المنفصلة اللاحقة أو طلب التعويض المقترن بطلب الإلغاء في دعوى واحدة أو إذا رفعت الدعويين معاً .

(الضابط الثالث-هل ترتب كل عيوب القرار الإداري ركن الخطأ في المسؤولية؟):

ليست كل عيوب القرار ترتب ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية لجهة الإدارة علي ذات الدرجة والمعيار ؛ فإذا ثبت عيب مخالف للقانون أو المحل أو إساءة السلطة أو التعسف في استعمالها أو الانحراف بها ، ونتج عن ذلك ضرر وقامت علاقة

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في ١٩٦٠/٥/٢١ مشار إليه لدى الدكتور / سليمان الطماوي، دروس، سابق، ص ٣٥٥.

السببية بين الخطأ والضرر قامت مسؤولية جهة الإدارة لثبوت عدم مشروعية القرار كمناط لركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية. (١)

ولكن إذا كان العيبان في القرار غير المشرع هما : عدم الاختصاص أو عيب في الشكل والإجراءات ، فقد لا يرتبان تقرير المسؤولية ، إلا إذا كان هناك ارتباط بينهما وبين صلب القرار ذاته بحيث أثرا فيه ، مما أنتج الضرر (٢) ، وذلك علي حسب الأحوال الخاصة بكل حالة علي حدة .

- (مناط مسؤولية جهة الإدارة عن العمل المادي) :

- (مفهوم العمل المادي) : العمل المادي هو كل عمل أو تصرف صادر عن

جهة الإدارة ويكون غير إرادي ، ذلك أن تصرفات الإدارة نوعان :

- تصرفات إرادية ، وتصرفات غير إرادية :

والتصرفات الإرادية فهي القرارات الإدارية وقد تكلمنا عنها ، أما التصرفات

غير الإرادية ، فهي كل ما لم يدخل في نطاق ما ينطبق عليه مفهوم القرار الإداري أو تنفيذه أو نفاذه. (٣)

وينعقد الاختصاص لمجلس الدولة بنظر دعاوي التعويض عن الأضرار التي

تحدث من جراء الأعمال المادية التي قد يكون مصدرها ما يلي :

(أ) انهيار إحدى العمارات علي قاطنيتها بفعل ترخيص مزور منحتة الإدارة

لأحد الأشخاص، لبناء عمارة بالمخالفة للجسيمة للمواصفات الفنية التي ينبغي أن تتوافر قبل إصدار هذه التراخيص.

(ب) قيام جهة الإدارة بأعمال الحفر والتقيب في منطقة معينة، فيترتب علي ذلك

انهيار إحدى البنايات ؛ أو إحداث تلفيات جسيمة بالأملاك الخاصة ببعض المواطنين

(١) دكتور / محمد رفعت عبد الوهاب ، أصول ، سابق ، ص ٢٤٧ ، ٢٤٨ .

(٢) دكتور / سليمان الطماوي ، دروس في القضاء الإداري، سابق ، ص ٣٦٠ ، ٣٦١ .

(٣) دكتور / سليمان الطماوي ، دروس في القضاء الإداري ، سابق ، ص ٣٣١ ، حيث يقول : " هذه الأعمال

المادية تشمل جميع التصرفات لا تدرج تحت مدلول القرارات الإدارية بمعناها المتفق عليه ، كأن تصدم سيارة حكومية أحد الأفراد فتصيبه بجراح ، أو أن يعتدي أحد الموظفين علي فرد من الأفراد ، أو أن تجري الإدارة حفراً في الطرق العامة وتغفل إصاعتها لبلأ مما يؤدي إلي إصابة المارة من جراء سقوطهم فيها ... " .

(ج) سيارة مملوكة للدولة تحدث تلفيات بأموال بعض المواطنين ؛ أو تصطدم بسيارة أخرى مملوكة ملكية خاصة ، فينتج عن ذلك وفاة أشخاص كانوا يملك السيارة الخاصة ؛ نتيجة خطأ قائد السيارة الحكومية .

(د) عمليات التعدي علي البعض من آحاد الناس ، من قبل بعض الموظفين العموميين، مما ترتب عليه إحداث عاهة مستديمة ببعض هؤلاء ، أو وفاة بعضهم أو انتهاك عرضه، أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإضرار ، والتي تعد من قبيل الأعمال المادية التي ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة ، باعتباره قاضي القانون العام في المنازعات الإدارية .

الفصل السادس

ركنا الضرر وعلاقة السببية في المسؤولية التقصيرية

انتهينا فيما سبق إلى توافر الركن الأول في المسؤولية وهو الخطأ ، ولكنه لا يكفي لانعقادها ما لم يترتب عليه ضرر ، وتقوم علاقة سببية بينه وبين ذلك الخطأ^(١)

- (ركن الضرر) :

نتناول مفهوم الضرر وأنواعه في التالي :

- (مفهوم الضرر) : هو الأذى المادي أو المعنوي الذي يلحق صاحب الشأن

من صدور القرار الإداري غير المشروع أو من تنفيذه أو نفاذه في مواجهته. ^(٢)

- (نوعا الضرر) : الضرر نوعان : ضرر مادي، وضرر معنوي : ^(٣)

- (الضرر المادي) : هو الذي يمس المال أو يصيب مصلحة مالية للمضرور .

- (الضرر الأدبي) : هو الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور ، ولا

يمس المال بأن يصيبه في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه .

وقد استقرت المحكمة الإدارية العليا علي ما يلي في شأن الضرر الأدبي :

(أولاً) : مسؤولية الإدارة عن قراراتها تقوم علي وجود خطأ من جانبها بأن

يكون القرار فير مشروع ، أي يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في

قانون مجلس الدولة ، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ ، وأن

تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر . ^(٤)

وإذا تخلف ركن أو أكثر منها ، انتفت المسؤولية المدنية ، والضرر إما أن يكون

مادياً أو أدبياً، والضرر المادي هو : الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور ،

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٢٢٢٧ لسنة ٣٢ ق . عليا . سالف البيان . حيث ورد ما يلي : " وذلك بتحقيق أركانها الثلاث : الخطأ ، الضرر ، وعلاقة السببية بينهما " .

(٢) انظر : حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٠٣٩ لسنة ٤٣ ق . عليا . صادر بجلسة ٢١/٣/٢٠٠٢ ، المصدر مجلة المحاماة - العدد الأول - ٢٠٠٣ ، ص ٤٠٥ ، قاعدة رقم (٣٧٤) .

(٣) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٠٣٩ لسنة ٤٣ ق . عليا ، سالف الإشارة إليه بذات المصدر ، ص ٤٠٥ .

(٤) الحكم السابق ، ذات المصدر والموضع.

أما الضرر الأدبي فهو: الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور ، علي أن يكون هذا الضرر مترتباً مباشرة علي الخطأ ومحققاً. (١)

(ثانياً) : في مجال تحديد الضرر الأدبي، يمكن القول بأنه الضرر الذي لا يمس المال ، ولكنه يصيب مصلحة غير مالية للمضرور، بأن يصيبه في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه ؛ وبصفة عامة كل ما من شأنه الإيذاء المعنوي للإنسان من جراء تصرف الإدارة غير المشروع سواء كان تصرفاً إرادياً وهو القرار الإداري ، مثل القرار الصادر بنقل بعض الأشخاص من مصلحة الجمارك إلي الحكم المحلي ، فهذا يعد من قبيل الضرر الأدبي الذي يلحق بالمدعين، وقد يكون التصرف الذي أحدث الضرر عملاً مادياً .

(ركن علاقة السببية) :

لا تتعدد المسؤولية التقصيرية لجهة الإدارة إلا إذا قامت علاقة السببية بين

الخطأ والضرر ؛ وفي هذا نوضح ما يلي :

١-المقرر قضاءً أن مناط مسؤولية جهة الإدارة عن القرارات الصادرة منها وجود خطأ من جانبها ، وأن يترتب عليه ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر الناشئ عنها ، والضرر ينقسم إلي نوعين : ضرر مادي وضرر أدبي ، والضرر المادي هو: الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور يشترط أن يكون هذا الإخلال محققاً ، والضرر الأدبي هو : الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور ، بأن يصيبه في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه . (٢)

٢-إذا لم تقم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، فلا محل لقيام المسؤولية التقصيرية في هذا الفرض ؛ لأن المبدأ أن المسؤولية لا تفترض ، وأن قيام العلاقة بين الخطأ هو الأساس في انعقادها ، فإذا ساهم المضرور بخطئه في وقوع الضرر،

(١) الحكم السابق ، ذات المصدر والموضع .

(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعين رقمي ٦٧٠٦ و ٦٧٦٧ لسنة ٤٤٤ ق . عليا - صادر في ٢٠٠١/١١/٢٠ - المصدر : مجلة المحاماة - العدد الثالث - ٢٠٠٣ ، ص ٢٩٧ - ٢٩٨ ، وحكم المحكمة أيضاً في الطعن رقم ٥٨٩٩ لسنة ٤٣ ق . عليا . صادر في ٢٠٠١/١٢/٨ - المصدر السابق ، ص ٣١٣ - القاعدة رقم ١٢٢ .

فإن المسؤولية الإدارية الموجبة للتعويض تنتفي ، أو كما لو وقع الضرر نتيجة لسبب خارجي لا علاقة له بجهة الإدارة ، فهنا تنتفي أيضاً السببية. (١)

٣- بناءً على ما تقدم كله ، فإن المسؤولية التقصيرية تنتفي في حالة اختلال ركن من هذه الأركان الثلاثة : الخطأ والضرر وعلاقة السببية .

واستثناء مما تقدم ، فإن هناك حالات من المسؤولية تحقق ركن الضرر فيها ، واختل ركن الخطأ ، كما أن ركن علاقة السببية هنا لا يرتبط بخطأ ، بل بفعل أو تصرف قانوني لجهة الإدارة أو عمل مادي مشروع ، فهذه المسؤولية يتوافر لها ركن الضرر وعلاقة السببية فقط .

ومن ثم فما هو النظام القانوني لهذه المسؤولية ؟ وما هي حالاتها الخاصة ؟

- (المسؤولية علي أساس المخاطر) :

تعني هذه المسؤولية ، أن الضرر لم يكن ناتجاً عن تصرف أو عمل ينطوي علي خطأ من جهة الإدارة ، ينحدر إلي مستوي الخطأ العمدي أو الخطأ الجسيم ، وإنما بسبب الخدمة التي تؤديها مرافقها ، وبمراعاة ظروفها ومخاطرها .

- (أحكام هذه المسؤولية) :

تتمثل أحكام هذه المسؤولية في الآتي :

(أ) هذا النوع من المسؤولية يعد أحد المبادئ الهامة التي تجري في أحكام القضاء الإداري في فرنسا علي سبيل الاستثناء ؟ حيث توجد حالات استند فيها لهذه النظرية توفيراً للحماية للمضرور من جراء تعرضه لمخاطر النشاط الإداري ، التي أصابته بالضرر ، رغم أن هذا النشاط في أصله مشروع ، ومن ثم تنتفي في شأنه نظرية الخطأ. (٢)

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - الطعن رقم ٦٠١٩ لسنة ٤٦ ق . عليا جلسة ٢٠٠٢/٢/١٦ - المصدر مجلة هيئة قضايا الدولة - العدد الثالث - السنة السابعة والأربعون - يوليو - سبتمبر ٢٠٠٣ ، ص ١٢٠ .

(٢) دكتور / سليمان الطماوي ، دروس ، سابق ، ص ٣٤٩ .

ونلاحظ هنا ما يلي : ١- المسؤولية علي أساس نظرية المخاطر لا تتأسس علي الخطأ .

٢- هذه المسؤولية تعد استثناء من قاعدة المسؤولية بناءً علي الخطأ .

٣- لا تعمل هذه النظرية إلا عند عدم إمكان تأسيس المسؤولية علي الخطأ .

١- المخاطر ترتبط بالخدمة . ٥- المخاطر مسائل نسبية تخضع للظروف والملابسات .

(ب) استقر القضاء الإداري المصري علي عدم الأخذ بنظرية المسؤولية علي أساس المخاطر ، إلا إذا نص عليها المشرع صراحة ؛ ومن ثم لا تستطيع محاكم مجلس الدولة أن تقضي بها في غيبة النص الصريح الذي يقررها ، وذلك فيما اتجهت إليه أحكامه الحديثة.

(ج) ومن أمثلة هذه الحالات التي قررها المشرع المصري ، ما نص عليه القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ للقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٨ ، وذلك بمراعاة ظروف ومخاطر الخدمة العسكرية ؛ حيث قد يصاب بعض الجنود بسبب وأثناء الخدمة بأضرار ، فهنا تقوم مسؤولية الإدارة عن التعويض ، علي الرغم من عدم وجود خطأ بل بتوافر الضرر وعلاقة السببية فقط.^(١)

- (أساس المسؤولية عن الضرر الذي يحدثه التابع) :

تقوم المسؤولية التقصيرية لجهة الإدارة علي ثلاثة عناصر هي : الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ، طبقاً لحكم المادة (١٦٣) من القانون المدني . ولكن في حالة مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع طبقاً لحكم المادة (١٧٤) من القانون المدني ؛ فإن أساس هذه المسؤولية هو علاقة التبعية بين جهة الإدارة وبين العامل وفق القواعد الآتية :^(٢)

١- تقوم هذه المسؤولية علي أساس مغاير للمسؤولية علي أساس الخطأ ، إذ يكفي لقيام هذه المسؤولية ، أن يثبت وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها .

٢- تقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعيه، متى كان له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه .

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في ٢٠٠١/١٢/٨ في الطعنين رقمي ٢٤٤٨ و ٢٤٨٥ ق . عليا - المصدر : مجلة المحاماة - العدد الثالث ٢٠٠٣ ، ص ٣١٨ ، ٣١٩ ، القاعدة رقم ١٣٢ .

ونلاحظ هنا ما يلي :

١- أن الأصل هو المسؤولية علي أساس الخطأ ، وفي حالة تقرير نص خاص بالمسؤولية علي أساس المخاطر فتكون هي المعيار ، ما لم تقرر بخطأ تقصيري فيمكن الجمع بين نوعي المسؤولية .

٢- المسؤولية علي أساس المخاطر تتطلب أن يكون الضرر قد حدث أثناء وبسبب الخدمة في المرفق

(٢) الفتوى رقم ١٠٠ صادرة في ٢٠٠٠/٢/٢٩ ملف رقم ٣١٠٢/٢/٣٢ ، المصدر : مجلة المحاماة - العدد الأول ٢٠٠١ ، ص ٤٠٨ - ٤٠٩ - قاعدة رقم (١١) .

٣- مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه هي مسؤولية مصدرها العمل غير المشروع ، وهي لا تقوم في حق المتبوع ، إلا حيث تتحقق مسؤولية التابع وتندور معها وجوداً وعدمًا.

- (أساس المسؤولية عن الضرر في حالات الحراسة) : لقد اتجه مجلس الدولة في فتواه إلي افتراض المسؤولية وفق ضوابط معينة كشفت عنها العديد من فتاويه الصادرة في هذا الشأن ، والمتصلة بالموضوع ، حيث قد ذهب في إحداها إلي أن : " الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له مكنة السيطرة علي الشيء يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير ، فإذا أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ في جانبه ، والتزم بتعويض الغير كما يلحقه من ضرر بسبب الشيء الخاضع لحراسته ، ولا تنتقل هذه الحراسة إلي تابعه المنوط به استعمال الشيء ، لأنه وأن كانت التابع له السيطرة المادية علي الشيء وقت استعماله ، إلا أنه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ، ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته ، وبذلك فإنه يكون خاضعاً للمتبوع وحده ، وهو الحارس علي الشيء كما لو كان هو الذي يستعمله ، ولا يعفيه من الالتزام إلا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبي ، رغم ما بذله من عناية في الحراسة ، وقد يكون السبب الأجنبي قوة قاهرة أو حادثاً مفاجئاً أو خطأ المضرور أو للغير " (١) .

وفي جميع حالات المسؤولية التي تنشأ عن الحراسة تنطبق عليها القواعد السابقة وهي قواعد مصدرها القانون المدني ، وتمثل من جانب طريقاً للمضرور لاقتضاء التعويض في ظل ضمانات قد تكون أكثر فائدة له .

(١) فتوى رقم ١٠٥ بتاريخ ٢٩/٢/٢٠٠٠ ملف رقم ١٩٩٥/١٢١ ، المصدر : مجلة المحاماة - العدد الأول - ٢٠٠١ - ص ٤٢٥ ، ٤٢٤ قاعدة رقم (٧) .

الفصل السابع التعويض

(التعويض هو أثر المسؤولية بأنواعها) :

من أثر انعقاد المسؤولية ثبوت حق المضرور في التعويض الكامل عن الضرر ؛ بحيث يجبر هذا الضرر كلية فيما لحقه من خسارة وما فاتته من كسب، (١) وذلك كقاعدة عامة .

ونشرح المفاهيم والقواعد والأحكام المتصلة بالتعويض كما يلي :
(مفهوم التعويض) :

(أ) التعويض : هو المقابل النقدي أو غير النقدي الذي يحصل عليه المضرور لقاء ما يجبر الضرر الذي حاق به ، وهو نوعان :
الأول - تعويض بمقابل . الثاني - تعويض عيني .
وللنوع الأول صورتان وهما :

(الصورة الأولى) : التعويض النقدي، وهو المبلغ المالي الذي يحصل عليه المضرور، والذي يجبر الخسارة اللاحقة به والكسب الفائت عليه كقاعدة عامة .
(الصورة الثانية) : وهو التعويض غير النقدي بإجراء معين يتم اتخاذه بما يجبر الضرر .

أما التعويض العيني فيكون بالحكم بعمل معين علي سبيل التعويض (٢).

(القواعد والأحكام المفصلة للتعويض):

١. يقدر القاضي التعويض إذا لم يكن مقدراً بنص القانون ، كما أنه يتعين عند تقدير التعويض، تقصي وجود الخطأ المشترك وأثره ، وذلك عملاً بالقاعدة الواردة في ٢١٦ من القانون المدني والتي جري نصها علي : " يجوز للقاضي أن ينتقص مقدار التعويض أولاً يحكم بتعويض إذا ما كان الدائن بخطئه قد اشترك في أحداث

(١) دكتور / محمد رفعت عبد الوهاب ، أصول القضاء الإداري ، سابق ، ص ٢٥٣ - ٢٥٤ .

(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٨٣٠ قضائية - عليا - سالف الإشارة إليه ذات المصدر ، ص ١٣٥٢ .

الضرر أو زاد فيه " ، ومؤدي هذه القاعدة أن المضرور لا يتقاضى في كل الأحوال تعويضاً كاملاً بل يتحمل نصيبه من المسؤولية إذا كان هناك ما يدعو لذلك . (١)

٢. التعويض بمقابل إما أن يكون نقدياً أو غير نقدي ، وهذا ما قصده القانون المدني بالنص علي أن : " يقدر التعويض بالنقد علي أنه يجوز للقاضي تبعاً للظروف وبناءً علي طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلي ما كانت عليه أو يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك علي سبيل التعويض " . (٢)

٣. التعويض يدور وجوداً أو عدماً مع الضرر ويقدر بمقداره بما يحقق جبره دون أن يجاوزه حتى لا يثري المضرور علي حساب المسئول دون سبب (٣) ، فإذا كان الضرر ثابتاً حيث استقرت عناصر تقدير قيمته وقت حدوثه، فإن العبرة في هذه الحالة في تحديد مقدار التعويض يكون بوقت حدوث الضرر، ولا يتأتى تقدير التعويض عند صدور الحكم إلا إذا كان الضرر متغيراً تغيراً فعلياً (٤) .

(قواعد وأحكام التعويض عن الضرر الأدبي) :

الضرر الأدبي هو الذي لا يمس المال ، ولكنه يصيب مصلحة غير مالية للمضرور ، فيصيبه في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه ، وإذا كان التعويض عن الضرر الأدبي أمراً مقررأً بنص القانون ، فإن التعويض بمعناه الواسع إما أن يكون تعويضاً عينياً أو تعويضاً بمقابل ، والتعويض بمقابل إما أن يكون نقدياً أو غير نقدي ، ويجد التعويض غير النقدي مجاله الطبيعي ، في التعويض عن الضرر الأدبي في الحالات التي يكون فيها هذا التعويض كافٍ لجبر الضرر ، وذلك عن طريق أمر

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٧٧٤ لسنة ٣٢ ق ، عليا ، صادر في ١٢/٥/١٩٩٢ - المصدر : مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا - السنة السابعة والثلاثون ، سابق ، العدد الثاني ، ص ١٣٨٤ ، قاعدة رقم (١٤٩) .

وانظر حكمها في الطعن رقم ١٨٢٠ لسنة ٣٠ ق . عليا سالف الإشارة إليه ، ذات المصدر ، ويلاحظ هنا أن القاضي بمقتضي سلطته في تقدير قيمة التعويض وتحديد نوع الضرر ، يتقصي ذلك بمقتضي سلطته الكاملة في التقدير في ضوء الظروف والملايسات الجارية والتي تحيط بالمضرور ، وذلك بما يحقق العدالة في التعويض الكامل الجابر للضرر كقاعدة عامة مع ملاحظة ما قد يدخل علي هذا التعويض من نقص حسب خطأ المضرور .

(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٨٢٠ لسنة ٣٠ ق . عليا ، سابق ، ذات المصدر : في ١٣٢٥ .

(٣) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٠٣٩ لسنة ٤٣ ق . عليا . سابق ، ذات المصدر ، ص ٤٠٥ .

(٤) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٧٧٤ لسنة ٣٢ ق . عليا . سابق ، ذات المصدر ، ص ١٣٨٥ .

القاضي بإعادة الحال إلي ما كانت عليه ، أو الحكم بأداء معين متصل بالعمل غير المشروع (١) .

والمحكمة هي التي تقدر حدوث ضرر أدبي من عدمه ، فإذا خلت الأوراق من أي دليل أو مستند يفيد وقوع أضرار أدبية علي الشركة الطاعنة سوى ما ذكرته من أنها ظهرت بمظهر المتراجع عن الوفاء بالتزاماتها ، وهو أمر لا يكفي مجرد ذكره لإثبات الضرر الأدبي ، لأن العدول عن تنفيذ الصفقات الجارية موقف مألوف في المعاملات ، لأن الضرر الأدبي واجب الإثبات ، ويلزم القطع بدليل عليه ، وهو ما لم يتوافر في العناصر المطروحة للنزاع ومن ثم فلا يكون للشركة الطاعنة حق في التعويض الأدبي (٢) .

ولكن قد لا يكفي هذا التعويض غير النقدي لجبر الضرر ؛ وهنا يجوز للقاضي أن يحكم بالتعويض النقدي بمبلغ من المال ، ولا يتعارض ذلك مع ما استقر عليه القضاء الإداري من أن إعادة العامل المفصول إلي عمله خير تعويض له مادياً وأدبياً ، ولكن لابد أن تتحري المحكمة من مدي وقوع الضرر الأدبي وكونه ثابتاً بالقطع . إذا هناك حالات ثلاث مفترضة للعلاقة بين التعويض ونوعية الضرر الأدبي ، ونتناول هذه الحالات الثلاث في الآتي :

(الحالة الأولى - التعويض غير النقدي كافٍ لجبر الضرر الأدبي الحادث) :

(القاعدة) - لما كان المجال الطبيعي للأخذ بالتعويض غير النقدي هو الضرر الأدبي في الحالات التي يكون فيها هذا التعويض كافٍ لجبر الضرر ؛ فإنه إذا ثبت أن الإجراء الذي تم اتخاذه لذلك كافٍ ، فلا محل هنا للمطالبة أو الحكم بتعويض نقدي (٣) .

(تطبيق) :- قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه : " ومن حيث أنه قد ثبت من الوقائع أن قرار نقل المدعين من الجمارك إلي الحكم المحلي ألغي بحكم محكمة القضاء الإداري ، ونهضت الجهة الإدارية إلي تنفيذ هذا الحكم تنفيذاً كاملاً بإزالة كل

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٨٢٠ لسنة ٣٠ ق . عليا . سابق ، المصدر ، ص ١٣٥٢ .

(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا ، طعن رقم ٧٧٤ لسنة ٣٢ ق . عليا ، ذات المصدر ص ١٣٨٦ .

(٣) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٨٠٢ لسنة ٣٠ ق . عليا - سابق ، ذات المصدر ، ص ١٣٥٢ .

ما يترتب علي قرار النقل الملغي من آثار ، فإن ذلك كاف وحده لجبر الأضرار الأدبية التي تكون قد أصابت المدعين بسبب هذا القرار ، وتبعاً لذلك فلا يكون للمدعين أصل حق في المطالبة بتعويض نقدي عن مثل هذه الأضرار ، بعد أن تم جبرها علي الوجه المتقدم ، لأن المقرر قانوناً أن التعويض لا بد وأن يكون بقدر الضرر حتى لا يثري المضرور علي حساب المسئول دون سبب .

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه إذ قضي بغير هذا النظر ، يكون قد خالف القانون وخطأ في تأويله وتطبيقه ، مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض الدعوى وإلزام المدعين بالمصروفات " (١)

(الحالة الثانية - التعويض غير النقدي غير كاف لجبر الضرر الأدبي) :

(القاعدة) :- لقد استقر قضاء مجلس الدولة علي أنه إذا ألغت المحكمة قرار إنهاء الخدمة مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، فإن مقتضي تنفيذ الجهة الإدارية للحكم إعادته للعمل وترقيته وصرف مستحقاته ، وهي عناصر تمثل كل ما لحق الطاعن من ضرر ، ويعتبر ذلك خير تعويض عن الأضرار ، الأمر الذي يترتب عليه عدم وجود مقتضي لطلب التعويض أو الحكم به (٢) .

ولكن المحكمة قد ترى في التعويض بمبلغ من النقود ، بالإضافة إلي التعويض غير النقدي ضرورياً ، من حيث كونه مكماً لجبر الضرر الذي حاق بالمدعي ، إعلاناً عن تقدير المحكمة للأضرار التي حاق بالمطعون ضده من الناحية الأدبية ، وجبرها بهذا المبلغ حتى تطيب نفس المطعون ضده ، ويعلم أن الدولة تعاف نفسها

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٨٢٠ لسنة ٣٠ ق . عليا - سابق ، ذات المصدر ، ص ١٣٥٢ ، وكانت محكمة القضاء قد سبق وقضت بإلغاء قرار النقل وما يترتب علي ذلك من آثار ؛ وقامت الجهة الإدارية بتنفيذ ذلك وأعادت المدعين إلي وظائفهم الأصلية وصرفت لهم جميع مستحقاتهم عدا الأجر الإضافي الذي لا يستحق إلا عن عمل فعلي ، ومن ثم تكون جهة الإدارة قد عوضت المدعين عن الأضرار المادية التي لحقت بهم إلا أن محكمة القضاء قد رأت أن ذلك غير كاف فقضت بتعويض عن الأضرار الأدبية وقدره ٥٠٠ جنيه لكل منهم ، إلا أن المحكمة الإدارية العليا ألغت هذا الحكم .

(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٥٧٦ لسنة ٢٨ ق . عليا ، صادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/٣٠ ، المصدر : إشارة في هامش ، ص ١٤٨٣ من مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا - السنة ٣٢ قضائية - الجز الثاني - سابق ، حيث ورد ما يلي : " إذا ألغت المحكمة قرار إنهاء الخدمة مع ما يترتب علي ذلك من آثار فإن مقتضي تنفيذ الحكم إعادته للعمل وترقيته وصرف مستحقاته وهي عناصر تمثل كل ما لحق الطاعن من ضرر ويعتبر ذلك خير تعويض عن الأضرار الأمر الذي يتعين معه رفض طلب التعويض " .

الظلم ، وتأتي أن تجرح شعور أبنائها أو تطغى علي مستقبل العاملين بها فتظلمهم وتشردهم بدون مقتضي وعلي خلاف القانون ، وهذا لا يتعارض مع المبادئ التي استقر عليها القضاء الإداري من أن إعادة العامل المفصول إلي عمله خير تعويض له مادياً (١) .

ذلك أن هناك اعتبارات معينة تدخلها المحكمة في نظرها وهي تجيل بصرها عن عناصر المنازعة المطروحة ، بما يصل بها لتحقيق العدالة في إزالة الضرر بالكامل مادياً كان أو أدبياً ، جبراً للضرر ، وإزاحة الغمة والمرارة التي استقرت في نفسه من جزاء قضاه ظلماً وتصحيحاً لوضعه بين أفراد مجتمعه .

هذا والتعويض هنا بمثابة شهادة من المحكمة تتضمن اعترافاً بالظلم الذي وقع عليه ، وأن الجهة الطاعنة رغم تنفيذها حكم المحكمة الصادرة بإلغاء قرار الفصل تعتبر ملزمة بتعويضه . وعندما يتوافر التعسف والتعنت من جهة الإدارة في حق المضرور ، فيكون ذلك مقتضياً لضرورة التعويض النقدي لجبر الضرر الأدبي ، بالإضافة إلي المقابل غير النقدي .

(الحالة الثالثة - الاكتفاء بجبر الضرر المادي دون الأدبي) : إذا توافر الضرر المادي وانتفي الضرر الأدبي ؛ فإن المحكمة تكفي بجبر الأول فقط ، حيث يتطلب التعويض عن الثاني قيام الدليل القاطع عليه ، فإذا انتفى في عناصر النزاع المطروح فلا محل للتعويض (٢) .

(التعويض عن حق لم يحصل عليه بسبب ليس راجعاً إليه) :

(القاعدة) : يرتبط بدراستنا للتعويض ، حالة وجود حق للمضرور لم يحصل عليه من جهة الإدارة لسبب ليس راجعاً إليه ، وهنا يكون من العدل اقتضاء المضرور لهذا التعويض ، جبراً لهذا الضرر الذي حاق بالمدعي بسبب ظروف العمل ومقتضياته مثلاً .

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٩٥١ لسنة ٢٩ ق . عليا . صادر في ١٩٨٧/٦/٣٠ ، المصدر : مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا - الجزء الثاني - أول مارس ١٩٨٧ - ٣٠ سبتمبر ١٩٨٧ ، مجلس الدولة ، المكتب الفني ، الناشر : نقابة المحامين - لجنة المكتبة والفكر القانوني - مكتبة المحامي - دار الطباعة الحديثة ، ص ١٤٨٩ - القاعدة رقم (٢٢٠) .

(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٧٧٤ لسنة ٢٩ ق . عليا . سابق ، ذات المصدر ، ص ١٣٨٦ .

(تطبيق) : من تطبيقات هذه الحالة ما كان يجري عليه القضاء الإداري من صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية مهما بلغت مدتها ، وذلك في ظل القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨م الملغي بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦م.

(تحول الالتزام بالتنفيذ العيني إلى الالتزام بأداء) :

مقتضي حجية الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تنفيذ تلك الأحكام وفقا لما اشتملت عليه ، ولكن حدثت مشكلة عملية متمثلة فيما قامت به الإدارة من بيع لبعض الشركات المملوكة لها وخاصة في الفترة من ٢١١ حتي ٢٠١٤ ، وقد رفعت الدعاوي بشأن طلب بطلان عقود البيع نظرا لما انطوت عليه من مخالفات قانونية ، ولما كانت هناك العديد من الأحكام القضائية قد صدرت ببطلان العديد من عمليات البيع ، فان القواعد العامة في التنفيذ تقتضي إعادة تلك الشركات إلى الدولة، ولكن عملية التنفيذ هذه اصطدمت بعقبتين :

الأولي - قيام المشتري بالتصرف في تلك الشركات للغير ، ومن ثم فقد وردت العديد من البيوع التالية عليها.

الثانية - التجاء أطراف تلك العقود إلى التحكيم ، الأمر الذي يهدد الإدارة بالعديد من أحكام التعويض الصادرة من محكم أجنبي ، والتأثير بالتالي في عمليات وجهود جذب الاستثمار لمصر. (١)

ومن ثم فقد سن المشرع قانونا في يونيو ٢٠١٩ خرج به عن القواعد العامة في تنفيذ أحكام التعويضات ، ليقرر جواز تحول الالتزام بالتنفيذ العيني إلى الالتزام بأداء التعويض الذي تقتضيه الدولة بالنظر إلى أن التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسمان متكافئان ، وذلك بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين ٨٥ و ٨٨ من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧م. ، ليصبح النص : " مع عدم الإخلال بنص المادة ٥٢ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، يجوز لرئيس مجلس

(١) انظر في المصدر : التقرير السبعون الصادر عن اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين ٨٥ و ٨٨ من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧م ، ص ٤ و ٥.

الوزراء بناء علي طلب من الوزير المختص أو من ذوي الشأن أن يحيل إلي أي من اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين (٨٥،٨٨) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ أي من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في شأن بعض الشركات التي تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأس مالها أو في نسبة منه سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه.

وتباشر اللجنتان المشار إليهما اختصاصهما وفقا للأحكام المقررة بقانون الاستثمار المشار إليه ، وله ما في سبيل ذلك الاستعانة بذوي الخبرة وتشكل لجان فرعية من بين أعضائهما أو من غيرهم " .

الباب الثاني قضاء التأديب

تمهيد وتقسيم :

يعد القانون التأديبي للوظيفة العامة باباً هاماً في دراسة القضاء الإداري ، حيث يأتي ضماناً للتحقق من الالتزام بالواجبات والامتناع عن المحظورات في ميدان هذه الوظيفة ، ومن ثم فإن الموظف الذي يخالف هذه مقتضيات يجازي تأديبياً ، بتوقيع العقوبة التي تتناسب المخالفة التي وقعت منه .

وإذا كان الجانب السابق قد راعي المصلحة العامة ، فإن مصلحة الموظف العام هي الأخرى جديرة بالاعتبار ، وبالتالي لا بد أن يحاط بتوقيع العقوبات التأديبية بالضمانات الكافية التي تحول دون الظلم الذي قد يتعرض له من جانب السلطة المختصة ، عن طريق سيف توقيع الجزاءات التأديبية .

وبناءً على هذا الاعتبار الأخير ، فلا بد من تحديد لجرم التأديبي انطلاقاً من مبدأ المشروعية ، والذي يقضي بعدم العقاب على فعل لا يعد مخالفة تأديبية ، كذلك يجب أن تتوفر للموظف المحال على سلطة التأديب كافة الإجراءات التي تمكنه من تحقيق دفاعه وسماع أقواله والاستعانة بمن يرى الاستعانة به ، وسوي ذلك من الإجراءات والضمانات .

وتأسيساً على ما تقدم نقسم هذا الباب إلى الفصول التالية :

الفصل الأول - النظام القانوني للمخالفات التأديبية .

الفصل الثاني - النظام القانوني للعقوبات التأديبية .

الفصل الثالث - السلطة التأديبية .

الفصل الرابع - الإجراءات التأديبية .

الفصل الأول

النظام القانوني للمخالفات التأديبية

يتطلب منا الكلام عن المخالفة التأديبية، أن نحدد مفهومها وأركانها سواء في التشريعات الخاصة بالعاملين أم في أحكام القضاء الإداري ، وكذلك يجب أن نتعرف علي حدود العلاقة بين المخالفات التأديبية والجرائم الجنائية ، وأثر الأحكام القضائية في المجالين الجنائي والمدني علي هذه المخالفات ، ونتناول هذه الموضوعات في المباحث التالية :

المبحث الأول

التطور التاريخي لمفهوم المخالفة التأديبية

وأركانها في التشريعات الوظيفية

لم تتعرض أي من تشريعات العاملين المدنيين بالدولة لتحديد مفهوم المخالفة التأديبية أو أركانها ، وكل ما قررته هو أن الوظائف العامة تكليف للقائمين بها ، هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها.

ففي ظل قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦م الجريدة الرسمية - العدد ٤٣ مكرر أ في أول نوفمبر ٢٠١٦م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧م ، فقد تضمن القانون النص علي المعيار العام في السلوك الوظيفي والتأديب ، وضمنه من ثم قاعدتين :

(القاعدة الأولى) :

يتعين علي الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها ، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن ، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص .

ويحظر علي الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة ، والتجرد ، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أي عمل حزبي

أو سياسي داخل مكان عمله ، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل ، أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية ، أو نشر الدعاية أو الترويج لها (م٥٧) .

(القاعدة الثانية) :

كل موظف يخرج علي مقتضي الواجب في أعمال وظيفته ، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازي تأديبياً .

ولا يعفى الموظف من الجزاء استناداً إلي أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس ، بالرغم من تنبيهه كتابة إلي المخالفة ، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية علي مصدر الأمر وحده .

ولا يسأل الموظف مدنياً إلا عن خطئه الشخصي (م٥٨) .

(مفهوم السلوك الوظيفي في ظل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم

٢١٦ لسنة ٢٠١٧م - الجريدة الرسمية ، العدد ٢١ مكرر في ٢١ مايو سنة ٢٠١٧م) :

تضمنت هذه اللائحة التمييز بين أمرين :

(الأمر الأول - الواجبات علي سبيل المثال) :

عرف المشرع هذا السلوك بأنه يجب علي الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل علي تطبيقها ، ويتعين علي الأخص ما يأتي :

١- القيام بالعمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ، وإنجازه في المواعيد المناسبة طبقاً لمعدلات الأداء المقررة .

٢- الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتخصيص أوقات العمل لأداء واجبات وظيفته .

٣- المحافظة علي كرامة الوظيفة وحسن سمعتها ، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ، ومراعاة آداب اللباقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه .

٤- التعاون مع رؤسائه وزملائه في العمل .

٥- القيام بأي أعمال وظيفية يكلف بها ولو في غير مواعيد العمل الرسمية ، متى اقتضت مصلحة العمل ذلك .

٦- المحافظة علي ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها ومراعاة صيانتها .

٧- إبلاغ الوحدة التي يعمل بها بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها خلال شهر علي الأكثر من تاريخ التغيير.

٨- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.

٩- الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية. (انظر م ١٤٩ من اللائحة) .

(الأمر الثاني - المحظورات علي سبيل المثال) :

يحظر علي الموظف مخالفة القوانين واللوائح ، والقرارات ، والنظم المعمول بها ، ويحظر عليه علي الأخص ما يأتي :

١- مباشرة الأعمال التي تتنافي مع الحيطة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية .

٢- إفشاء أية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك دون إذن كتابي من الرئيس المختص ، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد ترك الخدمة .

٣- عدم الرد علي مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها ، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماثلة والتسوية .

٤- عدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الإطلاع عليها بمقتضي قانون إنشائه.

- ٥- عدم موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالبيانات والمستندات أو ما يطلبه من أوراق أو وثائق و غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الإطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه .
- ٦- عدم الرد علي مكاتبات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو تأخير الرد عليها ، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويق .
- ٧- الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة رسمية أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ، ولو كانت خاصة بعمل كلف به ، أو الاحتفاظ بصورة أي وثيقة رسمية أو ذات طابع سري.
- ٨- أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق وسائل الإعلام والاتصال إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس المختص.
- ٩- أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها .
- ١٠- أن يؤدي أعمالاً للغير بأجر أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة ، ومع ذلك يجوز أن يتولي الموظف بأجر أو بمكافأة أعمال القوامه أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامه أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قرى أو نسب حتى الدرجة الرابعة .
- ١١- ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته .
- ١٢- الاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن من السلطة المختصة أو من تفوضه ، وذلك دون الإخلال بأحكام قوانين التنظيمات النقابية .
- ١٣- استغلال نفوذه الوظيفي .
- ١٤- إساءة معاملة الجمهور متلقي الخدمة أو التباطؤ المتعمد في أداء الخدمة أو تأخيرها ، أو إساءة استعمال السلطة .

١٥- إساءة استخدام أدوات أو معدات العمل أو العبث بأصول وممتلكات جهة العمل أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة والعاملين والمتعاملين مع الجهة.

١٦- أن يقبل أي هدايا أو عمولة أو خدمة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته .

١٧- مباشرة أي نشاط أو إتيان أي سلوك من شأنه تكدير الأمن العام ، أو التأثير علي السلام الاجتماعي أو أي فعل يفقده حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار في شغلها . (م ١٥٠ من اللائحة) .

١٨- ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن المشرع جري علي عهده في عدم الاهتمام بالتعريفات والمفاهيم ، تاركا هذه المهمة للفقهاء والقضاء .

المبحث الثاني

مفهوم المخالفة التأديبية وأركانها

في أحكام القضاء الإداري

استقرت أحكام القضاء الإداري علي أنه نظراً لعدم تحديد المخالفات التأديبية في أي من التشريعات الخاصة بالعاملين علي سبيل الحصر - فإن أي خروج علي مقتضيات الوظيفة ، أو ما تفرضه علي شاغلها من واجبات يعد ذنباً إدارياً. ^(١) وبناءً علي هذا فإن القرار التأديبي سببه كل فعل أو مسلك من جانب الموظف راجع إلي إرادته إيجاباً أو سلباً تتحقق به المخالفة لواجبات الوظيفة العامة ، أو الخروج علي مقتضي الواجب في أعمالها ، أو الإخلال بالنهي عن الأعمال المحرمة عليه ، وبالتالي يعد هذا ذنباً إدارياً يسوغ مؤاخذته تأديبياً ^(٢) ، ولقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن : " المخالفة التأديبية لا تقتصر علي إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجاباً وسلباً ، بل تنهض كذلك كلما سلك العامل سلوكاً معيباً ينطوي علي إخلال بكرامة الوظيفة ولا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنيا ، إذ لا يقوم بين الحياة العامة والحياة الخاصة عازل سميك يمنع

(١) المجموعة سابق تحت رقم ١٧٤ - ١٢ (١٩٧١/٦/١٢) ٣١٦/٤٨/١٦ ص ١٦٨٢ .

(٢) السابق ، ذات المبدأ والموضع .

التأثير المتبادل بينهما - لذلك فإنه لا يسوغ للعامل خارج نطاق وظيفته أن يفصل عنها ويقوم ببعض التصرفات التي تمس كرامته وتمس بطريق غير مباشر كرامة الجهة التي يعمل بها ، أساس ذلك : أن سلوك العامل وسمعته خارج عمله ينعكس تماماً علي عمله الوظيفي " (١) .

ومن هنا فإن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الوظيفة العامة والحياة الخاصة للموظف ، ومن ثم فإن العامل يؤخذ تأديبياً حتى ولو كان ما صدر منه قد تم في خارج نطاق الوظيفة ، أو كان لا علاقة له بها طالما مس كرامة الوظيفة حتى لا يتخذ ذلك سبيلاً للإخلال بواجبات الوظيفة ، وبالتالي فالقول بتوافر الذنب الإداري بأركانه يتطلب منا أن نراعي الدقة في ضبطه.

ضوابط تحديد المخالفة التأديبية :

يجب أن نلاحظ عند الكشف عن المخالفة أو الذنب الإداري مجموعة الضوابط التالية :

(أ) الأخذ بالمفهوم الواسع للصلة بين الذنب الإداري والوظيفة :

ففي حالة ما إذا كان الاجتماع سياسياً ، ولم يكن الموظف خلاله قائماً بأعمال وظيفته الأصلية ، وكان هذا الاجتماع قد انعقد بدعوة من رئيس مجلس إدارة الشركة ، والتقي فيه أعضاء مجلس الإدارة وكثير من مديري الشركة بأعضاء لجان الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكي واللجنة النقابية للعاملين بالشركة ، وكان الغرض من هذا مناقشة ما أنجزته الشركة ، وما هو منوط بها في الخطة المقبلة - وبذلك كان الموضوع المطروح للبحث هو عمل الشركة وإنتاجها وما قد يقتضيه ذلك من التعرض لمسئولية واختصاصات القائمين علي إدارتها والمنفذين لأوجه نشاطها - وإنه ولئن كان لكل من المشتركين في هذا الاجتماع أن يبدى رأيه بحرية وصراحة تامة ، وأن يتناول بالنقد ما يراه جديراً بذلك من أعمال الشركة أياً كان المسئول عنه - وأن يقترح ما يراه كفيلاً بعلاج ما فيها من عيوب - إلا أنه ليس له أن يتجاوز ذلك إلي الطعن والتجريح والتطاول دون مقتض علي الزملاء والرؤساء

(١) مجلة المحاماة ، ٣٤ ، ٣٠٠٣ ، ص ٤٠٣ ، حكم صادر في ٢٠٠٢/٣/٣٠ .

والتشهير بهم والخط من كرامتهم ، الأمر الذي لا يتفق مع المصلحة العامة ، وما تقتضيه من قيام الثقة والتعاون بين العاملين رؤساء ومرووسين - بل ومن شأنه أن يفوت الغرض الذي انعقد من أجله الاجتماع ، ومن ثم يعد ما بدر من العامل هنا خروج عن مقتضيات وظيفته يستوجب مؤاخذته تأديبياً^(١) .

(ب) اتخاذ الحق في الشكوى وسيلة للتشهير بالرؤساء يعد ذنباً إدارياً :

فالحق في الشكوى هو حق دستوري ، وللعامل أن يبلغ عن المخالفات التي تصل إلي علمه توخياً للمصلحة العامة ، إلا أن هناك حدوداً ينبغي عليه ألا يتعداها وهي^(٢) ١- يتعين علي العامل عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عما تقتضيه الوظيفة من توقيير الرؤساء واحترامهم .

٢- أن يكون قصده من الإبلاغ الكشف عن المخالفات توصلًا إلي ضبطها، لا أن يلجأ إليهم مدفوعاً بشهوة الإضرار بالرؤساء والكيد لهم ، والطعن في نزاهتهم علي غير أساس من الواقع.

٣- ألا تتخذ الشكوى ذريعة للتطاول علي الرؤساء بما لا يليق أو تحديدهم أو التشهير بهم .

٤- إذا لجأ العامل إلي اختلاق وقائع لا أساس لها ، أو بالباس واقعة لا مأخذ عليها ثوب المخالفة ، أو اتخاذ ما قد يكون مخالفة من أحد العاملين أو بعضهم ذريعة لاتهام الرئيس الإداري بأمر لا يد له فيها ، ولا تجوز مساءلته عنها ، فإن ذلك يتجاوز المصلحة العامة ، ويدخل في مجرد الكيد والتشهير .

فإذا خرج العامل عن الحدود السابقة ، فإنه يكون قد أخل بواجبات وظيفته، وارتكب ذنباً إدارياً يستوجب مؤاخذته تأديبياً.

(ج- ضرورة إقامة الدليل علي الإدعاء بوقوع المخالفة التأديبية :

فيجب علي سلطة الاتهام أن تقيم لدليل علي المخالفة التأديبية ، فتقرير الإدانة لابد أن ينبني علي القطع واليقين ، ومن ثم لا يكفي مجرد الإدعاء الذي لم يعضده ما يرقى به إلي مصاف الحقيقة ، وهو الأمر الذي تستجليه السلطة التأديبية المختصة ،

(١) المجموعة المبدأ تحت رقم ٩٩٥ - ١٣ (١٩٦٨/١٢/١٤) ١٣١/١٧/١٤ ، ص ١٦٨٤ ، ١٦٨٥ .

(٢) السابق المبدأ تحت رقم ٢٦٤ - ١٩ (١٩٧٤/٦/٢٩) ٤٦٣/٥٨/١٩ ، ص ١٦٨٥ - ١٦٨٩ .

وبالتالي فعدم وجود تحديد منضبط لما يعد من قبيل المخالفة التأديبية، لا يعني أن يلقي الإدعاء دون وجود ما يدعمه ويؤازره، حيث أن الأصل في الإنسان البراءة^(١).

(د) مناط المسؤولية التأديبية :

تقوم المسؤولية التأديبية علي أساس التيقن من وجود فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة من العامل في قيام الذنب الإداري ، فإذا انتقي المأخذ الإداري علي سلوكه واستبان أنه لم يقع منه ما يشكل مخالفة تستوجب العقاب الإداري ، فإن القرار الذي يوقع عليه جزاءاً تأديبياً في هذه الحالة يكون مفتقراً إلي سببه القانوني^(٢).

(هـ) سلطة تحديد المخالفة التأديبية :

نظراً لعدم تحديد المخالفات التأديبية علي سبيل الحصر ، كما أن ما ساقه المشرع من أمثلة لها كان في عبارات عامة ، فإن السلطة التأديبية هي التي تحدد ما إذا كان هناك مخالفة تأديبية في ضوء ما تتطلبه الوظيفة العامة في مثل نوعها وظروف العامل ، ولذا تقول المحكمة الإدارية العليا : " ومن حيث أن الثابت فيما تقدم أن المطعون ضده قد ارتكب المخالفة التي بني عليها قرار الجزاء المطعون فيه الذي قضي بخفض وظيفته ومرتبته ، وأن صدور هذه المخالفة ممن في مثل وظيفة المدعي وثقافته القانونية أمر من شأنه أن يسبغ عليها طابع الجسامة ، ومن ثم يقتضي تشديد العقاب وعلي ذلك يكون القرار المذكور قد صدر مستوفياً أركانه القانونية ومتفقاً مع حكم القانون فيما قام عليه من سبب وما انتهى إليه من جزاء"^(٣) .

ومن ثم تملك السلطة التأديبية الأعلى التعقيب علي الوصف الذي أسبغته السلطة الأدنى ، وتملك أن تلغي الجزاء التأديبي إذا لم يكن هناك ثمة مخالفة حيث يفتقر هذا الجزاء إلي سببه ، وتستطيع من ناحية أخرى أن تعيد الأمر إلي التناسب بين المخالفة

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في ٢٣/١٢/٢٠٠١ في الطعين رقمي ٥٢٨٦ ، ٥٣٧٨ ، س ٤٢ ق .عليا ، المصدر السابق ، ص ٣٢٨ ، حيث خلصت المحكمة إلي أن : " ما يرد بتقرير الاتهام إنما هو إدعاء بارتكاب المتهم للمخالفة التأديبية ولذلك فإن تطبيقاً للقاعدة الأصولية القاضية بأن البيئة علي من ادعى يكون علي جهة الاتهام أن تسفر عن الأدلة التي انتهت منها إلي نسبة الاتهام إلي المتهم " .

(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٧٩٣ ، س ٤٣ ق .عليا ، صادر في ٢٣/١٢/٢٠٠١ ، المصدر السابق ، ص ٣٢٨ ، ٣٢٩

(٣) المجموعة ، سابق ، ص ١٦٨٩ ، سالف الإشارة إلي هذا الحكم .

وما وقع من جزاء ، فإذا كان للسلطة التأديبية : " تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة ألا يشوب استعمالها غلو ومن صوره عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره ، ومؤدي ذلك خروج ذلك التقدير من نطاق المشروعية إلي نطاق عدم المشروعية، ومن ثم يخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا التي تخضع لرقابتها أيضاً الحد الفاصل بين النطاقين ، ومن هذا جاء تدرج القانون بالعقوبات التأديبية مبتدأ بالإنذار وانتهاء بالفصل من الخدمة علي نحو يتحقق بالتعدد في الجزاءات هدف العقاب ومشروعيته بزجر مرتكب الفعل وغيره وتأمين سير المرافق العامة " . (١)

والمحكمة الإدارية العليا حين يطعن أمامها في أحكام المحاكم التأديبية ، فهي تراقب الناحية القانونية ، ولا يعني ذلك استئناف النظر في الحاكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً ، إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها.

والمحكمة الإدارية العليا لا تتدخل وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء المحكمة غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق وكان استخلاص هذا الدليل لا تنتج الواقعة المطروحة علي المحكمة ، فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح حكم القانون، لأن الحكم في هذه الحالة يكون قائماً علي غير سبب يبرره ، ومن ثم تنبسط رقابة المحكمة الإدارية العليا علي الوصف الذي تضعه المحكمة التأديبية للمخالفة ، وتعيد التوازن إلي الجزاء الذي سبق وقررت المحكمة التأديبية للمخالفة ، كما تملك إلغاء هذا الجزاء في حالة ما إذا لم يكن هناك ثمة مخالفة تأديبية (٢).

وفي خارج هذا الإطار تظل المحكمة التأديبية ذات سلطة في استخلاص النتيجة التي انتهت إليها استخلاصاً سائغاً من أدلة تنتج مادياً وقانونياً ، وقامت بتكييفها التكييف السليم الذي يتفق وصحيح القانون ، ومن ثم كانت عقيدة المحكمة قد تكونت

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في ٢٣/١٢/٢٠٠١ في الطعن رقم ٨٧٧٧ س ٤٦ ق . عليا ، مجلة المحاماة ، ع ٣ ، ص ٢٠٠٣ ، ص ٣٢٩ ، ٣٣٠ .

(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا في ٢٥/١١/٢٠٠١ ، في الطعن رقم ٦٠٣٢ ، س ٤٣ ، عليا ، المصدر السابق ، ص ٣٠١

استناداً لهذا ، وبالتالي فلا محل لمراجعة ما خصت إليه ، طالما أن لها الحرية في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . (١)

(و) ارتكاب المخالفة تنفيذاً لأمر الرئيس :

لا يملك العامل أن يستند إلي أنه قد ارتكب المخالفة التأديبية تنفيذاً لأمر صادر له من رئيسه ، ومن ثم إعفائه من العقاب ، إلا إذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلي المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية علي مصدر الأمر وحده ، ولا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي .

المبحث الثالث

القواعد الضابطة للعلاقة بين المخالفة التأديبية

والجريمة الجنائية والخطأ المدني (٢)

بان لنا فيما سبق أن المخالفات التأديبية لم ترد علي سبيل الحصر ، وعلمنا كيف تتولي السلطة التأديبية المختصة استخلاص وقوع الذنب الإداري من الأصول المادية والقانونية التي تنتج في ضوء الاعتبارات المتعلقة بالوظيفة ، ومثل ظروف الموظف الذي حدث منه هذا الذنب وثقافته القانونية ، وما يفترض توافره فيه تحقيقاً للمصلحة العامة للوظيفة .

وبناءً علي هذا ، فإن الركن المادي في المخالفة التأديبية يتمثل في إخلال العامل بواجباته الوظيفية أو خروجه علي مقتضياتها ، ومن ثم فإن المخالفة التأديبية ترتبط بالوظيفة العامة والموظف العام ، وتتغيا دائماً الحفاظ علي كرامة هذه الوظيفة وهيبتها. (٣)

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في ٢٥/١١/٢٠٠١ ، في الطعن رقم ٦٢٣٤ ، س ٤٣ ق. عليا، المصدر السابق، ص ٣٠١

(٢) نأخذ هنا بالمفهوم الواسع للجريمة الجنائية وسواء أكانت من قبيل المخالفات أم الجنايات ، وأياً كان نوع العقوبة المقررة للجريمة مالية أو سالبة للحرية أو سواها ، وبالنسبة للمسئولية المدنية التي تترتب علي الخطأ المدني فهي تشمل الأفعال التي قد تقع من الموظف وترتب هذه المسؤولية .

(٣) حكم المحكمة الإدارية العليا في ٢٣/١٢/٢٠٠١ في الطعن رقم ٣٨٤٥ ، س ٤٠ ق عليا ، مجلة المحاماة ، العدد السابق ، ص ٣٢٧ .

ونتناول العلاقة بين المخالفة التأديبية والجريمة الجنائية والخطأ المدني علي

النحو التالي :

(أ) المخالفة التأديبية والجريمة الجنائية :

الجريمة الجنائية تشكل إهداراً لمصلحة حماها المشرع الجنائي عن طريق تجريم فعل أو امتناع وضع له عقوبة معينة ، وبالتالي يسودها مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يتضمن جوانب ثلاثة هي :

١- تحديد الأفعال محل التجريم من قبل المشرع .

٢- تحديد العقوبات علي سبيل الحصر .

٣- الربط بين كل فعل وعقوبته المحددة .

ولما كان كل شخص يعد بهذه الصفة عضواً في الهيئة الاجتماعية، فقد يصدر عنه ما يعد إخلالاً بالمصلحة الجنائية المحمية ، وقد يكون هذا الشخص موظفاً عاماً ، ومن هنا فإن البحث يدور حول حدود العلاقة بين الجريمة الجنائية والمخالفة التأديبية .

نلاحظ في البداية ، إن هناك اختلافاً بين كلا النوعين مرده المصلحة الجديرة بالحماية ، ومن هنا فإن العلاقة بينهما تحكمها عدة قواعد ، وهي :

أولاً - الاستقلال : الأصل هو استقلال الجريمة الجنائية عن المخالفة التأديبية ، فالذنب الإداري موضوعه بحث مدى إخلال الموظف بواجبات الوظيفة العامة ، وما تفرضه عليه من واجبات ومسئوليات حسبما يستخلص من التحقيق ، أما الجريمة الجنائية فنظامها القانوني قائم علي أساس ثبوت ارتكاب المتهم جريمة من الجرائم الموصوفة كذلك في القانون ، ومن ثم فإن القضاء من قبل المحكمة الجنائية بالبراءة لكون أدلة الثبوت أو الاتهام محل شك لا يعد مانعاً من المؤاخذه التأديبية ، إذا كانت الأفعال التي وقعت من العامل تشكل ذنباً إدارياً يستوجب المحاسبة الإدارية. (١)

ثانياً - الحجية : إن للحكم الجنائي حجية أمام القضاء التأديبي بشرط هو أن يتعلق الأمر بوقوع الجريمة ونسبتها للمتهم ، علي أن يكون هذا الحكم نهائياً فاصلاً

(١) الحكم السابق ، ذات المصدر والموضع .

في الموضوع حائزاً لقوة الأمر المقضي به ، وما يجوز الحجية هنا هو المنطوق والأسباب الجوهرية وثيقة الصلة بالمنطوق ، وذلك دون أن يتقيد قضاء التأديب بالتكييف الذي خلعه القاضي الجنائي علي الفعل ، نظراً لاختلاف التكييف في حالة المسألة التأديبية عنها في الحالة الجنائية (١) ، وتطبيقاً لهذا قضي بأن : " القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفي المسؤولية الجنائية من الأفعال التي تكون جرائم جنائية ، ومتى قضي في هذه الأعمال بحكم جنائي حائز لقوة الأمر المقضي به ، فلا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي ، أن تعاود البحث في ثبوتها أو عدم ثبوتها ، وتتقيد المحكمة التأديبية بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي (٢) .

ثالثاً - قيود الحجية : إن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء التأديبي ، لا يمنع الأخير من إعادة بحث الموضوع ، إذا كان الحكم الجنائي قد انتهى إلي تبرئة المتهم استناداً لعدم ثبوت الواقعة أو عدم نسبتها إليه ، أما إذا كان أساس هذه البراءة هو الشك في حدوث هذه الواقعة ، أو الشك في هذه النسبة ، فلا يحول ذلك دون إعادة النظر في الموضوع من قبل المحكمة التأديبية (٣) ، وتطبيقاً لهذا قضي بأن الحكم الجنائي الذي قضي ببراءة زوجة المطعون ضده لعدم كفاية الدليل المقدم ضدها ، إذ أنه مع هذا الحكم ، لا تزال للسلطة الإدارية حرية التقدير والموازنة فيما قدم لها من وقائع وأثرها علي سمعة المطعون ضده كموظف عام ، ومن ثم فقد انتهت المحكمة الإدارية العليا إلي جواز إعادة النظر في الأفعال المرتكبة من قبل المحكمة التأديبية وتوقيع الجزاء الملائم عليه . (٤)

رابعاً - معيار الذنب الإداري : لا يصح في مجال التأديب رد الفعل إلي نظام التجريم الجنائي والتصدي لتوافر أو عدم توافر الجريمة الجنائية بأركانها ، أو معالجة

(١) الحكم السابق ، ذات المصدر والموضع .

(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا في ٢٠٠١/١١/١١ ، في الطعن رقم ٢٢١٤ سنة ٤١ قضائية ، عليا ، المصدر السابق ، ص ٢٨٧ .

(٣) انظر نقلاً عن د / محمد ماهر أبو العنين ، الضمانات والإجراءات التأديبية ، ط ٢ ، ١٩٩٤ ، ص ٤٠١ ، ٤٠٢ .

(٤) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٦٣٤ س ٣ ق في ١٩٥٨/٣/٨ ، والطعن رقم ٣٧٨ س ٩ ق جلسة ١٩٦٣/١١/٢١ من ١٠ نقلاً عن المصدر السابق ، ص ٤٠٢ .

المخالفة التأديبية من زاوية جنائية من ناحية ثبوتها أو عدم ثبوتها ، فهذا كله ينطوي علي إهدار مبدأ استقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية ، وإنما الصحيح هو النظر إلي الوقائع المكونة للذنب نظرة مجردة لاستكشاف ما إذا كانت تلك الوقائع تطوى خروجاً علي واجبات الوظيفة ومقتضياتها فتقوم المخالفة التأديبية^(١) .

خامساً - أثر أوامر النيابة العامة علي التأديب : الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ أو بالألا وجه لقيام الدعوى الجنائية ، فإن هذا لا يعني عدم مؤاخذته تأديبياً ، هذا إذا كان وجه الحفظ أو ألا وجه هو عدم كفاية الأدلة أو الشك في نسبتها التهمة إلي المتهم ، وتطبيقاً لهذا قضي أن : " الثابت من استعراض وقائع النزاع علي نحو ما سلف أن المجلس الخاص للشئون الإدارية عندما قرر تخطي المدعي في الترقية ولوظيفة مشار مساعد (أ) كان تحت نظره الاتهامات المنسوبة إليه في القضية رقم ٦٥ لسنة ١٩٨٤ أمن الدولة العليا ، وهي اتهامات لها خطورتها البالغة ، وإذا كانت النيابة العامة قد قررت حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة ، فإن ذلك لا يعني بالضرورة - وفقاً للمستقر في قضاء المحكمة الإدارية العليا - عدم إدانته تأديبياً وهو ما تحقق فعلاً بصدر قرار الهيئة المشكل منها مجلس التأديب بإدانته فيما نسب إليه ونقله إلي وظيفة معادلة غير قضائية ، ومن ثم فإن قرار تخطيه قد قام علي أساس من الأفعال المنسوبة إليه ، والتي أدين بسببها علي النحو المشار إليه يضحى مصادفاً محله في القانون ، إذ لا يتفق ومنطق الأمور أن يتخذ المجلس قراراً بترقية الطاعن ، وقد أحاطت به اتهامات بمثل هذه الخطورة انتهت فعلاً بإدانته ، ولا مقتنع في القول بأن في ذلك إخلالاً بالقاعدة المستقرة من أنه لا يجوز أن يكون للظروف اللاحقة أثر ينعطف علي الماضي عند وزن وتقييم مدي مشروعيته القرار الإداري ، ذلك لأن الأفعال المنسوبة للمدعي والتي تخطى بسببها حدثت - علي ما يبين من الواقع - في تاريخ سابق للتخطي هو كاشف عن الحالة التي كان عليها المدعي في تاريخ تخطيه ، من حيث أنه كان مرتكباً للأفعال التي أدين بسببها ، ولا تثريب علي جهة الإدارة

(١) المجموعة ، سابق ، المبدأ تحت رقم ٧٩٥ - ١٦ (١٩٧٣/٦/٢) ١١٢/٦٨/١٨ ، ص ١٦٨٩ ، ١٦٩٠ .

إن هي تحسست أسباب التخطي وموجباته، فنأت بالمنصب القضائي علي علو قدره عن أن يشغل بمن لا يستكمل أهلية ثبوته " (١) .

سادساً - الإجراءات الجنائية توقف الإجراءات التأديبية : إذا كان القضاء التأديبي يتقيد بما سبق وفصلت فيه المحكمة الجنائية بحكم حاز قوة الأمر المقضي به ، فإنه من الواجب وقف نظر الدعوى التأديبية حتى يقول القضاء الجنائي كلمته في الموضوع ولكن ذلك مقيد ، بأن تكون الأفعال التي هي موضوع الدعوى الجنائية ذاتها المكونة للمسئولية التأديبية ، فإذا أثبتت الدعوى الجنائية كان من واجب سلطة التأديب أن توقف نظر الدعوى التأديبية ، حتى تقول المحكمة الجنائية كلمتها في الموضوع بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به (٢) ، ولا محل لهذا إذا لم تثر الدعوى الجنائية .

تقول المحكمة الإدارية العليا : " إذا استندت السلطة التأديبية إلي ذات الوصف الجنائي للاتهام محل المحاكمة الجنائية كأساس للمساءلة التأديبية فإنه يتعين عليها التريث لحين صدور حكم بالإدانة باتاً ونهائياً " (٣) .

(ب) المخالفة التأديبية والخطأ المدني : أشار المشرع في المادة ١٦٣ من القانون المدني إلي أن : " كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض " ، وتقوم هذه المسئولية علي أساس توافر أركان ثلاثة وهي : الخطأ ، والضرر ، وعلاقة السببية بينهما . (٤)

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في ١٩٨٧/٣/١ في الطعن رقم ١٩٠٧ ، س ٣١ ق . عليا ، منشور في مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا ، ج ٢ ، من أول مارس ١٩٨٧ - ١٩٨٧/٩/٣٠ ، نقابة المحامين ، لجنة المكتبة والمفكر القانوني ، ص ٨٩٩ .

(٢) سمير يوسف البهي ، قواعد المسئولية التأديبية ، دار الكتب القانونية ، ٢٠٠٢ ، ص ١٢٩ .
(٣) حكم الإدارية العليا في الطعن رقم ١٥٣ س ٣٨ ق ، عليا ، في ١٩٩٧/٥/٢٤ ، نقلاً عن المصدر السابق ، ص ١٣٠ .

(٤) انظر د / محمود أبو العنين ، الموسوعة الجامعية لأحكام المحكمة الإدارية العليا ، دار الفكر الجامعي ، ط ٢٠٠٣ ، ج ٤ ، ص ٢٥٧ ، ٢٥٨ .

وبالتالي يختلف ذلك عن أساس المخالفة التأديبية، وهو الإخلال بواجبات الوظيفة والخروج علي مقتضياتها وإهدار كرامتها ، وذلك دون أن يتطلب قيام المسؤولية عن هذه المخالفة وقوع ضرر أو خطأ بمفهوم القانون المدني.^(١)

ولذا فقد نص قانون العاملين المدنيين بالدولة الملغي في المادة ٧٨ علي أنه : " كل عامل يخرج علي مقتضي الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً . ولا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطأه الشخصي " . وفي ذات المعني راجع م ٥٨ من قانون الخدمة المدنية ٨١ لسنة ٢٠١٦م . وتطبيقاً لهذا قررت المحكمة الإدارية العليا بأنه : " ومن حيث إنه يلزم التقرير ابتداءً بأنه ليس كل خطأ يرتكبه الموظف العام خارج نطاق وظيفته العامة يرتب مسؤوليته التأديبية ، وإنما يتعين لقيام تلك المسؤولية أن يصل الخطأ ويرقي إلي الحد الذي يمس كرامة الوظيفة وينال من الاحترام الواجب لها ، فإن نأى الخطأ المرتكب عن هذا الإطار بحيث لم يكن له ثمة تأثير علي الوظيفة فلا يسأل عنه الموظف داخل مجال وظيفته تأديبياً، حتى ولو كان ذلك الخطأ مرتباً لنوع آخر من المسؤولية كالمسؤولية المدنية " ^(٢) .

المبحث الرابع

النطاق الشخصي للمخالفات التأديبية

كانت محاكم مجلس الدولة هي المختصة بنظر المنازعات التأديبية المتعلقة بالعاملين المدنيين بالدولة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية ، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ، كما تختص بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب التي تتصل بالعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة ، وكذلك العاملين بالقطاع العام والخاضعين للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ، وظل الحال علي هذا الوضع تطبيقاً لنص المادة (١٥) من قانون مجلس الدولة رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٢

(١) انظر د / محمود أبو العنين ، الموسوعة الجامعية لأحكام المحكمة الإدارية العليا ، دار الفكر الجامعي ، ط ٢٠٠٣ ، ج ٤ ، ص ٢٥٧ ، ٢٥٨ .

(٢) انظر حكم المحكمة في الطعن رقم ٣١٧٨ س ٣٤ ق . عليا صادر في ١٩٩٢/٧/٢٥ ، منشور في مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، صادرة عن المكتب الفني بمجلس الدولة ، ص ٣٧ ، العدد الثاني ، ط ١٩٩٩ ، ص ١٩٢٢ ، ١٩٢٣

والتي نصت علي أنه : " تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من :

أولاً : العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التي تضمّن لها الحكومة حد أدنى من الأرباح .
ثانياً : أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٦٣ المشار إليه .

ثالثاً : العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديد قرار من رئيس الجمهورية ممن تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً .
كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعاً وثالث عشر من المادة العاشرة. (١)

وبناءً علي ما تقدم فإن الاختصاص لمجلس الدولة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام في الحدود القانونية المقررة في المادة ٨٤ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨، إنما كان على سبيل الاستثناء حيث لا تنطبق عليهم صفة الموظف العام ، ومن هنا فقد قرر المشرع أن مجلس الدولة يختص بالنسبة لهؤلاء بالحالات التالية (٢) :
(أ) تختص المحكمة التأديبية بالنسبة للجزاءات الواردة في البنود من ٩ - ١١ من المادة ٨٢ من قانون شركات القطاع العام ، ويكون التظلم من هذه الجزاءات أمام المحكمة الإدارية العليا .

(ب) لمجلس الإدارة - بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثانية فما فوقها عدا أعضاء مجالس الإدارة المعيّنين والمنتخبين وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية - توقيع أي من الجزاءات الواردة في القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ م ، ويكون التظلم

(١) ينص البند التاسع من المادة العاشرة علي اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر : " الطعون التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية " ، كما نص البند الثالث عشر علي اختصاص هذه المحاكم بنظر : " الطعون في الجزاءات الموقعة علي العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً " .

(٢) انظر المادة ٨٤ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ م .

من توقيع هذه الجزاءات أمام المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه .

(ج) لرئيس الجمعية العمومية للشركة بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة توقيع أحد جزائي التنبيه أو اللوم، وله توقيع أي من الجزاءات الواردة في البنود من ٨-١ علي أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية ، فيما عدا جزاء الوقف الذي يكون بناءً علي حكم من السلطة القضائية المختصة ، ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات أمام المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه.

هذا وأحكام المحكمة التأديبية في الحالات السابقة نهائية .

(د) تختص المحكمة التأديبية بتوقيع جزائي الإحالة إلي المعاش والفصل من الخدمة بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية ، ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان العامل بالحكم .

الفصل الثاني النظام القانوني للعقوبات التأديبية

مفهوم العقوبة التأديبية وخصائصها :

يقضي مبدأ المشروعية في جانبه العقابي ، بأن يحدد المشرع العقوبات التأديبية ، علي سبيل الحصر تطبيقاً لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .
وإذا كان هذا المبدأ معمولاً به في نطاق القانون الجنائي ، فإنه في ميدان العقاب التأديبي يتميز بالخصائص التالية :

- (أ) المشرع قد حدد العقوبات التأديبية علي سبيل الحصر .
- (ب) المشرع لم يربط بين كل فعل وعقوبته ، بل قام بتعداد هذه العقوبات متدرجاً من الأخف للأشد ، وترك المهمة في تحديد جسامة الفعل ، والاختيار من بين العقوبات الملائم منها - للسلطة التأديبية المختصة .
- (ج) لا يجوز للسلطة التأديبية أن توقع جزاءات تتجاوز تلك المنصوص عليها في القانون ، وذلك تطبيقاً لمبدأ شرعية العقوبة التأديبية المحددة حصراً في قانون الخدمة المدنية .
- (د) لا يعتبر إخلالاً بمبدأ شرعية العقوبة التأديبية حالة ما إذا كان الموظف خاضعاً لنظام تأديبي خاص ، وخلا قانونه من النص علي العقوبات التي توقع علي المخالفة التي تقع منه ، فهنا يرجع إلي الشريعة العامة في شأنه (١) .

المبحث الأول

العقوبات التأديبية

تتمثل العقوبات في ظل قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦م فيما يلي:

الجزاءات التي يجوز توقيعها علي الموظف وفقاً للقانون الحالي هي (م ٦١ من

القانون) :

١- الإنذار .

٢- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تتجاوز ستين يوماً في السنة .

(١) انظر حكم المحكمة الإدارية العليا في ١٩٨٧/٤/١٨ في الطعن رقم ١٢٥٧ س ٣٢ق. عليا ، مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا ، ج ٢ ، سابق ، ص ١١٤٩ - ١١٥٤ .

- ٣- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل .
- ٤- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد علي سنتين .
- ٥- خفض إلي وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة .
- ٦- خفض إلي وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلي القدر الذي كان عليه قبل الترقية .
- ٧- الإحالة إلي المعاش .
- ٨- الفصل من الخدمة .

أما الجزاءات التي يجوز توقيعها علي شاغلي الوظائف القيادية هي :

- ١- التنبيه .
 - ٢- اللوم .
 - ٣- الإحالة إلي المعاش .
 - ٤- الفصل من الخدمة .
- وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي علي أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة .
- وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة علي العاملين ، ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية ، أو الثقافية ، أو الرياضية للعاملين طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها السلطة المختصة .

الجزاء التأديبي المقنع :

يعني أن ما تتخذه السلطة الإدارية من إجراءات تخفي ورائها عقوبات تأديبية تغدو غير مشروعة ، فقد قضي بأن : ما تضمنه القرار المطعون فيه من استبعاده من وظيفته كمدير إدارة الشئون الإدارية والأفراد بمديرية كهرباء كفر الشيخ مع إسناد عمل آخر له ، فإنه لما كان من المقرر أن نقل العامل قرين الجزاء التأديبي ، ومن جهة الاختصاص بتوقيعه ، استناداً إلي نتيجة التحقيق التي صدر من أجلها الجزاء مدوناً علي ذات المذكرة التي حملت النتيجة دون إفصاح عن الوظيفة المنقول إليها ، أو تحري مدى احتياجات العمل المنقول إليه ، أو التناسب في الدرجة بين

الوظيفة المنقول منها والوظيفة المنقول إليها ، لا يعتبر ذلك نقلاً مكانياً وإنما يستتر في الواقع جزاءً تأديبياً^(١).

كما أنه يكفي للمحكمة أن تتبين من ظروف الأحوال وملابساتها، أن نية الجهة الإدارية من نقل العامل وإبعاده قد اتجهت إلي عقابه، وعندئذ يكون قرارها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ومخالفاً للقانون مما يؤدي إلي إبطاله ، حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد تضمن خصم ثمانية أيام من أجر الطاعن واستبعاده عن وظيفته وإسناد عمل آخر له الأمر الذي يؤكد أن الهيئة المطعون ضدها قد قصدت من وراء ذلك عقاب الطاعن بعقاب غير وارد في القانون أو لائحة الجزاءات الخاصة بهيئة كهرباء الريف. ^(٢)

ومن ثم فإن المحكمة تتحرى عن النقل المكاني في ضوء ظروف الحال والقرار المطعون عليه ، لتستبين ما إذا كان نقلاً مكانياً لمصلحة العمل أو جزاءً تأديبياً مقنعاً ، ومن ثم يضحى جديراً بالإلغاء لمخالفة القانون ^(٣) .

وقد نصت المادة ١٠٥ من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الحالي علي أنه: " لا يجوز للوحدة أن تستخدم النقل كوسيلة لجزاء الموظف " .

عدم جواز تعدد الجزاءات علي الفعل الواحد :

الجزاء التأديبي لا يجوز أن يتعدد أكثر من مرة عن ذات الفعل الواحد ، لأن هذا يعد إخلالاً بمبدأ شرعية العقوبة التأديبية ، فإذا قامت جهة الإدارة بتوقيع عقوبة الخصم من الأجر لمدة يومين ، ولما كان سبب القرار التأديبي هو إخلال العامل بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة ، فكل عامل يخالف الواجبات التي تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو يخرج علي مقتضى الواجب في أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة وأمانة إنما يرتكب ذنباً إدارياً هو سبب القرار الذي يسوغ تأديبه ، ولما كانت المخالفة التي وقعت من الطاعن هي

(١) الحكم السابق ، غير منشور .

(٢) الحكم السابق ، غير منشور.

(٣) انظر حكم المحكمة الإدارية العليا الذي ورد تحت رقم ٨٨٤ - ١٩ (١٩٧٨/٣/١٨) ٩٥/٢٣ المجموعة ،

سابق ، ص ١٧٠١ ، ١٧٠٢ .

قيامه بإلغاء التوكيل الخاص الذي لا يجوز إلغائه إلا بحضور طرفيه ، وذلك بحضور طرف واحد ، فإن الجزاء الموقع عليه في هذه الحالة يتفق وصحيح القانون ، ولقد قامت جهة الإدارة بمجازاة الطاعن بالإنذار لما نسب إليه في تاريخ لاحق علي القرار السابق ، ومن حيث أنه لا يجوز معاقبة الموظف تأديبياً عن ذات الأفعال غير مرة واحدة ، حيث تستنفذ السلطة التأديبية ولايتها بتوقيعها العقاب التأديبي عن ذات الجرائم التأديبية لذات العامل الذي سبق مجازاته ، لانعدام سند القانوني ومخالفته للنظام العام العقابي ، لافتقاره إلي سيادة القانون، ولما كان الأمر كذلك فإن القرار الأخير يضحى مخالفاً للقانون متعيناً إلغائه^(١) .

ومبدأ وحدة الجزاء التأديبي وعدم جواز تعدده ، هو أمر يرتبط بمشروعية هذا الجزاء ، ويتعين علي المحكمة أن تتيقن ما إذا كان هناك تعدد في العقاب أم لا، من واقع ما اتخذته جهة الإدارة من قرارات في هذا الشأن .

المبحث الثاني

التناسب وشرعية العقاب التأديبي

- مفهوم التناسب في العقاب التأديبي : العقوبة التأديبية يجب أن تتناسب مع المخالفة التي وقعت من العامل، تطبيقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في شقه المتعلق بضرورة عدم المغالاة في العقوبة، وإلا كان القرار الصادر بتوقيع العقوبة التأديبية غير مشروع ، طالما أن القانون التأديبي شابه النقص فيما يتعلق بالربط الدقيق بين الذنب الإداري والعقوبة المناسبة له

- قواعد التناسب في العقاب التأديبي : أولاً : إن السلطة التأديبية هي التي تقوم بهذا التوازن بين المخالفة والعقوبة ، وحتى تكون سلطتها مشروعة في ذلك يجب ألا يشوب استعمالها غلو ، ومن صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة الذنب الإداري ونوع الجزاء ومقداره، ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملازمة الظاهرة مع الهدف الذي تغاياه القانون من التأديب، وهو تأمين سير المرافق العامة ، مما يخرج التقدير من نطاق المشروعية إلي نطاق عدم المشروعية^(٢) .

(١) حكم المحكمة التأديبية بطنطا في ٢٤/٤/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٦٩٤ س ٣١ ق ، تأديبي طنطا ، غير منشور .

(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا وارد في مجلة المحاماة ، ٣ ، ٢٠٠٣ ، ص ٣٠٠ .

ثانياً : إن المحكمة وهي تراقب التناسب تراعي ظروف وملابسات الواقعة ، ومن ثم تملك تعديل الجزاء وتطبيق صحيح القانون .

ثالثاً : استحالة تنفيذ العقوبة يخرجها عن إطار التناسب ، فإذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان عند صدور الحكم المطعون فيه يشغل وظيفة يقال من الدرجة السادسة طبقاً للجدول الثاني المرافق لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ، وهي درجة بداية التعيين في المجموعة الوظيفية ومن ثم فإن مقتضى مجازاته بالخفض إلي وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة هو خفضه إلي وظيفة ودرجة غير موجودتين في القانون ، وهو يضحى معه الحكم الطعين مستحدثاً لعقوبة لم يأت بها المشرع ومستحيلة التنفيذ ، ويكون ذلك قد صدر بالمخالفة للقانون حقيقياً بالإلغاء ، ولما كان المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ، وكانت الدعوى مهيأة للفصل فيها ، فإن المحكمة تكتفي بخفض الأجر في حدود علاوة (١) .

رابعاً : مقياس التناسب لا يقتصر علي الغلو في الجزاء بل التراخي فيه أيضاً إلي الحد الذي لا يكون هناك ملائمة بين جسامة المخالفة والجزاء التأديبي الموقع ، فإذا كانت المخالفات الثابتة في حق المدعي لا تقف عند حد الإهمال بل تتعداه ، فإن من الأمور المستقرة : أن إهمال العامل في المحافظة علي عهده وعدم مراعاته الدقة والحذر في المسائل المالية ، يعد إخلالاً بالتزاماته الوظيفية ومقتضيات واجبه الوظيفي ، يجيز مجازاته بأقصى الجزاءات وبالتالي لا يكون هناك ثمة عدم تناسب أو غلو بين ما ثبت في حق المدعي وبين الجزاء الذي وقعته عليه الشركة ، ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه إذا انتهت الجهة الإدارية ، بحسب فهمها الصحيح للعناصر التي استخلصت منها قيام العامل بارتكاب ذنب إداري إلي تكوين اقتناعها بأن مسلك العامل كان معيباً ، وأن الفعل الذي أتاها أو التقصير الذي بدا منه كان غير سليم أو مخالفاً للقانون ، أو الواجب إتباعه في هذا الشأن كان لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك ، وتقدير ما يناسبها من

(١) حكم المحكمة في ١٩٨٧/٣/٣ في الطعن رقم ١٨٢٦ س ٢٩ ق . عليا، المجموعة ، ج٢ ، ص ٩٠٣ ، ٩٠٤

جزاء تأديبي في حدود النصاب القانوني ، دون أن يخضع اقتناعها أو تقديرها في ذلك لرقابة القضاء (١) .

خامساً : إن القرار التأديبي شأنه شأن أي قرار إداري آخر يجب أن يقوم علي سبب يبرره، فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة قانونية أو واقعية تبرر تدخلها، ولما كان السبب هو ركن من أركان القرار ، فإن للقضاء الإداري أن يراقب قيام هذه الحالة أو عدم قيامها كركن من أركان القرار ، وفي نطاق الرقابة القانونية التي تسلط علي تلك القرارات التي غايتها التعرف علي مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصاً وروحاً ، فإذا كان الثابت أن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه ، هو إخلال المدعي بالتزاماته الجوهرية وخروجه علي مقتضي واجبه الوظيفي أمر ثابت في حقه ، فإن القرار المطعون عليه يكون قد قام علي سبب يبرره ومطابقاً للقانون. (٢)

سادساً : تسبب القرار التأديبي يعد ركناً جوهرياً فيه خرج به المشرع عن القاعدة القاضية بأن جهة الإدارة غير ملزمة بالكشف صراحة عن سبب قرارها ، فلقد قررت المادة ٧٩ من قانون العاملين المدنيين بالدولة الملغي ، والمادة ٥٩ من القانون الحالي، من أن القرار الصادر بتوقيع الجزاء يجب أن يكون مسبباً ، وأن عدم تسببه من شأنه أن يبطله .

سابعاً : إنه لا يعد ازدواجاً في الجزاء التأديبي إذا قامت المحكمة بمجازاة الطاعن بخفض وظيفته إلي وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة لأنه أصاب وجه الحق وقام علي أساس سليم من الواقع والقانون بما لا مطعن عليه ، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من أن مجازاته بالعقوبة التي صدر بها الحكم المطعون عليه ، يعتبر ازدواجاً في العقاب بعد أن قام بتوريد المبالغ التي أظهرت عجزاً في عهده ، وسدد قيمة غرامة التأخير علي ما يقضي به كتاب وزارة المالية لدوري رقم ٦١ لسنة ١٩٧٨ ، وذلك أن قيام الطاعن بتوريد العجز وسداد الغرامة لا يعتبر جزاءً

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا ، وارد في المجموعة ، تحت رقم ٦٧٣ - ١٦ (١٩٧٣/١٢/٨) ٤٤/١٦/١٩ .

(٢) المصدر السابق ، المبدأ تحت رقم ٤١١ - ٤ (١٩٧٣/١١/١٠) ٣/١/١٩ ، ص ١٧٠٢ .

تأديبياً ، يحول دون توقيع الجزاء التأديبي المناسب علي ما ثبت في حقه من مخالفات تشكل إخلالاً بواجبات وظيفته ومقتضياتها (١) .

ثامناً : إنه إذا كان الأصل في القانون الدستوري الجنائي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص صريح ، حيث يحدد قانون العقوبات الجرائم تحديداً قاطعاً ببيان الفعل أو الأفعال المادية المكونة لكل جريمة والعقوبة المقررة لها ، فإن هذا المبدأ غير وارد في القانون الإداري حيث لا يوجد تحديد للمخالفات التأديبية تحديداً جامعاً مانعاً أو تحديد عقوبة معينة لكل مخالفة تأديبية تستوجب عقابه ، وتترخص الإدارة في تقدير جسامة المخالفة وتقرير العقاب المناسب لها ، خاضعة في ذلك لرقابة القضاء التأديبي بمجلس الدولة (٢) .

الاستثناء علي هذا الأصل :

إذا قام المشرع في القانون أو اللائحة بتحديد عقوبات معينة لمخالفات معينة ، فنلتزم جهة الإدارة في هذه الحالة بتوقيع العقوبة المحددة في القانون أو اللائحة للمخالفة محل المؤاخذة التأديبية ولا محل هنا لتعدي هذا إلي عقوبة أشد (٣) .

تاسعاً : في مجال قيام الجهة الإدارية بوضع لائحة لتنظيم العلاقة بين المخالفة التأديبية والعقوبة التي تناسبها ، فإنه يتعين ضرورة لالتزام بهذا التحديد ، حيث يعد هذا رجوعاً إلي الأصل المقرر لشرعية العقوبة بصفة عامة والتأديبية بوجه خاص (٤) ، ولا محل في هذا الشأن للنعي علي القرار المخالف لذلك بالصحة لأنه التزم القانون وأهدر اللائحة وهي الأدنى ، نظراً للطبيعة الخاصة للقانون الإداري التأديبي (٥) .

عاشراً : إن رقابة القضاء الإداري علي التناسب هي رقابة ملائمة ، تقيس بها المحكمة ملائمة الجزاء التأديبي للمخالفة المرتكبة ، وتملك المحكمة المطعون أمامها أن توقع الجزاء المناسب، إن كانت الدعوى جاهزة للفصل فيها .

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٠٢٤ س ٣٠ ق، عليا في ١٩٨٧/٣/١٤ المجموعة سابق ص ٩٢٥

(٢) انظر حكم المحكمة الإدارية العليا في ١٩٩٢/٣/١٧ في الطعن رقم ٣٢٣٩ ، س ٣٣ ق ، عليا ، المجموعة ،

سابق ، ص ١٠٦٤ ، ١٠٦٥ .

(٣) نفس الحكم ، المصدر نفسه .

(٤) د / محمد ماهر أبو العنين ، الضمانات والإجراءات التأديبية ، مرجع سابق ، ص ١٧٤ .

(٥) د / محمد ماهر أبو العنين ، الضمانات والإجراءات التأديبية ، نفس المرجع ، ونفس المصدر .

المبحث الثالث

العقوبة التأديبية التبعية ورد الاعتبار

حينما يوقع علي العامل أيًا من الجزاءات التأديبية ، فإن لها أثر علي الترقية ، كما أن لا يجوز أن تظل هذه العقوبة وصفاً شائناً يلزمه مدى حياته ، بل يجب أن يتم محو هذه العقوبة بعد مضي فترة معينة ، ونتناول فيما يلي هذا الموضوع :

(أ) العقوبة التأديبية التبعية :

في ظل القانون لحالي فقد نص البند ٣ من المادة ٩٢ من اللائحة

التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الحالي علي أنه : " لا يجوز النظر في ترقية الموظف إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جزاءً أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه " .

(ب) الأثر في حالة توقيع جزاء خفض إلى وظيفة أدنى :

في قانون العاملين السابق رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ، كان يتم التطبيق عملاً عند توقيع جزاء خفض إلى وظيفة أدنى ، بأن يشغل العامل الوظيفة الأدنى من تلك التي كان يشغلها عند إحالته إلى المحاكمة، مع استحقاقه العلاوات الدورية المستقبلية المقررة للوظيفة الأدنى - بمراعاة شروط استحقاقها ، وتحدد أقدميته في الوظيفة الأدنى بمراعاة أقدميته السابقة فيها ، بالإضافة إلى المدة التي قضاها في الوظيفة الأعلى ، مع الاحتفاظ له بأجره الذي كان يتقاضاه عند صدور الحكم بتوقيع الجزاء ، ولا يجوز النظر في ترقيته إلا بعد مضي سنة ونصف من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء.(١)

ويلاحظ أنه إذا وقع على العامل جزاء خفض إلى وظيفة أدنى مع خفض الأجر فلا يجوز النظر في ترقيته إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء.(٢)

ولقد قرر المشرع أنه يحتفظ بالحصيلة الناتجة عن جزاءات الخصم الموقعة على العاملين في حساب خاص ، ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض

(١) م ٨٦ فقرة أولى من قانون العاملين المدنيين بالدولة .

(٢) م ٨٦ فقرة ثانية .

الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها السلطة المختصة. (١)

(ج) رد الاعتبار : يقوم نظام رد الاعتبار الوظيفي إلى العامل الذي وقع عليه الجزاء التأديبي على أساس تحقيق هذا الجزاء للغرض منه.

ففي ظل قانون الخدمة المدنية الحالي ، فقد نصت المادة ٦٧ منه علي أنه :
تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:

(١) سنة في حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.

(٢) سنتان في حالة اللوم والخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً .

(٣) ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوماً وحتى ثلاثين يوماً .

(٤) أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءي الفصل والإحالة إلى المعاش . وتحسب فترات المحو اعتباراً من تاريخ توقيع الجزاء.

ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو .

(١) م ٩٣ من القانون .

الفصل الثالث السلطة التأديبية

يحتل الاختصاص بتوقيع العقوبات التأديبية موضوعاً هاماً في دراسة التأديب ، ونظراً لتعدد المسؤولية التأديبية المتعلقة بالعاملين سواء كانوا تابعين للقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦م، أم تابعين للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ؛ فإن المشرع قد حدد السلطة المختصة بالتأديب ، سواء لأول مرة ، أم للتعقيب علي القرار التأديبي الصادر من هذه السلطة المختصة .

وبعد صدور القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، وهو قانون العمل الموحد ، فإن البحث يدور حول خروج العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام من اختصاص السلطة التأديبية للعاملين بهذه الجهات والتي سبق وقررها قانونيهما (٤٨ لسنة ١٩٧٨ و ٢٠٣ لسنة ١٩٩١) .

كذلك تنثور مسائل متفرقة تتعلق بالتفويض في توقيع الجزاء التأديبي ، وحدوده ، والمدى الذي تملكه السلطة التأديبية في التعقيب علي القرار التأديبي الصادر من السلطة التي وقعت الجزاء .

ومن ثم نقسم هذا الفصل للمباحث التالية :

المبحث الأول - الاختصاص التأديبي .

المبحث الثاني - التفويض في الاختصاص التأديبي .

المبحث الثالث - أثر الارتباط بين المجال التأديبي وغيره في تحديد الاختصاص

المبحث الرابع - الاختصاص المكاني للمحاكم التأديبية .

المبحث الأول الاختصاص التأديبي

يتحدد الاختصاص التأديبي بالنسبة للعاملين الخاضعين للكادرات الخاصة وفقاً لما نصت عليه قوانينهم كما هو الحال بالنسبة لرجال القضاء والشرطة والقوات المسلحة والجامعات ، حيث تتولي مجالس التأديب المشكلة طبقاً لها في توقيع العقوبات التأديبية المقررة علي هؤلاء بيد أن مجلس الدولة ينعقد اختصاصه بالنسبة لهؤلاء في التعقيب علي الطعون في القرارات الصادرة من مجالس التأديب هذه وفقاً

لما نص عليه البند التاسع من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة التي جعلت الاختصاص لمجلس الدولة في نظر الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .

*** الاختصاص التأديبي للعاملين المدنيين بالدولة في ظل القانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ م : يكون الاختصاص التصرف في التحقيق وفقا لهذا القانون علي النحو الآتي :**

١- للرؤساء المباشرين الذين تحددهم السلطة المختصة كل في حدود اختصاصه ، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر ، بما لا يجاوز عشرين يوماً في السنة ولا يزيد علي ثلاثة أيام في المرة الواحدة .

٢- لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل في حدود اختصاصه ، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر ، بما لا يجاوز أربعين يوماً في السنة ولا يزيد علي خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة .

٣- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (١) إلي (٥) من الفقرة لأولي من المادة (٦١) من هذا القانون والبندين (١، ٢) من الفقرة الثانية من ذات المادة .

٤- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون .

وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقاً لأحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة (م ٦٢ من القانون) .

• سلطة الوقف عن العمل وأحكامه في القانون الحالي:

١. لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية بحسب الأحوال ، أن يوقف الموظف عن عمله احتياطياً ، إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر ، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب علي وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف " (م ٦٣ من القانون) .

٢. يجب عرض الأمر فوراً علي المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف المتبقي من أجره ، فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كامل أجره حتى تقرر المحكمة ما يتبع في شأنه .
٣. علي المحكمة التأديبية أن تصدر خلال عشرين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها، فإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملاً ، فإذا برئ الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره ، وإذا جوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما تبع في شأن الأجر الموقوف صرفه ، فإذا جوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه في هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر (المادة ٦٣ من القانون) .

المبحث الثاني

التفويض في الاختصاص التأديبي

من شروط القرار الإداري أن يصدر من سلطة مختصة ، بيد أن النظام القانوني يسمح بالتفويض الإداري والذي بمقتضاه تعهد سلطة إلي سلطة أخرى في ممارسة جزء من اختصاصات الأولى في حدوده القانونية ، لكن البحث يدق في حالة التفويض في الاختصاص التأديبي ، نظراً لارتباطه بتوقيع جزاءات علي الموظف العام ، فهل تنطبق القواعد العامة في التفويض علي هذا الاختصاص أيضاً ؟

استقر مجلس الدولة في فتاويه وأحكامه علي جواز التفويض في الاختصاص التأديبي ، وقيدت ذلك بعدة شروط هي :

أولاً : إن التفويض ينبغي أن يصدر من السلطة التأديبية المختصة ، إذ الأصل أن يباشر صاحب الاختصاص بنفسه السلطات المخولة له قانوناً ، ما لم ير لاعتبارات معينة أن يفوض غيره في مباشرتها.

ثانياً : إن التفويض باعتباره استثناء من الأصل العام ، يجب أن يكون صريحاً وواضحاً ولا يجوز افتراضه ضمناً .

ثالثاً : إن أحكام التفويض بالاختصاصات ذات طابع استثنائي، وبالتالي تخضع لقاعدة التفسير الضيق ، فإذا أعطى القانون لسلطة تأديبية معينة الحق في التفويض

في الاختصاصات، فإنه ينبغي أن تقتصر هذه السلطات عليه دون غيره من مستويات السلطة الأخرى ، فهذه السلطات لا يجوز لها استعمال سلطة التفويض في الاختصاصات بدون نص صريح (١) .

خامساً : يشترط ألا يكون الاختصاص من طبيعته يتعارض مع التفويض ، ومن ثم فلا يجوز التفويض في اختصاصات المجالس واللجان إلي المسئول الفردي ، وذلك أن المشرع حين جعل الاختصاص للجنة الجماعية، قد راعى توفير الضمانات التأديبية للموظف المحال علي التأديب ، ومن ثم فلا يجوز للمسئول المفوض إليه فردياً أن يقوم بهذا الاختصاص .

سادساً : ألا يتعارض التفويض مع قصد المشرع من تحديد الاختصاصات وتوزيعها علي نحو معين ، وذلك من غير تفرقة في هذا الشأن بين القرار التأديبي وغيره من القرارات الأخرى.

وما عدا ذلك يخضع التفويض في مجال التأديب للقواعد العامة (٢) التي تقضي بأن الأصل يظل مسئولاً عن العمل محل التفويض مع المفوض إليه ، باعتبار أن التفويض لا يعني تنازل المفوض عن اختصاصه كلياً .

واستناداً إلي هذا ، فإنه في حالة تفويض الاختصاص، يستطيع الرئيس الإداري المفوض أن يستعمل سلطته القانونية في إلغاء أو سحب العمل محل التفويض أو إلغاء التفويض في حد ذاته .

بيد أنه إذا كان المفوض من نفس درجة المفوض إليه ، فإنه لا يتمكن من ذلك قانوناً ، بل عليه أن يتبع الطرق القانونية للطعن علي هذا العمل إن كان له في ذلك وجهاً .

ويجب علي المفوض احترام القرار الصادر بالتفويض ، بحيث لا يجوز له التدخل فيه إلا إذا كان رئيساً للمفوض ، كما يجب عليه الالتزام بالعمل الصادر بناءً علي التفويض طالما كان سليماً وصحيحاً ، ويظل المفوض إليه مسئولاً مع المفوض

(١) انظر حكم المحكمة الإدارية العليا واردة في المجموعة ، سابق ، تحت رقم ١٧٨-٢٣ (١٩٧٩/١٢/٨)
١٦٩٤ - ١٦٩٦ .

(٢) راجع مؤلفنا في القانون الإداري ، ط ٢٠٠٤ ، ص ٤٤ .

عن العمل محل هذا التفويض ، بحيث لا يجوز للمفوض أن يعفي نفسه من المسؤولية استناداً إلى هذا التفويض .

جزاء مخالفة اللائحة للقانون في تحديد السلطة التأديبية :

عند خروج اللائحة علي النظام السابق ، فإن القرار التأديبي الصادر استناداً لها ينحدر إلى حد الانعدام ، نظراً لعيب عدم الاختصاص الجسيم ، وفي ذلك قضي بأنه : " ومن حيث أنه لما كان من المقرر أن اللوائح التنفيذية التي تصدر بناءً علي قانون لا يجوز لها أن تخالف القواعد الواردة بالقانون التي صدرت اللائحة بناءً عليه ، وأنه إذا اختص القانون سلطة معينة بتوقيع جزاء محدد ، فإنه لا يجوز لللائحة الصادر بناءً علي القانون أن تخالف قواعد الاختصاص الواردة بالقانون (١)

التنظيم الخاص بالاختصاص التأديبي بتشريع عادي :

تعتبر الأحكام السابقة الخاصة بعدم جواز خروج لوائح الجهات الخاصة علي المبادئ العامة - أمراً فرضته طبيعة السلطة التأديبية ، ويظل الأمر فيما عداه خاضعاً للأحكام العامة .

ولكن الأمر علي عكس ذلك فيما يتعلق بما إذا كان الاختصاص التأديبي الخاص بهذه الجهات منصوص عليه بقانون وليس بلائحة ، فهنا فإن كلا النصين من ذات الدرجة ، وبالتالي فيسري النص الخاص ولا ينطبق النص العام إلا في حالة وجود نص في القانون الخاص ، وتطبيقاً لهذا قضي بأن : " ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص أن القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاءً من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام ، ومن ثم لا يجوز كقاعدة عامة إهدار نصوص القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ ، باعتباره قانوناً خاصاً والرجوع إلي أحكام القانون العام في كل ما فات القانون الخاص من قواعد أو أغلفه من أحكام لما في ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص .

(١) يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا - دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم ١٣٦٨ ، ١٤٣٠ لسنة ٤٣ق. ع ، جلسة ٢٠٠١/١/١٨ .

والقول بغير ذلك مؤداه أن يجمع من تطبق عليهم قوانين خاصة من العاملين بين ما تتضمنه هذه القوانين من أحكام راعي فيها المشرع نوعية مؤهلهم وتخصصاتهم وطبيعة المهام المسندة إليهم وبين أحكام القوانين العامة التي تطبق علي سائر العاملين المدنيين بالدولة ، ومن ثم يتعين القول بعدم سريان أحكام القوانين العامة فيما تنص عليه أو تنظمه القوانين الخاصة من أحكام تتكامل فيما بينها علي وجه مغاير لما تنظمه القوانين العامة من قواعد " (١) .

المبحث الثالث

أثر الارتباط بين المجال التأديبي وغيره في تحديد الاختصاص

ينعقد الاختصاص بجبر الضرر الناشئ عن الخطأ الصادر من الموظف والذي يتحملة شخصياً إلي المحاكم الأخرى في مجلس الدولة غير المحاكم التأديبية ، وذلك لاختلاف نظام التأديب عن فكرة جبر الضرر الناشئ عن المسؤولية التقصيرية ، والذي يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية تبعاً للدرجة التي يشغلها الموظف محل المساءلة .

بيد أن الموظف قد يرتكب مخالفة تأديبية تلزمه جهة الإدارة بما تحملته مترتباً علي هذه المخالفة ، ومن ثم فإن البحث يدور حول اختصاص المحاكم التأديبية بقرار التحميل هذا ، ومدى الارتباط بين الجزاء التأديبي وقرار التحميل هذا ، في الواقع إنه باستعراض أحكام المحكمة الإدارية العليا نجد أن لها اتجاهان في هذا الصدد وهما :

الاتجاه الأول - حيث تذهب في بعض أحكامها إلي أن المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم تدخل في اختصاص محكمة القضاء لإداري أو المحاكم الإدارية تبعاً للمستوى الوظيفي للمدعي ، وتختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوي التأديبية وطلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ، ومن ثم فإن قوام الدعوى التأديبية هو النظر في مؤاخذة العامل

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٢٥٠٠ س ٣٦ ق . عليا صادر في ١٧/١/١٩٩٨ ، المصدر: عن د / محمود أبو العنين ، الموسوعة الجامعة لأحكام المحكمة الإدارية العليا ، دار الفكر الجامعي ، ط ٢٠٠٣ ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ١٢١ .

تأديبياً عن الذنب الإداري الذي نسب إليه ، والذي يتمثل في إخلاله بواجبات وظيفته وخروجه علي مقتضياتها ، وبالتالي فإذا كان الفعل المكون للذنب الإداري يمكن أن يشكل ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية إلا أن ذلك لا يؤدي إلي القول بأن إلزام العامل جبر الضرر مرتبط بالدعوى التأديبية أو متفرع منها ، وذلك لاستقلال فكرة جبر الضرر الناشئ عن المسؤولية التقصيرية عن نظام التأديب ، من حيث القواعد القانونية التي تحكمه والغرض الذي يسعى إلي تحقيقه ، ومن ثم فإن اختصاص المحاكم التأديبية بنظر طلب إلغاء القرار النهائي للسلطة التأديبية ليس من شأنه أن يمتد هذا الاختصاص ليشمل ما عدا ذلك من موضوعات تختص بها محاكم أخرى (١) ، ومن ثم فإن الحكم في هذه الحالة سوف يكون بعد اختصاص المحكمة التأديبية بنظر طلب إلغاء القرار الصادر بالتحميل .

الاستثناء من القاعدة السابقة : يرد علي القاعدة السابقة استثناء يتمثل في اختصاص المحكمة التأديبية بنظر قرار التحميل ، في حالة ما إذا كان النزاع قد طرح أمامها مرتبطاً بصفة تبعية بمناسبة مباشرتها لاختصاصها المخول لها في القانون ، ومن ثم فإذا تضمنت صحيفة الدعوى طلب إلغاء قرار تأديبي معين وطلب فيها أيضاً إلغاء قرار التحميل الصادر بناءً علي قرار التأديب ، فإن المحكمة هنا تقضي باختصاصها بنظر الموضوع (٢) .

الاتجاه الثاني : ذهبت أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة إلي عكس اتجاهها السابق ، واستقر قضاؤها علي أن قرار التحميل ليس من الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً ، لكنه يرتبط ارتباطاً فرع بالأصل لقيامه علي أساس المخالفة التأديبية المنسوبة إلي العامل ، وهو ذات الأساس الذي يقوم عليه الجزاء عن هذه المخالفة فيما لو قدرت الجهة الإدارية أعمال سلطتها التأديبية قبل العامل عن المخالفة ، ومن ثم تختص المحكمة التأديبية بالفصل في مدى إلزام العامل بما تحملته جهة الإدارة من مبالغ بسبب هذه المخالفة ، يستوي في ذلك أن يكون طلب العامل قد قدم إلي المحكمة التأديبية مقترناً بطلب إلغاء الجزاء التأديبي أ ، و قدم إليها علي استقلال ، وبغض

(١) انظر المجموعة س ٣٢ق. عليا ، سابق ، القاعدة ٩٦ ، ص ٦٣٣ .

(٢) المجموعة ، السابق ، ج ٢ ، سابق ، ذات القاعدة ، ص ٦٣٣ .

النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد انتهى إلي توقيع جزاء تأديبي أو لم ينته إلي ذلك ، وذلك لئن انعقاد الولاية للمحكمة التأديبية في هذه الحالة أساسه أن قرار التحميل في هذه الحالة يعد بمثابة جزاء تأديبي غير مباشر ، طالما أنه يستند إلي المخالفة المنسوبة إلي العامل ، وليس إلي قاعدة من القواعد المحددة لمستحقات الوظيفة العامة^(١) .

رأينا في الموضوع :

ونحن نؤيد هذا الاتجاه الأخير للمحكمة ، لأن استبعاد قرار التحميل من اختصاصها من شأنه أن يجعل مسائل تأديبية من اختصاص محاكم أخرى غير المحاكم التأديبية ، وإن لم تكن جزاءات صريحة فعلاً ، ولكنها مرتبطة بالجزاء التأديبي ارتباط الفرع بالأصل ، وهو الأمر الذي يتعارض مع قواعد الاختصاص .

مدى اختصاص المحاكم التأديبية بالجزاء التأديبي المقنع :

لقد نص المشرع علي الجزاءات التأديبية التي توقع علي العاملين المدنيين بالدولة ، وكذا العاملين بالقطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، ومن ثم فإن المحاكم التأديبية وفي حدود اختصاصها المحدد قانوناً بالنسبة لكل طائفة من هؤلاء العاملين - تنظر الجزاءات التأديبية التي وقعتا الجهات التأديبية والمنصوص عليها صراحة في القانون .

بيد إن جهة الإدارة قد تلجأ إلي إصدار بعض القرارات الإدارية في شئون الموظفين بحكم مسئوليتها عن قيامها بنشاطها ، ولكن هذه القرارات قد تحوي في طياتها معني الجزاء التأديبي ، كما لو لجأت الإدارة لنقل موظف نقلاً مكانياً أو انتدبته إلي جهة أخرى ، وكان في الواقع وملابسات الحال يخفي جزاء تأديبياً مقنعاً ، ومن هنا فإن البحث يدور حول اختصاص المحاكم التأديبية بهذا النوع^(٢) .

لقد انتبعت دائرة توحيد المبادئ في مجلس الدولة إلي أن مجلس الدولة في مجال اختصاصه التأديبي يقتصر علي الجزاءات الصريحة الواردة في نصوص القانون ،

(١) انظر حكم المحكمة الإدارية العليا في ١٩٩٢/٣/١٧ في الطعن رقم ١٩٨٣ س ٣٥ ق . عليا ، مجموعة المبادئ ج، ٢ ، سابق ، س ٣٧ ، ص ١٠٧٣ - ١٠٨٠ .

(٢) مجموعة المبادئ ، سابق ، ٣٢ ، ج ٢ ، القاعدة ٢٥ ، ص ١٧٧ .

دون أن يمتد اختصاص المحاكم التأديبية إلى جزاءات أخرى بحجة تغييبها عقوبات تأديبية مقنعة مثل قرار النقل أو النذب^(١).

وإذا كان هذا الاتجاه من دائرة توحيد المبادئ قد ثار بمناسبة قرارات النقل أو النذب ، فإن مجلس الدولة قد مده إلى قرارات أخرى مثل الطعن علي قرار لفت النظر ، حيث قرر أنه لا يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية ، وذلك لأنه ليس من بين الجزاءات التأديبية الواردة صراحة في القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بنظام العاملين المدنيين بالدولة ، ومن ثم فإن الطعن علي هذا القرار يخرج أيضاً من اختصاص المحاكم الإدارية أيضاً المحدد علي سبيل الحصر في المادة ١٤ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، وبناءً عليه تختص محاكم القضاء الإداري بالطعن في قرار لفت النظر ، من حيث اعتبارها المحكمة ذات الولاية العامة في سائر المنازعات الإدارية^(٢) .

وإن كان الجزاء التأديبي المقنع قد تتنازعه المحاكم الإدارية أو محاكم القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية ، فإن الأمر لا تثور مشكلته عندما يصل الأمر إلى المحكمة الإدارية العليا ؛ فهي تبحث في هذه الحالة هذا الجزاء وتفرض عليه رقابتها ، فهي قد استقرت علي أن نقل المدعي دون إفصاح عن الوظيفة المنقول إليها أو تحري مدي احتياجات العمل أ ، و التناسب في الدرجة بين الوظيفة المنقول إليها والوظيفة المنقول منها ، لا يدع مجالاً للشك في أن مصدر القرار ما قصد به إلا توقيع جزاء علي المدعي^(٣) .

وبناءً علي هذا فقد استقر أن النقل من الأمور التي تترخص فيها جهة الإدارة ، مادام لا يترتب عليه تقويت فرصة للعامل في الترقية بالأقدمية ، أو كان يتضمن نقل

(١) حكم دائرة توحيد المبادئ صادر عن المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٢٠١ ، س ٢٨ ق . صادر

في ١٩٨٥/١٢/١٥ ، (مجموعة المبادئ، سابق، س ٣٢ ، ج ٢ ، فهرس هجائي (أ)) .

(٢) مجموعة المبادئ س ٣٢ ، ج ٢ ، سابق ، قاعدة رقم ٤٤ ب ، ص ٢٨١ .

(٣) مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خمسة عشر عاماً (١٩٦٥ - ١٩٨٠) ، سابق ، ص

١٧٠٢ ، المبدأ تحت رقم ١٩-٨٨٤ (١٩٧٨/٣/١٨) ٩٥/٢٣ .

إلى وظيفة من درجة أقل من تلك التي كان يشغلها أو كان مشوباً بإساءة استعمال السلطة أو متضمناً جزاءاً تأديبياً مقنعاً^(١).

المبحث الرابع

الاختصاص المكاني للمحاكم التأديبية

نظم المشرع الاختصاص المكاني للمحاكم التأديبية ، وذلك حتى ييسر علي المتقاضين مشقة الانتقال إلى مقر هذه المحاكم .

وتتوزع هذه المحاكم علي مستوى الجمهورية علي النحو التالي، وذلك لغير مستوى الإدارة العليا^(٢) :

أولاً : المحاكم التأديبية بالقاهرة : وهي المحكمة التأديبية للرئاسة ، المحكمة التأديبية للصناعة ، المحكمة التأديبية للتعليم والبحث العلمي، المحكمة التأديبية للزراعة ، المحكمة التأديبية للصحة ، المحكمة التأديبية للنقل والمواصلات .

ثانياً : المحكمة التأديبية بالإسكندرية : ويشمل اختصاصها العاملين بوزارة النقل البحري والمصالح العامة بمدينة الإسكندرية ومحافظة البحيرة ومطروح والجهات التابعة لها.

ثالثاً : المحكمة التأديبية بطنطا : ويشمل اختصاصها محافظات الغربية وكفر الشيخ والقليوبية والمنوفية .

رابعاً : المحكمة التأديبية بالمنصورة : ويشمل اختصاصها محافظات الدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية .

خامساً : المحكمة التأديبية بأسسيوط : ويشمل اختصاصها محافظات أسسيوط وسوهاج والمنيا وقنا والوادي الجديد وأسوان

سادساً : المحكمة التأديبية ببورسعيد : ويشمل اختصاصها محافظات بورسعيد ودمياط والسويس وسيناء الشمالية وسينا الجنوبية.

(١) انظر حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٢٢٢٧ ، س ٣٣ ، عليا ، صادر في ١٩٩٢/٥/٩ ، مجموعة المبادئ ، سابق ، س ٣٧ ، العدد الثاني ، ص ١٣٦٦ ، ١٣٦٧ .

(٢) هذه المحاكم بمحاكمة العاملين بفروع الوزارات بالمحافظات ووحدات الحكم المحلي بها .

سابعاً : المحكمة التأديبية بقنا : ويشمل اختصاصها محافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر .

والعاملون من ذوي مستوى الإدارة العليا فإن هناك محكمة تأديبية عليا مقرها مدينة القاهرة ، وتعقد جلساتها بالإسكندرية مرة كل شهر ، وتختص بنظر المنازعات التأديبية المتعلقة بهم .

ونحن نناشد السلطة المختصة، أن تتدخل بزيادة عدد مقيار المحاكم التأديبية بحيث تكون هناك محكمة لكل محافظة ، وذلك نظراً لما يعانيه المتقاضون من العنت والمشقة في منازعاتهم التأديبية ، وما يترتب ذلك من زيادة في النفقات وطول في الإجراءات ، يتنافي مع التزام الدولة بتقريب جهات القضاء من المتقاضين ، وتمكين كل متقاض من اللجوء إلي قاضيه الطبيعي كأحد المبادئ الدستورية المستقرة. وقد تحقق فعلاً إنشاء بعض المحاكم وكذلك بعض الدوائر في بعض المحافظات وهو ما يدعم ما نادينا به.

الفصل الرابع مرحلتى التحقيق والمحاكمة في المخالفات التأديبية

لما كان الجزاء التأديبي ينال من العامل سواء أديباً أم مادياً أم هما معاً ، فإنه من الواجب أن يحاط توقيع مثل هذا الجزاء بالضمانات التي تكفل التحقق من أنه قد تغيا الوجه السليم ، ثم يعقب ذلك الحكم في الدعوى التأديبية ، ونبناول ذلك من خلال المباحث التالية :

المبحث الأول مفهوم التحقيق والاختصاص به

مفهوم التحقيق الإداري وأهميته:

التحقيق في المخالفات التأديبية المالية والإدارية يعني عملية التثبت من مشروعية الجزاء التأديبي وملائمته ، ومن ثم فيواجه العامل بالاتهامات الموجهة إليه ، حتى يكون علي بيئة منها فيعد دفاعه علي أساسها . وتعود أهمية التحقيق في المخالفات التأديبية إلي ضمان حق الدفاع للعامل وهو حق دستوري أصيل ، وذلك حتى يطمئن الموظف علي مصيره ، ومن ثم يتصرف في عمله بنفس هادئة ، ولا يكون الأمر سيفاً سليطاً بيد السلطة التأديبية في توقيع الجزاءات التأديبية ، دون ضمان مفردات حق الدفاع في تحقيق نزيه يجري مع المحال علي المساءلة التأديبية يتم فيه التثبيت من المخالفة ، في ضوء ما يبديه الموظف من دفاعه عن نفسه (١) .

ومن ثم فلا يجوز لجهة الإدارة أن تتخذ من سلطتها في التأديب طريقاً تتكل به عن توفير ضمانة التحقيق لعاملها ، وتوقع عليهم جزاءات تأديبية دون تحقيق ، أو مع وجود تحقيق لا تتوافر فيه الضمانات الشكلية والموضوعية التي نص عليها القانون ، واستقر عليها قضاء مجلس الدولة ، وذلك تحقيقاً لمصلحة الموظف في الدفاع عن نفسه والمصلحة العامة في ذات الوقت .

(١) انظر مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الإداري ، المكتب الفني ، مطبعة النصر ، س ٦ ، المجلد الثاني ، القضية رقم ١٧٦ س ٤٤ ، جلسة ١٩٥٢/٣/١٩ ، ص ٦٩٩ ، ٧١١ ، ٧١٢ ، ٧١٣ .

***التنظيم القانوني لضمانة التحقيق الإداري في قانون الخدمة المدنية**

رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦م ولائحته التنفيذية رقم ٢١٦ لسنة ٢٠١٧م :

نظم المشرع في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أحكام التحقيق الإداري

علي الوجه التالي :

١. لا يجوز توقيع أي جزاء علي الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة ، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً .
٢. مع ذلك ، يجوز بالنسبة لجزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهة ، علي أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء . (م ٥٩ من القانون) .

***التنظيم القانوني للإحالة إلي التحقيق الإداري وإجراءاته في القانون الحالي**

ولائحته التنفيذية :

١. يحال الموظف إلي التحقيق فيما نسب إليه من مخالفات ، وذلك بموافقة أحد رؤسائه الإداريين ممن لا يقل مستواه الوظيفي عن مدير عام . (مادة ١٥١ من القانون) .
٢. يتعين قبل البدء في التحقيق مع الموظف إعلانه كتابة علي نحو يتحقق به علمه بقرار الإحالة للتحقيق من خلال أمر استدعاء يشتمل علي البيانات الآتية :
 - اسمه رباعياً .
 - الرقم القومي .
 - اسم الوظيفة التي يشغلها .
 - موضوع المخالفة المنسوبة إليه .
 - السلطة التي قررت إحالتها إلي التحقيق وتاريخ القرار .
 - موعد بدء التحقيق ومكانه ، علي ألا تتجاوز الفترة الزمنية لبدء التحقيق عشرة أيام من تاريخ تسلم قرار الإحالة إلي التحقيق . (مادة ١٥٢ من القانون) .
٣. إذا امتنع الموظف المحال إلي التحقيق عن الحضور رغم إعلانه كتابة يتم إعادة إعلانه خلال ثلاثة أيام عمل بالموعد الجديد ، فإذا تخلف عن الحضور تسير جهة التحقيق في استكمال التحقيق ، وينطبق ذات الحكم في حالة رفض الموظف

تسلم أمر الاستدعاء وينتشر علي أمر الاستدعاء بذلك ويودع ضمن أوراق التحقيق.
(مادة ١٥٣ من القانون).

٤. للمحقق في سبيل أداء مهمته اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة التحقيق وله علي الأخص ما يأتي :

(أ) الإطلاع علي السجلات والأوراق وإثبات ذلك في المحضر والتأشير علي كل ورقة يطلع عليها ، وإثبات تاريخ الإطلاع ، وللمحقق ختم الأوراق والسجلات وأية وثائق أخرى يستلزم التحقيق التحفظ عليها .

(ب) طلب صور أية أوراق لا يستلزم التحقيق التحفظ علي أصولها أو تدعو المصلحة العامة عدم إرفاقها .

(ج) طلب رأي أو شهادة أحد شاغلي الوظائف القيادية ، علي أن يكون طلب الرأي أو الشهادة والرد عليهما كتابياً . (المادة ١٥٤ من القانون) .

٥. مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (٥٩) من القانون ، يكون التحقيق مع الموظف المحال إلي التحقيق كتابة ، ويثبت في محضر مرقم بأرقام مسلسل ، يذكر به تاريخ وساعة ومقر فتح المحضر ، واسم المحقق ، وقرار الإحالة ، والسلطة التي أصدرته ، واسم الموظف المحال إلي التحقيق وسنه ومحل إقامته والإدارة التابع لها ، ووظيفته ومستواها الوظيفي ، وملخص الواقعة محل التحقيق ، وأقوال شهود الإثبات والنفي ، وما تم الإطلاع عليه من مستندات ، وإثبات ساعة وتاريخ غلق المحضر ، وتذيل كل صفحة من صفحات المحضر بتوقيع المحقق ومن أدلى بأقواله بهذه الصفحة . (المادة ١٥٥ من القانون) .

وللموظف المحال إلي التحقيق الإطلاع علي كافة أوراق التحقيق وتقديم ما يشاء من مستندات تؤيد دفاعه . (المادة ١٥٦ من القانون) .

وكل موظف يستدعي لسماع شهادته في التحقيق ويمتنع عن الحضور أو الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول يساءل تأديبياً . (المادة ١٥٧ من القانون) .

وإذا تبين من خلال التحقيق وجود شبهة ارتكاب جريمة جنائية ، تعين عرض الأمر علي السلطة المختصة لإبلاغ النيابة العامة ، ولا يترتب علي إبلاغ النيابة العامة الإخلال بحث الوحدة في توقيع الجزاء التأديبي عما ثبت في حق المخالف ما

لم يكن إثبات المسؤولية التأديبية يتوقف علي الفصل في الدعوى الجنائية . (المادة ١٥٨ من القانون) .

وإذا تعدد الموظفون المحالون إلي التحقيق ، وكان التحقيق مع أحدهم ينعقد الاختصاص به للنيابة الإدارية ، يجب عرض الموضوع علي السلطة المختصة لإحالة إلي النيابة الإدارية . (المادة ١٥٩ من القانون) .

انتهاء التحقيق والتصرف فيه :

تبدأ فترة التحقيق من تاريخ إحالة الموظف إلي التحقيق وتنتهي بإعداد التقرير النهائي عن نتائج التحقيق .

ولا يجوز أن تتجاوز فترة التحقيق ثلاثة أشهر ، ويجوز مدها لفترة أخرى بموافقة السلطة المختصة . (المادة ١٦٠ من القانون)

وتعد جهة التحقيق بعد انتهائه مذكرة بنتيجة التحقيق فيما هو منسوب إلي الموظف وتعرض علي السلطة المختصة بالتصرف لحفظه أو توقيع الجزاء المناسب . (مادة ١٦١ من القانون) .

ولا يجوز معاقبة الموظف تأديبياً عن ذات الفعل أكثر من مرة . (المادة ١٦٢ من القانون) .

ويعلن الموظف كتابة بقرار الجزاء الموقع عليه وأسبابه ، وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدوره .

فإذا امتنع الموظف عن تسلم الإعلان والتوقيع علي صورته ، يتأثر عليه بذلك ، وفي هذه الحالة يكتفي بنشر قرار الجزاء في لوحة الإعلانات .

وينفذ جزاء الخصم من الأجر الوظيفي المستحق للموظف اعتباراً من أجزر الشهر التالي لإعلانه بقرار الجزاء الموقع عليه أو نشره ، وذلك في الحدود الجائزة قانوناً . (المادة ١٦٢ من القانون) .

وتودع أوراق التحقيق والجزاء بملف فرعي يلحق بملف خدمة الموظف ، وتعد صحيفة خاصة بالجزاءات التأديبية تودع بالملف الفرعي المشار إليه تسجل بها المخالفات والجزاءات التي وقعت عليه وتواريخ وأرقام القرارات الصادرة بتوقيعها .

وإذا كان التحقيق قد أسفر عن أكثر من مخالف فيكتفي بحفظ أوراق التحقيق بمكلف المخالف الأول وتحفظ صورة طبق الأصل منها بملف الباقيين . (المادة ١٦٤ من القانون) .

الوقف الاحتياطي عن العمل:

إذا اقتضت مصلحة التحقيق وقف الموظف احتياطياً عن العمل ، يعرض الأمر علي السلطة المختصة بمذكرة تتضمن موضوع التحقيق ومبررات الوقف ومدته بما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، فإذا قررت وقفه عن العمل يتعين إعلانه بقرار الوقف وإرسال صورة منه إلي كل من رئيسه المباشر وإدارة الموارد البشرية . (المادة ١٦٥ من القانون) .

الإحالة إلي المحاكمة التأديبية والجنائية :

يعتبر الموظف محالاً للمحاكمة التأديبية من تاريخ إيداع قرار الإحالة قلم كتاب المحكمة التأديبية .

ويعتبر محالاً للمحاكمة الجنائية من تاريخ صدور أمر الإحالة من قاضي التحقيق أ تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحق المدني . (مادة ١٦٦ من القانون) .

وتمحى الجزاءات التأديبية التي توقع علي الموظف بانقضاء الفترات المنصوص عليها في المادة (٦٧) من القانون ، وذلك بقرار من السلطة المختصة بناءً علي عرض إدارة الموارد البشرية دون الحاجة إلي تقديم طلب من الموظف . (المادة ١٦٧ من القانون) .

الاختصاص بالتحقيق :

تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإدارية مع شاغلي الوظائف العليا من درجة مدير عام ووكيل وزارة ووكيل وزارة أول .

كما تختص بهذا التحقيق دون غيرها في المخالفات الناشئة عن ارتكاب الأفعال

المحظورة الواردة في الحالتين الآتيتين :

أولاً : مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة علي تنفيذ الموازنة العامة .

ثانياً : الإهمال والتقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة.

وعلى الجهة الإدارية بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجرّيه من تحقيق في واقعة أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ، وعلى تلك الجهة فوراً إخطارها بذلك إحالة أوراق التحقيق بحالته إلى النيابة الإدارية . ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف الأحكام السابقة .

وعلى النيابة الإدارية أن تنتهي من التحقيق خلال ستة أشهر مع شاغلي الوظائف العليا من تاريخ إحالة المخالفة إليها أو اتصال علمها بها (١) :

تكوين النيابة الإدارية واختصاصها :

تتكون النيابة الإدارية من قسمين هما : (أ) الرقابة . (ب) التحقيق . ويتكون كل قسم من إدارات لكل منها رئيس ويلحق بها عدد كاف من الأعضاء ويعين عدد الإدارات ودوائر اختصاصها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح المدير .

ويجوز أن يلحق بقسم الرقابة أعضاء من قسم التحقيق أو يندب للعمل به موظفون من رجال الضباط أو من موظفي الوزارات والهيئات العامة ، ويكون الندب بناءً على طلب المدير العام (م ٢ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨) .

والنيابة الإدارية هيئة مستقلة تلحق برياسة الجمهورية، وتشكل الهيئة من مدير يكون رئيساً لها ومن عدد مناسب من نواب المدير والوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين ورؤساء النيابة من الفتتين (أ) و (ب) وكلاء النيابة من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة ومساعدتها ، ويسري في شأن نواب المدير والوكلاء العامين الأول سائر الأحكام الواردة في هذا القانون في شأن الوكلاء العامين (م ١ من القانون ١١٧ لسنة ١٩٥٨) .

(١) المادة ٧٩ مكرراً (أ) مضافة بالمادة الثانية بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٨٣ م .

ويكون تعيين مدير النيابة بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون تعيين الوكلاء العامين من رئيس الجمهورية بناءً علي ترشيح المدير ،
ويكون تعيين سائر أعضاء النيابة الإدارية وترقياتهم ونقلهم بقرار من رئيس
الجمهورية بناءً علي عرض مدير النيابة وبعد أخذ رأي لجنة تشكل من المدير
والوكلاء العامين بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن أربعة ، فإذا قل عن ذلك أكمل
من رؤساء النيابة حسب الأقدمية ، وذلك عند النظر في شئون أعضاء قسم التحقيق
، أما عند النظر في شئون أعضاء قسم الرقابة فتشكل اللجنة من المدير والوكيل العام
لشئون الرقابة وثلاثة من مساعديه حسب الأقدمية بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة
عن أربعة ، فإن قل عن ذلك أكمل من رؤساء الإدارات حسب الأقدمية. (م ٣٥ من
القانون ١١٧ لسنة ١٩٥٨)

اختصاص النيابة الإدارية :

كما قلنا إن النيابة الإدارية لها اختصاصان : وهما الاختصاص بالرقابة ،
والفحص والثاني الاختصاص بالتحقيق .

الرقابة والفحص :

يختص هذا القسم بالآتي :

- اتخاذ الوسائل اللازمة لتحري المخالفات المالية والإدارية والكشف عنها ، وله
في سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة والموظفين الذين يتدربون للعمل بالقسم
المذكور ، ويحرر محضر يتضمن ما تم إجراؤه والنتيجة التي أسفر عنها .
إذا أسفر الاختصاص السابق عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلي
قسم التحقيق بإذن من مدير النيابة الإدارية أو من الوكيل المختص بقسم الرقابة . (م
٥ و ٦ من القانون) .

قسم التحقيق : إذا كان للجهة الإدارية الحق في الرقابة وفحص الشكاوى
والتحقيق فإن النيابة الإدارية تختص بالنسبة للموظفين الداخلين في الهيئة والخارجين
عنها والعمال بالتالي :

(أ) إجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية .

- (ب) فحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أي جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة .
- (ج) إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي يكشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة ، وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جد فيها .
- ويجب إرسال إخطار إلي الوزير المختص الذي يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء فيه ، وذلك عدا الحالات التي يجري فيها التحقيق بناءً علي طلب الوزارة أو الهيئة التي يتبعها الموظف . (م ٣ من القانون) .
- (د) تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكمة التأديبية بالنسبة للموظفين المعيّنين علي وظائف دائمة .
- وتختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية ، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها
- كما تتولي التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ .
- وعلي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ، ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك . (م ٦٠ من القانون) .

المبحث الثاني

ضمانات التحقيق الإداري وإجراءاته

- إن التحقيق الذي تجريه النيابة الإدارية أو جهة الإدارة بمر بإجراءات معينة ، ويحاط بضمانات من شأنها أن تكفل تحقيق الضمان والاطمئنان للعامل .
- ومن ثم فيجب أن تكفل ضمانات التحقيق للموظف المحال عليه ، وبالتالي ينبغي أن يتسم بالآتي (١) :

(١) راجع حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم ١٧٦ ، س ٤٤ ، سابق .

(أ) وجوب استدعاء الموظف أو العامل موضوع المساءلة وسؤاله ومواجهته بما هو موجه إليه من أفعال .

(ب) تمكين الموظف أو العامل من الدفاع عن نفسه والاستعانة بمحام .

(ج) إتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات وسماع من يري الاستعانة بهم من شهود النفي .

(د) يجب ألا يحاط التحقيق بظروف وملابسات من شأنها أن تؤثر في نزاهة التحقيق وحيدته .

(هـ) ويجب أن يحقق دفاع المدعي عليه ، وهو الأمر الذي يتطلب أن تكون في إجراءات التحقيق كتابة ، وذلك حتى تكون هناك رقابة علي إجراءات هذا التحقيق ، وذلك فيما عدا الحالات التي أجاز فيها المشرع أن يتم فيها التحقيق شفاهة . وبالتالي فإن الضمانات السابقة تعد أمثلة لمفردات ضمانات التحقيق وكفالاته ، وتبعاً فإنه التحقيق يبطل إذا لم يمكن الاطمئنان قانوناً إلي النتيجة التي انتهى إليها ، وعلي الأخص استدعاء الموظف وسؤاله بما هو موجه إليه ، وتمكينه من الدفاع عن نفسه وإتاحة الفرصة له لتنفيذ شهادة الإثبات ، فإذا حدث ولم يعط الموظف الحق في الإطلاع علي أوراق التحقيق الإداري ، بحجة أنه مستبعد بينما يستند إليه المحقق في تحقيقه ويواجه الشهود بأقوالهم ، أو منع من الحق في الكلام حين يرغب في الطعن علي هذا التحقيق والنعي علي تصرفات السلطة الإدارية ، ويظهر ما شاب قرارها من إساءة لاستعمال سلطتها ، فإن هذا كله من شأنه أن يبطل التحقيق سواء تم إجراؤه بمعرفة الجهة الإدارية أم النيابة الإدارية (١) .

سلطة النيابة الإدارية في التحقيق :

حق الإطلاع : فلعضو النيابة الإدارية ، عند إجراء التحقيق الإطلاع علي ما يراه لازماً من الأوراق بالوزارات والمصالح ، وله أن يستدعي الشهود ويسمع

وانظر : مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خمسة عشر عاماً (١٩٦٥ ، ١٩٨٠) ، سابق ، ص ١٦٧٩ ، ١٦٨٠ المبدأ تحت رقم ٤٠٤ - ٢٣ (١٩٧٩/١٢/١) ١١/٢٥ .

(١) راجع حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم ١٧٦ ، س٤. عليا ، سابق ، مجموعة مجلس الدولة ، س ٦ ، المجلد الثاني ، سابق ، ص ٧١١ ، ٧١٢ .

أقوالهم بعد حلف اليمين ، ويسري علي هؤلاء الشهود الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة ، بما في ذلك ضبط الشاهد وإحضاره . (م ٧ من القانون ١١٧ لسنة ١٩٥٨) .

الحق في الإذن بالتفتيش : يجوز لمدير النيابة الإدارية أو من يفوض من الوكلاء العامين في حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش منازل وأشخاص الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قانونية قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء .

ويجب في جميع الأحوال أن يكون الإذن بالتفتيش كتابياً وأن يباشر التحقيق أحد الأعضاء الفنيين ، علي أنه يجوز لعضو النيابة الإدارية في جميع الأحوال أن يجري تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجري معهم التحقيق في أعمالهم .

ويجب أن يحضر محضراً بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف وغيابه عند إجرائه (م ٩) .

سلطة الوقف عن العمل : لمدير النيابة الإدارية أو أحد الوكلاء العامين أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك . ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص ، فإذا لم يوافق الرئيس المختص علي وقف الموظف وجب عليه إبلاغ مدير النيابة الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه ، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة .

ويترتب علي وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من اليوم الذي وقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلي أن تقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه . (م ١٠) .

هذا ويثار بمناسبة الحديث عن إجراءات التحقيق عدة مسائل وهي : مدة كفاية التحقيق الجنائي الذي أجرى مع الموظف أو العامل عن إجراء تحقيق إداري ، والموقف القانوني في حالة امتناع العامل عن الإدلاء بأقواله ، وحرية النيابة الإدارية

في التحقيق والاثهام تتغيا بذلك الصالح العام وتوفير الضمان للموظف أو العامل ، وهذا كله نتناوله تباعا:

أولاً : مدى كفاية التحقيق الجنائي : إذا قامت النيابة العامة بإجراء تحقيق جنائي مع العامل فيما هو منسوب إليه من ذنب واتهام يقع تحت طائلة القانون الجنائي ، وفي نفس الوقت يصلح لأن يكون محلاً للمساءلة التأديبية لانطوائه علي مخالفة تأديبية لإخلاله بكرامة الوظيفة العامة ومقتضياتها ، فإن جهة العمل تملك أن تستخلص المخالفة التأديبية وتوقع العقوبة التأديبية المناسبة لها ، دون أن تكون ملزمة بإجراء تحقيق خاص عن هذه المخالفة ، ولكن هذا يتطلب توافر شرطين هما :

الشرط الأول : أن يتناول التحقيق الجنائي الوقائع التي تشكل الذنب الإداري المنسوب إلي العامل والذي يمثل إخلالاً بكرامة الوظيفة العامة ومقتضياتها .
الشرط الثاني : أن ينطوي التحقيق الجنائي علي مقتضيات حق الدفاع الذي ينبغي توفيره للعامل من سماع أقواله وتحقيق دفاعه وسائر ما يتفرع عن هذا الحق (١) .

ثانياً : امتناع الموظف أو العامل عن الإدلاء بأقواله في التحقيق الإداري :
من حق الجهة الإدارية أن تجري التحقيق مع العامل في حدود ما هو مسموح لها به ، فإن هي فعلت ذلك وامتنع المتهم عن الإجابة عن الأسئلة أو الإدلاء بأقواله ، فإن هذا لا يبطل هذا التحقيق ، ويعد الجزاء التأديبي الموقع استناداً إليه صحيحاً ، مادام أن هذا التحقيق قد تم علي وجه قانوني واستوفى الإجراءات الشكلية والموضوعية التي يتطلبها المشرع عامة ، ومن ثم فإن الاطمئنان والكفالة والضمان قد توافرت للعامل في إبداء ما يراه من أوجه دفاع ، وتمكينه من تقديم ما لديه من أدلة أو قرائن تؤيد أقواله ، ومن ثم فإنه بامتناعه عن الإدلاء بأقواله يكون قد فوت وبمحض إرادته حقه فلا يلومن إلا نفسه (٢) .

وإذا طلب العامل إحالة التحقيق إلي النيابة الإدارية ورفض الإدلاء بأقواله في التحقيق الذي تجريه السلطة الرئاسية ، فإن هذه الأخيرة غير ملزمة بهذه الإحالة ،

(١) انظر مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خمسة عشر عاماً (١٩٦٥ ، ١٩٨٠) سابق ، ص ١٦٨٠ ، ١٦٨١ ، تحت رقم ٢٢- ٢١ (١٩٧٧/١/٢٢) ٢١/٢٢ .

(٢) راجع المصدر السابق، ص ١٦٨١ / ١٦٨٢ ، تحت رقم ٢٦٤- ١٩ (١٩٧٤/٦/٢٩) ١٩/١٥٨/٦٣ .

وتستطيع أن تسير في التحقيق وتستوفيه علي وجه الصحيح يستوي في ذلك أن يكون العامل خاضعاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة أو لقانون القطاع العام الذي يخضعهم لمجلس الدولة (١).

ثالثاً : عدم تقديم النيابة الإدارية بميعاد معين سوى بالنسبة لشاغلي

الوظائف العليا :

لم يقيد المشرع النيابة الإدارية في مباشرتها لإجراءات التحقيق بميعاد معين إلا إذا اتصل الأمر لشاغلي الوظائف العليا ، حيث يجب أن يتم هذا التحقيق خلال ستة أشهر من تاريخ إحالة المخالفة إليها أو اتصال علمها بها. ويعد مباشرة النيابة الإدارية للتحقيق الإداري مع الموظف أو العامل بمثابة إجراء قاطع لتقدم الدعوى التأديبية ، ويظل هذا الأثر قائماً حتى تتخذ قرارها في التحقيق الذي تجريه .

المبحث الثالث

التصرف في التحقيق

بعد أن ينتهي التحقيق سواء من قبل جهة الإدارة أم النيابة الإدارية فإن التصرف في التحقيق يتم علي النحو التالي :

أولاً - سلطة جهة الإدارة في التصرف في التحقيق (توقيع الجزاء - الحفظ -

الإحالة) : :

يكون الاختصاص التصرف في التحقيق وفقاً للقانون الحالي في شأن الخدمة

المدنية علي النحو الآتي :

١- للرؤساء المباشرين الذين تحددهم السلطة المختصة كل في حدود اختصاصه

، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر ، بما لا يجاوز عشرين يوماً في السنة ولا يزيد علي ثلاثة أيام في المرة الواحدة .

(١) المصدر السابق نفسه .

٢- لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل في حدود اختصاصه ، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر ، بما لا يجاوز أربعين يوماً في السنة ولا يزيد علي خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة .

٣- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (١) إلي (٥) من الفقرة لأولي من المادة (٦١) من هذا القانون والبندين (١، ٢) من الفقرة الثانية من ذات المادة .

٤- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون .

وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقاً لأحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة (م ٦٢ من القانون) .

وللرؤساء المباشرين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة كل في حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة علي ثلاثة أيام.

وللسلطة المختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله ولها أيضاً إذا ألغت الجزاء أن تحيل العامل إلي المحاكمة التأديبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار .

ثانياً : سلطة النيابة الإدارية في التصرف في التحقيق (١) :

أعطى المشرع للنيابة الإدارية وعقب انتهائها من التحقيق الآتي :

١- يعرض المحقق أوراق التحقيق عقب الانتهاء منه علي رئيس القسم بملزمة يبين فيها ما أسفر عنه التحقيق من وقائع وتكييفها ورأيه فيها (م ١١ من القانون ١١٧ لسنة ١٩٥٨) .

(١) راجع فتوى الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم ٤٤٣ بتاريخ ٢٠٠٠/٨/١٧ ، ملف رقم ٩٨١/٣/٨٦ المصدر : مجلة المحاماة - العدد الأول ٢٠٠١ ، سابق ، ص ٤٥٣ ، ٤٥٤ .

٢- وإذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها لاتخاذ ما تراه هذه الجهة الإدارية (١٢٣) .

٣- للنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية إذا رأت مبرراً لذلك .

٤- في جميع الأحوال تخطر الجهة الإدارية التي يتبعها العامل بالإحالة .

٥- علي الجهة الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها نتيجة التحقيق أن تصدر قراراً بالحفظ أو بتوقيع الجزاء فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة .

٦- يجب علي الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها في الأوراق خلال خمسة عشر يوماً علي الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية .

٧- في حالة المخالفات التي ترى النيابة الإدارية أنها تستوجب جزاءً أشد مما تملكه الجهة الإدارية ، فإنها تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل .

هذا وبعد صدور دستور ٢٠١٤ ، فقد توسع المشرع في سلطة النيابة الإدارية علي النحو الوارد في المادة ١٩٧ منه ، ووفقاً لها ، فالنيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة ، تتولي التحقيق في المخالفات المالية والإدارية وكذلك التي تحال إليها ، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية ، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة ، كما تتولي تحريك ومباشرة الدعاوي والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة ، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون .

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .

وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً .

وفي ذات الشأن قررت المادة ٦٠ من قانون الخدمة المدنية ، منح السلطة للنيابة الإدارية في توقيع الجزاءات او الحفظ .

ثالثاً: إخطار النيابة العامة: إذا أسفر التحقيق الذي تجريه النيابة الإدارية عن وجود جريمة جنائية ، فإنها تحي الأوراق إلي النيابة العامة وتتولي النيابة العامة التصرف في التحقيق واستيفاءه ، إذا تراءى لها ذلك علي أن يتم ذلك علي وجه السرعة .

رابعاً : إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات : يجب علي الجهة الإدارية أن تخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرار الصادر منها في شأن المخالفات المالية . ولرئيس الجهاز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلي المحكمة التأديبية ، وعلي النيابة الإدارية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال خمسة عشر يوماً التالية .

والمشرع قد خص المخالفات المالية بهذا الحكم نظراً لخطورتها ، وبالتالي لا ينطبق هذا علي المخالفات الإدارية ، وهو الأمر الذي جعل المشرع يلزم النيابة الإدارية بمباشرة الدعوى التأديبية بناءً علي إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات دون أن يكون لها سلطة تقديرية في هذا المجال .

المبحث الرابع

مرحلة المحاكمة التأديبية

تبدأ المحاكمة التأديبية بإقامة الدعوى التأديبية وتنتهي بصدور حكم ينهي الخصومة فيها ، سواء أكان موضوع هذه الدعوى هو خصومة تأديبية مبتدأة أم طعن علي قرار تأديبي ، رأى فيه الطاعن أن هذا القرار لم يصب وجه الحق في المسألة . ونتناول هذا الموضوع من خلال المطالب التالية :

المطلب الأول

إجراءات رفع الدعوى التأديبية

تتم إثارة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة من قبل أحد أعضاء النيابة الإدارية ، فهي التي تتولي الإدعاء أمامها .

وتقام الدعوى التأديبية وفقاً للإجراءات التأديبية :

١- يتم إيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة ، ويجب أن يتضمن هذا القرار بياناً بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق .

وتتظر الدعوى في جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة المختصة ، ويتولي رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور ، علي أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق .

ويكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

ويتم إعلان أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم - ممن تسري عليهم أحكام هذا القانون - بتسليمه إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة (م ٣٤ من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ في شأن مجلس الدولة) .

٢- ويتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعاً لدرجة الموظف وقت إقامة الدعوى وإذا تعدد الموظفون المقدمون إلي المحاكمات كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم في الدرجة هي المختصة بمحاكمتهم جميعاً (م ٢٥ من القانون ١١٧ لسنة ١٩٥٨) .

٣- تكون محاكمة الموظف أو الموظفين المتهمين بارتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم علي أساس اعتبارهم تابعين للجهة أو للوزارة التي وقعت فيها المخالفة أو المخالفات المذكورة ، ولو كانوا تابعين عند المحاكمة لوزارات أخرى .

وإذا تعذر تعيين المحكمة المختصة علي النحو السابق تكون المحاكمة أمام المحكمة المختصة بالنسبة للوزارات التي يتبعها العدد الأكبر من الموظفين ، فإذا تساوي العدد عينت المحكمة المختصة بقرار من رئيس مجلس الدولة (م ٢٤ من القانون ١١٧ لسنة ١٩٥٨) .

محاكمة العاملين الذين انتهت خدمتهم :

القاعدة أن انتهاء خدمة العامل لأي سبب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدء في التحقيق معه قبل انتهاء الخدمة .

ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمسة سنوات من تاريخ انتهائها .

ويجوز أن يوقع علي من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة ، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق .

واستثناء من أحكام التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والقوانين المعدلة له تستوفي الغرامة المشار إليها من المعاش بما لا يجاوز رבעه أو بطريق الحجز الإداري علي أمواله (م ٦٦ من قانون الخدمة المدنية)

تقديم الدعوى التأديبية :

مدة تقديم الدعوى التأديبية بالنسبة للموجود بالخدمة هي ثلاث سنوات منت تاريخ ارتكاب المخالفة .

وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو الاتهام ويسري ميعاد جديد ابتداءً من آخر إجراء ، وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يرتب انقطاعها بالنسبة للباقيين ولو لم تكن قد اتخذ ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .

وإذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تتقدم الدعوى التأديبية إلا بتقدم الدعوى الجنائية .

شمول ولاية المحاكم التأديبية : تمتد ولاية المحكمة التأديبية لتشمل كل ما

يتعلق بتأديب العاملين المدنيين بالدولة ، وكذلك الأمر بالنسبة للعاملين بالقطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، ومن ثم فهي تشمل الطعون المبتدأة، والاختصاص بالفصل في الطعن في أي جزاء تأديبي صادر من السلطات الإدارية، وكذلك طلبات التعويض المترتبة علي الجزاء وغيرها من الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي (١).

(١) المجموعة ، السابق ، ص ١٧٢٣ ، تحت رقم ٤٣٢-٢٠ (١٩٨٠/٢/٩) ٥٧/٢٥ .

عدم جواز نظر الدعوى لسابقة العقاب الإداري عن المخالفة :

إذا قامت جهة الإدارة بالتحقيق مع المتهم ومجازاته تأديبياً ، فإنه لا محل بعد ذلك لرفع الدعوى التأديبية ضده ، لأن من المبادئ العامة في المحاكمة هي عدم جواز المعاقبة علي الذنب الإداري الواحد مرتين ، وتطبيقاً لهذا قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه : " ومن حيث أنه لما كانت القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية هي قرارات إدارية تسري في شأنها القواعد المتعلقة بالتنظيم والسحب والإلغاء ، وكان من المسلم به عدم جواز سحب القرارات الإدارية الصحيحة .

ومن حيث أنه ولما كان لم يثبت أن قرار الجزاء سالف الذكر قد شابته شائبة تنال من صحته ، فما كان يجوز والحالة هذه سحبه بعد صدوره ، وبعد أن استنفدت به السلطة التأديبية الرئاسية سلطتها التقديرية في تقدير الذنب الإدارية والجزاء الملائم له .

ومن حيث أنه لما كان قد صدر - رغماً عما تقدم - قرار صاحب لقرار الجزاء المشار إليه ، فإنه علاوة علي أنه لم يثبت أن المتهم سالف الذكر قد علم بهذا القرار الساحب فإنه - حتى بفرض علمه به - ما كانت له مصلحة في الطعن عليه ، باعتبار أن الأثر المترتب علي هذا القرار ، هو مجرد سحب الجزاء الموقع عليه دون أن ينطوي علي ثمة إساءة إلي مركزه القانوني ، وأن إحالته إلي التحقيق لا تتمخض قراراً إدارياً يسوغ الطعن فيه ، أما وقد أحيل إلي المحاكمة بعد ذلك عن ذات الواقعة التي سبق أن جوزي عنها ، وذلك كأثر آخر بدا للقرار الساحب باعتباره قراراً غير مشروع بما رتبته من هذا الأثر الأخير ، وذلك من طرق الدفع في الدعوى التأديبية المقامة ضده عن ذات الواقعة بعدم جواز نظرها بالنسبة إليه ، ذلك أن من الأصول المسلمة ومن البديهيات التي تقتضيها العدالة الطبيعية، أنه لا تجوز المحاكمة التأديبية عن تهمة أخرى جوزي الموظف من أجلها إدارياً ، أو بعبارة أخرى عدم جواز المعاقبة علي الذنب الإداري الواحد مرتين ... " (١).

(١) المجموعة ، السابق ، ص ١٧٢٤ ، ١٧٢٥ ، تحت رقم ٢٨ - ٢٠ (١٩٨٠/١/١٩) ٣٩/٢٥ .

إقامة الدعوى من النيابة الإدارية إجراء جوهري :

فالنيابة الإدارية هي سلطة تحقيق واتهام في المخالفة المالية والإدارية المنسوبة إلى العاملين ، ومن ثم فهي صاحبة الصفة في رفع الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية المختصة ، فهي صاحبة الولاية في تقديم مثل هذه المنازعات لهذه المحكمة ، ومن ثم فإن المحكمة الإدارية العليا أو محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية لا تملك الإحالة على المحكمة التأديبية المختصة بالتطبيق للمادة ١١٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ ، وذلك لإخلال قاعدة الإحالة في هذه الحالة بإجراء جوهري وهو مباشرة الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية ، وبالتالي فإن المحكمة غير المختصة لا تملك إلا أن تنوّه بأن من حق النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية المختصة ، ومن ثم فإن الأثر المترتب على رفع الدعوى التأديبية من غير النيابة الإدارية هو البطلان^(١).

حكم التصدي من قبل المحكمة التأديبية لمخالفة بمناسبة نظر الطعن في قرار

بتوقيع جزاء :

لا تملك المحكمة التأديبية من تلقاء نفسها وهي بصدد الفصل في طعن مقام أمامها من أحد العاملين في جزاء موقع عليه من السلطات الرئاسية ، أن تحرك الدعوى التأديبية ضد هذا العامل وتفصل فيها ، وذلك لأن المشرع قد حدد طريقاً وحيداً لاتصال الدعوى التأديبية بالمحكمة التأديبية، وهو أنه أناط بالنيابة الإدارية الاختصاص بإقامة الدعوى التأديبية أمامها^(٢)، وذلك حتى لا يضار طاعن من طعنه.

المطلب الثاني

الحكم في الدعوى التأديبية

تنتظر الدعوى التأديبية في جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة ، ويتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور ، علي أن يقوم قلم كتاب المحكمة إعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ

(١) المجموعة، السابق ، ص ١٧٢٦ ، ١٧٢٧ ، تحت رقم ٥٠٥ (١٩٧٢/١/٢٢) ١٨٥/٣٠/١٧ .

(٢) السابق ، ص ١٧٢٩ ، ١٧٣٠ ، تحت رقم ١٩١٠ (١٩٧٥/٢/٢٢) ٢٩٧ / ٨٥ / ٢٠ .

الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق (م ٣٤ فقرة ثانية من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢) .

وحرصاً من المشرع علي سرعة إنجاز الفصل في الدعاوي التأديبية ، فقد قرر أن يتم هذا الفصل علي وجه السرعة وعلي الوزراء والرؤساء المختصين موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل في الدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب .

ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب علي ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين .

وتصدر المحكمة حكمها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها.

سلطة المحكمة في الاستجواب : للمحكمة وهي في سبيل الفصل في الدعوى استجواب العامل المقدم إلي المحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيرهم ، ويكون أداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين ، ويسري علي الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور الأحكام المقررة قانوناً وتحرر محضراً بما يقع من الشاهد وتحيله إلي النيابة العامة إذا رأت في الأمر جريمة .

وإذا كان الشاهد من العاملين الذين تختص المحكمة التأديبية بتأديبهم ، ثم تخلف عن الحضور بعد إخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى وامتنع عن أداء الشهادة ، جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين (م ٣٦) .

وقد تكون الواقعة التي وردت بقرار الإحالة من النيابة الإدارية أو غيرها من الوقائع التي شملها التحقيق - جريمة مما يدخل في نطاق القانون الجنائي ، ومن هنا فإن المحكمة وقد رأت ذلك فإنها تحيلها إلي النيابة العامة للتصرف فيها ، ومع ذلك تسير المحكمة في الدعوى التأديبية وتفصل فيها .

ويرد علي هذه القاعدة استثناء يتمثل فيما إذا كان الفصل في الدعوى التأديبية

المعروضة متوقفاً علي الفصل في الدعوى الجنائية ، وهنا فيجب وقف الأولي حتى

يتم الفصل في الثانية ، وذلك دون أن يمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العامل ، وعلي النيابة الإدارية أن تعجل من نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف وذلك

بالفصل في الدعوى الجنائية التي يتوقف علي الفصل فيها حسم الدعوى التأديبية (م ٣٩) .

سلطة المحكمة في التصدي لوقائع لم يتضمنها قرار الإحالة :

الأصل هو أن تنقيد المحكمة التأديبية بالوقائع التي وردت بقرار الإحالة ، والتي تمثل موضوع الدعوى التأديبية المقامة من النيابة الإدارية ، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تتصدى لوقائع لم ترد بقرار الإحالة وذلك بشرطين هما :
أولاً : أن تكون عناصر المخالفة ثابتة بالأوراق .

ثانياً : أن تمنح العامل أجلاً مناسباً لتحضير أوجه دفاعه التي يراها إذا طلب ذلك .

سلطة المحكمة في إقامة الدعوى علي غير من ورد في قرار الإحالة :

كان المشرع قد أعطى المشرع في المادة ٤١ من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨ - الملغي سلطة إقامة الدعوى علي عاملين من غير من قدموا إلي المحاكمة التأديبية وذلك بأحكام هي :

(أ) أن تكون هناك أسباب جدية بوقوع المخالفة منهم .

(ب) أن يمنحوا أجلاً مناسباً لتحضير دفاعهم إذا طلبوا ذلك .

(جـ) أن تحال الدعوى إلي دائرة أخرى برمتها يحددها رئيس مجلس الدولة بقرار منه.

حضور الموظف : للموظف أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله أن يوكل محامياً عنه من المقيدين أمام محاكم الاستئناف ، وأن يبدي دفاعه شفويّاً أو كتابياً ، وللمحكمة أن تقرر حضور المتهم بنفسه .

في جميع الأحوال إذا لم يحضر المتهم بعد إخطاره بذلك تجوز محاكمته والحكم عليه غيابياً .

أن الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها عن طريق خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، في محل إقامة المعلن إليه أو في مقر عمله.

إجراءات نظر الطعون المتعلقة بالعاملين بالقطاع العام :

عندما تنظر المحكمة التأديبية الطعون المتعلقة بالعاملين بالقطاع العام ، فإنها تنقيد عند نظر الطعن المنصوص عليه في البند الثالث عشر من المادة العاشرة من

القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثالث - أولاً - من الباب الأول من هذا القانون عدا الأحكام المتعلقة بهيئة قضايا الدولة (م ٤٢) .

والإجراءات والقواعد التي أحال المشرع عليها هي تلك الخاصة بالإجراءات أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية في المواد من (٢٤ - ٣٣) .

الحكم في الدعوى التأديبية :

لا يجوز تأجيل النطق بالحكم أكثر من مرة ، وتصدر الأحكام مسببة ويوقعها الرئيس والأعضاء (م ٤٣) .

هذا ومنطوق الحق يجب أن يكون محققاً للهدف الذي تتغياه الدعوى ، وفي ذلك استقرت المحكمة الإدارية العليا علي أن : " كل الغرض المنشود من إقامة أي دعوى هو الوصول إلي استصدار حكم يقر الحق المرفوعة به في نصابه ويضع حداً للنزاع المتعلقة بموضوعها ولذلك وجب كفاعة قانونية ملزمة أن يكون نص منطوق الحكم محققاً لهذا الغرض فإذا كان موضوع النزاع شيئاً معيناً وجب أن يتضمن من النص تمكن المحكوم عليه من وضع يده علي هذا الشيء ... " (١) .

تسبيب الحكم الصادر في الدعوى التأديبية :

القاعدة هي وجوب هذا التسبيب ، بيد أنه ينبغي أن نلاحظ ما يلي :

(أ) يكفي أن تورد المحكمة الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في ثنايا أسباب الحكم التي تكفلت بالرد عليها .

(ب) يكفي لسلامة الحكم أن يكون قائماً علي أسباب تستقيم معه .

(جـ) لا يلزم أن يتعقب الحكم جميع حجج الخصوم في جميع مناحي أقوالهم استقلالاً ثم يفندوها تفصيلاً الواحدة تلو الأخرى (٢) .

(١) المجموعة ، السابق ، ص ١٠٧٤ ، ١٠٧٥ ، تحت رقم ١٢٥٣ / ٩ (١٩٧٠/٦/٢٨) ٤٣٩/٦٧/١٥ .

(٢) المجموعة ، السابق ، ص ١٠٧٥ ، تحت رقم ١٣٣٢ - ١٨ (١٩٧٨/٣/١١) ٩١/٢٣ .

الجزء الثالث (قضاء الإلغاء – القضاء الدستوري)

دكتور

أحمد عبد الحسيب السنتريسي
أستاذ ورئيس قسم القانون العام
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
جامعة الأزهر

تمهيد وتقسيم

يختص مجلس الدولة المصري بنظر العديد من الدعاوى التي تكون الإدارة طرفاً فيها، ومن هذه الدعاوى دعوى الإلغاء التي يكون محلها دائماً القرار الإداري، كما يختص القضاء الدستوري بالعديد من الدعاوى والتي من أهمها الدعوى التي يكون محلها الرقابة على دستورية القوانين.

ودرستنا في هذا الجزء ستخصص لدعوى الإلغاء التي تعد من الدعاوى الإدارية، وكذلك القضاء الدستوري في فصلين على النحو التالي:

الفصل الأول : دعوى الإلغاء.

الفصل الثاني : القضاء الدستوري.

الباب الأول

دعوى الإلغاء

(دعوى تجاوز السلطة)

للحديث عن دعوى الإلغاء ينبغي أن نبين مفهومها وعلاقتها بالدعاوى الإدارية الأخرى، ثم نبين شروط قبولها أو ما تسمى بالشروط الشكلية لدعوى الإلغاء، ثم نبين أوجه الطعن بالإلغاء أو ما تسمى بالشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء، ثم أخيراً نبين إجراءات رفع دعوى الإلغاء والحكم فيها، وذلك في أربعة فصول على النحو التالي :

الفصل الأول : مفهوم دعوى الإلغاء وعلاقتها بالدعاوى الأخرى.

الفصل الثاني : الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء.

الفصل الثالث : الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء.

الفصل الرابع : إجراءات دعوى الإلغاء والحكم فيها.

الفصل الأول

مفهوم دعوى الإلغاء

وعلاقتها بالدعاوى الإدارية الأخرى

يعود أصل قيام دعوى الإلغاء كدعوى قضائية في فرنسا إلى حصول مجلس الدولة الفرنسي على ولاية القضاء المفوض في عام ١٨٧٢ حيث كان الأمر يتعلق قبل ذلك بمجرد تظلم إداري، وفي سنة ١٩٥٣ أصبحت المحاكم الإدارية هي صاحبة الاختصاص في المنازعات الإدارية ومنها دعوى الإلغاء التي أصبح الفصل فيها أمام هذه المحاكم، وكان يستأنف الحكم الصادر فيها أمام مجلس الدولة الفرنسي حتى عام ١٩٨٧م، حيث تأسست فيه محاكم الاستئناف الإدارية التي حلت محل مجلس الدولة في هذا الاختصاص. وقد اهتم مجلس الدولة الفرنسي بدعوى الإلغاء وتحديد أحكامها، وتنظيم بعض جوانبها.

بينما تعود نشأة دعوى الإلغاء في مصر إلى نشأة مجلس الدولة عام ١٩٤٦م، حيث نص قانون مجلس الدولة رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦م في مادته العاشرة على اختصاص مجلس الدولة المصري بنظر دعوى إلغاء القرارات الإدارية.

ولدراسة هذا الفصل نتناول أولاً مفهوم دعوى الإلغاء ثم نتناول علاقتها بالدعاوى الإدارية الأخرى، وذلك في بحثين على النحو التالي :

المبحث الأول: مفهوم دعوى الإلغاء وخصائصها.

المبحث الثاني: علاقة دعوى الإلغاء بالدعاوى الأخرى.

المبحث الأول

مفهوم دعوى الإلغاء وخصائصها

يعتبر مبدأ المشروعية المرتكز الأساسي لدولة القانون، وسمه أساسية من سمات الدول الحديثة، ومن المعلوم أن الرقابة على أعمال وتصرفات الإدارة، تأخذ أشكالاً متعددة منها ما هو سياسي وما هو إداري وما هو قضائي، وسوف تقتصر دراستنا على الرقابة القضائية على أعمال وتصرفات الإدارة القانونية وخاصة فيما يتعلق بالأعمال القانونية التي تصدرها الإدارة من جانب واحد وهي الرقابة القضائية على

القرارات الإدارية، وذلك عن طريق دعوى الإلغاء التي يكون محلها دائماً القرار الإداري.

أولاً : تعريف دعوى الإلغاء :

ولقد عرف رأى في الفقه دعوى الإلغاء بأنها : الدعوى القضائية التي ترفع للمطالبة بإعدام قرار إداري غير مشروع.^(١)
وعرفها رأي آخر بأنها : الدعوى التي يرفعها صاحب المصلحة مختصاً فيها قراراً إدارياً طالباً إلغائه.^(٢)

فدعوى الإلغاء تعد دعوى قضائية ترفع للمطالبة بإعدام قرار إداري صدر مخالفاً للقانون، وتعد هذه الدعوى أهم وسائل حماية المشروعية، إذ أنها تؤدي إلى بطلان القرار الإداري غير المشروع .

ويمكننا تعريف دعوى الإلغاء بأنها : الدعوى التي يرفعها ذو الشأن إلى القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرار إداري غير مشروع، وذلك بمخالفته للقانون بمعناه الواسع.

فدعوى الإلغاء يقوم بموجبها القاضي الإداري بفحص مشروعية القرار الإداري؛ فإذا ما تبين له مخالفة القرار لمبدأ المشروعية، حكم بإلغائه فقط دون أن يتدخل في تعديل القرار المطعون فيه أو استبدال غيره به.

ثانياً : خصائص دعوى الإلغاء : تتميز دعوى الإلغاء بعدة خصائص تميزها عن غيرها من الدعاوى، وتتمثل هذه الخصائص في كونها دعوى ذات نشأة قضائية، وتنتمي إلى قضاء المشروعية، وهي الطريق الأصلي لإلغاء القرارات الإدارية، وتتميز بإجراءات خاصة في رفعها، كما أنها دعوى ذات طبيعة عينية.

١- دعوى الإلغاء دعوى قضائية ذات نشأة قضائية : تعتبر دعوى الإلغاء دعوى قضائية من صنع مجلس الدولة الفرنسي، فلقد بدأ مجلس الدولة الفرنسي بمرحلة القضاء المحجوز التي كانت دعوى الإلغاء فيه لا تعدو أن تكون تظلماً

(١) راجع د/ ماجد راغب الحلو، ود/ محمد عبده إمام : القضاء الإداري، طبعة أولى ٢٠٠٧م ، بدون دار نشر، ص ١٧٩.

(٢) راجع د/ إبراهيم محمد علي : القضاء الإداري، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر، ص ٣٣٥.

إدارياً، كما لا تعدو قرارات مجلس الدولة الفرنسي إلا توصيات غير نافذة إلا بموافقة رئيس الدولة عليها، وبعد هذه المرحلة بدأت مرحلة القضاء المفوض في سنة ١٨٧٢م، حيث صدر قانون ٢٤ مايو سنة ١٨٧٢م والذي منح مجلس الدولة سلطة إصدار الأحكام بصفة نهائية دون التوقف على التصديق عليها من رئيس الدولة؛ وبهذا أصبحت قرارات مجلس الدولة الفرنسي قرارات باتة لا تحتاج إلى التصديق عليها من رئيس الدولة؛ ومن ثم أضحت دعوى الإلغاء دعوى قضائية من صنع مجلس الدولة الفرنسي.

وإذا كانت دعوى الإلغاء دعوى قضائية من صنع مجلس الدولة الفرنسي إلا أن الوضع يختلف في مصر حيث نشأت دعوى الإلغاء كدعوى قضائية بمقتضى قانون إنشاء مجلس الدولة رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦م، وبذلك تكون دعوى الإلغاء في مصر دعوى قضائية ذات نشأة قانونية.

٢- دعوى الإلغاء دعوى تنتمى إلى قضاء المشروعية : يهدف قاضي الإلغاء في الأساس حماية المشروعية؛ ومن ثم يقوم هذا القاضي في دعوى الإلغاء بفحص مشروعية القرار الإداري، فإذا ما تبين له أن القرار موافق للمشروعية، حكم بموافقة القرار للمشروعية ورفض دعوى الإلغاء، أما إذا ما تبين له أنه مخالف للمشروعية حكم بإلغائه.

ومن ثم، فإن رافع دعوى الإلغاء لا يختصم الإدارة، ولكن يختصم القرار غير المشروع، ويترتب على ذلك أنه يكفي أن تتوافر في حق رافع دعوى الإلغاء بالمصلحة التي يمسه القرار، ولا يشترط أن يمس القرار حق شخصي أو ذاتي له، وهذا راجع لانتماء دعوى الإلغاء إلى قضاء المشروعية وكونها دعوى موضوعية عينية لا شخصية، ومن ثم يحوز الحكم الصادر بالإلغاء الحجية المطلقة كأصل عام. كما يترتب على ذلك أيضاً أن يقتصر حكم الإلغاء على تقرير عدم المشروعية وإلغاء القرار غير المشروع دون أن يوجه قاضي الإلغاء أوامر للإدارة بتعديل القرار أو إعادة إصداره على نحو معين.

٣- دعوى الإلغاء الطريق الأصلي لإلغاء القرارات الإدارية أمام القضاء الإداري: تعتبر دعوى الإلغاء الطريق الأصلي لإلغاء القرارات الإدارية غير

المشروعة، ومن ثم فإن الطعن على أي قرار إداري لا يكون إلا من خلال دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري وذلك كأصل عام، لكن قد تستثني بعض القوانين قرارات إدارية وتجعل سلطة الفصل في مدى مشروعيتها وإلغائها لجهات قضائية أخرى، وذلك مثل القرارات الصادرة من نقابة المحامين برفض القيد في جداولها، حيث جعل قانون المحاماة المصري سلطة النظر في مدى مشروعيتها وإلغائها من اختصاص محكمة استئناف القاهرة.

٤- إحاطة دعوى الإلغاء بإجراءات قانونية خاصة : أحاطت القوانين والقضاء الإداري في كل من مصر وفرنسا دعوى الإلغاء بإجراءات قانونية خاصة، وذلك مثل ضرورة سبق التظلم الإداري من ذوى الشأن قبل رفع دعوى الإلغاء بخصوص بعض القرارات الإدارية ورفع دعوى الإلغاء في مواعيد معينة وذلك حفاظاً على مبدأ الأمن القانوني، وكذلك ما قرره المشرع في مصر من ضرورة سبق اللجوء للجنة فض المنازعات قبل رفع دعوى الإلغاء.

كما قرر المشرع الفرنسي عدم تطلب إجراءات معينة تيسيراً على رافع دعوى الإلغاء لم يقررها المشرع المصري، تتمثل في عدم تطلب توقيع محام على عريضة دعوى الإلغاء، وعدم تطلب دفع رسوم لرفع دعوى الإلغاء.

المبحث الثاني

علاقة دعوى الإلغاء بالدعوى الإدارية الأخرى

تأخذ المنازعات مع الإدارة صوراً كثيرة ومتنوعة، فإذا كانت المنازعة بخصوص مشروعية قرار إداري؛ فتكون الدعوى الإدارية هي دعوى الإلغاء، وقد تثار مسؤولية الإدارة عن تعاقدها التي تستخدم فيها وسائل القانون العام، ومن ثم تثار دعوى المسؤولية التعاقدية للإدارة، وقد تثار مسؤولية الإدارة عن أعمالها القانونية غير المشروعة، وذلك كإصدار الإدارة لقرار إداري غير مشروع ترتب عليه ضرر، كما قد تثار مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية إذا رتب ضرراً للأفراد، وهنا نكون بصدد دعوى مسؤولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية، كما أن العاملين لدى الإدارة يخول لهم رفع منازعات كثيرة متعلقة بحقوقهم الوظيفية

كالمرتبات والعلاوات والترقيات، كما قد تحرك دعوى التأديب للموظفين العموميين أمام قضاء التأديب إذا كون فعلهم خطأً تأديبياً.

ولدعوى الإلغاء علاقة وطيدة بالدعوى الإدارية الأخرى وبصفة خاصة دعوى التأديب والتعويض، فتنتمى علاقة دعوى الإلغاء بدعوى التأديب في أن القرار الإداري غير المشروع قد يكون سبباً في إقامة الدعوى، حيث تحرك دعوى الإلغاء عن هذا القرار غير المشروع، وتحرك الدعوى التأديبية ضد الموظف الذي أصدر القرار الإداري غير المشروع على اعتبار أن إصداره القرار الإداري غير المشروع يمثل جريمة تأديبية.

كما أنه توجد علاقة بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض، حيث إن القرار الإداري غير المشروع علاوة على أنه قد تحرك قبله دعوى الإلغاء، فقد ترتب عدم المشروعية هنا خطأ من الإدارة يسبب ضرراً، ومن ثم يخول لمن وقع عليه هذا الضرر أن يقوم برفع دعوى التعويض أيضاً.

الفصل الثاني

الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء

يجب لقبول دعوى الإلغاء أمام المحكمة المختصة للمطالبة بإعدام قرار إداري مخالف للقانون أن تتوافر مجموعة من الشروط، وهذه الشروط منها ما يرتبط بالقرار موضوع الطعن، ومنها ما يتعلق برفع الدعوى، ومنها ما يتعلق بميعاد رفع هذه الدعوى، ومنها ما يتعلق بضرورة سبق طلب التوفيق في المنازعة، وأخيراً شرط انعدام طريق الطعن الموازي، وسنتناول هذه الشروط في خمس مباحث على النحو التالي :

المبحث الأول : الشروط المتعلقة بالقرار محل الطعن بالإلغاء.

المبحث الثاني : الشروط المتعلقة برفع الدعوى.

المبحث الثالث : الشروط المتعلقة بميعاد الطعن بالإلغاء.

المبحث الرابع : شرط سبق طلب التوفيق في المنازعة.

المبحث الخامس : شرط انعدام طريق الطعن الموازي.

المبحث الأول

الشروط المتعلقة بالقرار محل الطعن بالإلغاء

يشترط في القرار المخالف للقانون مجموعة من الشروط لقبوله في دعوى الإلغاء وتحدد هذه الشروط في وجوب ان يكون القرار الإداري نهائياً، وصدور القرار عن سلطة إدارية، وأن تكون هذه السلطة سلطة إدارية وطنية، وأخيراً، أن يكون هذا القرار صادراً قبل العمل بقانون مجلس الدولة .

أولاً : أن يكون القرار الإداري نهائياً : نصت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المصري على اختصاصات مجلس الدولة، وورد في البند الخامس منها أن من ضمن اختصاصاته "الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية" .

وبناءً على ما تقدم لا يجوز الطعن في القرار الإداري بالإلغاء إلا إذا كان قد اكتسب وصف النهائية، أي أنه أصبح قابلاً للتنفيذ دون التوقف على إرادة سلطة إدارية أخرى يكون لها الحق في التعقيب عليه أو التصديق عليه، كما هو الشأن

بالنسبة للقرارات التأديبية الصادرة عن المجالس التأديبية، والقرارات التي تنتهي إليها اللجان بخصوص إبداء الرأي في مسألة معينة، فهي تعتبر مجرد مقترحات، وليست قرارات نهائية لأنها تخضع لتصديق السلطة التي تملك حق التأديب، وبالتصديق عليها من طرف هذه السلطة تصبح قرارات إدارية نهائية يمكن أن تكون موضوعاً للطعن بالإلغاء الذي لا يقبل ضد القرار الذي يحتاج تنفيذه للتصديق عليه من الرئيس أو اعتماده من جهة إدارية أخرى، وكذلك لا يجوز الطعن بالإلغاء في الإجراءات والأعمال التحضيرية التي تسبق اتخاذ القرار النهائي.^(١)

ولا يكتسب القرار الإداري وصف النهائية إلا إذا أحدث أثراً قانونياً في المركز القانوني للأفراد، وذلك بإنشائه أو تعديله أو إنهائه، مثل قرارات التعيين في الوظيفة العامة والترقية وإنهاء الخدمة؛ ومن ثم لا يكون القرار الإداري قابلاً للطعن بالإلغاء ما لم يترتب على إصداره تأثيراً في المركز القانوني لذوي الشأن، فالقرارات التي لا ينشأ عنها أي أثر في الوضع الإداري والقانوني تخرج من نطاق الطعن بالإلغاء؛ وبالتالي لا يمكن الطعن بالإلغاء في الأعمال التي لا تكشف فيها الإدارة سوى عن نيبتها أو رغبتها بصدد مسألة من المسائل، كإجراء كشف طبي لأحد الموظفين، أو إصدار إعلان عن وظيفة ما.

كما أن الأوامر والتوجيهات والبيانات التي تصدر من رئيس المصلحة إلى العاملين تحت رئاسته والتي تنطوي على تفسير للقواعد القانونية وكيفية تنفيذها والتي تعرف باسم المنشورات والأوامر المصلحية، وهذه لا يمكن أن تكون محلاً لدعوى الإلغاء وذلك استناداً إلى كون هذه المنشورات والأوامر توجه إلى الموظفين وليست لها أي أثر مباشر قبل الأفراد، ولا تتضمن بالتالي أي تغيير في الأوضاع القانونية للأفراد؛ ومن ثم فلا يكون لها أي أثر قانوني بإنشاء أو تعديل أو إنهاء مركز قانوني كما أن دعوى الإلغاء لا يجوز رفعها ضد القرارات المفسرة أو المؤكدة لقرار سابق؛ حيث إنها لا أثر لها وإنما الأثر قد ترتب من قبل بصدد القرار الذي تم تفسيره

(١) راجع حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 54 لسنة 27 ق جلسة ١٩٧٣/٢/٦ - س ٢٧، ج ١، ص 129؛ وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٩٤٣ لسنة ٤٠ ق . عليا - جلسة ١٩٩٤/١٢/٣ - س ٤٠، ج ١، ص ٤٧٩.

أو توكيده، حيث إن القرارات المفسرة والمؤكددة لقرارات سابقة لا تأتي بجديد، لكن من الممكن أن ترفع دعوى الإلغاء ضد هذه القرارات إذا أتت بجديد عما هو مقرر في القرار الذي تم تفسيره أو تأكيده؛ لأنه في هذه الحالة لم يعد مكرراً لمضمون القرار الأول وإنما أحدث أثراً جديدة بما قرره من أحكام جديدة لم تكن مقررة في القرار الذي تم تفسيره أو تأكيده بما يخرج عن كونه قراراً مفسراً أو مؤكداً. ولا يؤثر في نهائية القرار الإداري كونه صدر صريحاً أو ضمناً أو كان من قبيل القرارات السلبية، فجميع هذه القرارات مادامت صدرت نهائية فيجوز الطعن عليها بالإلغاء.

ثانياً : صدور القرار من سلطة إدارية :

يشترط في القرار موضوع الطعن بالإلغاء أن يكون صادراً من سلطة إدارية، سواء كانت مركزية أو لامركزية، وسواء من سلطة إدارية ذات اختصاص أصيل أو ذات اختصاص مفوض.

فمن المستقر عليه أن دعوى الإلغاء لا توجه إلا إلى قرار إداري صادراً عن سلطة إدارية، والقرار الإداري وفقاً لما استقر عليه القضاء الإداري وهو إفصاح جهة الإدارة عن إدارتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.

ويتم تحديد القرارات الإدارية استناداً إلى نوعية العمل الصادر من الإدارة، فتميز القرارات الإدارية بكونها تصدر عن الإدارة أن هذا المعيار لا يكفي في حد ذاته للتمييز بين كافة الأعمال التي تصدر عن جهة الإدارة، حيث يصدر من الإدارة مجموعة من الأعمال منها ما هو مادي ومنها ما هو قانوني، فالأعمال المادية - كهدم منزل مثلاً - لا تعد محلاً لدعوى الإلغاء، وإنما من الممكن أن تكون محلاً لدعوى إدارية أخرى كدعوى التعويض التي تتدرج في نطاق دعاوى القضاء الكامل. كما أن الأعمال القانونية التي تصدر عن الإدارة منها ما يصدر بإرادتين وهذه الأعمال تسمى بالعقود الإدارية، وهذه الأعمال لا تخضع لدعوى الإلغاء، وإنما تخضع لدعوى القضاء الكامل، ولكن تخضع القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد

لدعوى الإلغاء، وذلك مثل القرار الصادر من الإدارة برسو المزداد أو المناقصة، ومن الأعمال القانونية أيضا ما يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة، وتسمى بالقرارات الإدارية، وهى محل الطعن بالإلغاء.

ونستطيع القول أن العمل القانوني الذي يمكن أن يكون محلاً للإلغاء يجب أن يصدر عن سلطة إدارية بإرادتها المنفردة، وأن تكون السلطة التي أصدرت التصرف محل الطعن بالإلغاء قد تصرفت باعتبارها سلطة إدارية.

ولا يكفي أن يكون العمل قد صدر عن سلطة إدارية لإمكان الطعن عليه بالإلغاء، بل يجب علاوة على ذلك أن يكون قد صدر عن الإدارة باعتبارها سلطة عامة وذلك باعتبار أن القرار الإداري يعد وسيلة من وسائل السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة وعلى ذلك فإن التصرف الذي يصدر عن الإدارة باعتبارها مجرد شخص من أشخاص القانون الخاص لا يعد قراراً إدارياً؛ ومن ثم لا يمكن أن يكون محلاً لدعوى الإلغاء .

أما بالنسبة للقرارات التي تصدر عن النقابات المختلفة كنقابة المحامين وغيرها من النقابات هل يجوز الطعن بالإلغاء في القرارات التي تصدر عن هذه النقابات أم لا ؟ فقد حسم مجلس الدولة الفرنسي هذا الوضع في حكم الصادر في ١٩٤٢ واعتبر أن القرارات الصادرة عن النقابات هي قرارات إدارية ومن ثم يمكن أن تكون محلاً للطعن عليها بالإلغاء أمام القضاء الإداري .

وفى مصر تعتبر أيضاً القرارات الصادرة من النقابات قرارات إدارية؛ ومن ثم تخضع للطعن عليها بالإلغاء، إلا ما استثنى بنص خاص، وذلك مثل الطعن في قرارات القيد بنقابة المحامين فقد أسندت إلى محاكم أخرى تابعة لجهة القضاء العادي.

وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا : " تختص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة بنظر الطعون في القرارات التي تصدر من أجهزة نقابة المحامين ولجانها والتعويض عنها ، طبقاً لأحكام قانون المحاماة ، وتخرج عن الاختصاص الولائي المعقود لمحاكم مجلس الدولة" (١) .

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن ١١٩٦١ لسنة ٤٦ ق.عليا - جلسة ٢٠٠٥/٢/١٩ - الدائرة الأولى عليا.

كما يخرج من نطاق دعوى الإلغاء القرارات الصادرة في نطاق نظرية أعمال السيادة؛ ومن ثم فإن أي قرار أضفى عليه القضاء الوصف السيادي، فإنه يخرج من نطاق رقابة القضاء ومن ثم لا يخضع لدعوى الإلغاء، طبقاً لنص المادة (١١) من قانون مجلس الدولة المصري والتي تنص على أنه : " لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة" .

ثالثاً : أن يكون القرار الإداري صادراً من سلطة إدارية وطنية : لا يجوز الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية الصادرة من سلطة إدارية أجنبية، فالقرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها بالإلغاء هي القرارات الإدارية الصادرة فقط من سلطة إدارية وطنية، سواء اتخذت هذه السلطة قرارها الإداري داخل أو خارج الوطن؛ ومن ثم لا يجوز الطعن على القرارات الإدارية الصادرة من سلطة إدارية أجنبية أمام محاكم مجلس الدولة المصري ولو اتخذت هذه القرارات على الأراضي المصرية، وذلك مثل القرارات التي تتخذها السفارات والقنصليات الأجنبية بمنح أو رفض منح تأشيرة السفر إلى بلادها.

ولقد اعتنق مجلس الدولة المصري هذا المسلك، فقررت محكمة القضاء في العديد من أحكامها هذا على الشرط الإداري، ومن أحكامها في في هذا الصدد حكمها الصادر في ٢٨ ديسمبر ١٩٥٤ بأنه : " لا نزاع في أن قطاع غزة يعتبر جزءاً خارجاً عن حدود مصر وأن السلطات المصرية في إدارتها لهذا القطاع إنما تباشر نوعاً من الحماية والإشراف على جزء من إقليم فلسطين ولما كان من الأمور المسلمة أنه يشترط لجواز الطعن أمام محكمة القضاء الإداري ألا يكون القرار المطعون فيه صادراً من سلطة أجنبية أو دولية فإنه يجب التفرقة بين طائفتين من القرارات:-

أ - القرارات التي يتخذها ممثلو مصر في قطاع غزة باعتبارهم موظفين مصريين يباشرون أعمال السلطة المصرية وهذا النوع من القرارات يخضع كقاعدة عامة لرقابة مجلس الدولة ما لم يكن طريق الطعن متعذراً بالتطبيق لنظرية أعمال السيادة .

ب - القرارات التي يتخذها ممثلو مصر نتيجة لإشرافهم على إدارة هذه البلاد وباعتبارهم جزءاً من السلطات الإدارية المحلية وهذا النوع من القرارات لا يخضع لرقابة مجلس الدولة المصري، ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن القرار الصادر من الحاكم الإداري لقطاع غزة أو من نائبه بمصادرة المبالغ المضبوطة في جريمة محاولة تهريب نقود إلى الخارج إنما تتعلق بإدارة هذا الإقليم وقد صدر بالتطبيق لأحكام القانون الفلسطيني؛ ومن ثم فإن هذا القرار من الحاكم المصري بقطاع غزة اتخذ في غير الحالات التي ينبسط عليها رقابة هذه المحكمة^(١).

ولقد أكدت محكمة القضاء الإداري على المبدأ السابق، فقضت في ١٠ مارس ١٩٥٩ بأنه : "من الأمور المسلمة أنه يشترط لجواز الطعن أمام محكمة القضاء الإداري أن يكون القرار المطعون فيه صادر من جهة إدارية وطنية تطبق قوانين البلاد وتستمد سلطتها منها؛ ومن ثم إذا كان القرار صادراً من هيئة أجنبية أو دولية فإنه يكون بعيداً عن اختصاص المحكمة ولا يدخل في ولايتها".^(٢) .

وقضت أيضاً في حكمها الصادر في ١٣ مايو ٢٠٠٨ بأنه : "... وترتباً على ما تقدم ولما كانتا منظمتي الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية منظمتين دوليتين وفقاً لميثاقتي إنشائهما وتعدان بهذه المثابة من أشخاص القانون الدولي العام؛ وبالتالي فإن ما يصدر عنهما من قرارات سواء أكانت قرارات إيجابية أو سلبية شأن ما يطالب به المدعى في الدعوى الماثلة يخرجان من رقابة القضاء الإداري والقضاء عموماً؛ مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر هذه الطلبات وإلزام المدعى مصروفاتها".^(٣)

ومن الجدير بالملاحظة أن العبرة في تحديد اختصاص القضاء الإداري إنما يرجع في الواقع إلى طبيعة القرار وقت صدوره، وهذا يعني عدم الاعتداد بتغير صفة مصدره بعد هذا التاريخ وهو ما تم التأكيد عليه من قبل القضاء .

(١) راجع حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم - 4355 لسنة 7 ق - بتاريخ ١٢/٢٨/١٩٥٤م، المجموعة س ٩، ج ١، ص ١٩٣، ص ١٩٣.

(٢) راجع حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم - 8095 لسنة 8 ق - بتاريخ ٣/١٠/١٩٥٩م، س 13، ج ١، ص ١٧٣.

(٣) راجع حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 42977 لسنة 60 ق - بتاريخ ١٣/٥/٢٠٠٨م.

وعلى الرغم مما سبق إلا أن القضاء الإداري المصري قرر مبدأ مفاده أن الهيئة الأجنبية إذا كانت تقوم بعمل من صميم أعمال أحد المرافق العامة، فإن ما يصدر منها من قرارات في هذا الخصوص تكون قرارات إدارية خاضعة لرقابة القضاء؛ ومن ثم فإن المؤسسات التعليمية الأجنبية التي تكون متاحة للمصريين والأجانب يجب أن تشرف عليها الدولة عن طريق الوزير المختص، سواء وزير التربية والتعليم بالنسبة للتعليم قبل الجامعي، أو وزير التعليم العالي بخصوص التعليم الجامعي؛ وبالتالي فإن ما تصدره هذه المؤسسات التعليمية من قرارات تخص العملية التعليمية تعد قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري المصري، أما إذا لم تكن هذه المؤسسات متاحة للمصريين بأن كانت مقصورة على الأجانب فقط؛ فلا إشراف عليها من قبل الدولة؛ ومن ثم لا تعد القرارات الصادرة منها ولو كانت ماسة بالعملية التعليمية قرارات إدارية صادرة من سلطة وطنية؛ وعلي تخرج من رقابة القضاء الإداري المصري.(١) .

فالجامعة الأمريكية هيئة تعليمية أجنبية على الأراضي المصرية وتقوم بعمل من أعمال مرفق التعليم؛ فمن ثم إن ما تصدره من قرارات خاصة بالعملية التعليمية يخضع لمراقبة مجلس الدولة إلغاءً وتعويضاً، ويختصم في الدعوى وزير التعليم العالي باعتباره مشرفاً على الجامعة، وأيضاً رئيس هذه الجامعة.(٢) .

رابعاً : أن يكون هذا القرار صادراً بعد العمل بقانون مجلس الدولة رقم

١١٢ لسنة ١٩٤٦م : طبقاً لقاعدة عدم رجعية القوانين، فإن القانون لا يسري بأثر رجعي على المراكز القانونية التي استقرت قبل دخوله حيز النفاذ في حق المخاطبين به، ولما كان قانون مجلس الدولة المصري رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦م قد استحدث قضاء الإلغاء؛ فإنه لا يجوز الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية النهائية التي

(١) راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم - 6085 لسنة 45 ق - بتاريخ ١٨/٤/٢٠٠١م، المجموعة س٤٦، ج٢، ص1469.

(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) في الطعن رقم ٣٢١٩ - لسنة ٤٨ ق - بتاريخ الجلسة ٢٠٠٧/٦/٩ - المجموعة، ص ٢٣٩؛ وراجع حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ٣٢٧٤ - لسنة ٦٢ ق - بتاريخ ٢٠٠٩/٣/٣م؛ وحكمها في الدعوى رقم ١٤٢ - لسنة ٢٠٠٩ ق - بتاريخ الجلسة ٢٠٠٩/٦/١٦م.

صدرت قبل هذا التاريخ، ومن ثم لا تقبل دعوى الإلغاء إلا بمناسبة القرارات الإدارية الصادرة بعد نفاذ هذا القانون، أما القرارات الصادرة قبل نفاذه فلا تقبل دعوى الإلغاء بصددتها، ولكن تقبل دعوى التعويض عن الأضرار التي قد تصيب ذوي الشأن بسببها.

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل صدور القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦م كان يتمتع على المحاكم القضائية النظر في الأعمال الإدارية غير المشروعة إلا عن طريق التعويض فحسب.

ولقد تم التأكيد على عدم قبول دعوى الإلغاء ضد القرارات الصادرة قبل سريان قانون مجلس الدولة من خلال العديد من الأحكام التي صدرت عن القضاء الإداري في مصر؛ ومن ثم قضت محكمة القضاء الإداري في ١٩ مارس ١٩٤٧ بأن : "الأمر أو القرار الإداري هو كل إفصاح من جانب الإدارة العامة يصدر صراحة أو ضمناً من إدارة هذه المصلحة في أثناء قيامها بأداء وظائفها المقررة لها قانوناً في حدود المجال الإداري، ويقصد منه إحداث أثر قانوني ويتخذ صفة تنفيذية. والقرار أو الأمر الإداري - على خلاف القوانين واللوائح - يتم ويحدث أثره القانوني بمجرد صدوره، وتتوافر له القوة التنفيذية بغير حاجة على إعلانه أو النشر عنه، اللهم إلا إذا كان الإعلان أو النشر عنصراً أساسياً في كيانه ووجوده. وإن فالقرار الصادر قبل العمل بقانون مجلس الدولة لا يسري عليه حكم هذا القانون ولو كان لم يعلن أو لم ينفذ إلا بعد العمل به" (١) .

وقضت أيضاً في ٢٤ مايو ١٩٤٩ بأن : "إذا كان طلب المدعى قد صدر فيه قرار صريح بالرفض في سنة ١٩٤١ ثم تأيد في سنة ١٩٤٤ وكانت الدعوى مكيفة على الوقائع الصحيحة تتضمن طلباً بإلغاء القرار المذكور وكان هذا القرار صادراً قبل العمل بقانون مجلس الدولة فلا ينسحب إليه أثره، كما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة فتكون الدعوى غير مقبولة." (٢)

(١) راجع حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1 لسنة 1 ق - بتاريخ ١٩/٣/١٩٤٧م، س ١، ص 216 .

(٢) راجع حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ٤٠٢ - لسنة ٢ ق - بتاريخ ٢٤/٥/١٩٤٩م، المجموعة، س ٣، ج ١، ص ٨٢٤ .

كما تجدر الإشارة إلى أن قيمة هذا الشرط تعد قيمة تاريخية، حيث لا يثار هذا الشرط إلا في الفترة التي أعقبت صدور قانون مجلس الدولة، حيث إن مدة دعوى الإلغاء وهي ستون يوماً بفواتها يمتنع الطعن بالإلغاء في القرارات التي صدرت بعد العمل بقانون مجلس الدولة؛ ومن ثم فبالأولى يمتنع الطعن بالإلغاء في القرارات السابقة على نفاذ القانون سواء من ناحية عدم سريان هذا القانون بأثر رجعي، أو من ناحية أخرى إذا مر على نفاذ هذه القرارات أكثر من ستين يوماً.

ونري أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦م وتقريره دعوى الإلغاء أنه كان ينبغي تطبيقاً للعدالة وموازنة بين مبدأ المشروعية ومبدأ الأمن القانوني أن تقرر مدة ستين يوماً - وهي المدة المقرر خلالها الطعن بالإلغاء - من تاريخ علم ذو الشأن بالقرار ولو صدر قبل العمل بقانون مجلس الدولة، حيث إن العلم هو أساس نفاذ القرار الإداري في حق المخاطبين به ولا يسري في حقهم قبل علمهم به؛ ومن ثم فالعبرة في عدم خضوع القرار لرقابة مجلس الدولة من عدمه هو بنفاذه قبل صدور قانون مجلس الدولة لا بعده.

المبحث الثاني

الشروط المتعلقة برفع الدعوى

يجب أن يتوافر في رافع دعوى الإلغاء شروط معينة تتمثل في المصلحة، والصفة، وسوف نتناول هذين الشرطين فيما يلي :

أولاً : شرط المصلحة : من الشروط الرئيسية لدعوى الإلغاء ، ضرورة توافر المصلحة الشخصية المباشرة في حق رافع دعوى الإلغاء.

وتنص المادة رقم (٣) من قانون المرافعات على أنه "لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقررها القانون...".

وتنص المادة الثانية عشر من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢م على أنه "لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة مباشرة".

١- تعريف المصلحة : المصلحة شرط أساسي لقبول الدعاوى كافة ومنها

دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري، وتعرف المصلحة بصفة عامة بأنها

(الفائدة أو المنفعة التي يمكن أن يحصل عليها رافعها في حالة إجابته إلى طلبه)^(١). ومن المستقر قضاءً أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.

والمصلحة في دعوى الإلغاء هي الفائدة التي تعود على رافع الدعوى من إلغاء القضاء للقرار الإداري محل الدعوى.

والمصلحة في دعوى الإلغاء تتميز عن تلك التي تتطلبها الدعاوى العادية أمام المحاكم العادية أو دعوى القضاء الكامل، فبينما تكمن مصلحة رافع الدعوى في القضاء الكامل في الاعتداء على حق للمدعي، أما في دعوى الإلغاء فيكتفى بالمساس بمركز قانوني للمدعي ولا يتطلب الاعتداء على حق من حقوقه.

٢- وقت توافر المصلحة : يجب أن تتوافر المصلحة في حق رافع الدعوى في وقت رفعها ، وإلا حكم بعدم قبولها، وإذا كانت المصلحة شرط ابتداء، فهل تعد أيضاً شرط استمرار، بمعنى آخر هل ينبغي أن تستمر المصلحة في حق رافع دعوى الإلغاء حتى الفصل فيها ؟ .

استقر مجلس الدولة الفرنسي على الاكتفاء بقيام المصلحة وقت رفع الدعوى وعدم اشتراط استمرارها إلى وقت الفصل فيها . فإذا زالت هذه المصلحة يستمر في نظر الدعوى وإصدار حكمه؛ وذلك لأن دعوى الإلغاء توجه ضد القرار الإداري وتهدف إلى حماية المشروعية، ومن ثم يكتفى فقط بضرورة توافر المصلحة وقت رفع دعوى الإلغاء ويستمر في نظر الدعوى ولو زالت المصلحة في وقت لاحق على رفع الدعوى .

أما مجلس الدولة المصري فقد تردد في أحكامه فأخذ أحياناً بضرورة توفر المصلحة في وقت رفع دعوى الإلغاء، ولا يتطلب استمرارها حتى الفصل فيها . كما أنه في أحيان أخرى يشترط وجود المصلحة واستمرارها لحين الفصل فيها، والاتجاه الأخير هو ما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري المصري، فقد ذهبَت المحكمة الإدارية العليا في حكم لها إلى أنه : " يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يتوافر

(١) د / ماجد الحلو : القضاء الإداري، ص ٣١٩.

في رافعها شرط المصلحة ويتعين توافر هذا الشرط من وقت رفع دعوى لحين الفصل فيها " (١).

ونرى أنه يجب أن تتوافر المصلحة في وقت رفع دعوى الإلغاء، ولا اعتبار إذا زالت المصلحة فيما بعد أثناء نظر الدعوى وقبل الفصل فيها؛ وذلك تأكيداً لمبدأ المشروعية ولأن دعوى الإلغاء ذات طبيعة موضوعية تختصم في الأساس القرار الإداري غير المشروع، كما أن الحكم فيها ذو حجية مطلقة على الكافة؛ ومن ثم ينبغي على المحكمة أن تستمر في نظر الدعوى وإن زالت المصلحة الشخصية لرافعها أثناء السير فيها؛ لأنه توجد مصلحة أخرى أولى بالحماية من مصلحة رافع الدعوى تتمثل في حماية مبدأ المشروعية وهذه المصلحة تبقى ولا تزول بزوال مصلحة رافع الدعوى.

وتجدر الإشارة إلى أن سحب الإدارة للقرار محل دعوى الإلغاء أثناء السير في الدعوى ينهي الخصومة وتزول مصلحة رافع الدعوى التي كانت تتمثل في إنهاء آثار القرار محل دعوى الإلغاء، كما تزول المصلحة العامة المتمثلة في حماية مبدأ المشروعية؛ وهذا لأن آثار سحب القرار الإداري مماثل للإلغاء القضائي له من حيث إنهاء القرار الإداري وآثاره بأثر رجعي، أما إذا اكتفت الإدارة بالإلغاء الإداري فقط للقرار محل الطعن مع بقاء آثاره في الماضي، فلا تزول مصلحة رافع الدعوى في إنهاء آثار القرار غير المشروع في الماضي، كما لا تزول مصلحة الجماعة في حماية مبدأ المشروعية.

٣- طبيعة الدفع بانعدام المصلحة : توجد ثلاثة دفعات في قانون المرافعات تتمثل في الدفع الموضوعية، وهذه الدفع يمكن أن تثار في أي مرحلة عليها الدعوى، والدفع الشكلية، وهذه الدفع يجب أن تتم إثارتها قبل الدخول في الموضوع، فإذا تغاضى الأطراف عن إثارتها ابتداءً فلا يجوز لهم إثارتها بعد الدخول في الموضوع، وأخيراً الدفع بعدم القبول ولكن ما هو التكييف القانوني للدفع بانعدام المصلحة؟ أو إلى أي نوع من هذه الدفع يندرج الدفع بانعدام المصلحة ؟

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا رقم ١٩١٥ لسنة ٣١ ق، بتاريخ ١٩٨٧/٤/٤م، المجموعة السنية الثانية والثلاثون - ص ١١٨.

من المستقر عليه قضاء أن الدفع بانعدام المصلحة لا يعد من الدفوع الشكلية التي تسقط بالتحدث في الموضوع، كما أنه ليس من الدفوع الموضوعية، ولكنه دفع بعدم القبول ولا يؤثر في هذا الدفع التأخر في إيدائه إلى ما بعد مواجهة موضوع الدعوى لأنه من الدفوع التي لا تسقط بالتكلم في الموضوع ويجوز إيداءه في أية حالة تكون عليها الدعوى .

ويؤكد غالبية الفقه على أن الدفع بانتفاء المصلحة هو دفع بعدم القبول^(١)، ومن جانبنا نؤيد هذا الاتجاه، حيث إن الدفع بانتفاء المصلحة هو دفع بعدم القبول وليس دفعاً شكلياً أو موضوعياً، وهذا الرأي يتفق مع ما تنص عليه المادة ١٢ من قانون مجلس الدولة والتي تنص على أنه "لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة" وهذا يعني أن نص هذه المادة يشير إلى أن المسألة هي مسألة قبول أو عدم قبول ، فالدفع بانعدام المصلحة ليس دفعاً شكلياً لأنه لا يسقط بالدخول في الموضوع، كما أنه لا يعد دفعاً موضوعياً؛ لأن موضوع دعوى الإلغاء هو القرار الإداري، والمصلحة هي الفائدة التي تعود على رافع الدعوى من إلغائه، ومن ثم فإنه يعد دفعاً بعدم القبول، وإن كان يتشابه مع الدفع الموضوع في كونه يجوز إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى. حيث تقول المحكمة الإدارية العليا بأنه : "لما كان من الأمور المسلمة أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوفر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائياً ويجوز إيداء هذا الدفع في أية حالة كانت عليها الدعوى"^(٢) .

٤- شروط المصلحة (شخصية مباشرة) :

يجب أن تكون المصلحة في دعوى الإلغاء شخصية ومباشرة، ومعنى كون المصلحة شخصية مباشرة أن يتواجد الطاعن في حالة قانونية أثار فيها القرار المطلوب إلغاؤه تأثيراً مباشراً دون التوقف على المساس بحق من حقوقه.

(١) راجع د/ داود الباز : القضاء الإداري، دار النهضة العربية ، ٢٠١١م، ص ٢٤٥.

(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2536 لسنة 39 ق بتاريخ ١٩٩٥/١/٢٩ منشور بالمجموعة الرسمية للمكتب الفني، السنة ٤٠ ، الجزء الأول، القاعدة رقم ١٠٦ ، ص ١٠٤٣ .

وقد اضطردت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أنه يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة إلا أنه في مجال دعوى الإلغاء وحيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام فإن القضاء الإداري لا يقف في تفسير شرط المصلحة الشخصية عند ضرورة وجود حق يكون القرار الإداري المطلوب إلغاؤه قد أهدره أو مس به كما هو الحال بالنسبة لدعوى التعويض سائر الدعوى الحقوقية - وإنما يتجاوز ذلك بالقدر الذي يتفق ويسهم في تحقيق مبادئ المشروعية وإرساء مقتضيات النظام العام، بحيث يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً في مصلحة جديّة له^(١).

ولقد أكدت المحكمة الإدارية العليا ما سبق فقضت بأن "القضاء الإداري قد استقر على أنه لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعى ذا حق مسه القرار المطعون فيه بل يكفي أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية في طلب الإلغاء وذلك باعتبار أن دعوى الإلغاء هي خصومة عينية تنصب على القرار الإداري ذاته وتهدف أساساً إلى حماية الشرعية ولهذا توسع مجلس الدولة في فرنسا ومصر في هذا الشرط تحقيقاً لهذه الغاية التي هي دعامة العدل وإقامة الحق ولما كان من المسلم به أن الآثار من الأموال العامة بل ولها هذه الصفة على الدوام وكان الدستور قد نص في المادة ٣٣ منه (دستور ١٩٧١م) على أن للملكية العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن فلا شك أن من وسائل هذه الحماية الالتجاء إلى القضاء للطعن على القرارات الإدارية التي تمس هذه الأموال العامة، وبناءً عليه فمن باب أولى يكون للمطعون ضدهم باعتبارهم من المتخصصين في الآثار والمشتغلين بالأمور العامة مصلحة في طلب إلغاء القرار الصادر بالموافقة على عرض هذه الآثار في الخارج وتكون الدعوى بالتالي مقبولة شكل"^(٢) .

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2536 لسنة 39 ق بتاريخ ١٩٩٥/١/٢٩ منشور بالمجموعة الرسمية للمكتب الفني، السنة ٤٠، الجزء الأول، القاعدة رقم ١٠٦، ص ١٠٤٣ .

(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 943 لسنة 40 ق، بتاريخ ١٩٩٤/١٢/٣ منشور بالمجموعة الرسمية للمكتب الفني، السنة ٤٠، الجزء الأول، القاعدة رقم ٤٩، ص ٤٧٩ .

ومن ثم إذا لم تكن المصلحة لرافع الدعوى شخصية؛ فلا تقبل هذه الدعوى، وذلك مثل من يرفع دعوى إلغاء لقرار لم تربطه به أي صلة ولن تناله أي فائدة من إلغائه، وذلك كأن ترفع دعوى الإلغاء من قبل شخص لا تربطه بالقرار المطعون فيه أي رابطة، كطعن موظف في قرار تعيين موظف آخر لا يؤثر قرار تعيينه في المركز القانوني المقرر له.

كما أنه إذا كانت توجد مصلحة شخصية لرافع الدعوى لكنها ليست مباشرة؛ فلا تقبل دعوى الإلغاء أيضاً، وذلك كأن ترفع دعوى الإلغاء من قبل زوجة أو أبناء أو دائني من صدر قرار بفصله، فلهؤلاء مصلحة شخصية في إلغاء قرار الفصل لكي يستفيدوا فيما بعد من الأموال التي سيتقاضاها الموظف نظير عمله بعد إلغاء قرار فصله من العمل، لكن هذه المصلحة ليست مباشرة؛ ومن ثم لا تقبل دعوى الإلغاء التي يتم رفعها في مثل هذه الحالات.

ويثور التساؤل حول ما إذا رفعت الدعوى من شخص ذي مصلحة شخصية ومباشرة، ثم بعد ذلك توفى هذا الشخص أثناء نظر دعوى الإلغاء، هل يجوز لورثته الحلول محله في هذه الدعوى؟

الإجابة على هذا التساؤل تختلف باختلاف الأحوال فإذا كان القرار الذي طعن فيه المورث يتعلق بالتعيين في إحدى الوظائف العامة فإن الورثة لا يستطيعون الاستمرار فيه؛ لأنهم لا يعدون في حالة قانونية خاصة أثر فيها القرار تأثيراً مباشراً، وهذا وهو الرأي الذي أخذ به قضاء مجلس الدولة المصري عندما قضي بعدم أحقية الورثة في الحلول محل مورثهم في السير في إجراءات دعوى الإلغاء . أما إذا كانت دعوى الإلغاء متعلقة بقرار إزالة لمبنى مملوك لمورثهم مثلاً فهنا يجوز للورثة الاستمرار في دعوى إلغاء هذا القرار حيث يعدون في هذه هنا في حالة قانونية خاصة أثر فيها القرار المطعون فيه تأثيراً مباشراً؛ لأنهم حلوا محل مورثهم في هذا المنزل.

ومما سبق يمكن القول : بأن كل من له مصلحة شخصية ومباشرة يستطيع أن يرفع دعوى الإلغاء، بيد أنه قد يحدث ويتعدد أصحاب المصالح الشخصية والمباشرة

وفي هذه الحالة يجوز لهؤلاء أن يرفعوا دعوة واحدة وهو المسلك الذي سلكه مجلس الدولة المصري.

٥- أنواع المصلحة :

أ- المصلحة المادية والمصلحة الأدبية :

إذا كانت دعوى الإلغاء تتطلب لقبولها توافر شرط المصلحة المباشرة والشخصية لرافعها فهل يجب أن تكون هذه المصلحة مادية أم يمكن أن تكون أدبية كذلك؟ من الثابت أن دعوى الإلغاء تحمي المصلحة المادية كما تحمي المصلحة الأدبية؛ ومن ثم فإن القضاء الإداري يقبل الدعوى حتى توافر لرافعها مصلحة أيا كانت مادية أو معنوية والمثال الواضح للمصلحة المعنوية يتمثل في حق كل من يعتق ديناً سماوياً معنياً في أن يطلب إلغاء القرار الإداري الذي يقضي بإلغاء دور العبادة المخصصة لممارسة الدين الذي يعتنقه.

والمبدأ الذي قرره المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن هو أنه لا ضير من كون المصلحة في الدعوى مادية أو أدبية ، ولهذا قررت بأن " مناط قبول الدعوى كشرط عام - سواء في شقها المستعجل أو الموضوعي وسواء كانت دعوى من دعاوى الإلغاء أو من دعاوى القضاء الكامل - أن تتوافر مصلحة المدعى في إقامتها من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائياً - لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعى ذا حق أثر فيه القرار المطعون فيه - يكفي أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية في طلب الإلغاء بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار من شأنها أن تجعله يؤثر تأثيراً مباشراً عليه - الكلية الواحدة بجميع أقسامها تكون وحدة وذلك فيما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي - الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس في مركز قانوني خاص بالنسبة لما عساه أن يصدر من مجلس الكلية من قرارات مما يحق معه لهم أن يلتجئوا إلى هذا القضاء المختص لعرض مطاعنهم على ما قد يصدر من هذا المجلس من قرارات يرون أنها تعرض العملية التعليمية أو البحث العلمي بصفة عامة لأضرار قد تنتهي بالإساءة إلى سمعة الجامعة كلها أو كلية من كلياتها مصلحتهم في هذا الشأن وإن كانت أدبية إلا أنها

قائمة وحالة" (١).

ب- المصلحة المحققة والمصلحة المحتملة : قد تكون المصلحة في الدعوى القضائية بصفة عامة محققة وقد تكون محتملة، ومما لا شك فيه أن دعوي الإلغاء تحمي المصلحة المحققة سواء أكانت مادية أو أدبية، ولكن يثور التساؤل حول مدى جواز الاكتفاء بالمصلحة المحتملة لقبول دعوى الإلغاء من عدمه؟

يشترط القضاء العادي ضرورة أن يكون لرافع الدعوى مصلحة حاله حتى تقبل دعوى ولا يكفي لقبولها أن تكون المصلحة التي تعود عليه مصلحة محتملة، بيد أنه توجد بعض الحالات التي أجاز فيها المشرع قبول الدعوى لحماية مصلحة محتملة وهي محددة علي سبيل الحصر، ولقد توسع القضاء العادي في تفسير الاستثناء الوارد في المادة ٣ من قانون المرافعات التي تنص علي أن لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لرافع الدعوى فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطالب الاحتياط لدفع ضرر محقق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

ولقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا أيضاً على جواز الاكتفاء بالمصلحة المحتملة للمدعي لقبول دعواه(٢) .

ومن ثم قضت في حكمها الصادر في ١٥ أبريل ١٩٩٣ بأنه : "ومن حيث أن المادة (١٢) من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ تنص على أن لا تقبل الطلبات الآتية: أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ب)..... ولما كانت الدعوى هي الوسيلة القانونية التي يلجأ بمقتضاها صاحب الشأن إلى السلطة القضائية أي إلى المحاكم لحماية حقه وأنه يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة قانونية في أقامتها بأن يكون موضوع الدعوى هو المطالبة بحق أو بمركز قانوني أو التعويض عن ضرر أصاب حقا من الحقوق وأن تكون المصلحة

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٢١٢٥ لسنة ٣٦ ق، بتاريخ ١٩٩٢/١/٢٥ م منشور بالمجموعة الرسمية للمكتب الفني، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا الجزء الثاني القاعدة رقم ٦٣ ص ٦٠٧.

(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 16834 و ١٨٩٧١ لسنة ٥٢ ق، بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/١٦ منشور بالمجموعة الرسمية للمكتب الفني، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى - الجزء الأول من أول أكتوبر ٢٠٠٦ إلى إبريل ٢٠٠٧ القاعدة رقم ٢٥ ص ٢١٣.

شخصية ومباشرة وقائمة وحالة بحسبان المصلحة هي فائدة عملية تعود على رافع الدعوى، فإنه أن يمس القرار المطلوب إلغاؤه حقاً ثابتاً للمدعى على سبيل الاستثناء والافراد، وإنما يكفي أن يكون المدعى في حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً تأثيراً في مصلحة شخصية له ولو شاركه فيها غيره، فقد أجاز المشرع على سبيل الاستثناء قبول بعض الدعاوى دون أن يكون رافعها هو صاحب الحق المعتدى عليه إذ يكفي بالمصلحة المحتملة أو لإثبات وقائع ليحتج بها في نزاع في المستقبل والمصلحة على هذا النحو هي التي تجعل للمدعى صفة في رفع الدعوى" (١).

ويتبين من اتجاه المحكمة الإدارية العليا في هذا الصدد، أن القضاء الإداري قرر وجوب أن تكون المصلحة قائمة لإقامة الدعوى بحسب الأصل، لكن من جهة أخرى اعترف استثناءً بالمصلحة المحتملة للمدعي في المستقبل، كما اعترف أيضاً له برفع دعوى لإثبات وقائع في للاحتجاج بها في نزاع مستقبلي.

ثانياً : الصفة : الصفة هي الصلاحية للترافع أمام القضاء كطرف في الدعوى. ويذهب رأى في الفقه إلى أن شرط الصفة يندمج مع شرط المصلحة؛ ومن ثم من تتوافر فيه المصلحة المباشرة لرفع الدعوى، تتوافر فيه الصفة في رفعها بالتبعية (٢). واستقر القضاء الإداري في مصر على اندماج شرط الصفة في المصلحة، فقضت المحكمة الإدارية العليا بأن "قيام شرط المصلحة يعني توافر الصفة في رافع الدعوى حيث يندمج الشرطان في دعوى الإلغاء" (٣).

ونرى مع البعض (٤) أن المصلحة والصفة شرطان منفصلان، فالمصلحة هي الفائدة التي تعود على المدعي من رفعه لدعواه، بينما الصفة فهي مكنة يخول القانون

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٣٤٧ لسنة ٣٩ ق، بتاريخ ١٥/٨/١٩٩٣ منشور بالمجموعة الرسمية للمكتب الفني، السنة ٣٨، الجزء الثاني، القاعدة رقم ١٦٥، ص ١٦٣٢.

(٢) راجع د/ محمد أنس قاسم جعفر : الوسيط في القانون العام - القضاء الإداري - ط ١٩٩٥، بدون دار نشر، ص ٣٣٠؛ وراجع المستشار : محمد عبد الغني حسن : قواعد وإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، بدون دار أو سنة نشر، ص ٢١٦.

(٣) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٣٤٦ لسنة ٣٥ ق، بتاريخ ١٣/١٢/١٩٩٢م، الموسوعة الإدارية الحديث، ج ٢٣، ص ١٥٧.

(٤) راجع د/ إبراهيم محمد علي : القضاء الإداري (قضاء الإلغاء) دار النهضة العربية، بدون سنة نشر، ص ٣٧٠؛ وأستاذنا الدكتور/ فؤاد محمد النادي : القضاء الإداري، مطابع الدار الهندسية، ٢٠١٣م، ص ٣٦٠.

بمقتضاها سلطة مباشرة الدعوى؛ ومن ثم فقد يكون صاحب المصلحة شخص، ومن يخول له القانون سلطة مباشرة الدعوى شخص آخر، وذلك مثل الولي والوصي فلهم الصفة في مباشرة الدعوى لصالح من يتولون أمرهم، على الرغم من أن المصلحة وهي الفائدة من رفع الدعوى في هذه الحالة ستعود على غيرهم ممن يتولون أمرهم .
وبناءً على ما تقدم : فإن الصفة في دعوى الإلغاء تتوافر في الحالات التالية :

الحالة الأولى : دعاوى الإلغاء التي يرفعها من له مصلحة من الأفراد ضد القرارات الإدارية بصفتهم الأصلية، وذلك كرفع مالك العقار دعوى إلغاء ضد القرار الصادر من الإدارة بنزع ملكية هذا العقار، وكرفع دعوى الإلغاء من الموظف العام بإلغاء القرار الصادر بفصله من الوظيفة العامة، ورفع أحد الأفراد من المستفيدين من المرافق العامة دعوى إلغاء ضد قرار إداري يمس مصلحة شخصية له باعتباره من المستفيدين من المرفق العام مصدر القرار غير المشروع، وصفة المنتمي لأحد الأديان للطعن في القرار الذي يتعلق بالدين الذي ينتمي إليه.

الحالة الثانية : دعاوى الإلغاء التي يقوم برفعها الممثل القانوني لمن له مصلحة في إلغاء القرار الإداري، وذلك مثل دعاوى الإلغاء التي يقوم برفعها الولي أو الوصي أو الوكيل بالخصومة ضد القرارات الإدارية التي تمس مصلحة من يقومون بتمثيلهم قانوناً.

الحالة الثالثة : دعاوى الإلغاء التي ترفع من الهيئات التي تتمتع بالشخصية المعنوية ضد القرارات الإدارية غير المشروعة، وفي هذا الصدد نفرق بين فئتين من هذه الأشخاص المعنوية :

الفئة الأولى : الهيئات ذات الشخصية المعنوية، مثل النقابات المهنية، فتتوافر في حقها الصفة في دعوى الإلغاء ضد القرارات التي تمس أهدافها أو المصالح المشتركة لأعضائها، وكذلك القرارات التي تمس مصلحة عضو أو أعضاء معينين بذاتهم من أعضائها.

الفئة الثانية : الأشخاص العامة ، مثل الوزارات والمحافظات، وهذه الأشخاص ليس لها أن ترفع دعوى الإلغاء فيما بينها، ولكن تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المنازعات التي تنشأ بين هذه الأشخاص،

وما تنتهي إليه الجمعية في هذا الصدد يكون ملزماً للأشخاص المعنوية العامة المتنازعة، أما بخصوص الدعاوى التي ترفع عليها من الأفراد فتتوافر صفة المدعى عليه في الممثل القانوني لهذه الأشخاص.

وبناءً على ما تقدم: تتوافر الصفة بخصوص الأفراد بصفتهم مدعين في دعوى الإلغاء بصفتهم الأصلية أو من يمثلهم قانوناً، كما تتوافر الصفة في الإدارة مصدرة القرار محل دعوى الإلغاء في مباشرة الدعوى باعتبارها مدعى عليها، وذلك من خلال ممثلها القانوني، فالطعن في القرار الصادر من وزارة الصحة، يكون المدعى عليه الممثل القانوني لوزارة الصحة وهو وزير الصحة، والقرار الصادر من الجامعة ترفع دعوى الإلغاء بشأنه على الممثل القانوني لها وهو رئيس الجامعة.

وتجدر الإشارة إلى أن المحامي الذي يوقع على صحيفة دعوى الإلغاء قد يكون نائباً عن صاحب المصلحة والصفة في مباشرة الدعوى بتوكيل منه، وقد يقتصر دوره مجرد التوقيع على صحيفة الدعوى كشرط لصحة رفع دعوى الإلغاء، ويقوم بمباشرتها صاحب المصلحة والصفة في دعوى الإلغاء.

كما تجدر الإشارة إلى أن هيئة قضايا الدولة ومحامي الإدارات القانونية هم من يقومون بتمثيل الجهات الإدارية أمام القضاء، ومن ثم هم من يقومون بمباشرة دعوى الإلغاء نيابة عن الممثل القانوني للجهة الإدارية أمام القضاء.

شرط الصفة من النظام العام : استلزام اشتراط الصفة في الدعاوى بصفة عامة ودعوى الإلغاء بصفة خاصة يعد من النظام العام؛ ومن ثم فإن "الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لا يحتاج إلى دفع به - وأساس ذلك : أن المحكمة وهي تنزل حكم القانون على الدعوى تقضي بذلك من تلقاء نفسها" (١) .

كما يجوز إثارة الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة أو من غير ذي صفة في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، ويجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به الخصوم.

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٣٢٦ لسنة ٣٣ ق، بتاريخ ١٩٩٥/١/٢٤م، منشور بالمجموعة الرسمية للمكتب الفني، السنة ٤٠، الجزء الأول، قاعدة رقم (٩٩٣)، ص ١٠٢ .

ومن ثم قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه : "ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى والطعن في الحكم الصادر فيها لرفعها على غير ذي صفة فإن صاحب الصفة هو من يختص وفقا لأحكام القانون بتمثيل الشخص الاعتباري والتحدث باسمه ، لأن الأصل في الاختصاص في الدعوى الإدارية أن توجه الدعوى ضد الجهة الإدارية التي أصدرت القرار فهي أدري الناس بمضمونه وأعرفهم بالأسباب التي أدت إليه . والصفة في تمثيل الجهة الإدارية أمر مستقل عن الشخص الذي تسلم إليه صور الإعلانات وفقا لحكم المادة ١٤ من قانون المرافعات ، ومستقل أيضا عن نيابة إدارة قضايا الحكومة عن الجهات الإدارية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا وطعون . فلا يكفي لصحة الأجراء أن تباشره إدارة قضايا الحكومة بل يتعين لصحته أن تكون مباشرته باسم صاحب الصفة وهو الوزير بالنسبة إلى شئون وزارته . والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة من النظام العام الذي يجوز لصاحب الشأن أن يثيره في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، كما يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء ذاتها ولو لم يكن ثمة دفع من المدعى عليه أو من هيئة مفوضى الدولة" (١) .

الوقت المعتبر في توافر الصفة : الأصل أن تتوافر الصفة في حق كل من المدعي والمدعي عليه وقت رفع الدعوى، إلا أنه بخصوص المدعى عليه، فإنه إذا رفع المدعي دعواه على غير ذي صفة، ثم قام بتوجيه الدعوى إلى صاحب الصفة؛ فيصح بذلك شكل الدعوى وتكون قد وجهت إلى ذي الصفة؛ ومن ثم تقبل الدعوى. ومن جهة أخرى، إذا تم رفع الدعوى على غير ذي صفة، ثم حضر صاحب الصفة في الدعوى وقدم دفاعاً فيها، فإن ذلك يصح شكل الدعوى أيضاً؛ ومن ثم تقبل الدعوى.

وتجدر الإشارة إلى أن الدعوى إذا رفعت على غير ذي صفة يجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى لإعلان ذي الصفة، وتؤجل المحكمة أيضاً الدعوى لإعلان ذي الصفة في حالة ما إذا رفعت الدعوى على ذي الصفة ثم انتقلت تبعية الوحدة الإدارية التي يعمل بها الطاعن لجهة أخرى.

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٢٢٦٨ لسنة ٢٩ ق، بتاريخ ١٢/٣/١٩٨٨م.

وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا "ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية ينص في المادة (١١٥) منه على أن "الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إيدأؤه في أية حالة تكون عليها . وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس اجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ، ويجوز لها في هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات.

ومن حيث أن انتقال تبعية الوحدة التى يعمل بها الطاعن من جهة إلى أخرى خلال أجل نظر المحكمة للطعن التأديبى يقتضى أن يختصم الطاعن الجهة ذات الصفة سواء تم الدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء صفة المطعون ضده أو لم يتم إيداء الدفع بذلك ويكون على المحكمة تنبيه الطاعن ومنحه الأجل اللازم لاختصام ذى الصفة ، فإن استجاب لذلك واختصم الجهة ذات الصفة صح طعنه من تلك الزاوية، وإلا قضت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة.

ومن حيث أنه إذا تم انتقال تبعية الوحدة التى يعمل بها الطاعن من جهة إلى أخرى وقامت المحكمة بتنبيه الطاعن ومنحه الأجل اللازم لاختصام ذى الصفة ، ثم طرأ انتقال تبعية الوحدة التى يعمل بها الطاعن مرة أخرى من الجهة الجديدة إلى جهة ثالثة؛ فإنه يكون على المحكمة أن تنبه الطاعن من جديد إلى وجوب اختصام الجهة ذات الصفة وتمنحه أجلا لإعلان ذى الصفة، فإن استجاب لذلك وأختصم الجهة ذات الصفة صح طعنه من تلك الزاوية؛ وإلا قضت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة.

وعلى ذلك فإنه إذا تم انتقال الوحدة التى يعمل بها الطاعن من جهة إلى أخرى وقامت المحكمة بتنبيه الطاعن ومد الأجل اللازم لاختصام ذى الصفة، ثم طرأ انتقال تبعية الوحدة التى يعمل بها الطاعن مرة أخرى من الجهة الجديدة إلى جهة ثالثة فلم تقم المحكمة بتنبيه الطاعن من جديد إلى وجوب اختصام الجهة ذات الصفة وتمنحه أجلا لإعلان ذى الصفة ورغم ذلك انتهت إلى القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى الصفة ، فإنها تكون بذلك قد أخطأت في تطبيق حكم القانون الذى يوجب عليها في هذه الحالة أن تنبه الطاعن مرة ثانية إلى وجوب اختصام صاحب الصفة

الجديدة وتؤجل نظر الطعن لتنفيذ ذلك حتى إذا تقاعس عن اختصام صاحب الصفة الجديدة، كان لها أن تقضى بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة. ومن حيث أنه تطبيقاً لما تقدم فإنه لما كانت تبعية منطقة صان الحجر التى يعمل بها الطاعنون قد انتقلت إلى وزارة المالية (جهاز شئون الشركات) ثم إلى محافظة الشرقية ، وقد ثبت ذلك فى محضر الجلسة من خلال ما دفع به محامى الحكومة فقد كان يجب على المحكمة أن تؤجل نظر الطعون وأن تطلب إلى الطاعنين إعلان الجهة الجديدة ذات الصفة وهى محافظة الشرقية، أما وقد أغفلت المحكمة هذا الإجراء اللازم فإنها تكون قد خالفت حكم القانون ويكون حكمها المطعون فيه واجب الإلغاء وتأخذ هذه المحكمة بإعادة هذه الطعون الأربعة إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. " (١).

المبحث الثالث

الشروط المتعلقة بميعاد دعوى بالإلغاء

يقصد بميعاد دعوى الإلغاء : المدة التى يجب على ذوى الشأن رفع دعوى الإلغاء خلالها، بحيث إذا رفعت خلال هذه المدة فتعد مقبولة شكلاً، وإن لم ترفع خلالها فتكون غير مقبولة شكلاً.

وسنتناول ميعاد دعوى الإلغاء من خلال المطالب التالية :

١- ميعاد دعوى الإلغاء وبدء سريانه.

٢- تجاوز ميعاد دعوى الإلغاء.

٣- أثر انتهاء ميعاد دعوى بالإلغاء.

المطلب الأول

ميعاد إقامة دعوى الإلغاء وبدء سريانه

تنص. المادة ٢٤ من قانون مجلس الدولة على أن : "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة- فيما يتعلق بطلبات الإلغاء- ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم ١١١٦ لسنة ٢٩ ق، بتاريخ ١٩٨٨/١/٣٠م، المجموعة، س ٣٣، الجزء الأول، قاعدة رقم (١١٨) ص ٧٥٩.

المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به".

ومن ثم يجب أن ترفع دعوى الإلغاء في خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ القرار الإداري المطعون فيه، ويختلف نفاذ القرارات الإدارية بتنوعها إلى قرارات تنظيمية وأخرى فردية.

فالقرارات التنظيمية تنفذ في حق المخاطبين بها من تاريخ علمهم بها، ويتحقق هذا العلم عن طريق النشر في الجريدة الرسمية أو اللوحات المخصصة للإعلانات في المصالح الإدارية، كما يتحقق العلم أيضاً بعلم ذوى الشأن بالقرار التنظيمي علماً يقينياً.

أما بخصوص القرارات الإدارية الفردية، فتتخذ في حق المخاطبين بها من تاريخ علمهم بها بطريق إعلانهم أو علمهم بها علماً يقينياً أيضاً.

وبناءً على ما تقدم : يبدأ ميعاد دعوى الإلغاء (الستون يوماً) من تاريخ علم ذوى الشأن بالقرار الإداري محل الدعوى، فيبدأ من تاريخ النشر بالنسبة للقرارات الإدارية التنظيمية، ويبدأ من تاريخ الإعلان بالنسبة للقرارات الإدارية الفردية، كما يبدأ من تاريخ العلم اليقيني سواء بالنسبة للقرارات التنظيمية أو الفردية.

ويقع عبء إثبات العلم بالقرار الإداري الذي تبدأ من تاريخه مدة الستين يوماً على عاتق رافع دعوى الإلغاء والذي صدر القرار الإداري في مواجهته.

وتجدر الإشارة إلى أن ميعاد الطعن بالإلغاء في فرنسا يختلف عن ميعاد الطعن في مصر، حيث إن ميعاد الطعن في فرنسا شهرين من تاريخ العلم بالقرار الإداري، أما في مصر فالميعاد هو ستون يوماً كما قررنا.

المطلب الثاني

تجاوز ميعاد دعوى الإلغاء

إذا كان على ذوى الشأن أن يقوموا برفع دعوى الإلغاء خلال ستين يوماً من تاريخ علمهم بالقرار الإداري، إلا أنه توجد بعض العوارض التي يتم تجاوز ميعاد دعوى الإلغاء بصدها لأكثر من ستين يوماً، وتتمثل هذه العوارض فيما يلي :

- ١- امتداد الميعاد.
- ٢- وقف الميعاد.
- ٣- انقطاع الميعاد.
- ٤- انفتاح الميعاد.
- ٥- دوام الميعاد.

أولاً : امتداد ميعاد دعوى الإلغاء : يمتد ميعاد دعوى الإلغاء إذا في حالتين :
الأولى: أيام العطلات الرسمية: إذا صادف آخر مدة الستين يوماً عطلة رسمية، فيمتد ميعاد دعوى الإلغاء إلى أول يوم عمل بعدها، وهنا لا يمتد الميعاد إلا ليوم واحد فقط
الثانية : مواعيد المسافة : يمتد ميعاد دعوى الإلغاء أيضاً بخصوص مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات، ومواعيد المسافة تتمثل فيما يلي :

أ- يوم لكل خمسين كيلو متر بحد أقصى أربعة أيام.

ب- خمسة عشر يوماً لقاطني المناطق الحدودية.

ت- ستون يوماً لمن يكون موطنه خارج البلاد.

وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا على امتداد الميعاد والحكمة منه وذلك بإضافة مواعيد المسافة، فقررت بأن : "ميعاد المسافة مقرر لتمكين ذوي الشأن من الحضور أو مباشرة الإجراءات القانونية بمنحهم فسحة من الوقت تجاوز الميعاد المقرر لسائر الأفراد تتمثل في ميعاد مسافة يضاف إلى المواعيد المقررة أصلاً - علة ذلك : تواجدهم بعيداً عن الجهة التي يتعين الحضور إليها أو مباشرة الإجراء فيها، يؤكد ذلك تدرج المشرع في منح هذا الميعاد بزيادته كلما بعدت المسافة بين موطن الفرد والمكان المتعين الحضور إليه".

ثانياً : وقف ميعاد دعوى الإلغاء : يقصد بوقف ميعاد دعوى الإلغاء عدم سريان مدة الطعن بالإلغاء بعد بدئها بصفة مؤقتة إلى أن يزول سبب الوقف فيسري ما بقي من المدة استكمالاً لها.

فعند تحقق سبب من أسباب وقف الميعاد يتوقف سريان مدة الستين يوماً لفترة من الزمن ، ثم يستكمل حساب هذه المدة من جديد عند زوال هذا السبب.

وتتمثل أسباب وقف ميعاد دعوى الإلغاء في سببين :

الأول:القوة القاهرة: تؤدي القوة القاهرة التي تحول بين من يريد الطعن بالإلغاء وبين قيامه بإجراءات رفع دعواه أمام القضاء الإداري إلى وقف ميعاد دعوى الإلغاء، بحيث إذا زال سبب القوة القاهرة يتم استكمال ما تبقى من حساب مدة الطعن بالإلغاء ويدخل في نطاق القوة القاهرة مرض طالب الإلغاء مرضاً يحول دون اتخاذ إجراءات رفع الدعوى، أو اعتقاله، أو حدوث ثورات أو انقلابات أو كوارث طبيعية

تحول دون اتخاذ هذه الإجراءات؛ ومن ثم إذا زال سبب القوة القاهرة هنا فتستكمل بالتبعية مدة الستون يوماً.

ولا يعد مرض المحامي وكيل الطاعن من قبيل القوة القاهرة التي توقف ميعاد الطعن بالإلغاء، وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بأن : المرض المفاجيء لو كبل الطاعنين لا يعتبر من قبيل الأعذار القهرية التي توقف سريان ميعاد الطعن - أساس ذلك - أنه في مقدور الطاعنين إسناد مهمة إيداع تقرير الطعن إلى محام آخر ، حيث إن مرض المحامي على فرض صحته لا يتعلق بالطاعنين أنفسهم وهم ذوي الشأن في الطعن؛ ومن ثم لا يترتب على ذلك وقف الميعاد أو امتداده.

الثاني : نص القانون : إذا نص القانون على وقف ميعاد دعوى الإلغاء لحين اتخاذ إجراء معين قبل رفع دعوى الإلغاء، فإن هذا الإجراء يوقف سريان مدة الطعن بالإلغاء لحين تمام هذا الإجراء، وذلك مثلما نص القانون الصادر سنة ٢٠٠٠ بخصوص ضرورة اللجوء إلى لجنة فض المنازعات قبل رفع دعوى الإلغاء، حيث إن طلب التوفيق يوقف سريان ميعاد دعوى الإلغاء بشرط تقديمه في ميعاد الطعن في القرار الإداري.

ثالثاً : انقطاع مدة الطعن بالإلغاء : يقصد بانقطاع مدة الطعن بالإلغاء عدم الاعتداد بالمدة التي انقضت من الميعاد لقيام صاحب الصفة والمصلحة من إلغاء القرار الإداري بإجراء يؤكد حرصه على إلغائه؛ ومن ثم يسري ميعاد من تاريخ زوال سبب الانقطاع.

وتتمثل حالات انقطاع ميعاد دعوى الإلغاء فيما يلي :

١- التظلم الإداري.

٢- طلب الإعفاء من الرسوم.

٣- رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة.

الحالة الأولى : التظلم الإداري : تنص المادة ٢٤ من قانون مجلس الدولة على أنه : "وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من

تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالفرض وجب أن مسبباً ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم، دون أن تجب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكور".

فالتظلم الإداري يعد إجراءً يقدمه من يريد الطعن في القرار الإداري بالإلغاء إلى الإدارة يبدي فيه تمسكه بحقه في إلغاء هذا القرار خلال مدة معينة. والتظلم الإداري إنما قرر لتخفيف العبء على القضاء لاحتمال أن تراجع الإدارة نفسها فيما أصدرته من قرارات غير مشروعة أو غير ملائمة؛ ومن ثم تقوم بتصحيح موقفها بسحب مثل هذه القرارات أو إلغاؤها أو استبدالها بغيرها.

وسوف نتناول التظلم الإداري كسبب من أسباب انقطاع ميعاد الطعن بالإلغاء

في النقاط التالية :

- أ- أنواع التظلم الإداري.
 - ب- مدى اعتبار اعتراض جهة إدارية أخرى تظلاً إدارياً.
 - ت- شروط التظلم الإداري.
 - ث- آثار التظلم الإداري.
- المسألة الأولى : أنواع التظلم الإداري :** يتنوع التظلم الإداري بحسب الزاوية التي ينظر إليه منها إلى نوعين، فبحسب الجهة التي يقدم إليها التظلم، فيتنوع إلى تظلم ولائي آخر رئاسي، ومن حيث مدى إلزاميته، فيتنوع إلى تظلم وجوبي وآخر جوازي، وبيان ذلك على النحو التالي :

النوع الأول : التظلم الولائي والتظلم الرئاسي : التظلم الولائي هو ذلك التظلم الذي يقدمه ذوي الشأن يبدي فيه اعتراضه على القرار الإداري إلى مصدر هذا القرار ذاته.

أما التظلم الرئاسي فهو الذي يبدي فيه صاحب الشأن اعتراضه على القرار الإداري إلى الجهات الرئاسية التابع لها مصدر القرار المتظلم منه. وفي كل من النوعين ينتج التظلم أثره بخصوص قطع ميعاد دعوى الإلغاء.

النوع الثاني : التظلم الوجوبي والتظلم الجوازي : قد يكون التظلم وجوبياً،

وذلك إذا تطلب القانون ضرورة إجراء التظلم من القرار الإداري قبل رفع دعوى الإلغاء، كما قد يكون جوازياً إذا لم يتطلب القانون ضرورة إجرائه، وفي كل منتج التظلم الإداري أثر من حيث قطع ميعاد دعوى الإلغاء.

أولاً التظلم الوجوبي : التظلم الوجوبي نص عليه قانون مجلس الدولة المصري

رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢م في المادة ١٢ فقرة ب منه ، حيث نصت هذه المادة على أن لا تقبل " الطلبات المقدمة رأساً بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها فى البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة ١٠ وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ، وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة".

وطبقاً لنص المادة السابقة فإن القرارات التى لا يجوز الطعن فيها بالإلغاء إلا إذا

تم التظلم منها قبل اللجوء إلى القضاء هى كالتالى :

١- القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقيّة أو منح

العلاوات (البند ثالثاً من المادة العاشرة).

٢- القرارات الإدارية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو

الاستبعاد أو فصلهم بغير الطريق التأديبي (البند رابعاً من المادة العاشرة).

٣- القرارات النهائية للسلطات التأديبية (البند تاسعاً من المادة العاشرة).

والتظلم الوجوبي لا يمنع ذوي الشأن من إقامة دعوى الإلغاء قبل البت فى

التظلم، بل يجوز لهم إقامة دعوى الإلغاء وكل ما هنالك أنه لا يجوز الحكم فى هذه

الدعوى قبل فوات ميعاد الستين يوماً المقرر للبت فى التظلم من قبل الإدارة أو رد

الإدارة رداً إيجابياً قبل فوات مدة التظلم؛ ومن ثم إذا أجابت الإدارة المتظلم رافع

دعوى الإلغاء إلى طلباته قبل انقضاء مدة الستين يوماً المقرر للتظلم الوجوبي؛

فإنها تحكم بانتهاء المنازعة لتحقيق طلبات المدعي. أما إذا انقضت مدة الستين يوماً

المقرر للتظلم الوجوبي دون أن تستجيب الإدارة للمدعى فى طلباته، فلا يقبل الدفع

بعدم قبول الدعوى لمجرد أنها أقيمت قبل انقضاء مدة الستين يوماً على تقديم التظلم.

أما إذا لم يقدم المدعي من الأساس التظلم إلي الجهة الإدارية في الحالات السابقة، ورفع دعواه بإلغاء القرار الإداري؛ فإن القاضي يحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم في القرار الإداري محل الطعن.

ويجب أن يشتمل التظلم الوجوبي على موضوع القرار المتظلم منه وتاريخ صدوره وإعلانه أو نشره، وكذلك اسم وعنوان المتظلم من هذا القرار.

ثانياً التظلم الجوازي : فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البنود أرقام (ثالثاً ورابعاً وتاسعاً) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة، فإنه لا إلزام على من يريد الطعن في القرار الإداري بإلغاء أن يتظلم من هذا القرار للإدارة قبل اللجوء إلى القضاء، فيستوى في غير تلك الحالات أن يتظلم المدعي بداءة للإدارة من القرار الإداري من عدمه، لكنه إذا تظلم فينتج التظلم أثره في انقطاع مدة الطعن بالإلغاء.

المسألة الثانية : مدى اعتبار اعتراض جهة إدارية أخرى تظلاً إدارياً :

إذا كان الأصل أن من يقوم بتقديم التظلم من القرار الإداري هو الشخص الذي يريد اختصام هذا القرار، إلا أنه من الممكن أن تعترض جهة إدارية أخرى على القرار الإداري، وهذا الاعتراض يعد بمثابة التظلم الإداري من هذا القرار؛ ومن ثم قرر القضاء الإداري بأن اعتراض جهة إدارية على القرار الإداري له ذات آثار التظلم الإداري من حيث قطعه لمدة الطعن بالإلغاء، بشرط الالتزام بالقواعد المقررة للتظلم الإداري وخاصة من حيث تقديم هذا الاعتراض في الميعاد والبت فيه أيضاً في المواعيد المقررة للبت في التظلم.

المسألة الثالثة: شروط التظلم الإداري: لكي ينتج التظلم الإداري أثره من

حيث قطعه لميعاد دعوى الإلغاء، فيجب أن تتوافر عدة شروط تتمثل فيما يلي :

١- أن يقدم التظلم ممن يمسه القرار الإداري بأن يكون ذا صفة ومصلحة أو ممن ينوب عنه قانوناً.

٢- أن يقدم التظلم بعد صدور القرار الإداري، ومن ثم فإن التظلم المقدم قبل هذا الصدور فلا أثر له.

٣- يجب أن يقدم التظلم الإداري في الميعاد، وميعاد التظلم هو ستون يوماً من تاريخ العلم بالقرار الإداري كقاعدة عامة، أي ينبغي أن يقدم التظلم في ميعاد الطعن بالإلغاء

ويستثنى من ذلك ما نصت عليه القوانين الخاصة من مواعيد أخرى للتظلم فيجب الالتزام بها، ومن ذلك ما نص عليه قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢م في مادته رقم (٣٢) من أنه "يكون التظلم من القرارات السابقة وفقاً لأحكام المواد السابقة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به. ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها طبقاً للفقرة السابقة".

٤- يجب أن يكون التظلم الإداري قاطعاً في معناه موضحاً ما يريده المتظلم^(١). ومن ثم ينبغي أن يتضمن التظلم تمسك ذوى الشأن بمخاصمة القرار الإداري محل التظلم لا مجرد عبارات إنشائية.

٥- ويجب أخيراً أن يكون التظلم ذا جدوى، بمعنى أن يكون بوسع الإدارة مراجعته، فإذا لم يكن بوسعها مراجعته فلا يكون ذا جدوى، وذلك مثل القرار الصادر بإزالة مبنى وتم تنفيذ قرار الإزالة بالفعل، فإن التظلم ف هذه الحالة يكون غير مجد لعدم إمكانية إعادة النظر فيه مرة أخرى لاستحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه.

• **عبء إثبات التظلم :** يقع عبء إثبات التظلم على رافع دعوى الإلغاء، ومن ثم إذا لم يستطع إثبات حصول التظلم فيحكم القاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم فيها وذلك في حالة التظلم الوجوبي، غير أنه من الممكن ألا يكون للتظلم أصل في أوراق الدعوى ويستدل عليه ببعض القرائن كإرسال المدعي التظلم للإدارة ب خطاب مسجل في الميعاد كما هو مستقر عليه في أحكام القضاء الإداري.

المسألة الرابعة : آثار التظلم الإداري : إذا تقدم ذوى الشأن بالتظلم الإداري للإدارة فإما أن يكون مستوفياً لشروطه أو لا.

فإذا لم يكن مستوفياً لشروطه فلا يعتد به كتظلم ينتج أثره في قطع ميعاد دعوى الإلغاء.

أما إذا كان مستوفياً لشروطه فيعتد به من حيث قطع ميعاد دعوى الإلغاء، ولا يخلو الأمر فهذه الحالة من الفروض التالية :

(١) راجع أستاذنا الدكتور / فؤاد النادي : القضاء الإداري، مرجع سابق، ص ٤١٠.

الفرض الأول : أن ترد الإدارة على المتظلم صراحة في ميعاد السنتين يوم المقررين لها أن ترد عليه في خلالها، وفي هذا الفرض إما أن ترد برفض التظلم أو إجابة المتظلم إلى طلبه.

فإذا قامت الإدارة برفض التظلم في ميعاد السنتين يوم، فيحق للمتظلم أن يقوم بالطعن على القرار الإداري المتظلم منه أمام القضاء الإداري عن طريق دعوى الإلغاء وفي خلال سنتين يوماً من تاريخ رد الإدارة بالرفض.

أما إذا قامت الإدارة بإجابة المتظلم إلى طلبه، فإن دعوى الإلغاء في هذه الحالة لا محل لها إذا لم ترفع بعد، أما إذا رفعت فيحكم القاضي بانتهاء الدعوى.

الفرض الثاني : أن تلتزم الإدارة الصمت حتى تنتهي مدة السنتين يوم ، وفي هذا الفرض يعتبر عدم الرد بمثابة رفض للتظلم، وللمتظلم أن يقوم برفع دعواه خلا سنتين يوماً تبدأ من انتهاء السنتين يوماً المقررة للإدارة أن ترد خلالها على التظلم.

غير أنه من الممكن - كما قرر القضاء الإداري - أن تقوم الإدارة بالرد على المتظلم بعد مدة السنتين يوم المقررة للإدارة الرد خلالها ويعتد بذلك لقطع مدة الطعن بالإلغاء، وذلك إذا أثبت المدعي أن الإدارة كانت في سبيلها للتصالح معه حين تظلم إليها، أو كانت الإدارة قد استجابت للمتظلم واتخذت إجراءات إيجابية نحو الاستجابة لطلبه، وأن المكاتبات لا تزال دائرة بين الجهات المختصة في سبيل الاستجابة للتظلم؛ ومن ثم لا محل في مثل هذه الحالات لافتراض رفض الإدارة للتظلم بمجرد مرور سنتين يوماً من تاريخ تقديم التظلم، وتكون العبرة بالرد النهائي على التظلم برفضه، فمن هذا التاريخ تبدأ مدة الطعن بالإلغاء.

وإذا تعددت التظلمات، فالعبرة في قطع ميعاد دعوى الإلغاء بالتظلم الأول، ولا يعتد بالتظلمات التالية له في قطع الميعاد، غير أنه من الممكن أن تفحص الإدارة هذه التظلمات وتجيب المتظلم لطلبه.

ومن ثم قضت المحكمة الإدارية العليا بأن : " التظلم الذي يعتد به في قطع الميعاد المقرر لرفع دعوى إلغاء القرار الإداري هو التظلم الأول الذي يقدم في الميعاد القانوني إلى الجهة الإدارية المختصة، وأنه لا يجدي قي قطع ميعاد الطعن أو امتداده الاسترسال في تقديم تظلمات متكررة عن ذات الموضوع، باعتبار أنه ليس

لذوي الشأن أن يتخذوا من تكرار التظلمات وسيلة لإطالة ميعاد رفع الدعوى إهدارا للاستقرار الواجب للمراكز القانونية التي يربتها القرار محل التظلم^(١).

الحالة الثانية : طلب الإعفاء من الرسوم : الحالة الثانية من حالات انقطاع ميعاد دعوى الإلغاء هي طلب المدعي في دعوى الإلغاء إعفائه من الرسوم القضائية. فغير القادر على دفع رسوم الدعوى لا يحرم من حقه في التقاضي، بل قرر له القانون مكنة تقديم طلب الإعفاء من الرسوم، ويفصل في طلب الإعفاء مفوض الدولة بالمحكمة المختصة بالنزاع .

ويقرر المفوض إجابة الطلب إذا كانت الدعوى المراد رفعها محتملة الكسب من وجهة نظره، وكان الطالب معسراً لدرجة لا تمكنه من دفع الرسوم وتوكيل محام^(٢). وطلب الإعفاء من الرسوم يجب أن يقدم في خلال مدة الطعن القضائي لينتج أثره في قطع الميعاد، حيث تبدأ مدة سنتين يوم جديدة من تاريخ الرد على طلب الإعفاء من الرسوم.

ويقوم طلب الإعفاء مقام التظلم الإدارة ويترتب عليه جميع آثاره شريطة تقديمه في الميعاد المقرر للتظلم، بل يعد هذا الطلب أقوى من التظلم ذاته حيث ينبىء عن رغبة ذوي الشأن في سلوك طريق القضاء للمطالبة بإلغاء القرار الإداري غير المشروع. كما أنه "ولئن كان مفاد النصوص المدنية في مجال القانون الخاص أنه لا يقوم طلب طلب مقام المطالبة القضائية في هذا الشأن ، إلا أنه يقوم مقامها في مجال الروابط الإدارية، نظراً لمقتضيات النظام الإداري التي تستلزم تقرير قاعدة أكثر تيسيراً في علاقة الحكومة بذوي الشأن، بمراعاة طبيعية هذه الروابط"^(٣).

الحالة الثالثة : رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة : إذا رفعت دعوى إلغاء القرار الإداري إلى محكمة غير مختصة في خلال مدة الطعن القضائي، فإن

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم - 13981 لسنة 48 ق، بتاريخ ١٢/٧/٢٠٠٦م - س ٥٢، ج ١، ص 165.

(٢) راجع أستاذنا الدكتور / فؤاد النادي : القضاء الإداري، مرجع سابق، ص ٣٧٥.

(٣) راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم - 685 لسنة 3 ق - بتاريخ ١٩٥٨/٣/٨م، س ٣، ج ٢، ص ٨٩١.

ذلك ينتج أثره من حيث قطع الميعاد وبدء مدة طعن جديدة ضد القرار الإداري محل الدعوى من تاريخ الفصل في الدعوى والحكم فيها بعدم الاختصاص. ورفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة ينتج أثره لأن ذلك ينبىء عن تمسك ذو الشأن بحقه في المطالبة القضائية، ومن ثم يعد أقوى حالاً من التظلم الإداري الذي يقدم للإدارة ضد القرار الإداري، وعليه يكون قاطعاً لمدة الستين يوم الواجب رفع دعوى الإلغاء خلالها.

ولقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن رفع الدعوى بالإلغاء القرار الإداري أمام محكمة غير مختصة يقطع الميعاد مادامت الدعوى قد رفعت في خلال الميعاد. (١)

وإذا كان رفع دعوى الإلغاء إلى محكمة غير مختصة يقطع الميعاد، فهل رفع دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري إلى محكمة غير مختصة في ميعاد الطعن يقطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء أيضاً أم لا؟ استقرت أحكام القضاء الإداري على أن رفع دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري يقطع ميعاد الطعن بالإلغاء. (٢)

رابعاً : انفتاح الميعاد : في هذا الفرض يكون ميعاد دعوى الإلغاء قد انتهى دون أن يقوم ذو الشأن برفع دعوى الإلغاء؛ ومن ثم يتحصن القرار الإداري من الطعن القضائي عليه، غير أنه قد تتغير الظروف القانونية أو الواقعية التي صدر في ظلها القرار الإداري بما ينتج عنه انفتاح ميعاد جديد لرفع دعوى الإلغاء.

ومن أمثلة تغير الظروف القانونية التي صدر في ظلها القرار الإداري ما يلي :

١- صدور تشريع لاحق على اللائحة يجعل وجودها غير مشروع، فيجوز رفع دعوى الإلغاء ضد هذه اللائحة بشرط أن ترفع هذه الدعوى خلال الستين يوماً اللاحقين على صدور التشريع المتعارض معها.

٢- صدور حكم بعدم دستورية قانون أو لائحة وكان قد صدر بناءً عليهما قرار إداري وتحصن من الطعن عليه بفوات المدة، فإنه يجوز رفع دعوى الإلغاء قبل هذا

(١) حكم المحكمة الإدارية في الطعن رقم 2334 لسنة 27 ق ، بتاريخ ١٩٨٤/٥/١م، س 29 ، ج ٢ ، ص ١٠٩٢ .
(٢) حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 764 لسنة 25 ق، بتاريخ ١٩٧٣/١/٢م، س 27 ، ج ١ ، ص .

القرار لانفتاح ميعاد جديد للطعن عليه يبدأ من اليوم التالي للحكم بعدم دستورية القانون أو اللائحة التي استند إليها في صدوره.

٣- تغيير التفسير القضائي الذي كان يجعل من القرار الإداري قراراً مشروعاً، بحيث أضحى غير مشروع على وفق التفسير الجديد، فهنا يفتح ميعاد طعن جديد ضد هذا القرار يبدأ من تاريخ علم ذوي الشأن بالتفسير الجديد.

ومن أمثلة تغيير الظروف الواقعية تغيير ظروف الواقع التي أدت إلى إصدار اللائحة، فإذا تغيرت الظروف وأصبحت اللائحة غير مستندة إلى سبب واقعي يبرر وجودها، جاز لأصحاب الشأن أن يطلبوا من الإدارة إلغاء هذه اللائحة، فإذا لم تستجب جهة الإدارة التجأوا إلى القضاء بدعوى الإلغاء لامتناع الإدارة^(١).

خامساً : دوام الميعاد : توجد بعض القرارات الإدارية لا تتحصن بمضي مدة الطعن القضائي؛ ومن ثم فلا يكون لانتهاء مدة رفع دعوى الإلغاء أي أثر لتحصنها، ويكون الميعاد بالنسبة لها وكأنه لم ينته أبداً، فهما من الزمن على مثل هذه القرارات فتكون محلاً للطعن، وذلك مثل القرارات ذات الطبيعة المستمرة كالقرارات الصادرة بالاعتقال، وكذلك أيضاً مثل القرارات المنعقدة كالقرارات الصادرة بناءً على غش، حيث إن الغش يفسد كل شيء فلا تلحقها أي حصانة مهما طال من الزمن^(٢)، فمثل هذه القرارات لا تتحصن بمضي المدة؛ ومن ثم تتمتع بديمومة ميعاد الطعن فيها بالإلغاء.

المطلب الثالث

أثر انتهاء ميعاد دعوى بالإلغاء

القاعدة العامة بشأن الأثر المترتب على انتهاء ميعاد دعوى الإلغاء أن تتحصن القرارات الإدارية من الطعن عليها بالإلغاء سواء كانت هذه القرارات تنظيمية أو فردية؛ ومن ثم إذا رفعت دعوى الإلغاء على الرغم من انتهاء ميعاد الطعن بالإلغاء فيحكم القاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، غير أنه توجد بعض الاستثناءات يجوز بصدها رفع دعوى الإلغاء على الرغم من انتهاء ميعاد دعوى

(١) راجع أستاذنا الدكتور / فؤاد النادي : المرجع سابق، ص ٣٧٨.

(٢) راجع حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 13425 لسنة 56 ق، بتاريخ ٢٠/١/٢٠٠٤.

الإلغاء^(١)، ولبيان هذه الاستثناءات ينبغي علينا التفرقة بين القرارات الفردية والقرارات التنظيمية على النحو التالي :

أولاً : القرارات الفردية : توجد بعض الاستثناءات على قاعدة عدم جواز الطعن على القرارات الفردية بعد فوات ميعاد رفع دعوى الإلغاء تتمثل في جواز الطعن على هذه القرارات حتى بعد انتهاء الميعاد، وذلك مثل حالات امتداد الميعاد كالقرارات المستمرة والتي تمس حريات الأفراد كقرارات الاعتقال وقرارات المنع من السفر، وكذلك كالقرارات المعدومة.

ثانياً : القرارات التنظيمية : توجد أيضاً بعض الاستثناءات على قاعدة عدم جواز الطعن على القرارات التنظيمية بعد انتهاء ميعاد رفع دعوى الإلغاء تتمثل فيما يلي :

- ١- إمكانية تقديم ذوى الشأن طلب إلى الإدارة لإعادة النظر في القرار اللاتحي ثم الطعن في القرار الصادر برفض هذا الطلب، وذلك في حالات معينة تتمثل في، حالة تغير الظروف القانونية كصدور تشريع لاحق متعارض مع اللائحة، وحالة تغير الظروف الواقعية التي أدت إلى إصدار اللائحة، وحالة تغير التفسير القضائي.
- ٢- إمكانية دفع الأفراد بعدم مشروعية اللائحة دون إلغائها بعد فوات ميعاد الطعن بالإلغاء، وهنا يقرر القاضي عدم مشروعية اللائحة فقط دون إلغائه، وذلك بمناسبة طلب الأفراد إلغاء القرارات الفردية الصادرة استناداً على اللائحة المعيبة.

المبحث الرابع

شروط سبق طلب التوفيق في المنازعة

نصت المادة (١١) من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠م بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أنه "لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة".

(١) راجع في ذلك د / ماجد الحلو ، ود/ محمد محمد عبده إمام : القضاء الإداري ، ٢٠٠٧، ص ٢٤٠ وما بعدها.

وبناءً على ذلك فإن دعوى الإلغاء لا تكون مقبولة أمام القضاء الإداري إلا إذا قام ذوى الشأن بتقديم طلب التوفيق إلى لجنة فض المنازعات المختصة وانقضاء المواعيد المنصوص عليها في القانون؛ وعليه لا تقبل دعوى الإلغاء إذا لم يقدم ذوى الشأن طلب التوفيق قبل رفع دعوى الإلغاء ويحكم القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم سبق تقديم طلب التوفيق إلى لجنة فض المنازعات.

ويستثنى من ضرورة تقديم طلب التوفيق كشرط لقبول دعوى الإلغاء، طلبات الأفراد بإلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، والتي محلها القرارات المتعلقة بشئون الموظفين.

وعلة هذا الاستثناء طول المواعيد المقررة من تقديم طلب التوفيق وحتى صدور التوصية من لجنة فض المنازعات، والتي تكاد تقترب من ثلاثة أشهر، وقد ترتبط بدعوى الإلغاء حالة استعجال تقتضي وقف التنفيذ الفوري للقرار ولا تحتمل انتظار مثل هذه المواعيد، وذلك مثل الطعن بإلغاء القرار الصادر بحرمان الطالب من أداء الامتحان أو القرار الصادر بهدم عقار، ^(١) غير أن هذا الاستثناء لا يمنع ذوى الشأن من اللجوء أولاً إلى لجنة فض المنازعات لتقديم طلب إليها، حيث أن هذا الاستثناء يعد رخصة لذوى الشأن ومن الممكن أن يقرروا التنازل عنها بتفضيلهم اللجوء للجنة فض المنازعات.

المبحث الخامس

شرط انعدام طريق الطعن الموازي

يشترط كذلك لقبول دعوى الإلغاء، أن لا يكون في وسع الطاعن اللجوء إلى جهة قضائية أخرى تحقق له نفس النتائج التي يريد الوصول إليها عن طريق دعوى الإلغاء، ويطلق على ذلك شرط انعدام الدعوى الموازية. وقد اختلف الفقهاء حول مدى تطلب هذا الشرط لقبول دعوى الإلغاء، فمنهم من اعتبره شرطاً لقبولها، ومنهم من اعتبر هذا الشرط متعلقاً بقواعد الاختصاص القضائي.

(١) راجع في ذلك د / ماجد الحلو : القضاء الإداري ، مرجع سابق، ص ٢٤٦ ، ٢٤٧.

ونرى أن هذا الشرط لا يتعلق بقبول دعوى الإلغاء، ولكن يتعلق بقواعد الاختصاص القضائي، فالقرار الإداري يختص القضاء الإداري بحسب الأصل بإلغائه إذا كان غير مشروع، ولكن قد يخرج القانون من اختصاص القضاء الإداري إلغاء بعض القرارات الإدارية؛ ومن ثم تختص بها جهة قضائية أخرى، وذلك مثل القرارات الإدارية الصادرة من نقابة المحامين برفض القيد في جداولها، حيث نص قانون المحاماة بأن تختص بإلغائها محكمة استئناف القاهرة.

وبناءً على ما تقدم : فإن إذا اختص القانون جهة قضائية أخرى غير القضاء الإداري بإلغاء قرار إداري معين، فإن رفع دعوى لإلغاء هذا القرار أمام القضاء الإداري يقتضي معه أن يحكم القاضي بعدم اختصاصه بنظر الدعوى وليس بعدم قبول الدعوى شكلاً لوجود الدعوى الموازية.

الفصل الثالث الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء (أوجه الطعن بالإلغاء)

يقصد بالشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء : تلك الشروط التي تتصل بالقرار الإداري ذاته، والتي إذا توافرت أو أحد منها أصبح القرار الإداري معيباً مما يستوجب إلغاؤه.

فيجب أن تتوافر شروط معينة لتكون القرارات الإدارية صحيحة، فالقرار الإداري يجب أن يصدر من صاحب الاختصاص في إصداره، كما يجب أن يراعى فيه الشكل والإجراءات التي يتطلبها القانون، وأن يصدر بما يتفق مع الشروط الموضوعية التي ينص عليها القانون، وبما يحقق الغاية التي ينص عليها القانون أو يكون مبتغياً للمصلحة العامة إذا لم يحدد له هدفاً معيناً، وأخيراً يجب أن يكون السبب أو الدافع من إصداره مشروعاً.

وبناءً على ما تقدم إذا فقد القرار الإداري شروط صحته كلها أو بعضها فيترتب على ذلك أن يكون هذا القرار معيباً؛ ومن ثم يحكم القاضي بإلغائه، أما إذا توافرت هذه الشروط وكانت دعوى الإلغاء مقبولة من حيث الشكل؛ فيحكم القاضي برفض الدعوى لكون القرار الإداري غير معيب لتوافر شروط صحته.

ومن ثم، سنقوم بدراسة العيوب التي تصيب القرار الإداري وتؤدي إلى الحكم بإلغائه في ستة مباحث على النحو التالي :

المبحث الأول : عيب عدم الاختصاص.

المبحث الثاني : عيب الشكل والإجراءات.

المبحث الثالث : عيب المحل أو مخالفة القانون.

المبحث الرابع : عيب الغاية.

المبحث الخامس : عيب السبب.

المبحث السادس : الأثر المترتب على توافر الشروط الموضوعية لدعوى

الإلغاء.

المبحث الأول عيب عدم الاختصاص

الاختصاص هو عبارة عن الصلاحية القانونية للقيام بعمل معين. والاختصاص في مجال القرارات الإدارية : السلطة او الصلاحية القانونية التي يتمتع بها متخذ القرار في إصداره من حيث النوع أو الزمان أو المكان. ويعتبر شرط الاختصاص من أهم شروط صحة القرار. والقاعدة أن يتم تحديد اختصاصات كل عضو إداري بموجب القوانين والأنظمة ولا يجوز تجاوز هذه الاختصاصات وإلا اعتبر القرار الصادر من هذا العضو باطلاً ويجوز الطعن فيه بالإلغاء..

وتتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام؛ ومن ثم لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وإلا فإن القرار الصادر مخالفاً لهذه القواعد يكون معيباً بعيب عدم الاختصاص، ويكون لصاحب الشأن أن يطعن بهذا العيب أمام القضاء الإداري بدعوى الإلغاء ولا يسقط الدفع بهذا العيب بالدخول في موضوع الدعوى، ويجوز إيدأؤه في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، والقاضي يحكم بعدم الاختصاص تلقائياً لو لم يثره طالب الإلغاء وبناءً على ما تقدم فإن عيب عدم الاختصاص يعني : عدم القدرة القانونية على القيام بتصرف معين. وفي نطاق القرارات الإدارية يقصد به صدور القرار من موظف ليس له سلطة إصداره طبقاً للقوانين واللوائح (١).

أنواع عيب عدم الاختصاص : يتنوع عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري إلى أربعة أنواع تتمثل فيما يلي : عيب عدم الاختصاص الشخصي، وعيب عدم الاختصاص الموضوعي، وعيب عدم الاختصاص المكاني، وعيب عدم الاختصاص الزماني؛ ومن ثم قد يرجع عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري إلى أحد هذه الأنواع وذلك على النحو التالي :

١- **عيب الاختصاص الشخصي :** يشترط لصحة القرار الإداري أن يصدر من الشخص أو من الهيئة التي اسند إليها القانون سلطة إصداره؛ ومن ثم لا يجوز لغير

(١) راجع د/ داود الباز : القضاء الإداري - مجلس الدولة - دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، ٢٠١١، ص ٢٦٤.

هذا الشخص أو تلك الجهة أن يصدر القرار الإداري سواء كان شخصاً عادياً لا علاقة له بالعمل الإداري، أو كان شخصاً له علاقة بالعمل الإداري لكن لم تسند إليه مهمة إصدار قرارات معينة، أو لم يخول له القانون سلطة إصدار قرارات أصلاً. كما لا يستطيع المختص بإصدار القرار الإداري أن يتنازل عن هذا الاختصاص إلى الغير، ولكن يجوز له تفويض بعض اختصاصاته، أو أن يحل محله آخر وفقاً للقانون، وإلا كان القرار الصادر مشوباً بعيب عدم الاختصاص.

٢- **عيب الاختصاص الموضوعي** : يحدد القانون اختصاصات كل موظف أو جهة إدارية بموضوعات معينة فإذا تجاوز هذا الموظف أو الإدارة اختصاصاته تلك فتعدى على اختصاصات جهة أخرى؛ تحقق عيب عدم الاختصاص ويكون القرار غير صحيح.

فيشترط لصحة القرار الإداري أن يصدر من سلطة تمتلك حق إصداره موضوعياً، أي يجب أن يكون موضوع القرار مما يدخل في اختصاص الجهة التي أصدرته، ويكون الاختصاص الموضوعي محدداً في القوانين واللوائح، فإذا صدر القرار على خلاف القانون أو اللائحة كان ذلك القرار مشوباً بعيب عدم الاختصاص الموضوعي.

ومخالفة الاختصاص الموضوعي قد يكون بتعدي جهة إدارية على اختصاصات جهة إدارية أخرى موازية أو مساوية لها، كتعدي مدير الشؤون المالية بالوحدة على اختصاصات مدير الشؤون الإدارية، كما قد يكون التعدي أيضاً من جهة إدارية دنياً على اختصاصات جهة إدارية عليا، وذلك مثل تعدي وكيل الوزارة على اختصاصات الوزير. أو أن يكون التعدي من جهة إدارية عليا على اختصاصات جهة أدنى منها، كتعدي مجلس الجامعة على اختصاصات مجلس الكلية. كما يتحقق التعدي أيضاً في حالة اعتداء السلطة المركزية على اختصاصات الهيئات اللامركزية .

٣- **عيب الاختصاص المكاني** : يحدد القانون نطاق جغرافي معين لممارسة كل موظف لاختصاصاته؛ ومن ثم لا يجوز له أن يمارس اختصاصاته خارج النطاق الجغرافي المحدد له، وإلا كان تعدياً من على اختصاص غيره، مما يجعل القرار معيباً بعيب عدم الاختصاص.

فقد يكون الموظف مختص موضوعياً بإصدار القرار الإداري، لكن يصدره فتعدياً النطاق المكاني الذي حدده القانون له فيصبح القرار معيباً، وذلك مثل إصدار المحافظ قراراً بخصوص محافظة أخرى غير محافظته.

٤- **عيب الاختصاص الزمني** : الاختصاص الزمني يعني : تحديد فترة زمنية معينة يكون لرجل الإدارة أن يباشر اختصاصه فيها، فإذا أصدر قرار خارج النطاق الزمني المقرر لممارسته.

فقد يسند القانون لشخص ما سلطة إصدار قرارات إدارية، ويقوم هذا الشخص بممارسة اختصاصاته فقط ولا يتعدي على اختصاصات غيره سواء من حيث الموضوع أو المكان المحدد له قانوناً، لكن على الرغم من ذلك قد يكون غير مختص بإصدار هذه القرارات من حيث الزمان، بأن يصدر القرار في غير الفترة الزمنية المحددة لممارسة اختصاصه قانوناً. كما لو أصدر الموظف قراراً إدارياً بعد انفصال الرابطة الوظيفية بقبول استقالته أو فصله من الوظيفة أو إحالته إلى التقاعد، ففي هذه الحالات يعد القرار معيباً بعيب عدم الاختصاص .

درجات عيب عدم الاختصاص : تتفاوت درجات عيب عدم الاختصاص، فقد يكون عيب عدم الاختصاص جسيماً يصل بالقرار إلى درجة الانعدام بحيث يكون مجرد واقعة مادية لا يرقى بها إلى وصف القرار الإداري، كما قد يكون عيب عدم الاختصاص بسيطاً بحيث يكون القرار موجوداً لكنه فقد شرط من شروط صحته.

أولاً : عيب عدم الاختصاص الجسيم : مخالفة قواعد الاختصاص قد تكون مخالفة جسيمة، ويسمى عيب الاختصاص في هذه الحالة بعيب عدم الاختصاص الجسيم أو ما يطلق عليه اغتصاب السلطة. ويكون القرار في هذه الحالة فاقداً لركن من أركانه.

كما إذا صدر القرار من شخص لم يعين أصلاً في الوظيفة العامة - باستثناء حالة الموظف الفعلي -، وفي هذه الحالة يكون القرار قد فقد ركن صدوره من جهة إدارية ويكون منعدماً.

ثانياً : عيب عدم الاختصاص البسيط : قد تكون مخالفة قواعد الاختصاص بسيطة، وذلك إذا كان ينظر إلى الاختصاص باعتباره شرط صحة في القرار

الإداري، كأن يصدر موظف قراراً إدارياً من اختصاصات موظف آخر، وفي هذه الحالة يكون القرار قد فقد شرط صحته فيما يتعلق بالاختصاص ويكون باطلاً لا منعماً.

وتجدر الإشارة إلى أن عيب عدم الاختصاص البسيط قد يكون إيجابياً، وذلك عندما يصدر الموظف أو الجهة الإدارية قراراً من اختصاص موظف آخر أو جهة إدارية أخرى . ومن ناحية أخرى قد يكون عيب عدم الاختصاص البسيط سلبياً، وذلك إذا رفض الموظف إصدار قرار ظاناً منه أنه لا يدخل في اختصاصه.

المبحث الثاني **عيب الشكل والإجراءات**

سنتناول في هذا المطلب تعريف عيب الشكل والإجراءات كمتطلب ، ثم نبين مدى تطلب الشكل والإجراءات في القرارات الإدارية لكي نحكم بتعييبها أو عدم تعييبها، والأثر المترتب على ذلك، وذلك على النحو التالي :

أولاً : تعريف عيب الشكل : يقصد بالشكل في القرار الإداري : المظهر الخارجي الذي يبدو فيه القرار، والإجراءات التي تتبع في إصداره والتي نص عليها القانون.

ومن ثم يقصد بعيب الشكل والإجراءات : عدم مراعاة الإدارة للشكل أو الإجراءات التي نص عليها القانون ، ويرتبط هذا العيب بالمظهر الخارجي للقرار الإداري

والأصل أن القرار الإداري ليس له شكل معين يتعين أن يصدر فيه، فمن الممكن أن يكون القرار الإداري مكتوباً أو شفوياً، صريحاً أو ضمنياً؛ لذلك فإن الإدارة غير مقيدة بشكل معين تفصح فيه عن إرادتها الملزمة، إلا إذا قرر القانون اتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معين، أو اتباع إجراءات معينة في إصداره؛ ومن ثم حدد القانون شكل محدد أو إجراءات معينة وجب على جهة الإدارة التقيد بها، وذلك كضرورة توقيعه أو ختمه، أو أخذ رأي جهة معينة قبل إصداره . وعليه إذا لم تراعى الأشكال والإجراءات التي يتطلبها القانون في القرار الإداري؛ فإنه يعد معيباً بعيب الشكل.

ويحدد القانون بمعناه الواسع قواعد الشكل والإجراءات سواء بنص في الدستور أو القوانين أو اللوائح، كذلك تؤدي المبادئ القانونية التي يقرها القضاء الإداري دوراً مهماً في ابتداع قواعد شكلية غير منصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك بالاستناد إلى روح التشريع وما يمليه العقل وحسن تقدير الأمور . (١)

ثانياً : مدى تطلب الشكل في القرار الإداري : نفرق في هذا الصدد بين حالتين : الأولى : وتتمثل في نص القانون على أشكال أو إجراءات معينة في القرار الإداري. والثانية : تتمثل في عدم نص القانون على أشكال أو إجراءات معينة في القرار الإداري.

الحالة الأولى: نص القانون على أشكال أو إجراءات معينة في القرار الإداري : إذا نص القانون على اتباع شكل أو إجراء معين، فإنه يريد من ذلك الموازنة بين مصلحتين، الأولى مصلحة الأفراد وعدم فسح المجال للإدارة لإصدارها قرارات تضر بهم وبحقوقهم، وثانياً المصلحة العامة والمتمثلة في إلزام الإدارة بالتروي وعدم التسرع في اتخاذ قرارات خاطئة قد تضر بالمصلحة العامة.

وقد ميّز القضاء الإداري بين نوعين من الأشكال والإجراءات التي يتطلبها القانون، **الأول :** ويتمثل في الأشكال والإجراءات الجوهرية، **والثاني:** ويتمثل في الأشكال والإجراءات الغير جوهرية أو الثانوية.

والأشكال والإجراءات الجوهرية هي التي يترتب على تخلفها أو عدم مراعاتها في القرار الإداري تعييب بعيب الشكل أو الإجراءات مما يجعله قابلاً للبطلان ومحلّاً للطعن فيه بالإلغاء.

ومن قبيل الأشكال والإجراءات الجوهرية، الأشكال والإجراءات المقررة لصالح الأفراد والمقررة كضمانه لهم عند إصدار القرارات الإدارية، كضرورة تسبيب قرار الصادر بالجزاء التأديبي، وإجراء التحقيق قبل صدور هذا الجزاء.

كما يعد الشكل أو الإجراء جوهرياً إذا وصفه القانون صراحة بذلك، أو إذا رتب القانون البطلان كجزاء على مخالفته. (٢)

(١) راجع د/ مصطفى أبو زيد فهمي : القضاء الإداري ومجلس الدولة ، المصدر السابق ، ص ٤٧٩ .

(٢) د/ مصطفى أبو زيد فهمي : المرجع السابق ، ص ٤٨٤ .

أما الأشكال والإجراءات غير الجوهرية أو الثانوية، فهي تلك الأشكال والإجراءات التي لا يترتب على تخلفها أو عدم مراعاتها في القرار الإداري أن يكون معيباً بعيب الشكل أو الإجراءات، ولا يكون قابلاً للإبطال، أو محلاً للطعن فيه بالإلغاء.

ومن قبيل هذه الأشكال والإجراءات الثانوية، تلك التي تكون مقررة لصالح الإدارة ولا تضر بالأفراد؛ ومن ثم إذا تنازلت الإدارة عن هذه الإجراءات، فلا يجوز لها فيما بعد أن تحتج ببطالان القرار الإداري لتعيبه بعيب الشكل أو الإجراءات. وذلك كأن يتطلب القانون صدور قرار التعيين في وظيفة معينة بعد أخذ رأي جهة إدارية معينة، وأصدرت الإدارة قرار التعيين دون أخذ رأي هذه الجهة، فلا يجوز للإدارة أن تحتج ببطالان قرار التعيين لعدم أخذ رأي هذه الجهة، لكي لا تستفيد الإدارة من خطئها.

الحالة الثانية: عدم نص القانون على أشكال أو إجراءات معينة في القرار الإداري :

إذا لم ينص القانون على تطلب إجراء أو شكل معين في القرار الإداري، فإن الإدارة بحسب الأصل لا تكون ملزمة بتتبع أشكال أو إجراءات معينة عند إصدارها للقرار الإداري، لكن إذا اعتادت على الرغم من عدم وجود نص قانوني على اتخاذ إجراء معين قبل صدور القرار الإداري، أو اعتادت على اتباع شكل معين عند إصداره، فلا يعد عدم التزامها بهذا الإجراء أو ذلك الشكل عيب في القرار الإداري؛ ومن ثم لا يكون قابلاً للإبطال أو الطعن فيه أمام القضاء، هذا ما لم يقرر القضاء ذاته مبدأ قانونياً بأن هذا الإجراء أو الشكل يعد جوهرياً يترتب على مخالفته البطلان.

ثالثاً : الأثر المترتب على مخالفة قواعد الشكل والإجراءات :

مما سبق يتضح لنا الأثر المترتب على تخلف قواعد الشكل والإجراءات والتي تتمثل فيما يلي :

١- بالنسبة للأشكال والإجراءات الجوهرية التي نص عليها القانون: يترتب على تخلفها قابلية القرار للإبطال والطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري.

٢- وبالنسبة للأشكال والإجراءات الثانوية التي نص عليها القانون : لا يترتب على مخالفتها أو عدم مراعاتها قابلية القرار الإداري للبطلان أو الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري.

٣- وأخيراً بالنسبة للأشكال والإجراءات التي لم ينص عليها القانون : لا يترتب على مخالفتها أو عدم مراعاتها قابلية القرار الإداري للبطلان أو الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري، ما لم يقرر القضاء مبدأ قانونياً بأن هذا الإجراء أو الشكل يعد جوهرياً يترتب على مخالفته البطلان.

المبحث الثالث

عيب المحل

(عيب مخالفة القانون)

يقصد بمحل القرار الإداري : موضوع القرار أو الأثر القانوني الذي يحدثه هذا القرار . فالمحل في إصدار القرار التأديبي بحق موظف عام هو توقيع الجزاء، والمحل في قرار التعيين في الوظيفة هو إدخال الفرد بهذا القرار في الوظيفة . والمحل في قرار الصادر بإنهاء خدمة الموظف هو انقضاء العلاقة الوظيفية بينه وبين الإدارة .

ومحل القرار الإداري يجب أن يتوافر فيه شرطين:

الأول : أن يكون جائزاً قانوناً : وذلك بأن يكون موضوعه متوافق مع القوانين واللوائح؛ ومن ثم إذا كان المحل غير جائز قانوناً ، فإن القرار يكون باطلاً لعيب المحل .

ومن قبيل ذلك إصدار قرار بتوقيع عقاب على موظف من غير الجزاءات الجائز توقيعها عليه، أو جزاء لم ينص عليه القانون أصلاً. أو أن تعين الإدارة شخصاً على خلاف لم تتوافر فيه شرط من شروط التعيين في الوظيفة العامة.

الثاني : أن يكن المحل ممكناً: وهذا يعني أن موضوع القرار لا يكتفى بكونه جائزاً فحسب من الناحية القانونية، لكن يجب أيضاً أن توجد إمكانية لتحقيقه واقعياً، فإن كان المحل غير ممكن من الناحية المادية استحال تنفيذ القرار . كأن تصدر الإدارة قراراً بتعيين أحد الموظفين مع عدم وجود درجات شاغرة، أو تصدر قراراً بإحالة موظف إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانونية.

وإذا كان القرار في موضوعه مخالفاً للقانون؛ فإنه يكون معيب بعيب المحل أو ما يسمى بعيب مخالفة القانون، فالتزام محل القرار بالقانون يعنى أن يأتي القرار في موضوعه متوافقاً مع جميع القواعد القانونية الموجودة في الدولة أياً كان مصدرها، سواء كان هذا المصدر دستورياً أو تشريعياً أو لائحياً أو عرفياً أو مبادئ قانونية قررها القضاء؛ ومن ثم إذا خالف موضوع القرار أي من هذه القواعد فيكون غير مشروع ويكون القرار بالتالي باطلاً .

وعيب المحل في القرار الإداري يعني : إتيان الأثر القانوني الذي يحدثه القرار الإداري بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني عام أو فردي على خلاف ما قرره القانون ، ومخالفة محل القرار أو موضوعه للقواعد القانونية تتخذ صورتين على النحو التالي :

أولاً : المخالفة الصريحة للقانون : وهنا لا تلتزم الإدارة عن عمد بالقاعدة القانونية وتتصرف كأنها غير موجودة ، ومن ناحية أخرى قد تكون مخالفة الإدارة للقاعدة القانونية غير عمدية نتيجة عدم علم الإدارة بوجود القاعدة القانونية نتيجة تعاقب التشريعات وعدم مواكبة الإدارة للساير منها والذي تم إلغاؤه.

ثانياً : الخطأ في تفسير القانون أو تأويله أو تطبيقه: وهنا لا تخالف الإدارة القانون عن عمد أو غير عمد، ولكنها تطبق القاعدة القانونية وتخطئ في تفسيره فتعطي معنى آخر غير الذي قصده المشرع، فتصدر القرار بالمخالفة لما قصده المشرع من تطبيق القانون، وذلك مثل أن يحدد القانون شروط معينة للترقية في وظيفة معينة فتقوم الإدارة بتفسير تطبيق هذه الشروط على الموظفين بطريقة خاطئة، مما يجعلها تقوم بترقية موظف لا تنطبق عليه هذه الشروط، أو لا تقوم بترقية موظف يستحق الترقية وفقاً للتطبيق الصحيح للقانون.

والخطأ في تفسير القانون أو تأويله يأتي في الغالب لعدم الفهم الصحيح لها نظراً لغموضها، وهذا يعد مخالفاً لما استقرت عليه المبادئ القانونية التي تقضي بضرورة وجوب أن تكون القاعدة القانونية واضحة ولا لبس فيها ولا غموض، وهي إحدى تطبيقات مبدأ الأمن القانوني الذي يعني ضمان الاستقرار النسبي للقاعدة القانونية،

وهذا يتحقق بأن تكون القاعدة القانونية واضحة وصريحة في مفهومها ولا غموض فيها. (١)

ومن جهة أخرى قد تكون الإدارة عالمة بالمفهوم الصحيح للقانون، وأن القاعدة القانونية صريحة في معناها ولا تحتل تأويلاً، ولكن الإدارة تتعمد التفسير الخاطيء وتصدر القرار طبقاً لهذا التفسير مما يجعله مخالفاً للقانون ويكون معيباً بعيب المحل، كما يكون أيضاً معيباً بعيب الانحراف بالسلطة لتعمد الإدارة التفسير الخاطيء؛ وفي هذه الحالة يختلط عيب المحل بعيب الغاية أو الانحراف بالسلطة.

المبحث الرابع **عيب الغاية أو الانحراف بالسلطة**

يقصد بالغاية من القرار الإداري : الهدف المراد تحقيقه من إصدار القرار الإداري.

ويختلف الهدف من القرار الإداري باختلاف القرارات الإدارية، فالهدف من إصدار القرار بتعيين موظف عام هو تحقيق استمرار سير العمل في المرفق الذي تم تعيينه فيه، والهدف من إصدار قرارات الضبط الإداري هو حماية النظام العام بعناصره الثلاث التقليدية والمتمثلة في السكينة العامة ، والصحة العامة ، والأمن العام .

ويقصد بعيب الغاية : انحراف الإدارة عن الهدف الذي حدده القانون من إصدارها للقرار الإداري أو عدم ابتغاءها المصلحة العامة في حالة عدم تحديد القانون للإدارة هدف معين لإصدار القرار الإداري.

ومن ثم فالهدف المقصود من القرار الإداري قد يكون هدفاً عاماً ، وقد يكون هدفاً خاصاً، أو ما يسمى بقاعدة تخصيص الهدف ، وسوف نبين ذلك على النحو التالي :

(١) للمزيد عن مبدأ الأمن القانوني ومبدأ وضوح القاعدة القانونية راجع بحثنا "العدالة التشريعية في ضوء فكرة التوقع المشروع" بحث مقدم لمؤتمر العدالة بين الواقع والمأمول بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية ٢٠١٢م. والدكتور/ رفعت عيد سيد/ مبدأ الأمن القانوني ، ٢٠١١م، بدون دار نشر.

أولاً : تحقيق المصلحة العامة : إذا لم يحدد القانون للإدارة هدفاً معيناً يجب أن تبتغيه لإصدار القرار الإداري، فيجب أن يكون هدف الإدارة من إصدار القرار تحقيق المصلحة العامة.

فإذا انحرفت الإدارة في استعمال سلطتها بإصدار قرار إداري لتحقيق أهداف تتعارض مع المصلحة العامة، فإن قرارها يكون مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وذلك كأن تقوم الإدارة بنقل موظف لمصلحة العمل وكان الهدف الرئيس هو من وراء إصدارها لهذا القرار الانتقام منه لا المصلحة العامة.

ثانياً : قاعدة تخصيص الأهداف : قد يحدد القانون هدفاً معيناً للإدارة يجب عليها الالتزام به عند إصدار القرار الإداري وهو ما يعرف بقاعدة تخصيص الأهداف ، وفي هذه الحالة يجب على جهة الإدارة عند إصدارها للقرار الإداري أن تحقق الأهداف الخاصة التي حددها القانون أو اللائحة، وإلا اعتبر القرار مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها أو ما يسمى بعيب الغاية.

ومثال القرارات التي حدد لها القانون هدفاً خاصاً، قرارات الضبط الإداري التي حدد لها القانون أهدافاً ثلاثة لا يجوز للإدارة مخالفتها وهي المحافظة على الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة ، فإذا خالفت الإدارة هذه الأهداف في قرارات الضبط الإداري فإن قرارها هذا يكون معيباً بعيب الغاية ومحلاً للطعن فيه بالإلغاء.(١)

وقد يكون الهدف الذي حدده القانون للإدارة يتمثل في ضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وذلك كالقرار الصادر من من الإدارة برفض الاستقالة للحاجة إلى الموظف الذي قدم استقالته لتسيير المرفق العام.

إثبات عيب الغاية : يفترض في القرار الإداري أن له هدفاً يبتغي المصلحة العامة، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات انحراف الإدارة عن هذا الهدف، وعبء الانحراف بالسلطة أو الغاية عيب قصدي تتعمد فيه الإدارة دائماً الانحراف بالسلطة المخولة لها في إصدار القرارات، ويتعلق هذا العيب بنية مصدر القرار الذي يجب

(١) د/ ماجد راغب الحلو : القضاء الإداري ، المرجع السابق ، ص ٥٣٨.

أن يكون سيء النية يعلم أنه يسعى إلى غاية بعيدة عن المصلحة العامة أو غير تلك التي حددها القانون .

ويعد إثبات هذا العيب من الصعوبة بمكان، حيث إنه يتصل بالبواعث النفسية الخفية لجهة الإدارة، وإثباته يتطلب أن يبحث القضاء في وجود هذه البواعث، ومن ثم فقد أضفى القضاء على هذا العيب الصفة الاحتياطية، فلا يبحث في وجود عيب الغاية طالما أن هناك عيب آخر شاب القرار الإداري، مثل عدم الاختصاص أو عيب الشكل، أو المحل.

المطلب الخامس

عيب السبب

السبب في القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية السابقة على إصدار القرار والتي دفعت الإدارة إلى إصداره.

فالسبب في القرار الإداري يعد عنصراً خارجياً يبرر للإدارة التدخل بإصدار القرار الإداري، وليس عنصراً نفسياً داخل من أصدر هذا القرار، وبهذا يختلف السبب عن الغاية في القرار الإداري، فإذا كان السبب هو الهدف الأول من وراء صدور القرار وهو عنصر موضوعي، فإن الغاية هي النتيجة النهائية التي تسعى جهة الإدارة إلى تحقيقها من وراء إصدارها القرار الإداري. فالسبب للذهاب إلى الطبيب هو المرض، لكن الغاية من هذا الذهاب هي علاج هذا المرض.

ومن ثم يعتبر السبب هو الدافع والمبرر لإصدار القرار الإداري. هذا وعلى الرغم من أهمية وجود السبب على اعتبار أنه أمر لازم وضروري لإصدار القرار، غير أن ذلك لا يفرض على الإدارة ضرورة اتخاذ القرار، فإن لها حرية اتخاذ أو عدم اتخاذ القرار حتى ولو توفر سببه، فالأمر متروك في النهاية لتقدير جهة الإدارة وحدها، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وأوجب على الإدارة إصدار القرار في حالة توافر سببه وفي حالات معينة، وذلك مثل إلزام الإدارة بترقية الموظف بعد مرور الفترة الزمنية المحددة قانوناً للترقية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب التمييز بين السبب والتسبب في القرار الإداري : فالسبب كما أوضحنا هو الحالة الواقعية أو القانونية التي دفعت رجل الإدارة إلى

اتخاذ قرار معين، لكن التسبب يعني إلزام القانون في بعض الحالات الإدارة بضرورة تسبب قراراتها ، بمعنى ذكر سبب القرار في صلب القرار نفسه أي تعليل سبب صدوره ، ومن ثم فإن تخلف الإدارة عن تسبب القرار الإداري يجعله معيباً بعيب الشكل، فالتسبب يعبر عن الشكل الذي يجب أن يخرج القرار فيه بأن تذكر أسبابه في صلبه. أما تخلف شرط السبب، بأن أصدرت الإدارة قراراً غير مستندة لأي سبب، أو مستندة لسبب غير صحيح، فيعد القرار معيباً بعيب السبب.

ولقد أكدت محكمة القضاء الإداري على أن : "المفروض في كل قرار إداري، حتى ولو صدر خلواً من ذكر أسباب أن يكون مستنداً في الواقع إلى دواع قامت لدى الإدارة حين إصداره وإلا كان القرار باطلاً لفقدانه ركناً أساسياً هو سبب وجوده ومبرر إصداره فإذا تكتفت هذه الدواعي بعد ذلك على أنها كانت هي السبب الذي دعا الإدارة إلى إصداره، وكان للمحكمة بمقتضى رقابتها القضائية أن تتحرى مبلغها من الصحة، فإن ظهر أنها غير صحيحة ولو ظنت الإدارة بحسن نية أنها صحيحة. فقد القرار أساسه القانوني الذي يجب أن يقوم عليه وكان مشوباً بعيب مخالفة القانون . أما إذا كانت الإدارة قد أصدرت القرار وهي تعلم أن هذه الأسباب غير صحيحة وإنما استهدفت غاية أخرى غير الصالح العام كان القرار مشوباً بالانحراف وإساءة استعمال السلطة إلى جانب مخالفة القانون" (١).

وبناءً على ما تقدم يلزم أن يقوم القرار الإداري على أسبابه، ولكن لا يلزم أن يشار إلى تلك الأسباب في صلب القرار الإداري (التسبب)، وهذا هو الاتجاه التقليدي، إلا أن الاتجاه المعاصر (التقدمي) يتجه نحو مبدأ عام لتسبب القرارات الإدارية، ألا وهو وجوب تسبب القرارات الإدارية، وبصفة خاصة القرارات الإدارية التنظيمية.

فإلزام جهة الإدارة بتسبب قراراتها يقوى النزاهة والثقة العامة في الحكومة وإدارتها، كما أن التسبب يعد مدعاة لاهتمام الإدارة بقراراتها وإصدارها بناءً على دراسة كافية، كما يعد التسبب وسيلة أيضاً لتسهيل الرقابة الخارجية على أعمال الإدارة، سواء كانت رقابة من جهة إدارية أو قضائية.

(١) حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 176 لسنة 4 ق - بتاريخ ١٩/٣/١٩٥٢م، س٦، ج٢، ص٦٨٣.

ويعد التسبب في مصر من الأمور الوجوبية منذ عام ٢٠٠٤م، وذلك بعد انضمام مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام ٢٠٠٣م بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠٧ لسنة ٢٠٠٤م في ١١ سبتمبر ٢٠٠٤م، ووافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٢٠ ديسمبر سنة ٢٠٠٤م، والمصدق عليها بقرار رئيس الجمهورية ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٤م، حيث ألزمت هذه الاتفاقية الإدارة في الدول الأعضاء بتحري الشفافية والنزاهة في إصدار القرارات الإدارية، الأمر الذي يستوجب معه ضرورة تسبب القرارات الإدارية (١).

ويجب أن تتوافر أربعة شروط في السبب كي يكون صحيحاً، ومن ثم إذا لم تتوافر هذه الشروط فيكون القرار الإداري معيباً بعيب السبب الأمر الذي يخول لذوي الشأن الطعن فيه بالإلغاء لعيب السبب، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي :

أولاً : أن يكون السبب موجوداً : وذلك بأن يكون له وجود مادي في الواقع؛ ومن ثم إذا انعدم السبب وقت صدور القرار الإداري، فلا يكون القرار حينئذ مبني على سبب، وبالتالي يكون قد فقد شرط من شروط صحته.

وذلك مثل أن يكون القرار الصادر بترقية موظف دون أن يتوافر السبب الدافع لهذه الترقية في الواقع، فإن هذا القرار يكون غير قائم على سبب أصلاً؛ ومن ثم يكون معيباً بعيب السبب مما يستوجب القضاء بإلغائه، وذلك كترقية الموظف على الرغم من عدم مرور المدة القانونية اللازمة للترقية إلى الدرجة الأعلى. وكذلك كأن يتم تعيين موظف مع أن الدرجة التي عين عليها مشغولة بغيره، وكصدور قرار من الإدارة بمجازاة الموظف تأديبياً على واقعة تبين أنها لم تحدث في الواقع من الأساس. كما أن صدور قرار من الإدارة بمنع الدخول أو الخروج في بلدة معينة لظهور وباء فيها، ولم يكن من حيث الواقع وجود لهذا الوباء، ففي جميع هذه الحالات يكون السبب منعدماً مما يستوجب الحكم بإلغاء القرار الإداري.

ثانياً : أن يكون السبب مشروعاً : ومعنى ذلك أنه لا يكتفى أن يكون سبب القرار الإداري موجوداً فحسب، بل يجب أيضاً أن يكون موافقاً للقانون، ومعنى ذلك أنه إذا حدد القانون للإدارة أسباباً معينة لكي تصدر قراراً إدارياً ما، فيجب على

(١) تم نشر هذه الاتفاقية بالجريدة الرسمية - العدد رقم ٦ بتاريخ ٢٠٠٧/٢/٨، ص ٣.

الإدارة أن تلتزم بهذه الأسباب عند اتخاذها لهذا القرار، وإلا كان القرار معيباً بغييب السبب، وذلك مثل تحديد القانون للإدارة سبب ترقية الموظف بالأقدمية بأن تمر على شغله لدرجته الوظيفية مدة معينة، فتقوم الإدارة بترقية الموظف قبل اكتمال هذه المدة على أساس مهارته في العمل ونشاطه، فهنا يكون سبب الترقية غير مشروع ومخالف لما نص عليه القانون.

ثالثاً : أن يكون السبب متصفاً بالوصف القانوني الصحيح : ومقتضى هذا الشرط أنه لا يكتفى فقط بوجود السبب وكونه مشروعاً، بل يجب علاوة على ذلك أن تكون الإدارة أضفت على السبب - الذي دفعها إلى إصدار القرار الإداري - الوصف القانوني السليم، وإلا كان قرارها فاقداً لشرط السبب؛ ومن ثم يكون معيباً بغييب السبب.

وذلك مثل أن تقوم الإدارة بعدم منح الترخيص بالبناء لشخص على أساس أن الأرض التي سيقوم بالبناء عليها أرض زراعية، ثم يتبين أن هذه الأرض داخلة في كردون المباني.

فهنا الإدارة بنت قرارها برفض الترخيص بالبناء على سبب أن الأرض التي سيقوم الشخص بالبناء عليها أرض زراعية وهذا سبب صحيح، لكنها أخطأت في وصف هذا السبب حيث إن الأرض داخلة في كردون المباني وليست أرض زراعية. وكالقرار الصادر من الإدارة بتوقيع جزاء تأديبي على موظف ثم يتبين أن الفعل الذي تم توقيع العقوبة على الموظف بسببه لا يشكل جريمة تأديبية.

رابعاً : أن يكون السبب ملائماً لصدور القرار : الأصل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة ألا تمتد رقابة القضاء الإداري لتشمل البحث في مدى تناسب الوقائع التي تعد سبباً لصدور قرار معين مع هذا القرار، لأن تقدير أهمية الوقائع وخطورتها مسألة تدخل ضمن نطاق السلطة التقديرية للإدارة .

إلا أن القضاء الإداري في فرنسا ومصر قرر بأن يراقب الملائمة بين السبب والقرار المبني عليه، لاسيما إذا كانت الملائمة شرطاً من شروط المشروعية وخاصة فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالحريات العامة للأفراد والقرارات التأديبية الصادرة في حق الموظفين .

وذلك مثل القرار الصادر بمنع الترخيص بعقد اجتماع معين بناءً على أسباب معينة، فيقرر القضاء أن هذه الأسباب غير ملائمة لعدم منح الترخيص بعقد الاجتماع. وكذلك أيضاً مثل القرار الصادر بالإدارة بمنع الترخيص لشخص بحمل السلاح لأسباب معينة، فيقدر القضاء أن هذه الأسباب غير ملائمة لعدم منحه هذا الترخيص. وكأن يخير القانون الإدارة بمجازاة الموظف تأديباً من بين عدة جزاءات، فيقرر القضاء أن الجزاء الذي وقعته الإدارة على الموظف لا يتناسب مع الأفعال التي أدت إلى توقيع الجزاء عليه، وكان ينبغي عليها أن توقع عليه جزاءً أقل.

وبناءً على ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في ٤ مارس ١٩٦٧م بأنه " ولئن كان للسلطات التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك - إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة - شأنها كشأن أية سلطة تقديرية أخرى - ألا يشوب استعمالها غلو ومن صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره ، فتقدير الجزاء المشوب بالغلو يخرج من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية؛ ومن ثم يخضع لرقابة القضاء الإداري" (١).

وبناءً على ما تقدم فإن القضاء الإداري في مراقبته لمدى توافر شرط السبب في القرار الإداري، فإنه يراقب مدى وجود الحالة القانونية أو الواقعية التي تمثل السبب الذي دفع الإدارة إلى إصدارها للقرار الإداري، هذا بالإضافة إلى تحققه من مشروعية السبب وأنه متفق مع ما قرره القانون، كما يراقب أيضاً الوصف الصحيح لهذا السبب ومدى ملاءمته لموضوع القرار الذي أصدرته الإدارة.

إثبات عيب السبب :

الأصل أن الإدارة غير ملزمة بذكر أسباب قراراتها استناداً إلى قرينة المشروعية التي تفترض أن قرارات الإدارة تصدر بناءً على سبب مشروع وعلى صاحب الشأن إثبات العكس، أما إذا أفصححت الإدارة عن هذا السبب في قراراتها من

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١١٤١ لسنة ١١ ق، بتاريخ ١٩٦٧/٣/٤م، المجموعة س ١٢، ص ٧٢١.

تلقاء ذاتها فإنه يجب أن يكون صحيحاً وحقيقياً. أما إذا ألزم القانون الإدارة بذكر سبب القرار؛ فيجب أن يتضمن القرار أسباب صدوره وإلا كان معيباً بغييب السبب . أما فيما يتعلق بعبء إثبات السبب، فإنه يقع على من يدعي إنعدامه أو عدم صحته، ولما كان من يدعي انعدام السبب هو من يطلب إلغاء القرار الإداري، والقضاء الإداري قد جرى على التخفيف من عبء الإثبات على الأفراد ويتساهل في توفير القرائن التي تعينهم على الإثبات.

المبحث السادس **الأثر المترتب على توافر الشروط الموضوعية** **لدعوى الإلغاء**

إذا توافرت الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء أو أحدها؛ فيحكم القاضي بإلغاء القرار الإداري لأحد العيوب التي أصابت هذا القرار، سواء تمثل ذلك في عيب عدم الاختصاص أو عيب المحل أو عيب الغاية أو عيب الشكل أو الإجراءات، أو عيب السبب.

أما إذا تخلفت هذه العيوب عن القرار الإداري، فيكون صحيحاً لتوافر جميع شروط صحته؛ ومن ثم لا يجوز الحكم بإلغائه، ويحكم القاضي في هذه الحالة برفض الدعوى ولو كانت مقبولة من ناحية الشكل.

وبالنظر إلى عيوب التي تصيب القرار الإداري نجد أن لها علاقة بالبطلان والإنعدام، والتفرقة بينهما قائمة على أساس درجة جسامة انتهاك المشروعية.

فالبطلان يلحق بالقرار الإداري الذي لم يبلغ انتهاك المشروعية فيه حداً من الجسامة؛ ومن ثم يظل القرار مرتباً لآثاره منذ نفاذه في حق المخاطبين به وواجب احترامه من قبل الأفراد إلى أن يتم الحكم بإلغائه إذا طعن عليه بالإلغاء في الميعاد المقرر قانوناً، ويتحصن من الطعن عليه بفوات هذا الميعاد.

أما الانعدام فيلحق بالقرار الإداري الذي بلغ انتهاك المشروعية فيه حداً من الجسامة، بما يفقده صفته كقرار إداري، ولا يكون إلا مجرد واقعة مادية، ولا يتحصن بفوات مواعيد الطعن، ويجوز سحبه في أي وقت، ولا تترتب المسؤولية على

الأفراد عند عدم احترامهم له، ويختص قاضي الإلغاء بتقرير انعدامه عند تبينه بلوغ مخالفة المشروعية حداً من الجسامة.

ويتعلق البطلان بجميع عيوب القرار الإداري، أما الانعدام فيتعلق بالقرار الذي فقد ركن من أركانه، والمتمثلة في ركن النية، وصدوره من سلطة إدارية، والسند القانوني له، وإحداثه أثر قانوني. كما يتعلق أيضاً ببعض عيوب القرار الإداري التي بلغت مخالفة المشروعية فيها حداً من الجسامة لدرجة أنها تمس ركن من أركان القرار الإداري، وذلك مثل عيب عدم الاختصاص عندما يكون مصدر القرار الإداري ليست سلطة إدارية أو فرد عادي ليس له أى علاقة بالإدارة، ففي هذه الحالة يمس عيب عدم الاختصاص ركن صدور القرار من سلطة إدارية.

وكذلك عيب المحل، عندما تصدر الإدارة قراراً لا تستند فيه لأى نص في القانون، كمنح الموظف علاوة تشجيعية دون الاستناد لأى نص في القانون، ففي هذه الحالة يمس عيب المحل ركن السند القانوني للقرار الإداري، فحيث ينعدم السند القانوني للقرار الإداري فينعدم القرار ذاته، أما إذا وجد السند القانوني للقرار الإداري دون أن يصدر على وفق صحيح هذا السند؛ فيكون باطلاً لا منعماً.

وفي جمع الأحوال، يحكم القاضي بإلغاء القرار الإداري سواء لحق القرار المطعون فيه البطلان أو الانعدام.

الفصل الرابع

إجراءات رفع دعوى الإلغاء والحكم فيها

للحديث عن هذا الفصل يجب أن نتناول أولاً إجراءات رفع دعوى الإلغاء، ثم نبين الحكم في هذه الدعوى، وذلك على النحو التالي :

المبحث الأول : إجراءات رفع دعوى الإلغاء.

المبحث الثاني : الحكم في دعوى الإلغاء.

المبحث الأول

إجراءات رفع دعوى الإلغاء

إن دعوى إلغاء القرارات الإدارية تمر بعدة مراحل ، هذه المراحل تمثل الإجراءات التي يلزم القيام بها من جانب رافع الدعوى أو المحكمة المختصة وتكون البداية بإيداع عريضة الدعوى قلم كتاب المحكمة وتنتهي بصدور الحكم في تلك الدعوى، سواء من حيث إلغاء القرار المطعون فيه أو رفض الدعوى.

وتتمثل إجراءات دعوى الإلغاء فيما يلي :

أولاً : تقديم عريضة الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة : يجب أن يقدم ذوي الشأن طلباً إلى قلم كتاب المحكمة المختصة وذلك بعريضة، وينبغي أن تشمل هذه العريضة على بيانات الدعوى وإعلانها إلى الجهة الإدارية وإلى ذوي الشأن حيث أن رفع الدعوى تبدأ من خلال تقديم طلب الى قلم كتاب المحكمة الادارية المختصة، ولقد جرى القضاء الاداري المصري على ضرورة تقديم دعوى الالغاء من خلال توقيع احد المحامين المقيدین بجدول المحامين، باعتبار ان ذلك من الإجراءات الجوهرية في رفع الدعوى؛ ومن ثم فإن العريضة يجب ان تشمل البيانات العامة التالية «اسم الطالب من يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحل إقامتهم موضوع الطلب، تاريخ التظلم من القرار ونتيجته، المستندات المؤيدة للطلب، صورة أو ملخص عن القرار الإداري المطعون فيه، مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب كما انه يجب علاوة على ذلك أن يودع اصل العريضة إضافة إلى عدد كافياً من صور العريضة والمذكرات وحافظة المستندات.

وتجدر الإشارة إلى أن القاعدة الأصلية توجب أن يتم تقديم طلب مستقل بكل قرار إداري بعريضة دعوي مستقلة، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي في هذا السياق قد جرى على سبيل الاستثناء بقبول الطلب بإلغاء عدة قرارات إدارية إذا ما وجدت بينهم صلة وثيقة تجمع بينهم، وما عدا ذلك فإن الدعوى تعتبر مرفوعة ضد أول القرارات الادارية المذكورة في الدعوى.

كما يجوز رفع دعوى الإلغاء والتعويض بعريضة واحدة في مصر، أما في فرنسا فلا ترفع دعوى الإلغاء إلا في عريضة مستقلة.

كما لا يجوز طلب الإلغاء الجماعي أو ما يسمى بالدعوى الجماعية، وهي التي يتم رفعها من أكثر من شخص ضد قرار إداري معين وذلك في حالة وجود الطاعنين في نفس المركز القانوني إزاء القرار المطعون فيه مثل القرارات التنظيمية المعيبة، ومن ثم يجب أن ترفع دعوى الإلغاء من كل واحد على حده، في صحيفة مستقلة.

وبالنسبة للجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض في عريضة واحدة، فلقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي كقاعدة عامة باستقلال كل دعوى بعريضة مستقلة، بينما اتجه القضاء الإداري في مصر إلى مخالفة مجلس الدولة الفرنسي في ذلك حيث أجاز الجمع بين كل من دعوى الإلغاء ودعوى التعويض في عريضة واحدة.

وتوجه عريضة دعوى الإلغاء ضد الجهة الإدارية؛ لأنها هي التي أصدرت القرار وهي أجدر بالدفاع عنه، ويعتبر ممثل الجهة الإدارية ذا الصفة في توجيه الدعوى ضده، وذلك كرئيس الجامعة فهو ممثل الجامعة بخصوص الدعاوى التي ترفع بإلغاء القرارات التي تصدرها الجامعة.

ثانياً: إعلان العريضة : يتم إعلان عريضة الدعوى ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن بعد تقديمها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، وذلك في ميعاد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول طبقاً لما نصت عليه المادة ٢٥ من قانون مجلس الدولة المصري.

وطبقاً لنص المادة ٢٦ من قانون مجلس الدولة على الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق الخاصة بها .

ويكون للطالب أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات في المهلة التي يحددها له المفوض إذا رأى وجهاً لذلك فإذا استعمل الطالب حقه في الرد كان للجهة الإدارية أن تودع مذكرة بملاحظات على هذا الرد مع مستندات في مدة مماثلة، ويجوز لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمراً غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة ويعلن الأمر إلى ذوى الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطريق البريد أو يسرى الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.

ويقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربعة وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد في الفقرة الأولى بإرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة .

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا شاب البطلان إعلان عريضة الدعوى، فإن هذا البطلان لا ينال من رفع الدعوى ذاتها، وهذا طبقاً لما ذهب إليه القضاء المصري طالما أن الدعوى قد أقيمت في خلال المواعيد الصحيحة، ولكن إذا صدر الحكم في دعوى الإلغاء على الرغم من بطلان إعلان عريضة الدعوى، فيكون هذا الحكم باطلاً لصدوره بناءً على إجراء شابه عوار جسيم، حيث إن الإعلان يعد إجراءً جوهرياً يقصد به تمكين صاحب الشأن من العلم بالخصومة ضده والدفاع عن نفسه^(١).

ثالثاً : تحضير الدعوى من قبل هيئة المفوضين : بعد تقديم عريضة الدعوى وإعلانها واستيفاء المدد المحددة في المادة ٢٦ من قانون مجلس الدولة تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة طبقاً لنص المادة ٢٧ من قانون مجلس الدولة، ولمفوض الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازماً من بيانات وأوراق وأن يأمر

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 160 لسنة 33 ق، عليا بتاريخ ١٩٩٢/٣/٣ م، منشور بالمجموعة الرسمية للمكتب الفني، السنة ٣٧، الجزء الثاني، قاعدة رقم ٩٩، ص ٩٤٧.

باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث فى الدعوى أو بتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذى يحدده لذلك .

ولا يجوز فى سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد . ومع ذلك يجوز للمفوض إذا رأى منح أجل جديد أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر ويودع المفوض - بعد إتمام تهيئة الدعوى - تقريراً يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسبباً ، ويجوز لذوى الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم . كما يفصل المفوض فى طلبات الإعفاء من الرسوم .

رابعاً : التدخل فى الدعوى : يجوز للغير أن يطلب التدخل فى الدعوى، والتدخل فى الدعوى قد يكون انضمامياً وقد يكون اختصامياً، وسنبين كلا النوعين فيما يلي :

١- **التدخل الانضمامي :** التدخل الانضمامي يهدف المتدخل من ورائه إلى المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام إلى أحد أطراف الخصومة لتقوية مركزه ودفاعه عن مصلحته. أو أن يتدخل الغير لتأييد المدعي في دعواه، كما في حالة تدخل النقابات والجمعيات إلى جانب أعضائها في الدعاوى المرفوعة منهم (١) .

٢- **التدخل الاختصامي :** يهدف المتدخل خصامياً إلى الرد على ادعاءات المدعي ودحض دعواه التي تؤثر في مصالح الغير المتدخل، وذلك كتدخل الموظف الذي صدر قرار بتعيينه في الوظيفة العامة في الدعوى التي رفعها زميله للطعن على قرار التعيين.

ويجب أن تتوفر في المتدخل جميع الشروط التي يجب أن تتوفر في المدعي في دعوى الإلغاء، وأهمها المصلحة والصفة.

والتدخل بحسب الأصل اختياري، لكن قد يكون إجبارياً كما نصت عليه المادة ٢٧ من قانون مجلس الدولة المصري من أنه : " لمفوض الدولة فى سبيل تهيئة

(١) راجع د/ ماجد الطو ، د/ محمد إمام، القضاء الإداري ٢٠١٣م، ص ٤١٨.

الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازماً من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزوم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث فى الدعوى...".

خامساً : أثر رفع الدعوى على القرار المطعون فيه : تنص المادة ٤٠ من قانون مجلس الدولة المصري على أنه : " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها . وبالنسبة إلى القرارات التى لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها ، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتاً باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادراً بالفصل ، فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء فى الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه".

ويتبين مما سبق أن رفع دعوى الإلغاء كأصل عام لا يؤثر على وقف تنفيذ القرار الإداري محل الطعن، غير أنه استثناءً من الأصل العام يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري محل الطعن إذا توافرت الشروط التالية :

- ١- أن يطلبه الطاعن صراحة في صحيفة الدعوى.
 - ٢- أن تكون نتائج تنفيذ القرار يتعذر تداركها، وهذه مسألة يقدرها القاضي على حسب ما يراه.
 - ٣- أن يستند طلب وقف التنفيذ قائم على أسباب جدية.
 - ٤- ألا يكون طلب وقف التنفيذ متعلقاً بالقرارات التي لا يقبل الطعن فيها بالإلغاء قبل التظلم منها إدارياً والتي تتمثل في القرارات الخاصة بشئون الموظفين.
- ويستثنى من ذلك حالة الفصل من الوظيفة، حيث يجوز للمحكمة بناءً على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتاً باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه، فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء فى الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه.

وإذا استوفى طلب وقف التنفيذ شروطه السابقة، فيجوز للمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالإلغاء، وهذا الحكم يعد حكماً مؤقتاً ويحوز قوة الشيء المحكوم فيه، ويجوز الطعن فيه استقلاً، غير أنه معلق على نتيجة الحكم الصادر في دعوى الإلغاء؛ ومن ثم إذا قررت المحكمة في دعوى الإلغاء رفض الدعوى لمشروعية القرار الإداري، فيزول أثر الحكم الصادر بوقف تنفيذ هذا القرار، أما إذا حكمت المحكمة بإلغاء هذا القرار، فيتأكد هذا الحكم ويعدم القرار الإداري الموقوف تنفيذه للأبد.

سادساً : انتهاء الخصومة بالتنازل أو التصالح : فيما يتعلق بترك الخصومة

وانتهائها، فإنه يحق للمدعي التنازل وذلك عن طريق التنازل عن عريضة الدعوى التي تقدم بها طالباً فيها إلغاء القرار الإداري، وهو ما يعرف بترك الخصومة في المنازعة الإدارية.

وليس معنى ذلك التنازل أن يمتد إلى التنازل عن حق النقاضي بدعوى الإلغاء، حيث إن مثل هذا التنازل يعد باطلاً لكونه يقع على حق يتعلق بالنظام العام. كما تنتهي الخصومة إذا استجابت الإدارة لطلبات المدعي أثناء نظر الدعوى، حيث إن الخصومة في هذه الحالة تصبح غير ذات موضوع ويتعين الحكم باعتبارها منتهية، ومن ثم لا يجوز طرح هذه الخصومة من جديد لسبق تسويتها ودياً بين الطرفين.

وأخيراً إذا استمر القاضي الإداري في نظر الدعوى واستوفت شرائطها وإجراءاتها، وكانت صالحة للحكم فيها؛ فلذوي الشأن حجزها للحكم؛ ومن ثم تحدد المحكمة جلسة للنطق بالحكم، وعليه سنقوم بدراسة الحكم الصادر من المحكمة في مطلب التالي.

المبحث الثاني

الحكم في دعوى الإلغاء

الحكم القضائي بصفة عامة : هو القرار القانوني الصادر في الشكل الذي يحدده القانون من جهة لها ولاية القضاء حسماً لنزاع رفع إليها، ويبين فيه حكم القانون ، ويكون له قوة النفاذ والتنفيذ والإلزام.

وللحديث عن الحكم في دعوى الإلغاء ينبغي أن نبين أولاً منطوق الحكم في دعوى الإلغاء، ثم نبين حجية الحكم في دعوى الإلغاء، ثم نبين آثار الحكم الصادر في دعوى الإلغاء، وأخيراً نبين الطعن في الحكم الصادر في دعوى الإلغاء. وذلك أربعة مطالب على النحو التالي :

المطلب الأول : منطوق الحكم الصادر في دعوى الإلغاء.

المطلب الثاني : حجية الحكم الصادر في دعوى الإلغاء.

المطلب الثالث : آثار الحكم الصادر في دعوى الإلغاء.

المطلب الرابع : الطعن في الحكم الصادر في دعوى الإلغاء.

المطلب الأول

منطوق الحكم الصادر في دعوى الإلغاء

نفرد في هذا الصدد بين الشروط الشكلية والشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء، فالشروط الشكلية والموضوعية لدعوى الإلغاء إذا توافرت فيحكم القاضي بقبول الدعوى شكلاً، أما إذا لم تتوافر الشروط الشكلية لرفع دعوى الإلغاء، فيترتب عليها أن يحكم القاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً، وتختلف علة عدم قبول الدعوى شكلاً باختلاف الشرط الشكلي الذي لم يتوافر في القرار الإداري، فالقرار الصادر من الإدارة ولم تتوافر فيه أركانه وطعن فيه أمام القضاء الإداري؛ يترتب عليه أن يحكم القاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتهاء القرار الإداري، وكذلك إذا رفعت الدعوى من غير ذي مصلحة أو صفة فيحكم القاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذي مصلحة أو صفة، وكذلك إذا لم تراعى مواعيد رفع دعوى الإلغاء؛ فيحكم القاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.

أما بخصوص الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء، فيترتب على توافرها كلها أو بعضها، أن يحكم القاضي بإلغاء القرار الإداري، سواء لعيب الاختصاص أو المحل أو الشكل أو الغاية أو السبب.

أما إذا لم تتوافر هذه الشروط بأن كان القرار الإداري صحيحاً من كل الجوانب وتوافرت فيه جميع شروط صحته والتي تتمثل في الاختصاص والمحل والشكل والغاية والسبب؛ فيحكم القاضي برفض الدعوى المقامة لإلغاء القرار الإداري.

وبناءً على ما تقدم : قد يكون منطوق الحكم في دعوى الإلغاء "قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري" وهنا تكون الشروط الشكلية والموضوعية لدعوى الإلغاء قد توافرت.

وقد يكون المنطوق "قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً" وهنا تكون الشروط الشكلية لدعوى الإلغاء قد توافرت مع عدم توافر شروطها الموضوعية".

وقد يكون المنطوق "عدم قبول الدعوى شكلاً" وهنا تكون الشروط الشكلية لدعوى الإلغاء أو بعضها غير متوافرة، وفي منطوق هذا الحكم لا يتطرق القاضي في حكمه لموضوع الدعوى وبحث توافر أو عدم توافر الشروط الموضوعية، بل يقتصر فقط على بيان عدم توافر الشروط الشكلية لدعوى الإلغاء أو أحدها.

ومنطوق الحكم الصادر في دعوى الإلغاء يجب أن يبين القاضي أسبابه في الحكم ذاته، وأن تكون هذه الأسباب صحيحة بحيث تكون من شأنها التوصل إلى هذا المنطوق.

وتقتصر سلطة القاضي الإداري على بحث مدى مشروعية القرار الإداري محل الدعوى ويصدر منطوق حكمه بالإلغاء أو رفض الدعوى، دون يوجه أوامر للإدارة؛ لتتافي ذلك مبدأ الفصل بين السلطات.

المطلب الثاني

حجية الحكم الصادر في دعوى الإلغاء

تحوز الأحكام القضائية حجية الشيء المحكوم به، ويقصد بهذه الحجية القرينة القانونية غير القابلة لإثبات العكس مؤداها أن الحكم قد صدر صحيحاً من ناحية الشكل والموضوع، ويعد حجة على ما قضى به، ولو كان قابلاً للطعن فيه، وتكون هذه الحجية مؤقتة تزول إذا تم إلغاء الحكم، وتثبت إذا أصبح باتاً، وإذا رفعت الدعوى مرة أخرى عن ذات النزاع، فلذوي الشأن الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها، وهو دفع من الدفوع المتعلقة بعدم القبول^(١). وتحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها.

(١) راجع المستشار : محمد عبد الغني حسن : قواعد وإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص ٤٠٩، ٤١٠.

ولدراسة حجية الحكم الصادر في دعوى الإلغاء، نبين القاعدة العامة في أحكام القضاء الإداري، ثم نبين حجية الحكم الصادر في دعوى الإلغاء.

أولاً : حجية الأحكام الصادرة من القضاء الإداري :

وان الأصل في أحكام القضاء الإداري أنها تحوز على حجية الشيء المحكوم به، كما أن القاعدة العامة في ذلك أن هذه الحجية نسبية ، بمعنى اقتصار الاحتجاج بها على أطرافها فقط، ويشترط لإعمال الحجية توافر ثلاثة شروط هي وحدة الخصوم والسبب والموضوع؛ ولهذا لا يجوز للخصم نفسه أن يقدم دعوى جديدة بالموضوع ذاته واستناداً لذات للسبب.

ثانياً : حجية الحكم الصادر في دعوى الإلغاء : نفرق في هذا الصدد بين

حجية الحكم الصادر برفض إلغاء القرار الإداري، وبين الحكم الصادر بالإلغاء.

١- حجية الحكم الصادر برفض إلغاء القرار الإداري : يتمتع الحكم الصادر

برفض إلغاء القرار الإداري بحجية مطلقة من حيث بقاء القرار الإداري في الحياة القانونية حاكماً للعلاقة التي صدر بصدها. غير أنه يتمتع بحجية نسبية من حيث إمكانية إثارة النزاع مرة أخرى للمطالبة بإلغائه، حيث يقتصر أثر الحكم بالرفض على من صدر الحكم قبله فقط؛ ويشترط لإعمال هذه الحجية النسبية وحدة الخصوم والموضوع والسبب.

وفي ذلك تقول محكمة القضاء الإداري : " الحكم برفض الطعن بالإلغاء فإن

حجيته مقصورة على طرفيه، ذلك لأنه قد يكون صائباً بالنسبة إلى الطاعن وخاطئاً بالنسبة إلى غيره، كما إذا قدم موظف طعناً بإلغاء ترقية موظف آخر على أساس أنه أحق منه بالترقية فقضى برفض طعنه، فإن هذا القضاء لا يمنع من أن يكون الموظف الذي رقى قد تخطى شخصاً آخر بغير حق ولا يجوز في هذه الصورة أن يعتبر الحكم حجة على هذا الأخير إذ طالب بإلغاء القرار" (١).

(١) حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 884 : لسنة 5 ق، بتاريخ ١١/٢٩/١٩٥٣م، المجموعة ، ص ٨، ص ١٢٧ .

٢- **حجية الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري :** إذا كان الحكم الصادر برفض دعوى الإلغاء يحوز حجية نسبية، فإن الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري يحوز حجية مطلقة، ومن ثم يكون حجة على الجميع خصوم الدعوى وغيرهم. وترجع العلة في تقرير الحجية المطلقة لحكم إلغاء القرار الإداري إلى انتهاء دعوى الإلغاء إلى القضاء الموضوعي أو العيني، حيث تقوم الدعوى على أساس اختصام القرار الإداري لإصابته بعيب من العيوب، كما أن الحكم بالإلغاء يؤدي إلى إعدام القرار الإداري سواء كان هذا القرار تنظيمياً أم فردياً بأثر رجعي واعتباره كأن لم يكن، مثله في ذلك مثل سحب القرار الإداري من جهة الإدارة، ومن ثم فليس من المنطقي أن يصدر حكم الإلغاء حائزاً لحجية نسبية، لأن معنى ذلك يؤدي إلى نتيجة غير منطقية مفادها أن القرار يعتبر معدوماً في مواجهة البعض وقائماً في مواجهة الآخرين، وهذا مخالف للواقع.

ونصت على الحجية المطلقة لدعوى الإلغاء المادة رقم (٥٢) من قانون مجلس الدولة الحالي، والتي قررت بأن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على كافة. ويحوز الحكم الصادر بالإلغاء الحجية المطلقة سواء كان الإلغاء كاملاً للقرار الإداري، أو جزئياً بإلغاء القرار فيما تضمنه من جزئه غير المشروع، وذلك كإلغاء القرار فيما تضمنه من تخطى المدعي في التعيين أو الترقية. والحجية المطلقة لحكم الإلغاء تمنع من إثارة الدعوى مرة أخرى ضد القرار الذي صدر الحكم بإلغائه سواء من الخصوم الذين صدر الحكم في مواجهتهم أو غيرهم، وهنا تقترب دعوى الإلغاء من دعوى الحسبة التي يمثل فيها الفرد مصلحة الجماعة.

ولقد قررت المحكمة الإدارية العليا الأحكام السابقة فقالت : "إن حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء... هي حجة عينية كنتيجة طبيعية لإعدام القرار الإداري في دعوى هي في حقيقتها اختصاص له في ذاته ، إلا أن مدى الإلغاء يختلف بحسب الأحوال فقد يكون شاملاً لجميع أجزاء القرار، وهذا الإلغاء الكامل، وقد يقتصر الإلغاء على جزء منه دون باقيه، وهذا هو الإلغاء الجزئي ، كأن يجرى الحكم بإلغاء القرار فيما تضمنه من تخطى المدعي في الترقية . و غنى عن البيان أن مدى الإلغاء أمر يحدد

بطلبات الخصوم و ما تنتهى إليه المحكمة فى قضائها . فإذا صدر الحكم بالإلغاء كلياً أو جزئياً فإنه يكون حجة على الكافة ، وعلّة ذلك أن الخصومة الحقيقية فى الطعن بالإلغاء تنصب على القرار الإدارى ذاته وتستند على أوجه عامة حددها القانون ... وكل وجه منها له من العموم فى حالة قبول الطعن ما يجعل القرار المطعون فيه باطلاً لا بالنسبة للطاعن وحده ، بل بالنسبة للكافة ، فهو بطلان مطلق . وما من شك فى أن المساواة بين الأفراد والجماعات فى تطبيق القواعد العامة المستفادة من حكم الإلغاء تقتضى وجوباً أن يكون حكم الإلغاء حجة على الكافة حتى يتقيد الجميع بآثاره . وينبنى على ما تقدم أنه إذا ألغى مجلس الدولة قراراً إدارياً ثم أقام طاعن آخر دعوى أخرى أمام مجلس الدولة بإلغاء ذات القرار كانت الدعوى الثانية غير ذات موضوع ، باعتبار ذلك إحدى نتائج الحجية المطلقة للشئ المقضى به فى حكم الإلغاء، وكذلك من لم يختصم فى الدعوى تصيبه آثار الحكم بالإلغاء بوصف أنه من الكافة و تكون الإدارة على صواب فى تطبيقه فى شأنه ، ذلك لأن دعوى الإلغاء أشبه بدعوى الحسبة يمثل فيها الفرد مصلحة المجموع^(١).

وتتعلق حجية الحكم الصادر بالإلغاء بالنظام العام، وذلك لاتصال هذا الحكم باستقرار الأوضاع والمراكز القانونية التى حسمها فى منطوقة، فلا تجوز العودة إلى إثارة النزاع مرة أخرى حتى لا تتزعزع الأوضاع التى استقرت بصور حكم الإلغاء

المطلب الثالث

آثار الحكم الصادر فى دعوى الإلغاء

ليبان آثار الحكم الصادر فى دعوى الإلغاء ينبغى أن نفرق بين الحكم المستعجل والحكم الموضوعي، ثم نبين تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء وجزاء تعطيله، وأخيراً الإشكال فى تنفيذه.

أولاً: التفرقة بين الحكم المستعجل والموضوعي من حيث الآثار: الحكم المستعجل فى دعوى الإلغاء كما علمنا حكم وقتي لا يصير نهائياً إلا بصور الحكم الموضوعي فى دعوى الإلغاء، فإذا حكم القاضي فى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم ٤٧٥ لسنة 5 ق، بتاريخ ١١/٢٦/١٩٦٠م، المجموعة، س٦، الجزء ١، ص ٢٠١ .

القرار المطعون فيه، فإن هذا الحكم يعتبر حكماً وقتياً يشمل عملية تنفيذ القرار بالنسبة للمستقبل فقط ولا يتأكد إلا بصدور الحكم الموضوعي بإلغاء القرار بحيث يعتبر القرار في هذه الحالة كأن لم يكن، أما إذا حكم القاضي برفض الدعوى؛ فيزول ما للحكم المستعجل بوقف تنفيذ القرار الإداري من أثر، ومن ثم يثبت القرار الإداري ويعود للنفاذ مرة أخرى.

أما الحكم الموضوعي في دعوى الإلغاء بإلغاء القرار الإداري فإنه يعدم هذا القرار بأثر رجعي ويزول من ثم من الحياة القانونية، وعليه فإن الإلغاء القضائي له أثر رجعي وحال ومستقبلي، حيث يؤثر على القرار محل دعوى الإلغاء بالنسبة للماضي والمستقبل بحيث كون كأن لم يكن.

ولقد أكدت المحكمة الإدارية العليا الأحكام السابقة فقررت بأن الحكم بوقف التنفيذ ليس له أثر رجعي، ومن ثم عندما ينتج القرار المتنازع بوقف كل آثاره القانونية، بحسبان أن حكم وقف التنفيذ يرمي إلى شل آثار القرار المتنازع عليه مؤقتاً بالنسبة للمستقبل والحفاظ على الوضع الراهن كما هو لحين الفصل بالإلغاء، بينما يترتب على الحكم بالإلغاء تعديل المراكز القانونية التي نشأت على أثر صدور القرار الملغي^(١)، لسريانه بأثر رجعي واعتباره كأن لم يكن.

ثانياً : تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء وجزاء تعطيله : إذا كان يترتب على الحكم الصادر بالإلغاء اعدام القرار الإداري محل الطعن بالإلغاء بأثر رجعي، فهذا يترتب التزاماً على الإدارة بضرورة تنفيذ منطوق الحكم وإعادة الحال إلى ما كان عليه وكأن القرار لم يصدر أبداً، ولا يجوز للإدارة أن تصدر قراراً جديداً تردد فيه مضمون القرار المحكوم بإلغائه حيث يدخل ذلك في عداد عدم تنفيذ حكم الإلغاء. وتنفيذ حكم الإلغاء يكون بالصورة التنفيذية للحكم، قد نصت المادة ٥٤ من قانون مجلس الدولة على أن تكون الصورة التنفيذية للأحكام الصادرة بالإلغاء مشمولة بالصيغة التنفيذية التالية : "على الوزراء ورؤساء المصالح المختصة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه".

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٧١٤ لسنة ٤٤٤ ق، بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٠٤م، المجموعة، س ٥٠، الجزء ١، ص ٩٩.

وبناءً على ما تقدم : إذا امتنعت الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء فإن الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم يتعرض لجزاء جنائي ومدني.

فالجزاء الجنائي نصت عليه المادة ١٢٣ من قانون العقوبات المصري والتي قررت بأنه : "بأنه : يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة. وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذاً للحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف".

أما الجزاء المدني فيتمثل في التعويض الذي يتقاضاه المضرور من عدم تنفيذ حكم الإلغاء، بناءً على الحكم الصادر في دعوى التعويض المؤسّسة على خطأ الموظف الشخصي المتمثل في عدم تنفيذ الحكم الصادر في دعوى الإلغاء.

وعلى الرغم مما تقدم : إلا أن القضاء أجاز للإدارة أن تقوم بعدم تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء إذا كان يترتب على هذا التنفيذ الإضرار بالمصلحة العامة.

ثالثاً : الإشكال في تنفيذ حكم الإلغاء : يقصد بإشكالات التنفيذ تلك المنازعات التي تتعلق بإجراءات التنفيذ ويترتب على الحكم فيها أن يصبح التنفيذ جائزاً أو غير جائز، ومبناها دائماً وقائع لاحقة على صدور الحكم.^(١)

ولقد نصت على اختصاص مجلس الدولة المصري بمنازعات التنفيذ ومنها المنازعات في تنفيذ الأحكام الصادرة بوقف أو إلغاء القرار الإداري المادة ١٩١ من الدستور، حيث نصت على أن : "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه...".

واتساقاً مع الدستور الحالي لعام ٢٠١٤ قام مجلس النواب بإصدار قانوناً بتعديل قانون مجلس الدولة المصري رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢م، بإضافة المادة (٥٠ مكرر)، حيث أضافت المادة الثالثة من قانون التعديل المادة ٥٠ مكرر والتي تنص على أن : "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ

(١) المستشار/ سمير يوسف البهي: دفوع وعوارض الدعوى الإدارية، ط٤، ٢٠١٢م، بدون دار نشر، ص ١٧٩.

المتعلقة بالأحكام الصادرة منها ويرفع الإشكال إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم ويترتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه وتفصل المحكمة فى الإشكال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إقامته دون أخذ رأى هيئة مفوضى الدولة ولا يترتب على رفع الإشكال أمام أية محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم".

ويتبين من نص المادة المضافة بقصر اختصاص الفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكام مجلس الدولة عليه دون غيره ، حيث قصرت الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة على المحاكم التي أصدرت الحكم دون غيرها، ورتبت على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه.

وأوجب هذه المادة على المحكمة أن تفصل فيه خلال ٣٠ يوماً من إقامته، وذلك دون أخذ رأى هيئة مفوضى الدولة، على أن يظل الأثر الواقف للإشكال منتجاً لآثاره حتى تفصل فيه المحكمة المختصة أو تصدر دائرة فحص الطعون المختصة بالمحكمة الإدارية العليا أو محكمة القضاء الإداري - بحسب الأحوال - حكمها في طلب وقت تنفيذ الحكم المنظور أمامها، ولا يترتب على رفع الإشكال أمام أي محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم.

وقبل هذا التعديل كان الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر من إحدى محاكم مجلس الدولة المصري موقفاً لتنفيذه ، وتختص به محكمة القضاء الإداري؛ وذلك بحسبان أن منازعة التنفيذ هنا منازعة إدارية، ومحكمة القضاء الإداري صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية.

ولقد تم النص في القانون المعدل لقانون مجلس الدولة على استمرار محكمة القضاء الإداري في نظر الدعوى المقامة أمامها، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الإدارية، متى كانت مهياًة للفصل فيها؛ وقررت هذه الأحكام المادة الرابعة من قانون التعديل، حيث نصت على أنه : " تستمر محكمة القضاء الإداري فى نظر الدعوى المقامة أمامها والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الإدارية متى كانت مهياًة للفصل فيها".

ومن ثم فإن لمحكمة القضاء الإداري أن تفصل في إشكالات التنفيذ المرفوعة أمامها والتي أصبحت من اختصاص محكمة إدارية أخرى من محاكم مجلس الدولة بحسبان أنها التي أصدرت الحكم، وذلك متى كانت مهياًة للفصل فيها، وأما إذا لم تكن مهياًة للفصل فيها، فتفصل في الإشكال المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل في تنفيذه.

المطلب الرابع

الطعن في الحكم الصادر في دعوى الإلغاء

توجد عدة طرق للطعن على الأحكام الإدارية بصفة عامة، والحكم الصادر في دعوى الإلغاء بصفة خاصة، وهذه الطرق تتمثل في : الطعن بالاستئناف، والطعن بالنقض، والتماس إعادة النظر، ومعارضة الخصم الثالث، وطلب تصحيح الأخطاء المادية، وطلب تفسير الحكم.

أولاً : استئناف الحكم الصادر في دعوى الإلغاء : يجوز للإدارة أو المدعي في دعوى الإلغاء أو رئيس هيئة مفوضي الدولة أن يستأنف الحكم الصادر في هذه الدعوى، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم، وهذا الطريق يعد من الطرق العادية للطعن على الأحكام.

ويكون استئناف الأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء من المحاكم الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري باعتبارها محكمة ثاني درجة.

وقد نصت المادة ١٣ من قانون مجلس الدولة على ذلك فقررت بأنه : "تختص محكمة القضاء الإداري... بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم".

ثانياً : الطعن بالنقض أمام المحكمة الإدارية العليا : من الطرق الطعن غير العادية الطعن بالنقض، ويجوز لذوي الشأن ورئيس هيئة مفوضي الدولة الطعن بالنقض في الحكم الصادر في دعوى الإلغاء من محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم، وذلك في الأحوال التالية :

- ١- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله
- ٢- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم
- ٣- إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .

ولا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري باعتبارها ثاني درجة إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة، إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أو كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره من قبل.

ولقد نصت على الأحكام السابقة المادة ٢٣ من قانون مجلس الدولة فقالت: " يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية :

- ١- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله
- ٢- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
- ٣- إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .

ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم .

أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس مفوضي الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره" .

ثالثاً : الطعن بطريق التماس إعادة النظر : التماس إعادة النظر في الحكم الصادر في دعوى الإلغاء يعد من طرق الطعن غير العادية، ويجوز الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري

والمحاكم التأديبية، أما المحكمة الإدارية العليا، فلا يجوز الطعن في أحكامها بهذا الطريق، ولا يترتب على سلوك هذا الطريق وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بالوقف.

والتماس إعادة النظر بمقتضاه يطعن ذوي الشأن في الحكم أمام المحكمة التي أصدرته إذا كان معيباً بأحد العيوب التي نص عليها القانون، وذلك حتى تعيد النظر فيه وتعدله أو تلغيه بعد اكتشاف العيب الذي تضمنه أو بنى عليه الحكم المطعون فيه^(١).

وقد نصت على هذا الطريق المادة ٥١ من قانون مجلس الدولة فقالت : "يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات المنظورة أمام هذه المحاكم .

ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيهاً فضلاً عن التعويض إذا كان له وجه" .

رابعاً : معارضة الخصم الثالث : يجوز للغير الذي لم يكن طرفاً في دعوى الإلغاء وتعدى أثر الحكم في دعوى الإلغاء إليه أن يطعن في الأحكام النهائية الصادرة في دعوى الإلغاء، وذلك إذا لم يكن يعلم بقيام الخصومة، أو لم يكن في مركز يسمح له بتوقعها، وإلا لا يقبل طعنه.

ولقد قرر هذا الطريق لكفالة حق التقاضي للشخص الذي لم يكن طرفاً في الخصومة وانغلق عليه طرق الطعن أمام محكمة أخرى.

ولقد قررت المحكمة الإدارية الأحكام السابقة فقضت بأنه: "الحكم الذي يصدر بالإلغاء يعتبر حجة على الكافة وليست حجته نسبية تقتصر على طرفي الخصومة دون غيرهما وإنما حجته مطلقة تتعدى إلى الغير أيضاً، وذلك وفقاً لما حرصت على تأكيده جميع التشريعات المتتالية لمجلس الدولة ، إلا أن من الأصول المسلمة التي

(١) د/ فؤاد النادي : القضاء الإداري، مرجع سابق، ص ٥٣٨.

يقوم عليها حسن توزيع العدالة وكفالة تأدية الحقوق لأربابها ألا يحول دون ذلك صدور حكم حاز حجية الأمر المقضى بمقولة إن حكم الإلغاء يكتسب حجية عينية تسرى على الكافة متى كان أثر هذا الحكم يتعدى أطراف الخصومة وهم ذو الشأن الممثلون فيها الذين عناهم نص المادتين ١٥ ، ٣٣ من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ الخاص بمجلس الدولة بما تضمنه من تحديد ميعاد الطعن بالنسبة إليهم بستين يوماً من تاريخ صدور الحكم، بحيث يمس بطريقة مباشرة حقوقاً و مصالح ومركز قانونية مستقرة للغير الذي كان يتعين أن يكون أحد الطرفين الأصليين في المنازعة، ومع ذلك لم توجه إليه ولم يكن مركزه يسمح له بتوقعها أو العلم بها حتى يتدخل فيها في الوقت المناسب - إذ لا مناص من رفع ضرر التنفيذ عن هذا الغير ، الذي لم يكن طرفاً في المنازعة ، و ذلك بتمكينه من التداعي بالطعن في هذا الحكم من تاريخ علمه به حتى يجد له قاضياً يسمع دفاعه و ينصفه إن كان ذا حق في ظلامته مادام قد استغلق عليه سبيل الطعن في هذا الحكم أمام محكمة أخرى ، وذلك كي لا يغلق عليه نهائياً وهو الحسن النية الأجنبي عن المنازعة التي صدر فيها الحكم سبيل الالتجاء إلى القضاء، والقول بغير هذا فيه حرمان لصاحب المصلحة الحقيقية من حق اللجوء إلى القضاء تظلاً من حكم في منازعة لم يكن طرفاً فيها ، و لم يعلم بها و مست آثار هذا الحكم حقوقاً له .

وبناء على ما تقدم يكون للطاعن مصلحة حقيقية في المنازعة باعتباره صاحب الصيدلية التي قضى بإلغاء القرار الصادر بالترخيص بفتحها ، وهو لم يختص ولم يتدخل أمام القضاء الإداري لعدم علمه بها وقتئذ ويتعدى أثر هذا الحكم إليه ، فمن ثم، و تأسيساً على ما تقدم ، يجوز له الطعن في الحكم المشار إليه خلال ستين يوماً من تاريخ علمه به^(١).

خامساً : طلب تفسير الحكم الصادر في دعوى الإلغاء : أجاز قانون المرافعات لذوي الشأن أن يطلبوا تفسير ما وقع في منطوق الأحكام أو أسبابها من غموض أو إبهام؛ ومن ثم إذا شاب الحكم الصادر في دعوى الإلغاء غموض أو إبهام

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٩٧٧ لسنة ٧ق، بتاريخ ١٢/٢٣/١٩٦١م، المجموعة، س٧، الجزء ١، ص ١٥٥ .

في منطوقه أو أسبابه، فيجوز لذوي الشأن طلب تفسيره، بحيث تقوم المحكمة بالتفسير فقط دون استكمال نقص أو اتخاذ التفسير ذريعة لتعديله.

ولقد قررت المحكمة الإدارية العليا الأحكام السابقة فقضت بأن : "المشرع أجاز في المادة ٣٦٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام . وذلك بطلب يقدم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى ، و نص في المادة ٣٧٧ منه على أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً لحكم الذي يفسره أى ليس حكماً مستقلاً ، ومفاد ذلك أن طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد في منطوقه، وهو الذى يحوز حجية الشئ المقضى به أو قوته دون أسبابه إلا ما كان من هذا الأسباب مرتبطاً إرتباطاً جوهرياً ومكوناً لجزء منه مكملاً له . لما لا يكون إلا حيث يقع في هذا المنطوق غموض أو إبهام يقتضى الإيضاح و التفسير لإستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم ابتغاء الوقوف على حقيقة المراد منه حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد" (١) .

سادساً : طلب تصحيح الأخطاء المادية : وفقاً للمادة ١٩١ من قانون المرافعات المصري يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم من تلقاء نفسها تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في منطوق الحكم، كما يجوز لذوي الشأن اللجوء للمحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيح هذا الخطأ ، كأن توجد أخطاء كتابية أو حسابية، وتصدر المحكمة قرار بتصحيح هذه الأخطاء، ولا يجوز أن تتخذ المحكمة التصحيح ذريعة لتعديل حكمها أو تفسيره.

ولقد قررت المحكمة الإدارية العليا الأحكام السابقة فقضت بأن : "المادة ١٩١" من قانون المرافعات تقضى بأن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع بحكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية و ذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه رئيس المحكمة، و جرى قضاء محكمة النقض تفسيراً لهذا النص

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٨٩٧ لسنة ٧ق، بتاريخ ١٩/٤/١٩٦٨م، المجموعة، س٩، الجزء ٢، ص ٩٩٤ .

على أن الأصل في تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة في القانون لا بدعوى مبتدأه وإلا انهارت قوة الشئ المحكوم فيه وأتخذ التصحيح تكة للمساس بحجيتها، واستثناء من هذا الأصل أجاز القانون تصحيح ما عساه يقع فى منطوق الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفس المحكمة، أما ما عدا هذه الأخطاء المادية المحضة التى تكون قد أثرت على الحكم فيكون سبيل إصلاحها بالطعن فى الحكم بطريق الطعن المناسب كما جرى قضاء هذه المحكمة، على أنه وإن كانت المحكمة الإدارية تستنفذ ولايتها بإصدار حكمها، إلا أنها تملك تصحيح ما وقع فى المنطوق أو فى الأسباب الجوهرية التى تعتبر متممة له من أخطاء مادية أو كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوى الشأن، ولا يعتبر الحكم المصحح معدلاً للحكم الذى يصححه بل متمماً له، فإذا جاوزت المحكمة حدود ولايتها فى التصحيح إلى التعديل أو التفسير كان حكمها مخالفاً للقانون" (١) .

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم ٢٨٥ لسنة ١٥ ق، بتاريخ ٤/٤/١٩٧٦م، المجموعة، س ٢١، الجزء ١، ص ١١٨ .

الباب الثاني

القضاء الدستوري

على اعتبار أن الدستور يتربع على قمة الهرم القانوني في الدولة؛ فمن ثم لا يجوز مخالفته من أى سلطة من سلطات الدولة، وبصفة خاصة، السلطة التشريعية، فإذا أصدرت السلطة التشريعية قوانين، فيجب أن تلتزم بنصوص الدستور؛ حيث إنها تسمو على غيرها من القواعد القانونية.

والدول التي تأخذ بنظام الرقابة على دستورية القوانين تنشئ جهة تباشر مهمة الرقابة على دستورية القوانين، وهذه الجهة قد تُسند إليها اختصاصات أخرى بالإضافة إلى اختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين، وسوف تقتصر دراستنا في هذا الباب على اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة على دستورية القوانين.

ولدراسة الرقابة على دستورية القوانين، ينبغي أن نبين، مفهوم الرقابة على دستورية القوانين وأنواعها، وأخيراً، نبين أثر القرار الصادر بعدم الدستورية على القانون غير الدستوري، وذلك من خلال فصلين على النحو التالي :

الفصل الأول : مفهوم الرقابة على دستورية القوانين وأنواعها.

الفصل الثاني : أثر القرار الصادر بعدم الدستورية على القانون غير

الدستوري.

الفصل الأول

مفهوم الرقابة على دستورية القوانين وأنواعها

تعتبر الرقابة التي تباشر على القوانين العادية بقصد التأكد من احترامها للقواعد الواردة في الوثيقة الدستورية وعدم مخالفتها لأحكامها، من أهم الوسائل القانونية التي تكفل نفاذ القانون الدستوري وتطبيقه تطبيقاً سليماً^(١).

وسوف نقوم بدراسة هذا الفصل من خلال ثلاثة مباحث على النحو التالي :

المبحث الأول : مفهوم الرقابة على دستورية القوانين.

المبحث الثاني : أنواع الرقابة على دستورية القوانين.

المبحث الأول

مفهوم الرقابة على دستورية القوانين

ويقصد بالرقابة على دستورية القوانين، ألا يخالف قانون حكماً مقررأ في الدستور، على أساس أن الدستور هو مستقر الشرعية في الدولة، وبالتالي فإن جميع القواعد الملزمة في نطاقها يجب ألا تخالف حكماً من أحكامه^(٢).
أو هي التحقق من تطابق القوانين العادية أو الأساسية التي تصدرها السلطة التشريعية مع أحكام الدستور ونصوصه، وعدم تعارض أى قانون عادى مع قانون أعلى منه وإلا عد هذا القانون باطلاً، وهذا البطلان أمر طبيعى ونتيجة منطقية مترتبة على مبدأ علو الدستور^(٣).

وتأسيساً على ما تقدم : تعد الرقابة على دستورية القوانين نتيجة منطقية لمبدأ سمو الدستور La suprématie de la constitution الذي يفترض أن يكون الدستور هو قمة النظام القانوني في الدولة. ويقصد بهذا المبدأ أن القواعد الدستورية تعلو على ما عداها من قواعد قانونية داخل الدولة وتلتزم سائر السلطات باحترامها في كل ما يصدر عنها من أعمال، سواء كانت تشريعية أم قضائية أم تنفيذية. ويعد

(١) راجع الدكتور/ رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية ٢٠٠٥م، ص ٦٥٢.

(٢) راجع الدكتور/ سليمان الطماوى، الأساليب المختلفة لرقابة دستورية القوانين، مجلة العلوم الإدارية السنة الثانية والثلاثون، ديسمبر، ١٩٩٠م، ص ٧.

(٣) راجع أستاذنا الدكتور/ عبد العظيم عبد السلام : الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة، مطبعة حمادة، قويسنا، ص ١١، ١٢.

هذا المبدأ نتيجة منطقية لمبدأ آخر وهو مبدأ تدرج التشريعات « la hiérarchie .des règles de droit” ou “La hiérarchie des norms”

وقد أكد هذا المبدأ القاضي مارشال رئيس المحكمة العليا الأمريكية منذ القدم في قضية ماربري ضد ماديسون بقوله: (إنه لا جدال في عدم تطبيق القانون العادي إذا ما تعارض مع أحكام الدستور باعتبار أن هذا الأخير هو التشريع الأعلى الذي تنضبط في نطاقه حدود ممارسة السلطات المختلفة على الوجه الذي رسمته إرادة الأمة وارتفعت به إلى حيث يكون مستعصياً على التعديل بالوسائل التشريعية الأدنى منه، فإن جنحت السلطة التشريعية إلى غير ذلك كان جزاء خروجها البطلان، وليس في رفض السلطة القضائية تطبيق قانون مخالف للدستور أي تجاوز أو اعتداء على السلطة التشريعية، بل هي إذ تفعل إنما تمارس وظيفتها في حل المشكلات الناجمة عن تعارض القوانين المتصلة بالنزاع المطروح مع ما يعلوها من القواعد الدستورية)^(١).

فالدستور يتميز بطبيعة خاصة تطفئ عليه صفة السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامه وحق لقواعده أن تستوي على القمة من البناء القانوني للدولة، وأن تتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الأمرة التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعها وفي قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية، ذلك أن سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية كلها سلطات مؤسسة أنشأها الدستور، تستمد منه وجودها وكيانها وهو المرجع في تحديد وظائفها^(٢).

وضمن إعمال مبدأ سمو الدستور يستلزم وجود وسيلة تضمن عدم الخروج على قواعد الدستور ومبادئه، والرقابة على دستورية القوانين تعد من أهم الوسائل القانونية والفنية لحماية مبدأ سمو الدستور. فمما لا شك فيه أن مبدأ سيادة الدستور وسموه سيظل نظرياً إذا لم يكمله مبدأ الرقابة على دستورية القوانين، وذلك حتى يتحقق

(١) راجع الدكتور/ رمزي طه الشاعر، رقابة دستورية القوانين دراسة مقارنة مع دراسة تحليلية للقضاء الدستوري في مصر، بدون دار نشر سنة ٢٠٠٤م، ص ٩٩، ١٠٠.

(٢) راجع/ حكم المحكمة الدستورية العليا في ١٩ مايو ١٩٩٠م، مجموعة أحكام المحكمة الجزء الرابع، ص ٢٥٦.

المبدأ الأول عملياً، وحتى تتحقق حماية أحكام الدستور وقواعده من الخروج عليها من جانب سلطات الدولة (١).

نطاق الرقابة على دستورية القوانين (الدساتير الجامدة) : والرقابة على دستورية القوانين تجد مجالها في الدساتير الجامدة، وهي تلك التي لا يمكن تعديلها إلا بنفس الطريقة التي أنشأتها، ولذلك فلا يمكن تعديله بالطريقة التي تعدل بها القوانين العادية (٢).

لذلك نجد أن جمود الدستور ينتج عنه نتيجتين هامتين : الأولى : أن جمود الدستور يضمن تعزيز الشرعية، والثانية : أن جمود الدستور يؤدي إلى بعض الاستقرار القانوني للدستور (٣) «la rigidité constitutionnelle» والأنظمة الدستورية التي تأخذ بالرقابة على دستورية القوانين لم تتخذ اتجاهاً واحداً في أسلوب الرقابة على دستورية القوانين، فمنها ما قرر رقابة سياسية على دستورية القوانين، ومنها ما قرر رقابة قضائية للثبوت من دستورية القوانين، وفي كل تصدر الهيئة المخول لها مراقبة الدستور قرارها سواء بتأكيد دستورية القانون أو بالمقابل تقرر عدم دستوريته، وهذا ما سوف نتناوله من خلال المبحث التالي.

المبحث الثاني

أنواع الرقابة على دستورية القوانين

تمهيد :

تتنوع الرقابة على دستورية القوانين تبعاً للنظام الذي تأخذ به كل دولة بصدد الرقابة على دستورية القوانين، فمن الدول ما تأخذ بنظام الرقابة السياسية على دستورية القوانين، ومنها ما تأخذ بنظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين، وفي

(١) راجع الدكتور/ محمد صلاح عبد البديع السيد، الحكم بعدم الدستورية بين الأثر الرجعي والأثر المباشر دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، ٢٠٠٠م، ص ٦ .

(٢) راجع الدكتور/ يحيى الجمل، النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية، دار النهضة العربية، ١٩٨٤م، ص ٧، وأستاذنا الدكتور/ عبد العظيم عبد السلام/ الرقابة على دستورية القوانين، المرجع السابق، ص ١٤ وما بعدها.

(3) Joseph-parthélemy et Paul Duez,op .cit, P . 192 et suiv.

كلا النوعين قد تكون الرقابة لاحقة علي صدور القانون، وبالمقابل قد تكون سابقة عليه.

ومن ثم سوف نتناول في دراستنا لأنواع الرقابة على دستورية القوانين : الرقابة السياسية على دستورية القوانين، ثم الرقابة القضائية على دستورية القوانين، وأخيراً بيان موقف الفقه الإسلامي من تقرير الرقابة على دستورية القوانين، وذلك في مطلبين على النحو التالي :

المطلب الأول: الرقابة السياسية على دستورية القوانين.

المطلب الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين.

المطلب الأول

الرقابة السياسية على دستورية القوانين

Le contrôle par un organe politique

نبين في هذا لمطلب مفهوم الرقابة السياسية وتقديرها، ثم نتناول، الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا باعتبارها تطبيقاً للرقابة السياسية على دستورية القوانين، وذلك على النحو التالي:

أولاً : مفهوم الرقابة السياسية على دستورية القوانين وتقديرها :

١- مفهوم الرقابة السياسية على دستورية القوانين : الرقابة السياسية على دستورية القوانين هي الرقابة التي تُجري من قبل هيئة ذات تشكيل سياسي على القوانين أو اللوائح ، سواء كانت هذه الرقابة سابقة أو لاحقة على صدور القانون أو اللاحقة.

وفي الغالب تعد الرقابة السياسية رقابة وقائية تسبق صدور القانون، ومن ثم تحول دون صدوره إذا كان مخالفاً لأحكام الدستور.(١)

وترمز الرقابة السياسية إلى صفة الجهة التي تباشرها، أي الهيئة المنوط بها ممارسة الرقابة السياسية، وهي هيئة ذات صفة سياسية، وتختلف الدساتير من حيث تحديد هذه الهيئة وتكوينها(٢) وتعد الرقابة السياسية رقابة سابقة على إصدار القانون

(١) راجع الدكتور/ إبراهيم محمد على : القانون الدستوري، ار النهضة العربية، بدون تاريخ نشر، ص١٧٨.

(٢) راجع الدكتور/ محمد إبراهيم درويش ، والدكتور/ إبراهيم محمد درويش، المرجع السابق، ص ١٥٤.

في أغلب الأحوال، وإن وجدت بعض صور الرقابة السياسية اللاحقة على صدور القوانين^(١) ولذلك أطلق عليها الرقابة الدستورية الوقائية.

وتعد فرنسا أول دولة قامت بتطبيق الرقابة السياسية على دستورية القوانين، وقد أخذت بعض الدول العربية بالرقابة السياسية على دستورية القوانين مثل : دستور الجزائر الصادر عام ١٩٨٨م والمعدل عام ١٩٩٦م، ودستور المغرب الصادر عام ١٩٩٦م، والدستور التونسي عام ١٩٩٥م والمعدل عام ٢٠٠٢م، والدستور اللبناني الصادر عام ١٩٢٦م، بموجب التعديل الذي أدخل عليه عام ١٩٩٠م^(٢).

٢- **تقدير الرقابة السياسية على دستورية القوانين :** تعد الرقابة السياسية أكثر فاعلية حيث تهدف إلى منع الخطأ الدستوري قبل وقوعه هذا من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية ونظراً للتشكيل ذى الصبغة السياسية الذي تتسم به الهيئة التي تقوم بالرقابة السياسية، فإن الرقابة السياسية تعد غير فعالة وغير مجدية حيث تتأثر بالاعتبارات السياسية الباعثة عليها ودون أن تراعى الاعتبارات الدستورية والقانونية^(٣).

كما أن من أبرز عيوب الرقابة السياسية أنه إذا تم تشكيل أعضائها بطريق التعيين من جانب البرلمان، فإنها تكون عرضة لأن تكون تابعة له، وتفقد بذلك سبب وجودها وهو الرقابة على نشاطه، وإن شكلت بطريق الانتخاب سيطرت عليها نفس الاتجاهات السياسية التي تسيطر على البرلمان، وانعدمت بذلك كل قيمة لإنشائها، أما إذا سيطرت عليها اتجاهات سياسية مخالفة، فإنها لا تعدو حينئذ أن تكون مجلساً سياسياً إضافياً يتنازع السلطة والنفوذ مع المجلس السياسي التشريعي الأصلي، وبذلك يكون وجودها سبباً من أسباب السياسية، ولا تكون أداة لتحقيق الاستقرار في ظل

(٣) راجع الدكتور/ محمد صلاح عبد البديع السيد، الحكم بعدم الدستورية بين الاثر الرجعي والاثـر المباشر دراسة

مقارنة، الطبعة الاولى، دار النهضة العربية ٢٠٠٠م، ص ٧.

(٥) راجع أستاذنا الدكتور/ عبد العظيم عبد السلام، تطور الأنظمة الدستورية - دراسة مقارنة - الكتاب الثاني - الجزء الثاني - المرجع السابق، ص ٥٧٦.

(3) Joseph-parthélemy et Paul Duez,op .cit, P .203.

الدستور^(١) فتغليب الطابع السياسى فى أسلوب اختيار أعضاء المجلس الدستورى عن طريق السلطتين التشريعية والتنفيذية دون فرض أى قيود عليها فى اختيارهم، مما يؤدى إلى عدم تحقيق الاستقلال التام بين أعضاء المجلس وهاتين السلطتين^(٢).

ثالثاً : الرقابة السياسية على دستورية القوانين فى فرنسا :

١- إسناد الرقابة على دستورية القوانين إلى هيئة سياسية : تعد فرنسا هى أول دولة فى العالم أخذت بهذه الرقابة على دستورية القوانين، سواء فى دساتيرها التقليدية، أو فى ظل دستور ١٩٥٨م الفرنسى الحالى، والمعروف بدستور الجمهورية الخامسة^(٣) والمعدل فى عام ٢٠٠٨م، ويعتبر النظام الدستورى الفرنسى من أهم الأنظمة التى تطبق الرقابة السياسية على دستورية القوانين، ولقد أسند هذه المهمة إلى المجلس الدستورى، الذى يعد - على الرأى الراجح هيئة سياسية - نظراً لما يتسم به تكوينه، حيث يضم من بين أعضائه، أعضاء تنتمي إلى الهيئة السياسية، على سبيل المثال رؤساء الجمهورية السابقين.

فالمادة ٥٦ فقرة ١ من الدستور الفرنسى الصادر سنة ١٩٥٨ نصت على تكوين المجلس الدستورى من نوعين من الأعضاء :

النوع الأول: وهم رؤساء الجمهورية وهم أعضاء مدى الحياة وهم أعضاء بقوة القانون، **والنوع الثانى :** أعضاء معينون يبلغ عددهم تسعة أعضاء لمدة تسعة سنوات غير قابلة للتجديد، ويقوم بتعيينهم كل من رئيس الجمهورية ، و رئيس الجمعية الوطنية، ورئيس مجلس الشيوخ ، بحيث يتم تجديد عضوية ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات بواقع ثلاثة أعضاء يعين كل من رئيس الجمهورية ، و رئيس الجمعية الوطنية، ورئيس مجلس الشيوخ واحد منهم.

(٢) راجع المستشار/ يسرى زين العابدين: الرقابة على دستورية القوانين، مجلة العلوم الإدارية السنة الأربعون، يونيو، ٢٠٠٢م، ص٩؛ وللمزيد راجع الدكتور/ إبراهيم محمد على : القانون الدستورى، المرجع السابق، ص١٨٦ وما بعدها.

(٣) راجع أستاذنا الدكتور/ عبد العظيم عبد السلام: الرقابة على دستورية القوانين، المرجع السابق، ص١٥٨.

(٤) راجع أستاذنا الدكتور/ عبد العظيم عبد السلام: تطور الأنظمة الدستورية - دراسة مقارنة - الكتاب الثانى - التطور الدستورى فى مصر - الجزء الثانى ، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى ٢٠٠٦م، ص٥٧٥.

٢-أنواع الرقابة على دستورية القوانين التي يجريها المجلس الدستوري

الفرنسي:

يختص المجلس الدستوري الفرنسي باختصاصات عديدة^(١) أهمها الرقابة على دستورية القوانين، ويوجد نوعين من الرقابة يقوم بممارستها المجلس الدستوري :

النوع الأول: الرقابة السابقة على دستورية القوانين : *Le contrôle a priori*

يجري المجلس الدستوري الفرنسي رقابة سابقة على مدى دستورية القوانين ، وقد نص الدستور الفرنسي على اختصاصه هذا في المادة رقم (٦١) ، وهذه الرقابة تنقسم إلى رقابة وجوبية وأخرى جوازية على النحو التالي :

١-الرقابة الجوازية :

ويتمثل في الرقابة الجوازية على دستورية القوانين، حيث إنه طبقاً للمادة (٦١) من الدستور الفرنسي يجوز لكل من رئيس الجمهورية، والوزير الأول، أو رئيس الجمعية الوطنية، أو رئيس مجلس الشيوخ ، وكل ستين نائباً من أعضاء الجمعية الوطنية، وكل ستين عضو من أعضاء مجلس الشيوخ، يجوز لكل من هؤلاء أن يعرض على المجلس الدستوري أي قانون قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور^(٢).

وقد أجاز المجلس الدستوري لنفسه حق التصدي لعدم دستورية نص معين على الرغم من عدم طلب أحد الأشخاص الذين خصهم الدستور بحق طلب الرقابة منه على قانون معين، وذلك في حالة ممارسة دستورية نص معين مرتبط بنص آخر غير مطعون في دستوريته^(٣).

٢-الرقابة الوجوبية :

الرقابة الوجوبية على دستورية القوانين، وذلك فيما يتعلق بالقوانين الأساسية، واقتراحات القوانين المنصوص عليها في المادة (١١) من الدستور، ولوائح المجالس

(١) فيختص المجلس الدستوري بالإضافة إلى رقابة دستورية القوانين، يختص أيضاً بالفصل في صحة انتخاب النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، طبقاً للمادة (٥٩) من الدستور، كما يختص بمراقبة صحة عمليات الاستفتاء وإعلان نتائجه.

(١) راجع/ نص المادة (٦١) من الدستور الفرنسي الحالي.

(٢) راجع أستاذنا الدكتور/ عبد العظيم عبد السلام : الرقابة على دستورية القوانين، المرجع السابق، ص ١٤٥ وما بعدها.

البرلمانية، إذ يجب أن تعرض على المجلس الدستوري قبل إصدارها بالنسبة للقوانين الأساسية ومقترحات القوانين الواردة في المادة (١١) ، وقبل تطبيقها بالنسبة للوائح البرلمان، وذلك طبقاً لما قرره المادة (٦١) في فقرتها الثانية^(١).

أ- القوانين الأساسية :

يقصد بالقوانين الأساسية في هذا المجال : القوانين التي يتبع في إصدارها إجراءات خاصة نص عليها الدستور في المادة (٤٦) منه، وتختلف عن الإجراءات التي تتبع في إصدار القوانين العادية مما جعلها مميزة عنها وأعلى منها مرتبة، ونظراً لأهمية الموضوعات التي تنظمها القوانين الأساسية، فلقد تطلب الدستور عرض هذه القوانين على سبيل الإلزام على المجلس الدستوري للتحقق من مطابقتها للدستور قبل إصدارها^(٢) . حيث إن هذه القوانين تنظم موضوعات مهمة تتعلق بسلطات الدولة وأجهزتها ، من حيث تشكيلها واختصاصاتها وعلاقتها فيما بينها ، أو فيما بينها وبين الأفراد، وكذلك تنظيم ممارسة الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد تجاه الدولة، وذلك كله بغرض تكملة نصوص الدستور.

ب- النظام الأساسي لمجلسي البرلمان :

يقصد بالنظام الأساسي لمجلسي البرلمان : اللوائح المنظمة للبرلمان الفرنسي بمجلسيه، سواء اللائحة المنظمة لمجلس الشيوخ Sénat أو الجمعية الوطنية Assemblée nationale.

ولقد قرر الدستور الفرنسي أيضاً الرقابة الوجوبية بخصوص عرض لوائح المجالس البرلمانية على المجلس الدستوري قبل تطبيقها^(٣). وذلك طبقاً للمادة ٦١ من الدستور الفرنسي.

(1) Jean-Claude ACQUAVIVA : droit constitutionnel et institution politique, 10e édition, Gualino éditeur, EJA - Paris – 2007 p .203 et suiv.

Voir aussi, Véronique Champeil-Desplats, Les grandes questions du droit constitutionnel, 2003, P. 121 et suiv.

(٢) راجع أستاذنا الدكتور/ عبد العظيم عبد السلام : الرقابة على دستورية القوانين، المرجع السابق، ص ١٤٠ وما بعدها.

(3) voir, Valérie Sommacco, Le droit d'amendement et le juge constitutionnel en France et en Italie , L.G.D.J., 2002, P. 120 et suiv.

ج- اقتراحات القوانين الصادرة طبقاً للمادة (١١) من الدستور :

قررت المادة (١١) من الدستور الفرنسي بأنه يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على اقتراح من الحكومة خلال فترة انعقاد البرلمان، أو بناءً على اقتراح مشترك من المجلسين (أى مجلسى البرلمان) منشور فى الجريدة الرسمية أن يعرض الاستفتاء على أى مشروع قانون يتضمن تنظيم السلطات العامة، أو الإصلاحات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية للأمة، وبالمرافق العامة التى تساهم فى ذلك أو يهدف إلى الترخيص بالتصديق على معاهدة دون أن تكون متعارضة مع الدستور قد ترتب آثاراً على سير المؤسسات.

ولقد أوجبت المادة ٦١ من الدستور الفرنسي ضرورة عرض اقتراحات القوانين المتعلقة بالمادة (١١) سالفه الذكر على المجلس الدستوري لبيان مدى مطابقتها للدستور من عدمه، وذلك قبل عرضها على الاستفتاء.

النوع الثانى : الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين (١)

Le contrôle a posteriori

إذا كان الدستور الفرنسى الحالى الصادر عام ١٩٥٨م قد حدد طرق اللجوء للمجلس الدستوري، وكلها طرق سابقة على صدور القوانين - كما بينا سابقا - سواء بخصوص حالات الرقابة على دستورية القوانين الوجوبية أو الاختيارية، فإنه وفقاً للتعديل الدستوري الصادر فى ٢٣ يوليو ٢٠٠٨م ، تم إضافة طريق جديد لهذه الطرق التقليدية، وهو طريق الإحالة من القضاء، وهذه الإحالة تتم بعد صدور القانون.

فى عام ٢٠٠٨م تقدم الرئيس ساركوزى - وهو ينتمى إلى التيار الديقولى - بمشروع جديد لتعديل الدستور تضمن عدداً من الإصلاحات، من بينها تعديل المادة (٦١) من الدستور بما يوسع من اختصاصات المجلس الدستوري ويمنح للأفراد حق الدفع بعدم دستورية أحد النصوص التشريعية التى تتضمن اعتداء على أحد الحقوق والحريات الأساسية التى كفلها الدستور، وذلك بمناسبة دعوى قضائية قائمة أمام

(1) - voir, Philipp Foilard, Droit constitutionnel et institutions politique, éd 2009-2010, P.38.

الجهات القضائية، وفي حالة قبول القاضي للدفع، فإنه يحيله لمحكمة النقض أو لمجلس الدولة على حسب الأحوال، اللذين يملكان إحالته للمجلس الدستوري أو رفضه^(١) فطبقاً للقانون الدستوري الصادر في ٢٣ يوليو ٢٠٠٨^(٢) تم تعديل المادة (٦١) من الدستور الفرنسي، وذلك في المادة ٢٩ من هذا القانون بإضافة المادة (٦١) فقرة (١) بعد المادة (٦١) من الدستور، وذلك بخصوص الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، وهذه الرقابة إنما تكون في حالة ما إذا كانت الدعوى مطروحة أمام القضاء، وتبين أن النصوص التشريعية تنتهك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، فيمكن للمجلس الدستوري النظر في هذه المسألة بناءً على الإحالة من مجلس الدولة أو محكمة النقض خلال مدة محددة^(٣).

ويتبين مما سبق : أن التعديل الدستوري لم يطلق للأفراد حرية التمسك بالقواعد الدستورية، وإنما على العكس حدد لهم طائفة معينة من القواعد الدستورية، والتي تتمثل في القواعد التي تكفل الحقوق والحريات، ومن ثم فإنه لا يجوز التمسك بغيرها من القواعد الدستورية الأخرى^(٤). كما أن المحاكم التي يجوز إثارة الدفع بعدم الدستورية أمامها تتمثل في المحاكم التابعة لمجلس الدولة أو محكمة النقض، ولا تحال مسألة عدم الدستورية إلا من مجلس الدولة أو محكمة النقض، ويتعين على المجلس الدستوري الفصل في الدعوى الدستورية في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة^(٥).

(٢) راجع الدكتور/ يسرى محمد العصار : الجمع بين الرقابة السابقة واللاحقة على الدستورية في فرنسا بمقتضى التعديل الدستوري لعام ٢٠٠٨م، مقال منشور بمجلة الدستورية، العدد السادس عشر، السنة السابعة، أكتوبر ٢٠٠٩م، ص ٤١.

(2) - Loi constitutionnelle n° 2008-724 de modernisation des institutions de la Ve République, Loi adoptée par le Parlement réuni en Congrès, à Versailles, le 23 juillet 2008. JORF n° 171, 140 Année, 24 JUILLET 2008, P. 11890 : 11895.

(١) راجع الدكتور/ محمد عبد اللطيف : رقابة الدستورية اللاحقة في فرنسا، مقال منشور بمجلة الدستورية، العدد السادس عشر، السنة السابعة، أكتوبر ٢٠٠٩م، ص ٢٠.

(5) Voir, la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, JORF du 11 décembre 2009, n° 287 ; et Décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, JORF du 18 février 2010, n° 41.

المطلب الثاني

الرقابة القضائية على دستورية القوانين (١)

Le contrôle par un organe juridictionnel

لدراسة الرقابة القضائية على دستورية القوانين، ينبغي أن نبين النظرية العامة لهذه الرقابة، ثم نبين بعض تطبيقاتها، وذلك على النحو التالي :

الفرع الأول

النظرية العامة للرقابة القضائية على دستورية القوانين

أولاً : مفهوم ونشأة الرقابة القضائية على دستورية القوانين :

١- تعريف الرقابة القضائية :

بعض الأنظمة الدستورية جعلت الرقابة على دستورية القوانين من اختصاص هيئة قضائية تختص بالفصل في دستورية القوانين. والرقابة القضائية على دستورية القوانين تعنى الرقابة التى يمارسها القضاء بقصد التحقق من مطابقة القوانين بكافة أشكالها (٢).

ونرى أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين تعنى : إسناد مهمة الحفاظ على الدستور والتصديق لمخالفته إلى هيئة قضائية تقوم بفحص القانون ومقابلته بالدستور للتوصل فى النهاية الى إصدار قرارها بمطابقة هذا القانون للدستور أو مخالفته له.

٢- نشأة الرقابة القضائية على دستورية القوانين :

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة فى العالم أخذت بفكرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين على الرغم من عدم وجود نص فى الدستور يقررها، ولقد نشأت هذه الرقابة بفضل جهود القضاء الأمريكى، وبصفة خاصة قضاء المحكمة العليا الأمريكية وتأييد الفقه الأمريكى له، وذلك بقصد حماية وتكملة مبدأ المشروعية، الذى اعتبره من المبادئ الأساسية التى سجلها الشعب الأمريكى فى وثائقه

(1) - Joseph-Barthélémy et Paul Duez op.cit p. 207 et suiv.

(٢) راجع أستاذنا الدكتور/ عبد العظيم عبد السلام، تطور الأنظمة الدستورية، الكتاب الثانى، التطور الدستوري فى مصر، الجزء الثانى، المرجع السابق، ص ٥٧١؛ وفى ذات المعنى راجع الدكتور/ إبراهيم محمد على : القانون الدستوري، المرجع السابق، ص ١٨٩.

الدستورية، سواء الإقليمية أو الاتحادية بعد كفاحه ضد الاستعمار الانجليزى، وذلك بقصد إخضاع نظام الدولة من حكام ومحكومين لأحكام القوانين المعمول بها فى الدولة سواء كانت قوانين دستورية أم عادية^(١).

وقد انتقلت الرقابة القضائية بعد ذلك إلى العديد من دول العالم، فبعض هذه الدول قررت المحاكم فيها الرقابة القضائية على دستورية القوانين دون النص عليها فى الدستور، وذلك مثل: محكمة النرويج العليا عام ١٨٩٠م، ومحكمة النقض برومانيا عام ١٩١٢م، ومحكمة القضاء الإدارى المصرى عام ١٩٤٨م، وحتى إنشاء المحكمة العليا عام ١٩٦٩م. كما قررت بعض الدول الرقابة القضائية على دستورية القوانين فى دساتيرها، وذلك مثل : الدستور النمساوى الصادر عام ١٩٢٠م، والدستور الإيطالى عام ١٩٧٤م، والدستور المصرى الحالى الصادر عام ١٩٧١م^(٢) ثانياً : الجهة القضائية التى تتولى الرقابة على دستورية القوانين : باستقراء أنظمة الرقابة على دستورية القوانين فى العالم نستطيع أن نقرر بأنه يوجد اتجاهان بصدد الجهة القضائية التى تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين^(٣) :

١- مركزية الجهة التى الرقابة على دستورية القوانين : قد تمارس الرقابة القضائية على دستورية القوانين بصورة مركزية تتولاها جهة قضائية واحدة، هذه الجهة قد تكون المحكمة العليا فى النظام القضائى العادى، وذلك مثل سويسرا فى دستورها الحالى وفنزويلا، وقد تكون هيئة قضائية مختصة بمراقبة الدستورية، وذلك مثل المحكمة الدستورية العليا فى مصر، وما هو مأخوذ به فى النمسا فى دستور ١٩٢٠ ودستور ١٩٤٥ ، وإيطاليا فى دستور ١٩٤٧^(٤).

(٣) راجع أستاذنا الدكتور/ عبد العظيم عبد السلام: الرقابة على دستورية القوانين، المرجع السابق، ص ١٨ وما بعدها.

(١) راجع أستاذنا الدكتور/ عبد العظيم عبد السلام، تطور الأنظمة الدستورية، الكتاب الثانى، التطور الدستورى فى مصر، الجزء الثانى، المرجع السابق، ص ٥٧٢، وراجع الدكتور/ رمزى الشاعر: رقابة دستورية القوانين ٢٠٠٤م، المرجع السابق، ص ٩٤ وما بعدها، ومؤلفه أيضاً/ النظرية العامة للقانون الدستورى، ٢٠٠٥م، ص ٦٩٢ وما بعدها.

(٤) راجع أستاذنا الدكتور/ عبد العظيم عبد السلام، تطور الأنظمة الدستورية، الكتاب الثانى، التطور الدستورى فى مصر، الجزء الثانى، المرجع السابق، ص ٥٧٣ وما بعدها.

(١) راجع فى ذلك الدكتور/ رمزى الشاعر : رقابة دستورية القوانين ٢٠٠٤م - ص ١٠٩ وما بعدها، ومؤلفه أيضاً/ النظرية العامة للقانون الدستورى، ٢٠٠٥م، ص ٦٩٠.

٢- لامركزية الجهة التي الرقابة على دستورية القوانين :ومن جهة أخرى

قد تمارس هذه الرقابة بصورة لامركزية، وفيها يعهد بالرقابة على دستورية القوانين إلى جميع الهيئات التي تمارس الوظيفة القضائية في الدولة، وعلى جميع مستويات المحاكم ودرجاتها، فتمارس الرقابة هنا المحاكم الدنيا والمحاكم العليا. ومن الدول التي أخذت بهذا الأسلوب من الرقابة الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان في دستور ١٩٤٦، ورومانيا في دستور ١٩٣٨، ومصر بداية من عام ١٩٤٨ وحتى عام ١٩٦٩^(١)، حيث تم إنشاء المحكمة العليا لتتولى رقابة دستورية القوانين.

ثالثاً : أنواع الرقابة القضائية على دستورية القوانين : قد تكون الرقابة

القضائية على دستورية القوانين سابقة على صدور القانون، أو لاحقة على صدوره، وفي ظل الرقابة القضائية المركزية على دستورية القوانين ، قد تكون الرقابة لاحقة أو سابقة على دستورية القوانين، أما في ظل الرقابة القضائية اللامركزية، فلا تكون الرقابة إلا لاحقة على نفاذ القانون وتطبيقه، حيث تتعرض المحكمة لمدى دستورية القانون هنا أثناء التطبيق بعد صدور القانون ونفاذه لا قبله.

رابعاً : أساليب تحريك الرقابة القضائية على دستورية القوانين : يوجد

أسلوبين لتحريك الرقابة القضائية على دستورية القوانين:

١- أسلوب الدعوى الأصلية *la voie de l'action* : يعنى أسلوب الدعوى ،

أن يكون تحريك الرقابة على دستورية القوانين عن طريق دعوى أصلية ترفع وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون أمام الجهة القضائية المختصة بالرقابة على دستورية القوانين. ولا تتوقف هذه الدعوى على وجود نزاع أمام أى جهة قضائية

ومن المحاكم التي تُحرك أمامها رقابة دستورية القوانين بأسلوب الدعوى

المحكمة الفيدرالية السويسرية، والمحكمة الدستورية النمساوية ، والألمانية.

٢- أسلوب الدفع الفرعي *La voie de l'exception* :تأخذ بعض الدول

بأسلوب الدفع لتحريك الرقابة على دستورية القوانين، وهذا الأسلوب يقتضى أن نكون بصدد قضية مرفوعة أمام أى جهة قضائية، فيظهر لأحد الخصوم أو يعتقد في

(٢) راجع المستشار/ يسرى زين العابدين: مقاله السابق، ص ١٢، ١٣؛ والدكتور/ رمزي الشاعر: النظرية العامة للقانون الدستوري ٢٠٠٥م، ص ٦٩١، ٦٩٢.

أن القانون الذى يحكم النزاعاً أو أحد نصوصه يتعارض مع الدستور، فيقوم هذا الخصم أو من يوكله بالدفع أمام المحكمة التى تنظر النزاع بعدم دستورية النصوص القانونية التى لها صلة بهذا النزاع. ثم توقف المحكمة الفصل فى النزاع لحين فصل الجهة القضائية المختصة بالرقابة على دستورية القوانين بدستورية أو عدم دستورية النصوص القانونية محل الدفع بعدم الدستورية. وذلك كما هو الوضع فى الولايات المتحدة الأمريكية ومصر^(١).

رابعاً : الرقابة القضائية من حيث أثر الحكم الصادر بعدم الدستورية على القانون غير الدستوري :

١- إذا كانت الرقابة سابقة على صدور القانون، فيكون الأثر هو عدم صدور هذا القانون.

٢- أما إذا كانت الرقابة القضائية لاحقة على صدور القانون، فتختلف الأنظمة فى ذلك إلى نوعين : رقابة امتناع أو رقابة إلغاء، وذلك تبعاً للأثر الذى يترتب عليها بالنسبة للقانون المطعون عليه بعدم الدستورية^(٢).

أ- **رقابة الامتناع تعنى :** أن القاضى يمتنع عن تطبيق القانون غير الدستورى على القضية المطروحة أمامه.

ب - **رقابة الالغاء :** تعنى إنهاء حياة القانون المطعون عليه بعدم الدستورية وإبطاله فى مواجهة الكافة، ومن ثم اعتبار هذا القانون كأن لم يكن.

الفرع الثانى

تطبيقات للرقابة القضائية على دستورية القوانين

نتناول هنا نموذجين من تطبيقات الرقابة القضائية على دستورية القوانين فى

العالم، وهما النموذج الأمريكى، والنموذج المصرى، وذلك على النحو التالى :

أولاً : الرقابة القضائية على دستورية القوانين فى أمريكا : الولايات المتحدة الأمريكية تعد أسبق الدول إلى تشييد صرح الرقابة القضائية على دستورية

(1)- voir, Joseph-Barthélémy et Paul Duez op.cit p. 20^h et suiv.

وراجع فى الفقه المصرى الدكتور/ رمزى الشاعر : النظرية العامة للقانون الدستورى، ٢٠٠٥م، ص ٧٠٥ وما بعدها؛ والدكتور/ إبراهيم محمد على : القانون الدستورى، المرجع السابق، ص ٢٠١ وما بعدها.

(٢) راجع الدكتور/ محمد ابراهيم درويش ، والدكتور/ ابراهيم محمد درويش، المرجع السابق، ص ١٧٤، ١٧٣.

القوانين، ثم انتقلت هذه الفكرة بعد ذلك إلى كثير من الدول التي سارت فى فلكها، ووجدت فى اختصاص القضاء بها وسيلة فعالة لضمان حسن نفاذ القاعدة الدستورية، وحماية الدستور من الاعتداء عليه ومخالفة أحكامه^(١).

ولم يتضمن دستور الولايات المتحدة الأمريكية أى نص يقرر حق المحاكم فى رقابة دستورية القوانين، ولكن تقرر هذا الحق بواسطة القضاء من جانب وتأيد الفقه من جانب آخر^(٢).

وقد استند الرأى المؤيد لحق المحاكم الفيدرالية فى الرقابة على دستورية القوانين إلى نص المادة الثالثة من الدستور الفيدرالى والتي أوجبت إنشاء محكمة فيدرالية عليا وناط بها اختصاص الفصل فى جميع الخصومات التى تنشأ بخصوص هذا الدستور، وكذلك فإن الأعمال التحضيرية تؤكد ولا تنفى امتناع واضع الدستور عن تقرير الرقابة على دستورية القوانين، وأن ذلك لا يحتمل التأويل أو تفسير مغاير لذلك^(٣) وكذلك أيضاً لتقرير القضاء مبدأ تدرج القواعد القانونية^(٤).

كما يلاحظ أن الدستور الاتحادى للولايات المتحدة الأمريكية قد نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على أن "يعتبر هذا الدستور وكذا ما تسنه الولايات المتحدة من قوانين (القوانين الفيدرالية) طبقاً لأحكامه، وجميع المعاهدات المبرمة، أو التى تبرم تحت سلطة الولايات المتحدة، القانون الأعلى للبلاد، وسيلتزم بذلك القضاء فى كل ولاية، ولا يلتفت لأى شىء يكون مخالفاً لهذا فى دستور أو قوانين أى ولاية"^(٥).

(١) راجع الدكتور/ رمزى الشاعر : رقابة دستورية القوانين - دراسة مقارنة، ٢٠٠٤م - مرجع سابق، ص ٩٤ ، ٩٥ ، ومؤلفه/ النظرية العامة للقانون الدستورى، ٢٠٠٥م، ص ٦٨٢ ، ٦٨٣.

(٢) راجع الدكتور/ رمزى الشاعر : الرقابة على دستورية القوانين، المرجع السابق - ص ٩٥، وراجع مؤلفه/ النظرية العامة للقانون الدستورى، ٢٠٠٥م، ص ٦٨٣؛ وفى هذا المعنى راجع أستاذنا الدكتور/ عبد العظيم عبد السلام : الرقابة على دستورية القوانين، المرجع السابق، ص ٢٠.

(٣) راجع الدكتور/ محمد ابراهيم درويش ، والدكتور/ ابراهيم محمد درويش، المرجع السابق، ص ١٨١، ١٨٢.

(٤) راجع المستشار/ يسرى زين العابدين : الرقابة على دستورية القوانين - مجلة العلوم الإدارية - السنة الأربعون- يونية ٢٠٠٢ - ص ١٩.

(5) Art (6) - « La présente Constitution, ainsi que les lois des États-Unis qui en découleront, et tous les traités déjà conclus, ou qui le seront, sous l'autorité des États-Unis, seront la loi suprême du pays ; et les juges dans chaque État seront liés par les susdits, nonobstant toute disposition contraire de la Constitution ou des lois de l'un quelconque des États ».

ومن الواضح أن هذه المادة تقرر حق القضاء فى الولايات المتحدة فى رقابة دستورية قوانين الولايات، وتقضى بوجوب امتناع محاكم الولايات عن تطبيق دستور الولاية وقوانينها إذا ما تعارضت مع الدستور الفيدرالى والقوانين الفيدرالية، لكنها من ناحية أخرى لم تنظم حالة تعارض قوانين الاتحاد مع الدستور الفيدرالى، وما إذا كان يجوز للمحاكم الفيدرالية رقابة دستورية القوانين والامتناع عن تطبيقها إذا ما شابها عدم الدستورية، وفى هذا المجال ظهر الدور الأساسى للمحكمة العليا، حيث أقرت للمحاكم الاتحادية برقابة مدى مطابقة القوانين الفيدرالية للدستور الفيدرالى^(١).

وكانت قضية Marbery V. Madison فى عام ١٨٠٣م بداية الفرصة لتقرير المحكمة العليا حق القاضى فى عدم تطبيق القانون متى رأى أنه مخالف للدستور، حيث قال القاضى جون مارشال - مؤكداً فى حكمه مبدأ الرقابة على دستورية القوانين - : "إن دستور الولايات المتحدة هو قانون البلاد. وأن جميع القوانين الأخرى التي تتعارض مع الدستور تكون باطلة. ويحدد الدستور حدود السلطة والصلاحيات للحكومة."^(٢).

" The Constitution of the United States is the Law of the Land. All other laws in conflict with the Constitution are void. The Constitution defines and limits the power and authority of the government".

ويعد هذا الحكم أول حكم تصدره المحكمة العليا الأمريكية بعدم دستورية قانون اتحادى، وذلك على الرغم من عدم وجود نص دستورى يقرر صراحة هذه الرقابة أو ينظمها^(٣).

ولقد أكدت المحكمة العليا الأمريكية هذا المعنى فى قضية United States v. Butler عام ١٩٣٦م، حيث أكدت على أن الدستور هو القانون الأعلى للبلاد ولقد

(٢) راجع الدكتور/ رمزى الشاعر : الرقابة على دستورية القوانين، المرجع السابق - ص ٩٥.
(2) - Marbury v. Madison, 5 U.S. Supreme Ct (1 Cranch) 137 (1803).
Voir : HENNINGER Julien, Marbury v. Madison, Presses Universitaires de Strasbourg, 2006, P. 118.

(١) راجع أستاذنا الدكتور/ عبد العظيم عبد السلام : الرقابة على دستورية القوانين، المرجع السابق، ص ٣٢ وما بعدها.

استقر بواسطة الشعب، وجميع التشريعات يجب أن تتفق مع المبادئ التي ينص عليها^(١).

وبناءً على ما تقدم : فإن جميع المحاكم فى الولايات المتحدة الامريكية تمارس الرقابة على دستورية القوانين، فهى رقابة لامركزية، كما أنها رقابة لاحقة على نفاذ القانون، ولكن المرجع الأخير فى الفصل فى دستورية القوانين يكون من اختصاص المحكمة العليا التى تعلق جميع المحاكم فى الولايات المتحدة الامريكية سواء كانت تلك المحاكم أول درجة أو ثانى درجة، لذلك إذا ما أثبتت أمام أى محكمة من محاكم الولايات المتحدة مسألة تتعلق بدستورية قانون ما أو نص من نصوصه، فإن المحكمة العليا تكون هى صاحبة الكلمة الأخيرة فى تأكيد الدستورية أو إعلان عدم الدستورية للنص التشريعى محل النزاع^(٢).

ثانياً : الرقابة القضائية على دستورية القوانين فى مصر :

لم تتضمن الدساتير السابقة على دستور مصر الدائم الصادر فى سنة ١٩٧١ أية نصوص تخول القضاء أو أية جهة أخرى حق الرقابة على دستورية القوانين، وكان أول تشريع صدر فى البلاد وخول القضاء هذا الحق، هو قانون المحكمة العليا الصادر فى ٣١ أغسطس سنة ١٩٦٩، ثم أتى الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية فى ١١ سبتمبر ١٩٧١، وتضمن النص على إنشاء المحكمة الدستورية العليا وأعطى لها الحق وحدها فى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وصدر نتيجة

(١) United States v. Butler (No. 401) 78 F.2d 1 affirmed, 297 U.S. 1, January 6, 1936.

« The Constitution is the supreme law of the land, ordained and established by the people, and all legislation must conform to the principles it lays down ».

(٣) ورد النص على المحكمة العليا الامريكية فى المادة الثالثة من الدستور الأمريكى ، وذلك تحت عنوان السلطة القضائية راجع القواعد المنظمة للمحكمة العليا للولايات المتحدة الامريكية بأحدث التعديلات لها سنة ٢٠٠٧، والذى تم اعتمادها فى ١٧ يوليو ٢٠٠٧ م، واصبحت سارية المفعول فى ١ أكتوبر ٢٠٠٧ .

لذلك قانون هذه المحكمة فى سبتمبر سنة ١٩٧٩، ليحل محل قانون المحكمة العليا الصادر فى سنة ١٩٦٩^(١).

وتأسيسا: على ما تقدم : مرت نشأة الرقابة على دستورية القوانين فى مصر بثلاثة مراحل، **المرحلة الأولى :** وتتمثل فى مرحلة ما قبل إنشاء المحكمة العليا، **والمرحلة الثانية :** وتتمثل فى المرحلة التالية لإنشاء المحكمة العليا، **والمرحلة الثالثة :** وتتمثل فى المرحلة التالية لإنشاء المحكمة الدستورية العليا وحتى الآن^(٢).

ففى المرحلة الأولى : والتي سبقت إنشاء المحكمة العليا، فلم يكن يوجد أى نص قانونى - دستورى أو عادى- يقرر إباحة أو تحريم الرقابة على دستورية القوانين؛ لذلك اختلف الفقه آنذاك حول مؤيد ومعارض للرقابة على دستورية القوانين، ولكن الرأى الذى كان يمثل الأغلبية قرر حق القضاء فى الرقابة على دستورية القوانين، وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الصادر فى ١٠ فبراير ١٩٤٨، والذى أعلنت فيه صراحة حق القضاء فى رقابة دستورية القوانين والامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور.

ففى هذه المرحلة كان القضاء المصرى يأخذ بلامركزية الرقابة على دستورية القوانين، فيمارس القضاء على اختلاف جهاته ودرجاته رقابة دستورية القوانين، كما أنها رقابة لاحقة لا سابقة على صدور القانون، وكان القاضى يقتصر دوره على مجرد الامتناع عن تطبيق النص القانونى غير الدستورى دون أن يلغيه.

وفى المرحلة الثانية : وهى المرحلة التى تلت إنشاء المحكمة العليا عام ١٩٦٩، حيث تم إنشاء المحكمة العليا بقرار رئيس الجمهورية الصادر فى ٣١ أغسطس ١٩٦٩، وجعل من بين اختصاصها الرقابة على دستورية القوانين، وقررت المحكمة لنفسها الحق فى رقابة دستورية الوائح، وبذلك كانت الرقابة على دستورية القوانين

(١) راجع الدكتور/رمزى الشاعر : النظرية العامة للقانون الدستورى، المرجع السابق، ص ٧٣٩؛ وأستاذنا

الدكتور/ عبد العظيم عبد السلام : الرقابة على دستورية القوانين، المرجع السابق، ص ١٧١ وما بعدها.

(٢) لمعرفة المزيد راجع أستاذنا الدكتور/ عبد العظيم عبد السلام: الرقابة على دستورية القوانين، المرجع السابق،

ص ١٧٢ وما بعدها؛ والدكتور/رمزى الشاعر: النظرية العامة للقانون الدستورى ٢٠٠٥م، ص ٧٣٩ وما

بعدها؛ والدكتور/ إبراهيم محمد على : القانون الدستورى، المرجع السابق، ص ٢١٠ وما بعدها.

آنذاك مركزة فى يد هيئة قضائية واحدة مستقلة هى المحكمة العليا. كما تعد الرقابة هنا رقابة لاحقة على صدور القانون، وكانت تتم عن طريق الدفع الفرعى لا الدعوى الأصلية.

وفى المرحلة الثالثة : والتى شهدت إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وذلك بنص الدستور المصرى لعام ١٩٧١م عليها فى المواد (١٧٤ - ١٧٨) وجعل من بين اختصاصاتها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وصدر بناء على ذلك فى ٢٩ أغسطس ١٩٧٩ القانون رقم (٤٨) لعام ١٩٧٩ الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، والمعدل بالقرار بقانون رقم (١٦٨) لسنة ١٩٩٨، والذى خص المحكمة الدستورية العليا بمراقبة دستورية القوانين واللوائح، وحدد تشكيل المحكمة وبين آثار الأحكام والقرارات الصادرة منها.

ولقد توالى النص على المحكمة الدستورية العليا واختصاصها بالفصل فى دستورية القوانين فى الإعلان الدستوري الصادر فى مارس ٢٠١١م، والدستور المصري المعطل والصادر فى ديسمبر ٢٠١٢م، والإعلان الدستوري الصادر فى يوليو ٢٠١٣م.

وبناءً على ما تقدم : نجد أن النظام الدستوري المصري الحالى، وقانون المحكمة الدستورية العليا قد أخذ بما يأتى :

١- أخذ النظام الدستوري بالرقابة القضائية على دستورية القوانين، التى يقوم بها هيئة قضائية لا سياسية.

٢- وإذا كان قد أخذ بالرقابة القضائية ، فإنها رقابة قضائية لاحقة على صدور القانون وتطبيقه، وذلك كقاعدة عامة بخصوص جميع القوانين، وذلك كما هو مقرر الآن فى ظل الإعلان الدستوري الحالى الصادر فى ٨ يوليو ٢٠١٣م ، وقانون المحكمة الدستورية العليا .

وتجدر الإشارة إلى أن دستور عام ٢٠١٢م المعطل، كان قد نص على الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين كقاعدة عامة ، واستثنى بعض القوانين من الرقابة اللاحقة وأخضعها للرقابة السابقة على دستورية القوانين، وتتمثل هذه القوانين - كما نصت المادة ١٧٧ من هذا الدستور - فى مشروعات القوانين المنظمة

لمباشرة الحقوق السياسية، وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية ، وذلك من خلال عرض رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب هذه المشروعات على المحكمة الدستورية العليا، ويجب أن تصدر قرارها خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُذ عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة، أما إذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من مشروع أى من القوانين سالفه الذكر، وجب تعديلها بما يتفق مع الدستور، ويجب عرض هذا التعديل مرة أخرى لمطابقته بالدستور.

٣- تقرير مركزية الرقابة على دستورية القوانين بهيئة قضائية مستقلة تتمثل فى المحكمة الدستورية العليا. وبالتالي لا تمارس المحاكم الأخرى مدى دستورية القوانين واللوائح.

٤- أخذ قانون المحكمة الدستورية العليا بأساليب ثلاثة لتحريك الرقابة على دستورية القوانين^(١) :

أ- **أسلوب الدفع الفرعى:** لتحريك الرقابة على دستورية القوانين، الذى يفترض وجود دعوى منظورة أمام محكمة الموضوع ويدفع أحد الخصوم أمامها بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة يتعلق بموضوع النزاع، ثم تبحث المحكمة مدى جدية هذا الدفع ، فإذا ما تحققت من جدية هذا الدفع، فتقوم بتأجيل الدعوى المنظورة أمامها، وتحدد للخصوم ميعاداً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعوى الدستورية، فإذا لم ترفع فى هذا الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن.

ب- **أسلوب الإحالة من محكمة الموضوع :** أعطى المشرع لقاضى الموضوع من تلقاء نفسه الحق فى الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا لأى نص قانوني أو لائحة يراه غير دستوري وكان لازماً للفصل فى الدعوى المنظورة أمامه ، وذلك بصرف النظر عن مصالح الخصوم فى المنازعة الموضوعية، ولو لم يبدى أى منهم نية للتشكك فى مدى دستورية هذا النص.

(١) للمزيد راجع د/ عبد العزيز محمد سالم : ضوابط وقيود الرقابة على دستورية القوانين، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، ٢٠١١م، ص ٧٠، وما بعدها،

ويوقف قاضى الموضوع الدعوى ويحيل الأوراق بدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (٢٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

ت- أسلوب الرقابة التصدى من المحكمة الدستورية العليا ذاتها : قرر قانون المحكمة الدستورية العليا فى المادة (٢٧) منه حق المحكمة الدستورية العليا فى أن تتصدى لممارسة الرقابة على دستورية القوانين، وذلك كلما رأت نصاً غير دستوري، وكان ذا صلة بالنزاع المطروح عليها.

الفصل الثاني

أثر القرار الصادر بعدم الدستورية على القانون غير الدستوري

تمهيد :

تختلف الأنظمة الدستورية في تقرير الأثر المترتب على الحكم بعدم الدستورية على القانون المخالف للدستور، وذلك لأن الدول في رقابتها على دستورية القوانين لا تتبع نظاماً واحداً، فمن الأنظمة ما تقرر عدم صدور القانون كأثر للحكم بعدم الدستورية، وهذا إنما يكون في الأنظمة التي تأخذ بالرقابة السابقة على إصدار القوانين مثل فرنسا، كما تقرر بعض الأنظمة الامتناع عن تطبيق القانون كأثر للحكم الصادر بعدم الدستورية، وذلك مثل النظام الأمريكي، وأخيراً تقرر غالبية الأنظمة إلغاء القانون غير الدستوري كأثر للحكم بعدم الدستورية، وذلك مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال والنمسا. وتعد الأنظمة التي تأخذ برقابة الامتناع ورقابة الإلغاء رقابة لاحقة على صدور القانون.

ومن ثم سوف نتناول في دراستنا لأثر القرار الصادر بعدم الدستورية على القانون المخالف للدستور في بعض الأنظمة التي تقرر الرقابة على دستورية القوانين، وذلك في المباحث التالية.

المبحث الأول: أثر القرار الصادر بعدم الدستورية على القانون غير الدستوري في فرنسا

المبحث الثاني: أثر القرار الصادر بعدم الدستورية على القانون غير الدستوري في أمريكا

المبحث الثالث: أثر القرار الصادر بعدم الدستورية على القانون غير الدستوري في مصر.

المبحث الأول

أثر القرار الصادر بعدم الدستورية على القانون

غير الدستوري في فرنسا

تمهيد :

كما بينا سابقاً يمارس المجلس الدستوري في فرنسا الرقابة على دستورية القوانين نوعين من الرقابة على دستورية القوانين، ونجد أن معظم الحالات التي يمارس المجلس الدستوري الرقابة بصدد رقابة سابقة على خروج القانون إلى حيز النفاذ، كما أنه أيضاً يمارس رقابة لاحقة على نفاذ القانون، وذلك طبقاً للتعديل الأخير للدستور الفرنسي في يوليو ٢٠٠٨م.

ومن ثم سوف نتناول أثر القرار الصادر بعدم الدستورية على القانون غير الدستوري في فرنسا تبعاً لتنوع نظام الرقابة على دستورية القوانين فيها إلى سابقة ولاحقة، وذلك في مطلبين على النحو التالي :

المطلب الأول : الأثر طبقاً للرقابة السابقة على صدور القانون.

المطلب الثاني : الأثر طبقاً للرقابة اللاحقة على صدور القانون.

المطلب الأول

الأثر طبقاً للرقابة السابقة على صدور القانون

contrôle a priori

بالبحث عن أثر القرار الصادر من المجلس الدستوري على القانون المخالف، نجد أن هذا الأثر يختلف تبعاً للقانون الذي تقرر عدم دستوريته. وذلك طبقاً لما ورد في المادتين (٦١) ، (٦٢) من الدستور الفرنسي^(١).

(١) حيث نصت المادة ٦١ من الدستور الفرنسي على أن "القوانين الأساسية قبل صدورها واللوائح التي تنظم العمل داخل المجالس البرلمانية قبل تطبيقها يجب أن تعرض على المجلس الدستوري ، وبناءً على ذلك إذا قرر المجلس عدم دستوريته، فإنه يترتب عليه عدم الإصدار للقوانين الأساسية ، وعدم التطبيق للوائح التي تنظم العمل داخل المجالس البرلمانية، وكذلك بالنسبة للقوانين العادية إذا تم رفعها قبل إصدارها إلى المجلس الدستوري من قبل المحددين في المادة (٦١) من الدستور فإنه يترتب على القرار الصادر بعدم دستوريته عدم جواز إصدارها، وهذا ما بينته المادة (٦٢) في مستهلها حيث نصت على الآتي :

« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application »

للمزيد راجع :

فبالنسبة للقوانين الأساسية Les lois organiques و القوانين العادية les lois ordinaires إذا تقرر عدم دستوريتهما، فإنه يترتب على هذا القرار عدم جواز إصدارها.

أما بالنسبة للوائح التي تنظم العمل داخل المجالس البرلمانية les règlements des assemblées Parlementaires، يترتب على القرار الصادر بعدم دستوريتهما عدم جواز تطبيقها، وذلك طبقاً لما بينته المادة (٦١) من الدستور الفرنسي الحالي. إلا أن قرارات المجلس الدستوري استقرت في هذا الصدد على التصديق على هذه اللوائح وعدم رفضها^(١)

أما رقابة المجلس الدستوري على الاقتراحات القانونية طبقاً للمادة (١١) من الدستور، فيترتب عليها عدم طرحه على الاستفتاء حتى يتم تعديله بما يتفق مع الدستور.

وأخيراً بالنسبة للمعاهدات والاتفاقات الدولية، فطبقاً لنص المادة (٥٤) من الدستور الفرنسي إذا تبين للمجلس الدستوري عدم توافقها مع الدستور فإنه يترتب على قرار المجلس الدستوري تعديل الدستور نفسه بما يتفق وأحكام المعاهدة^(٢) وبالتالي فإنه لا يترتب على إعلان المجلس الدستوري مخالفة نصوص المعاهدة الدولية للدستور عدم صدورها، وإنما كل ما يحدثه من أثر هو الدعوة لتعديل الدستور بما يتفق وأحكام المعاهدة الدولية، ولذلك نصت المادة (٥٤) من الدستور على أنه "إذا قرر المجلس الدستوري، بناءً على إبلاغ رئيس الجمهورية، أو الوزير الأول أو رئيس أي من المجلسين، أن تعهداً دولياً يتضمن شرطاً مخالفاً للدستور، فلا يمكن الإذن بالتصديق أو الموافقة عليه إلا بعد تعديل الدستور"^(٣).

- Patrick Fraisseix: droit constitutionnel, © Librairie Vuibert - avril 2006, P.280 et suiv.

- والدكتور/ إبراهيم محمد علي : القانون الدستوري، المرجع السابق، ص ١٨٥.

(٢) راجع أستاذنا الدكتور/ عبد العظيم عبد السلام: الرقابة على دستورية القوانين، المرجع السابق، ص ١٤٣.

(2) Voir, Jean-Claude ACQUAVIVA, Droit constitutionnel et institutions politiques, 10e édition, Gualino éditeur, EJA - Paris – 2007, P. 205,206.

(3) - article (54) de la constitution française, « Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante

ومن ثم إذا قرر المجلس الدستوري وجود نص معين بالمعاهدة المعروضة عليه يخالف الدستور، فإنه لا يمكن التصديق على المعاهدة أو إقرارها إلا بعد تعديل الدستور، وذلك لضمان إعطاء المعاهدات الدولية قوة تعادل الدستور^(١).

وقد طبق المجلس الدستوري هذا الأثر بالفعل في أحكام عديدة، نذكر منها حكمه الصادر في ٩ أبريل ١٩٩٢م، وذلك بخصوص الرقابة على معاهدة الاتحاد الأوروبي والمسماه بمستريخت Maastricht^(٢) حيث إنه بعرضها على المجلس الدستوري تبين أن "الالتزامات الدولية التي تحقق الغاية من هذه المعاهدة تتضمن بنوداً مخالفة للدستور أو تنتهك الشروط الأساسية لممارسة السيادة الوطنية، ويدعو التصديق عليها إلى إجراء تعديلاً دستورياً"^(٣) ولقد صدر بناءً على ذلك القانون الدستوري رقم (٩٢-٥٥٤) في ٢٥ يونية ١٩٩٢، بتعديل أحكام الدستور بما يتوافق وأحكام المعاهدة^(٤).

على انه تجب التفرقة بصدد القرار الصادر بعدم دستورية القانون بين حالة عدم الدستورية الكلية وعدم الدستورية الجزئية^(٥) فبالنسبة لعدم الدستورية الكلية للقانون أو عدم دستورية بعض نصوصه مع عدم إمكانية فصلها عن النصوص الأخرى، بأن

sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution ».

(٢) راجع أستاذنا الدكتور/ عبد العظيم عبد السلام: الرقابة على دستورية القوانين، المرجع السابق، ص ١٤٦ وما بعدها.

(٣) للمزيد عن الرقابة على دستورية معاهدة مستريخت راجع :

- Blumann Claude : La ratification par la France du traité de Maastricht, Revue du marché commun et de l'Union européenne, 1994, p. 393.

(3)- CC. Décision n° 92-308 DC du 09 avril 1992, Traité sur l'Union européenne, Publiée au Journal officiel du 11 avril 1992, p. 5354.

(5)- Patrick Fraisseix : DROIT CONSTITUTIONNEL, op.cit P. 302.

« Le Conseil constitutionnel peut déclarer une loi totalement inconstitutionnelle ou partiellement inconstitutionnelle ».

كانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة *non détachables* ، فإنه يترتب على ذلك عدم إمكانية إصدار القانون كله^(١) .

ومن أمثلة القرارات الصادرة من المجلس الدستوري بعدم دستورية بعض النصوص مع عدم قابلية فصلها عن النصوص الأخرى الموافقة للدستور، قراره الصادر في ٣ أبريل ٢٠٠٣ بشأن قانون ١١ نيسان / أبريل ٢٠٠٣ الخاص بتنظيم الانتخابات للمجالس المحلية وأعضاء البرلمان^(٢).

أما بالنسبة لحالة عدم الدستورية الجزئية، فإنه يترتب على القرار الصادر بعدم دستورية نص أو بعض نصوص القانون وكانت غير مرتبطة بباقي نصوص القانون الأخرى الصحيحة، أحد حلين:

الحل الأول: أن يصدر رئيس الجمهورية القانون بدون النصوص الغير دستورية.

الحل الثاني: أن يطلب رئيس الجمهورية من البرلمان إعادة النظر في القانون مرة أخرى مع مراعاة ما انتهى إليه المجلس الدستوري في قراره، وذلك بأن يعدل من النصوص المقضى بعدم دستورتها، وجعلها متوافقة مع الدستور.

المطلب الثاني

الأثر طبقاً للرقابة اللاحقة على صدور القانون^(٣)

Le contrôle a posteriori

كما بينا سابقاً تم تعديل المادة (٦١) من الدستور الفرنسي، وذلك بإضافة المادة (٦١) فقرة (١) بعد المادة (٦١) من الدستور، وذلك بخصوص الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين بخصوص القوانين التي تنتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. فيراقب المجلس الدستوري هنا مدى دستورية مثل هذه القوانين بعد

(1) - Ibid P.302.

(٢)- C.C.Décision n° 2003-468 DC du 03 avril 2003, Publication Journal officiel du 12 avril 2003, p. 6493.

(3) - voir, Philipp Foilard, Droit constitutionnel et institutions politique, éd 2009-2010, P.38.

صدورها ودخولها حيز النفاذ، وينتهى المجلس الدستوري في نهاية رقابته إلى تقرير دستورية القانون ، أو عدم دستوريته.

فإذا قرر دستورية القانون فإنه يظل سارياً وناظراً في الحياة القانونية. ويحكم جميع العلاقات التي تقع في نطاقه. أما إذا قرر عدم دستورية هذا القانون فيثور التساؤل عن أثر القرار الصادر بعدم الدستورية، وزمان سريانه وذلك وفقاً لما يأتي :

أولاً : إلغاء القانون كأثر للقرار الصادر بعدم الدستورية :

يترتب على إعلان عدم دستورية النصوص القانونية طبقاً للرقابة اللاحقة إلغاء تلك النصوص، وذلك طبقاً لما قرره المادة (٦٢) من الدستور المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ٢٣ يوليو ٢٠٠٨ في المادة ٣٠ منه (١).

والإلغاء l'abrogation بوصفه جزءاً لعدم الدستورية يعنى أن القاعدة التشريعية لا تستبعد فقط من التطبيق على المنازعة التي أثيرت فيها المسألة الأولية la question prioritaire، وإنما تستبعد أيضاً من التطبيق على جميع المنازعات أمام القضاء. (٢)

ثانياً : المدى الزمني لسريان إلغاء النصوص غير الدستورية : قررت

المادة (٦٢) من الدستور الفرنسي أن إلغاء النصوص غير الدستورية يسرى اعتباراً من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري بعدم الدستورية، كما من الممكن أن يحدد القرار الصادر من المجلس الدستوري بعدم الدستورية تاريخاً لاحقاً على نشره لنفاذه. ويحدد المجلس الدستوري الشروط والحدود التي يمكن وفقاً لها إعادة النظر في الآثار التي رتبها النص. (٣)

ويستفاد مما تقدم : أن القرار الصادر بعدم الدستورية في هذه الحالة يكون له أثر مباشر، فينتج أثره اعتباراً من تاريخ نشره، كما أنه يجوز للمجلس الدستوري أن

(١)- Article 62 de la constitution française : ...« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée »

(٤) راجع/ محمد عبد اللطيف : رقابة الدستورية اللاحقة في فرنسا، مقاله السابق، ص ٢٤.

(3) - Art 62 (2) « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ».

يقرر له أثراً مستقبلياً، وذلك بتحديد تاريخ لاحق على صدور قرار عدم الدستورية لنفاذه، كما يجوز للمجلس الدستوري أن يعيد النظر في الآثار التي ترتبت في الماضي على النص غير الدستوري، وهذا يعني أنه من الممكن أن يقرر المجلس الدستوري أثراً رجعياً لقراره الصادر بعدم الدستورية وفقاً للشروط والحدود التي يضعها، لعدم الإخلال بالحقوق المكتسبة التي تكون قد ترتبت خلال فترة تطبيق ذلك النص، وهذا يحدده المجلس الدستوري وفقاً لظروف كل حالة على حدة.^(١)

ويتضح مما سبق أن المدى الزمني للقرار الصادر بعدم دستورية نص قانوني يحدده المجلس الدستوري طبقاً لما يأتي :

١- الأثر المباشر لإلغاء النص القانوني غير الدستوري :

ويعني الأثر المباشر للإلغاء هنا : أن القرار الصادر بعدم الدستورية يجعل القانون غير الدستوري غير موجود في الحياة القانونية من تاريخ نفاذ هذا القرار. ومن ثم ينصرف أثره إلى الوقائع التي تحدث بعد صدوره لا قبله.

٢- تحديد أثر مستقبلي لإلغاء النص القانوني غير الدستوري :

وهذا يعني أن يحدد المجلس الدستوري وقت لاحق على صدور قراره بعدم الدستورية يبدأ منه إلغاء النص القانوني غير الدستوري، فإذا افترضنا أن القرار الصادر بعدم الدستورية أصدره المجلس الدستوري في ١ يناير ٢٠١٤ ، فيقرر مثلاً في ذات الحكم أن آثاره تبدأ من ١ مايو ٢٠١٤ ، أي بعد أربعة أشهر من صدور الحكم.

٣- إعادة النظر في الآثار التي ترتبت في الماضي على النص القانوني غير

الدستوري :

في هذه الحالة يستطيع المجلس الدستوري أن يقرر لإلغاء النص القانوني غير الدستوري أثر رجعي، لكنه يعيد النظر في الآثار التي ترتبت في الماضي على النص غير الدستوري، فيضع الشروط التي بمقتضاها يتم تطبيق آثار إلغاء النص القانوني على الماضي، وذلك وفقاً لكل حالة على حدة.

(١) راجع في نفس المعنى/ الدكتور محمد عبد اللطيف، رقابة الدستورية اللاحقة في فرنسا، مقاله سابق الإشارة إليه، ص ٢٤.

المبحث الثاني

أثر القرار الصادر بعدم الدستورية على القانون

غير الدستوري في أمريكا

لبيان أثر القرار الصادر بعدم الدستورية على القانون غير الدستوري في أمريكا، ينبغي أن نبين تحديد هذا الأثر، ثم نبين المدى الزمني لهذا الأثر، وذلك في مطلبين على النحو التالي:

المطلب الأول

تحديد أثر القرار الصادر بعدم الدستورية على القانون غير الدستوري

وإذا أصدرت المحكمة العليا حكمها بعدم دستورية قانون معين أو نص فيه، فإن هذا الحكم لا يلغى هذا القانون أو النص غير الدستوري ولا يبطله، ولكن كل ما ينتج من أثر على النص المخالف للدستور أن يمتنع القضاء عن تطبيقه على النزاع المعروض أمامه. فكل ما تفعله المحكمة أنها تقرر ما إذا كان القانون المعروض عليها موافق للدستور أم لا^(١).

وجاءت عبارات المحكمة العليا الأمريكية واضحة في ذلك، حيث قالت: "يجب ألا يساء فهم مهمة المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين، إذ كثيراً ما يقال: أن المحكمة تبطل القوانين المخالفة للدستور وهو قول غير صحيح إذ كل ما تفعله أنها تضع النص الدستوري إلى جوار النص القانوني المطعون فيه لتحديد حقيقة ما بينهما من توافق أو تعارض، فإذا فصلت في هذه المشكلة ورتبت عليها نتائجها في خصوص الدعوى المعروضة أمامها فقد انتهت مهمتها بالنسبة للقانون"^(٢).

(1) United States v. Butler, op.cit.

"All that the court does or can do in such cases is to announce its considered judgment upon the question; it can neither approve nor condemn any legislative policy; it can merely ascertain and declare whether the legislation is in accordance with, or in contravention of, the provisions of the Constitution".

(٢) راجع في ذلك المستشار الدكتور/ إبراهيم محمد حسنين: الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الفقه والقضاء - منشأة المعارف، الإسكندرية، ٢٠٠٠م - ص ٢٧٤، ٢٧٥، وراجع أيضاً الدكتور/ أحمد أبو المجد: رسالته السابقة، ص ٢٢١..

ويقرر الأستاذ الدكتور رمزي الشاعر بأن المحكمة في هذه الحالة لا تقضى ببطلان التشريع أو إلغائه، وإنما يقف سلطانها عند إهمال القاضي لحكم القانون غير الدستوري والامتناع عن تطبيقه في القضية المعروضة؛ ولذلك فإن حكم المحكمة هنا ذو حجية نسبية مقصورة على أطراف النزاع القائم ولا يقيد المحاكم الأخرى التي يكون لها أن تأخذ بالتشريع ذاته إذا رأت أنه لا يخالف الدستور، وبالتالي فليس من شأن هذا الحكم أن يحول دون استمرار القانون أو إعمال حكمه في الأحوال التي يتسنى فيها ذلك.^(١)

وهذا يعني أن القانون المخالف للدستور لا يزال موجوداً فعلاً رغم الحكم بعدم دستوريته. ولمراعاة هذا الوجود الفعلي للقانون واستقرار المعاملات تم الاكتفاء بترتيب هذه الآثار في مواجهة الخصوم وحدهم، ومع هذا يلاحظ أن الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور على موضوع النزاع له أثر رجعي بالنسبة للخصوم، فيعتبر كأن لم يكن في الحقيقة لعدم إمكانية الاستفادة منه وعدم تطبيق القضاء له.^(٢)

فرقابة الامتناع المطبقة في النظام الأمريكي شديدة الأثر والمفعول حتى يمكن القول بأنها تقترب من رقابة الإلغاء في ظل نظام السوابق القضائية، وبالذات في حالة صدور حكم بعدم الدستورية من المحكمة العليا بشأن قانون ما، إذ تنقيد سائر المحاكم كلها بهذا الحكم ويصبح أمراً مفروضاً عليها يجب أن تنقيد وتلتزم به.^(٣)

ويقرر أستاذنا الدكتور عبد العظيم عبد السلام بأن : قضاء الامتناع وإن كان يقترب من قضاء الإلغاء، إلا أنه ليس قضاء إلغاء، والدليل على ذلك عدم إلغاء القانون المحكوم بعدم دستوريته من الناحية الشكلية، وأيضاً عدول المحكمة العليا في كثير من الحالات وتحت وطأة الظروف على نقض قضاءها السابق.^(٤)

(٣) راجع الدكتور/ رمزي الشاعر: النظرية العامة للقانون الدستوري، ٢٠٠٥م، المرجع السابق، ص ٧٠٩ وما بعدها.

(١) راجع الدكتور/ صبرى محمد السنوسى محمد : آثار الحكم بعدم الدستورية -دراسة مقارنة- دار النهضة العربية ٢٠٠٠ - ص ٩٦.

(٢) راجع الدكتور/ محمد إبراهيم درويش ، والدكتور/ إبراهيم محمد درويش : القانون الدستوري - المرجع السابق - ص ٢٧٦، والدكتور/ رمزي الشاعر: النظرية العامة للقانون الدستوري، المرجع السابق، ص ٧١١.

(٣) راجع أستاذنا الدكتور/ عبد العظيم عبد السلام : الرقابة على دستورية القوانين، المرجع السابق، ص ٥٣.

نخلص مما تقدم : أن أثر الحكم الصادر بعدم الدستورية على القانون غير الدستوري في الولايات المتحدة الأمريكية يتمثل امتناع القاضى عن تطبيق القانون غير الدستوري، ولا يمثل هذا الامتناع إلغاءً لهذا القانون وإن كان يقترب منه.

المطلب الثاني

المدى الزمني لأثر الحكم الصادر بعدم الدستورية

يأخذ النظام القانوني الأمريكي بفكرة الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين ، والتي تمارس بعد صدور القانون ودخوله حيز النفاذ وتطبيقه في الواقع العملي في أغلب الأحوال، وهذا ما يدعونا أن نتساءل عن إذا ما صدر الحكم بعدم الدستورية، فهل يكون له أثر رجعي، وبالتالي يمس المراكز التي تكونت بموجب القانون الذي حُكم بعدم دستوريته منذ صدوره، أو أن له أثراً مباشراً وبالتالي فلا ينفذ الحكم الصادر بعدم الدستورية إلا منذ صدوره وبالنسبة للمستقبل فقط، أما ما قبل صدور هذا الحكم في الماضي، فإن القانون يكون موجوداً ومرتباً لأثاره ؟

بداية فإن الدستور الأمريكي الفيدرالي لم يتضمن نصاً حاسماً بشأن سريان الأحكام الصادرة بعدم الدستورية بأثر رجعي، أو حتى سريانها بأثر فوري ومستقبلي، مما حدا بال بعض أن يقول : أن للمحكمة أن تختار بين الأثر الرجعي والأثر المباشر والمستقبلي وفقاً لظرف كل قضية على حده.^(١) وبصفة خاصة أن مبدأ السوابق القضائية Principle of stare decisis المطبق في النظام الأمريكي يسمح بالعدول عن السوابق القضائية التي لم تعد تواكب التطورات، والأوضاع التي استجدت في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يسمح للقانون بالتطور، ويسمح للمحكمة بعدم الالتزام بالقواعد العتيقة.^(٢)

ومن المقرر - كما سبق القول - بناء على موقف الفقه والقضاء الأمريكي أن الحكم بعدم الدستورية لا يبطل القانون ولا يلغيه، ولا ينشئ حالة قانونية جديدة متصلة به، وإنما يكشف عن حقيقة العمل التشريعي المعروض على المحكمة، ويقف

(١) راجع الدكتور/ محمود أحمد زكي : الحكم الصادر في الدعوى الدستورية - رسالته السابقة، ص ٢٦٢.
(٢) راجع الدكتور/ محمود أحمد زكي : رسالته السابقة - ص ٢٨٢، والدكتور/ محمد إبراهيم درويش ، والدكتور / إبراهيم محمد درويش: القانون الدستوري، الطبعة الأولى ٢٠٠٧م، دار النهضة العربية، ص ٢١٤ وما بعدها.

سلطان المحكمة عند إهمال القاضى لحكم القانون غير الدستورى والامتناع عن تطبيقه فى القضية المعروضة.(١)

ورغم هذا الغموض فى تحديد سريان أحكام المحكمة العليا من حيث الزمان، إلا أن المحكمة العليا ذهبت إلى تقرير الأثر الرجعى للحكم الصادر منها بعدم الدستورية فى الكثير من أحكامها. ومن أهم الأحكام التى قررت المحكمة العليا بصددها فكرة الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية حكمها فى قضية "شكتر ضد الولايات المتحدة" الصادر فى عام ١٩٣٥، والذى قررت فيه براءة المتهمين استناداً إلى عدم دستورية قانون الإصلاح الصناعى، وما يترتب على ذلك من سقوط التنظيم اللائحى الصادر فى ظله.(٢)

كما ذهبت المحكمة العليا أيضاً فى حكمها فى قضية « Norton V. Shelby » الصادر فى عام (١٨٨٦) إلى أن "التشريع المخالف للدستور ليس فى الحقيقة قانوناً على الإطلاق فهو لا ينشأ حقاً، ولا يرتب واجبات، ولا يمنح حماية ، ولا ينشئ وظيفة، وهو من الناحية القانونية منعدم تماماً وكأنه لم يصدر أصلاً".(٣)

وما أكدته المحكمة العليا من تقرير الأثر الرجعى للحكم الصادر منها بعدم الدستورية أيده الفقه الدستورى فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقرر سريان الحكم بعدم الدستورية بأثر رجعى.(٤) وذلك على أساس عدم اعتبار القانون المخالف للدستور قانوناً بالمدلول الفنى لهذا الاصطلاح إذ يشترط حتى تكتسب الأعمال التشريعية صفة القانون أن تكون صادرة فى الحدود التى رسمها لها الدستور من

(٣) راجع الدكتور/ رمزى طه الشاعر : النظرية العامة للقانون الدستورى - الطبعة الخامسة ٢٠٠٥ - دار النهضة العربية - ص ٧٠٩ وما بعدها، وراجع أستاذنا الدكتور/ عبد العظيم عبد السلام : الرقابة على دستورية القوانين، المرجع السابق، ص ٥٣.

(2) - Schechter Poultry Corp. v. United States, 295 US 495 (1935)

(3) - Norton V. Shelby Country, 118 U.S. 425 (1886).

4(- Voir : LAMBERT Jacques, op.cit, P. 1 et suiv.

وراجع أيضا الدكتور/ عادل عمر شريف : المرجع السابق - ص ٣١٢.

ناحية الشكل والموضوع جميعاً^(١) هذا بالإضافة إلى تأسيس الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية على القاعدة التى تقضى بأن الأحكام كاشفة وليست منشئة^(٢) ومما تجدر الإشارة إليه أن قاعدة الأثر الرجعى لا تطبق على المحكوم عليه وفقاً لقانون أثرت مشكلة دستوريته فى الدعوى وانتهت المحكمة إلى توافقه مع الدستور، ثم عادت بعد ذلك فقررت عدم دستوريته، والوسيلة الوحيدة التى يستطيع فيها المحكوم عليه أن يستفيد من الحكم الجديد هى التماس العفو من رئيس الجمهورية^(٣).

إلا أن قاعدة الأثر الرجعى لأحكام المحكمة العليا الأمريكية لم تأخذ بها المحكمة فى جميع أحكامها، حيث إنه فى عهد محكمة « Warren » لم تصدر أحكامها متضمنة آثاراً رجعية، وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة العليا ببطلان الطلاق القانونى، ولكنها رفضت تطبيق هذا الحكم بأثر رجعى لكى لا يؤثر على حالات الطلاق التى سبقت تاريخ هذا الحكم^(٤).

ولقد أخذت المحكمة العليا بالأثر الفورى لأحكامها فى قضية « Chveron V. Huson » فى عام ١٩٧١، وقررت أن عدم سريان الأحكام بأثر رجعى يرجع إلى ثلاثة أسباب^(٥) :

الأول : إن القرار الذى لا يطبق بأثر رجعى يكون قراراً مؤكداً لمبدأ قانونى جديد.

(٤) راجع الدكتور/ محمد صلاح عبد البديع : المرجع السابق - ص ١٧ ، ١٨ ، والدكتور/ أحمد كمال أبو المجد : رسالته السابقة - ص ٢٢٢ ، والدكتور/ عبد العزيز محمد سالم : نظم الرقابة على دستورية القوانين - دراسة مقارنة بين مختلف النظم القانونية والقانون المصرى - بحث ضمن أبحاث المؤتمر العلمى الأول - كلية الحقوق جامعة حلوان - ١٩٩٨ م، ص ٩٩٩ وما بعدها.

(١) راجع الدكتور/ أحمد فتحى سرور : الحماية الدستورية للحقوق والحريات - دار الشروق - ص ٣٠٦.

(١) راجع الدكتور/ أحمد كمال أبو المجد : رسالته السابقة - ص ٢٢٤ هامش رقم ٣.

(4) - Bingham V. Miller, 17 Ohio 445, 448 (1848).

راجع فى ذلك الدكتور/ محمود أحمد زكى : رسالته السابقة : ص ٢٦١ : ٢٦٣.

(5) (CHEVRON OIL CO . V . HUSON , [404U.S.97](https://www.courtney.com/cases/404U.S.97) (1971).

الثاني : يجب الأخذ في الاعتبار المزايا والعيوب في كل قضية على حده، والنظر إلى التاريخ السابق للحكم محل الدعوى، والغرض من تقرير الأثر الرجعي، وما إذا كان إعمال هذا الأثر سيدعم القرار أم أنه سيعوق تفعيل دور القانون.

الثالث : إن إعمال الأثر الرجعي قد يؤدي إلى نتائج ظالمة بحق من اعتمدوا على وجود القانون قبل تقرير عدم دستوريته.

وإذا كانت المحكمة العليا في بعض الفترات قررت لأحكامها أثراً مباشراً، إلا أنها فترات قليلة لا ترقى لأن ترسي الأثر المباشر كقاعدة عامة مطردة لأثر أحكامها من حيث الزمان، مما يصح القول معه أن الأثر الرجعي لأحكام المحكمة العليا بعدم الدستورية هو القاعدة العامة. إلا أن للمحكمة العليا الحق في أن تقرر لأحكامها أثراً مباشراً أو مستقبلياً على حسب ظروف كل قضية.^(١)

وعلى الرغم من إقرار الفقه والقضاء لفكرة الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية الصادر من المحكمة العليا، إلا أن إعمال هذه الفكرة ليس على الإطلاق، بل ترد عليها بعض الحدود التي تقتضي الحد من فكرة الأثر الرجعي لحكم المحكمة العليا بعدم الدستورية.

فإعمال قاعدة الأثر الرجعي على إطلاقها يؤدي إلى العديد من الإشكالات القانونية، إذ لا يخفى أن القضاء على كافة الحقوق والواجبات الناشئة في ظل القانون قبل القضاء بعدم دستوريته قد يكون له من الأضرار المادية والمعنوية أضعاف ما قد يؤدي إليه بقاء القانون المخالف للدستور، وخصوصاً وأن دستورية القانون قد لا تثار أمام القضاء إلا بعد سنوات طويلة من دخوله حيز النفاذ وترتيب الأفراد والمؤسسات أوضاعهم على أساسه، ولذلك قد سلم الفقه والقضاء بضرورة تقييد قاعدة الأثر الرجعي مراعاةً للوجود الفعلي للقانون قبل القضاء بعدم دستوريته.^(٢)

(٤) راجع الدكتور/ محمود أحمد زكي : رسالته السابقة- ص ٢٦٧. وراجع حكم المحكمة العليا التالي :
- ANDERSON V. TOWNSHIP OF SANTA ANNA, DE WITT COUNTY, 116 U.S.
356 (1886). <http://supreme.vlex.com/source/us-supreme-court-1101>

(٢) راجع الدكتور/ أحمد كمال أبو المجد : الرقابة على دستورية القوانين - رسالته السابقة - ص ٢٢٣، وفي هذا المعنى راجع أيضاً :

The Supreme Court: justice and the law, 3rd, ed washington, D.C.
congressional Quarterly Inc. 1983, P; 159-164.

مشار إليه في رسالة الدكتور/ محمود أحمد زكي : ص ٢٢٥.

لذلك يرى البعض بأن : أثر الحكم بعدم الدستورية يجب أن يكون له حدود، ذلك أن الوجود الواقعي للقانون قبل هذا التحديد أمر عملي واقعي ويمكن أن تكون له نتائج لا يمكن تجاهلها، فالماضي لا يمكن أن يحجب بإعلان أحكام جديدة ، كما أن المسائل الخاصة بحقوق ثبتت وفقاً لقانون سابق وجوده تستحق أن يكون لها ثباتها، وأن يتصرف وفقاً لها في السياسة العامة على ضوء هذه المسائل.(١)

واستناداً إلى كل ما سبق : اعترف الفقه في أمريكا ومصر، وقضاء المحكمة العليا الأمريكية بأنه يجب أن توضع قيود لتحديد فكرة الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية، لذلك بينت المحكمة العليا في حكم لها في عام ١٩٤٠ قال فيه القاضي هيوز : " إن الوجود المادي للقانون قبل صدور الحكم بعدم الدستورية أمر واقعي، كما أنه قد يكون أنتج آثاراً لا يمكن تجاهلها، فليس من الحكمة في كثير من الأحوال أن تسدل المحكمة على الماضي ستاراً من النسيان ولذلك يجب أن يعاد النظر في أثر القضاء بعدم دستورية القانون على كثير من الأوضاع والعلاقات التي نشأت في ظلّه".(٢)

وقد لجأ القضاء الأمريكي في سبيل الاعتراف بالآثار القانونية المترتبة على الوجود المادي للقانون قبل القضاء بعدم دستوريته إلى وسائل شبيهة بالنظريات المعروفة في القانون الإداري، حيث استند لتصحيح نشاط الموظفين والهيئات الإدارية التي أقيمت بمقتضى القانون محل الطعن إلى نظرية الموظف الفعلي، وهذا ما قضت به المحكمة العليا في قضية ولاية أهايو ضد جاردنهام سنة ١٨٩٦، حيث استند إلى

(٣) راجع الدكتور/ عزيزة حامد الشريف : أثر الحكم بعدم الدستورية على التشريعات المخالفة، بحث ضمن أبحاث المؤتمر العلمي الأول لكلية الحقوق جامعة حلوان سنة ١٩٩٨م-ص١٩٣، وراجع أيضاً الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان : نظم الرقابة على دستورية القوانين -دراسة مقارنة - سابق الإشارة إليه - ص٩٩٩.

(2) - Chicot County Drainage District V. Baxter State Bank, 380 U.S 371-374 (1940)

"the actual existence of a statute prior to have a determination is an operative fact and my have consequences which cannot justly be ignored. The past cannot always b erased by a new judicial declaration"

نظرية الموظف الفعلى مشيرة إلى الآثار الخطيرة التى تترتب إلى تجاهلها عند تحديد الآثار القانونية للأعمال التى تمت فى ظل قانون غير دستورى.^(١)

وبالإضافة إلى نظرية الموظف الفعلى نجد أن المحكمة العليا الأمريكية قد لجأت أيضاً إلى الأخذ فى الاعتبار حسن نية ذوى الشأن وضرورة مراعاة جانبهم.^(٢)

ومما تجدر الإشارة إليه أنه مراعاةً للوجود الفعلى للقانون، واستقرار المعاملات يتم الاكتفاء بترتيب آثار الحكم بعدم الدستورية فى مواجهة الخصوم وحدهم، ومع هذا يلاحظ أن الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور على موضوع النزاع له أثر رجعى بالنسبة للخصوم فيعتبر كأن لم يكن فى الحقيقة لعدم إمكانية الاستفادة منه، وعدم تطبيق القضاء له.^(٣)

المبحث الثالث

أثر القرار الصادر بعدم الدستورية على القانون غير الدستورى فى مصر

إذا أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بنقض دستورى القانون المطعون عليه بعدم الدستورية، فإن هذا القانون يتأكد دستوريته، وبالتالي فإنه يطبق على النزاع المطروح أمام محكمة الموضوع، وعلى غيره مما يستجد من منازعات يحكمها هذا القانون.

(1) - WAGNER (W.J) : le contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois aux États-Unis d'Amérique, Annales de la faculté de droit et de science politique (Clermont-Ferrand), 1977, vol, 14, P. 3٤7- 3٧8.

راجع فى ذلك الدكتور / أحمد كمال أبو المجد : رسالته السابقة - ص ٢٢٤ هامش ٣ ، والدكتور / مصطفى محمود عفيفى : رقابة الدستورية فى مصر والدول الأجنبية- ص ١١٣ ، والدكتور / طعيمة الجرف : رقابة الدستورية دراسة مقارنة - ١٩٩٣م- بدون دار نشر، ص ١٨٧، والدكتور / بشير على باز : المرجع السابق - ص ٤١، والدكتور / شعبان رمضان : ضوابط وآثار الرقابة على دستورية القوانين "دراسة مقارنة" رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة أسيوط ٢٠٠٠م- ص ٦٢٠ : ٦٢٤.

(2) - S. V. Realty co 1136 U.S. 427.

مشار إليها فى مؤلف الدكتور / أحمد كمال أبو المجد : رسالته السابقة ص ٢٢٤، والدكتورة / عزيزة الشريف : المقال السابق - ص ١٩٧.

(١) راجع الدكتور / صبرى السنوسى: المرجع السابق ص ٩٦.

أما إذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص قانوني أو لائحي، فينبغي أن نحدد أولاً أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، ثم نبين المدى الزمني لهذا الأثر، وذلك على النحو التالي :

المطلب الأول

وقف نفاذ النص القانوني كأثر للحكم الصادر بعدم الدستورية

نصت المادة (٤٩) في فقرتها الثالثة من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه "يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم..".

ويتضح من هذا النص أن أثر الحكم بعدم الدستورية على القانون غير الدستوري يتمثل في وقف أو إلغاء نفاذ هذا القانون فيفقد قوته الإلزامية، فالنص من الناحية النظرية قائماً إلي أن تقوم بإلغائه السلطة التشريعية، وليس من سلطة المحكمة الدستورية إلغاؤه^(١)، ولكن من ناحية أخرى يتشابه هذا الأثر من الناحية العملية مع إلغاء النص التشريعي غير الدستوري^(٢)

ولقد أكدت المحكمة الدستورية العليا هذا الأثر في العديد من أحكامها، ومن أحكامها في هذا الشأن ما قضت به في حكمها الصادر في ٦ فبراير ١٩٨٢ من أن : "الرقابة القضائية على دستورية القوانين التي اختصت بها المحكمة العليا دون غيرها هي رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه"^(٣).

وقضت أيضاً في حكمها الصادر في ١٩ يونيو ١٩٩٣ بأن : "قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن موافقة النصوص التشريعية المطعون عليها لأحكام الدستور أو مخالفتها، إما ان يكون كاشفاً عن صحتها منذ صدورهما، أو مقررراً بطلانها وملغياً قوة نفاذها اعتباراً من تاريخ العمل بها"^(٤).

(١) راجع الدكتور/ محمد عبد الواحد الجميلي: آثار الحكم الصادر بعدم الدستورية، دار النهضة العربية ٢٠٠٢م، ص ٤٧ وما بعدها، والدكتور/ إبراهيم محمد علي : القانون الدستوري، المرجع السابق، ص ٢٣١.

(٢) راجع الدكتور/ محمد جمال جبريل عثمان : أثر الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، ص ١٩، ٢٠. (٣) راجع/ حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٣٩ لسنة ٢ قضائية في ٦ فبراير ١٩٨٢م "دستورية"، وحكمها في القضية رقم ١٣٦ لسنة ٥ قضائية بتاريخ ١٧ مارس سنة ١٩٨٤م، "دستورية".

(٤) راجع/ حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٧ لسنة ١٤ قضائية "منازعة تنفيذ" بتاريخ ١٩ يونيو سنة ١٩٩٣ م.

وقالت أيضاً في حكمها الصادر في ٩ سبتمبر ٢٠٠٠ : "وحيث إنه من المقرر أن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً عما به من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به" (١).

وجاء في حكم لها أيضاً صادر في ٩ مايو ٢٠٠٤ بأنه : " لما كان الأصل في النصوص القانونية ، المدعى مخالفتها للدستور ، أن تُحْمَل على أصل صحتها ، فلا يعطل الطعن عليها قوة نفاذها ، ولا يجوز بالتالي وقف تنفيذها ، وإنما تظل قوة نفاذها ملازمة لها كلما طرح أمر مشروعيتها الدستورية على المحكمة الدستورية العليا وفقاً لقانونها ؛ وهو الاختصاص الذي لا تزاحمها فيه أية جهة أخرى . وللمحكمة ، بعد ذلك ، إما أن تقرر أن للنصوص المطعون عليها سنداً من الدستور فلا ترتد عنها قوة نفاذها ، وإما أن تنتهي إلى مصادمتها للدستور فتعدها وتنتهي وجودها" (٢).

وتأسياً علي ما سبق : فإن أثر الحكم الصادر بعدم الدستورية من المحكمة الدستورية العليا يتمثل في إلغاء قوة نفاذ القانون الغير دستوري، وهذا لا يعد من الناحية النظرية إلغاء لهذا القانون وإن كان يعد كذلك من الناحية العملية.

المطلب الثاني

المدى الرمي لسريان الحكم بعدم الدستورية

قبل تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (٤٨) لسنة ١٩٧٩م كان إلغاء النص المحكوم بعدم دستوريته يسري بأثر رجعي كقاعدة عامة، ولا يستثنى من ذلك إلا النصوص الجنائية فيكون أثر مباشر، أما بعد تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بالقرار بقانون رقم (١٦٨) لسنة ١٩٩٨ بشأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة (٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (٤٨) لسنة ١٩٧٩، والتي تبين الآثار المترتبة علي الحكم بعدم الدستورية، للحد من الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية، ونص هذا القرار بقانون علي الآتي:

(١) راجع/ حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 20 قضائية " طلبات أعضاء " بتاريخ ٩ سبتمبر سنة ٢٠٠٠م.

(٢) راجع/ حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم لسنة 24 قضائية " دستورية " بتاريخ ٩ مايو سنة ٢٠٠٤ م، وحكمها في القضية رقم 219 لسنة 23 قضائية " دستورية " ١٣ أبريل سنة ٢٠٠٣م.

" ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص "(١).

ولبيان المدى الزمني للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا وفقاً لما هو مقرر بعد تعديل ١٩٩٨م، ينبغي أن نبين أولاً القاعدة العامة في سريان الحكم الصادر بعدم الدستورية من حيث الزمان هي الأثر الرجعي مطلقاً، ثم نبين ثانياً الاستثناءات الواردة على هذه القاعدة والتي تتمثل في ثلاثة استثناءات، بعبارة نص الفقرة الثالثة من المادة (٤٩) المعدلة، وما قررته المذكرة الإيضاحية، ومن ثم سوف نعرض هذه القاعدة والاستثناءات الواردة عليها على النحو التالي :

أولاً: القاعدة العامة: الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية :

التعديل الذي جاء به القرار بقانون رقم (١٦٨) لسنة ١٩٩٨ بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا، لم يخرج عن قاعدة الأثر الرجعي التي تحكم تنفيذ الحكم بعدم الدستورية، والتي استقرت عليها أحكام القضاء وقررتها آراء الفقهاء قبل التعديل، وما جاء به التعديل إلا إضافة لبعض الاستثناءات المقررة على قاعدة الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية، وتغليباً لاعتبارات مبدأ الأمن القانوني على اعتبارات المشروعية الدستورية.

وما يؤكد أن القاعدة العامة هي الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية بعد التعديل،

الحجج التالية :

١- لما كان الحكم بعدم الدستورية يعد كاشفاً عن عدم دستورية القانون منذ صدوره وليس منشأً لها، فكان من المنطقي أن تكون القاعدة العامة هي الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية، كما أن القول بالأثر المباشر للحكم بعدم الدستورية يفقد الرقابة على دستورية القوانين فاعليتها(٢).

(١) صدر القانون في ١٠ / ٧ / ١٩٩٨م، وتم نشره في الجريدة الرسمية في العدد ٢٨ مكرر والصادر بتاريخ ١١ / ٧ / ١٩٩٨م.

(٢) راجع الدكتور/ عاطف البنا: دراسة حول المشروعية الدستورية وأساس سلطة الحكم، مقال منشور بجريدة الوفد في ١٦ يوليو ١٩٩٨م.

٢- إن جعل القاعدة العامة هي الأثر المباشر للحكم بعدم الدستورية يؤدي إلى آثار خطيرة ونتائج وآثار سلبية يصعب تجنبها^(١)، حيث يؤدي هذا إلى إسراف السلطة التشريعية في إصدار تشريعات غير دستورية ما دام أنه لم تقرر عدم دستورتها إلا بالنسبة للمستقبل فحسب، وهذا يمثل اعتداءً على الحقوق والحريات. كما أن القول بالأثر المباشر للحكم بعدم الدستورية يولد أوضاعاً شاذة وغير منطقية تتمثل في اعتبار التشريع دستورياً في فترة من الفترات وغير دستوري في فترة أخرى بعد صدور الحكم بعدم الدستورية^(٢).

٣- كما أن المذكرة الإيضاحية قبل التعديل كانت تقرر بأن عبارة " ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم " تعني أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعي كقاعدة عامة، وهذه العبارة قد أبقى عليها التعديل كما هي مما يدل على أن التعديل لم يعدل عن فكرة الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية، وإنما قرر على قاعدة الأثر الرجعي بعض الاستثناءات، منها ما هو جوازي للمحكمة بأن تحدد تاريخاً آخر غير رجعي للحكم بعدم الدستورية في غير النصوص الضريبية، ومنها ما هو إجباري مقرر بقوة القانون، وهو الأثر المباشر للحكم بعدم دستورية النصوص الضريبية.

٤- إن القول بالأثر المباشر لا يحقق التوازن بين مبدأ المشروعية الدستورية ومبدأ استقرار المراكز القانونية، وذلك لما يترتب على الأثر المباشر من تحصين المركز الذي استند إلى النص غير الدستوري، ويهمل مراكز قانونية مستمدة من الدستور بما يخالف مبدأ تدرج القواعد القانونية، أما القول بالأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية وفرض بعض القيود عليه يحقق التوازن بين متطلبات الشرعية الدستورية التي تقضي بزوال النصوص غير الدستورية منذ صدورها، وبين مبدأ الاستقرار

(١) راجع الدكتور/ أحمد كمال أبو المجد: مستقبل القضاء الدستوري في مصر، مقال منشور بجريدة الأهرام بتاريخ ١٩ أغسطس ١٩٩٨م.

(٢) راجع/ المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة: القانون الجديد إنهاء لدور المحكمة - التعديل يهدد الضمانات الحقيقية للمتهمين الجنائيين والسياسيين- مقال منشور في جريدة الوفد بتاريخ ١٤ يوليو ١٩٩٨.

القانوني الذي يقضي بالحفاظ على الحقوق والمراكز التي ترتبت واستقرت بناءً على النصوص غير الدستورية قبل صدور حكم عدم الدستورية^(١).

ثانياً: الاستثناءات الواردة على قاعدة الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية:
يستثني من قاعدة الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية بعد تعديل المادة (٤٩) في فقرتها الثالثة ثلاثة استثناءات :

الاستثناء الأول : تخويل المحكمة الدستورية العليا تحديد تاريخاً آخر لسريان حكمها بعدم الدستورية في غير المواد الضريبية :

ومفاد هذا الاستثناء أنه يجوز للمحكمة أن تخرج على قاعدة الأثر الرجعي المطلق للحكم بعدم الدستورية بخصوص النصوص غير الضريبية، وتحدد لسريان الحكم بعدم الدستورية أثراً مباشراً، بأن تقرر تنفيذ الحكم بعدم الدستورية بالنسبة للمستقبل فقط. أو تقرر له أثراً مستقبلياً، بأن توقف المحكمة تنفيذه لفترة معينة ثم يبدأ سريانه بعد مضي هذه الفترة^(٢).

وقد يكون التاريخ الآخر الذي تحدده المحكمة لسريان حكمها بعدم الدستورية بالانتقاص من الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية، بحيث يسري الحكم بعدم الدستورية على بعض الفترات التي طبق فيها القانون غير الدستوري دون الأخرى.

الاستثناء الثاني : تقرير أثر مباشر للحكم بعدم دستورية نص ضريبي :
وهذا الاستثناء أيضاً قد قرره التعديل، ومفاده أنه بالنسبة للأحكام الصادرة بعدم دستورية النصوص الضريبية لا يكون لها أثر رجعي بل أثر مباشر في جميع الأحوال، وذلك استثناءً من قاعدة الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية، لكن هذا الاستثناء على خلاف الاستثناء السابق مقرر بقوة القانون ولا يجوز للمحكمة أن تقرر غير الأثر المباشر لأحكامها الصادرة بعدم دستورية النصوص الضريبية.

ولقد لاقى هذا الاستثناء انتقادات كثيرة من جانب الفقه، حيث إن هذا الاستثناء يعطي تصريح للدولة بأن تصدر تشريعات ضريبية على خلاف الشرعية الدستورية

(١) راجع في ذلك الدكتور/ أحمد المواقى: حول تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بالقرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨م، بدون دار نشر أو تاريخ نشر، ص ٥٥.

(٢) راجع الدكتور/ أحمد المواقى: المرجع السابق، ص ١٢؛ والدكتور/ عبد الله ناصف: المرجع السابق، ص ٦١. ومن الفقه المؤيد لهذا التفسير: الدكتور/ محمد صلاح عبد البديع: المرجع السابق، ص ١١٠.

غير مبالية في ذلك، لأنها علي علم مسبق بأن هذه التشريعات عند الحكم بعدم دستوريته لا يترتب عليها أي إرهاب لخزانتها.

لكن بعد أن قرر التعديل الاستثناء القاضي بالأثر المباشر المطلق للحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي، قرر من جهة أخرى أن المدعي في الدعوي الدستورية يستفيد من الحكم الصادر بعدم دستورية النص الضريبي، وهذا يعد استثناءً علي الاستثناء، بما مفاده الرجوع إلي القاعدة العامة التي تقضي بالأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية.

الاستثناء الثالث: الحقوق والمراكز التي استقرت بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي، أو بمضي مدة التقادم :

وهذا الاستثناء قرره المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم (٤٨) الصادر سنة ١٩٧٩، ومفاد هذا الاستثناء أن الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضي، أو بمضي مدة التقادم، لا يسري الحكم بعدم الدستورية قبلها إلا بأثر مباشر ولا تطبق بصدها قاعدة الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية.

ولما كانت الفقرة الرابعة من المادة (٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا لم يتناولها التعديل، وبالتالي يبقى حكمها كما هو، ولقد قررت هذه الفقرة استثناءً علي هذا الاستثناء معناه الرجوع إلي الأصل، أي الرجوع إلي القاعدة العامة التي تحكم تنفيذ الحكم بعدم الدستورية وهي الأثر الرجعي.

وهذه الفقرة تقرر أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة والتي استندت في ذلك إلي النص الجنائي الذي تقرر عدم دستوريته، يسري عليها الأصل العام في تنفيذ الحكم بعدم الدستورية وهو الأثر الرجعي، وتستثنى من تطبيق الأثر المباشر المقرر في الاستثناء الذي يقرر عدم المساس بالحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضي.

وخلاصة القول : إن التعديل الذي أتي به القرار بقانون رقم (١٦٨) لسنة ١٩٩٨ للفقرة الثالثة من قانون المحكمة الدستورية العليا لم يحدث أي تغير بخصوص القاعدة المستقرة لتنفيذ الحكم بعدم الدستورية، والتي تتمثل في الأثر الرجعي، وكل ما أتي به

التعديل هو الزيادة في الاستثناءات التي المقررة علي هذه القاعدة، فالمفهوم الصحيح لهذا التعديل يتمثل في أن القاعدة العامة هي الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية، واستثناءً من ذلك يخول للمحكمة تحديد تاريخ آخر لتنفيذ الحكم بعدم الدستورية، وكذلك تقرير الأثر المباشر للحكم بعدم دستورية نص ضريبي، وأخيراً الأثر المباشر للحكم بعدم الدستورية بخصوص الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بمضى مدة التقادم.